

teoria & direito público

TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Robert Alexy

Este é, sem dúvida alguma, um clássico da teoria constitucional alemã
(NEIL MACCORMICK, University of Edinburgh)

A Teoria dos Direitos Fundamentais, de ROBERT ALEXY, é provavelmente a mais importante e influente obra de teoria constitucional escrita nos últimos cinquenta anos (ALEC STONE SWEET, Yale University)

Os direitos fundamentais têm uma importância fundamental no ordenamento jurídico. No entanto, ainda subsistem profundas disputas acerca de questões centrais da teoria dos direitos fundamentais. Levando em consideração sobretudo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, ALEXY desenvolve uma teoria geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã, cujos pontos centrais são uma teoria dos princípios e uma teoria sobre a estrutura dos direitos subjetivos.

A teoria dos princípios é uma teoria axiológica livre de suposições insustentáveis. A teoria da estrutura dos direitos subjetivos faz com que as múltiplas relações entre direitos fundamentais possam ser construídas de forma precisa. A partir dessa base são tratados os principais problemas da dogmática dos direitos fundamentais.

A parte final da obra é dedicada ao papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico. ALEXY demonstra que a positivação dos direitos fundamentais, aos quais todos os poderes estatais estão vinculados, significa uma abertura do sistema jurídico diante da Moral, abertura que é razoável e que pode ser levada a cabo por meios racionais.

ISBN 85-7420-872-8



**MALHEIROS
EDITORES**

teoria & direito público

TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Robert Alexy

tradução

Virgílio Afonso da Silva



*Obras da Coleção**

coleção dirigida por

VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA
Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo

JEAN PAUL C. VEIGA DA ROCHA
Núcleo "Direito & Democracia",
Cebrap

1. ROBERT ALEXY – *Teoria dos Direitos Fundamentais*
2. WILSON STEINMETZ – *A Vinculação dos Particulares a Direitos Fundamentais*
3. VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA (org.) – *Interpretação Constitucional*
4. VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA – *A Constitucionalização do Direito*
5. MARCO AURÉLIO SAMPAIO – *A Medida Provisória no Presidencialismo Brasileiro*

* www.teoriaedireitopublico.com.br

— *teoria & direito público* —

ROBERT ALEXY

**TEORIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS**

tradução de

VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA

 **MALHEIROS
EDITORES**

TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

ROBERT ALEXY

© SUHRKAMP VERLAG, 1986

© Tradução de VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA
da 5ª edição alemã

Theorie der Grundrechte

publicada pela Suhrkamp Verlag (2006)

ISBN: 978-85-7420-872-5

Direitos reservados desta edição por
MALHEIROS EDITORES LTDA.

Rua Paes de Araújo, 29, conjunto 171
CEP 04531-940 — São Paulo — SP
Tel.: (11) 3078-7205 Fax: (11) 3168-5495
URL: www.malheiroseditores.com.br
e-mail: malheiroseditores@terra.com.br

Composição

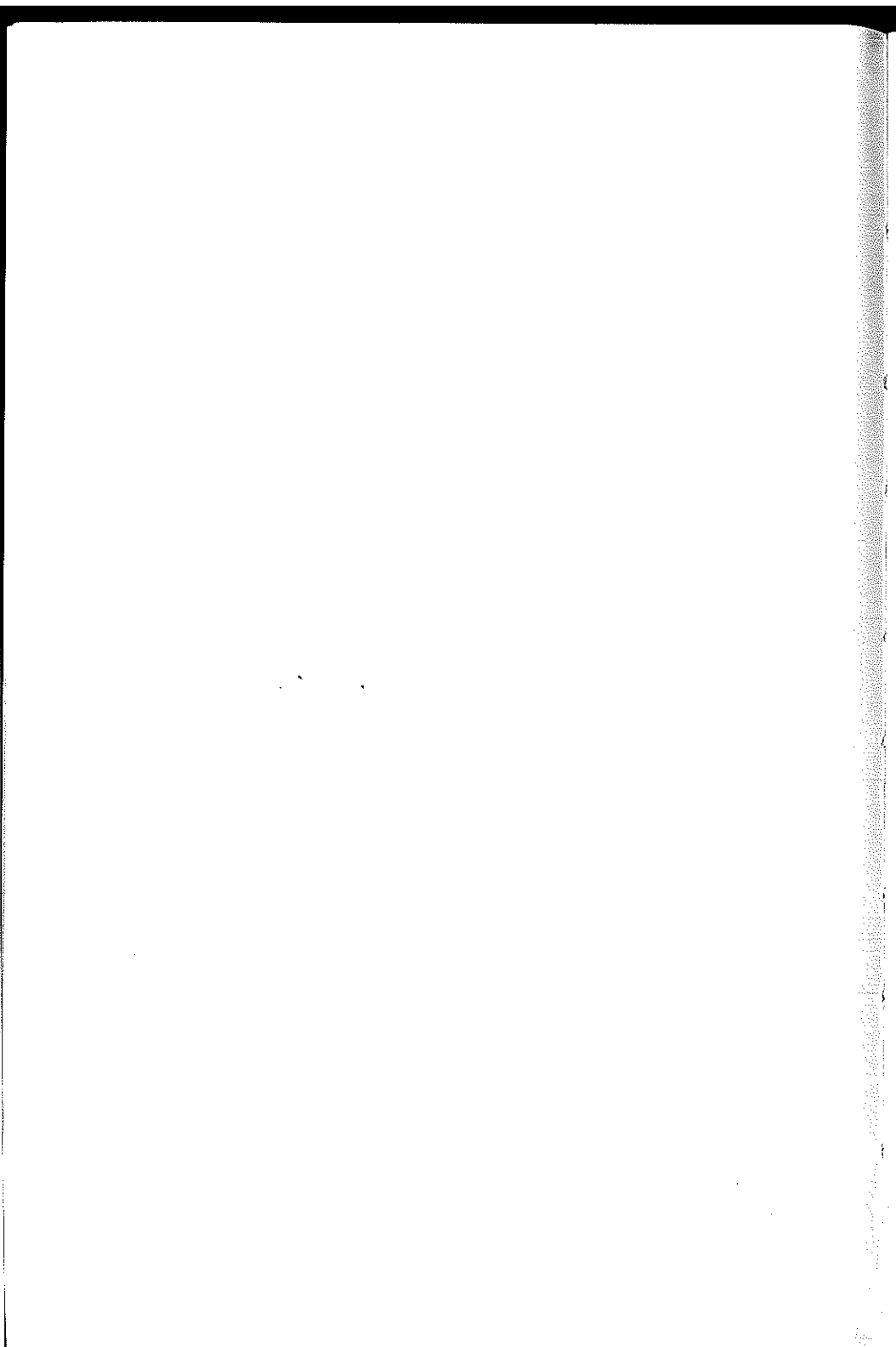
Acqua Estúdio Gráfico Ltda.

Capa

Criação: Vânia Lúcia Amato
Arte: PC Editorial Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil
04.2008 ✓

*Para
Georg Corbin
e
Julia.*

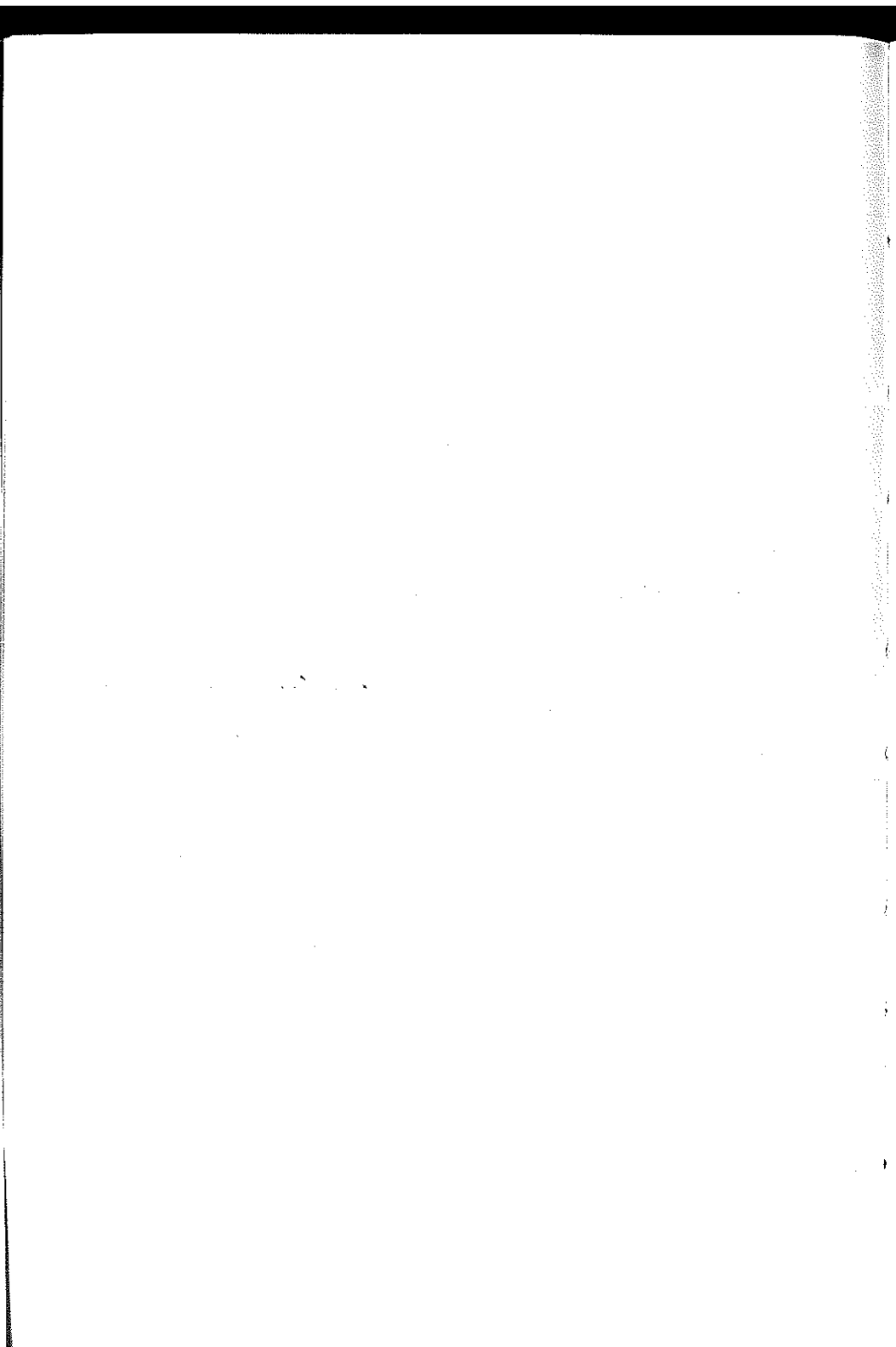


PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA

A tradução de textos acadêmicos pressupõe não apenas o domínio de ambos os idiomas – como toda e qualquer tradução –, mas também um amplo conhecimento da matéria a ser traduzida. Para mim, é uma alegria especial que a *Teoria dos Direitos Fundamentais* tenha encontrado em VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA um tradutor que satisfaz perfeitamente a ambas as condições. Fico feliz que um exímio conhecedor da língua alemã e reconhecido especialista na dogmática dos direitos fundamentais tenha assumido a imensa tarefa de traduzir este livro para a língua portuguesa. A ele fica aqui o meu profundo agradecimento.

Kiel, fevereiro de 2008

ROBERT ALEXY



NOTA DO TRADUTOR

Esta tradução é baseada na 5ª edição da *Theorie der Grundrechte* (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006). Alguns pequenos erros e omissões do texto original foram corrigidos, sempre com a expressa concordância do autor. Além da obra original, esta edição brasileira inclui também o posfácio que o autor escreveu em 2002, com respostas às principais críticas feitas às teses centrais deste livro.

Baseado na idéia de que uma das possíveis funções de uma tradução é tornar a obra traduzida acessível ao maior público possível, achei por bem não apenas traduzir o texto alemão, mas também todas as várias citações feitas em inglês. No caso de algumas poucas citações em latim, o trecho citado foi deixado no original, mas uma tradução para o português foi acrescentada à respectiva nota de rodapé. Em nenhum momento pareceu-me recomendável deixar termos ou expressões no original, nem mesmo entre parênteses após a tradução, como é às vezes comum em traduções de textos jurídicos do alemão para o português. Em geral, esses termos ou expressões acabam por atrapalhar a fluência do texto.

A fluência do texto foi também determinante para que não se fizesse uma tradução extremamente literal. Por mais que a tônica da tradução seja reproduzir, de forma fiel, a obra de um determinado autor, traduções literais, em alguns casos, acabam por tornar o texto incompreensível. Se isso já seria um problema em qualquer tradução, na tradução da obra de um autor que dá tanto valor à clareza analítica, como é o caso de ROBERT ALEXY, a escolha por uma literalidade radical seria, necessariamente, uma escolha equivocada, ao menos nos casos em que essa literalidade levasse a uma diminuição na clareza do texto. Por isso, em alguns momentos tomei a liberdade de inverter ordens de

frases, de aglutinar dois períodos em apenas um ou de dividir um período em dois.

Também ligada à compreensão do texto está a decisão acerca da inserção de “notas do tradutor” ao longo do texto, com o intuito de explicar alguns pontos que poderiam ser mais difíceis de serem compreendidos pelo público brasileiro. Embora fosse possível inserir uma série dessas notas, em nenhum momento elas me pareceram fundamentais à compreensão do livro. É claro que toda obra tem pontos que podem ser esclarecidos por meio de algum comentário adicional. No entanto, o risco desse tipo de estratégia é o de induzir o leitor a uma determinada interpretação específica – a do tradutor –, que pode não coincidir com aquilo que o autor do texto traduzido pode ter pretendido. É claro que a interpretação de qualquer obra é sempre um ato de criação do intérprete, e é claro também que toda tradução tem uma certa dimensão interpretativa. Mas, em nenhum momento, pareceu-me necessário ir além disso, ou seja, em nenhum momento pareceu-me necessário passar da *tradução que interpreta* para a *interpretação daquilo que foi traduzido*.

Mas uma breve explicação acerca da escolha da tradução de alguns termos importantes da obra parece-me necessária. Talvez a mais importante diga respeito aos termos “Prinzip”, “Grundsatz” e, em alguns contextos, “Satz”. Os dois primeiros, em português, podem ser traduzidos pelo termo “princípio”. Ocorre que, em alguns momentos, há uma deliberada escolha do autor pelo uso de um ou de outro, justamente para marcar uma diferença que a ele pareceu necessária. O caso mais importante está ligado à idéia de proporcionalidade. Alexy evita denominá-la de princípio (“Prinzip”), justamente para evitar confusões em relação ao seu conceito de princípio como espécie de norma contraposta à regra. Não pretendo entrar, aqui, na discussão acerca de como classificar a proporcionalidade. Há suficiente bibliografia em português sobre isso. Mas, para reproduzir a opção do autor – de intencionalmente usar dois termos distintos – escolhi traduzir “Grundsatz” por “máxima”. Por isso, a proporcionalidade será aqui chamada de “máxima da proporcionalidade”. Alerto, no entanto, que em outros poucos casos o termo “Grundsatz” foi eventualmente traduzido como “princípio”, sempre que não houvesse risco de confusão (ou seja, sempre que ele pudesse ser considerado como princípio em qualquer acepção da palavra). Já a tradução do termo “Satz” foi problemática apenas

no Capítulo 8 (“O direito geral de igualdade”). Para a igualdade, Alexy não utiliza nem o termo “Prinzip” nem o termo “Grundsatz”, mas o termo “Satz”, que pode ser traduzido, dentre outras possibilidades, por “enunciado”. Na tradução inglesa, feita por Julian Rivers,¹ no caso específico da igualdade, decidiu-se traduzir “Satz” por “princípio”. Como há uma opção deliberada do autor em não utilizar nem o termo “Prinzip” nem o termo “Grundsatz”, pareceu-me que traduzir “Gleichheitssatz” por “princípio da igualdade” esmaeceria a distinção que o autor havia criado. Isso justificou a opção por “enunciado da igualdade”, ainda que essa expressão possa soar estranha à primeira vista.

Um segundo termo central e, ao mesmo tempo, problemático é o termo “Geltung” (e, por extensão, o verbo “gelten”), que, dependendo do contexto, pode ser traduzido por “validade”, “existência”, “vigência”, “vigor” e “aplicabilidade” (e, por extensão, “valer”, “existir”, “viger”, “estar em vigor” ou “ser aplicável”). No vocabulário jurídico em português, como se sabe, esses termos têm significados muito distintos e há um amplo debate acerca da relação entre eles. Em vista dessa peculiaridade, a opção por um dos equivalentes em português teve quer ser uma opção minha, sempre com base no contexto em que o termo em alemão foi empregado. Traduzir “Geltung” sempre por “validade” – como às vezes ocorre – teria sido uma opção a meu ver equivocada e, por mais que não fosse possível uma escolha que satisfizesse a todas as posições nesse debate conceitual e terminológico, procurei sempre escolher a tradução mais precisa em face de cada contexto.

Uma característica importante do conceito de norma jurídica de Alexy é a existência de uma espécie de norma que não é “expressa diretamente por enunciados da Constituição”.² A expressão alemã utilizada é “zugeordnete Grundrechtsnorm”. Uma comparação entre a tradução espanhola, feita por Ernesto Garzón Valdés,³ e a já citada tradução inglesa, de Julian Rivers, pode dar uma idéia da diversidade de possibilidades. Garzón Valdés optou pela expressão “norma de

1. Cf. Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

2. Cf. Capítulo 2, II.2.

3. Cf. Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

direito fundamental *adscreta*” e Rivers, pela expressão “norma de direito fundamental *derivada*”. Pareceu-me mais conveniente traduzir a expressão por “norma de direito fundamental *atribuída*” e o fenômeno a ela associado, por “atribuição”.

Por fim, a expressão “Spielraum”, muito utilizada no posfácio de 2002, mas também presente ao longo de todo o texto, foi aqui traduzida por “discricionariedade”. Literalmente, “Spielraum” significa algo como “margem de manobra” e esse termo é às vezes traduzido por “margem de conformação” ou expressões similares. Embora essas traduções sejam corretas, optei – da mesma forma que fez Rivers na tradução inglesa – pelo termo “discricionariedade”. Sobretudo no posfácio, utilizar “margem de conformação” poderia gerar expressões extensas e de difícil compreensão, como “margem de conformação para escolher meios” ou “margem de conformação epistêmica de tipo empírico”. Desde que se tenha em mente que, aqui, o termo “discricionariedade” é utilizado não no sentido específico que pode ter no direito administrativo, mas em um sentido amplo, como simples sinônimo de “liberdade de decisão”, a opção por esse termo parece-me mais conveniente.

Nos textos jurídicos alemães, os artigos da Constituição costumam ser citados em numeração cardinal, por número de artigo, de parágrafo e, quando for o caso, de frase dentro de um parágrafo (ou de um *caput* de artigo). Nesta tradução, entendi que seria melhor utilizar a forma usual de citação de artigos no Brasil. Nesse sentido, uma citação como “art. 5º, § 3º, 2º”, significa a segunda frase do terceiro parágrafo do art. 5º da Constituição alemã. Alerto também que, em alguns textos legais alemães, o sinal “§” é utilizado para designar algo que, no Brasil, seria um artigo. Os exemplos mais importantes são os artigos do Código Civil e do Código Penal. Essa designação foi aqui mantida. Assim, quando no texto se faz menção ao § 826 do Código Civil alemão ou ao § 223 do Código Penal, essa menção equivale àquilo que, na técnica legislativa brasileira, seria chamado de art. 826 e art. 223.

Para o repertório oficial de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, inúmeras vezes citado ao longo desta obra, foi mantida a sua denominação usual: *BVerfGE*. Os números que seguem essas citações referem-se ao volume, à página inicial da decisão em questão e à página específica citada, quando for o caso. Assim, a men-

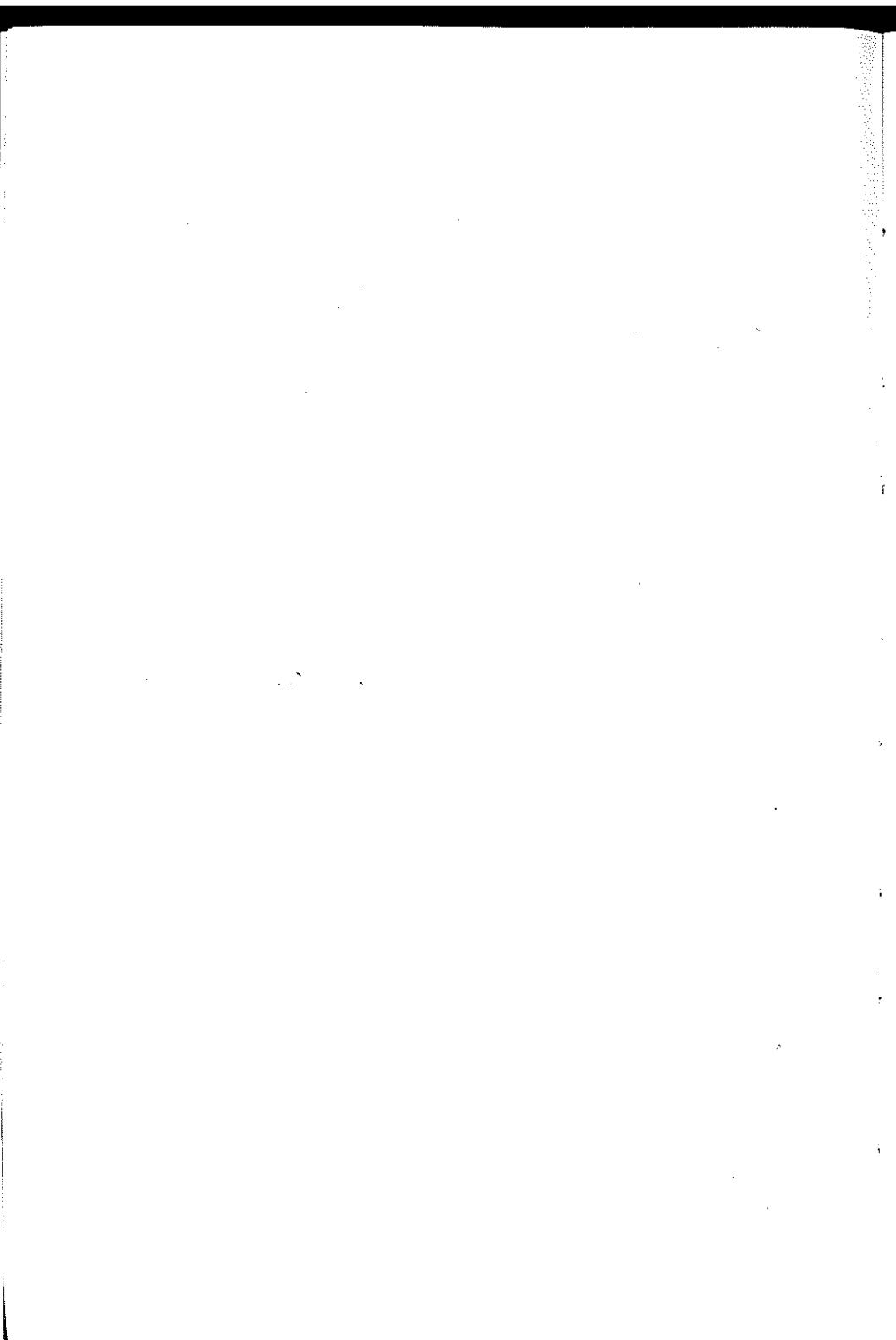
ção a “*BVerfGE* 7, 198 (215)” faz referência à página 215, da decisão que começa na página 198 do volume 7 (nesse exemplo, a decisão no caso *Lüth*).

Uma última informação importante: alguns poucos artigos da Constituição de Weimar, de 1919, ainda estão em vigor na Alemanha. São eles os artigos 136, 137, 138, 139 e 141. Essa informação é essencial para que não se pense que sua eventual citação tem um mero caráter histórico.⁴ A menção a esses artigos é, portanto, referência a direito vigente.

São Paulo, fevereiro de 2008

VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA

4. Cf., por exemplo, Capítulo 8, I.



SUMÁRIO

PREFÁCIO À EDIÇÃO BRASILEIRA	7
NOTA DO TRADUTOR.....	9
INTRODUÇÃO	25
 CAPÍTULO 1 – OBJETO E TAREFA DE UMA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	
<i>I – O CONCEITO DE UMA TEORIA JURÍDICA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO ALEMÃ.....</i>	31
<i>1. Teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã</i>	32
<i>2. Teoria jurídica dos direitos fundamentais da Constitui- ção alemã</i>	32
<i>3. Teoria jurídica geral dos direitos fundamentais da Cons- tituição alemã.....</i>	38
<i>II – TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E TEORIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS</i>	39
<i>III – TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO TEORIA ESTRUTURAL.....</i>	42
 CAPÍTULO 2 – O CONCEITO DE NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS	
<i>I – DO CONCEITO DE NORMA.....</i>	51
<i>1. Da polêmica acerca do conceito de norma.....</i>	52
<i>2. O conceito semântico de norma</i>	53
<i>3. A separação entre questões semânticas e questões relati- vas à validade</i>	58
<i>4. A conexão entre questões semânticas e questões relati- vas à validade</i>	60
<i>5. Aserção sobre normas e criação de normas.....</i>	62

II – A Norma de Direito Fundamental	65
1. <i>Norma de direito fundamental e disposição de direito fundamental</i>	66
2. <i>Normas de direitos fundamentais atribuídas</i>	69
3. <i>A teoria das normas de direitos fundamentais de Friedrich Müller</i>	76

CAPÍTULO 3 – A ESTRUTURA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

I – REGRAS E PRINCÍPIOS	85
1. <i>Critérios tradicionais para a distinção entre regras e princípios</i>	86
2. <i>Princípios como mandamentos de otimização</i>	90
3. <i>Colisões entre princípios e conflitos entre regras</i>	91
3.1 <i>O conflito entre regras</i>	92
3.2 <i>A colisão entre princípios</i>	93
3.2.1 <i>A lei de colisão</i>	94
3.2.2 <i>Resultados de sopesamentos como normas de direito fundamental atribuídas</i>	99
4. <i>O distinto caráter “prima facie” das regras e dos princípios</i>	103
5. <i>Regras e princípios como razões</i>	106
6. <i>Generalidade e princípios</i>	108
7. <i>Três objeções ao conceito de princípio</i>	109
7.1 <i>A invalidade de princípios</i>	110
7.2 <i>Princípios absolutos</i>	111
7.3 <i>A amplitude do conceito de princípio</i>	114
8. <i>A teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade</i>	116
II – TRÊS MODELOS	
1. <i>O modelo puro de princípios</i>	121
2. <i>O modelo puro de regras</i>	123
2.1 <i>Direitos fundamentais garantidos sem reserva</i>	124
2.2 <i>Direitos fundamentais com reserva simples</i>	130

2.3 Direitos fundamentais com reserva qualificada	132
3. O modelo de regras e princípios	135
3.1 O nível dos princípios	135
3.2 O nível das regras	139
3.3 O duplo caráter das normas de direitos fundamentais	141
III – TEORIA DOS PRINCÍPIOS E TEORIA DOS VALORES	
1. Princípio e valor	144
1.1 Conceitos deontológicos, axiológicos e antropológicos...	145
1.2 Sobre o conceito de valor	147
1.2.1 Juízos classificatórios, comparativos e métricos ...	147
1.2.2 Valores como critérios de valoração	149
1.3 A diferença entre princípios e valores	153
2. Objeções às teorias de princípios e de valores	153
2.1 Objeções filosóficas	155
2.2 Objeções metodológicas	158
2.2.1 A concepção de uma ordem hierarquizada de valores	158
2.2.2 A idéia de sopesamento	163
2.2.2.1 O modelo decisionista e o modelo fundamentado	165
2.2.2.2 A fundamentação de enunciados de preferências condicionadas não relacionada especificamente ao sopesamento	165
2.2.2.3 A fundamentação relacionada especificamente ao sopesamento	166
2.3 Objeções dogmáticas	176

CAPÍTULO 4 – DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO DIREITOS SUBJETIVOS

I – SOBRE A DISCUSSÃO ACERCA DOS DIREITOS SUBJETIVOS	180
1. Direitos subjetivos e questões normativas	180
2. Direitos subjetivos e questões empíricas	183
3. Direitos subjetivos e questões analíticas	

3.1 Norma e posição.....	184
3.2 Um modelo de direitos subjetivos em três níveis.....	185
3.3 A diversidade de direitos subjetivos	190
II – UM SISTEMA DE POSIÇÕES JURÍDICAS FUNDAMENTAIS.....	193
1. Direitos a algo	
1.1 A estrutura básica do direito a algo	193
1.1.1 Direitos a ações negativas (direitos de defesa)	196
1.1.1.1 Direitos ao não-embaraço de ações	196
1.1.1.2 Direitos à não-afetação de características e situações	199
1.1.1.3 Direitos à não-eliminação de posições ju- rídicas	199
1.1.2 Direitos a ações positivas	201
1.2 Acerca da lógica do direito a algo	204
1.2.1 As modalidades deonticas básicas	204
1.2.2 Direitos a algo como relações jurídicas	208
2. Liberdades	
2.1 Sobre o conceito de liberdade	218
2.2 Liberdades jurídicas	226
2.2.1 Liberdades não-protegidas.....	227
2.2.1.1 Liberdades não-protegidas absolutas e re- lativas relacionadas a pessoas e objetos.....	228
2.2.1.2 A liberdade não-protegida como mera ne- gação do dever-ser	229
2.2.1.3 Normas constitucionais permissivas	230
2.2.2 Liberdades protegidas	232
2.2.2.1 Sobre a estrutura básica da proteção	233
2.2.2.2 Sobre a proteção das liberdades funda- mentais	234
3. Competências	
3.1 Questões terminológicas	235
3.2 Competência e permissão.....	236
3.3 Competência e capacidade fática.....	238

3.4 Exercícios de competência como ações institucionais	239
3.5 Competência, sujeição, não-competência, não-sujeição...	242
3.6 Direitos fundamentais e competências	244
3.6.1 Competências do cidadão	244
3.6.2 Competências do Estado.....	247
III – O DIREITO FUNDAMENTAL COMPLETO	248

CAPÍTULO 5 – DIREITO FUNDAMENTAL E STATUS

I – A TEORIA DOS STATUS DE JELLINEK	254
1. O status passivo	256
2. O status negativo	258
3. O status positivo	263
4. O status ativo	267
II – SOBRE A CRÍTICA À TEORIA DOS STATUS DE JELLINEK	269

CAPÍTULO 6 – DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS RESTRIÇÕES

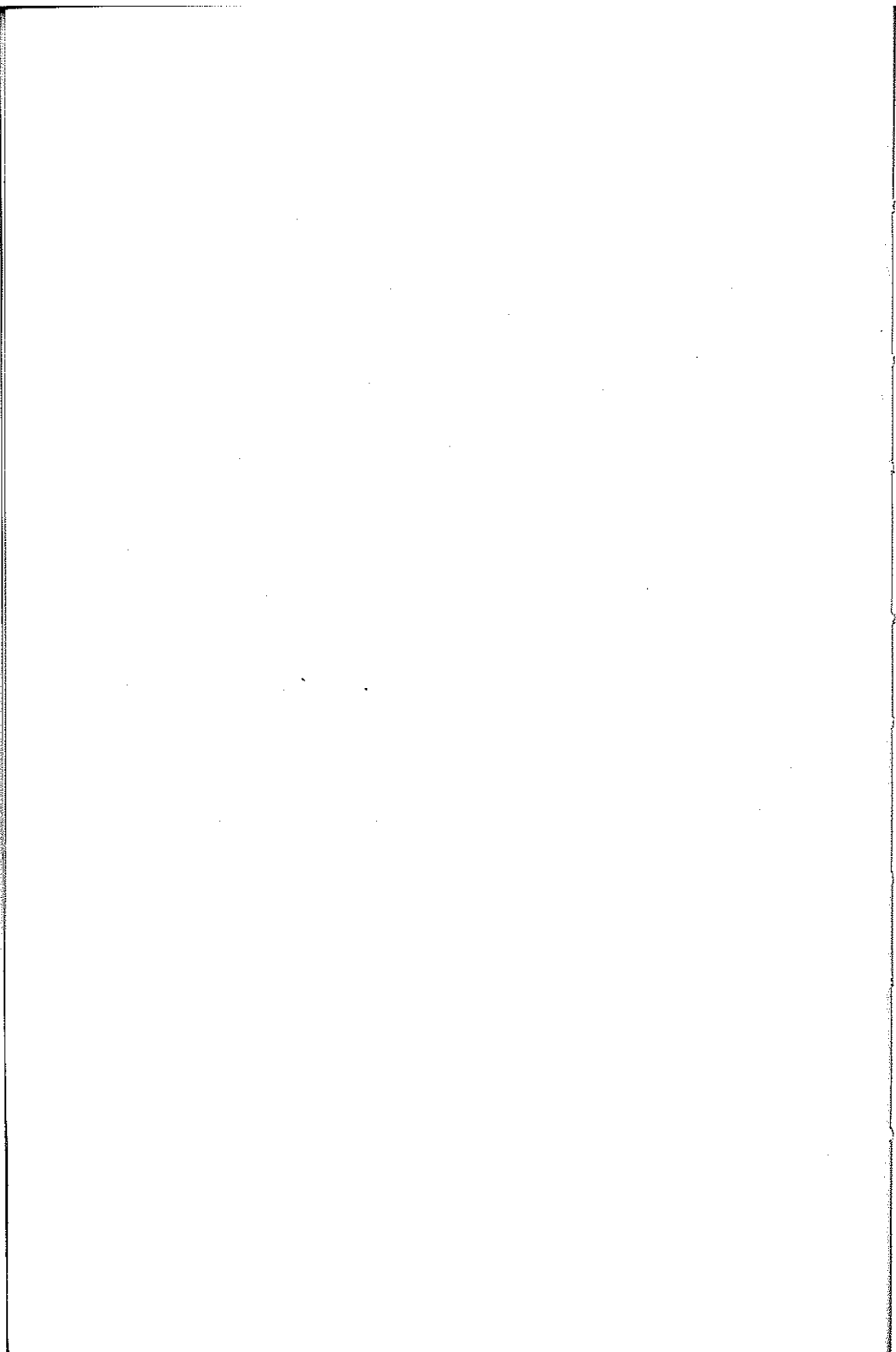
I – CONCEITO E TIPOS DE RESTRIÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS	276
1. A possibilidade lógica de restrições a direitos fundamentais	276
2. O conceito de restrição a direitos fundamentais	281
3. Espécies de restrições a direitos fundamentais	285
3.1 Restrições diretamente constitucionais	286
3.2 Restrições indiretamente constitucionais	291
4. Da garantia do conteúdo essencial como restrição das restrições	295
II – SUPORTE FÁTICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E RESTRIÇÕES A ESSES DIREITOS	301
1. Âmbito de proteção e suporte fático	302
2. Teorias restritas e amplas sobre o suporte fático	307
2.1 Teorias restritas do suporte fático	
2.1.1 A teoria do alcance material, de Friedrich Müller	309
2.1.2 Restrição ao suporte fático em virtude de leis gerais	316

2.2 <i>Uma teoria ampla do suporte fático</i>	321
III – <i>RESTRIÇÃO E CONFIGURAÇÃO</i>	332
CAPÍTULO 7 – O DIREITO GERAL DE LIBERDADE	341
I – <i>O CONCEITO DE DIREITO GERAL DE LIBERDADE</i>	341
II – <i>UMA CONCEPÇÃO FORMAL-MATERIAL DO DIREITO GERAL DE LIBERDADE</i>	345
1. <i>A objeção da falta de conteúdo</i>	346
1.1 <i>A tese da ausência de suporte fático</i>	347
1.2 <i>A tese da ausência de substância</i>	348
2. <i>A vinculação entre princípios formais e materiais</i>	354
III – <i>ESFERAS DE PROTEÇÃO E DIREITOS DE LIBERDADE IMPLÍCITOS</i>	360
1. <i>A teoria das esferas</i>	360
2. <i>Direitos de liberdade implícitos</i>	364
2.1 <i>Direitos relacionados a ações</i>	365
2.2 <i>Direitos relacionados a situações</i>	367
IV – <i>PROBLEMAS DO DIREITO GERAL DE LIBERDADE</i>	370
1. <i>Direito geral de liberdade e garantias pontuais</i>	370
2. <i>Direito geral de liberdade e o sistema dos direitos fundamentais</i>	372
3. <i>Direito geral de liberdade e “indivíduo isolado”</i>	376
4. <i>Direito geral de liberdade e outras normas constitucionais</i>	381
4.1 <i>Normas de competência</i>	381
4.2 <i>Normas de direitos fundamentais</i>	384
CAPÍTULO 8 – O DIREITO GERAL DE IGUALDADE	
I – <i>IGUALDADE NA APLICAÇÃO E NA CRIAÇÃO DO DIREITO</i>	393
II – <i>A ESTRUTURA DO DEVER DE IGUALDADE NA CRIAÇÃO DO DIREITO</i> ...	396
III – <i>AS FÓRMULAS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL</i>	401
IV – <i>TRATAMENTO IGUAL E TRATAMENTO DESIGUAL</i>	
1. <i>O dever de tratamento igual</i>	407
2. <i>O dever de tratamento desigual</i>	409

V – ENUNCIADO DE IGUALDADE E VALORAÇÃO	411
VI – IGUALDADE JURÍDICA E IGUALDADE FÁTICA	415
1. Sobre os conceitos de tratamento igual em sentidos jurídico e fático	416
2. Os princípios da igualdade jurídica e da igualdade fática ...	417
3. Sobre o papel do princípio da igualdade fática	419
VII – A ESTRUTURA DOS DIREITOS DE IGUALDADE COMO DIREITOS SUBJETIVOS	429
CAPÍTULO 9 – DIREITOS A AÇÕES ESTATAIS POSITIVAS (DIREITOS A PRESTAÇÕES EM SENTIDO AMPLO)	
I – CONCEITOS FUNDAMENTAIS E CONCEPÇÃO FUNDAMENTAL	433
1. O texto constitucional e a história de sua elaboração	434
2. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal	435
3. A polêmica sobre os direitos a prestações e sua natureza	440
4. Conceito e divisão dos direitos a prestações	442
5. Idéia-guia	446
II – DIREITOS A PROTEÇÃO	
1. Sobre o conceito de direito a proteção	450
2. A existência de direitos a proteção	451
2.1 Direito subjetivo ou (mera) norma objetiva	452
2.2 Defesa e proteção	456
3. Estrutura e justiciabilidade dos direitos a proteção	461
III – DIREITOS A ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTO	
1. Sobre o estágio da discussão	470
2. O conceito de direito a organização e procedimento	472
3. Sobre o problema da existência	474
4. Direitos procedimentais e teoria do status	477
4.1 Direitos procedimentais e status negativo	477
4.2 Direitos procedimentais e status ativo	479
5. Tipos de direitos a organização e procedimento	483
5.1 Competências de direito privado	484
5.2 Procedimentos judiciais e administrativos (procedimentos em sentido estrito)	488

5.3 Organização em sentido estrito	490
5.4 Formação da vontade estatal	498
IV – DIREITOS A PRESTAÇÃO EM SENTIDO ESTRITO (DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS)	
1. Conceito e estrutura	499
2. Sobre os argumentos contrários e favoráveis aos direitos fundamentais sociais	503
3. Um modelo de direitos fundamentais sociais	511
 CAPÍTULO 10 – DIREITOS FUNDAMENTAIS E NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SISTEMA JURÍDICO	
I – A FUNDAMENTALIDADE DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.....	520
II – EFEITO PERANTE TERCEIROS OU EFEITO HORIZONTAL	523
1. Sobre a tese da irradiação	524
2. Sobre a construção do efeito perante terceiros.....	528
2.1 A equivalência de resultados entre as construções	529
2.2 Um modelo em três níveis para os efeitos perante terceiros	533
III – SISTEMA JURÍDICO E ARGUMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	
1. Direitos fundamentais e a natureza do sistema jurídico ..	543
2. Sobre o problema da competência de controle do tribunal constitucional.....	544
3. Argumentação e decisão	548
3.1 Sobre a teoria geral da argumentação jurídica	548
3.2 A base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais.....	551
3.2.1 Texto e vontade	552
3.2.2 Precedentes	554
3.2.3 Teorias materiais dos direitos fundamentais	559
3.3 O processo da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais.....	573

POSFÁCIO (2002)	575
I – INSUFICIÊNCIA E DEMASIA	575
II – MOLDURA E FUNDAMENTO	578
1. O conceito de ordem-moldura	579
2. O conceito de ordem-fundamento	583
III – DISCRICIONARIEDADE ESTRUTURAL E SOPESAMENTO	584
1. Discricionariedade para definir objetivos	585
2. Discricionariedade para escolher meios	586
3. Discricionariedade para sopesar	587
3.1 Adequação e necessidade	588
3.2 Proporcionalidade em sentido estrito	593
IV – PRINCÍPIOS FORMAIS	611
1. A discricionariedade epistêmica como resultado de sope- samentos	612
2. A discricionariedade epistêmica e a vinculação à consti- tuição	623
BIBLIOGRAFIA	629
ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO	661



INTRODUÇÃO

As indagações sobre quais direitos o indivíduo possui enquanto ser humano e enquanto cidadão de uma comunidade, quais princípios vinculam a legislação estatal e o que a realização da dignidade humana, da liberdade e da igualdade exige expressam grandes temas da filosofia prática e pontos centrais de lutas políticas, passadas e presentes. Elas tornam-se problemas jurídicos quando uma Constituição, como é o caso da Constituição da República Federal da Alemanha, vincula os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a normas de direitos fundamentais diretamente aplicáveis, e quando essa vinculação está sujeita a um amplo controle por parte de um tribunal constitucional.

Diante da existência de um catálogo escrito de direitos fundamentais, o problema jurídico associado a esses direitos é, em primeiro lugar, um problema que diz respeito à interpretação das formulações do direito positivo. Neste ponto, ele não se diferencia dos problemas de interpretação diante dos quais se depara a Ciência do Direito em geral. Contudo, um rápido olhar sobre a discussão acerca dos direitos fundamentais da Constituição alemã demonstra que a polêmica a respeito dos direitos humanos e dos direitos dos cidadãos, embora tenha adquirido um novo caráter, em virtude de sua positivação como direitos diretamente vinculantes, não perdeu em agudeza nem em profundidade.

Uma razão para isso é a freqüentemente mencionada abertura das disposições do catálogo de direitos fundamentais. Fala-se em “fórmulas lapidares e máximas, que, em si mesmas, são desprovidas de um

conteúdo inequívoco”,¹ em “estilo taquigráfico”,² em “aglomeração de cláusulas gerais e conceitos maleáveis”,³ em ausência de “suficiência conceitual”⁴ e em “fórmulas vazias, sob as quais quase qualquer fato pode ser subsumido”.⁵ Em uma análise mais detida, é necessário diferenciar entre disposições de direitos fundamentais mais, ou menos, abertas,⁶ mas, em geral, é verdade que o catálogo de direitos fundamentais junto com os demais regramentos materiais da Constituição, sobretudo as disposições sobre os fins e a estrutura do Estado, são, no sistema jurídico da República Federal da Alemanha, as “estruturas normativas de menor densidade regulatória”.⁷

Mas a abertura não é, sozinha, uma explicação suficiente para a intensidade das controvérsias acerca dos direitos fundamentais. Mesmo que extremamente aberta, uma normatização pode não suscitar grandes discussões caso haja um amplo consenso sobre a matéria. Mas, se a abertura estiver associada a um profundo dissenso sobre o objeto regulado, estará aberto o flanco para uma ampla disputa. É exatamente esse o caso dos direitos fundamentais. O catálogo de direitos fundamentais regula de forma extremamente aberta questões em grande parte muito controversas acerca da estrutura normativa básica do Estado e da sociedade. Isso pode ser percebido com grande clareza nos

1. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, *NJW* 27 (1974), p. 1.529; cf. também Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1976, p. 197, que fala em “cláusulas lapidárias genéricas”.

2. Hans Huber, “Über die Konkretisierung der Grundrechte”, in Peter Saladin et al. (Orgs.), *Der Staat als Aufgabe: Gedenkschrift für Max Imboden*, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1972, p. 197.

3. Ralf Dreier, “Zur Problematik und Situation der Verfassungsinterpretation”, in Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, p. 112.

4. Walter Leisner, *Von der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zur Gesetzmäßigkeit der Verfassung*, Tübingen: Mohr, p. 5.

5. Karl-Dieter Opp, *Soziologie im Recht*, Reinbek: Rowohlt, 1973, pp. 124, 232. Sobre a tese das fórmulas vazias, cf. também Erhard Denninger, *Staatsrecht*, I, Reinbeck: Rowohlt, 1973, pp. 25 e ss., 117; Ernst Topitsch, “Die Menschenrechte”, *JZ* 18 (1963), pp. 3-4; Gert Degenkolbe, “Über logische Struktur und gesellschaftliche Funktionen von Leerformeln”, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialphilosophie* 17 (1965), pp. 327 e ss.

6. A possibilidade de se diferenciar não apenas entre disposições de direitos fundamentais mais ou menos abertas, mas também entre diversas espécies de abertura, é algo que será discutido mais adiante.

7. Otto Bachof, “Diskussionsbeitrag”, *VVDStRL* 39 (1981), p. 175.

conceitos dos direitos fundamentais à dignidade, à liberdade e à igualdade. Se a eles forem adicionados conceitos sobre os fins do Estado, a estrutura da democracia, do Estado de Direito e do Estado Social, chega-se a um sistema de conceitos que abarca os conceitos-chave do direito racional moderno,⁸ complementado pelo princípio do Estado Social, que expressa as exigências dos movimentos sociais dos séculos XIX e XX. Esses conceitos continuam a ser conceitos fundamentais da filosofia política. Ao mesmo tempo, são eles utilizados, nas discussões ideológicas, como armas semânticas. A expressão “luta pela constituição” refere-se, acima de tudo, a tais conceitos.⁹

Se a discussão sobre os direitos fundamentais não pudesse ter outra sustentação além do texto constitucional e do vacilante solo de seu surgimento, seria de se esperar uma luta de idéias sem fim e quase sem limites. Se não é isso o que ocorre, isso se deve, em grande medida, à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Ao longo de sua práxis jurisprudencial de mais de cinquenta anos, ele nunca deixou de criar novas determinações dentro do amplo campo de possibilidades aberto pelo texto constitucional. O significado atual dos direitos fundamentais é devido sobretudo à jurisprudência desse tribunal. A ciência dos direitos fundamentais – a despeito das controvérsias em torno do efeito vinculante das decisões do Tribunal Constitucional Federal¹⁰ – tornou-se, em considerável medida, uma ciência da jurisprudência constitucional.

Mas, embora a rede de precedentes cada vez mais densamente interligada tenha proporcionado alguns pontos fixos nas polêmicas sobre os direitos fundamentais, ela não diminuiu a vitalidade dessas discussões. Isso não se deve somente ao grande número de antigas questões ainda não resolvidas ou às novas que a elas continuamente se somam, nem ao fato de que as decisões do Tribunal Constitucional Federal podem ser questionadas pela ciência dos direitos fundamen-

8. Cf. Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, p. 124. Enquanto conceitos-chave do direito racional moderno, os conceitos mencionados baseiam-se, por sua vez, em tradições mais antigas. Cf., por exemplo, Christian Starck, “Menschenwürde als Verfassungsgarantie”, in Luigi Lombardi Vallauri/Gerhard Dilcher (Orgs.), *Christentum, Säkularisation und modernes Recht*, Baden-Baden: Nomos, 1982, pp. 814 e ss., que fala em “ignição bíblico-antiga da idéia de dignidade humana”.

9. Cf. Peter Römer (Org.), *Der Kampf um das Grundgesetz*, Frankfurt am Main: Syndicat, 1977; Martin Kriele, “Das Grundgesetz im Parteienkampf”, in Martin Kriele, *Legitimationsprobleme der Bundesrepublik*, München: Beck, 1977, pp. 131 e ss.

10. Cf. Capítulo 10, III.3.2.2.

tais, mas sobretudo ao fato de que o Tribunal Constitucional Federal, com suas manifestações gerais e freqüentemente ambíguas, acaba sempre por provocar novas discussões de base sobre os direitos fundamentais. Alguns exemplos de discussões desse tipo iniciadas pela jurisprudência constitucional são a tese de que o catálogo de direitos fundamentais estabelece uma ordem objetiva de valores,¹¹ a idéia de que os usos políticos das liberdades têm preferência diante daqueles que servem apenas a interesses privados,¹² sua interpretação das disposições de direitos fundamentais como garantias de "liberdades institucionais",¹³ sua hipótese de que normas de direitos fundamentais impõem ao Estado deveres de proteção, que podem se estender até um dever de criminalizar certos atos,¹⁴ suas considerações sobre direitos a prestações, que devem garantir os pressupostos fáticos para o exercício dos direitos de liberdade,¹⁵ e sua recente e crescente ênfase no conteúdo jurídico-procedimental dos direitos fundamentais.¹⁶ Esses exemplos demonstram que coisas as mais diversas estão presentes no quadro que o Tribunal Constitucional Federal pinta sobre os direitos fundamentais. Quase qualquer tomada de posição na disputa sobre os direitos fundamentais pode se utilizar de alguma decisão e/ou posicionamento do tribunal. Mesmo que a discussão sobre os direitos fundamentais se limitasse somente à definição daquilo que é válido com base nas decisões do Tribunal Constitucional Federal, ainda assim seria possível, em inúmeras questões, sustentar opiniões diversas. À abertura das disposições de direitos fundamentais soma-se, então, a abertura da jurisprudência sobre esses direitos. Nesse sentido, mesmo que essa jurisprudência tenha em parte diminuído o problema da abertura, não se pode dizer que o tenha resolvido por completo.

Diante dessa situação, a ciência dos direitos fundamentais impõe-se como tarefa dar respostas racionalmente fundamentadas às questões relativas a esses direitos. A presente teoria dos direitos fundamentais procura colaborar com o cumprimento dessa tarefa. O primeiro Capítulo é dedicado a seu objeto e sua natureza e, por essa razão, pode

11. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 7, 198 (205).

12. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 7, 198 (212); 42, 163 (170).

13. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 12, 205 (264); 31, 314 (326).

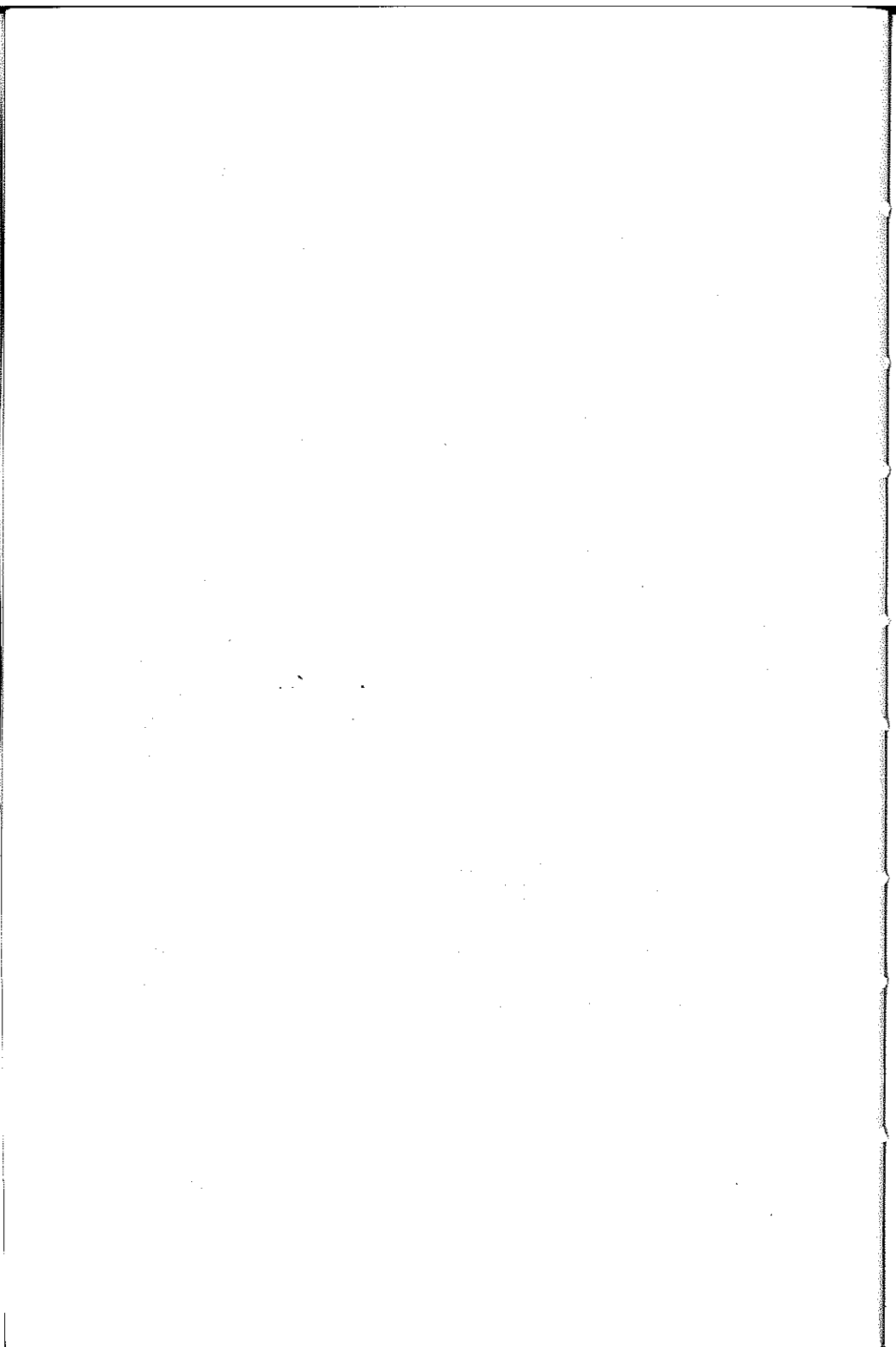
14. *BVerfGE* 39, 1 (41-42).

15. Cf. *BVerfGE* 33, 303 (331-332).

16. Cf. *BVerfGE* 37, 132 (148); 45, 297 (322); 48, 292 (297-298); 51, 150 (156).

ser lido como uma continuação desta Introdução. Aqui é necessário apenas salientar que essa teoria é uma teoria jurídica, a saber, uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã. Não se trata, portanto, nem de uma filosofia dos direitos fundamentais, desatrelada do direito positivo, nem de uma teoria sociológica, histórica ou politológica. O que dela se pode esperar pode ser caracterizado, para usar uma terminologia clássica, como uma parte geral da dogmática dos direitos fundamentais. Sua base é constituída pela teoria dos princípios, apresentada no terceiro Capítulo, e pela teoria das posições jurídicas fundamentais, elaborada no quarto Capítulo. A teoria dos princípios é uma teoria axiológica livre de suposições insustentáveis. Será demonstrado que uma adequada dogmática dos direitos fundamentais não é possível sem uma teoria dos princípios. Nesse sentido, um dos objetivos desta pesquisa é a reabilitação da tão depreciada teoria valorativa dos direitos fundamentais. Já a teoria das posições jurídicas fundamentais reduz as múltiplas relações de direitos fundamentais a posições e relações mais elementares, o que faz com que elas possam ser construídas de forma exata, o que é um pressuposto necessário de uma dogmática dos direitos fundamentais que se pretenda clara. Tal teoria segue o espírito da teoria dos *status* de Jellinek, a qual, com sua ajuda, será precisada e refinada. Tendo como base a teoria dos princípios e a teoria das posições elementares, serão tratados alguns dos principais problemas da dogmática dos direitos fundamentais, como a teoria do suporte fático e das restrições, os direitos gerais de liberdade e de igualdade, o direito à proteção e a organização e procedimentos, os direitos fundamentais sociais e os efeitos perante terceiros ou efeitos horizontais. O Capítulo conclusivo é dedicado ao papel dos direitos fundamentais e das normas de direitos fundamentais no sistema jurídico e à argumentação e à decisão no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse âmbito, será demonstrado que a positivação de direitos fundamentais que vinculam todos os poderes estatais representa uma abertura do sistema jurídico perante o sistema moral, abertura que é razoável e que pode ser levada a cabo por meios racionais.

É claro que, dentre a enorme quantidade de questões ligadas aos direitos fundamentais, somente algumas poderão ser tratadas. Caso se obtenha êxito em dar a elas respostas corretas, é possível esperar que estas também sejam úteis à resolução dos problemas que aqui não tenham sido tratados.



Capítulo 1

OBJETO E TAREFA DE UMA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

I – O CONCEITO DE UMA TEORIA JURÍDICA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO ALEMÃ

Sobre os direitos fundamentais é possível formular teorias das mais variadas espécies. Teorias históricas, que explicam o desenvolvimento dos direitos fundamentais,¹ teorias filosóficas, que se empenham em esclarecer seus fundamentos,² e teorias sociológicas, sobre a função dos direitos fundamentais no sistema social,³ são apenas três exemplos. Difícil haver uma disciplina no âmbito das ciências humanas que, a partir de sua perspectiva e com seus métodos, não esteja em condições de contribuir com a discussão acerca dos direitos fundamentais.

A análise a ser aqui desenvolvida diz respeito a uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã. O objeto e a natureza dessa teoria decorrem dos três atributos mencionados: ela é, em primeiro lugar, uma teoria dos *direitos fundamentais da Constituição alemã*; em segundo lugar, uma teoria *jurídica*; e, por fim, uma teoria *geral*.

1. Cf., por exemplo, os trabalhos reunidos em Roman Schnur (Org.), *Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964, especialmente os de Georg Jellinek e Émile Boutmy.

2. De trabalhos recentes, cf., de um lado, John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1971, e, de outro, Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, New York: Basic Books, 1974.

3. Cf. Niklas Luhmann, *Grundrechte als Institution*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1974.

TEORIAS
- Históricas → desenvolvimento
- Filosóficas → fundamentos
- Sociológicas → função

1. Teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã

Uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã é uma teoria acerca de determinados direitos fundamentais positivos vigentes. Isso a diferencia tanto de teorias sobre direitos fundamentais que tenham vigido no passado (teorias histórico-jurídicas), como de teorias sobre direitos fundamentais *per se* (teorias filosófico-jurídicas), como de teorias sobre direitos fundamentais que não os da Constituição alemã – por exemplo, teorias sobre direitos fundamentais de outros países ou teorias sobre direitos fundamentais dos Estados Federais alemães.

Diferenciar tais teorias não significa que não haja relações entre elas. Teorias histórico-jurídicas, no âmbito da interpretação histórica, e teorias de direitos fundamentais de outros países, no âmbito da interpretação comparada, podem desempenhar um significativo papel para a interpretação dos direitos fundamentais da Constituição alemã.⁴ Uma relação com teorias filosófico-jurídicas decorre do fato de que estas se ocupam, entre outras coisas, das estruturas possíveis e necessárias dos direitos fundamentais, isto é, de uma teoria geral sobre sua forma. Dizer que determinados direitos fundamentais são válidos significa dizer que as estruturas necessárias e algumas das estruturas possíveis foram realizadas. Portanto, uma teoria sobre determinados direitos fundamentais em vigor pode, de um lado, beneficiar-se dos conhecimentos jurídico-filosóficos e, de outro, contribuir com a Filosofia do Direito por meio da análise de seu material. Exatamente para compreender tais conexões é que se faz necessário diferenciar os elementos que se conectam.

2. Teoria jurídica dos direitos fundamentais da Constituição alemã

Enquanto teoria do direito positivo de um determinado ordenamento jurídico, uma teoria jurídica dos direitos fundamentais da Constituição alemã é uma teoria dogmática. O que faz uma teoria ser dog-

4. Sobre as referidas formas de interpretação, cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978, pp. 293-294.

mática e, em decorrência disso, jurídica é algo pouco claro.⁵ É natural orientar-se, de início, por aquilo que de fato é praticado como Ciência do Direito e designado como “dogmática jurídica” ou “ciência jurídica”, ou seja, pela Ciência do Direito em sentido estrito e próprio.⁶ Se isso é feito, é possível distinguir três dimensões da dogmática jurídica: uma analítica, uma empírica e uma normativa.⁷

De forma resumida, a dimensão *analítica* diz respeito à dissecação sistemático-conceitual do direito vigente. O espectro de tal dimensão estende-se desde a análise de conceitos elementares (por exemplo, do conceito de norma, de direito subjetivo, de liberdade e de igualdade),

5. Sobre o conceito de dogmática jurídica, cf. Ewald J. Thul, “Die Denkform der Rechtsdogmatik”, *ARSP* 46 (1960), pp. 241 e ss.; Theodor Viehweg, “Zwei Rechtsdogmatiken”, in Ulrich Klug (Org.), *Philosophie und Recht: Festschrift für C. A. Emge*, Wiesbaden: Steiner, 1960, pp. 106 e ss.; Ludwig Raiser, “Wozu Rechtsdogmatik”, *DRiZ* 46 (1968), p. 98; Franz Wieacker, “Zur praktischen Leistungen der Rechtsdogmatik”, in Rüdiger Bubner et al. (Orgs.), *Hermeneutik und Dialektik, Festschrift für H.-G. Gadamer*, 2, Tübingen: Mohr, 1970, pp. 311 e ss.; Josef Esser, “Möglichkeiten und Grenzen des dogmatischen Denkens im modernem Zivilrecht”, *AcP* 172 (1972), pp. 97 e ss.; do mesmo autor, “Dogmatik zwischen Theorie und Praxis”, in Fritz Baur (Org.), *Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen*, Tübingen: Mohr, 1974, pp. 517 e ss.; Klaus Adomeit, “Zivilrechtstheorie und Zivilrechtsdogmatik”, *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie* 2 (1972), pp. 503 e ss.; Hans Albert, “Erkenntnis und Recht”, *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie* 2 (1972), pp. 80 e ss.; Spirios Simitis, “Die Bedeutung von System und Dogmatik”, *AcP* 172 (1972), pp. 131 e ss.; Werner Krawietz, “Was leistet Rechtsdogmatik in der richterlichen Entscheidungspraxis?”, *ÖZöR* 23 (1972), pp. 47 e ss.; Ulrich Meyer-Cording, *Kann der Jurist heute noch Dogmatiker sein?*, Tübingen: Mohr, 1973; Dieter de Lazzer, “Rechtsdogmatik als Kompromißformular”, in Roland Dubischar et al. (Orgs.), *Dogmatik und Methode*, München: Scriptor, 1975, pp. 85 e ss.; Gerhard Struck, “Dogmatische Diskussionen über Dogmatik”, *JZ* 30 (1975), pp. 84 e ss.; Eike v. Savigny/Ulfrid Neumann/Joachim Rahlf, *Juristische Dogmatik und Wissenschaftstheorie*, München: Beck, 1976; Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, pp. 51 e ss., 85 e ss., 109 e ss.

6. Cf. Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 8ª ed., Stuttgart: Koehler, 1973, pp. 205 e ss.

7. Sobre a tese da tridimensionalidade, cf. Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, pp. 10 e ss., 51 e ss., 88-89; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 308 e ss. Aqui, a tese da tridimensionalidade diz respeito à dogmática jurídica. Para sua aplicação no âmbito da distinção entre Teoria do Direito, Sociologia Jurídica e Filosofia do Direito, cf. Hubert Rottluthner, *Rechtstheorie und Rechtssoziologie*, Freiburg: Alber, 1981, pp. 13 e ss., o qual, de resto, no âmbito da dogmática jurídica, faz as mesmas diferenciações presentes no texto. Cf. também Manfred Rehbinder, *Rechtssoziologie*, Berlin: de Gruyter, 1977, pp. 5 e ss., que aplica a tridimensionalidade à diferenciação entre Filosofia do Direito, dogmática jurídica e Sociologia Jurídica.

Diagrama da tridimensionalidade da dogmática jurídica

```

  Dogmática jurídica —> Analítica
                        —> Empírica
                        —> Normativa
  
```

passando por construções jurídicas (por exemplo, pela relação entre o suporte fático dos direitos fundamentais e suas restrições e pelo efeito perante terceiros), até o exame da estrutura do sistema jurídico (por exemplo, da assim chamada irradiação dos direitos fundamentais) e da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais (por exemplo, do sopesamento).

A dimensão *empírica* da dogmática jurídica pode ser compreendida a partir de dois pontos de vista: primeiro, em relação à cognição do direito positivo válido e, segundo, em relação à aplicação de premissas empíricas na argumentação jurídica,⁸ por exemplo, no âmbito de argumentos consequencialistas.⁹ Aqui, interessa somente a primeira acepção.¹⁰

Aquele que toma como objeto da dimensão empírica a cognição do direito positivo válido tem que pressupor conceitos amplos e polifacetados de direito e de validade. A dimensão empírica não se esgota com a descrição do direito nas leis, pois inclui também a descrição e o prognóstico da práxis jurisprudencial, ou seja, não só direito legislado, mas também direito jurisprudencial. Além disso, também a efetividade do direito é objeto da dimensão empírica, ao menos na medida em que tal efetividade for condição para a validade do direito, legislado ou jurisprudencial.¹¹ O objeto da dimensão empírica engloba, portanto, mais que o conceito de direito e de validade do positivismo jurídico. Os motivos para tanto, no âmbito dos direitos fundamentais, são facilmente perceptíveis. Devido à abertura de suas normas, a simples cognição do direito legislado não oferece muita coisa. Mesmo aqueles que defendem um conceito positivista de direito e de validade — seja como jurista, ao escrever um comentário aos direitos fundamen-

8. Cf., neste ponto, Klaus J. Philippi, *Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts*, Köln: Heymann, 1971; Gerd Winters, "Tatsachenurteile im Prozeß richterlicher Rechtssetzung", *Rechtstheorie* 2 (1971), pp. 171 e ss.; Christian Starck, "Empirie in Sozialwissenschaft", *JZ* 27 (1972), pp. 609 e ss.; Hubert Rottleuthner, *Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft*, Frankfurt am Main: Fischer, 1973, pp. 205 e ss.

9. Cf. Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, München: Beck, 1982, pp. 227 e ss.; Thomas W. Wälde, *Juristische Folgenorientierung*, Kronstein/Ts.: Athenäum, 1979.

10. Trata-se, portanto, de uma "Teoria do Direito meramente empírica", no sentido de Kant. Cf. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten* (Akademie-Ausgabe), Berlin: Reimer, 1907/14, p. 230.

11. Cf., por todos, Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, 2ª ed., Wien: Deuticke, 1960, pp. 212 e ss.

tais, seja como advogado, ao assessorar um cliente em questões de direitos fundamentais, seja como juiz constitucional, ao fundamentar uma decisão – não podem renunciar à cognição e ao manuseio da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Os detalhes sobre como isso deve ser reconstruído do ponto de vista da teoria da validade e das fontes do direito é algo que pode ser deixado em aberto por enquanto.¹² Neste ponto é suficiente constatar que existe um conceito amplo de cognição do direito positivo válido, que não pode ser evitado por ninguém que queira satisfazer as exigências das profissões jurídicas.

A caracterização da segunda dimensão como “empírica” não significa que a cognição do direito positivo válido se esgote com a cognição de fatos observáveis ou que a estes possa ser reduzida. É um truismo afirmar que não se pode concluir pela existência de direito válido – qualquer que seja o sentido que se dê a essa expressão – *tão-somente* a partir de observações como a reunião de um número de pessoas em uma sala, que primeiro conversam e depois levantam a mão.¹³ Aquele que quiser formular enunciados sobre direito válido com base em fatos desse tipo¹⁴ deve fazê-lo à luz de suposições que os transformem em fatos jurídicos.¹⁵ Os pormenores desse processo interpretativo são controversos.¹⁶ Por enquanto, interessa apenas o fato de que seu ponto de partida são sempre fatos em um sentido empírico estrito. Isso justifica falar de uma “dimensão empírica”.

A terceira dimensão, a dimensão *normativa*, avança para além do simples estabelecimento daquilo que, na dimensão empírica, pode ser elevado à condição de direito positivo válido, e diz respeito à elucidação e à crítica da prática jurídica, sobretudo da prática jurisprudencial. ///

12. Cf. Capítulo 10, III.3.1.

13. Cf., por todos, Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 2 e ss.

14. Trata-se, neste caso, de “fatos brutos” no sentido dado por Searle. Desses devem ser distinguidos os “fatos institucionais”, dos quais a sanção legislativa é um exemplo. Cf. John R. Searle, *Speech Acts*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969, pp. 50 e ss.

15. Cf. Neil MacCormick, “Law as institutional fact”, *The Law Quarterly Review* 90 (1974), pp. 102 e ss.; Ota Weinberger, “Das Recht als institutionelle Tatsache”, *Rechtstheorie* 11 (1980), pp. 427 e ss.

16. Para um modelo de processo interpretativo, cf. Aulis Aarnio/Robert Alexy/Aleksander Peczenick, “Grundlagen der juristischen Argumentation”, in Werner Krawietz/Robert Alexy (Orgs.), *Metatheorie juristischer Argumentation*, Berlin: Duncker & Humblot, 1983, pp. 13 e ss.

A questão central, nessa dimensão, é, a partir do direito positivo válido, determinar qual a decisão correta em um caso concreto. Em todos os casos polêmicos a resposta a essa questão implica valorações de quem a responde.¹⁷ A dogmática jurídica é, em grande medida, uma tentativa de se dar uma resposta racionalmente fundamentada a questões axiológicas que foram deixadas em aberto pelo material normativo previamente determinado. Isso faz com que a dogmática jurídica seja confrontada com o problema da possibilidade de fundamentação racional dos juízos de valor.¹⁸ Mais adiante será demonstrado que isso é em princípio possível.¹⁹

O problema dos valores surge sobretudo quando da interpretação do material normativo empiricamente constatável e do preenchimento de suas lacunas. Nesse sentido, é possível falar em um "*problema de complementação*". E, na medida em que para a identificação do material normativo são necessárias valorações, a esse problema soma-se o *problema da fundamentação*. No âmbito do direito constitucional o problema da fundamentação revela-se importante, por exemplo, em conexão com as assim denominadas normas constitucionais inconstitucionais²⁰ ou com a questão acerca da força vinculante das decisões do Tribunal Constitucional Federal. O problema da fundamentação também diz respeito, por fim, à questão do porquê da obediência à Constituição,²¹ embora, por esse aspecto, ele não desempenhe quase nenhum papel relevante na dogmática dos direitos fundamentais.²²

17. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 17 e ss.

18. Idem, pp. 31 e ss., 53 e ss., 161 e ss.

19. Cf. Capítulo 10, III.3.2.2.

20. O problema da fundamentação pode ser claramente percebido quando o Tribunal Constitucional Federal afirma que é concebível que o Poder Judiciário, cuja "autoridade se funda não apenas externamente na Constituição, mas, de certa maneira, também na própria idéia de direito – o que corresponde à essência de sua atividade", controle as "normas constitucionais com base no direito supralegal incorporado à Constituição e por ela pressuposto" (*BVerfGE* 3, 225 (235)). Para uma crítica a essa idéia – e com referências adicionais –, cf. Friedrich Müller, *Die Einheit der Verfassung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1979, pp. 50 e ss. e 128 e ss.

21. Cf., neste ponto, a teoria das "razões fundantes" (*underpinning reasons*): Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Clarendon, 1978, pp. 62 e ss., 138 e ss., 240 e ss., 275 e ss.

22. Nesse contexto, é elucidativa a diferenciação feita por Peczenick entre justificação profunda e justificação suficiente no contexto jurídico. Cf. Aleksander Peczenick, *Grundlagen der juristischen Argumentation*, Wien: Springer, 1983, pp. 1 e ss.

Por que se precisa a Constituição?

Na história da Ciência do Direito e, mais ainda, na história das teorias sobre a Ciência do Direito, os pesos dados a cada uma das três dimensões variam. A transição da jurisprudência dos conceitos para a jurisprudência dos valores, passando pela jurisprudência dos interesses, é um claro exemplo disso.²³ O que, em cada caso, é considerado como jurídico em sentido estrito e próprio depende de como seja definido o relacionamento entre as três dimensões. Para se determinar essa relação é necessário um ponto de vista abrangente. A natureza da Ciência do Direito como uma disciplina *prática* é um ponto de vista desse tipo. A Ciência do Direito, na forma como levada a cabo hoje, é, em primeira instância, uma disciplina prática, porque a pergunta central, em um caso real ou hipotético, diz respeito ao que deve ser. Na Ciência do Direito essa questão é formulada a partir de uma perspectiva que corresponde à perspectiva do juiz.²⁴ Isso não significa que a Ciência do Direito não possa abranger outras perspectivas, nem que sempre diga respeito diretamente à solução de casos concretos, mas somente que a perspectiva do juiz é a perspectiva típica da Ciência do Direito e que os enunciados e teorias desenvolvidos a partir dela, mesmo quando abstratos, referem-se sempre à fundamentação de juízos concretos de dever-ser.²⁵

Em face das três dimensões, o caráter prático da Ciência do Direito revela-se como um princípio unificador. Se a ciência jurídica quiser cumprir sua tarefa prática de forma racional, deve ela combinar essas três dimensões. Ela deve ser uma disciplina integradora e multidimensional: combinar as três dimensões é uma condição necessária da racionalidade da ciência jurídica como disciplina prática.

As razões disso são facilmente perceptíveis. Para se obter uma resposta a uma questão sobre o que deve ser juridicamente, é necessário conhecer o direito positivo. O conhecimento do direito positivo

23. Cf. Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, 2ª ed., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967, pp. 433 e ss., 574 e ss.

24. Sobre a Ciência do Direito como uma disciplina prática nesse sentido, cf. Philipp Heck, *Das Problem der Rechtsgewinnung*, 2ª ed., Tübingen: Mohr, 1912, p. 3; Helmut Coing, *Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehre der allgemeinen Hermeneutik*, Köln: Westdeutscher Verlag, 1959, p. 23; Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung*, pp. 39 e ss.

25. Cf. Karl Engisch, *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, 3ª ed., Heidelberg: Winter, 1963, p. 5.

válido é tarefa da dimensão empírica. Nos casos mais problemáticos, o material normativo que pode ser obtido por meio da dimensão empírica não é suficiente para fundamentar um juízo concreto de dever-ser. Isso leva à necessidade de juízos de valor adicionais e, com isso, à dimensão normativa. Clareza conceitual, ausência de contradição e coerência são pressupostos da racionalidade de todas as ciências.²⁶ Os inúmeros problemas sistemático-conceituais dos direitos fundamentais demonstram o importante papel da dimensão analítica no âmbito de uma ciência prática dos direitos fundamentais que pretenda cumprir sua tarefa de maneira racional.

O dogmático – e, com isso, o jurídico em sentido próprio e estrito – é constituído pela ligação das três dimensões, de forma orientada à tarefa prática da ciência jurídica. Se o conceito de teoria jurídica é definido a partir dessa base, então, uma teoria jurídica dos direitos fundamentais da Constituição alemã é uma teoria inserida no contexto das três dimensões e voltada à tarefa prática da ciência jurídica.

3. Teoria jurídica geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã

Uma teoria geral dos direitos fundamentais da Constituição alemã é uma teoria que se ocupa com problemas relacionados a todos os direitos fundamentais, ou a todos os direitos fundamentais de uma determinada espécie, como, por exemplo, a todos os direitos de liberdade, de igualdade ou a prestações positivas. Seu contraponto seria uma teoria particular, que se ocupa de problemas especiais de direitos fundamentais específicos. Essa diferenciação destaca o alcance da teoria, que é uma questão de grau. Nesse sentido, uma teoria que se ocupe de problemas comuns a todos os direitos de liberdade é, certamente, uma teoria geral, mas menos geral que uma teoria que se ocupe dos

26. Sobre o conceito de coerência, cf. Nicholas Rescher, *The Coherence Theory of Truth*, Oxford: Oxford University Press, 1973; do mesmo autor, *Cognitive Systematization*, Oxford: Blackwell, 1979; sobre o papel da coerência na Ciência do Direito, cf. Aleksander Peczenick, *Grundlagen der juristischen Argumentation*, pp. 176 e ss.; Aulis Aarnio, *Philosophical Perspectives in Jurisprudence*, Helsinki: Societas Philosophica Fennica, 1983, p. 191; Neil MacCormick, "Coherence in legal justification", in Werner Krawietz et al. (Orgs.), *Theorie der Normen: Festgabe für Ota Weinberger*, Berlin: Duncker & Humblot, 1984, pp. 37 e ss.

problemas comuns a todos os direitos fundamentais. Dificuldades surgem quando se intenta diferenciar entre teoria geral e teoria particular nos casos de direitos fundamentais que têm características de direitos gerais, isto é, nos casos dos direitos gerais de liberdade ou igualdade. O próprio objeto, nesses casos, implica generalidade. Mas é possível, mesmo nesses casos, diferenciar entre uma teoria geral desses direitos como direitos fundamentais de uma determinada espécie e uma teoria particular, que se ocupe de problemas específicos relativos à interpretação desses direitos.

II – TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E TEORIAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A concepção de uma teoria jurídica geral dos direitos fundamentais expressa um ideal teórico. Ela tem como objetivo uma teoria integradora, a qual engloba, da forma mais ampla possível, os enunciados gerais, verdadeiros ou corretos, passíveis de serem formulados no âmbito das três dimensões e os combine de forma otimizada. Em relação a uma tal teoria, pode-se falar em uma “teoria ideal dos direitos fundamentais”. Toda teoria dos direitos fundamentais realmente existente consegue ser apenas uma aproximação desse ideal.

A idéia de uma teoria integradora está sujeita a dois tipos de incompreensões. O primeiro sugere que o postulado da integração conduziria a uma enorme mixórdia. O que se pretende é exatamente o oposto: um sistema de enunciados gerais de direitos fundamentais, corretos ou verdadeiros, ordenados da forma mais clara possível. O segundo tipo de incompreensão sugere que o programa integrativo exige demais da teorização sobre direitos fundamentais, fazendo com que toda teoria de direitos fundamentais pareça insuficiente ou sem valor se, mesmo que verdadeira ou correta, ela não for ampla. Também não é esse o caso. O conceito de uma teoria integrativa é uma idéia regulativa, da qual a teorização sobre os direitos fundamentais pode se aproximar das mais variadas formas. Toda teoria sobre direitos fundamentais que contribua para a realização desse ideal tem, devido a essa contribuição, o seu valor. Considerá-la sem valor por não realizar totalmente o ideal significaria desconhecer o caráter regulativo do programa integrativo. Para realizar da forma mais ampla possível a teoria dos direitos fundamentais (no sentido de uma teoria ideal), é necessá-

rio reunir várias teorias verdadeiras ou corretas sobre direitos fundamentais. Mas é claro que essas teorias devem ser avaliadas na medida de sua contribuição à teoria ideal.

À luz dessas observações, é instrutivo um breve exame das teorias que, na literatura jurídica contemporânea, são chamadas de "teorias de direitos fundamentais". A sistematização mais influente é aquela realizada por Böckenförde. Ele diferencia entre cinco teorias: "a teoria liberal ou do Estado de Direito burguês, a teoria institucional, a teoria axiológica, a teoria democrático-funcional e a teoria social-estatal".²⁷ O *status* dessas teorias será analisado mais adiante.²⁸ Por ora interessa apenas sua "função como idéia normativa guia para a interpretação", enfatizada por Böckenförde.²⁹ A partir *desse* ponto de vista, as teorias apresentadas são concepções básicas das mais gerais sobre o objetivo e a estrutura dos direitos fundamentais.

Teorias sobre direitos fundamentais que tenham esse caráter de concepção básica geral padecem de dois problemas. O primeiro resulta de sua abstração.³⁰ Por definição, tais teorias não são desenvolvidas levando-se em consideração as três dimensões. Em primeiro lugar, elas não oferecem mais que hipóteses que possam guiar a elaboração de uma teoria abrangente. Se confirmadas nesse processo, elas podem adotar o caráter de uma soma geral das teorias elaboradas. Teorias de direitos fundamentais sob a forma de concepções básicas não podem, portanto, substituir uma teoria mais elaborada, podendo apenas constituir seu ponto de partida e, possivelmente, seu ponto de chegada.

O segundo problema é mais grave. Isoladamente consideradas, cada uma das teorias apresentadas expressa *uma* tese fundamental. Uma teoria que pretenda reduzir os direitos fundamentais a apenas uma

27. Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation", *NJW* 27 (1974), p. 1.530; em sentido semelhante, cf. Klaus Kröger, *Grundrechtstheorie als Verfassungsproblem*, Baden-Baden: Nomos, 1978; Michael Kloepfer, *Datenschutz als Grundrecht*, Königstein/Ts.: Athenäum, 1980, p. 20; Edzard Schmidt-Jortzig, *Die Einrichtungsgarantien der Verfassung*, Göttingen: Schwartz, 1979, pp. 63 e ss.

28. Cf. Capítulo 10, III.3.2.3.

29. Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Die Methoden der Verfassungsinterpretation", *NJW* 29 (1976), p. 2.096; em sentido semelhante, Klaus Kröger, *Grundrechtstheorie als Verfassungsproblem*, p. 11: "horizonte de orientação determinante para a interpretação dos direitos fundamentais".

30. Cf., a esse respeito, Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, Darmstadt: s.e., 1977, p. 5.

tese básica pode ser classificada como uma “teoria unipolar”. Uma teoria que não consta da lista de teorias unipolares elaborada por Böckenförde é a tese dos direitos fundamentais como garantia procedimental.³¹ Tudo milita a favor da suposição de que os direitos fundamentais não são adequadamente compreendidos com base em uma teoria unipolar, qualquer que ela seja. A confirmação de tal suposição será analisada no correr deste trabalho. Neste ponto quis-se apenas suscitar, de forma genérica, que seria surpreendente que – dadas a multiplicidade e a complexidade daquilo que é regulado pelos direitos fundamentais e a experiência de que em questões práticas de alguma importância sempre há um feixe de pontos de vista conflitantes – justamente os direitos fundamentais pudessem ser reduzidos a apenas um único princípio. Uma exceção seria uma teoria unipolar de grau máximo de abstração, como aquela segundo a qual o fim último dos direitos fundamentais é a garantia da dignidade humana.³² Contudo, essa não é uma verdadeira exceção, pois tais teorias de grau máximo de abstração não são, na realidade, teorias unipolares, porquanto abarcam, dentro de seus limites, as mais diversas teorias de direitos fundamentais das espécies aqui apresentadas.

Contraposto ao conceito de teoria unipolar é o conceito de *teoria combinada*. Uma teoria combinada é a que subjaz à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, a qual recorre a todas as concepções básicas aqui mencionadas.³³ Esse tipo de teoria é também sustentada por inúmeros autores, que falam em inúmeras funções,³⁴ aspectos³⁵ ou fins³⁶ dos direitos fundamentais. Contra uma teoria combinada levan-

31. Cf., com inúmeras referências, Helmut Goerlich, *Grundrechte als Verfahrensgarantie*, Baden-Baden: Nomos, 1981.

32. Cf., além disso, fórmulas como a de Walter Schmidt, “Grundrechtstheorie im Wandel der Verfassungsgeschichte”, *Jura* 5 (1983), p. 180, segundo a qual a proteção “da liberdade decisória do indivíduo entre a dominação estatal e o poder social” deve ser o ponto central de uma moderna teoria dos direitos fundamentais.

33. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 50, 290 (337): teoria liberal; *BVerfGE* 12, 205 (259 e ss.): teoria institucional; *BVerfGE* 7, 198 (205): teoria axiológica; *BVerfGE* 42, 163 (170): teoria democrática; *BVerfGE* 33, 303 (330 e ss.): teoria social-estatal; *BVerfGE* 53 30 (64-65): teoria procedimental.

34. Cf. Eckehart Stein, *Staatsrecht*, 8ª ed., Tübingen: Mohr, 1982, pp. 250 e ss.; Erhard Denninger, *Staatsrecht*, v. 2, Reinbeck: Rowohlt, 1979, p. 138; Albert Bleckmann, *Allgemeine Grundrechtslehren*, Köln: Heymann, 1979, pp. 155 e ss.

35. Cf. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, *VVDStRL* 30 (1972), p. 75.

36. Cf. Martin Kriele, *Einführung in die Staatslehre*, pp. 336 e ss.

ta-se de imediato a objeção de que ela não é uma teoria que possa guiar a decisão e a fundamentação jurídicas, mas apenas uma coleção de *topoi* extremamente abstratos, dos quais se pode servir da maneira que se desejar. Exatamente nesse sentido é a crítica feita por Böckenförde ao Tribunal Constitucional Federal, segundo a qual esse tribunal “apóia-se alternadamente em diversas teorias sobre direitos fundamentais como ponto de partida de sua interpretação, sem que, nessa alternância, seja possível reconhecer um sistema”.³⁷ A objeção é correta ao apontar que uma teoria que consista precipuamente em uma lista extremamente geral de idéias básicas sobre os fins e as estruturas dos direitos fundamentais tem pouca valia. E isso não apenas devido ao grau de abstração das teorias agrupadas, mas sobretudo ao fato de que, nos casos concretos, essas teorias podem colidir entre si de diversas formas.³⁸

Se houvesse apenas uma alternativa – ou uma teoria unipolar, ou uma combinação indeterminada de idéias básicas abstratas e passíveis de colisão – poder-se-ia dizer que a teoria dos direitos fundamentais encontra-se, de fato, diante de um dilema. Mas essas alternativas não esgotam, de forma nenhuma, as possibilidades de construção de teorias sobre direitos fundamentais. A insuficiência de ambas as teorias apenas demonstra que uma teoria dos direitos fundamentais não pode manter-se na superficialidade de idéias básicas, seja sob a forma de uma teoria unipolar, seja sob a forma de uma teoria combinada. Embora a teoria combinada expresse de forma acertada a existência de inúmeros pontos de vista a serem considerados, o controle desses pontos de vista requer, no entanto, um modelo que proporcione mais que uma simples compilação não vinculante. Elaborar um modelo desse tipo é a tarefa de uma teoria integrativa.

III – TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO TEORIA ESTRUTURAL

O caminho para uma adequada teoria integrativa passa por uma teoria estrutural dos direitos fundamentais. Enquanto parte integrante de uma teoria integrativa, uma teoria estrutural é, primariamente,

37. Cf. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, p. 1.536.

38. Cf. Erhard Denninger, *Staatsrecht*, v. 2, p. 182.

uma teoria analítica. Mas apenas primariamente, e não totalmente analítica, porque investiga estruturas como a dos conceitos de direitos fundamentais, de suas influências no sistema jurídico e na fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais com vistas às tarefas práticas de uma teoria integrativa. Seu principal material é a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Nesse sentido, tem ela um caráter empírico-analítico. Sua idéia guia é a questão acerca da decisão correta e da fundamentação racional no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse sentido, tem ela um caráter normativo-analítico.

Uma teoria estrutural não tem como tarefa apenas constituir a primeira peça de uma teoria integrativa dos direitos fundamentais, mas também a base e a estrutura para o que vem depois. Há uma série de razões para tanto. Clareza analítico-conceitual é uma condição elementar da racionalidade de qualquer ciência. Nas disciplinas práticas, que apenas muito indiretamente podem ser controladas por experiências empíricas, esse postulado tem um significado ainda maior. Isso vale principalmente para o campo dos direitos fundamentais, os quais são marcados por uma tradição analítica em uma medida muito menor que, por exemplo, o direito civil e expostos em medida muito maior a influências ideológicas.

A dogmática dos direitos fundamentais, enquanto disciplina prática, visa, em última instância, a uma fundamentação racional de juízos concretos de dever-ser no âmbito dos direitos fundamentais. A racionalidade da fundamentação exige que o percurso entre as disposições de direitos fundamentais e os juízos de dever-ser seja acessível, na maior medida possível, a controles intersubjetivos. Isso, no entanto, pressupõe clareza tanto acerca da estrutura das normas de direitos fundamentais quanto acerca de todos os conceitos e formas argumentativas relevantes para a fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais. De forma nenhuma é possível dizer que tal clareza já exista em grau suficiente. Quando se examina a caracterização teórico-estrutural dos direitos fundamentais e de suas normas na jurisprudência e na literatura, o que se encontra é um quadro quase desconcertante. Mesmo uma observação à primeira vista simples, como a que afirma que os direitos fundamentais são, de um lado, "direitos individuais" e, de outro, "princípios objetivos",³⁹ quando analisada mais de perto, susci-

39. *BVerfGE* 50, 290 (337).

ta problemas. O que se quer dizer com “objetivo” e com “princípios”? A aparência de simplicidade não surge somente quando às disposições de direitos fundamentais são atribuídos, para além de “direitos de defesa”, também “direitos de participação” ou “pretensões à participação”.⁴⁰ E o que se quer dizer quando às vezes se fala em “poder jurídico”?⁴¹ Dificuldades especiais estão associadas às descrições do aspecto objetivo, ligado ao conceito de valor. Exemplos são: “normas axiológicas fundamentais”,⁴² “decisão axiológica”,⁴³ “decisão axiológica jurídico-objetiva”,⁴⁴ “conteúdo axiológico”,⁴⁵ “valores constitucionais”⁴⁶ e “valor comunitário constitutivo”.⁴⁷ É também muito difícil ter uma visão de conjunto dos termos não pertencentes à família dos valores, como: “princípios da ordem social”,⁴⁸ “diretrizes”,⁴⁹ “impulsos”,⁵⁰ “princípios estruturais”,⁵¹ “princípios básicos”,⁵² “norma guia”,⁵³ “norma parâmetro”,⁵⁴ “parâmetros”,⁵⁵ “postulados”,⁵⁶ “tarefas”⁵⁷ e “dever de proteção”.⁵⁸ E a variedade terminológica da jurisprudência é ainda superada pela da literatura. Assim, para mencionar apenas um exemplo, cuja extensão, ainda que notável, não é, de forma alguma, atípica, Scheuner emprega, em um artigo,⁵⁹ em relação aos direitos fundamentais, dentre outras, as seguintes vinte e uma expressões ou termos com conotação teórico-estrutural: “garantias de liberdade”, “princípios de conforma-

40. *BVerfGE* 35, 79 (112, 128, 115).

41. *BVerfGE* 24, 367 (396).

42. *BVerfGE* 6, 55 (71); 35, 79 (112); 39, 1 (47).

43. *BVerfGE* 27, 195 (201).

44. *BVerfGE* 49, 89 (142).

45. *BVerfGE* 7, 198 (208); 27, 104 (109).

46. *BVerfGE* 35, 202 (225).

47. *BVerfGE* 12, 45 (54).

48. *BVerfGE* 7, 198 (215).

49. *BVerfGE* 39, 1 (41).

50. *Idem*.

51. *BVerfGE* 31, 58 (69).

52. *BVerfGE* 31, 58 (70).

53. *Idem*.

54. *BVerfGE* 21, 73 (85).

55. *BVerfGE* 42, 143 (148).

56. *BVerfGE* 35, 79 (114).

57. *BVerfGE* 35, 321 (331).

58. *BVerfGE* 39, 1 (42).

59. Ulrich Scheuner, “Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat: Die Grundrechte als Richtlinie und Rahmen der Staatstätigkeit”, *DÖV* 24 (1971), pp. 505 e ss.

ção social", "elementos da ordem social",⁶⁰ "princípios constitucionais", "restrições" (à liberdade do legislador), "objetivos", "encargo", "diretriz vinculante",⁶¹ "princípios e determinações em seu aspecto institucional-funcional", "máximas",⁶² "determinações objetivas", "moldura", "liberdades fundamentais", "objetivos de direitos fundamentais",⁶³ "participação",⁶⁴ "direitos sociais", "objetivos estatais", "concepções de finalidades", "objetivos vinculantes", "encargos legislativos" e "diretrizes".⁶⁵

Diante dessas compilações, as palavras de Hohfeld ganham um peso especial: "em qualquer análise mais atenta de um problema, seja ele jurídico ou não, palavras camaleônicas são um risco tanto para a clareza de pensamento quanto para a lucidez na expressão".⁶⁶ Se não há clareza acerca da estrutura dos direitos fundamentais e de suas normas, não é possível haver clareza na fundamentação nesse âmbito. O mesmo vale para todos os conceitos relativos à dogmática dos direitos fundamentais. Teses dogmáticas, como as que sustentam que "a liberdade não [seria] uma liberdade do direito, mas uma liberdade no direito e para o direito",⁶⁷ ou que "de acordo com a lógica pura não haveria restrições das disposições de direitos fundamentais, mas apenas definições dessas disposições",⁶⁸ ou que direitos a prestações positivas estariam, "por sua estrutura lógica e jurídica, (...) em oposição"⁶⁹ aos direitos de liberdade, ou mesmo em "contradição"⁷⁰ com eles, não são

60. Idem, p. 506.

61. Idem, p. 507.

62. Idem, p. 508.

63. Idem, p. 510.

64. Idem, p. 512.

65. Idem, p. 513.

66. Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", in Wesley N. Hohfeld, *Fundamental Legal Concepts as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, New Haven: Yale University Press, 1923, p. 35.

67. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, 3ª ed., Heidelberg: C. F. Müller, 1983, p. 226.

68. Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, 1, Berlin: Vahlen, 1957, B XV 1 b, p. 122.

69. Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, 5ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, p. 169.

70. Walter Schätzel, "Der internationale Schutz der Menschenrechte", in Erich Becker (Org.), *Festschrift für Friedrich Giese*, Frankfurt am Main: Kommentator, 1953, p. 218.

suscetíveis de uma análise racional sem que haja clareza sobre os conceitos de liberdade, de restrições ou de direito a prestações positivas.

Há provavelmente um amplo consenso sobre a necessidade de esclarecimentos sistemático-conceituais e, com isso, sobre a importância da dimensão analítica. Não faltam vozes nesse sentido. Lerche, por exemplo, acentua o "valor que todo contorno formal e retilíneo possui, o valor da clareza constitucional";⁷¹ Kloepfer adverte acerca de uma "perigosa subestimação do formal";⁷² e a crítica de ForsthoFF sobre uma "desformalização da Constituição" deve ser interpretada, em sua ligação com as referências à "escola matemática na Economia Política" e à "corrente lógica na Filosofia moderna",⁷³ também no sentido de um postulado por uma clareza sistemático-conceitual. É de se esperar controvérsia, por outro lado, quando se trata de definir o peso que a dimensão analítica deve ter em relação às dimensões empírica e normativa no trabalho jurídico. Tal controvérsia conduz às questões fundamentais do método jurídico, desde há muito discutidas.

A atividade na dimensão analítica coincide em grande medida com aquilo que é denominado, pela jurisprudência dos conceitos, de "tratamento lógico do direito".⁷⁴ Uma formulação clássica desse programa é a de Laband: "Eu sei perfeitamente que a dominação *exclusiva* do tratamento lógico do direito seria de uma unilateralidade extremamente desvantajosa e, em determinadas relações, levaria a uma atrofia de nossa ciência. Eu não desconheço nem o significado das pesquisas histórico-jurídicas (...), nem o valor que História, Economia, Política e Filosofia têm para a cognição do direito. A dogmática não é a *única* face da Ciência do Direito, mas é uma delas. A tarefa científica da *dogmática* de um determinado direito positivo consiste na construção de institutos jurídicos, na remissão dos enunciados ju-

71. Peter Lerche, "Rezension: Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*", *DÖV* 18 (1965), p. 213.

72. Michael Kloepfer, *Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandschutz*, München: Beck, 1970, p. 26.

73. Ernst ForsthoFF, "Die Umbildung des Verfassungsgesetzes", in Hans Barion *et al.* (Orgs.), *Festschrift für Carl Schmitt*, Berlin: Duncker & Humblot, 1959, p. 52.

74. Cf. as referências em Werner Krawietz, "Begriffsjurisprudenz", in Joachim Ritter *et al.*, *Historisches Wörterbuch der Philosophie*, v. 1, Basel: Schwabe, 1971, colunas 809 e ss.; cf. também Werner Krawietz (Org.), *Theorie und Technik der Begriffsjurisprudenz*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.

rídicos particulares a conceitos mais gerais e, também, na dedução das conseqüências que decorrem de tais conceitos. Isso significa, abstração feita à análise dos enunciados jurídicos positivos válidos, isto é, do conhecimento e do domínio completo do material a ser trabalhado, uma atividade mental puramente lógica. Para a solução dessa tarefa, não há nenhum outro meio que não a Lógica; para tal fim, não há como substituí-la; todas as considerações históricas, políticas e filosóficas – por mais valiosas que possam ser – são, para a dogmática de um material jurídico concreto, sem relevância e, com frequência, servem apenas para camuflar a carência de trabalho construtivo”.⁷⁵ O que Laband descreve como “tratamento lógico do direito” tem sido objeto de veemente crítica, desde a polêmica metodológica levada a cabo principalmente por civilistas no início do século XX.⁷⁶ Na teoria do direito público essa discussão ocorreu com um certo atraso, especialmente nos anos 1920.⁷⁷

Autores tão diversos como Smend, Kaufmann, Heller e Schmitt estavam unidos na rejeição da tradição positivista-analítica marcada por Gerber, Laband, Jellinek e Kelsen. Smend caracterizava a “linha Jellinek-Kelsen” como um “beco sem saída sem fim e sem objetivo”⁷⁸ e defendia a substituição do “formalismo jurídico” por uma teoria do direito público baseada em um “método das ciências humanas”.⁷⁹ Kaufmann censurava a corrente analítica de orientação neokantiana por “eliminar o conteúdo humano dos conceitos jurídicos”⁸⁰ e por ser

75. Paul Laband, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*, 2ª ed., v. 1, Freiburg: Mohr, 1888, p. X. Cf., além disso, Rudolf v. Jhering, “Unsere Aufgabe”, *Jahrbücher für die Dogmatik* 1 (1857), pp. 7 e ss.; Carl F. W. Gerber, *System des deutschen Privatrechts*, 2ª ed., Jena: Mauke, 1850, pp. V e ss. Para uma exposição mais ampla, cf. também Walter Wilhelm, *Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main: Klostermann, 1958.

76. Cf., nesse sentido, Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 5ª ed., Berlin: Springer, 1983, pp. 43 e ss.

77. Cf. Manfred Friedrich, “Die Grundlagendiskussion in der Weimarer Staatsrechtslehre”, *Politische Vierteljahresschrift* 13 (1972), pp. 582 e ss.; Kurt Sontheimer, “Zur Grundlagenproblematik des deutschen Staatsrechtslehre in der Weimarer Republik”, *ARSP* 46 (1960), pp. 39 e ss.

78. Rudolf Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht (1928)”, in, do mesmo autor, *Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1968, p. 124.

79. Idem, pp. 119 e ss.

80. Erich Kaufmann, *Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie*, Tübingen: Mohr, 1921, p. 75.

"responsável (...) pelo extraordinário baixo nível cultural de grande (...) parte de nossa Ciência do Direito".⁸¹ Heller falava de um "formalismo inteiramente sem substância ou vínculos"⁸² e de um "caminho errôneo que nossa Teoria do Estado trilha há duas gerações, por acreditar ser necessário evitar todos os problemas sociológicos e éticos de nossa vida estatal".⁸³ Carl Schmitt sustentava que "apenas o absurdo ideológico, econômico, moral e político resta como característica específica única de uma forma de pensar sem dúvida pura e exclusivamente jurídica".⁸⁴⁻⁸⁵

Na medida em que se critica, com tais posições, uma redução da Ciência do Direito à dimensão analítica, é de se concordar com elas. A Ciência do Direito somente pode cumprir sua tarefa prática sendo uma disciplina multidimensional. A conhecida frase de Windscheid – "A decisão é o resultado de uma conta na qual os fatores são os conceitos jurídicos"⁸⁶ – expressa uma superestimação das possibilidades da Lógica. A análise lógica demonstra exatamente que, nos casos minimamente problemáticos, a decisão não tem como ser tomada com base apenas nos meios da Lógica, a partir de normas e conceitos jurídicos pressupostos.⁸⁷ Para tanto, são necessários valores adicionais e, como fundamento desses valores, conhecimentos empíricos. Um tratamento lógico que, prescindindo dessas premissas adicionais, alcance resultados e, nesse sentido, pretenda ser *produtivo* só pode ser um método pseudológico, que encobre as premissas normativas necessárias para uma fundamentação lógica realmente concludente. Isso era o que Jhering (em sua segunda fase) tinha em mente quando rechaça-

81. Idem, p. 76.

82. Hermann Heller, "Die Krisis der Staatslehre (1926), in *Gesammelte Schriften*, v. 2, Leiden: Sijthoff, 1971, p. 9.

83. Idem, p. 15.

84. Carl Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, Hamburg: Hanseatische Verlags-Anstalt, 1934, pp. 39-40.

85. Fora dessa série encontra-se a polêmica de Ehrlich contra a "perspicácia estéril". Contudo, vale mencioná-la, porque ela é marcada por uma tendência antianalítica até hoje não amansada: "A perspicácia é o mais estéril dentre os dons do espírito humano: há uma profunda sabedoria nas lendas populares alemãs que, com frequência, chamam o diabo de um dialético perspicaz" (Eugen Ehrlich, "Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft", in *Gesammelte Schriften*, Berlin: Duncker & Humblot, 1967, p. 202).

86. Bernhard Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, v. 1, 9ª ed., Frankfurt am Main: Buddeus, 1906, p. 111.

87. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 273 e ss.

va o “culto ao lógico, que imagina elevar a jurisprudência a uma matemática do direito”.⁸⁸

Assim como são procedentes as objeções contra uma redução da Ciência do Direito à dimensão analítica e contra toda tentativa de fundamentar as decisões jurídicas *apenas* com os meios da Lógica, é improcedente a clara subestimação do analítico presente nas opiniões expostas. Sem uma compreensão sistemático-conceitual a Ciência do Direito não é viável como uma disciplina racional. A medida de racionalidade do direito depende em grande parte do nível alcançado pela dimensão analítica. Sem clareza analítica nem mesmo seriam possíveis enunciados precisos e fundamentados sobre a interação das três dimensões. Seria impossível falar de um controle racional das valorações indispensáveis à Ciência do Direito e de uma aplicação metodologicamente controlada do saber empírico. Se há algo que pode livrar ao menos um pouco a ciência dos direitos fundamentais da retórica política e das idas e vindas das lutas ideológicas é o trabalho na dimensão analítica. Se acrescentarmos que na dimensão analítica da Ciência do Direito são possíveis conhecimentos que, em primeiro lugar, não podem ser substituídos por conhecimentos de nenhuma outra ciência e que, em segundo lugar, estão entre os conhecimentos mais seguros da Ciência do Direito, há, então, motivos suficientes para se designar e praticar a análise sistemático-conceitual do direito como *opus proprium* da Ciência do Direito.⁸⁹

Portanto, a despeito das falhas do “tratamento lógico”, não há como ignorar o que nele há de correto e imprescindível para o direito. E há ainda menos motivos para tanto quando se tem em mente que a moderna Lógica; a Teoria da Ciência e a Filosofia Prática fornecem instrumentos que prometem um desenvolvimento frutífero da pesquisa jurídico-conceitual já existente,⁹⁰ bem como sua incorporação a um modelo abrangente de uma teoria integrativa. Nesse sentido, a teoria estrutural aqui pretendida pertence à grande tradição analítica da jurisprudência dos conceitos.

88. Rudolf v. Jhering, *Geist des römischen Rechts*, v. 3, 5ª ed., Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1906, p. 321. Cf., além disso, Eugen Ehrlich, *Die juristische Logik*, Tübingen: Mohr, 1918, pp. 299 e ss.; Philipp Heck, *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Tübingen: Mohr, 1932, pp. 94 e ss.

89. Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, p. 112.

90. Como exemplo, cf. a teoria dos *status* de Jellinek, analisada no Capítulo 5.

Capítulo 2

O CONCEITO DE NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Entre o conceito de norma de direito fundamental e o conceito de direito fundamental há estreitas conexões.¹ Sempre que alguém tem um direito fundamental, há uma norma que garante esse direito. Se a recíproca é verdadeira, isso já é duvidoso. Ela não é verdadeira quando há normas de direitos fundamentais que não outorgam direitos subjetivos. Seria possível responder à pergunta acerca da existência desse tipo de normas por meio da definição segundo a qual são consideradas como normas de direitos fundamentais somente as normas que outorgam direitos fundamentais. Direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais seriam, assim, sempre dois lados da mesma moeda. Para uma teoria relacionada ao direito positivo tal caminho não é,

1. A existência de uma estreita conexão não significa que não se possa diferenciar entre norma de direito fundamental e direito fundamental. Há numerosos exemplos de uma diferenciação deficiente nesse âmbito. A menção a dois deles é suficiente: o Tribunal Constitucional Federal, por exemplo, fala que ele “só [pode] decidir se uma regulamentação legal está de acordo com as *normas* da Constituição, especialmente com os *direitos fundamentais* (...)” (BVerfGE 21, 73 (78); sem grifos no original), e Breuer utiliza a expressão “direitos fundamentais como normas de pretensão” como título de um artigo sobre o conteúdo das “pretensões de direitos fundamentais” (Rüdiger Breuer, “Grundrechte als Anspruchsnormen”, in Otto Bachof et al. (Orgs.), *Verwaltungsrecht zwischen Freiheit, Teilhabe und Bindung*, München: Beck, 1978, p. 89). Uma clara diferenciação entre norma de direito fundamental e direito fundamental é feita, por exemplo, por Walter Schmidt-Rimpler/Paul Gieseke/Ernst Friesenhahn/Alexander Knur, “Die Lohnungleichheit von Männern und Frauen”, AöR 76 (1950), p. 172, e Ernst Friesenhahn, “Der Wandel des Grundrechtsverständnisses”, in *Verhandlungen des fünfzigsten Deutschen Juristentages*, v. II, München: Beck, 1954, p. G4, bem como por Friedrich Klein, “Vorbemerkung”, in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, 1, A VI, p. 79.

contudo, recomendável. Isso porque às disposições do catálogo de direitos fundamentais são atribuídas normas às quais não corresponde diretamente nenhum direito subjetivo. Se isso é, ou não, correto é uma questão de interpretação do direito positivo, que não pode ser resolvida por intermédio de uma simples definição. Uma definição segundo a qual somente normas que outorguem direitos subjetivos podem ser consideradas como normas de direitos fundamentais poderia ter como consequência a existência de normas que, ainda que estabelecidas por enunciados contidos no catálogo de direitos fundamentais, não poderiam ser chamadas de “normas de direitos fundamentais”. Tal terminologia parece inadequada. É recomendável, por isso, tratar o conceito de norma de direito fundamental como um conceito que pode ser mais amplo que o conceito de direito fundamental. Isso e o fato de que toda pretensão à existência de um direito fundamental pressupõe a validade de uma norma de direito fundamental correspondente justificam iniciar com uma análise do conceito de norma de direito fundamental.²

I – DO CONCEITO DE NORMA

Normas de direitos fundamentais são normas. Por isso, o conceito de norma de direito fundamental compartilha de todos os problemas que dizem respeito ao conceito de norma. O conceito de norma é um dos conceitos fundamentais da Ciência do Direito, talvez o mais fundamental de todos. Isso não significa que a utilização do termo “norma” se restrinja à Ciência do Direito. Tal palavra tanto quanto outras a ela relacionadas, como “regra”, “mandamento” ou “preceito”, são de uso corrente, não só na linguagem coloquial como também em outras ciências, como na Sociologia, na Etnologia, na Filosofia Moral e na Linguística. O emprego do termo “norma”, em todos esses âmbitos, é caracterizado pela variedade de sentidos com que isso ocorre,³ pela

2. Com isso não se pretende tomar posição sobre o clássico problema acerca da prioridade do direito ou do dever, da norma objetiva ou do direito subjetivo. Esse problema diz respeito primariamente a questões substanciais. Cf., a esse respeito, John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford: Clarendon Press, 1980, pp. 205 e ss.

3. Uma abrangente exposição, tanto da diversidade da terminologia quanto da multiplicidade de significados a ela relacionados na Sociologia, pode ser encontrada em Rüdiger Lautmann, *Wert und Norm: Begriffsanalysen für die Soziologie*, 2ª ed., Opladen: Westdeutscher Verlag, 1971, pp. 54 e ss. Uma das mais fecundas tentativas

vagueza que o acompanha em todos esses sentidos e pelas disputas que sempre suscita, disputas que são intermináveis quando tal termo é empregado fora de seu uso mais óbvio.

1. Da polêmica acerca do conceito de norma

Não é de surpreender que a discussão acerca do conceito de norma como conceito fundamental da Ciência do Direito não tenha fim. Toda definição desse conceito implica decisões sobre o objeto e o método da disciplina, ou seja, sobre seu próprio caráter. Dessa forma, a fundamentação daquilo que se sustenta variará conforme se entenda norma como o "sentido (objetivo) de um ato pelo qual se ordena ou se permite e, especialmente, se autoriza uma conduta"⁴ ou uma "expectativa de comportamento contrafaticamente estabilizada",⁵ como um imperativo⁶ ou um modelo de conduta que ou é respeitado ou, quando não, tem como consequência uma reação social,⁷ como uma expressão com uma forma determinada⁸ ou uma regra social.⁹ Ainda que em medidas diversas, os problemas sugeridos por essa enumeração são importantes para as análises a serem aqui feitas. Por outro lado, esse não é seu objeto. Isso sugere que se busque um modelo de norma que, de um lado, seja sólido o suficiente para constituir a base das análises que se seguirão e, de outro lado, suficientemente frágil para que seja compatível com o maior número possível de decisões no campo dos problemas mencionados. Essas exigências são satisfeitas por um modelo semântico, compatível com as mais variadas teorias sobre validade.

de sistematização foi levada a cabo por Georg H. v. Wright, *Norms and Action*, London: Routledge & Kegan Paul, 1963, pp. 1 a 16.

4. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, p. 5.

5. Niklas Luhmann, *Rechtssoziologie*, v. 1, Reinbeck: Rowohlt, 1972, p. 43.

6. John Austin, *Lectures on Jurisprudence*, 4ª ed., vol. 1, London: Murray, 1873, p. 98.

7. Theodor Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, 2ª ed., Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1964, pp. 61-62 e 68 e ss.

8. Jerzy Wróblewski, "The problem of the meaning of the legal norm", in, do mesmo autor, *Meaning and Truth in Judicial Decision*, Helsinki: Juridica, 1979, p. 15.

9. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon, 1961, pp. 54 e ss.

2. O conceito semântico de norma

O ponto de partida desse modelo consiste na diferenciação entre *norma* e *enunciado normativo*.¹⁰ Um exemplo de enunciado normativo seria o seguinte texto:

- (1) "Nenhum alemão pode ser extraditado" (art. 16, § 2º, 1, da Constituição alemã).

Esse enunciado expressa a norma segundo a qual é proibida a extradição de um alemão. Que é proibido que um alemão seja extra-

10. Tal diferenciação é feita, de fato, por diversos autores, mas a terminologia é bastante vacilante e há uma série de diferenças tanto na fundamentação dessa diferenciação quanto naquilo que diz respeito às consequências dela advindas. A terminologia aqui adotada coincide com a de Christiane Weinberger e Ota Weinberger (cf. Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, München: Beck, 1979, pp. 20 e 108). Ross diferencia entre a "forma linguística que expressa uma diretiva" e a "diretiva" (Alf Ross, *Directives and Norms*, London: Routledge & Kegan Paul, 1968, pp. 34 e ss.). A "diretiva" é o que aqui é chamado de "norma". Ele, no entanto, dá outro significado ao conceito de "norma", como será exposto mais adiante. Segundo Hans J. Wolff, o termo "norma" significa o "conteúdo (sentido) imperativo expresso por um 'enunciado jurídico'" (Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, I, 9ª ed., München: Beck, 1974, p. 115). Georg H. v. Wright emprega as expressões "formulação normativa" e "norma", mas tal diferenciação não coincide totalmente com a tese aqui defendida acerca da relação entre enunciado normativo e norma (Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 93-94). Rottleuthner adota a terminologia de von Wright (cf. Hubert Rottleuthner, *Rechtstheorie und Rechtssoziologie*, p. 42). Já a expressão "enunciado normativo" é por ele empregada, na esteira de Kelsen, para designar enunciados sobre a validade de uma norma. Kelsen chama tais enunciados de "enunciados jurídicos" e os contrapõe às "normas jurídicas" (Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, p. 73). Kelsen emprega a expressão "norma" de forma diversa da aqui proposta, pois segundo ele só é norma aquilo que tem "objetivamente o sentido do dever-ser", o que para ele significa poder ser reconduzido a uma norma fundamental que fundamenta a validade objetiva (idem, pp. 7-8). Mesmo que desconsiderado isso, é difícil integrar a concepção de Kelsen no modelo aqui utilizado. Segundo Kelsen a norma é o "sentido de uma vontade, um ato de vontade" (Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, Wein: Manz, 1979, p. 2; cf. também, do mesmo autor, *Reine Rechtslehre*, pp. 4 e ss.), o que parece ser algo completamente distinto do sentido ou significado de um enunciado. O sentido de um ato de vontade é caracterizado por Kelsen da seguinte forma: "que o outro deve se comportar de uma determinada maneira" (idem, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 31). Nesse sentido, ele afirma: "por 'norma' designa-se que algo *deve* ser ou acontecer, especialmente que uma pessoa *deve* se comportar de uma determinada maneira" (idem, *Reine Rechtslehre*, p. 4). Mas isso é exatamente o que aqui se entende por "norma". Se se desconsideram os elementos mentalísticos (vontade, ato de vontade), parece haver relações estreitas entre o modelo aqui utilizado e a concepção de Kelsen.

ditado é o que significa o enunciado “nenhum alemão pode ser extraditado”. Uma norma é, portanto, o significado de um enunciado normativo.¹¹

A necessidade de se diferenciar entre enunciado normativo e norma pode ser percebida pelo fato de que a mesma norma pode ser expressa por meio de diferentes enunciados normativos. Assim, a norma segundo a qual é vedada a extradição de um alemão pode ser expressa, ao invés de por meio de (1), por exemplo, por meio de:

(1') É proibido extraditar alemães.

Ou:

(1'') Alemães não podem ser extraditados.

Ou, ainda, por intermédio de um enunciado em outro idioma. É relativamente fácil reconhecer que esses enunciados expressam normas, pois eles contêm expressões como “proibido” ou “não podem”. No entanto, normas podem também ser expressas sem a utilização de tais termos. Exemplos disso oferecem as fórmulas do Código Penal alemão, como a do § 223, 1: “Quem causar lesão corporal a alguém ou danos à sua saúde será punido com até três anos de prisão ou com multa em dinheiro”. Com esse enunciado, como se percebe pelo contexto, não se diz que algo é, mas que algo deve ser. Também a norma segundo a qual é proibida a extradição de um alemão poderia ser expressa por uma fórmula do mesmo tipo, como:

(1''') Alemães não serão extraditados.

É de se salientar, além disso, que normas podem ser também expressas sem a utilização de enunciados, como é o caso, por exemplo, das luzes de um semáforo.

Isso faz com que fique claro que o conceito de norma é, em face do conceito de enunciado normativo, o conceito primário.¹² É recomendável, portanto, que os critérios para a identificação de normas sejam buscados no nível da norma, e não no nível do enunciado normativo. Tal critério pode ser formulado com o auxílio das modalidades deônticas, dentre as quais serão mencionadas, neste passo, apenas as moda-

11. Cf. também Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, pp. 20 e 108, bem como, em relação à “forma linguística que expressa uma diretiva”, Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 34.

12. Cf. Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 102-103.

lidades básicas do dever, da proibição e da permissão. O que exatamente deve ser entendido por modalidades deônticas, quantas existem, quais estruturas elas assumem e como se relacionam entre si é algo que será discutido mais adiante. Para se esclarecer o problema em questão aqui, é suficiente recorrer à modalidade da proibição, já reiteradamente utilizada nos exemplos. Sobre a utilização dessa modalidade, pode-se dizer que o enunciado “alemães não serão extraditados” (1’’) expressa uma norma e é, portanto, um enunciado normativo, pois expressa a proibição de extradição de alemães.

Isso conduz à indagação sobre o que é uma proibição e como é possível reconhecer se um enunciado, como o utilizado acima, expressa uma proibição. À primeira questão podem ser dadas respostas como: uma proibição é a negação de uma permissão. Mas o que é uma permissão? Se se obtém como resposta que permissão é a negação de uma proibição, não há como não se objetar que se esteja movendo em círculos. A essa objeção pode-se facilmente associar uma outra, segundo a qual, caso não seja possível encontrar uma melhor resposta para o conceito de proibição, então, não há como utilizar esse conceito na definição do conceito de norma. Contra essa objeção é possível argumentar que a exigência de uma definição para todo conceito por meio de um conceito novo implica um regresso infinito e é, por isso, impossível de ser satisfeita. Assim, se se quer dizer alguma coisa, é necessário partir de conceitos que, dentro do sistema de conceitos pressuposto, não são definidos por nenhum conceito adicional. Isso não significa que o campo dos conceitos básicos é dominado pelo arbítrio. Procurar-se-á demonstrar que os conceitos deônticos básicos aqui utilizados encontram-se em uma ordem bem definida entre eles. É necessário também examinar se é possível, com a ajuda deles, reproduzir a estrutura da linguagem jurídica de forma adequada. Por fim, é necessário demonstrar sua aptidão para alicerçar a construção de uma teoria dos direitos fundamentais que seja fecunda.

À segunda pergunta, isto é, sobre como é possível reconhecer se um enunciado, por exemplo, um enunciado indicativo de um Código Penal, expressa uma norma, deve ser respondido que isso é possível com base em seu contexto. Por “contexto” devem ser entendidos não somente os outros enunciados que estão em conexão com esse enunciado, mas também seu uso, isto é, as circunstâncias e regras de sua utilização. O fato de que, dessa forma, seja indispensável o recurso a

considerações pragmáticas para a identificação de algo como norma em nada altera o fato de que aquilo que é identificado é uma entidade semântica, isto é, um conteúdo de significado que inclui uma modalidade deôntica.¹³

Toda norma pode ser expressa por um enunciado normativo. Como já foi demonstrado, é possível expressar uma norma de diversas maneiras. Dentre essas diversas formas, é conveniente que uma delas seja distinguida. Essa forma ocorre, por exemplo, quando a norma segundo a qual é proibido extraditar um alemão é expressa por enunciados como (1) "nenhum alemão pode ser extraditado", (1') "é proibido extraditar alemães" ou (1'') "alemães não podem ser extraditados". Enunciados como estes são caracterizados pelo uso de *expressões deônticas* como "permitido", "proibido" e "devem". Por essa razão devem eles ser chamados de "enunciados deônticos".¹⁴

Uma outra expressão deôntica é a expressão "tem direito a (...)".¹⁵ Locuções como "tem direito a (...)" expressam modalidades deônticas complexas, como será visto mais adiante. É por isso que enunciados normativos, como "todos os alemães têm direito de formar associações e sociedades" (art. 9º, § 1, da Constituição alemã), são também

13. Nesse contexto, Ross afirma que, assim como as afirmações têm um elemento específico indicativo – "assim é" –, as diretivas têm um "elemento específico diretivo 'assim deve-ser'" (Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 13 e 34). Hare designa esses elementos, em um desenvolvimento de sua conhecida diferenciação entre nêustica e frástica (cf. Richard M. Hare, *The Language of Morals*, Oxford: Clarendon Press, 1952, p. 18), como trópica, à qual pertence o que se diz e não o que se faz, como é o caso da nêustica (cf. Richard M. Hare, "Meaning and speech acts", in Richard M. Hare, *Practical Inferences*, London: Macmillan, 1971, p. 90). Cf., a esse respeito, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 83 e ss. O que aqui é chamado de "modalidade deôntica" corresponde ao que Hare chama de "trópica" e ao que Ross chama de "elemento específico diretivo 'assim deve-ser'".

14. A respeito dessa expressão, cf. Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, p. 96. Há que se salientar que enunciados deônticos não são algo diverso de enunciados normativos, mas sim uma espécie destes. Todos os enunciados deônticos são enunciados normativos, mas nem todo enunciado normativo é um enunciado deôntico. Christiane Weinberger e Ota Weinberger usam a expressão "enunciado deôntico" em um sentido completamente diverso: como um enunciado afirmativo sobre sistemas normativos, ou seja, no sentido daquilo que, mais adiante, será denominado "enunciado de asserções sobre normas" (cf. Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, pp. 99 e 111-112). Mais adiante será às vezes usado, no lugar do termo "deôntico", o termo "deontológico", principalmente em contraposição a termos como "axiológico".

15. Cf., sobre isso, Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 36.

enunciados deônticos. Por outro lado, não são enunciados deônticos nem os *enunciados imperativos*, como “jamais um alemão será extraditado!”, nem os *enunciados indicativos sem expressões deônticas*, como “alemanes não serão extraditados” (1’”). Sempre que esses enunciados expressarem normas, será possível transformá-los em um enunciado deôntico que expresse a mesma norma. Nem todo enunciado normativo é um enunciado deôntico, mas todo enunciado normativo pode ser transformado em um enunciado deôntico. Isso tem uma importância que não deve ser subestimada, pois é possível construir formas padrão para enunciados deônticos que permitam identificar a estrutura das normas que elas expressam. As formas padrão dos enunciados deônticos são o último estágio antes da apresentação da estrutura lógica das normas por meio de uma linguagem baseada em fórmulas.

A relação entre enunciado normativo e norma equivale à relação entre enunciado afirmativo e afirmação.¹⁶ Em vez de afirmação, o significado de um enunciado afirmativo é também denominado “pensamento”¹⁷ ou “proposição”.¹⁸ Costuma-se identificar a diferença decisiva entre enunciados normativos e normas, de um lado, e enunciado afirmativo e afirmação, de outro, no fato de que a respeito de afirmações e enunciados afirmativos faz sentido dizer que eles são verdadeiros ou falsos, enquanto no caso das normas ou dos enunciados normativos isso não é possível.¹⁹ Evitar-se-á, aqui, uma tal suposição baseada em

16. Essa correspondência estrutural é desenvolvida com muito cuidado por Ross, que, no entanto, ao invés de “norma”, fala em “diretiva”. Cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 9 e ss. e 34 e ss. Cf. também Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, pp. 19 e ss., bem como Hans J. Wolff, in Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, I, p. 115, para o qual a diferenciação entre “norma” e “enunciado jurídico” corresponde àquela entre “juízo lógico” e “enunciado lógico”. Cf., para uma visão crítica sobre essa correspondência estrutural, Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 93-94.

17. Assim, por exemplo, Gottlob Frege, “Der Gedanke: Eine logische Untersuchung”, in, do mesmo autor, *Logische Untersuchungen*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966, p. 33, que, além disso, usa “sentido” em vez de “significado”. Também Weinberger fala de normas como pensamentos. Cf. Ota Weinberger, *Logische Analyse in der Jurisprudenz*, Berlin: Duncker & Humblot, 1979, p. 97: “A norma é um pensamento”.

18. Rudolf Carnap, *Meaning and Necessity*, 2ª ed., Chicago: University of Chicago Press, 1956, p. 27.

19. Cf. Gottlob Frege, “Der Gedanke: Eine logische Untersuchung”, p. 34 (em relação a enunciados imperativos); Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, p. 20.

uma teoria da verdade. Para compreender essa diferenciação, é suficiente dizer que com enunciados afirmativos se expressa que algo é, enquanto que com enunciados normativos se expressa que algo é devido, proibido etc. Se resumirmos as diferentes modalidades deônticas ao conceito de dever-ser,²⁰ é possível dizer que enunciados afirmativos expressam algo que *é*, enquanto enunciados normativos expressam algo que *deve-ser*.

A analogia apresentada entre enunciado normativo e norma, de um lado, e enunciado afirmativo e afirmação, de outro, é freqüentemente percebida nas escolhas terminológicas. Isso acontece, por exemplo, quando, em vez das quatro expressões mencionadas, são usadas expressões como “enunciado de normas”, “afirmação normativa”, “enunciado empírico” ou “afirmação empírica”. Também aqui essas expressões serão ocasionalmente utilizadas.

3. *A separação entre questões semânticas e questões relativas à validade*

A concepção semântica do conceito de norma, acima apresentada, distingue de forma estrita entre o conceito de norma e o conceito de sua validade. Um exemplo de uma definição que não distingue esses elementos é a de Alf Ross. Segundo Ross, uma norma é “uma diretiva que corresponde a certos fatos sociais de forma tal que o modelo de conduta expresso na norma (1) é geralmente seguido pelos membros da sociedade, e (2) é encarado por eles como vinculante (válido)”.²¹ Por “diretiva” Ross entende aquilo que aqui é chamado de “norma”. A incorporação de elementos relativos à validade, nesse caso elementos empíricos, no conceito de norma seria necessária para que se possa “dizer que certas normas de fato *existem*, ou *estão em vigor*”.²² Mas a definição de Ross extrapola seus objetivos. Ela não só *possibilita* falar em existência ou em validade de uma norma, mas torna isso também *necessário*, pois, segundo essa definição, somente normas válidas ou normas existentes são normas. Se há um interesse em se falar sobre a validade ou a existência de uma norma, e esse in-

20. Cf., por exemplo, Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 77.

21. Cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 93.

22. Idem, p. 79.

teresse realmente existe, então, há também um interesse em se falar da invalidade e da inexistência de uma norma. Mas, então, o conceito de norma não pode ser definido de forma a pressupor a validade e a existência da norma. Da mesma forma que é possível “expressar um pensamento sem tomá-lo como verdadeiro”,²³ tem que ser também possível expressar uma norma sem classificá-la como válida.

Liberar o conceito de norma de elementos relativos à validade tem, à primeira vista, uma desvantagem, pois o universo das normas se expande sensivelmente. Qualquer um poderia expressar quantas normas quisesse, com qualquer conteúdo. Mas isso não cria nenhum problema sério. Em si, não há diferença entre questionar – para se saber se algo é uma norma – se houve o preenchimento de um determinado critério de validade ou – para se saber se algo é uma norma válida – se esse algo é uma norma e, em caso afirmativo, se preencheu um determinado critério de validade. Mais séria seria uma objeção que demonstrasse que o conceito semântico de norma não reflete tão bem a linguagem coloquial e/ou a linguagem jurídica quanto um conceito enriquecido com elementos relativos à validade. Em uma série de casos essa objeção é com certeza procedente. Na linguagem coloquial a ordem de um assaltante de banco “não me dêem moedas!” dificilmente seria classificada como a expressão de uma norma.²⁴ Por outro lado, há uma série de expressões que são mais bem compreendidos pelo conceito semântico de norma. Se por “norma” forem entendidas apenas as normas válidas, então, um enunciado tão simples como “essa norma não é mais válida” passa a ser contraditório. Também enunciados como “essa norma deveria ser válida” criariam dificuldades. Além disso, no caso do ladrão de banco, não são somente razões ligadas à teoria da validade que fazem com que o uso do termo “norma” seja duvidoso, mas também a estrutura lógica daquilo que é expresso. A linguagem coloquial resiste em considerar

23. Gottlob Frege, “Der Gedanke”, p. 35.

24. Nesse caso, o modelo kelseniano – segundo o qual uma ordem desse tipo, por falta de autorização ao ladrão de bancos, tem apenas “subjetivamente o sentido de dever-ser”, mas não objetivamente, e, por isso, não é a expressão de uma norma (Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 8 e ss.) – reflete melhor que o modelo semântico o sentido usual de norma. Também Ross considera que o ladrão de bancos não expressa nenhuma norma. Ele fundamenta sua posição ao afirmar que se trata apenas de um acontecimento passageiro. Cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 80.

normas individuais,²⁵ como aquelas expressas em decisões judiciais, como "normas". Se o ladrão de bancos tivesse dito "em todo primeiro dia do mês todos os caixas do banco devem ter cédulas de dinheiro à disposição!", haveria menos resistências em se falar em uma norma (inválida). Poder-se-ia dizer, de forma geral, que a objeção de não-correspondência com a linguagem coloquial e com a linguagem jurídica refere-se não tanto a problemas relativos à validade, mas sim à inclusão de normas com uma determinada estrutura, como as normas individuais, no conceito de norma. A linguagem coloquial e a linguagem técnica prevalente são importantes na construção de conceitos científicos, mas não são, de forma alguma, critérios decisivos. O decisivo é sua funcionalidade. O conceito semântico de norma certamente não é igualmente adequado a todas as finalidades, mas quando se trata de problemas da dogmática jurídica e da aplicação do direito é sempre mais adequado que qualquer outro conceito de norma. Esses âmbitos dizem respeito a questões como a de saber se duas normas são logicamente compatíveis, quais são as consequências de uma norma, como interpretá-la e aplicá-la, se ela é válida e, algumas vezes, se a norma, quando inválida, deveria ser válida. O conceito semântico de norma é adequado exatamente para lidar com essas questões.²⁶

4. *A conexão entre questões semânticas e questões relativas à validade*

Uma outra vantagem do conceito semântico de norma consiste no fato de ele não apenas ser compatível com as mais variadas teorias da validade como, também, ser pressuposto por elas. Por teoria da validade deve ser entendida uma teoria que forneça critérios para se saber quando uma norma é válida. De forma simplificada, a estrutura formal do cerne de diferentes teorias da validade pode ser expressa da seguinte forma: se a norma *N* satisfaz os critérios $K_1, \dots, K_n$, então, *N* é válida. As diversas teorias da validade podem ser distinguidas com base nos diferentes tipos de critérios utilizados. Se se faz menção a

25. Sobre o conceito de norma individual, cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 106 e ss.; Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, p. 20.

26. Cf., sobre isso, Hajime Yoshino, "Zur Anwendbarkeit der Regeln der Logik auf Rechtsnormen", in Hans-Kelsen-Institut (Org.), *Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion*, Wien: Manz, 1982, pp. 146 e ss.

fatos sociais, como, por exemplo, a obediência regular à prescrição normativa, aliada a um sentimento de vinculação,²⁷ ou a alternativa entre cumprimento e sanção para o não-cumprimento,²⁸ trata-se, então, de uma teoria *sociológica* da validade. Se se menciona a edição por uma autoridade cuja competência deriva de uma norma de nível superior,²⁹ deve-se falar em teoria *jurídica* da validade. Quando se vê uma razão moral, como, por exemplo, uma “lei natural”,³⁰ como fundamento de validade, está-se diante de uma teoria *ética* da validade.³¹ Os diversos problemas relacionados à subsunção das teorias da validade a esses três conceitos não têm aqui grande interesse.³² O que é

27. Cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 82 e ss., 93.

28. Cf. Theodor Geiger, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, pp. 68 e ss.

29. Cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 200 e ss.

30. Cf., por exemplo, Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten* (Akademie-Ausgabe), in *Kant's gesammelte Schriften*, v. VI, Berlin: Reimer, 1907/14, p. 224.

31. Sobre a tripartição do conceito de validade em um conceito sociológico, um conceito jurídico e um conceito ético de validade, cf. Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, pp. 194 e ss.; cf. também Jerzy Wróblewski, “Three concepts of validity of law”, *Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland* 118 (1982), pp. 408 e ss., que distingue entre validade sistêmica, fática e axiológica.

32. Digno de menção especial é o problema de se saber se os três conceitos de validade mencionados estão categorialmente no mesmo nível. O conceito jurídico de validade dá ensejo a esse questionamento. De acordo com ele, a validade de uma norma baseia-se na validade de uma outra norma hierarquicamente superior na estrutura escalonada do ordenamento jurídico, a qual outorga competência para a criação da norma em questão. Quando se questiona a validade da norma autorizadora, é necessário recorrer a uma outra norma. Como esse processo não pode continuar infinitamente, é preciso interrompê-lo com o recurso a algum tipo qualquer de norma fundamental. Se não se pretende conceber essa norma fundamental como condição de validade meramente transcendental-lógica ou fictícia (cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 204 e ss.: “pressuposto transcendental-lógico”; do mesmo autor, *Allgemeine Theorie der Normen*, pp. 206 e ss.: “norma imaginária”), e há diversas razões para tanto (cf. Ralf Dreier, “Bemerkungen zur Rechtserkenntnistheorie”, *Rechtstheorie*, Beih. 1 (1979), pp. 95 e ss.; Aleksander Peczenick, “On the nature and function of the *Grundnorm*”, *Rechtstheorie*, Beih. 2 (1981), pp. 279 e ss.), então, só resta fundamentar a norma fundamental por meio de um conceito de validade sociológico ou ético. Mas, nesse caso, o significado do conceito jurídico de validade é reduzido à sua relação com a validade das normas no sistema normativo que sejam criadas com base em normas que autorizam a criação de outras normas. Embora essas normas criadas com base em outras normas sejam uma característica típica dos modernos ordenamentos jurídicos, elas existem também em sistemas normativos que não são ordenamentos jurídicos. Isso poderia sugerir que se fale em apenas dois, ao invés de três, conceitos de validade – um sociológico e um ético – e, no âmbito de cada um desses conceitos, que se diferencie entre uma fundamentação da validade direta e uma indireta (nesse caso, uma

necessário salientar é o fato de que o conceito semântico de norma não pressupõe nem exclui nenhuma dessas teorias. Mas cada teoria, para dizer que algo é válido, tem que ter algo a partir do qual essa afirmação seja possível, e, para tanto, o mais adequado é a norma em seu conceito semântico.

5. *Asserção sobre normas e criação de normas*

Até aqui tratou-se somente das normas e dos enunciados que as expressam, os enunciados normativos. É necessário distinguir ambos tanto da asserção sobre a validade de uma norma como da criação de uma norma. Aquele que sustenta que uma norma é válida, ou que cria uma norma, realiza uma ação. Essa ação pode ser chamada, de acordo com J. L. Austin, de "ato lingüístico".³³ Quando se analisam atos de asserção sobre normas e de criação de normas, abandona-se o âmbito da semântica e adentra-se o da pragmática.

Nem sempre é possível, com base apenas no conteúdo da expressão, reconhecer se se trata de um ato de asserção sobre normas ou de criação normativa. Se à pergunta "posso estacionar aqui?" alguém responde "você pode estacionar aqui", pode ele ter feito coisas diversas. Ele pode ter informado, àquele que perguntou, sobre uma situação jurídica, isto é, sobre uma norma válida; mas ele pode também ter criado uma norma, caso tenha dado autorização para o estacionamento em terreno de sua propriedade.³⁴ O que realmente aconteceu só pode ser verificado com base na situação concreta da declaração. Supondo-se que se trata de uma informação, então, o que foi expresso deve ser entendido como um enunciado sobre o que é permitido de acordo com a ordem jurídica vigente, ou seja, sobre qual norma é válida. Enuncia-

fundamentação que se relacione com a norma autorizadora). No entanto, a manutenção da tripartição justifica-se pelo fato de que na Ciência do Direito a fundamentação da validade por meio da referência a fatos sociais e razões morais ocupa uma posição de menor destaque diante da fundamentação por meio da referência à positividade procedimentalmente correta, que inclui a referência à compatibilidade substancial com normas de hierarquia superior.

33. Cf. John L. Austin, *How to do Things with Words*, London: Oxford University Press, 1962, e John R. Searle, *Speech Acts*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969. Para uma breve exposição da teoria dos atos lingüísticos cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 77 e ss.

34. Cf., sobre o tema, Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 104 e ss.

dos que têm por objetivo informar quais normas são válidas devem ser chamados de “*enunciados sobre validade normativa*”. Dependendo do critério de validade pressuposto, podem ser expressas coisas diversas com esse tipo de enunciados. Normalmente, os casos como o mencionado não dizem respeito nem à obediência fática das regras sobre estacionamento, nem à sua sanção, nem ao que é obrigatório ou permitido a partir de considerações racionais, mas àquilo que é determinado, no âmbito do ordenamento jurídico pressuposto – e em geral eficaz –, em relação à questão do estacionamento. Esse tipo de enunciado sobre validade normativa é passível de uma análise quanto à sua veracidade: eles são ou verdadeiros ou falsos.³⁵

35. Em vez de “enunciados sobre validade normativa”, Kelsen usa a expressão “enunciado jurídico” (Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, p. 73). Aqui, a expressão “enunciado jurídico” é reservada àqueles enunciados normativos que expressam normas jurídicas. Segundo Kelsen, os enunciados sobre validade normativa, relacionados à validade jurídica e passíveis de uma análise quanto à sua veracidade, são os enunciados da ciência jurídica, visto que, na sua opinião, a Ciência do Direito deve limitar-se à descrição do direito (idem, p. 75). De fato, há enunciados sobre a validade de normas, como se verá logo a seguir no texto, que não são passíveis de uma análise quanto à sua veracidade nesse mesmo sentido. Como será demonstrado, essa existência tem sua razão de ser.

É preciso fazer uma distinção entre enunciados sobre o que é válido juridicamente e enunciados sobre o que é válido socialmente. Estaríamos diante de um enunciado desse último tipo se, no caso do estacionamento, embora fosse proibido estacionar, alguém dissesse: “Você pode estacionar aqui tranquilamente”; e acrescentasse: “Todos nós fazemos isso, e a polícia passa todos os dias por aqui e nada faz”.

As classificações feitas aqui são relativamente rudimentares, mas não serão feitas diferenciações adicionais. No caso em questão, essas diferenciações poderiam, por exemplo, ter relação com a possibilidade de aquele que responde às perguntas ser uma pessoa investida de alguma competência legal (juiz, policial) ou uma pessoa sem essa competência, ou ainda com a possibilidade de uma pessoa privada dar uma informação neutra ou expressar uma expectativa ou uma exigência de obediência à norma. Há bons argumentos no sentido de aceitar uma asserção de uma norma em todos os casos e em alguns deles qualificá-las de forma especial ou associá-las a atos lingüísticos adicionais.

É necessário fazer uma distinção entre as asserções explícitas sobre validade e as asserções de normas até aqui analisadas, as quais quando se encontram, por exemplo, em um manual jurídico podem ser realizadas por meio da reprodução do enunciado normativo. Os enunciados expressos no primeiro caso têm a seguinte forma: “Na sociedade *G* (no ordenamento jurídico *R*), a norma *N* é válida no momento *t*” (cf. Hubert Rottleuthner, *Rechtstheorie und Rechtssoziologie*, p. 47). Asserções não-implícitas sobre validade podem ser reconstruídas nos termos dessas asserções explícitas.

Enunciados sobre validade normativa, como os mencionados, não causam em geral grandes dificuldades. Os problemas surgem quando se pressupõe um conceito ético de validade ou, o que é mais plausível, se são aceitos critérios morais em um conceito jurídico de validade. Esses problemas assemelham-se àqueles causados por *asserções interpretativas*, que são uma subclasse dos enunciados sobre validade normativa. Que *status* tem, por exemplo, uma asserção segundo a qual “especialmente as liberdades garantidas pelos art. 2ª (livre desenvolvimento da personalidade), art. 5ª (liberdade de formar e expressar opiniões) e art. 12 (liberdade profissional) da Constituição alemã também conferem uma pretensão à educação e à educação continuada”?³⁶ Essa afirmação diferencia-se, em aspectos fundamentais, daquela sobre o estacionamento. Entretanto, também ela deve ser classificada como uma asserção sobre validade normativa. As razões que podem ser aduzidas a favor dela (ou contra ela) são, contudo, de tipo diverso. Referências a atos de criação normativa ou a outros fatores empíricos não são suficientes. Para se chegar a uma fundamentação completa (procedente ou não) da afirmação sobre a pretensão à educação e à educação continuada são necessárias proposições normativas, que não decorrem nem do material dotado de autoridade pressuposto, nem de observações empíricas. Mas isso não altera nem o caráter da afirmação como um enunciado sobre validade normativa, nem da asserção como uma asserção sobre validade normativa. Da mesma forma que, com base em diferentes critérios de validade, enunciados normativos podem ser qualificados como enunciados sobre normas válidas, podem também as asserções sobre validade normativa pressupor diferentes critérios de correção.

Já foi salientado que, com a exteriorização de um enunciado como “você pode estacionar aqui”, se pode estar realizando não somente uma asserção sobre uma norma, mas também a criação de uma norma. Há criações normativas dos mais variados tipos. Uma criação simples, como a do caso do estacionamento, acontece quando um pai proíbe seus filhos de beber algo durante a refeição enquanto os pratos não estiverem vazios. Por outro lado, tratou-se de uma criação normativa bastante complexa quando, depois da aceitação pelo Conselho Parla-

36. Klaus Grimmer, *Demokratie und Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1980, p. 285.

mentar, em 8.5.1949, e da autorização por parte das forças de ocupação, em 12.5.1949, a Constituição alemã, na semana de 16 a 22.5.1949, foi aceita pelos representantes do povo de dez dos onze Estados Federados e, depois da ratificação dessa aprovação pelo Conselho Parlamentar, em 23.5.1949, foi por este – representado por seu Presidente – promulgada. Criações normativas como esta não são o tipo de ação que a Ciência do Direito realiza ou deve realizar. Já, as considerações sobre ações de criação de normas ou os *enunciados sobre criação normativa*³⁷ que são expressos por essas considerações têm um papel significativo na Ciência do Direito, como argumentos para asserções sobre validade de normas. No âmbito da dogmática dos direitos fundamentais esses enunciados têm, contudo, uma importância secundária, pois é possível partir do pressuposto de que as normas estabelecidas pelos atos de criação mencionados são válidas.

II – A NORMA DE DIREITO FUNDAMENTAL

Até aqui falou-se de normas em geral. A partir de agora deve ser questionado o que são normas *de direitos fundamentais*. Essa questão pode ser formulada de forma abstrata ou concreta. Ela é formulada de forma abstrata quando se indaga por meio de quais critérios uma norma, independentemente de pertencer a um determinado ordenamento jurídico ou a uma Constituição, pode ser identificada como sendo uma norma de direito fundamental. A pergunta assume uma forma concreta quando se questiona que normas de um determinado ordenamento jurídico ou de uma determinada Constituição são normas de direitos fundamentais, e quais não. Neste trabalho o objeto é uma teoria dos *direitos fundamentais da Constituição alemã*. A pergunta a ser feita, portanto, é a segunda e, além disso, em uma versão que se refere a uma determinada Constituição, a Constituição alemã.

Uma resposta simples poderia ser: normas de direitos fundamentais são aquelas normas que são expressas por disposições de direitos fundamentais; e disposições de direitos fundamentais são os enunciados presentes no texto da Constituição alemã, e somente esses enunciados. Essa resposta apresenta dois problemas. O *primeiro* consiste na

37. Sobre esse conceito, cf. Franz v. Kutschera, *Einführung in die Logik der Normen, Werte und Entscheidungen*, Freiburg: Alber, 1973, p. 13.

pressuposição da existência de um critério que permita dividir os enunciados da Constituição alemã entre aqueles que expressam normas de direitos fundamentais e aqueles que não as expressam, já que nem todos os enunciados da Constituição alemã expressam direitos fundamentais. O *segundo* problema consiste em saber se, de fato, aos direitos fundamentais da Constituição alemã pertencem somente aquelas normas expressas diretamente por enunciados da própria Constituição alemã.

1. Norma de direito fundamental e disposição de direito fundamental

Na formulação dos dois problemas acima mencionados, o conceito de enunciado da Constituição alemã desempenha um papel decisivo. Um exemplo de um tal enunciado seria: "Nenhum alemão pode ser extraditado" (art. 16, § 2º, 1). Esse enunciado expressa uma norma. Ele é, por conseguinte, um enunciado normativo. Todos os artigos da Constituição alemã contêm enunciados normativos ou parte de enunciados normativos. A norma expressa pelo enunciado acima é uma norma de direito fundamental. O enunciado pode, por isso, ser chamado de "enunciado normativo de direito fundamental". Mas, em vez dessa expressão um pouco tosca, usar-se-á a expressão corrente "*disposição de direito fundamental*". A questão fundamental, neste ponto, é: o que faz com que um enunciado da Constituição alemã seja uma disposição de direito fundamental? A resposta a essa pergunta pode basear-se em aspectos materiais, estruturais e/ou formais.

Um critério que associa elementos *substanciais* e *estruturais* pode ser encontrado na definição de direitos fundamentais de Carl Schmitt, segundo a qual os direitos fundamentais são "apenas aqueles direitos que constituem o fundamento do próprio Estado e que, por isso e como tal, são reconhecidos pela Constituição".³⁸ Dizer que um direito "constitui o fundamento do próprio Estado" é expressar uma definição substancial. Dos fundamentos do Estado Liberal faz parte, segundo Schmitt, apenas um grupo de direitos, os "direitos individuais de

38. Carl Schmitt, "Grundrechte und Grundpflichten (1932)", in, do mesmo autor, *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1973, p. 190.

liberdade".³⁹ "Direitos fundamentais, ou direitos fundamentais em sentido estrito",⁴⁰ seriam apenas aqueles que tivessem uma determinada estrutura, qual seja, a dos direitos individuais de liberdade.

Uma definição do conceito de direito fundamental como essa, orientada por teses substanciais e estruturais, tem inconvenientes. Ela vincula de antemão o conceito de direito fundamental a uma determinada concepção de Estado, e não há consenso para se afirmar que essa determinada concepção é a concepção da Constituição alemã. Um direito como o direito à garantia de um mínimo existencial⁴¹ não poderia ser classificado como "direito fundamental", ainda que pudesse ser fundamentado com base em normas do catálogo de direitos fundamentais,⁴² visto que não tem a estrutura de um direito de liberdade do Estado de Direito liberal.⁴³ É aconselhável, por isso, e ao contrário do que faz Schmitt, não limitar de antemão o conceito de direito fundamental e, com isso, o conceito de normas de direito fundamental.

O critério de Schmitt é caracterizado pela vinculação de critérios substanciais e estruturais. Poder-se-ia imaginar que seria possível evitar essa indesejada limitação do conceito de norma de direito fundamental por meio de uma orientação baseada apenas naquelas disposições da Constituição alemã que, de alguma forma, garantam direitos subjetivos. Dessa forma, ter-se-ia um conceito puramente *estrutural*. De acordo com esse critério puramente estrutural, o art. 7º, 1, da Constituição alemã ("Todo o sistema escolar está sob a supervisão estatal") não conteria uma disposição de direito fundamental e, por conseguinte, não expressaria uma norma de direito fundamental. Isso teria uma vantagem: somente as normas que garantissem direitos subjetivos seriam, tal como seu próprio nome sugere, consideradas como "normas de direitos fundamentais". Mas haveria também um inconveniente.

39. Idem, p. 206.

40. Idem, p. 207.

41. Sobre esse direito, largamente aceito, cf., com diversas outras referências, Günter Dürig, "Art. 1 Abs. 1", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, §§ 43-44, e "Art. 2 Abs. 2", §§ 26-27. Cf. também Capítulo 9, IV, abaixo.

42. Sobre as diversas possibilidades de construção desse direito – art. 1º, § 1º; art. 2º, § 2º, 2; princípio do Estado Social – cf. Günter Dürig, "Art. 1 Abs. 1", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, §§ 43-44, e "Art. 2 Abs. 2", §§ 26-27.

43. Cf. Capítulo 4, II.1.1.2.

niente, já que aquelas normas que se encontram em uma estreita conexão sistemática e textual com normas que garantem direitos subjetivos não poderiam mais ser abarcadas pelo conceito que melhor expressa essa conexão. Isso e o fato de que uma ampla utilização de expressões como "norma de direito fundamental" ou "disposição de direito fundamental" está sedimentada na tradição da dogmática do direito constitucional⁴⁴ justificam a rejeição desse critério estrutural.

Mais conveniente que basear o conceito de norma de direito fundamental em critérios substanciais e/ou estruturais é vinculá-lo a um critério *formal*, relativo à forma de sua positivação. Segundo esse critério, são disposições de direitos fundamentais, em primeiro lugar, todas as disposições do capítulo da Constituição alemã intitulado "Os Direitos Fundamentais" (arts. 1^a a 19), independentemente daquilo que por meio delas seja estabelecido. Todavia, o que é abrangido por esse critério é ainda muito estreito. Não há dúvidas de que há uma série de outras disposições da Constituição alemã que expressam normas de direitos fundamentais, como, por exemplo, a do art. 103, § 1^a, que garante a todos o direito de serem ouvidos pelo Judiciário. Para a identificação dessas disposições, chamadas de forma precisa por Friedrich Klein de "disposições periféricas associadas",⁴⁵ há o critério formal do catálogo de "direitos" do art. 93, § 1^a, 4a, da Constituição alemã, direitos, esses, que, segundo esse artigo, autorizam o recurso à reclamação constitucional. Se se conjugam ambos os critérios orientados pelo texto da Constituição, poder-se-ia, provisoriamente, definir os conceitos de disposição e de norma de direitos fundamentais da seguinte maneira: *disposições de direitos fundamentais* são aquelas contidas nas disposições dos arts. 1^a a 19 da Constituição alemã, bem como as disposições garantidoras de direitos individuais dos arts. 20, § 4^a, 33, 38, 101, 103 e 104 da Constituição alemã.⁴⁶ *Normas de di-*

44. Cf., por exemplo, Richard Thoma, "Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung im allgemeinen", in Hans C. Nipperdey (Org.), *Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung*, Berlin: Hobbing, 1929, pp. 3 e ss.; Friedrich Klein, "Vorbemerkung", in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, A VI, pp. 78 e ss.

45. Friedrich Klein, "Vorbemerkung", in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, A VII 3, p. 83.

46. Acerca do caráter de direito fundamental do direito de resistência do art. 20, § 4^a, da Constituição alemã, cf. Josef Isensee, *Das legalisierte Widerstandsrecht*, Bad Homburg: Gehlen, 1969, pp. 81 e ss. Um catálogo de disposições periféricas ao catálo-

reitos fundamentais são as normas diretamente expressas por essas disposições.

O que aqui se sustenta acerca dessas definições é apenas que elas são adequadas para uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição alemã. Levando-se em consideração que, no âmbito dos conceitos aqui desenvolvidos, inúmeras diferenciações são possíveis, então, é possível afirmar que essas definições têm quatro vantagens: (1) elas se apóiam da forma mais estreita possível na Constituição alemã; (2) sem que, com isso, excluam considerações de caráter mais geral; (3) por meio delas não escolhem de antemão teses substanciais e estruturais; e (4) elas abrangem, em grande medida, as disposições às quais se costuma atribuir, no debate sobre o tema, um caráter de direito fundamental.

2. Normas de direitos fundamentais atribuídas

Segundo as definições que acabam de ser formuladas, de caráter ainda provisório, são normas de direito fundamental somente aquelas normas que são expressas diretamente por enunciados da Constituição alemã (disposições de direitos fundamentais). É necessário indagar, contudo, se tal conceito não é muito estreito. Para responder a essa pergunta, convém olhar para o art. 5º, § 3º, 1, da Constituição alemã, do qual a seguinte parte interessa aqui:

(2) “(...) a ciência, a pesquisa e o ensino são livres”.

Por meio do contexto em que se insere, principalmente em razão do disposto no art. 1º, § 3º, da Constituição alemã, segundo o qual o legislador, o Poder Executivo e o Judiciário estão vinculados diretamente aos direitos fundamentais, que são considerados direitos diretamente aplicáveis, não resta dúvida de que o enunciado acima não é descritivo, mas normativo. Assim, aquilo que se quer dizer com ele pode ser formulado por meio dos seguintes enunciados deônticos:

go de direitos fundamentais que, com exceção do direito de resistência, coincide com o mencionado no texto pode ser encontrado em Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, 14ª ed., Heidelberg: Müller, 1984, § 277. Sensivelmente mais amplo é o rol de direitos fundamentais que vão além do catálogo da Constituição na classificação de Theodor Maunz, *Deutsches Staatsrecht*, 23ª ed., München: Beck, 1980, pp. 111 e ss. Sua lista inclui, para citar apenas dois exemplos, também os direitos dos deputados (arts. 46 a 48) e a independência dos juízes (art. 97).

(2') É obrigatório que a ciência, a pesquisa e o ensino sejam livres.

Ou:

(2'') A ciência, a pesquisa e o ensino devem ser livres.

A respeito desses três enunciados é possível afirmar que eles expressam de formas diversas a mesma norma *diretamente* estabelecida pelo texto constitucional. Essa norma é, contudo, extremamente indeterminada. Essa indeterminação é de duas espécies: essa norma é tanto *semântica* quanto *estruturalmente aberta*.

Ela é *semanticamente aberta* em razão da indeterminação dos termos "ciência", "pesquisa" e "ensino".⁴⁷ Essa indeterminação pode ser enfrentada por meio do estabelecimento de regras semânticas.⁴⁸ O Tribunal Constitucional Federal cria regras semânticas quando afirma, por exemplo, que a atividade científica é tudo aquilo "que, por seu conteúdo e forma, pode ser encarado como uma tentativa séria e planejada de descobrimento da verdade",⁴⁹ ou quando afirma que não se trata de atividade científica quando "conhecimentos obtidos de forma contemplativa são adotados pelo programa de um partido político – ou seja, de um grupo que, por sua natureza, pretende participar de forma ativa na vida político-estatal – e que os utiliza como razões determinantes de sua ação política".⁵⁰

Aqui interessa somente a primeira das regras mencionadas. Essa regra pode ser formulada da seguinte forma:

(3) Tudo aquilo que, por seu conteúdo e forma, é uma tentativa séria e planejada de descobrimento da verdade é ciência.

De (3) em conjunto com (2'') chega-se a:

(4) Aquilo que, por seu conteúdo e forma, é uma tentativa séria e planejada de descobrimento da verdade deve ser livre.

47. Aqui é possível renunciar a uma análise mais acurada da abertura semântica. Cf., a esse respeito, Hans-J. Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, pp. 191 e ss.; Robert Alexy, "Die logische Analyse juristischer Entscheidungen", *ARSP Beih.* 14 (1980), pp. 190 e ss.

48. Cf., a respeito, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 276 e ss.

49. *BVerfGE* 35, 79 (113).

50. *BVerfGE* 5, 85 (146).

O enunciado (4) expressa uma norma. É possível indagar se uma norma desse tipo é uma norma de direito fundamental. Antes de responder a essa questão, é necessário enfrentar o problema da abertura estrutural, no âmbito do qual essa pergunta surge com especial premência.

A *abertura estrutural*, característica de inúmeras disposições de direitos fundamentais, pode ser identificada no caso do art. 5º, § 3º, 1, da Constituição alemã na impossibilidade de se determinar, a partir do mero dever de que ciência, pesquisa e ensino sejam livres, se essa situação deve ser realizada por meio de ação estatal ou se exige abstenções estatais, e se a existência ou a realização dessa situação pressupõe ou não a existência de direitos subjetivos dos cientistas que digam respeito à liberdade científica. Em sua decisão sobre a lei provisória sobre o ensino superior integrado na Baixa Saxônia, o Tribunal Constitucional Federal fornece, entre outras, a seguinte resposta à pergunta mencionada:

- (5) "O Estado deve possibilitar e promover o exercício da liberdade científica e sua transmissão às gerações futuras por meio da disponibilização de meios pessoais, financeiros e organizacionais".⁵¹

E:

- (6) "Todo aquele que atua na área científica, de pesquisa e de docência – respeitado o dever do art. 5º, § 3º, 2, da Constituição alemã – tem o direito à defesa contra qualquer interferência estatal no processo de obtenção e transmissão de conhecimentos científicos".⁵²

Não há dúvida de que esses enunciados expressam normas. Mas expressam eles normas de direitos fundamentais?

Contra o entendimento de que essas normas são normas de direitos fundamentais pesa o fato de que elas não coincidem com a norma diretamente expressa pelo art. 5º, § 3º, 1, da Constituição alemã, nem delas diretamente decorrem. Assim, não se vai contra o disposto no art. 5º, § 3º, 1, se ele for interpretado exclusivamente como uma proibição de afetação negativa, ou seja, se se nega (5). O texto dessa disposição, isoladamente considerado, não fornece informações adicio-

51. BVerfGE 35, 79 (114-115).

52. BVerfGE 35, 79 (112-113).

nais sobre a garantia de um direito subjetivo, ou seja, sobre a validade de (6). Isso faz com que fiquem claras as consequências da interpretação, à primeira vista bastante plausível, segundo a qual só são normas de direitos fundamentais aquelas diretamente expressas pelo texto constitucional. Uma tal interpretação levaria, no caso do art. 5º, § 3º, 1, à conclusão de que no âmbito da ciência, da pesquisa e do ensino existiria somente uma norma de direito fundamental, a saber, a norma que pode ser expressa, por exemplo, da seguinte forma:

(2º) Ciência, pesquisa e ensino devem ser livres.

Essa interpretação não pode ser considerada como errada, mas para a interpretação contrária há argumentos mais fortes. Para decidir um caso como o da lei provisória sobre o ensino superior integrado na Baixa Saxônia é preciso eliminar a indeterminação que essa norma apresenta no que diz respeito à sua estrutura. Nesse caso, é preciso recorrer a normas como as normas (5) e (6). Isso demonstra que tais normas guardam mais que uma relação casual com o texto constitucional. Elas são necessárias quando a norma expressa pelo texto constitucional tem que ser aplicada a casos concretos. Se normas desse tipo não fossem aceitas, não ficaria claro o que é obrigado, proibido ou permitido de acordo com o texto constitucional (isto é, de acordo com a norma por ele diretamente expressa). Esse tipo de relação entre as normas mencionadas e o texto constitucional deve ser denominado "*relação de refinamento*".⁵³ Além dessa, há uma segunda relação especial com o texto constitucional, isto é, com a norma por ele diretamente expressa. Na medida que o Tribunal Constitucional Federal aceita as normas anteriormente mencionadas, ele pressupõe que elas devem ser aceitas *porque* a Constituição contém o art. 5º, § 3º, 1. Trata-se, portanto, de uma *relação de fundamentação* entre a norma a ser refinada e a norma que a refina. Essas duas relações justificam considerar como normas de direitos fundamentais não somente normas que são expressas diretamente pelo texto constitucional, mas também normas do tipo acima mencionado.

53. Essa situação é, por conseguinte, diferente da que ocorre quando se aceita um "direito fundamental não-escrito". Um direito fundamental não-escrito é caracterizado pelo fato de que a norma de direito fundamental que o garante não se encontra em uma relação de refinamento com uma norma de direito fundamental expressa diretamente pelo texto constitucional.

Normas como (4), (5) e (6) não são estabelecidas diretamente pelo texto constitucional, elas são atribuídas às normas diretamente estabelecidas pela Constituição. Isso justifica chamá-las de "normas atribuídas". As normas de direito fundamental podem, portanto, ser divididas em dois grupos: as normas de direito fundamental estabelecidas diretamente pelo texto constitucional e as normas de direito fundamental atribuídas.

Contudo, ao qualificar as normas atribuídas como normas de direito fundamental abre-se a porta para uma série de problemas. Às normas que são estabelecidas diretamente pelas disposições de direitos fundamentais são atribuídas normas as mais diversas. A discussão sobre direitos fundamentais é, em grande parte, uma discussão sobre que normas devem ser atribuídas às normas diretamente estabelecidas pelo texto constitucional. Devem ser consideradas como asserções sobre normas de direitos fundamentais todas as asserções sobre normas que forem levantadas nessa discussão? Mesmo aquelas que são rejeitadas por quase todos e aquelas cuja fundamentação é deficiente? Nesse caso, até mesmo um enunciado externado por uma pessoa qualquer, de forma não muito séria, como "com base no art. 13 da Constituição alemã, deve a Administração disponibilizar a cada estudante um apartamento de dois cômodos perto da universidade", expressaria uma norma de direito fundamental.

Essa dificuldade só é superável se houver um critério que permita, dentro da classe potencialmente ilimitada de candidatos à atribuição, diferenciar entre aqueles que são normas de direitos fundamentais e aqueles que não o são. Pode-se pensar, de um lado, em um critério empírico e, de outro, em um critério normativo. Escolhe um critério empírico aquele que afirma que normas de direitos fundamentais atribuídas são aquelas que são de fato atribuídas pela jurisprudência e pela Ciência do Direito às normas diretamente estabelecidas pelo texto constitucional. Mas, a partir da perspectiva de uma teoria jurídica dos direitos fundamentais, um tal critério empírico não se mostra adequado. Para esta teoria a questão sobre quais atribuições podem ser *corretamente* levadas a cabo é uma questão constitutiva. Para responder a essa pergunta, ainda que precedentes judiciais e consensos dogmáticos

desempenhem um papel relevante,⁵⁴ simples referências àquilo que já foi decidido ou afirmado não são suficientes.

Uma atribuição correta ocorre quando a norma atribuída pode ser classificada como válida. Para classificar as normas diretamente estabelecidas pelo texto constitucional basta a referência à sua posituação. No caso das normas atribuídas isso é, por definição, excluído. Logo, sua identificação por meio do critério jurídico de validade não é possível. O mesmo vale para os critérios sociológico e ético. Que uma norma seja válida social ou eticamente não significa que ela possa ser corretamente atribuída a uma norma de direito fundamental diretamente estabelecida. Portanto, nenhum dos três critérios de validade é adequado para identificar normas de direito fundamental atribuídas. Mas todos eles são levados em consideração no âmbito do seguinte critério: uma norma atribuída é válida, e é uma norma de direito fundamental, se, para tal atribuição a uma norma diretamente estabelecida pelo texto constitucional, for possível uma *correta fundamentação referida a direitos fundamentais*. É possível perceber que os três critérios são levados em consideração quando se atenta ao papel que desempenham o texto das disposições de direitos fundamentais, os precedentes do Tribunal Constitucional Federal e os argumentos práticos gerais na fundamentação referida a direitos fundamentais.

Saber se uma norma atribuída é uma norma de direito fundamental depende, portanto, da argumentação referida a direitos fundamentais que a sustente. À primeira vista, isso tem consequências fatais. Em muitos casos que dizem respeito à atribuição de uma norma, a possibilidade de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais é algo discutível. As regras da fundamentação referida a direitos fundamentais não definem um procedimento que leve, em todos os casos, a somente um resultado.⁵⁵ Além disso, essas próprias regras não são objeto de controvérsias.⁵⁶ Isso significa, então, que, em muitos casos, é incerto quais normas são normas de direitos fundamentais.

54. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 326 e ss. e 334 e ss.

55. Isso é válido, de forma geral, para as regras da fundamentação jurídica. Cf., sobre isso, Robert Alexy, "Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation", *Rechtstheorie*, Beiheft 2 (1981), pp. 180 e ss.

56. Pode ocorrer, portanto, que para duas normas inconciliáveis, N_1 e N_2 , existam fundamentações igualmente procedentes. Devem, então, tanto N_1 quanto N_2 valer

Essa dificuldade não é, contudo, tão séria. Em primeiro lugar porque ela não atinge na mesma medida todas as normas atribuídas. Assim, não há quase dúvida sobre a possibilidade de se fundamentar a atribuição de uma norma que outorgue um direito de defesa ao art. 5^a, § 3^a, da Constituição alemã. Além disso, essa dificuldade é a expressão de um problema incontornável. Nesse sentido, mesmo que se abra mão do conceito de norma de direito fundamental atribuída, a questão acerca do que deve valer segundo as disposições de direitos fundamentais permanece com a mesma agudeza. E, visto que há bons motivos para o uso daquele conceito, e como não se cria, com ele, nenhuma dificuldade adicional, tudo milita a favor de sua utilização.⁵⁷

A definição do conceito de norma de direito fundamental baseada no conceito de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais dizia respeito, até aqui, somente às normas de direitos fundamentais atribuídas. Mas ela pode ser estendida também às normas de direitos fundamentais diretamente estabelecidas e pode, nesse sentido,

como normas de direitos fundamentais? A resposta a essa pergunta deve ser negativa. Para tanto, o conceito de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais, utilizado no critério mencionado acima, deve ser entendido de tal forma que uma fundamentação da atribuição de N_1 , — que, isoladamente considerada, seria correta — perde seu caráter de correção se N_2 puder ser fundamentada de forma igualmente correta. Nesse caso, nenhum dos candidatos à atribuição é considerado como norma atribuída. Assim, um tribunal que entenda que N_1 e N_2 são igualmente fundamentáveis não tem como se basear em uma norma que possa ser considerada como válida em razão de sua correta fundamentação e tem que, por isso, decidir em um âmbito aberto no que diz respeito à questão da validade. Em razão de sua força como precedente, importante inclusive do ponto de vista da fundamentação, essa decisão pode fazer com que a norma a que se deu preferência pareça, no futuro, como sendo mais bem fundamentada. A situação em questão aqui, na qual, do ponto de vista daquele que decide, duas normas inconciliáveis entre si são supostamente igualmente corretas no que diz respeito às possibilidades de fundamentação, deve ser distinguida da situação na qual dois julgadores distintos têm diferentes concepções sobre as possibilidades de fundamentação de uma norma. Esta última situação é muito mais freqüente que aquela na qual um julgador não consegue definir qual das duas fundamentações é a melhor.

57. Uma vantagem desse conceito pode ser mencionada de passagem: ele permite que se fale em descoberta de novas normas de direitos fundamentais. Nesse contexto, pode-se mencionar a bela metáfora usada por Thoma, que, com algumas relativizações, vale também para a Constituição atual: “É possível dizer que a Ciência do Direito alemã trata a Constituição de Weimar como uma região montanhosa, em cujos rincões a vara-de-condão da exegese pode sempre revelar novos veios de normas válidas, até então ocultas” (Richard Thoma, *Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung im allgemeinen*, p. 4).

ser generalizada. Uma tal definição geral sustenta que normas de direitos fundamentais são todas as normas para as quais existe a possibilidade de uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais. Para as normas diretamente estabelecidas normalmente é suficiente uma referência ao texto constitucional. Uma fundamentação mais profunda, que demonstre por que aquilo que a Constituição diz é válido, normalmente tem, para a práxis da fundamentação referida a direitos fundamentais, um interesse apenas teórico. Isso demonstra que a generalização da definição baseada em uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais não elimina, de forma nenhuma, a diferença entre normas de direitos fundamentais estabelecidas direta e indiretamente. No caso de uma norma diretamente estabelecida, uma fundamentação correta é sempre diferente da fundamentação no caso de uma norma indiretamente estabelecida.

3. *A teoria das normas de direitos fundamentais de Friedrich Müller*

A definição do conceito de norma de direito fundamental acima exposta tem três níveis. Ela parte da diferenciação entre enunciado normativo e norma, constitutiva do conceito semântico de norma. No primeiro nível, o conceito de norma de direito fundamental é definido com base em enunciados normativos estatuídos por uma determinada autoridade, o legislador constituinte. Esses enunciados normativos, as disposições de direitos fundamentais, são identificados com base em critérios formais, segundo a forma de sua positivação: estarem inseridos no título dos direitos fundamentais da Constituição alemã e referidos na disposição sobre reclamação constitucional (art. 93, § 1º, 4a). Isso garante uma orientação da teoria dos direitos fundamentais a partir da positivação feita pela Constituição alemã, sem com isso excluir as devidas diferenciações estruturais e substanciais. No segundo nível, o das normas de direitos fundamentais atribuídas, é dada continuidade a essa orientação, já que o conceito de norma de direito fundamental atribuída é vinculado à correção da atribuição a disposições dotadas de autoridade. A necessária liberdade no âmbito da atribuição é levada em consideração por meio do conceito de asserção sobre normas de direitos fundamentais. Qualquer um pode, a respeito de qualquer norma, asseverar que ela deve ser atribuída a disposições de di-

reitos fundamentais. Mas essa asserção tem como objeto uma norma de direito fundamental somente se ela for correta, o que só ocorre se, para tal atribuição, for possível uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais. Em um terceiro passo, a definição baseada no conceito de fundamentação correta é generalizada, e passa a valer tanto para as normas estabelecidas diretamente quanto para as normas atribuídas.

Essa teoria da norma de direito fundamental, e também a concepção semântica do conceito de norma, que a ela subjaz, encontra um contraponto na teoria da norma desenvolvida por Friedrich Müller. Essa teoria tem especial interesse no presente contexto porque ela, em primeiro lugar, foi desenvolvida tendo em vista o direito constitucional⁵⁸ e, além disso, porque conta com uma crescente aceitação.⁵⁹

Müller caracteriza sua teoria com uma “teoria da norma que supera o positivismo jurídico”.⁶⁰ O enunciado central de sua – como ele define – “teoria estrutural pós-positivista da norma jurídica”⁶¹ consiste na tese da “não-identidade entre norma e texto normativo”.⁶² Com essa tese, Müller pretende dizer “que uma norma jurídica é mais que o texto”.⁶³ A concepção da norma jurídica como “constituída apenas linguisticamente” seria a “ilusão de uma concepção puramente formalista do Estado de Direito”.⁶⁴ Uma teoria pós-positivista – que para Müller significa uma teoria adequada – da norma jurídica teria, por oposição, que partir do pressuposto de que “a norma jurídica é determinada também pela realidade social, pelo âmbito da norma”.⁶⁵ Segundo Müller, o texto normativo “expressa o ‘programa da norma’, tradicionalmente entendido como o ‘comando jurídico’. Com igual

58. Cf. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1976, pp. 24 e 26 e ss.

59. Cf. a exposição de Müller na obra acima citada, pp. 116-117.

60. Idem, p. 126.

61. Idem, p. 265.

62. Friedrich Müller, “Rechtsstaatliche Methodik und politische Rechtstheorie”, *Rechtstheorie* 8 (1977), p. 75; do mesmo autor, *Juristische Methodik*, pp. 55, 61, 147, 202 e 265.

63. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 117; do mesmo autor, *Normstruktur und Normativität*, Berlin: Duncker & Humblot, 1966, pp. 147 e ss.

64. Friedrich Müller, “Rechtsstaatliche Methodik und politische Rechtstheorie”, p. 74.

65. Idem, p. 75.

hierarquia faz parte da norma também o âmbito normativo, isto é, o setor da realidade social em sua estrutura básica, o qual é 'escolhido' ou, em parte, até mesmo criado pelo programa normativo como sua área de regulação".⁶⁶ Por conseguinte, "a norma jurídica [deve] ser entendida como um projeto vinculante, que abarca tanto o que regula quanto o que há de ser regulado".⁶⁷ A contraposição entre ser e dever-ser é, desse modo, superada.⁶⁸ Para os direitos fundamentais, ainda segundo as palavras de Müller, isso significa o seguinte: "Os direitos fundamentais são garantias de proteção, substancialmente conformadas, de determinados complexos de ações, organizações e matérias, individuais e sociais. Esses 'âmbitos materiais' são transformados em 'âmbitos normativos' por meio do reconhecimento constitucional e da garantia da liberdade no campo da prescrição normativa, do programa da norma. Os âmbitos normativos participam da normatividade prática, isto é, eles são elementos co-determinantes da decisão jurídica".⁶⁹

Essa teoria da norma em geral, e da norma de direito fundamental em especial, é incompatível com a teoria semântica da norma, que é o ponto de partida da definição do conceito de norma de direito fundamental aqui apresentada. Isso fica claro no caso das normas de direitos fundamentais diretamente estabelecidas. Estas constituídas por aquilo, e somente por aquilo, que as disposições de direitos fundamentais expressam. Aquilo que aqui é chamado de "disposição de direito fundamental" corresponde àquilo que Müller chama de "texto", e aquilo que aqui leva o nome de "norma" corresponde àquilo que Müller chama de "programa normativo". O conceito central da teoria normativa de Müller, o âmbito normativo, não tem lugar aqui. O mesmo vale para as normas de direitos fundamentais atribuídas. Significa isso que uma teoria dos direitos fundamentais que se baseie nos conceitos de norma e de norma de direito fundamental aqui desenvolvidos está fadada a não conseguir explicar, "por razões ligadas ao positivismo jurídico, a normatividade jurídica e, com isso, também as peculia-

66. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 117.

67. Idem, pp. 194 e 121. Cf., além disso, Friedrich Müller, *Normbereiche von Einzelgrundrechten in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts*, Berlin: Duncker & Humblot, 1968, p. 9.

68. Cf. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, pp. 60 e 193.

69. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1969, p. 11.

ridades da Ciência do Direito como uma ciência normativa"? Ou que, da mesma forma que, segundo Müller, ocorre com posições tão variadas como "positivismo, normologismo, decisionismo e sociologismo", tal teoria revelar-se-ia "reducionista no que diz respeito à compreensão do processo de concretização em seu todo"?⁷⁰ Para poder responder a essas perguntas é necessário analisar as razões que Müller aduz para sua tese da não-identidade.

A razão principal reside na concepção que Müller tem da ligação entre teoria da norma e teoria da aplicação do direito. A diferença entre ambas é, segundo ele, apenas uma diferença de perspectiva; elas são dois lados da mesma moeda: "Essa concepção pode, portanto, ser formulada tanto como um modelo estrutural geral das *normas jurídicas*, quanto como *estruturação dos processos de decisão* jurídica, quanto, por fim, como *exigências de trabalho* aos juristas".⁷¹ Müller utiliza-se, nesse contexto, de um argumento em três níveis. O primeiro nível consiste na constatação de que "normas jurídicas gerais não podem nunca determinar de antemão, e por completo, o estabelecimento de normas individuais por parte dos órgãos aplicadores do direito".⁷² "Conceitos jurídicos não têm significado e os enunciados não têm sentido como se fossem algo hermeticamente predeterminado".⁷³ Ressalvando-se alguns refinamentos, e também algumas relativizações, isso é algo com o qual dificilmente alguém não concordaria.⁷⁴ O argumento torna-se interessante a partir do segundo nível, que consiste na alegação de que teorias como a teoria semântica das normas aqui formulada, a qual concebe as normas jurídicas válidas como objetos lingüísticos identificáveis por meio de determinados critérios de validade, estariam obrigadas a "construir a norma de decisão exclusivamente por meio de dados lingüísticos".⁷⁵ Isso seria, contudo, segundo

70. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 194.

71. Friedrich Müller, *Juristische Methodik und politisches System*, Berlin: Duncker & Humblot, 1976, p. 94. Cf. também, do mesmo autor, *Juristische Methodik*, p. 271 e *Strukturierende Rechtslehre*, Berlin: Duncker & Humblot, 1984, pp. 230 e ss.

72. Friedrich Müller, *Normstruktur und Normativität*, p. 148.

73. Friedrich Müller, "Rechtsstaatliche Methodik und politische Rechtstheorie", p. 73.

74. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 17-18.

75. Friedrich Müller, "Rechtsstaatliche Methodik und politische Rechtstheorie", p. 75.

as conclusões do primeiro nível do argumento, algo impossível. Em decorrência disso, uma teoria orientada por um conceito semântico de norma seria uma teoria inadequada. O terceiro nível do argumento, por fim, contém a solução proposta por Müller. Para a tomada de decisões, ao lado dos "dados lingüísticos (programa da norma)" – e com precedência em relação a todos os outros elementos concretizadores –, seriam decisivos e, em princípio, de importância equivalente os "dados reais (âmbito da norma)".⁷⁶ O âmbito da norma pertence, por conseguinte, à norma.

Contra esse argumento podem ser suscitadas três objeções. A primeira contesta que as teorias orientadas por um conceito semântico de norma jurídica estejam obrigadas a fundamentar suas decisões jurídicas somente por meio de argumentos semânticos ("dados lingüísticos"); a segunda dirige-se em geral contra a proposta de se incluir no conceito de norma algum argumento puro e simplesmente porque ele seja necessário para a fundamentação da decisão; a terceira dirige-se em particular contra a tese segundo a qual os argumentos que devem ser incluídos no conceito de norma são exatamente os argumentos relacionados ao âmbito da norma ("dados reais"). Como essas objeções estão intimamente ligadas entre si, serão elas analisadas em conjunto.

A tese segundo a qual uma teoria orientada por um conceito semântico de norma jurídica está obrigada a fundamentar suas decisões jurídicas somente por meio de argumentos semânticos seria verdadeira somente se fosse correta a afirmação de que aquilo que não pertence ao conceito de norma não pode ser utilizado na argumentação jurídica. Nem mesmo a teoria de Müller se atém a essa proposição, pois ela aceita como elementos da fundamentação jurídica, além dos elementos diretamente relacionados à norma (elementos metodológicos em sentido estrito, elementos do âmbito normativo e outros elementos dogmáticos), também elementos não diretamente relacionados à norma (alguns elementos dogmáticos, técnicas de solução e elementos teóricos, político-constitucionais e político-jurídicos),⁷⁷ sem que esses sejam, contudo, qualificados como pertencentes à norma. Se levarmos

76. Cf. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, pp. 200 e ss. Somente na definição dos limites dos resultados admissíveis é que os dados lingüísticos teriam precedência em face dos dados reais (idem, p. 202).

77. Cf. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, pp. 199 e ss.

a sério a proposição de que na fundamentação jurídica somente pode ser utilizado aquilo que pertence à norma, então, ou teríamos que incluir no conceito de norma todo o arsenal da argumentação jurídica ou restringir consideravelmente, e à custa de sua racionalidade, o âmbito dessa argumentação. Assim, os juízos axiológicos independentes (ou os valores que a eles subjazem), necessários às fundamentações jurídicas, deveriam ou ser incluídos no conceito de norma jurídica ou eliminados da argumentação jurídica. Nenhuma das soluções parece, no entanto, plausível.

À tese de Müller deve ser contraposta uma diferenciação minuciosa entre o conceito de norma, o conceito de relevância normativa e o conceito de fundamento da norma. Normativamente relevante é tudo aquilo que pode ser corretamente apresentado como argumento a favor ou contra uma decisão jurídica.⁷⁸ A favor ou contra uma decisão jurídica podem ser suscitadas sobretudo normas jurídicas válidas, o que significa, portanto, que todas as normas jurídicas são normativamente relevantes. Mas isso não significa que tudo aquilo que é normativamente relevante é uma norma jurídica ou parte dela, e isso nem por razões conceituais nem por razões jurídico-positivas (especialmente aquelas decorrentes do Estado de Direito). Por razões conceituais, porque é perfeitamente possível diferenciar uma norma como um objeto semântico dos argumentos axiológicos, empíricos, jurisprudenciais, dogmáticos, entre outros, que podem ser usados na fundamentação de uma proposta de interpretação. Uma tal diferenciação não é somente possível, como também recomendável. Sem que se diferencie entre a norma, a proposta de interpretação e os argumentos que sustentam essa proposta torna-se impossível uma visão clara da fundamentação jurídica. Também as razões decorrentes do Estado de Direito não somente permitem como também exigem uma distinção entre o conceito de norma e o conceito daquilo que é simplesmente normativamente relevante. Embora seja muito tentador incluir na norma todos ou pelo menos os mais importantes argumentos para uma dada interpretação, pois, dessa forma, a interpretação poderá ser apre-

78. A essa definição do conceito de relevância normativa corresponde um aspecto central do conceito de normatividade de Müller, o qual é expresso, dentre outras, pela seguinte formulação: "'normativo' é tudo aquilo que determina o caso a ser decidido, tudo aquilo que indica a direção de sua solução" (Friedrich Müller, *Normbereiche von Einzelgrundrechten*, p. 10).

sentada como a expressão de uma estrita vinculação à própria norma, com esse proceder ganha-se, no entanto, muito pouco. O ideal do Estado de Direito é mais respeitado se se distingue claramente entre aquilo que o legislador impôs como norma e aquilo que um intérprete apresenta como razões para uma determinada interpretação que por meio de uma fidelidade à lei construída a partir de uma dada definição do conceito de norma.

É necessário salientar, contudo, que Müller pretende incluir no conceito de norma somente os elementos ligados ao âmbito normativo, e não todo e qualquer argumento possível na argumentação jurídica. Mas mesmo nessa restrição há uma ampliação inaceitável no conceito de norma. No caso dos elementos do âmbito da norma ou dos "dados reais" pode tratar-se ou exclusivamente de argumentos empíricos ou de argumentos empíricos ligados a argumentos axiológicos ou normativos. No primeiro caso pouco se ganha com a problemática inclusão de argumentos exclusivamente empíricos no conceito de norma, porque de uma norma que é aberta em relação ao caso a ser decidido não resulta, com a simples adição de argumentos empíricos, a decisão do caso. Para tanto são necessários argumentos axiológicos e normativos, os quais conferirão algum significado normativo aos argumentos empíricos. Se com o conceito de âmbito da norma se faz referência a tais argumentos axiológicos e normativos, então, visto que esses argumentos não decorrem de modo algum do texto normativo em conjunto com os argumentos empíricos, é incorporada no conceito de norma uma incontrolável e muitas vezes extremamente polêmica pluralidade de concepções, contra a qual valem os argumentos acima expostos, de maneira geral, contra a inclusão de tudo o que seja normativamente relevante no conceito de norma. Com isso nada se pretende dizer contra a importância de análises empíricas à luz da legislação. Dessas análises é possível extrair argumentos valiosos e, freqüentemente, decisivos. O que se rejeita é sua inclusão no próprio conceito de norma.

O que foi exposto até agora vale também para as normas de direitos fundamentais atribuídas, as quais guardam uma certa semelhança com aquilo que Müller denomina de "normas de decisão".⁷⁹ Uma

79. Mas não se pretende estabelecer mais que uma certa semelhança. Uma análise mais detalhada poderia expor alguns problemas da norma de decisão de Müller. Isso pode ser percebido de forma exemplar na seguinte passagem: "Por fim, enquanto

norma é uma norma de direito fundamental atribuída quando, para sua atribuição a uma disposição de direito fundamental, é possível uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais. Seria possível afirmar que com isso se realiza uma ligação entre norma e argumentação muito semelhante àquela realizada por Müller. É necessário observar, no entanto, que, no caso das normas atribuídas, é possível distinguir sem dificuldades entre a norma como um objeto semântico e as razões que a sustentam, e que essa distinção deve ser feita. A possibilidade de uma fundamentação correta para a atribuição a uma disposição de direito fundamental é um *critério* para identificar a norma em questão como uma norma de direito fundamental. Mas é necessário diferenciar claramente entre o critério para se decidir sobre uma determinada característica e o próprio objeto que pode ou não satisfazer esse critério e que, nesse sentido, terá ou não aquela carac-

norma de decisão, uma prescrição deve ser considerada como definitiva somente (e, mesmo assim, apenas para esse caso específico) quando o caso estiver solucionado" (Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 132). O trecho entre parêntesis parece sustentar que a norma de decisão é uma norma somente para o caso a ser decidido, ou seja, uma norma individual, no sentido kelseniano (cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 255 e ss.; e, do mesmo autor, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 180) ou um juízo de dever-ser jurídico concreto, no sentido de Engisch (cf. Karl Engisch, *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, pp. 3 e ss.). Nesse sentido é a afirmação de Müller que identifica a norma de decisão como a formulação lingüística da decisão individual: "A imputação da decisão individual e de sua formulação lingüística (a 'norma de decisão')" (Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 278). Contra essa posição, sugerida pelo trecho citado de Müller, militam não somente o fato de ele falar da prescrição *como* norma de decisão, mas sobretudo o fato de que, por essa interpretação, a norma jurídica não poderia, "no decorrer de seu tempo de validade, ser determinada, modificada ou ampliada em seu conteúdo por meio das normas de decisão que são a ela imputadas em cada caso concreto" (idem, pp. 272-273). Isso pressuporia uma prática decisória universalista, que associaria a norma jurídica relativamente geral a normas de decisão relativamente específicas, mas, ainda assim, universais. Essa versão da norma de decisão – que é a que Larenz tem em mente quando salienta "que Müller, por 'norma de decisão', de maneira semelhante a Fikentscher, com sua 'norma do caso', supõe uma norma que é concretizada de forma tão ampla por parte daquele que decide, que sua aplicação ao caso concreto não exige nenhum passo intermediário" (Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 4ª ed., Berlin: Springer, 1979, p. 495) – deve ter preferência não somente por razões substantiais, mas também porque corresponde à constatação de Müller segundo a qual a norma de decisão seria a "situação agregada [da norma jurídica], 'concretizada' a partir de um determinado caso e com vistas à sua solução vinculante" (Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 119).

terística. Um critério para algo é coisa diversa de um elemento de algo. No final das contas, as normas atribuídas fazem com que fique claro o papel decisivo da argumentação referida a direitos fundamentais na resposta à questão acerca daquilo que é válido no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse ponto é necessário concordar com Müller, já que sua teoria da norma salienta essa importância.

Capítulo 3

A ESTRUTURA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

I – REGRAS E PRINCÍPIOS

Até aqui a análise concentrou-se no conceito de norma de direito fundamental. A partir de agora, é sua estrutura que será analisada. Para alcançar esse objetivo, é possível utilizar diversas diferenciações teórico-estruturais. Para a teoria dos direitos fundamentais, a mais importante delas é a distinção entre regras e princípios. Essa distinção é a base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. Sem ela não pode haver nem uma teoria adequada sobre as restrições a direitos fundamentais, nem uma doutrina satisfatória sobre colisões, nem uma teoria suficiente sobre o papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico. Essa distinção constitui um elemento fundamental não somente da dogmática dos direitos de liberdade e de igualdade, mas também dos direitos a proteção, a organização e procedimento e a prestações em sentido estrito. Com sua ajuda, problemas como os efeitos dos direitos fundamentais perante terceiros e a repartição de competências entre tribunal constitucional e parlamento podem ser mais bem esclarecidos. A distinção entre regras e princípios constitui, além disso, a estrutura de uma teoria normativo-material dos direitos fundamentais e, com isso, um ponto de partida para a resposta à pergunta acerca da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse sentido, a distinção entre regras e princípios é uma das colunas-mestras do edifício da teoria dos direitos fundamentais.

Não faltam indícios de que a distinção entre regras e princípios desempenha um papel no contexto dos direitos fundamentais. As normas de direitos fundamentais são não raro caracterizadas como "princípios".¹ Com ainda mais frequência, o caráter principiológico das normas de direitos fundamentais é sublinhado de maneira menos direta. Como será visto, isso ocorre, por exemplo, quando se fala em valores,² objetivos,³ fórmulas abreviadas⁴ ou regras sobre ônus argumentativo.⁵ Por outro lado, faz-se referência às normas de direitos fundamentais como regras quando se afirma que a Constituição deve ser levada a sério como lei,⁶ ou quando se aponta para a possibilidade de fundamentação dedutiva também no âmbito dos direitos fundamentais.⁷ No entanto, essas caracterizações permanecem quase sempre no nível de sugestões. O que falta é uma distinção precisa entre regras e princípios e uma utilização sistemática dessa distinção. A isso serão dedicados os tópicos seguintes.

1. Critérios tradicionais para a distinção entre regras e princípios

A distinção entre regras e princípios não é nova. Mas, a despeito de sua longevidade e de sua utilização freqüente, a seu respeito impe-

1. Cf., por exemplo, Eike v. Hippel, *Grenzen und Wesensgehalt der Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1965, pp. 15 e ss.; Detlef C. Göldner, *Verfassungsprinzip und Privatrechtsnorm in der verfassungskonformen Auslegung und Rechtsfortbildung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1969, pp. 23 e ss.; Ulrich Scheuner, "Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat: Die Grundrechte als Richtlinie und Rahmen der Staatstätigkeit", *DÖV* 24 (1971), p. 507; Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Die Methoden der Verfassungsinterpretation", *NJW* 29 (1976), p. 2.091.

2. Cf. os exemplos da jurisprudência Tribunal Constitucional Federal, apresentados no Capítulo 1, III.

3. Cf., por exemplo, Peter Häberle, "Grundrechte im Leistungsstaat", *VVDStRL* 30 (1972), p. 135.

4. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 32,54 (72); Hans Huber, "Über die Konkretisierung der Grundrechte", in *Der Staat als Aufgabe*, p. 197: estilo taquigráfico.

5. Cf. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, Berlin: Duncker & Humblot, 1976, p. 195; Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen des allgemeinen verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes*, Berlin: Duncker & Humblot, 1971, p. 90.

6. Cf. Ernst Forsthoff, *Zur Problematik der Verfassungslegung*, Stuttgart: Kohlhammer, 1961, p. 34.

7. Cf. Hans-J. Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, pp. 97 e ss.

ram falta de clareza e polêmica. Há uma pluralidade desconcertante de critérios distintivos, a delimitação em relação a outras coisas – como os valores – é obscura e a terminologia vacilante.

Com frequência, não são regra e princípio, mas norma e princípio ou norma e máxima, que são contrapostos.⁸ Aqui, regras e princípios serão reunidos sob o conceito de norma. Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deonticas básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas.

Há diversos critérios para se distinguir regras de princípios. Provavelmente aquele que é utilizado com mais frequência é o da generalidade.⁹ Segundo esse critério, princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto o grau de generalidade das regras é relativamente baixo. Um exemplo de norma de grau de generalidade relativamente alto é a norma que garante a liberdade de crença. De outro lado, uma norma de grau de generalidade relativamente baixo seria a norma que prevê que todo preso tem o direito de converter outros presos à sua crença.¹⁰⁻¹¹ Segundo o critério de generalidade,

8. Cf., por exemplo, Josef Esser, *Grundsatz und Norm*, 3ª ed., Tübingen: Mohr, 1974. O Tribunal Constitucional Federal às vezes fala em “normas e princípios da Constituição” (*BVerfGE* 51, 324 (350)).

9. Cf., por exemplo, Joseph Raz, “Legal principles and the limits of law”, *Yale Law Journal* 81 (1972), p. 838; George C. Christie, “The model of principles”, *Duke Law Journal* 17 (1968), p. 669; Graham Hughes, “Policy and decision making”, *Yale Law Journal* 77 (1968), p. 419; August Simonius, “Über Bedeutung, Herkunft und Wandlung der Grundsätze des Privatrechts”, *Zeitschrift für Schweizerisches Recht* NF 71 (1952), p. 239. Contra a generalidade como critério distintivo, cf. Josef Esser, *Grundsatz und Norm*, p. 51; Karl Larenz, *Richtiges Recht*, München: C. H. Beck, 1979, p. 26: “Não é o grau de generalidade que é decisivo para o princípio mas a sua aptidão como razão fundamentadora”.

10. Cf., nesse sentido, *BVerfGE* 12, 1 (4).

11. O conceito de *generalidade* de uma norma tem que ser estritamente distinguido do conceito de *universalidade*. A despeito de seus diferentes graus de generalidade, tanto “todos gozam de liberdade de crença” quanto “todo preso tem o direito de converter outros presos à sua crença” expressam normas universais. Isso porque ambas as normas se referem a *todos* os indivíduos de uma classe aberta (pessoas/presos). Sobre o conceito de classe aberta, cf. Alf Ross, *Directives and Norms*,

seria possível pensar em classificar a primeira norma como princípio, e a segunda como regra. Outros critérios discutidos são “a determinabilidade dos casos de aplicação”,¹² a forma de seu surgimento – por exemplo, por meio da diferenciação entre normas “criadas” e normas “desenvolvidas”¹³ –, o caráter explícito de seu conteúdo axiológico,¹⁴ a referência à idéia de direito¹⁵ ou a uma lei jurídica suprema¹⁶ e a importância para a ordem jurídica.¹⁷ Princípios e regras são diferen-

pp. 109-110. O oposto de norma universal é a norma individual. Os enunciados “o senhor L. goza de liberdade de crença” e “o preso L. tem o direito de converter outros presos à sua crença” expressam igualmente normas individuais, das quais uma tem um grau de generalidade relativamente alto, e a outra um grau relativamente baixo. O conceito oposto ao de generalidade é o conceito de especialidade. A primeira das normas pode, portanto, ser considerada “relativamente geral”, e a segunda, “relativamente especial”. Toda norma é sempre ou universal ou individual. Já a generalidade, ou seu oposto, a especialidade, é um problema de grau. Sobre os pares conceituais universalidade/individualidade e generalidade/especialidade, cf. Richard M. Hare, *Freedom and Reason*, Oxford: Oxford University Press, 1963, pp. 39-40; do mesmo autor, “Principles”, *Proceedings of the Aristotelian Society* 73 (1972/73), pp. 2-3.

Os termos “individual”, “universal”, “especial” e “geral” são utilizados também de diversas outras maneiras. Outros termos, como “abstrato” e “concreto”, podem ser adicionados. Bastante difundida é a caracterização de uma norma desmembrada em suporte fático e consequência jurídica, e aplicável a um número indeterminado de pessoas e casos, como “abstrata-geral” (cf., por exemplo, Dieter Volkmar, *Allgemeiner Rechtssatz und Einzelakt*, Berlin: Duncker & Humblot, 1962, pp. 74 e ss.). Quando a diferenciação não for necessária, será usada essa forma de expressão já consagrada. Para outras diferenciações, cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 106 e ss.; Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 70 e ss.

12. Josef Esser, *Grundsatz und Norm*, p. 51; Karl Larenz, *Richtiges Recht*, p. 23. Cf. também Hannu T. Klami, *Legal Heuristics*, Vammala: Vammalan, 1982, pp. 31 e ss.

13. Cf. Samuel I. Shuman, “Justification of judicial decisions”, *California Law Review* (Essays in Honour of Hans Kelsen) 59 (1971), pp. 723, 729; Thorstein Eckhoff, “Guiding standards in legal reasoning”, *Current Legal Problems* 29 (1976), pp. 209-210.

14. Cf. Carl-W. Canaris, *Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1983, p. 50.

15. Cf. Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 5ª ed., Berlin: Springer, 1983, pp. 218 e 404.

16. Cf. Hans J. Wolff, “Rechtsgrundsätze und verfassungsgestaltende Grundentscheidungen als Rechtsquelle”, in Otto Bachof et al. (Orgs.), *Forschungen und Berichte aus dem Öffentlichen Recht: Gedächtnisschrift für Walter Jellinek*, München: Isar, 1955, pp. 37 e ss.

17. Cf. Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, p. 461; Aleksander Peczenik, “Principles in law”, *Rechtstheorie* 2 (1971), pp. 24-25; cf. também

ciados também com base no fato de serem razões para regras ou serem eles mesmos regras,¹⁸ ou, ainda, no fato de serem normas de argumentação ou normas de comportamento.¹⁹

Com base nesses critérios, são possíveis três teses inteiramente diversas acerca da distinção entre regras e princípios. A primeira sustenta que toda tentativa de diferenciar as normas em duas classes, a das regras e a dos princípios, seria, diante da diversidade existente, fadada ao fracasso. Isso seria perceptível, por exemplo, na possibilidade de que os critérios expostos, dentre os quais alguns permitem apenas diferenciações gradativas, sejam combinados da maneira que se desejar. Assim, não seria difícil imaginar uma norma que tenha um alto grau de generalidade, não seja aplicável de pronto, não tenha sido estabelecida expressamente, tenha um notório conteúdo axiológico e uma relação íntima com a idéia de direito, seja importantíssima para a ordem jurídica, forneça razões para regras e possa ser usada como um critério para a avaliação de argumentos jurídicos. Some-se a isso o fato de que, isoladamente considerados, aquilo que esses critérios distinguem é algo extremamente heterogêneo.²⁰ Diante disso, é necessário atentar para as diversas convergências e diferenças, semelhanças e dessemelhanças, que são encontradas no interior da classe das normas, algo que seria mais bem captado com a ajuda do conceito wittgensteiniano de *semelhança de família*²¹ que por meio de uma divisão

Sławomira Wronkowska/Maciej Zieliński/Zygmunt Ziemiński, "Rechtsprinzipien: Grundlegende Probleme", in *Zasady prawa*, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1974, p. 226.

18. Cf. Josef-Esser, *Grundsatz und Norm*, p. 51: "princípio (...) não é, ele mesmo, 'diretiva', mas fundamento, critério e justificação da diretiva"; Karl Larenz, *Rich- tiges Recht*, pp. 24-25; Joseph Raz, "Legal principles and the limits of law", p. 839; Neil MacCormick, "Principles of law", *Judicial Review* 19 (1974), p. 222; do mesmo autor, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford: Clarendon, pp. 152 e ss.

19. Cf. Hyman Gross, "Standards as law", *Annual Survey of American Law* 1968/69, p. 578.

20. Esser diferencia, por exemplo, princípios axiomáticos, retóricos e dogmáticos, princípios imanes e informativos, princípios jurídicos e princípios do direito, bem como princípios construtivos e axiológicos (Josef Esser, *Grundsatz und Norm*, pp. 47-48, 73 e ss., 90 e 156). Peczenik divide os princípios em "princípios ou 'leis' da lógica", "princípios de justiça", "semilógicos" e "princípios jurídicos instrumentalmente formulados"; princípios "similares aos instrumentalmente formulados" e "todos os outros princípios" (Aleksander Peczenik, "Principles of law", pp. 17 e ss.).

21. Cf. Ludwig Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen*, §§ 66-67.

em duas classes. A segunda tese é defendida por aqueles que, embora aceitem que as normas possam ser divididas de forma relevante em regras e princípios, salientam que essa diferenciação é somente *de grau*. Os adeptos dessa tese são sobretudo aqueles vários autores que vêem no grau de generalidade o critério decisivo para a distinção. A terceira tese, por sua vez, sustenta que as normas podem ser distinguidas em regras e princípios e que entre ambos não existe apenas uma diferença gradual, mas uma diferença *qualitativa*. Essa tese é correta. Há um critério que permite que se distinga, de forma precisa, entre regras e princípios. Esse critério não se encontra na lista apresentada acima, mas declara a maioria dos critérios tradicionais nela contidos como típicos, ainda que não decisivos, dos princípios. Ele será apresentado a seguir.

2. Princípios como mandamentos de otimização

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que *princípios* são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.²² Princípios são, por conseguinte, *mandamentos de otimização*,²³ que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.²⁴

22. Cf., nesse sentido, Robert Alexy, "Zum Begriff des Rechtsprinzips", *Rechtstheorie*, Beih. 1 (1979), pp. 79 e ss.; do mesmo autor, "Rechtsregeln und Rechtsprinzipien", *ARSP*, Beiheft 25 (1985), pp. 13 e ss.

23. O conceito de mandamento é aqui utilizado em um sentido amplo, que inclui também as permissões e as proibições.

24. É necessário distinguir dois casos de restrição à realização ou à satisfação dos princípios por meio de regras: (1) A regra *R*, que restringe o princípio *P*, vale estritamente. Isso significa que vale uma *regra* de validade *R'*, que diz que *R* tem precedência em relação a *P*, independentemente de se saber o quão importante é a realização de *P* e o quão desimportante é a realização de *R*; (2) *R* não vale estritamente. Isso significa que vale um *princípio* de validade *P'*, que permite, em determinadas situações, que *P* supere ou restrinja *R*. Essas condições não podem ser satisfeitas com a simples constatação de que o cumprimento de *P* é, no caso concreto, mais importante que o cumprimento do princípio *PR*, que *materialmente* sustenta *R*, pois isso faria

Já as *regras* são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas.²⁵ Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, *determinações* no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau.²⁶ Toda norma é ou uma regra ou um princípio.²⁷

3. *Colisões entre princípios e conflitos entre regras*

A diferença entre regras e princípios mostra-se com maior clareza nos casos de colisões entre princípios e de conflitos entre regras.²⁸ Co-

com que *P'* não desempenhasse nenhum papel. Tudo seria uma questão de relação entre *P* e *PR*. *P'* desempenha um papel se para a determinação da precedência de *P* não somente se exija que *P* preceda o princípio *PR*, que materialmente sustenta *R*, mas também que *P* seja mais forte que *PR* em conjunto com o princípio *P'*, que exige o cumprimento de regras e que, nesse sentido, sustenta formalmente *R*.

25. O § 5º, 1, do Código de Trânsito alemão (StVO) é uma regra que exprime bem o que se quer dizer com isso. Ultrapassagens são possíveis ou pela esquerda ou pela direita. A característica de poder ser ou não ser cumprida não se limita, contudo, a esse tipo simples de regras. Ela não depende do fato de que a ação obrigatória (proibida, permitida) somente pode ser realizada ou não realizada. Mesmo as regras que prescrevem ações que podem ser realizadas em diferentes graus podem ter aquela qualidade. Isso ocorre também quando um *determinado* grau da ação ou do comportamento é obrigatório (proibido, permitido). Um exemplo são as prescrições que se referem a condutas imprudentes. O que se exige não é um grau máximo de cuidado, mas um determinado grau de cuidado, dependendo do ramo do direito de que se trate. Embora seja possível que surjam dúvidas, em casos individuais, sobre qual é o grau de cuidado exigido, isso é algo possível na aplicação de qualquer norma e não representa nenhuma peculiaridade. Para o esclarecimento dessas dúvidas exige-se exatamente que se decida se o grau de cuidado exigido pelo dispositivo foi satisfeito, ou não. Esse questionamento é típico das regras.

26. Essa é também a conclusão de Josef Esser, *Grundsatz und Norm*, p. 95.

27. A distinção apresentada assemelha-se à proposta por Dworkin (cf. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, 2ª ed., London: Duckworth, 1978, pp. 22 e ss. e 71 e ss.). Mas ela dela difere em um ponto decisivo: a caracterização dos princípios como mandamentos de otimização. Para uma discussão acerca dessas semelhanças e diferenças, cf. Robert Alexy, "Zum Begriff des Rechtsprinzips", pp. 59 e ss.

28. A terminologia é oscilante. Paulson, por exemplo, sem diferenciar entre regras e princípios, utiliza em geral a expressão "conflito entre normas" (cf. Stanley Paulson, "Zum Problem der Normkonflikt", *ARSP* 66 (1980), pp. 487 e ss.), e o Tri-

num às colisões entre princípios e aos conflitos entre regras é o fato de que duas normas, se isoladamente aplicadas, levariam a resultados inconciliáveis entre si, ou seja, a dois juízos concretos de dever-ser jurídico contraditórios. E elas se distinguem pela forma de solução do conflito.

3.1 O conflito entre regras

Um conflito entre regras somente pode ser solucionado se se introduz, em uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos uma das regras for declarada inválida. Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido por meio da introdução de uma cláusula de exceção é aquele entre a proibição de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever de deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver sido tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si. Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na primeira regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de incêndio.

Se esse tipo de solução não for possível, pelo menos uma das regras tem que ser declarada inválida e, com isso, extirpada do ordenamento jurídico. Ao contrário do que ocorre com o conceito de validade social ou de importância da norma, o conceito de validade jurídica não é graduável. Ou uma norma jurídica é válida, ou não é. Se uma regra é válida e aplicável a um caso concreto, isso significa que também sua consequência jurídica é válida. Não importa a forma como sejam fundamentados,²⁹ não é possível que dois juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si sejam válidos. Em um determinado caso, se se constata a aplicabilidade de duas regras com consequências jurídicas concretas contraditórias entre si, e essa contradição não pode ser eliminada por meio da introdução de uma cláusula de exceção, então, pelo menos uma das regras deve ser declarada inválida.

bunal Constitucional Federal fala às vezes, sem maiores diferenciações, em "colisões entre normas" (cf. *BVerfGE* 26, 116 (135); 36, 342 (363)). A terminologia aqui escolhida pretende salientar que as colisões entre princípios e os conflitos entre regras, a despeito de importantes aspectos comuns, são algo fundamentalmente distinto.

29. Cf., por exemplo, Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 135 e 141 e ss.; Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 169 e ss.; Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, pp. 133-134.

A constatação de que pelo menos uma das regras deve ser declarada inválida quando uma cláusula de exceção não é possível em um conflito entre regras nada diz sobre qual das regras deverá ser tratada dessa forma. Esse problema pode ser solucionado por meio de regras como *lex posterior derogat legi priori* e *lex specialis derogat legi generali*, mas é também possível proceder de acordo com a importância de cada regra em conflito. O fundamental é: a decisão é uma decisão sobre validade. Um exemplo de conflito entre regras que o Tribunal Constitucional Federal resolveu exatamente nesse sentido – com base na norma sobre conflitos do art. 31 da Constituição alemã (“o direito federal tem prioridade sobre o direito estadual”) – é aquele entre o § 22, 1, da ordenação sobre o horário de trabalho, de 1934 e 1938 (direito federal vigente na época da decisão), que, pela interpretação do tribunal, permitia a abertura de lojas entre 7 e 19h nos dias úteis, e o § 2º da lei do Estado de Baden sobre o horário de funcionamento do comércio, de 1951, que, entre outras coisas, proibia a abertura de lojas após as 13h nas quartas-feiras.³⁰ As duas regras não poderiam valer ao mesmo tempo, caso contrário a abertura das lojas nas tardes de quartas-feiras seria tanto permitida quanto proibida. A possibilidade de considerar a cláusula da lei estadual como uma exceção ao direito federal estava excluída, em face do disposto no art. 31 da Constituição. Nesse sentido, restou apenas a possibilidade de declaração de nulidade da norma de direito estadual.

3.2 A colisão entre princípios

As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido –, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concre-

30. BVerfGE 1, 283 (292 e ss.).

tos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso.³¹

Exemplos de soluções de colisões entre princípios podem ser encontrados nos numerosos sopesamentos de interesses feitos pelo Tribunal Constitucional Federal.³² Aqui serão utilizadas duas decisões: a decisão sobre a incapacidade para participar de audiência processual e a decisão do caso Lebach. A análise da primeira decisão servirá para a compreensão da estrutura das soluções de colisões, que será resumida em uma lei de colisão; e a análise da segunda, para aprofundar essa compreensão e conduzir a uma concepção do resultado do sopesamento como norma de direito fundamental atribuída.

3.2.1 A lei de colisão

No caso sobre a incapacidade para participar de audiência processual tratava-se da admissibilidade de realização de uma audiência com a presença de um acusado que, devido à tensão desse tipo de procedimento, corria o risco de sofrer um derrame cerebral ou um infarto.³³ O tribunal observou que nesse tipo de caso há “uma relação de tensão entre o dever estatal de garantir uma aplicação adequada do direito penal e o interesse do acusado na garantia de seus direitos constitucionalmente consagrados, para cuja proteção a Constituição tam-

31. Sobre o conceito da dimensão do peso, cf. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 26-27.

32. Os sopesamentos de interesses demonstram com grande clareza que o Tribunal Constitucional Federal concebe as normas de direitos fundamentais (pelo menos também) como princípios. Isso pode ser percebido de forma ainda mais clara quando o tribunal formula expressamente mandamentos de otimização, como, por exemplo, no caso da decisão sobre o Partido Comunista Alemão (*BVerfGE* 5, 85 (204)): “o desenvolvimento de sua personalidade na *maior medida possível*”; na decisão sobre farmácias (*BVerfGE* 7, 377 (403)): “A escolha da profissão (...) deve ser protegida o *máximo* possível contra intervenções dos poderes estatais”; e na decisão sobre a regulação dos ofícios manuais (*BVerfGE* 13, 97 (195)): “a *maior liberdade possível* na escolha da profissão” (sem grifos nos originais).

33. *BVerfGE* 51, 324.

bém obriga o Estado”.³⁴ Essa relação de tensão não pode ser solucionada com base em uma precedência absoluta de um desses deveres, ou seja, nenhum desses deveres goza, “*por si só*, de prioridade”.³⁵ O “conflito” deve, ao contrário, ser resolvido “por meio de um sopesamento entre os interesses conflitantes”. O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses – que *abstratamente estão no mesmo nível* – tem *maior peso no caso concreto*: “Se esse sopesamento levar à conclusão de que os interesses do acusado, que se opõem à intervenção, têm, no caso concreto, um peso sensivelmente maior que os interesses em que se baseia a ação estatal, então, a intervenção estatal viola o princípio da proporcionalidade e, com isso, o direito fundamental do acusado que deriva do art. 2º, § 2º, 1, da Constituição”.³⁶ Essa situação de decisão corresponde exatamente à colisão entre princípios. As diferenças são de caráter terminológico. Na decisão não se fala em “colisão”, mas de uma “situação de tensão” e de um “conflito”; e aquilo que colide e que é sopesado não é caracterizado como “princípio”, mas como “dever”, “direito fundamental”, “pretensão” e “interesse”. Mas a caracterização da situação decisória como uma colisão entre princípios é perfeitamente possível. Isso ocorre quando se fala, de um lado, do dever de garantir, na maior medida possível, a operacionalidade do direito penal e, de outro lado, do dever de manter incólume, na maior medida possível, a vida e a integridade física do acusado. Esses deveres devem ser aplicados na medida das possibilidades fáticas e jurídicas de sua realização. Se houvesse apenas o princípio da operacionalidade do direito penal, a realização da audiência seria obrigatória ou, no mínimo, permitida.³⁷ Se houvesse apenas o

34. BVerfGE 51, 324 (345).

35. Idem.

36. BVerfGE 51, 324 (366).

37. Aqui será considerada apenas a constelação que surge do caso a ser solucionado e de ambos os princípios. Se se deixa de lado um dos princípios colidentes, a referência às possibilidades jurídicas perde seu significado. De mandamento de otimização, o princípio seria transformado em mandamento de maximização relativo apenas às possibilidades fáticas. Isso conduz à idéia geral segundo a qual os princípios, se isoladamente considerados – isto é, independentemente de sua relação com outros princípios –, têm natureza de mandamentos de maximização. Em virtude disso, alguém poderia pensar em definir os princípios como mandamentos de maximização, ao invés de mandamentos de otimização. Mas essa definição não contemplaria a relação constitutiva que os princípios têm com outros princípios. Seria, então, necessário ou expandi-la, por meio da adição de uma regra de otimização ao mandamento de

princípio da proteção da vida e da integridade física, a realização da audiência seria proibida. Portanto, se isoladamente considerados, ambos os princípios conduzem a uma contradição. Isso significa, por sua vez, que um princípio restringe as possibilidades jurídicas de realização do outro. Essa situação não é resolvida com a declaração de invalidade de um dos princípios e com sua conseqüente eliminação do ordenamento jurídico. Ela tampouco é resolvida por meio da introdução de uma exceção a um dos princípios, que seria considerado, em todos os casos futuros, como uma regra que ou é realizada, ou não é. A solução para essa colisão consiste no estabelecimento de uma relação de precedência condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto. Levando-se em consideração o caso concreto, o estabelecimento de relações de precedências condicionadas consiste na fixação de *condições* sob as quais um princípio tem precedência em face do outro. Sob outras condições, é possível que a questão da precedência seja resolvida de forma contrária.

Esse conceito de relação de precedência condicionada tem importância fundamental na compreensão das colisões entre princípios e, com isso, para a teoria dos princípios. Para poder explicá-lo com mais detalhes, os princípios colidentes no caso da incapacidade para participar de audiência processual serão chamados de P_1 (direito à vida e à integridade física) e P_2 (operacionalidade do direito penal). Isoladamente considerados, P_1 e P_2 levariam a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si: P_1 levaria a "é proibido realizar a audiência", e P_2 a "é obrigatória a realização da audiência". Essa colisão pode ser resolvida ou por meio do estabelecimento de uma relação de precedência incondicionada ou por meio do estabelecimento de uma relação de precedência condicionada. Como símbolo para a relação de precedência deve ser usado o sinal P .³⁸ Para as condições sob as quais um princípio tem precedência em face do outro será utilizado o sinal

maximização, ou suplementá-la, por meio de uma definição como mandamentos de otimização que abarcasse a conexão entre os princípios. Diante disso, a definição geral aqui escolhida – princípios como mandamentos de otimização – tem a vantagem da simplicidade. Além disso, ela não exclui, se for conveniente, a adoção de um ponto de vista no qual princípios sejam considerados em si mesmos ou de forma isolada, o que ao longo do texto ocorrerá com frequência.

38. Cf., sobre isso, Georg H. v. Wright, *The Logic of Preference*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1963, p. 19.

C. Há, então, quatro possibilidades de decisão do caso a partir da solução de uma colisão entre princípios:

- (1) $P_1 \text{ P } P_2$.
- (2) $P_2 \text{ P } P_1$.
- (3) $(P_1 \text{ P } P_2) C$.
- (4) $(P_2 \text{ P } P_1) C$.

(1) e (2) são relações incondicionadas de precedência. É possível falar também em relações de precedências “abstratas” ou “absolutas”. O Tribunal Constitucional Federal excluiu a possibilidade dessa forma de relação de precedência com a afirmação: “nenhum desses interesses goza, em si mesmo, de precedência sobre o outro”.³⁹ Essa afirmação vale de forma geral para as colisões entre princípios de direito constitucional. O princípio da dignidade humana, ao qual ainda voltarei, constitui somente à primeira vista uma exceção a essa idéia. Sobre, portanto, apenas a possibilidade de uma relação condicionada, ou, como também se pode dizer, de uma relação de precedência concreta ou relativa, como as indicadas sob os ns. (3) e (4). A questão decisiva é, portanto, sob quais condições qual princípio deve prevalecer e qual deve ceder. Nesse contexto, o Tribunal Constitucional Federal utiliza-se da muito difundida metáfora do peso. Em suas palavras, o que importa é se os “interesses do acusado no caso concreto têm manifestamente um peso significativamente maior que os interesses a cuja preservação a atividade estatal deve servir”.⁴⁰ Esses interesses não têm um peso quantificável. Por isso, é necessário indagar o que se quer dizer quando se fala em “pesos”. O conceito de relação condicionada de precedência oferece uma resposta simples. Em um caso concreto, o princípio P_1 tem um peso maior que o princípio colidente P_2 se houver razões suficientes para que P_1 prevaleça sobre P_2 sob as condições C , presentes nesse caso concreto. Essa idéia será precisada mais abaixo.

O sopesamento do Tribunal Constitucional Federal consiste, exatamente nos moldes acima apresentados, na alusão às condições de precedência (C) e na fundamentação da tese segundo a qual, sob essas condições, P_1 prevalece sobre P_2 . A condição de precedência de P_1 (ou seja, do princípio estabelecido por meio do art. 2º, § 2º, 1, da

39. BVerfGE 51, 324 (345).

40. BVerfGE 51, 324 (346).

Constituição alemã) encontra sua formulação mais geral no enunciado: "se a realização da audiência implica um risco provável e concreto à vida do acusado ou uma possibilidade de dano grave à sua saúde, então, a continuação do procedimento lesa seu direito fundamental garantido pelo art. 2º, § 2º, 1, da Constituição".⁴¹ Esse enunciado conduz a um ponto importante para a teoria das relações de precedências condicionadas. Salta aos olhos que nela não se faz menção à precedência de um princípio, de um interesse, de uma pretensão, de um direito ou de um objeto semelhante; na verdade, são indicadas *condições* sob as quais se verifica uma *violação a um direito fundamental*. Se uma ação viola um direito fundamental, isso significa que, do ponto de vista dos direitos fundamentais, ela é proibida. A frase citada pode, por isso, ser compreendida como uma formulação de uma regra, nos seguintes moldes: "se uma ação preenche as condições *C*, então, do ponto de vista dos direitos fundamentais, ela é proibida".

Portanto, aquilo que aqui é denominado como "condição de precedência", e identificado pela letra "*C*", desempenha um duplo papel. No enunciado de preferência:

$$(3) (P_1 \text{ P } P_2) \cdot C,$$

C é a condição de uma relação de precedência. Na formulação da regra:

- (5) Se uma ação *h* preenche *C*, então, *h* é proibida sob o ponto de vista dos direitos fundamentais,

C é o pressuposto do suporte fático de uma regra. Esse duplo caráter de *C* decorre necessariamente da estrutura do enunciado de preferência. Isso porque a precedência de *P*₁, ou seja, do princípio estabelecido no art. 2º, § 2º, 1, em face dos princípios que com ele colidem sob as condições *C* significa que a consequência jurídica que resulta de *P*₁ é aplicável se estiverem presentes as condições *C*.⁴² Por conse-

41. Idem.

42. No caso analisado tratava-se de decidir se a consequência jurídica resultante do princípio *P*₁ deveria ser realizada em toda sua extensão, ou não. Pode haver casos nos quais seja necessário excluir parte da consequência jurídica do princípio prevalente. Nesse caso, *P*₁ tem precedência em relação a *P*₂ sob as condições do caso (*C*) apenas em relação a uma consequência jurídica limitada (*R'*), o que pode ser simbolizado por (*P*₁ P *P*₂) *C*, *R'*. A questão da precedência em relação a uma consequência jurídica limitada deve ser distinguida dos problemas da adequação e da necessidade, a serem analisados mais adiante, os quais dizem respeito às possibilidades de realização fática do princípio.

guinte, de um enunciado de preferência acerca de uma relação condicionada de preferência decorre uma regra, que, diante da presença da condição de precedência, prescreve a consequência jurídica do princípio prevalente. Nesse sentido, é possível formular a seguinte lei sobre a conexão entre relações de preferências condicionadas e regras:

- (K) Se o princípio P_1 tem precedência em face do princípio P_2 sob as condições C : $(P_1 \text{ P } P_2) C$, e se do princípio P_1 , sob as condições C , decorre a consequência jurídica R , então, vale uma regra que tem C como suporte fático e R como consequência jurídica: $C \rightarrow R$.

Uma formulação menos técnica seria:

- (K') As condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro constituem o suporte fático de uma regra que expressa a consequência jurídica do princípio que tem precedência.

Essa lei, que será chamada de "*lei de colisão*", é um dos fundamentos da teoria dos princípios aqui defendida. Ela reflete a natureza dos princípios como mandamentos de otimização: em primeiro lugar, a inexistência de relação absoluta de precedência e, em segundo lugar, sua referência a ações e situações que não são quantificáveis. Ao mesmo tempo, constituem eles a base para a resposta a objeções que se apóiam na proximidade da teoria dos princípios com a teoria dos valores.⁴³⁻⁴⁴

3.2.2 Resultados de sopesamentos como normas de direito fundamental atribuídas

O que foi dito até agora pode ficar ainda mais claro com o auxílio do caso Lebach.⁴⁵ Nessa decisão estava em questão a seguinte situação: a emissora de televisão ZDF planejava exibir um documentário

43. Cf., neste Capítulo, III.1.

44. Aqui é necessário apenas salientar que, ao estabelecer relações concretas de precedência, a lei de colisão conduz a uma dogmática diferenciada dos direitos fundamentais específicos, isto é, não a preferências e cedências generalizantes. Assim, nos termos dessa lei, o estabelecimento de uma restrição não é uma questão tudo-ou-nada, mas um problema de "afastamento do direito fundamental em relações individuais" (BVerfGE 28, 243 (263)).

45. BVerfGE 35, 202.

chamado "O assassinato de soldados em Lebach". Esse programa pretendia contar a história de um crime no qual quatro soldados da guarda de sentinela de um depósito de munições do Exército Alemão, perto da cidade de Lebach, foram mortos enquanto dormiam e armas foram roubadas com o intuito de cometer outros crimes. Um dos condenados como cúmplice nesse crime, que, na época prevista para a exibição do documentário, estava perto de ser libertado da prisão, entendia que a exibição do programa, no qual ele era nominalmente citado e apresentado por meio de fotos, violaria seu direito fundamental garantido pelos arts. 1º, § 2º, e 2º, § 1º, da Constituição alemã, sobretudo porque sua ressocialização estaria ameaçada. O Tribunal Estadual rejeitou seu pedido de medida cautelar para proibir a exibição, e o Tribunal Superior Estadual negou provimento ao recurso contra essa decisão. O autor ajuizou, então, uma reclamação constitucional contra essas decisões.

Aqui interessam apenas as partes da decisão que se referem à solução da colisão entre princípios. Outros problemas, como o dos efeitos dos direitos fundamentais perante terceiros, não serão ainda abordados. A argumentação do Tribunal Constitucional Federal desenvolveu-se em três etapas, o que é de especial interesse para a teoria das condições de precedência. Na primeira etapa constatou-se uma "situação de tensão entre a proteção da personalidade, garantida pelo art. 2º, § 1º, combinado com o art. 1º, § 1º, da Constituição alemã, e a liberdade de informar por meio de radiodifusão, nos termos do art. 5º, § 1º, 2º".⁴⁶ Também aqui o primeiro princípio será simbolizado por P_1 , e o segundo por P_2 . Isoladamente considerados, P_1 levaria à proibição, e P_2 à permissão da exibição do programa. Esse "conflito" – como o Tribunal Constitucional Federal costuma chamar esse tipo de colisão – não é solucionado por meio da declaração de invalidade de uma das duas normas, mas por meio de "sopesamento", no qual nenhum dos princípios – nesse contexto, o Tribunal Constitucional Federal chama-os de "valores constitucionais" – "pode pretender uma precedência geral". Ao contrário, é necessário "decidir qual interesse deve ceder, levando-se em consideração a configuração típica do caso e suas circunstâncias especiais".⁴⁷ Uma descrição mais inequívoca de uma colisão entre princípios dificilmente

46. BVerfGE 35, 202 (219).

47. BVerfGE 35, 202 (225).

seria possível. Duas normas levam, se isoladamente consideradas, a resultados contraditórios entre si. Nenhuma delas é inválida, nenhuma tem precedência absoluta sobre a outra. O que vale depende da forma como será decidida a precedência entre elas sob a luz do caso concreto.⁴⁸ É necessário notar, neste ponto, que à já mencionada variedade de formas de se denominar os objetos do sopesamento deverá ser acrescentada mais uma, a dos “valores constitucionais”.

Depois da constatação de uma colisão entre princípios cujo valores abstratos estão no mesmo nível, o Tribunal Constitucional Federal, em um segundo passo, sustenta uma precedência geral da liberdade de informar (P_2) no caso de uma “informação atual sobre atos criminosos” (C_1),⁴⁹ ou seja; ($P_2 \text{ P } P_1$) C_1 . Essa relação de precedência é interessante, porque nela se sustenta apenas uma precedência geral ou básica. Isso significa que nem toda informação atual é permitida. A condição de precedência e, com isso, o suporte fático da regra que corresponde ao enunciado de preferência segundo a lei de colisão incluem uma cláusula *ceteris paribus*, a qual permite o estabelecimento de exceções.

A decisão ocorre na terceira etapa. Nela, o tribunal constata que, no caso da “repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime,

48. Não pode haver dúvidas de que o tribunal decidiu o caso por meio de um sopesamento entre princípios. Mas é possível indagar se esse era o único caminho possível. E são considerações feitas pelo próprio tribunal que dão ensejo a essa indagação, quando ele examina se a transmissão de um programa que identificasse o reclamante seria *adequada e necessária* para os *objetivos* perseguidos pela emissora ZDF. Dentre esses objetivos estão, por exemplo, o esclarecimento da população sobre a eficácia das sanções penais, um efeito intimidador sobre outros possíveis criminosos e um “fortalecimento da moral pública e da responsabilidade social” (*BVerfGE* 35, 202 (243)). Diante disso, seria possível sustentar que o caso poderia ter sido resolvido não no nível do sopesamento entre valores ou princípios constitucionais, ou seja, não na terceira etapa da máxima da proporcionalidade (cf., a respeito, Lothar Hirschber, *Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit*, Göttingen: Schwartz, 1982, pp. 2 e ss.; cf. também o tópico I.8, neste Capítulo), mas nas etapas anteriores – da adequação e da necessidade (nesse sentido, cf. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, p. 34). Mas dessa forma teria sido possível apenas excluir a identificação nominal do reclamante e a exposição de sua imagem. No entanto, como o tribunal pressupõe que o reclamante teria seus direitos violados mesmo sem sua identificação nominal e sem a exposição de sua imagem (*BVerfGE* 35, 202 (243)), a decisão na terceira etapa da máxima da proporcionalidade era inafastável. Somente se o tribunal não tivesse partido dessa premissa é que seria possível solucionar o caso apenas com o auxílio das máximas da adequação e da necessidade.

49. *BVerfGE* 35, 202 (231).

não mais revestido de um interesse atual pela informação", que "coloca em risco a ressocialização do autor" (C_2), a proteção da personalidade (P_1) tem precedência sobre a liberdade de informar (P_2), o que, no caso em questão, significa a proibição da veiculação da notícia.⁵⁰ Nesse sentido, vale o enunciado de preferência ($P_1 \text{ P } P_2$) C_2 . C_2 é composto por quatro condições (repetição/ausência de interesse atual pela informação/grave crime/risco à ressocialização). A regra $C_2 \rightarrow R$, que corresponde ao enunciado de preferência, é uma regra com quatro atributos de suporte fático, com a seguinte estrutura:

$$(6) T_1 \text{ e } T_2 \text{ e } T_3 \text{ e } T_4 \rightarrow R.$$

Ou seja: uma notícia repetida (T_1), não revestida de interesse atual pela informação (T_2), sobre um grave crime (T_3), e que põe em risco a ressocialização do autor (T_4), é proibida do ponto de vista dos direitos fundamentais.

Anteriormente foram designadas como normas de direitos fundamentais tanto as estabelecidas diretamente pela Constituição quanto as normas atribuídas.⁵¹ Uma norma de direito fundamental atribuída é uma norma para cuja atribuição é possível uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais. Se é possível uma correta fundamentação referida a direitos fundamentais para a norma que se acaba de apresentar – algo que aqui se pressupõe –, então, ela é uma norma de direito fundamental. Ao mesmo tempo ela é uma regra, à qual se podem subsumir os elementos do caso concreto, como se fosse uma norma positiva. Foi o que aconteceu no caso *Lebach*.⁵² Diante disso, pode-se afirmar: como resultado de todo sopesamento que seja correto do ponto de vista dos direitos fundamentais pode ser formulada uma norma de direito fundamental atribuída, que tem estrutura de uma regra e à qual o caso pode ser subsumido. Nesse sentido, mesmo que todas as normas de direitos fundamentais diretamente estabelecidas tivessem a estrutura de princípios – o que, como ainda será demonstrado, não ocorre –, ainda assim haveria normas de direitos fundamentais com a estrutura de princípios e normas de direitos fundamentais com a estrutura de regras.

50. *BVerfGE* 35, 202 (237).

51. Cf. Capítulo 2, II.2.

52. Sobre a estrutura dessa subsunção, cf. Robert Alexy, "Die logische Analyse juristischer Entscheidungen", pp. 195 e ss.

Essas últimas considerações conduzem à aplicação da teoria dos princípios à teoria das normas de direitos fundamentais. Mas, antes de adentrar esse caminho, a análise da teoria dos princípios ainda precisa ser aprofundada um pouco mais. Até aqui os princípios foram definidos como mandamentos de otimização, e as regras como normas que sempre ou são satisfeitas ou não o são. Dessa diferença decorrem os diferentes comportamentos em casos de conflitos ou colisões. A partir de agora, é necessário analisar outras características que decorrem dessas características básicas, e também abordar algumas objeções que poderiam ser feitas diretamente contra a teoria sobre conflitos e colisões. As objeções de caráter mais geral, que se baseiam na proximidade entre a teoria dos princípios e as teorias dos valores e do sopesamento, serão tratadas apenas após a aplicação da teoria dos princípios à teoria das normas de direitos fundamentais.

4. O distinto caráter "*prima facie*" das regras e dos princípios

Uma primeira característica importante que decorre do que foi dito até agora é o distinto caráter *prima facie* das regras e dos princípios.⁵³ Princípios exigem que algo seja realizado na maior medida

53. Sobre o conceito de caráter *prima facie*, cf. a obra fundamental, ainda que pouco clara em muitos pontos, de W. D. Ross, *The Right and the Good*, Oxford: Clarendon, 1930, pp. 19 e ss., 28 e ss., bem como Kurt Baier, *The Moral Point of View*, Ithaca/London: Cornell University Press, 1958, pp. 102 e ss., e Richard M. Hare, *Moral Thinking*, Oxford: Clarendon, 1981, pp. 27 e ss. e 38 e ss., os quais se baseiam em Ross. John Searle ("*Prima facie* obligations", in Joseph Raz (ed.), *Practical Reasoning*, Oxford: Oxford University Press, 1978, pp. 84 e ss.) sugere que se abra mão da expressão "*prima facie*" e de seus contrapontos para, no lugar deles, diferenciar entre aquilo "que alguém tem como obrigação de fazer" e aquilo "que alguém deve fazer depois de se levar tudo em consideração" (idem, pp. 88-89). Aqui interessa apenas que, também segundo Searle, há dois usos para "dever-ser" (*ought*): um "depois de se levar tudo em consideração" e um *não* "depois de se levar tudo em consideração". É necessário concordar com Searle quando ele afirma que o segundo caso está associado a alguns problemas. Mas renunciar à expressão "*prima facie*" seria recomendável apenas se se pretendesse renunciar a toda e qualquer distinção terminológica. Para uma interessante tentativa de reconstrução do caráter *prima facie* com os meios da lógica deontica, cf. Jaakko Hintikka, "Some main problems of Deontic Logic", in Risto Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht: Reidel, 1971, pp. 67 e ss.

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Nesse sentido, eles não contêm um *mandamento definitivo*, mas apenas *prima facie*. Da relevância de um princípio em um determinado caso não decorre que o resultado seja aquilo que o princípio exige para esse caso. Princípios representam razões que podem ser afastadas por razões antagônicas. A forma pela qual deve ser determinada a relação entre razão e contra-razão não é algo determinado pelo próprio princípio. Os princípios, portanto, não dispõem da extensão de seu conteúdo em face dos princípios colidentes e das possibilidades fáticas.

O caso das regras é totalmente diverso. Como as regras exigem que seja feito exatamente aquilo que elas ordenam, elas têm uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas. Essa determinação pode falhar diante de impossibilidades jurídicas e fáticas; mas, se isso não ocorrer, então, vale definitivamente aquilo que a regra prescreve.

Diante disso, alguém poderia imaginar que os princípios têm sempre um mesmo caráter *prima facie*, e as regras um mesmo caráter definitivo. Um tal modelo parece estar presente em Dworkin, quando ele afirma que regras, se válidas, devem ser aplicadas de forma tudo-ou-nada, enquanto os princípios apenas contêm razões que indicam uma direção, mas não têm como consequência necessária uma determinada decisão.⁵⁴ Esse modelo é, contudo, muito simples. Um modelo diferenciado é necessário. Mas também no âmbito desse modelo diferenciado o diferente caráter *prima facie* das regras e dos princípios deve ser mantido.

Do lado das regras, a necessidade de um modelo diferenciado decorre da possibilidade de se estabelecer uma cláusula de exceção em uma regra quando da decisão de um caso. Se isso ocorre, a regra perde, para a decisão do caso, seu caráter definitivo. A introdução de uma cláusula de exceção pode ocorrer em virtude de um princípio. Ao contrário do que sustenta Dworkin,⁵⁵ as cláusulas de exceção introduzidas em virtude de princípios não são nem mesmo teoricamente enumeráveis.⁵⁶ Nunca é possível ter certeza de que, em um novo caso, não será necessária a introdução de uma nova cláusula de exceção.

54. Cf. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 24 e 26.

55. Cf. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, p. 25.

56. Cf. Robert Alexy, "Zum Begriff des Rechtsprinzips", pp. 68 e ss.

Entretanto, é possível imaginar um sistema jurídico que proíba a restrição de regras por meio da introdução de cláusulas de exceção. Como demonstram os inúmeros casos da assim chamada redução teleológica, o sistema jurídico alemão é um sistema que não contém tal proibição, pelo menos não para todas as áreas do direito.⁵⁷ As regras para as quais uma tal proibição não é aplicável perdem seu caráter definitivo estrito. Contudo, o caráter *prima facie* que elas adquirem em razão da perda desse caráter definitivo estrito é muito diferente daquele dos princípios. Um princípio cede lugar quando, em um determinado caso, é conferido um peso maior a um outro princípio antagônico. Já uma regra não é superada pura e simplesmente quando se atribui, no caso concreto, um peso maior ao princípio contrário ao princípio que sustenta a regra. É necessário que sejam superados também aqueles princípios que estabelecem que as regras que tenham sido criadas pelas autoridades legitimadas para tanto devem ser seguidas e que não se deve relativizar sem motivos uma prática estabelecida. Tais princípios devem ser denominados "princípios formais". Em um ordenamento jurídico, quanto mais peso se atribui aos princípios formais, tanto mais forte será o caráter *prima facie* de suas regras.⁵⁸ Somente quando se deixa de atribuir algum peso a esse tipo de princípios — o que teria como consequência o fim da validade das regras enquanto regras — é que regras e princípios passam a ter o mesmo caráter *prima facie*.

O fato de o enfraquecimento de seu caráter definitivo não fazer com que as regras passem a ter o mesmo caráter *prima facie* dos princípios constitui apenas um lado da questão. O outro lado é que, mesmo diante de um fortalecimento de seu caráter *prima facie*, os princípios não obtêm um caráter *prima facie* como o das regras. O caráter *prima facie* dos princípios pode ser fortalecido por meio da introdução de uma carga argumentativa a favor de determinados princípios ou de deter-

57. Cf., por exemplo, BGHZ 24, 153; 59, 236. Para uma visão geral, cf. Hans-Friedrich Brandenburg, *Die teleologische Reduktion*, Göttingen: Schwartz, 1983.

58. Nesse contexto é possível introduzir os conceitos de *rigidez* e *flexibilidade* de um ordenamento jurídico. Um ordenamento jurídico é tão mais rígido quanto mais forte for o caráter *prima facie* de suas regras e quanto mais coisas forem reguladas por meio delas. Para uma verificação de que a polêmica sobre a necessária rigidez do ordenamento jurídico não é um tema novo, cf. Okko Behrends, "Institutionelles und prinzipielles Denken im römischen Privatrecht", *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung)* 95 (1978), pp. 187 e ss.

minadas classes de princípios. A decisão no caso da incapacidade para participar da audiência processual mostrou que tanto as normas que conferem direitos fundamentais aos indivíduos quanto as normas que exigem a persecução de um interesse da comunidade podem ser compreendidas como princípios. É possível introduzir uma carga argumentativa a favor dos princípios do primeiro tipo e contra os princípios do segundo tipo, ou seja, uma carga argumentativa a favor de interesses individuais e contra interesses coletivos. Algo semelhante é o que Schlink tem em vista quando diz que “direitos fundamentais [são] regras sobre ônus argumentativo”.⁵⁹ Aqui não interessa ainda investigar se tais regras sobre ônus argumentativo são corretas. O que aqui interessa é somente que a aceitação de uma carga argumentativa em favor de determinados princípios não iguala seu caráter *prima facie* ao das regras. Mesmo uma regra sobre ônus argumentativo não exclui a necessidade de definir as condições de precedência no caso concreto. Ela tem como consequência apenas a necessidade de se dar precedência a um princípio em relação a outro caso haja razões equivalentes em favor de ambos ou em caso de dúvida. Não há dúvidas de que isso reforça o caráter *prima facie* do princípio confirmado pela regra sobre ônus argumentativo. Ainda assim, o caráter *prima facie* das regras, que se baseia na existência de decisões tomadas pelas autoridades legítimas para tanto ou decorrentes de uma prática reiterada, continua a ser algo fundamentalmente diferente e muito mais forte.

Portanto, mesmo à luz dos necessários refinamentos acima apresentados, regras e princípios continuam a ter um caráter *prima facie* distinto

5. Regras e princípios como razões

As reflexões levadas a cabo até agora demonstram que regras e princípios são razões de naturezas distintas. Princípios são sempre razões *prima facie* e regras são, se não houver o estabelecimento de alguma exceção, razões *definitivas*. Mas com essa identificação como razões *prima facie* e razões definitivas ainda não se disse *para quê* regras e princípios são razões. Eles podem ser considerados como

59. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, p. 195.

razões para ações ou razões para normas; enquanto razões para normas, podem eles ser razões para normas universais (gerais-abstratas) e/ou para normas individuais (juízos concretos de dever-ser).⁶⁰ O entendimento de que normas são razões para ações é defendido por Raz.⁶¹ Aqui, ao contrário, regras e princípios devem ser considerados como razões para normas. O fosso entre ambas as concepções é, no entanto, menos profundo do que pode parecer, pois, se regras e princípios são razões para normas, eles são também indiretamente razões para ações. A visão aqui defendida corresponde ao ponto de vista da Ciência do Direito. Na Ciência do Direito são formulados juízos sobre o que é devido, o que é proibido e o que é permitido, e o juiz decide exatamente sobre isso. O conceito semântico de norma é desenvolvido para essa tarefa. Se se compreendem regras e princípios como razões para normas, a relação de fundamentação fica limitada a objetos de uma categoria, o que facilita seu manejo e, sobretudo, sua análise lógica.

Um dos critérios para a diferenciação entre regras e princípios, acima mencionados, classifica os princípios como razões para regras, e somente para regras. Se esse critério fosse correto, princípios não poderiam servir como razões diretas para decisões concretas. A compreensão de que os princípios são razões para regras e as regras são razões para decisões concretas (normas individuais) tem, à primeira vista, algo de plausível. Mas, a partir de uma análise mais detalhada, essa concepção mostra-se incorreta. Regras podem ser também razões para outras regras e princípios podem também ser razões para decisões concretas. Quem aceita para si como inafastável a norma "não ferir alguém em sua auto-estima", aceita uma regra. Essa regra pode ser uma razão para outra regra: "não falar com alguém sobre seus fracassos". De outro lado, princípios podem também ser razões para decisões, isto é, para juízos concretos de dever-ser. Nesse sentido, o princípio da proteção à vida foi, na decisão sobre a incapacidade de participar de audiência processual, uma razão para a não-admissibilidade da realização da audiência. Ainda assim a caracterização dos princípios como razões para regras indica um ponto acertado. Ela reflete o diferente caráter das regras e dos princípios como razões para

60. Sobre essas diferenciações, cf. a nota de rodapé 11, neste Capítulo.

61. Cf. Joseph Raz, *Practical Reason and Norms*, London: Oxford University Press, 1975, pp. 15 e 58.

juízos concretos de dever-ser. Se uma regra é uma razão para um determinado juízo concreto – o que ocorre quando ela é válida, aplicável e infensa a exceções –, então, ela é uma *razão definitiva*. Se o juízo concreto de dever-ser tem como conteúdo a definição de que alguém tem determinado direito, então, esse direito é um *direito definitivo*. Princípios são, ao contrário, sempre razões *prima facie*. Isoladamente considerados, eles estabelecem apenas direitos *prima facie*. Assim, a emissora de televisão ZDF tinha apenas um direito *prima facie* à exibição do documentário. Decisões sobre direitos pressupõem a identificação de direitos definitivos. O caminho que vai do princípio, isto é, do direito *prima facie*, até o direito definitivo passa pela definição de uma relação de preferência. Mas a definição de uma relação de preferência é, segundo a lei de colisão, a definição de uma regra. Nesse sentido, é possível afirmar que sempre que um princípio for, em última análise, uma razão decisiva para um juízo concreto de dever-ser, então, esse princípio é o fundamento de uma regra, que representa uma razão definitiva para esse juízo concreto. Em si mesmos, princípios nunca são razões definitivas. Esser provavelmente tinha essas conexões em mente quando afirmava que o “princípio (...) não é, ele mesmo, ‘diretiva’, mas fundamento, critério e justificação da diretiva”;⁶² e seria também a isso que Kant se referia quando afirmava que “seria perfeitamente possível haver duas *razões* para a obrigação (*rationes obligandi*), em um sujeito e na regra que ele prescreve a si mesmo, das quais, no entanto, ou uma ou a outra não é suficiente para obrigá-lo (*rationes obligandi non obligantes*); mas, nesse caso, um deles não é dever”.⁶³

6. Generalidade e princípios

É razoavelmente simples fundamentar a correção relativa do critério da generalidade. Normalmente, princípios são relativamente gerais, porque ainda não estão em relação com as possibilidades dos mundos fático e normativo. A partir do momento em que se passam a se relacionar com os limites dos mundos fático e normativo, chega-se, então, a um *sistema diferenciado de regras*. O conceito de sistema

62. Josef Esser, *Grundsatz und Norm*, p. 51.

63. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, IV, p. 224.

diferenciado de regras dependente dos princípios será importante quando forem analisadas as críticas que se voltam contra um pretensão caráter generalizante do sopesamento. A existência de normas de alto grau de generalidade que não são princípios demonstra que o critério da generalidade é apenas relativamente correto. O enunciado normativo “só serão penalmente puníveis os atos que a lei previamente definir como crimes” (art. 103, § 2º, da Constituição alemã; § 1º do Código Penal alemão) pode dar ensejo a uma série de problemas interpretativos, e a ele subjaz um princípio ao qual se pode recorrer para sua interpretação. Mas esse enunciado estabelece uma regra, já que aquilo que ele exige é algo que sempre ou é cumprido, ou não. Como essa norma é frequentemente caracterizada como “princípio”, ela é um exemplo dos casos em que a teoria dos princípios aqui defendida se desvia do uso corrente da linguagem.

As razões para as outras múltiplas características dos princípios são óbvias. Enquanto razões para regras de natureza muitas vezes bastante técnica, o conteúdo axiológico dos princípios é mais facilmente identificável que o das regras; como razões decisivas para inúmeras regras, os princípios têm uma importância substancial fundamental para o ordenamento jurídico; sua relação à idéia de direito decorre de um modelo de fundamentação que avança do mais geral na direção do sempre mais especial; e a contraposição dos princípios, enquanto normas “desenvolvidas”, às normas “criadas” deve-se à desnecessidade de que os princípios sejam estabelecidos de forma explícita, podendo decorrer de uma tradição de posituação detalhada e de decisões judiciais que, em geral, expressam concepções difundidas sobre o que deve ser o direito.

7. Três objeções ao conceito de princípio

Independentemente de ser recomendável sua utilização no âmbito da teoria dos direitos fundamentais, contra o conceito de princípio aqui apresentado podem ser suscitadas três objeções. A primeira sustenta que há colisões entre princípios que podem ser resolvidas por meio da declaração de invalidade de um deles; a segunda, que existem princípios absolutos, que nunca podem ser colocados em uma relação de preferência em face de outros princípios; e a terceira, que o conceito de princípio é muito amplo e, por isso, inútil, porque abarcaria

todo e qualquer interesse que possa ser introduzido em um processo de sopesamento.

7.1 A invalidade de princípios

Não há dúvidas de que há princípios que, se surgissem em um determinado ordenamento jurídico, seriam declarados inválidos no primeiro confronto com outros princípios. Um exemplo seria o princípio da segregação racial. O direito constitucional da República Federal da Alemanha exclui esse princípio. Não se pode dizer que haja algum caso em que esse princípio tenha preferência e outros em que não tenha; enquanto valerem os princípios do atual direito constitucional, esse princípio será preterido em todos os casos, o que significa que ele não é válido. Se houvesse um confronto, ele seria resolvido como um conflito entre regras. Diante disso, alguém poderia sustentar que o teorema da colisão apresentado anteriormente não é válido. Isso significaria, contudo, ignorar um ponto decisivo. Para explicar por que isso é assim, é necessário reunir os conceitos de conflito entre regras e colisão entre princípios sob o conceito de contradição normativa em seu sentido mais amplo. O ponto decisivo é a existência de dois tipos categorialmente distintos de contradição normativa em sentido amplo. O primeiro diz respeito ao pertencimento ao ordenamento jurídico, ou seja, à validade. O conflito de regras é o exemplo principal desse tipo de contradição. O princípio da segregação racial demonstra que também no caso dos princípios é possível que a questão da validade seja postulada, embora isso raramente ocorra. O âmbito da validade diz respeito à decisão sobre o que deve ser colocado dentro e o que deve ser deixado de fora do ordenamento jurídico.

Já o segundo tipo de contradição normativa em sentido amplo ocorre no interior do ordenamento jurídico. Contradições normativas em sentido amplo que ocorrem no interior do ordenamento jurídico são sempre colisões entre princípios, e colisões entre princípios ocorrem sempre no interior do ordenamento jurídico. Com isso fica claro que o conceito de colisão entre princípios pressupõe a validade dos princípios colidentes. Por isso, a referência à possibilidade de se classificar princípios como inválidos não atinge o teorema da colisão, apenas torna mais claro um de seus pressupostos.

7.2 *Princípios absolutos*

O problema da invalidade de princípios dizia respeito a princípios extremamente fracos, isto é, princípios que em caso algum prevalecem sobre outros. No caso dos princípios absolutos trata-se de princípios extremamente fortes, isto é, de princípios que em nenhuma hipótese cedem em favor de outros. Se existem princípios absolutos, então, a definição de princípios deve ser modificada, pois se um princípio tem precedência em relação a todos os outros em casos de colisão, até mesmo em relação ao princípio que estabelece que as regras devem ser seguidas, nesse caso, isso significa que sua realização não conhece nenhum limite jurídico, apenas limites fáticos. Diante disso, o teorema da colisão não seria aplicável.

É fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um ordenamento jurídico que inclua direitos fundamentais. Princípios podem se referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se um princípio se refere a interesses coletivos e é absoluto, as normas de direitos fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a ele. Assim, até onde o princípio absoluto alcançar não pode haver direitos fundamentais. Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites desse princípio levaria à seguinte situação contraditória: em caso de colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio absoluto, teriam que ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, também fundamentados pelo princípio absoluto. Diante disso, ou os princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos individuais que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não podem ser garantidos a mais de um sujeito de direito.

Seria ainda possível sustentar que a Constituição alemã estabelece pelo menos um direito absoluto, fundamentado pelo art. 1º, § 1º, 1: "A dignidade humana é inviolável". De fato, o art. 1º, § 1º, 1, desperta a impressão de um caráter absoluto. A razão para essa impressão não reside, contudo, no estabelecimento de um princípio absoluto por parte dessa disposição, mas no fato de a norma da dignidade humana ser tratada em parte como regra e em parte como princípio, e também no fato de existir, para o caso da dignidade, um amplo grupo de condições de precedência que conferem altíssimo grau de certeza de que, sob essas condições, o princípio da dignidade humana prevalecerá con-

tra os princípios colidentes. Um âmbito definido por tais condições, isto é, protegido pelas regras a que correspondem essas condições, é aquele que o Tribunal Constitucional Federal classifica como "esfera nuclear da configuração da vida privada, protegida de forma absoluta".⁶⁴

Nos casos em que a norma da dignidade humana é relevante, sua natureza de regra pode ser percebida por meio da constatação de que não se questiona se ela prevalece sobre outras normas, mas tão-somente se ela foi violada, ou não. Contudo, em face da abertura da norma da dignidade humana, há uma ampla margem de apreciação na resposta a essa questão. Esclarecedoras são as considerações do Tribunal Constitucional Federal na decisão sobre interceptação telefônica: "No que diz respeito ao princípio da inviolabilidade da dignidade humana, disposto no art. 1º da Constituição alemã (...), tudo depende da definição das circunstâncias nas quais a dignidade humana pode ser considerada como violada. Com certeza não há uma resposta geral, devendo-se sempre levar em consideração o caso concreto".⁶⁵ Com a fórmula do "tratamento degradante",⁶⁶ utilizada nessa decisão, o tribunal cria para si uma ampla margem de apreciação para essa definição nos casos concretos. E para essa definição existe a possibilidade de se recorrer ao sopesamento. A utilização dessa possibilidade pelo tribunal pode ser verificada em manifestações como aquela segundo a qual a dignidade humana não é violada "se a exclusão da proteção judicial não é motivada por uma desconsideração ou uma depreciação da pessoa humana, mas sim por uma necessidade de manter em segre-

64. BVerfGE 34, 238 (245). É interessante, nessa decisão, como o tribunal define a relação entre o conceito de âmbito absolutamente protegido e o conceito de sopesamento: "nem mesmo interesses preponderantes da coletividade podem justificar uma intervenção na esfera nuclear da configuração da vida privada, protegida de forma absoluta; não há lugar para um sopesamento nos termos da máxima da proporcionalidade". Esse enunciado suscita problemas de interpretação. Deve ele ser compreendido de forma a que o princípio da dignidade humana tenha precedência também nos casos em que um princípio colidente tenha um peso maior *do ponto de vista do direito constitucional*? Isso seria contraditório. Para evitar essa contradição, a cláusula "interesses preponderantes da coletividade" tem que ser compreendida de forma a que se refira a interesses que tenham mais peso a partir de algum outro ponto de vista que não o do direito constitucional. Assim, do ponto de vista do direito constitucional seria possível simplesmente sopesar e decidir que o princípio da dignidade humana é mais importante.

65. BVerfGE 30, 1 (25).

66. BVerfGE 30, 1 (26).

do as medidas que sirvam para a proteção da ordem democrática e para a própria existência do Estado".⁶⁷ Isso pode ser compreendido de forma tal que, quando a manutenção do segredo for necessária e outras condições forem satisfeitas – como o controle jurídico por meio de órgãos de representação popular e seus órgãos auxiliares –, então, o princípio da proteção do Estado tem precedência em face do princípio da dignidade humana no que diz respeito à exclusão da proteção judicial em casos de escuta telefônica. A contraposição entre razões e contra-razões é perceptível a partir da constatação de que, caso as condições mencionadas desaparecessem, a medida a ser julgada permaneceria a mesma, mas não seria mais considerada permitida. O princípio da dignidade humana prevaleceria, então, sobre o princípio da proteção do Estado. Isso pode ser generalizado: se no nível dos princípios a dignidade *tem precedência*, então, ela foi *violada* no nível das regras.

Que o princípio da dignidade humana é sopesado diante de outros princípios, com a finalidade de determinar o conteúdo da regra da dignidade humana, é algo que pode ser percebido com especial clareza na decisão sobre prisão perpétua, na qual se afirma que "a dignidade humana (...) tampouco é violada se a execução da pena for necessária em razão da permanente periculosidade do preso e se, por essa razão, for vedada a graça".⁶⁸ Com essa formulação fica estabelecido que a proteção da "comunidade estatal", sob as condições mencionadas, tem precedência em face do princípio da dignidade humana. Diante de outras condições a precedência poderá ser definida de outra forma.

Por isso, é necessário que se pressuponha a existência de duas normas da dignidade humana: uma regra da dignidade humana e um princípio da dignidade humana. A relação de preferência do princípio da dignidade humana em face de outros princípios determina o conteúdo da regra da dignidade humana. Não é o princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em razão de sua abertura semântica, não necessita de limitação em face de alguma possível relação de preferência.⁶⁹ O prin-

67. BVerfGE 30, 1 (27).

68. BVerfGE 45, 187 (242).

69. A vantagem dessa construção é, de um lado, a não-necessidade de introdução de uma cláusula de restrição no direito fundamental à dignidade humana e, de outro, a possibilidade de realização de um sopesamento entre o princípio da dignidade e outros princípios constitucionais. A possibilidade – suscitada por Kloepper – de "uma dignidade humana que se imponha, em qualquer circunstância, contra todo e qualquer

cípio da dignidade humana pode ser realizado em diferentes medidas. O fato de que, dadas certas condições, ele prevalecerá com maior grau de certeza sobre outros princípios não fundamenta uma natureza absoluta desse princípio, significando apenas que, sob determinadas condições, há razões jurídico-constitucionais praticamente inafastáveis para uma relação de precedência em favor da dignidade humana. Mas essa tese sobre a existência de uma posição nuclear também vale para outras normas de direitos fundamentais. Ela não afeta sua natureza de princípio. Por isso, é possível dizer que a norma da dignidade humana não é um princípio absoluto. A impressão de um caráter absoluto advém, em primeiro lugar, da existência de duas normas da dignidade humana: uma regra e um princípio; além disso, essa impressão é reforçada pelo fato de que há uma série de condições sob as quais o princípio da dignidade humana prevalecerá – com grande grau de certeza – em face de todos os outros princípios.

7.3 A amplitude do conceito de princípio

Princípios podem se referir tanto a direitos individuais quanto a interesses coletivos. No caso Lebach, por exemplo, dois princípios são contrapostos: um garante um direito *prima facie* à proteção da personalidade, e o outro um direito *prima facie* à liberdade de informar.⁷⁰ Por sua vez, na decisão acerca da capacidade para participar de audiência processual colidem os direitos à vida e à incolumidade física com o princípio da garantia da operacionalidade da justiça penal,⁷¹ que é um princípio vinculado a um interesse coletivo. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal oferece inúmeros exemplos de princípios vinculados a interesses coletivos. Essa série de exemplos

outro interesse constitucional” reduziria “a garantia da dignidade, no fim das contas, (...) a uma defesa contra brutalidades apocalípticas” (Michael Kloepfer, “Grundrechtsbestand und Grundrechtsschranken in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – dargestellt am Beispiel der Menschenwürde”, in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, v. 2, Tübingen: Mohr, 1976, p. 411) pode dessa forma ser evitado, sem que se insira uma cláusula não-escrita de restrição no suporte fático da norma da dignidade humana, o que parece ser a sugestão de Kloepfer. A possibilidade dessa construção decorre da abertura semântica do conceito de dignidade humana.

70. BVerfGE 35, 202 (219). Cf. também BVerfGE 30, 173 (195).

71. BVerfGE 51, 324 (345).

vai desde a saúde da população,⁷² o fornecimento de energia⁷³ e a segurança alimentar,⁷⁴ passa pelo combate ao desemprego⁷⁵ e engloba, por fim, a garantia da estrutura interna das Forças Armadas,⁷⁶ a segurança da República Federal da Alemanha⁷⁷ e a proteção da ordem democrática.⁷⁸ O fato de que um princípio se refira a esses tipos de interesses coletivos significa que ele exige a criação ou a manutenção de situações que satisfaçam – na maior medida possível, diante das possibilidades jurídicas e fáticas – critérios que vão além da validade ou da satisfação de direitos individuais.⁷⁹

72. BVerfGE 7, 377 (414-415).

73. BVerfGE 30, 292 (317).

74. BVerfGE 39, 210 (227).

75. BVerfGE 21, 245 (251).

76. BVerfGE 28, 243 (261).

77. BVerfGE 28, 175 (186).

78. BVerfGE 30, 1 (26-27). Para outras referências, cf. Harald Schneider, *Die Güterabwägung des Bundesverfassungsgerichts*, pp. 133 e ss.

79. Essa definição faz com que fique claro que a distinção entre direitos individuais e interesses coletivos não é tão simples como pode parecer à primeira vista. É possível distinguir quatro relações entre direitos individuais e interesses coletivos, as quais podem ser combinadas entre si de inúmeras formas. (1) Um direito individual é exclusivamente um meio para um interesse coletivo. Essa relação é pressuposta, por exemplo, por quem vê no direito de propriedade apenas um meio para a realização da produção econômica. Uma colisão entre o direito e o interesse coletivo é impossível, pois se o direito perde seu caráter de meio ou até mesmo embarça a produtividade, então, não há mais fundamento para o direito. Se todos os direitos individuais fossem apenas meios para interesses coletivos, não poderia mais haver colisões entre eles. Nesse sentido, direitos como meios para interesses coletivos não teriam força própria. (2) Um interesse coletivo é exclusivamente um meio para direitos. Dessa relação parte aquele que afirma que a garantia da operacionalidade da justiça penal serve apenas para a segurança dos direitos individuais. Por esse ponto de vista, a colisão entre um direito individual e o princípio da garantia da operacionalidade da justiça penal é, na verdade, uma colisão entre direitos individuais (ou entre os princípios que os garantem). Se todos os interesses coletivos fossem exclusivamente meios para direitos individuais, então, haveria apenas colisões entre direitos. (3) Um interesse coletivo é uma situação na qual as normas que garantem direitos individuais são válidas ou satisfeitas. Se isso valesse para todos os interesses coletivos, falar nesse tipo de interesses seria redundante. (4) Entre direitos individuais e interesses coletivos não existem nem as relações meio-fim do tipo (1) e (2), nem a relação de identidade do tipo (3). Se direitos individuais não têm caráter absoluto diante de interesses coletivos, então, sob o pressuposto (4), as colisões entre direitos individuais e interesses coletivos são colisões entre objetos pertencentes a categorias distintas. Relações do quarto tipo podem existir ao lado de relações do primeiro ao terceiro tipos. Qual das relações é aplicável é algo que depende das teses sobre o conteúdo e a natureza dos

O conceito de princípio em Dworkin é definido de forma mais restrita que essa. Segundo ele, princípios são apenas aquelas normas que podem ser utilizadas como razões para direitos individuais. Normas que se refiram a interesses coletivos são por ele denominadas como "políticas".⁸⁰ A diferenciação entre direitos individuais e interesses coletivos é, sem dúvida, importante. Mas não é nem exigível nem conveniente vincular o conceito de princípio ao conceito de direito individual. As características lógicas comuns aos dois tipos de princípios aos quais Dworkin faz referência com seu conceito de "princípio em sentido genérico"⁸¹ – e que aparecem com clareza nos casos de colisões entre princípios – indicam a conveniência de um conceito amplo de princípio. As diferenças apontadas por Dworkin podem ser feitas no âmbito desse conceito amplo de princípio. O mesmo vale para outras possíveis diferenciações.

8. A teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade

Já se deu a entender que há uma conexão entre a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade. Essa conexão não poderia ser mais estreita: a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade, e essa implica aquela. Afirmar que a natureza dos princípios implica a máxima da proporcionalidade significa que a proporcionalidade, com suas três máximas parciais⁸² da adequação, da

direitos individuais e dos interesses coletivos. É possível uma boa fundamentação tanto para a tese de que direitos fundamentais não são apenas meios para interesses coletivos quanto para a tese de que há interesses coletivos que independem de direitos individuais. A primeira tese pode apoiar-se na dignidade e na autonomia da pessoa, ou seja, ser fundamentada em um sentido kantiano; a segunda tese pode ser justificada por meio da indicação de que nem toda atividade estatal tem que se relacionar a um direito, podendo dizer respeito apenas a algo útil, aprazível e desejável. Isso é suficiente para justificar que se fale, de um lado, em direitos individuais e, de outro, em interesses coletivos.

80. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 82 e 90.

81. Idem, p. 23.

82. Sobre as três máximas parciais da proporcionalidade, cf., com diversas referências, Lothar Hirschberg, *Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit*, Göttingen: Schwartz, 1981, pp. 2, 50 e ss. e 75 e ss.; cf. também Rudolf Wendt, "Der Garantiegehalt der Grundrechte und das Übermaßverbot", *AöR* 104 (1979), pp. 415 e ss.;

necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito), decorre logicamente da natureza dos princípios, ou seja, que a proporcionalidade é deduzível dessa natureza. O Tribunal Constitucional Federal afirmou, em formulação um pouco obscura, que a máxima da proporcionalidade decorre, “no fundo, já da própria essência dos direitos fundamentais”.⁸³ A seguir se pretende demonstrar que isso é válido de forma estrita quando as normas de direitos fundamentais têm o caráter de princípios.⁸⁴

Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas. A *máxima da proporcionalidade em sentido estrito*, ou seja, exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito fundamental com caráter de princípio colide com um princípio antagônico, a possibilidade jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de colisão.⁸⁵ Visto que a aplicação de princípios válidos – caso sejam aplicáveis – é obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas de direito fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem com princípios

Eberhard Grabitz, “Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, *AöR* 98 (1973), pp. 571 e ss.; Manfred Gentz, “Zur Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen”, *NJW* 21 (1968), pp. 1.601 e ss.; Peter Lerche, *Übermaß und Verfassungsrecht*, Köln: Heymann, 1961, pp. 19 e ss.; Klaus Stern, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, Bd. 1, München: Beck, 1977, p. 674; Friedrich E. Schnapp, “Die Verhältnismäßigkeit des Grundrechtseingriffs”, *JuS* 23 (1983), p. 851.

83. *BVerfGE* 19, 342 (348-349); 65, 1 (44).

84. A máxima da proporcionalidade é com frequência denominada “princípio da proporcionalidade”. Nesse caso, no entanto, não se trata de um princípio no sentido aqui empregado. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito não são sopesadas contra algo. Não se pode dizer que elas às vezes tenham precedência, e às vezes não. O que se indaga é, na verdade, se as máximas parciais foram satisfeitas ou não, e sua não-satisfação tem como consequência uma ilegalidade. As três máximas parciais devem ser, portanto, consideradas como regras. Cf., nesse sentido, Görg Haverkate, *Rechtsfragen des Leistungsstaats*, Tübingen: Mohr, 1983, p. 11, que faz menção a um “enunciado jurídico passível de subsunção”.

85. Cf., neste Capítulo, I.3.2.1.

antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito é deduzível do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais.

A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das possibilidades *fáticas*.

Para demonstrar como a máxima da *necessidade* decorre do caráter principiológico dessas normas, será utilizada, aqui, a forma mais simples que um exame da necessidade pode ter. O fato de a máxima da necessidade impor dificuldades adicionais em casos mais complexos pode expor suas limitações, mas nada diz acerca de sua dedutibilidade do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais.⁸⁶ A constelação mais simples é caracterizada pela presença de apenas

86. A constelação mais simples é aquela formada por apenas dois sujeitos de direito, o Estado e um cidadão, com apenas dois princípios em jogo. Se mais de dois princípios estiverem envolvidos, pode surgir a seguinte situação: M_1 e M_2 são duas medidas igualmente adequadas em relação ao objetivo Z , cuja persecução é requerida por P_1 (ou Z é idêntico a P_1). M_2 afeta menos que M_1 a realização de P_2 , mas M_1 afeta menos que M_2 a realização de P_3 . Nesse caso, a máxima da necessidade não permite nenhuma decisão dentre as três possibilidades existentes: (1) M_1 é escolhida e, com isso, P_3 tem precedência em face de P_2 e P_1 é realizado; (2) M_2 é escolhida e, com isso, P_2 tem precedência em face de P_3 e P_1 é realizado; (3) nem M_1 nem M_2 são escolhidas e, com isso, P_2 e P_3 têm, juntos, precedência em face de P_1 . Para fundamentar a escolha entre uma dessas possibilidades — por exemplo, a primeira — é necessário demonstrar que é justificado preferir a não-afetação de P_3 por M_2 em conjunto com a realização de P_1 à afetação de P_2 por M_1 . Mas isso não seria nada mais que a fundamentação de uma relação condicionada de preferência entre P_2 , de um lado, e P_1 e P_3 , de outro; ou seja, um sopesamento.

Completamente diferentes são os problemas que podem surgir quando estão envolvidas mais pessoas. De novo, M_1 e M_2 são duas medidas igualmente adequadas em relação ao princípio P_1 , perseguido pelo Estado. M_1 afeta menos que M_2 o direito *prima facie* de a , garantido por P_2 . M_2 afeta menos que M_1 o direito *prima facie* de b , garantido por P_2 ou por um outro princípio P_3 . Também nesse caso a máxima da necessidade não permite nenhuma decisão.

Esses problemas suscitados por constelações complexas devem ser distinguidos dos problemas que a aplicação da máxima da necessidade suscita também nas constelações mais simples. Dentre esses problemas destaca-se a questão acerca da extensão da discricionariedade para fazer prognósticos que deve ser conferida ao legislador e à Administração no âmbito do exame da necessidade e, com isso, também na definição de medidas alternativas (sobre esses problemas, cf., com inúmeras referências adicionais, Lothar Hirschberg, *Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit*, pp. 50 e ss.).

dois princípios e dois sujeitos de direito (Estado/cidadão). Ela tem a seguinte estrutura: o Estado fundamenta a persecução do objetivo Z com base no princípio P_1 (ou Z é simplesmente idêntico a P_1). Há pelo menos duas medidas, M_1 e M_2 , para realizar ou fomentar Z , e ambas são igualmente adequadas. M_2 afeta menos intensamente que M_1 – ou simplesmente não afeta – a realização daquilo que uma norma de direito fundamental com estrutura de princípio – P_2 – exige. Sob essas condições, para P_1 é indiferente se se escolhe M_1 ou M_2 . Nesse sentido, P_1 não exige que se escolha M_1 em vez de M_2 , nem que se escolha M_2 em vez de M_1 . Para P_2 , no entanto, a escolha entre M_1 e M_2 não é indiferente. Na qualidade de princípio, P_2 exige uma otimização tanto em relação às possibilidades fáticas quanto em relação às possibilidades jurídicas. No que diz respeito às possibilidades fáticas, P_2 pode ser realizado em maior medida se se escolhe M_2 em vez de M_1 . Por isso, pelo ponto de vista da otimização em relação às possibilidades fáticas, e sob a condição de que tanto P_1 quanto P_2 sejam válidos, apenas M_2 é permitida e M_1 é proibida. Esse raciocínio vale para quaisquer princípios, objetivos e medidas. Portanto, o exame da necessidade, que o Tribunal Constitucional Federal define como a exigência de que “o objetivo não possa ser igualmente realizado por meio de outra medida, menos gravosa ao indivíduo”,⁸⁷ decorre do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais.

A inter-relação entre as possibilidades jurídicas e as possibilidades fáticas pode também ser esclarecida por meio da constelação mais simples acima utilizada. Se tanto M_1 quanto M_2 embarçam a realização de P_2 – o que é sempre o caso quando há motivo para um exame de necessidade – e M_2 o faz em menor escala que M_1 , então, M_1 e M_2 não esgotam o campo das possibilidades fáticas para a realização de P_2 , nem mesmo se se parte da suposição de que M_1 e M_2 sejam as únicas medidas adequadas para a realização do objetivo Z , exigido pelo princípio P_1 . Do ponto de vista das possibilidades fáticas, uma ainda maior realização de P_2 é alcançada se nem M_1 nem M_2 são levadas a cabo. O exame da necessidade permite apenas privilegiar M_2 em face de M_1 . Que uma das duas alternativas tenha que ser escolhida não é, no entanto, uma questão de possibilidades fáticas, isto é, não é uma questão para o exame da necessidade, mas uma questão de possibili-

87. BVerfGE 38, 281 (302).

dades jurídicas, ou seja, uma questão de sopesamento entre P_1 e P_2 (proporcionalidade em sentido estrito). É por isso que, caso até mesmo o meio menos gravoso afete a realização de P_2 , ao exame da necessidade deve se seguir sempre o exame da proporcionalidade em sentido estrito, isto é, a exigência de sopesamento.

Em face do que foi dito até aqui, a dedução do exame da *adequação* não constitui um problema. Se M_1 não é adequada para o fomento ou a realização do objetivo Z — que ou é requerido por P_1 ou é idêntico a ele —, então, M_1 não é exigida por P_1 . Para P_1 é, portanto, indiferente se se adota a medida M_1 , ou não. Se, sob essas condições, M_1 afeta negativamente a realização de P_2 , então, a adoção de M_1 é vedada por P_2 sob o aspecto da otimização em relação às possibilidades fáticas. Isso vale para quaisquer princípios, objetivos e medidas. Portanto, o exame da adequação também decorre do caráter principiológico das normas de direitos fundamentais.⁸⁸

A dedução acima exposta é uma fundamentação da máxima da proporcionalidade a partir das normas de direitos fundamentais, na medida em que tenham caráter de princípio. Ela pode ser chamada de “fundamentação a partir dos direitos fundamentais”. Outras fundamentações, como aquelas que se baseiam no princípio do Estado de Direito,⁸⁹ na prática jurisprudencial ou no conceito de justiça,⁹⁰ não são por ela excluídas.⁹¹ Na medida em que forem relevantes, são elas reforços bem-vindos à fundamentação a partir dos direitos fundamentais.

88. Eberhard Grabitz (“Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, p. 586) aproxima-se da dedução da máxima da proporcionalidade aqui apresentada: “Se se concebe o princípio que subjaz aos direitos de liberdade de forma positiva como a *maior chance possível* de desenvolvimento da personalidade garantida ao indivíduo em virtude da Constituição, então, toda regulação ‘excessiva’ frustra a maximização de chances e é, por isso, constitucionalmente ilegítima”.

89. Para essa linha de fundamentação, cf., por exemplo, BVerfGE 23, 127 (133); 38, 348 (368).

90. Cf., a respeito, Hans Schneider, “Zur Verhältnismäßigkeits-Kontrolle insbesondere bei Gesetzen”, in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, Bd. 2, Tübingen: Mohr, 1976, pp. 393-394; Rudolf Wendt, “Der Garantiegehalt der Grundrechte und das Übermaßverbot”, p. 416. Rupprecht v. Krauss (*Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit*, Hamburg: Appel, 1955, p. 41) fala do “direito natural do indivíduo, em um sentido atemporal, de ser protegido contra encargos que superem a medida do necessário”.

91. Para uma exposição das diversas tentativas de fundamentação da máxima da proporcionalidade, cf. Peter Wittig, “Zum Standort des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im System des Grundgesetzes”, DÖV 21 (1968), pp. 818 ss.

II – TRÊS MODELOS

1. O modelo puro de princípios

A análise levada a cabo até agora demonstrou que o Tribunal Constitucional Federal, pelo menos em alguns casos, concebe as normas de direitos fundamentais como princípios. Com a ajuda da lei de colisão pôde ser definida a conexão entre as normas de direitos fundamentais enquanto princípios e as regras de direitos fundamentais que se relacionam com a decisão: as condições sob as quais um princípio prevalece sobre outro constituem o suporte fático de uma regra, a qual expressa as consequências jurídicas do princípio prevalente.

Essas observações sugerem um modelo simples de normas de direitos fundamentais, segundo o qual elas são de duas espécies: princípios e regras. As garantias estabelecidas diretamente pelas disposições de direitos fundamentais devem ser compreendidas como princípios. Regras surgem da fixação de relações de precedência como resultados de sopesamentos. Como em modelo desse tipo as regras são inteiramente dependentes dos princípios, pode ele ser definido como um “modelo puro de princípios”.

O modelo proposto por Eike von Hippel é um modelo puro de princípios. Segundo ele, as normas de direitos fundamentais são “(meras) normas de princípios”, que “indicam que, na ordenação das relações sociais e na solução de conflitos, deve ser conferido um peso especial a determinados interesses de liberdade (liberdades de crença, de opinião, de profissão e de propriedade etc.), em suma, à idéia de autodeterminação individual. Mas isso não deve excluir a consideração de outros pontos de vista”.⁹² “Somente com base em uma análise cuidadosa de cada situação, e em um justo sopesamento de todos os interesses em jogo, é que se poderá decidir, em cada caso, a que resultados poderá conduzir essa indicação geral, que, claro, com frequência também possibilita uma decisão inequívoca.”⁹³ Seria uma “ilusão”⁹⁴ imaginar que o problema das restrições aos direitos fundamentais pode ser resolvido com o recurso às disposições sobre reservas e restrições da Constituição alemã. Melhor é partir da fórmula geral “toda

92. Eike v. Hippel, *Grenzen und Wesensgehalt der Grundrechte*, pp. 15-16.

93. Idem, p. 18.

94. Idem, p. 22.

norma de direito fundamental vale somente se e na medida em que a um interesse de liberdade protegido não forem contrapostos interesses (bens jurídicos) de maior valor".⁹⁵ A aplicação dessa fórmula pressupõe uma "valoração dos respectivos interesses".⁹⁶ O que importaria no "sopesamento de interesses" seriam sobretudo "as circunstâncias de cada caso particular".⁹⁷

As objeções contra um tal modelo puro de princípios são óbvias. A principal delas sustenta que esse modelo não levaria a sério a Constituição escrita. Essa objeção baseia-se sobretudo no fato de que um modelo puro de princípios passaria ao largo da regulação diferenciada que a Constituição alemã contém sobre as restrições a direitos fundamentais. O constituinte rejeitou expressamente uma cláusula geral de restrição e dotou cada garantia de direito fundamental com regras muito distintas acerca de possíveis restrições.⁹⁸ O Tribunal Constitucional Federal, que, de um lado, trata as normas de direitos fundamentais como princípios, ressalta, de outro lado, a importância dessas regras quando faz menção a uma "cuidadosa regulação das restrições, ajustada à natureza de cada um dos direitos fundamentais".⁹⁹ Na medida em que um modelo puro de princípios não leva a sério essa regulação, é possível criticá-lo por ser contrário ao texto constitucional.¹⁰⁰

95. Idem, pp. 25-26 e 30.

96. Idem, p. 32.

97. Idem, p. 34.

98. O art. 21, §§ 3º e 4º, do Projeto de Constituição elaborado na conferência de *Herrenchiemsee* (1948) continha ainda o dispositivo: "(3) Na medida em que de seu conteúdo não resultar algo distinto, os direitos fundamentais devem ser compreendidos no contexto da ordem jurídica geral; (4) Uma restrição a direitos fundamentais só é permitida por meio de lei e sob a condição de que seja absolutamente necessária em face da segurança pública, moral ou saúde". Sobre a eliminação dessas cláusulas gerais, Hermann v. Mangoldt declarou, na oitava sessão da Comissão de Princípios Fundamentais do Conselho Parlamentar, de 7.10.1948, que essa Comissão "considerou, desde o início, que esse enunciado sobre a validade dos direitos fundamentais no contexto da ordem jurídica geral seria perigoso e, por isso, esforçou-se em concretizá-lo na formulação de cada um dos direitos fundamentais específicos, de forma a que ele poderia ser descartado como cláusula geral. Também o art. 21, § 4º, 1, do mesmo Projeto (...) foi deslocado por meio de uma concretização no âmbito dos direitos fundamentais específicos e, com isso, obteve-se uma garantia mais forte dos direitos fundamentais" (*JöR N.F.* 1 (1951), p. 177).

99. *BVerfGE* 32, 54 (75).

100. Cf. Thomas Wülfing, *Grundrechtliche Gesetzesvorbehalte und Grundrechtsschranken*, Berlin: Duncker & Humblot, 1981, p. 21.

Ele substituiria vinculação por sopesamento e, com isso, ignoraria o caráter da Constituição alemã como uma “‘Constituição rígida’ com pretensão de clareza normativa e univocidade”.¹⁰¹

Não há dúvida de que essa objeção atinge o modelo puro de princípios em um ponto importante. Embora seja possível discutir o que a vinculação à Constituição significa e se, em certos casos, é possível se desviar do texto constitucional, não é passível de discussão o fato de que se deve, pelo menos em um primeiro momento, partir do texto da Constituição, e dele se desviar apenas por razões especiais. Mesmo que o constituinte tenha criado um “caos de restrições” ou não tenha estabelecido, de fato, um “sistema de restrições”,¹⁰² a regulação por ele criada não poderia ser desprovida de força vinculante.

A questão é saber que conseqüências devem ser tiradas da aceitação dessa objeção contra o modelo puro de princípios. Há duas possibilidades: ao modelo puro de princípios é possível contrapor um modelo puro de regras, mas também é possível tentar construir um modelo combinado.

2. O modelo puro de regras

Do ponto de vista da vinculação ao texto constitucional, da segurança jurídica e da previsibilidade, um modelo puro de regras é, sem dúvida, a alternativa mais atraente. Os defensores do modelo puro de regras são aqueles que consideram que as normas de direitos fundamentais, por mais que possam ser carentes de complementação, são sempre aplicáveis sem o recurso a ponderações e são, nesse sentido, normas *livres de sopesamentos*. Mesmo que no modelo puro de regras permaneça a complexa tarefa de interpretar as disposições de direitos fundamentais – por exemplo, por meio das “velhas e consolidadas regras da hermenêutica jurídica”¹⁰³ –, nele se renuncia ao sopesamento, sobre o qual pesam tantas inseguranças. Isso já é suficiente para provocar um questionamento inicial acerca da aceitabilidade de um modelo puro de regras. Esse questionamento deve ser suscitado em relação a três tipos de normação dos direitos fundamentais: os direitos funda-

101. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, pp. 17 e ss.

102. Sobre a tese do “caos de restrições”, cf. Karl-August Bettermann, *Grenzen der Grundrechte*, Berlin: de Gruyter, 1968, p. 3.

103. Ernst Forsthoff, *Zur Problematik der Verfassungslegung*, p. 34.

mentais sem reserva, os direitos fundamentais com reserva simples e os direitos fundamentais com reserva qualificada. Isso não abarca todos os tipos de normação de direitos fundamentais, mas abarca três tão importantes que, caso o modelo puro de regras não seja com eles compatível, pode ser considerado insustentável como um todo.

2.1 *Direitos fundamentais garantidos sem reserva*

Aquele que se baseia apenas no texto dos dispositivos sobre direitos fundamentais garantidos sem reservas necessariamente chega à conclusão de que não são possíveis restrições à liberdade de crença, à liberdade artística e ao direito de se recusar a prestar serviço militar. Contudo, há um certo consenso de que nem tudo aquilo que puder, de alguma forma, ser incluído no suporte fático de uma norma garantida sem reservas será, ao final, protegido pelo direito fundamental em questão. Alguém poderia imaginar que isso já seria suficiente para rejeitar o modelo puro de regras. Mas isso é correto apenas para uma variante extrema desse modelo, que se apegue estritamente ao texto das disposições de direitos fundamentais e a mais nada. Um modelo puro de regras não precisa ter essa forma estrita. Pode-se tentar justificar uma não-proteção por meio de uma cláusula de restrição *não-escrita* ou por meio de uma limitação *não-escrita* ao suporte fático. As especificidades da construção desse tipo de restrições – frequentemente chamadas de “*imanescentes*”¹⁰⁴ – não serão analisadas neste ponto.¹⁰⁵ O que interessa, aqui, é somente saber se é possível, no âmbito dos direitos fundamentais garantidos sem reservas, estabelecer critérios que possibilitem decisões acerca da extensão da proteção de um direito fundamental *sem o recurso a qualquer forma de sopesamento*.

Um exemplo paradigmático de um critério *que incorpora um sopesamento* é a fórmula cunhada pelo Tribunal Constitucional Federal em sua decisão sobre a recusa ao serviço militar obrigatório, de 1970,¹⁰⁶ e que, desde então, e com diferentes formulações, está na base

104. Para uma ampla exposição das teorias dos limites dos direitos fundamentais chamados de imanescentes – e também para uma análise crítica –, cf. Herwig van Nieuwland, *Darstellung und Kritik der Theorien der immanenten Grundrechts-schranken*: Göttingen: Dissertation, 1981.

105. Cf., para isso, Capítulo 6, I.2.

106. BVerfGE 28, 243.

de sua jurisprudência sobre a restrição a direitos fundamentais garantidos sem reservas.¹⁰⁷ Essa fórmula, que é uma prova clara de que o Tribunal Constitucional Federal concebe as normas de direitos fundamentais também como princípios, tem a seguinte redação: “Somente direitos fundamentais de terceiros e outros valores jurídicos de hierarquia constitucional estão em condições de, excepcionalmente e com a devida consideração à unidade da Constituição e à ordem de valores por ela protegida, restringir, em relações individualizadas, direitos fundamentais irrestringíveis. Os conflitos que surjam nesse âmbito só podem ser resolvidos se se examina qual dispositivo constitucional tem um maior peso para a questão concreta a ser decidida (...). A norma mais fraca só pode ser deixada em segundo plano na medida do necessário do ponto de vista lógico e sistemático; em qualquer caso, o seu conteúdo axiológico fundamental deve ser respeitado”.¹⁰⁸ A questão é saber se há alternativas – ao mesmo tempo aceitáveis e livres de sopesamento – a esse tipo de fórmula.

O paradigma de uma teoria que, à primeira vista, parece prescindir de sopesamentos e que, com isso, corresponda ao modelo de regras é a teoria das restrições imanentes de não-perturbação, de Dürig. A construção que Dürig faz dessas restrições – segundo Maunz,¹⁰⁹ essa construção é obtida da tríade de restrições do art. 2º, § 1º, da Constituição alemã, interpretado não apenas como direito de defesa, mas também como regra de interpretação para todos os direitos fundamentais¹¹⁰ – não será objeto de análise aqui.¹¹¹ Importante, aqui, é somente examinar se essas “três restrições originárias de não-perturbação”¹¹² – a saber, a “restrição imanente lógico-jurídica”, atribuída a “direitos de terceiros”; a “restrição socialmente imanente”, atribuída à “ordem constitucional”; e a “restrição eticamente imanente”, atribuída à “lei moral”¹¹³ – são realmente cláusulas livres de sopesamento.

107. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 30, 173 (193 e ss.); 32, 98 (108); 33, 23 (29); 41, 29 (50); 44, 37 (50); 49, 24 (56).

108. *BVerfGE* 28, 243 (261).

109. Cf. Theodor Maunz, *Deutsches Staatsrecht*, p. 123.

110. Cf. Günter Dürig, “Art. 2 Abs. 1”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz*, § 72.

111. Cf., para uma posição divergente, *BVerfGE* 30, 173 (192-193).

112. Cf. Günter Dürig, “Art. 2 Abs. 1”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz*, § 70.

113. *Idem*, §§ 73 e ss.

A *restrição imanente lógico-jurídica* refere-se a direitos de terceiros, inclusive a direitos privados. É facilmente perceptível que esse não é um critério livre de sopesamento. Caso o fosse, as normas de direitos fundamentais poderiam ser restringidas por qualquer direito garantido por uma norma de direito privado. É sintomático que Dürig, fazendo menção ao caso Luth – um caso clássico de sopesamento –, observe que o juiz civil, o qual “não [pode] ficar neutro diante das decisões axiológicas presentes nos direitos fundamentais”, poderia se deparar com “problemas reais de sopesamento de valores”. Sopesamentos são inevitáveis quando “todos [são] igualmente titulares de direitos fundamentais”.¹¹⁴

As coisas ficam mais complicadas no caso das *restrições socialmente imanes*, entre as quais Dürig inclui uma “restrição a direitos fundamentais decorrente de normas proibitivas de direito penal”.¹¹⁵ Para que ao legislador não seja possível criar restrições arbitrárias a direitos fundamentais por meio de normas proibitivas de direito penal, Dürig se vê obrigado a restringir o critério das normas proibitivas de direito penal. Esse critério deve abarcar somente aquelas normas proibitivas que tratem de um “ilícito penal jurídico-material”, as quais, por isso, dizem respeito a uma “perturbação óbvia”.¹¹⁶ Por meio de qualificações desse tipo, a “restrição decorrente de normas proibitivas de direito penal” perde sua determinação, que é decisiva para o modelo de regras. A definição do que seja um ilícito penal é algo polêmico, e diferentes pessoas têm diferentes concepções sobre aquilo que é óbvio no âmbito dos direitos fundamentais. Deixando-se de lado o caso do direito de resistência do art. 20, § 4^a, da Constituição alemã, é certo que há inúmeros suportes fáticos penais sobre os quais se pode ter certeza de que sua realização não seria permitida, em nenhuma circunstância, pelos direitos fundamentais. O caso do homicídio é um exemplo nesse sentido. Mas há outros suportes fáticos, sobretudo aqueles do direito penal subsidiário – que, segundo Dürig, “normalmente” estabelece “restrições óbvias de não-perturbação” –, sobre os quais é possível indagar se, por meio deles, direitos fundamentais são legitimamente restringidos.¹¹⁷ Responder a essa pergunta com uma

114. Idem, § 13, nota 1.

115. Idem, §§ 75-76.

116. Idem, § 76.

117. Idem, § 79.

referência ao que é óbvio significaria dar uma resposta racionalmente não-controlável, o que conduziria a um intuicionismo no âmbito dos direitos fundamentais.

Nos casos claros ainda seria possível se contentar com a constatação de que se trata de um ilícito penal material. Mas também nesses casos é possível questionar por que isso excluiria uma proteção de direito fundamental. A resposta seria que aquilo que determinadas normas de direito penal protegem – como a vida das pessoas – é, em todos os casos e a partir da perspectiva do direito constitucional, mais importante que aquilo que é protegido pela norma de direito fundamental que sofre restrição. O critério do ilícito penal material pode ser encarado, portanto, como uma *generalização* a partir de uma série de casos nos quais uma determinada norma de direito penal corretamente proíbe algo que normas de direito fundamental garantidas sem reservas *prima facie* permitem. As deficiências desse tipo de generalização ficam claras nos casos em que a correção da eliminação, por meio de uma norma penal proibitiva, de uma permissão de direito fundamental *prima facie* é questionável. Por isso, a questão definitiva só pode ser se, do ponto de vista do direito constitucional, a norma proibitiva, ou a razão a ela subjacente, é mais importante que a permissão fundada em um direito fundamental. É nesse sentido a observação de Dürig segundo o qual é perfeitamente possível “imaginar casos nos quais se coloca em dúvida se a criminalização de uma conduta é justificável do ponto de vista dos direitos fundamentais”.¹¹⁸ Nesses casos duvidosos, o critério do ilícito penal material ou perde seu caráter definitivo ou se transforma na expressão do resultado de um sopesamento. Ele perde seu caráter definitivo se se admite a possibilidade de que algo possa ser um ilícito penal material em um *grau* tão pequeno que uma restrição a direitos fundamentais não seria justificada. E ele se torna a *expressão do resultado de um sopesamento* se, partindo-se da admissibilidade da norma restritiva nos casos de ilícito penal material, a decisão sobre a ocorrência de um tal ilícito ficasse dependente de um juízo sobre a importância daquilo que é protegido pela norma restritiva, para se saber se essa importância justifica a restrição ao direito fundamental. Em ambos os casos chega-se a um sopesamento, e isso é inevitável, porque não há outra forma racional de decisão nos casos duvidosos a não ser

118. Idem, § 76.

estabelecer uma relação entre as razões para a restrição e o direito fundamental a ser restringido. Uma análise isolada das razões para a restrição pode fornecer inúmeras informações, mas não é capaz de dar uma resposta bem fundamentada à questão sobre se essas razões são importantes o suficiente para restringir algo também importante como um direito fundamental.

O que foi afirmado sobre o critério de Dürig, baseado na idéia de ilícito penal material, pode ser generalizado. Embora seja possível formular critérios que independam de sopesamentos e que possam abarcar corretamente uma série de casos, esses critérios são simplesmente a expressão de uma relação de precedência – que a eles subjaz – entre norma de direito fundamental e razão para restrição. Quando a relação de precedência é suficientemente sólida, o critério parece ser óbvio. Quando o critério é óbvio tornam-se desnecessárias maiores considerações sobre preferências para a fundamentação da decisão. No entanto, ao contrário do que ocorre com as condições concretas de precedência, as cláusulas abstratas de restrição freqüentemente dão ensejo a casos duvidosos, em razão de sua abertura e da variedade de relações jurídicas no âmbito dos direitos fundamentais. Nesses casos duvidosos o sopesamento volta a ser relevante. Nesse sentido, cláusulas que independam de sopesamento podem, em alguma medida, servir como regra geral, mas sua correção continua dependente dos sopesamentos que a elas subjazem. Quando surgem dúvidas, um sopesamento é inafastável. Portanto, critérios livres de sopesamentos são, na verdade, sempre o resultado de um sopesamento que os sustenta e, na melhor das hipóteses, podem resumi-lo de maneira geral. Um acesso direto – ou “intuitivo” – a eles é algo que não satisfaz as exigências de uma fundamentação racional e, por isso, fracassa nos casos duvidosos. A impressão intuitiva de sua correção ou de seu caráter evidente – que surge em vários casos – decorre da obviedade dos pesos atribuídos aos princípios em colisão.

No que diz respeito à *restrição eticamente imanente* da lei moral, é necessário defender apenas uma tese: a de que, enquanto restrição a direitos fundamentais, a lei moral – não importa o que se entenda por essa expressão – nunca poderá ser uma cláusula totalmente independente de sopesamentos. Isso porque, de um lado, os próprios direitos fundamentais a serem restringidos contêm um conteúdo moral e, de

outro, porque a lei moral, para que seja juridicamente relevante, tem que dizer respeito a relações entre indivíduos, bem como entre indivíduos e coletividade, o que significa que, para a sua aplicação em casos concretos, os sopesamentos são inafastáveis.

O que foi até aqui afirmado sobre as cláusulas restritivas de Dürig pode ser aplicado também às tentativas de solucionar o problema dos direitos fundamentais garantidos sem reserva por meio não do estabelecimento de restrições, mas de limitações ao suporte fático. Um exemplo de uma tentativa nesse sentido é a teoria de Müller acerca das modalidades de ação materialmente específicas. Como essa teoria – bem como, em geral, a relação entre limitação ao suporte fático e cláusula de restrição – será analisada com mais detalhes mais adiante,¹¹⁹ aqui será suficiente um breve exame de um caso utilizado por Müller como exemplo. Trata-se do caso do pintor que quer pintar no meio de um cruzamento viário. Segundo Müller, a proibição de realizar essa ação não intervém no direito fundamental à liberdade artística, porque ela não estreitaria qualquer “forma de ação específica protegida pelo direito fundamental”.¹²⁰ Decisivo seria que uma “modalidade específica, (...) equivalente e intercambiável, (...) permanecesse aberta”.¹²¹ Se se pressupõe que não há grande diferença – nem subjetivamente para o artista, nem objetivamente para a obra de arte – se a pintura for realizada no cruzamento ou em uma faixa de grama ao lado dele, então, o critério de Müller é claramente aplicável. Mesmo assim, é facilmente perceptível que ele não é aplicável sem um recurso ao sopesamento. Suponha-se que o cruzamento estivesse bloqueado ao tráfego¹²² e que, por isso, a pintura nesse cruzamento a ninguém incomodasse nem afetasse qualquer interesse público. Nessas circunstâncias, obrigar o pintor a se deslocar até a faixa de grama não é justificável nem mesmo sob as condições aceitas acima, porque, nesse caso, não haveria razão suficiente para que o pintor fosse expulso. A intercambiabilidade não é alterada. Mas, ao contrário, se houver diferença entre pintar em um cruzamento movimentado e em um cruzamento bloqueado, então, a

119. Cf. Capítulo 6, II.2.1.1.

120. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 64.

121. Idem, p. 101.

122. Cf., neste ponto, Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 160.

intercambiabilidade não pode ser o critério decisivo. O critério decisivo é o impedimento e ameaça ao trânsito. Isso e o direito fundamental devem ser contrapostos. No necessário sopesamento que daí surge, a intercambiabilidade pode desempenhar um papel importante, porque nos casos em que há uma alternativa viável a intervenção é menos intensa que nos casos em que não há. Mas o critério da intercambiabilidade não consegue substituir o sopesamento.

2.2 *Direitos fundamentais com reserva simples*

Se se tomam as normas de direitos fundamentais estabelecidas sem reserva de forma literal, pode-se dizer que elas garantem muita coisa. Já o problema das normas de direitos fundamentais com reserva simples – também se as tomamos literalmente – é que elas que garantem muito pouco. Assim é que, segundo o teor das disposições de direitos fundamentais, a liberdade pessoal, ou seja, a liberdade física de locomoção,¹²³ garantida pelo art. 2º, § 2º, da Constituição alemã, está, nos termos da regra de reserva do art. 2º, § 2º, 3, e até o limite de seu conteúdo essencial, completamente à disposição do legislador, que deve apenas respeitar as exigências formais do art. 19, § 2º. Se se leva em consideração apenas o texto constitucional, os direitos fundamentais garantidos com reserva simples ficam esvaziados na parte que está além de seu conteúdo essencial.¹²⁴ Que isso não possa ser assim é uma consequência da vinculação do próprio legislador aos direitos fundamentais, prevista pelo art. 1º, § 3º. Se o legislador puder restringir livremente um direito fundamental, não se pode dizer que está a ele vinculado.

Esse esvaziamento pode ser evitado ou por meio de uma garantia do conteúdo essencial que se estenda a toda intervenção em um direito fundamental, ou por meio da introdução, para além da garantia do conteúdo essencial, de um critério adicional não-escrito que limite a competência do legislador para impor restrições. A garantia do con-

123. BVerfGE 35, 185 (190).

124. Sobre o conceito de esvaziamento dos direitos fundamentais, cf. Richard Thoma, "Grundrechte und Polizeigewalt", in Heinrich Triepel, *Festgabe zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Preussischen Obergerverwaltungsgerichts*, Berlin: Heymann, 1925, p. 195.

teúdo essencial é estendida a todos os direitos fundamentais pelas teorias chamadas de relativas, segundo as quais uma restrição atinge o conteúdo essencial de um direito fundamental se ela for desproporcional,¹²⁵ isto é, se for inadequada, desnecessária ou desproporcional em sentido estrito, ou seja, se não estiver “em uma relação apropriada com o peso e a importância do direito fundamental”¹²⁶ Diante disso, no entanto, a limitação da competência do legislador para restringir direitos fundamentais torna-se, em sua essência, um problema de sopesamento.¹²⁷ Se se defende uma teoria absoluta do conteúdo essencial dos direitos fundamentais¹²⁸ e, nesse sentido, se não se estende tanto a garantia do conteúdo essencial, então, para o âmbito não compreendido por essa garantia, surge a questão do critério adicional. Mas esse critério, por sua vez, só pode ser a proporcionalidade. Como foi demonstrado no caso dos direitos fundamentais garantidos sem reserva, ainda que critérios livres de sopesamento possam, em certa medida, dar conta dos casos claros, os casos complexos demonstram que esses critérios nada mais são que a expressão de determinadas relações de preferência entre princípios. A jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional Federal – a qual, para todos os casos de restrição a direitos fundamentais, exige que sejam atendidas as máximas da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito¹²⁹ – está alinhada com as perspectivas teórico-normativas e de fundamentação da teoria dos princípios. A impossibilidade de uma solução – que prescindia de sopesamentos – para o problema da reserva simples confirma a correção dessa perspectiva e daquela prática. O modelo puro de regras fracassa, portanto, também no caso dos direitos fundamentais garantidos com reserva simples.

125. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, §§ 332 e ss.

126. Idem, § 318.

127. Cf., neste Capítulo, I.8. Sobre a relação entre sopesamento e garantia do conteúdo essencial na teoria relativa, cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, pp. 58 e ss.; Eike v. Hippel, *Grenzen und Wesensgehalt der Grundrechte*, p. 47.

128. Em que medida as teorias absolutas são, de fato, absolutas, ou seja, em que medida elas podem prescindir do sopesamento, é uma questão que será analisada mais adiante (cf. Capítulo 6, I.4).

129. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 19 330 (337); 21, 150 (155); 26, 215 (228); 27, 211 (219); 30, 292 (316).

2.3 *Direitos fundamentais com reserva qualificada*

Por fim, o modelo puro de regras revela-se também insuficiente nos casos em que parecia ter maiores perspectivas de êxito: nos casos de direitos fundamentais garantidos com reserva qualificada. Nem toda intervenção no direito fundamental à inviolabilidade do domicílio pode ser considerada como justificada simplesmente porque pode ser qualificada como um meio para atingir um dos objetivos elencados no art. 13, § 3º, da Constituição alemã e porque os demais requisitos formais tenham sido preenchidos. A intervenção tem que ser, além disso, necessária e proporcional em sentido estrito. Graves déficits no número de habitações disponíveis no mercado podem ser facilmente classificados como escassez de moradia no sentido dado pelo art. 13, § 3º. Se uma medida, que não intervenha de forma muito intensa na inviolabilidade do domicílio, é adequada e necessária para superar essa escassez, não se mostra necessário ponderar de forma detalhada entre o peso atribuído a essa superação e o peso atribuído à inviolabilidade do domicílio. Para esses casos claros o legislador constituinte já fixou, com o critério da escassez de moradia, um critério de preferência aplicável diretamente. A situação é diversa quando a escassez de moradia não é tão grave. Nesses casos é procedente questionar se a superação dessa escassez justifica uma intervenção muito intensa na inviolabilidade do domicílio. Tentar solucionar esse caso de forma racional somente por meio de subsunção – isenta de sopesamentos – ao conceito de escassez de moradia é algo fadado ao fracasso. Nessa subsunção não se trata de determinar se o déficit habitacional deve ser qualificado como escassez de moradia, mas se esse déficit fundamenta a restrição a um direito fundamental. É perfeitamente possível que alguém qualifique o déficit habitacional como uma escassez de moradia que deve ser prontamente superada por meio de medidas estatais, mas não como uma escassez de moradia que justifique a restrição a um direito fundamental. Em face dessa possibilidade, o conceito de escassez de moradia só pode ser usado como um critério definitivo para todos os casos caso essa escassez seja compreendida como uma “escassez no sentido do art. 13, § 3º, da Constituição alemã”, o que ocorre apenas e tão-somente se uma escassez de moradia justificar uma intervenção no direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Isso significa, contudo, que o conceito de escassez de mo-

radia se converte em expressão do resultado de um sopesamento. Com isso, a dependência do sopesamento fica clara também nos conceitos das cláusulas de reserva qualificada. O Tribunal Constitucional Federal expressa essa dependência quando, no âmbito da interpretação do art. 13, § 3º, afirma que “as restrições ao exercício de direitos fundamentais, para serem compatíveis com o Estado de Direito, devem ser fixadas respeitando-se a presunção elementar de liberdade e a máxima constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade”.¹³⁰

O julgamento do caso sobre inspeção de tinturarias,¹³¹ no qual o Tribunal Constitucional Federal teve que decidir se o direito de visita e inspeção comercial, com o intuito de controle econômico, violava o art. 13 da Constituição alemã, demonstra as dificuldades com as quais o modelo puro de regras pode se defrontar nos casos de direitos fundamentais com reserva qualificada e como elas podem ser evitadas por meio da aceitação do caráter principiológico dos direitos fundamentais.

O tribunal escolheu uma construção que corresponde à subsunção a normas com a estrutura de regras. Em um primeiro momento o tribunal inclui os cômodos de uma tinturaria no conceito de domicílio, o que, como o próprio tribunal reconhece, “não decorre de forma inequívoca” do texto do art. 13, § 1º, da Constituição alemã.¹³² A expansão da garantia do suporte fático para além do texto constitucional conduz a dificuldades no plano das restrições. O objetivo “controle econômico” não se encontra entre os motivos que o próprio art. 13, § 3º, define como justificadores de restrições à inviolabilidade do domicílio. Com intuito de ainda assim chegar a uma decisão pela admissibilidade da visita e da inspeção comercial, o tribunal conclui que, quando a visita e a inspeção são permitidas, elas perdem o caráter de “intervenções e restrições”.¹³³ É possível perceber que o próprio tribunal tem certas dúvidas acerca dessa construção, que contradiz os conceitos básicos da dogmática dos direitos fundamentais – uma intervenção é sempre uma intervenção, não interessa o quão bem fundamentada ela seja –, quando ele a caracteriza como uma “perspectiva

130. BVerfGE 32, 54 (72).

131. BVerfGE 32, 54.

132. BVerfGE 32, 54 (72).

133. BVerfGE 32, 54 (76): direitos de visita e inspeção que não podem ser qualificados como “intervenções e restrições”.

livre”, da qual o Conselho Parlamentar que elaborou a Constituição também poderia ter partido, e também quando o tribunal sugere a necessidade de “uma reformulação do texto constitucional”.¹³⁴

Do ponto de vista da teoria dos princípios é possível uma construção na qual a extensão da proteção do domicílio a espaços comerciais não crie os mencionados problemas no plano das restrições aos direitos fundamentais. Seu ponto de partida é o de que o disposto no art. 13, § 1º – “O domicílio é inviolável” – é, entre outras coisas, a expressão do princípio da proteção do âmbito físico do desenvolvimento individual da personalidade. O tribunal fala, nesse contexto, do “escopo da proteção” do direito fundamental.¹³⁵ Se se inclui, como faz o tribunal, a “atividade profissional livre de perturbações” como parte do desenvolvimento individual da personalidade, então, é “coerente estender uma correspondente proteção jurídica eficaz ao espaço em que esse trabalho é em geral desenvolvido”.¹³⁶ Nos termos da construção que aqui se prefere, isso deve ser compreendido de forma a que tinturarias não gozem da proteção do art. 13, § 1º, por estarem compreendidas no teor literal desse dispositivo constitucional, mas porque elas são abarcadas pelo princípio atribuído a esse art. 13, § 1º. Esse princípio faz com que, no âmbito do suporte fático, se vá além do conteúdo literal do texto constitucional. Para essa finalidade o âmbito das restrições não é apropriado. As razões que autorizam restrições foram concebidas tendo em vista intervenções e restrições que atinjam o domicílio em sentido estrito. Para esses casos o teor literal da Constituição e os pesos atribuídos aos princípios relevantes coincidem em grande medida. No caso de espaços comerciais e empresariais a situação é distinta. O tribunal salienta, com precisão, que, nesse caso, os “interesses de terceiros e da coletividade” têm um maior peso que o princípio da proteção da esfera privada em seu aspecto físico.¹³⁷ À luz desse sopesamento o tribunal elabora uma série de condições para a admissibilidade de visitas e inspeções comerciais, dentre as quais estão, por exemplo, a exigência de que elas ocorram durante o horário comercial.¹³⁸ Essas condições podem ser formuladas como uma regra,

134. BVerfGE 32, 54 (76).

135. BVerfGE 32, 54 (70).

136. BVerfGE 32, 54 (71).

137. BVerfGE 32, 54 (75-76).

138. BVerfGE 32, 54 (77).

que, segundo a lei de colisão,¹³⁹ expressa a relevância dos princípios em jogo. Essa regra não é um refinamento do texto do art. 13 da Constituição alemã, mas pode a ele ser atribuída, porque se baseia no princípio que esse dispositivo estatui. Dessa forma, em primeiro lugar, não se viola o texto do art. 13, § 1º, da Constituição, pois tinturarias não são qualificadas como “domicílio”, de forma a não contrariar o uso corrente do termo. Em segundo lugar, não se pode falar em uma violação do teor literal das cláusulas de restrição do art. 13, § 3º, da Constituição. O texto desse dispositivo refere-se somente àquilo que se inclui no teor do suporte fático da garantia constitucional. Se essa garantia é estendida para além do seu teor literal, por meio da aposição de uma regra que estenda a proteção do direito fundamental, baseada no caráter principiológico do art. 13, então, o alcance dessa regra não está vinculado ao teor das cláusulas de restrição do art. 13, § 3º, porque estas se referem somente àquilo que se inclui no teor literal do suporte fático. Dessa forma, apoiando-se na teoria dos princípios, é possível alcançar, sem problemas construtivos, a mesma proteção de direito fundamental que o tribunal concedeu em sua decisão.

3. O modelo de regras e princípios

O modelo puro de regras fracassa em todas as três formas de regulação dos direitos fundamentais consideradas acima. É possível supor que esse modelo é insuficiente também para as outras formas de regulação encontradas na Constituição alemã. O modelo puro de princípios foi rejeitado porque ele não leva a sério as regulações adotadas pela Constituição. Quando duas formas puras e antagônicas não são aceitáveis, deve-se considerar a possibilidade de uma forma mista ou combinada, ou seja, de um modelo combinado. Um tal modelo é o modelo de regras e princípios, que surge da ligação entre um nível de princípios e um nível de regras.

3.1 O nível dos princípios

Ao nível dos princípios pertencem todos os princípios que, sob a Constituição alemã, sejam relevantes para as decisões no âmbito dos

139. Cf., neste Capítulo, I.3.2.1.

direitos fundamentais. Um princípio é relevante para uma decisão de direito fundamental quando ele pode ser utilizado *corretamente* a favor ou contra uma decisão nesse âmbito. Se ele puder ser utilizado corretamente, então, ele é válido. É claro que é possível discutir quais princípios são válidos nesse sentido. Mas, por razões óbvias, essa discussão sobre a validade é menos freqüente que a discussão sobre os pesos abstratos e concretos dos princípios. As discussões acerca da máxima *in dubio pro libertate*, por exemplo, dizem respeito a pesos abstratos, já que essa máxima expressa a precedência básica dos princípios que se referem à liberdade jurídica individual.¹⁴⁰ Já o debate sobre a solução correta para casos individuais de direitos fundamentais diz respeito sobretudo a sopesamentos ou precedências concretas.

Entre os princípios relevantes para decisões de direitos fundamentais não se encontram somente princípios que se refiram a direitos individuais, isto é, que conferem direitos fundamentais *prima facie*, mas também aqueles que têm como objeto interesses coletivos e que podem ser utilizados sobretudo como razões contrárias a direitos fundamentais *prima facie*, embora possam ser também utilizados como razões favoráveis a eles. O conjunto básico dos princípios que conferem direitos fundamentais *prima facie* é facilmente determinável. Sempre que uma disposição de direito fundamental garante um direito subjetivo, a ela é atribuído ao menos um princípio dessa natureza. Mais difícil é responder à pergunta acerca dos princípios relacionados a interesses coletivos. Alguns deles podem ser atribuídos sem maiores exigências a cláusulas de restrição qualificadas; outros, por meio de uma interpretação institucional das disposições de direitos fundamentais, podem ser atribuídos até mesmo ao suporte fático.¹⁴¹ Outros ainda, como o princípio do Estado Social¹⁴² e o princípio democrático,¹⁴³ podem ser atribuídos, sem que isso cause algum problema, a

140. Cf. Capítulo 10, III.3.2.3.

141. Cf., por exemplo, BVerfGE 20, 162 (176): "imprensa livre"; BVerfGE 35, 79 (120): "operacionalidade da instituição 'liberdade científica' enquanto tal".

142. Sobre o princípio do Estado Social como razão para restrições, cf. BVerfGE 8, 274 (329): "princípio do Estado Social, que define e restringe também a liberdade contratual". Cf. também BVerfGE 21, 87 (91).

143. Um exemplo de caso no qual o princípio democrático é utilizado como um princípio ligado a um interesse coletivo com o objetivo de fortalecer um direito fundamental – ainda que às custas de outro direito fundamental antagônico – pode ser encontrado na decisão do caso Lüth: BVerfGE 7, 198 (208, 212).

disposições constitucionais que não sejam dispositivos de direitos fundamentais. Problemática é, por outro lado, a atribuição de princípios como o da defesa militar a normas constitucionais de competência,¹⁴⁴ pois o fato de algo ser da competência da União pouco diz sobre sua importância em relação aos direitos fundamentais. Aquilo que é de competência dos Estados – é possível, aqui, pensar na educação e na polícia – pode ter igual ou maior importância.

A atribuição de princípios às disposições da Constituição tem relevância sobretudo para a questão de sua hierarquia constitucional. Mas também os princípios que, por seu conteúdo, não podem ser atribuídos a nenhuma disposição constitucional são relevantes do ponto de vista dos direitos fundamentais. Inúmeras cláusulas de restrição incluem uma autorização ao legislador para que ele próprio decida por qual princípio quer se orientar, ou seja, uma autorização para restringir direitos fundamentais com base em princípios cuja realização, do ponto de vista da Constituição, não é obrigatória. Um exemplo é o princípio da “manutenção e promoção dos ofícios manuais”.¹⁴⁵ Princípios como esse, que se referem aos chamados interesses relativos da comunidade,¹⁴⁶ devem sua relevância constitucional em parte ao uso que o legislador faz de uma competência outorgada por uma reserva de direito fundamental. Nesse sentido é possível afirmar que esses princípios são atribuídos *formalmente* às disposições de direitos fundamentais. Isso não significa que, no caso desses princípios, apenas o aspecto formal da atribuição tem importância. A indagação acerca da demonstração de sua relevância *substancial* na argumentação no âmbito dos direitos fundamentais permanece indispensável.¹⁴⁷ Isso conduz à questão de se saber se um tal princípio, que, no curso da argumen-

144. BVerfGE 28, 243 (261).

145. BVerfGE 13, 97 (110).

146. Para uma distinção entre interesses absolutos da comunidade, “isto é, valores comunitários geralmente reconhecidos e independentes da política atual na comunidade (por exemplo: a saúde pública), e interesses relativos, que decorrem das “concepções e dos objetivos sobretudo econômicos, sociais e comunitários” do legislador, cf. BVerfGE 13, 97 (107 e ss.).

147. A forma com que o Tribunal Constitucional Federal resume sua análise acerca do peso substancial do princípio da manutenção e promoção dos ofícios manuais é sintomática: “Ainda que o legislador pudesse, com razão, avistar algum interesse comunitário especialmente importante na manutenção e no cultivo de um alto padrão de desempenho dos ofícios manuais (...)” (BVerfGE 13, 97 (113)).

tação constitucional, deverá se mostrar suficientemente relevante para superar um princípio de direito fundamental, não tem necessariamente que ter hierarquia constitucional. Para a solução desse problema é possível distinguir entre uma hierarquia constitucional de primeiro e outra de segundo grau. Um princípio tem hierarquia constitucional de primeiro grau se puder restringir um direito fundamental garantido sem reserva. Ele terá hierarquia constitucional de segundo grau se puder restringir um direito fundamental somente com o apoio de uma norma de competência estabelecida em uma disposição de reserva. Portanto, no caso de princípios de hierarquia constitucional de segundo grau o aspecto substancial e o aspecto formal (competência) devem se reforçar reciprocamente para que uma restrição seja justificada. A fundamentação de uma hierarquia constitucional de segundo grau com base no aspecto substancial é algo que, por definição, não pode ser demonstrado por meio de uma atribuição substancial direta a uma disposição constitucional, sendo necessária uma argumentação relacionada aos direitos fundamentais. Por isso, a hierarquia constitucional de segundo grau é algo muito mais inseguro que a já insegura hierarquia constitucional de primeiro grau. Quando, daqui em diante, se falar de "hierarquia constitucional", a menção será sempre à hierarquia de primeiro grau.

A distinção entre atribuição substancial e atribuição formal não está, em si mesma, vinculada à distinção entre dois tipos de princípios estruturalmente diferentes. Princípios substanciais de estrutura idêntica podem ser atribuídos material e/ou formalmente. Mas essa distinção aponta para uma relevante diferenciação entre dois tipos fundamentalmente distintos de princípios: os *princípios substanciais* ou *materiais* e os *princípios formais* ou *procedimentais*. Um princípio formal ou procedimental é, por exemplo, o princípio que sustenta que as decisões relevantes para a sociedade devem ser tomadas pelo legislador democrático. Esse princípio formal pode, junto com um princípio substancial que sirva a interesses apenas secundários da sociedade, ser sopesado contra um princípio constitucional garantidor de um direito individual. Aquele princípio formal é, além disso, o fundamento para as diversas formas de discricionariedade que o Tribunal Constitucional Federal garante ao legislador. Na medida em que a garantia de uma discricionariedade faz com que haja uma menor proteção aos direitos fundamentais do que haveria se não houvesse essa discriciona-

riedade, é possível qualificar aquele princípio como uma razão autônoma para a restrição.

Essa breve – e de forma alguma exaustiva – visão do nível dos princípios mostra que nele estão reunidas coisas extremamente diversas. Mas mais importante que a referência a essa diversidade é a constatação acerca de sua indeterminação. No espaçoso mundo dos princípios há lugar para muita coisa. Esse mundo pode ser chamado de um mundo do dever-ser ideal.¹⁴⁸ Colisões ou, para empregar algumas expressões frequentemente utilizadas, tensões, conflitos e antinomias¹⁴⁹ surgem a partir do momento em que se tem que passar do espaçoso mundo do dever-ser ideal para o estreito mundo do dever-ser definitivo ou real. Neste ponto passam a ser inevitáveis as decisões acerca do peso dos princípios colidentes, ou seja, da fixação de relações de preferência.

3.2 O nível das regras

As disposições de direitos fundamentais podem – e com isso se adentra o segundo nível – ser consideradas não somente como uma positivação e uma decisão a favor de princípios, mas também como a expressão de uma tentativa de estabelecer determinações em face das exigências de princípios contrapostos. Dessa forma, elas adquirem um caráter duplo. De um lado, princípios são positivados por meio delas; mas, de outro lado, elas contêm determinações em face das exigências de princípios contrapostos, na medida em que apresentam suportes fáticos e cláusulas de restrição diferenciados. Essas determinações têm, contudo, um caráter incompleto, já que por meio delas não são possíveis decisões independentes de sopesamento em todo e qualquer caso. Além disso, as diferentes regulações constitucionais têm um grau de determinação bastante diversificado. Basta comparar a regulação da liberdade artística com a da inviolabilidade do domicílio.

Quando, por meio de uma disposição de direito fundamental, é fixada alguma determinação em relação às exigências de princípios

148. Sobre esse conceito, que, em virtude dos mal-entendidos que pode suscitar, será utilizado aqui com muita cautela, cf. Robert Alexy, "Zum Begriff des Rechtsprinzips", pp. 79 e ss.

149. Cf., por exemplo, Norbert Achterberg, "Antinomien verfassungsgestaltender Grundentscheidungen", *Der Staat* 8 (1969), pp. 159 e ss.

colidentes, então, por meio dela não é estabelecido somente um *princípio*, mas também uma *regra*. Se a regra não é aplicável independentemente de sopesamentos, então, ela é, enquanto regra, incompleta. Na medida em que ela for incompleta nesse sentido, a decisão constitucional pressupõe um recurso ao nível dos princípios, com todas as incertezas que estão a ele vinculadas. Mas isso nada muda no fato de que as determinações devem ser levadas a sério na medida em que forem suficientes. A exigência de se levar a sério as determinações estabelecidas pelas disposições de direitos fundamentais, isto é, de levar a sério o texto constitucional, é uma parte do postulado da vinculação à Constituição. E é apenas uma parte desse postulado, porque, dentre outras razões, tanto as regras estabelecidas pelas disposições constitucionais quanto os princípios também por elas estabelecidos são normas constitucionais. Isso traz à tona a questão da hierarquia entre os dois níveis. A resposta a essa pergunta somente pode sustentar que, do ponto de vista da vinculação à Constituição, há uma primazia do nível das regras. Ainda que o nível dos princípios também seja o resultado de um ato de positivação, ou seja, de uma decisão, a decisão a favor de princípios passíveis de entrar em colisão deixa muitas questões em aberto, pois um grupo de princípios pode acomodar as mais variadas decisões sobre relações de preferência e é, por isso, compatível com regras bastante distintas. Assim, quando se fixam determinações no nível das regras, é possível afirmar que se decidiu mais que a decisão a favor de certos princípios. Mas a vinculação à Constituição significa uma submissão a todas as decisões do legislador constituinte. É por isso que as determinações estabelecidas no nível das regras têm primazia em relação a determinadas alternativas baseadas em princípios. É claro que, neste ponto, se deve indagar o quão rígida é essa relação de primazia. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal demonstra que ele não pressupõe uma primazia inafastável das determinações fixadas pelo texto constitucional. Um exemplo disso é a decisão em um caso envolvendo farmácias. De acordo com o texto do art. 12, § 1º, 1, da Constituição alemã, a liberdade de escolha profissional, ao contrário do que ocorre com a liberdade do exercício profissional, não está sujeita a nenhum tipo de reserva. O argumento do Tribunal segundo o qual a tentativa de "rejeitar qualquer possibilidade de intervenção do legislador na liberdade de escolha profissional (...) não corresponderia à realidade social e, por con-

seguinte, não conduziria a resultados jurídicos plausíveis”¹⁵⁰ pode ser entendido de forma a que um desvio do teor literal do texto constitucional seja justificado caso se esteja diante de condições sob as quais os princípios colidentes tenham um peso muito maior que o peso da liberdade de escolha profissional. Trata-se, portanto, de um caso que não corresponde à primazia do nível das regras – definidas por meio do teor literal da Constituição – diante do nível dos princípios. A relação de primazia entre os dois níveis não é, portanto, uma primazia estrita. Na verdade, aplica-se a regra de precedência, segundo a qual o nível das regras tem primazia em face do nível dos princípios, a não ser que as razões para outras determinações que não aquelas definidas no nível das regras sejam tão fortes que também o princípio da vinculação ao teor literal da Constituição possa ser afastado. A questão da força dessas razões é objeto da argumentação constitucional.¹⁵¹

3.3 O duplo caráter das normas de direitos fundamentais

O fato de que, por meio das disposições de direitos fundamentais, sejam estatuídas duas espécies de normas – as regras e os princípios – é o fundamento do caráter duplo das *disposições* de direitos fundamentais. Mas isso não significa ainda que também as *normas* de direitos fundamentais compartilhem desse mesmo caráter duplo. De início elas são *ou* regras (normalmente incompletas) *ou* princípios. Mas as normas de direitos fundamentais adquirem um caráter duplo se forem construídas de forma a que ambos os níveis sejam nelas reunidos. Uma tal vinculação de ambos os níveis surge quando na formulação da norma constitucional é incluída uma cláusula restritiva com a estrutura de princípios, que, por isso, está sujeita a sopesamentos. Com base na liberdade artística é possível mostrar como é essa cláusula restritiva sujeita a sopesamentos. A disposição de direito fundamental pode ter a seguinte forma:

(1) A arte é livre.

É possível supor, da mesma forma que faz o Tribunal Constitucional Federal, que “o art. 5º, § 3º, 1, da Constituição alemã (...) ga-

150. BVerfGE 7, 377 (401).

151. Sobre esse ponto, cf. Capítulo 10, III.3.

rante a liberdade de ação no âmbito artístico de forma ampla".¹⁵² Isso significa, dentre outras coisas,¹⁵³ que qualquer intervenção em uma atividade que se inclua no âmbito artístico é *prima facie* proibida. Nesse sentido, vale o seguinte:

- (2) São proibidas intervenções estatais em atividades que façam parte do campo artístico.

Se isso fosse compreendido como uma regra completa, estar-se-ia diante de um direito irrestringível, o que não pode ser correto, diante da existência de casos nos quais princípios colidentes têm preferência sobre o princípio da liberdade artística. É necessário, portanto, que seja incluída uma cláusula de restrição que dê vazão a essa realidade. Caso se construa uma tal cláusula com base na fórmula desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal no vol. 28 de seu repertório de jurisprudência,¹⁵⁴ ter-se-ia uma norma com a seguinte forma:

- (3) São proibidas intervenções estatais em atividades que façam parte do campo artístico se tais intervenções não forem necessárias para a satisfação de princípios colidentes que tenham hierarquia constitucional (que podem se referir a direitos fundamentais de terceiros ou a interesses coletivos), os quais, devido às circunstâncias do caso, têm primazia em face do princípio da liberdade artística.¹⁵⁵

A cláusula que se introduziu exige, em primeiro lugar, que os princípios colidentes – que podem ser designados por $P_2, \dots, P_n$ – tenham *hierarquia constitucional* e, em segundo lugar, que a intervenção destinada a fomentar a realização de $P_2, \dots, P_n$ seja *necessária*, o que inclui também a exigibilidade de sua *adequação*, e, em terceiro lugar, que $P_2, \dots, P_n$, sob as condições do caso (C), tenham *primazia* diante do princípio da liberdade artística – que pode ser designado por P_1 ; o que, no fim, significa que vale a fórmula $(P_2, \dots, P_n \text{ } P_1) \text{ } C$. Fica claro que a cláusula – com exceção da exigência de hierarquia consti-

152. BVerfGE 30, 173 (191).

153. O que mais isso pode significar é algo que não interessa aqui.

154. BVerfGE 28, 243 (261).

155. De acordo com a teoria absoluta do conteúdo essencial, seria ainda necessária uma cláusula de restrição das restrições relacionada a esse conteúdo. As teorias sobre o conteúdo essencial serão discutidas mais adiante. Por isso, será deixado em aberto, por enquanto, se deve ser inserida uma cláusula relacionada à garantia do conteúdo essencial.

tucional para os princípios colidentes, decorrente da garantia sem reservas da liberdade artística – expressa nada mais que as três partes da máxima da proporcionalidade. Se se utiliza *S* para o preenchimento completo da cláusula e *T* para uma intervenção estatal em uma atividade que faça parte do campo artístico, e *R* para a consequência jurídica, que consiste na proibição constitucional da medida em questão, obtém-se, então, a seguinte forma extremamente geral da norma de direito fundamental provida de uma cláusula restritiva:

(4) $T \text{ e } \text{ não-}S \rightarrow R$.

Sob dois aspectos essa norma tem inteiramente o caráter de uma regra. Ela é aplicável sem que seja necessário sopesá-la contra outra norma e a ela é possível se subsumir.¹⁵⁶ Aquilo que é abarcado pelo suporte fático mas não satisfaz a cláusula restritiva é proibido. Mas, por outro lado, ela não tem o caráter de uma regra, na medida em que faz, na cláusula de restrição, explícita referência a princípios e a seu sopesamento. Normas com essa forma podem ser denominadas como normas constitucionais de caráter duplo.

Essas normas de caráter duplo surgem sempre que aquilo que é estabelecido diretamente por uma disposição de direito fundamental é transformado, com o auxílio de cláusulas que se referem a um sopesamento, em normas subsumíveis. Assim, aquilo que é estabelecido pelo art. 2º, § 2º, 2 e 3, da Constituição alemã deve ser transformado, por exemplo, na seguinte norma:

(5) São proibidas intervenções estatais na liberdade pessoal se elas não estiverem baseadas em uma lei ou não forem necessárias para a satisfação de princípios colidentes que, devido às circunstâncias do caso, tenham primazia em face do princípio da liberdade pessoal.

A não-necessidade de que os princípios colidentes tenham que passar pelo filtro da hierarquia constitucional decorre da decisão do legislador constituinte por uma reserva não-qualificada, expressa no art. 2º, § 2º, 3, da Constituição.

Mesmo normas dotadas de reserva qualificada necessitam de uma transformação complementadora, o que faz com que nelas seja incor-

156. Sobre a forma lógica da subsunção a uma norma desse tipo, cf. Hans-Joachim Koch/Helmut Rübmann, *Juristische Begründungslehre*, pp. 101 e ss.

porada a máxima da proporcionalidade e, com isso, uma parte da teoria dos princípios. Sua peculiaridade consiste na limitação do espectro dos princípios colidentes por meio de determinações no nível das regras. O art. 13, § 3º, oferece um exemplo para esse tipo de limitação.

Nos detalhes, muita coisa ainda pode ser refinada e precisada.¹⁵⁷ Neste ponto, no entanto, é possível abrir mão disso. Compreender as normas de direitos fundamentais apenas como regras ou apenas como princípios não é suficiente. Um modelo adequado é obtido somente quando às disposições de direitos fundamentais são atribuídos tanto regras quanto princípios. Ambos são reunidos em uma norma constitucional de caráter duplo.

Resta, contudo, uma objeção fundamental. É possível sustentar que a teoria dos princípios é necessariamente incorreta porque implica sopesamentos e as insuportáveis inseguranças a eles ligadas. Além disso, a teoria dos princípios estaria associada à teoria dos valores. Tudo que é possível censurar na teoria dos valores seria censurável também em relação à teoria dos princípios. A essa objeção é dedicado o próximo tópico.

III – TEORIA DOS PRINCÍPIOS E TEORIA DOS VALORES

1. Princípio e valor

Duas considerações fazem com que seja facilmente perceptível que princípios e valores estão intimamente relacionados: de um lado, é possível falar tanto de uma colisão e de um sopesamento entre princípios quanto de uma colisão e de um sopesamento entre valores; de outro lado, a realização gradual dos princípios corresponde à realização gradual dos valores. Diante disso, é possível transformar os enunciados sobre valores do Tribunal Constitucional Federal em enunciados sobre princípios, e enunciados sobre princípios ou máximas em enunciados sobre valores, sem que, com isso, haja perda de conteúdo. Ao invés de constatar que “a liberdade de imprensa (...) [encerra] em si a possibilidade de entrar em conflito com outros valores protegidos pela Constituição”,¹⁵⁸ o tribunal poderia ter afirmado, na decisão Spie-

157. Cf., por exemplo, a tentativa de refinamento de Rüdiger Rubel, *Planungs-ermessen*, Frankfurt am Main: Metzner, 1982, pp. 91 e ss.

158. BVerfGE 20, 161 (176).

gel, que a liberdade de imprensa encerra em si a possibilidade de colidir com outros princípios estabelecidos pela Constituição;¹⁵⁹ e na decisão sobre a duração da prisão preventiva, de 1973, o tribunal poderia ter falado em uma colisão entre valores, no lugar de um conflito entre princípios.¹⁶⁰

1.1 Conceitos deontológicos, axiológicos e antropológicos

A despeito dessas visíveis semelhanças, há um diferença importantíssima entre valor e princípio, que pode ser melhor compreendida com base na divisão dos conceitos práticos proposta por von Wright. Segundo ele, os conceitos práticos dividem-se em três grupos: os deontológicos, os axiológicos e os antropológicos.¹⁶¹ Exemplos de conceitos *deontológicos* são os conceitos de dever, proibição, permissão e de direito a algo. Comum a esses conceitos, como será demonstrado mais adiante, é o fato de que podem ser reduzidos a um conceito deontico básico, que é o conceito de dever ou de dever-ser. Já os conceitos *axiológicos* são caracterizados pelo fato de que seu conceito básico não é o de dever ou de dever-ser, mas o conceito de bom. A diversidade de conceitos axiológicos decorre da diversidade de critérios por meio dos quais algo pode ser qualificado como bom. Assim, conceitos axiológicos são utilizados quando algo é classificado como bonito, corajoso, seguro, econômico, democrático, social, liberal ou compatível com o Estado de Direito. Exemplos de conceitos *antropológicos*, por fim, são os conceitos de vontade, interesse, neces-

159. Que essa não é uma alternativa remota é algo que pode ser percebido pelo fato de o tribunal, ao longo de sua argumentação, falar, de um lado, em "máxima da liberdade de imprensa" e, de outro, na "não menos importante máxima constitucional do dever incondicional de todos os órgãos estatais, instituições e cidadãos defenderem a existência e a segurança do Estado e de sua ordem de liberdade" (BVerfGE 20, 162 (218-219)).

160. BVerfGE 36, 264 (270).

161. Cf. Georg Henrik v. Wright, *The Logic of Preference*, p. 7; do mesmo autor, *The Varieties of Goodness*, London: Routledge, 1963, pp. 6-7. A terminologia de von Wright é vacilante. Às vezes ele utiliza duas designações para o mesmo conceito. Assim, por exemplo, no lugar de "antropológico", ele às vezes fala em "psicológico"; no lugar de "deontológico", fala ele também em "normativo"; por fim, além de "axiológico", ele utiliza também a expressão "conceitos valorativos". Sobre a distinção triplíce, cf. também Joseph Raz, *Reasons and Norms*, pp. 11 e ss.

cidade, decisão e ação.¹⁶² Esses três grupos de conceitos abarcam o campo de disputas fundamentais tanto na Filosofia Prática quanto na Ciência do Direito. Aqui é possível mencionar, por exemplo, as controvérsias acerca do caráter deontológico ou teleológico da Ética, as quais são, em grande parte, uma disputa sobre o primado do conceito de dever-ser ou do conceito de bom;¹⁶³ é possível também mencionar o desenvolvimento da jurisprudência dos conceitos, passando pela jurisprudência dos interesses, até a jurisprudência dos valores, o qual pode ser apresentado como uma sequência do primado dos conceitos deontológicos, antropológicos e axiológicos.

Se se aceita a tripartição aqui esboçada, fica fácil perceber a diferença decisiva entre o conceito de princípio e o conceito de valor. Princípios são mandamentos de um determinado tipo, a saber, mandamentos de otimização. Como mandamentos, pertencem eles ao âmbito deontológico. Valores, por sua vez, fazem parte do nível axiológico.

162. A caracterização dos objetos do sopesamento com o auxílio de termos antropológicos parece ser mais freqüente que sua caracterização por meio de termos deontológicos e axiológicos. Assim, nas duas decisões mencionadas no texto encontram-se, entre outros, os seguintes termos antropológicos: "importância", "necessidades", "interesses" e "finalidades" (*BVerfGE* 36, 264 (269-270); 20, 162 (176 e ss.)). Um outro termo é "preocupação" (*BVerfGE* 35, 79 (122)). É claro que, como caracterização de objetos de um sopesamento jurídico, esses termos não são utilizados para designar conceitos puramente antropológicos. Um conceito puramente antropológico seria expresso pelo termo "interesse", por exemplo, caso ele designasse algo que alguém de fato desejasse. Que alguém de fato deseje algo não é uma condição nem necessária nem suficiente para que isso seja considerado em um processo de sopesamento, ainda que possa ser uma razão – dentre outras – para tanto. Para que seja considerado em um sopesamento, é preciso que se trate de um interesse que, do ponto de vista do direito, deva ser levado em consideração ou que mereça ser levado em consideração. Portanto, termos antropológicos que sejam usados para designar objetos de sopesamentos jurídicos referem-se a conceitos que têm uma dimensão deontológica ou uma dimensão axiológica. Nesse contexto, eles são sempre substituíveis por algum termo deontológico ou axiológico. O mesmo vale para a designação de algo como "bem jurídico", que se refere a um conceito composto por elementos deontológicos e/ou axiológicos e/ou antropológicos. Sobre esse conceito, cf., por todos, Knut Amelung, *Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft*, Frankfurt am Main: Athenäum, 1972, e Michael Marx, *Zur Definition des Begriffs "Rechtsgut"*, Köln: Heymann, 1972.

163. Cf., a esse respeito, Georg Henrik v. Wright, *The Varieties of Goodness*, pp. 156-157; Max Scheler, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, 5ª ed., Bern: Francke, 1966, pp. 173 e ss.; Nicolai Hartmann, *Ethik*, Berlin: de Gruyter, 1926, pp. 39-40; Edmund Husserl, *Logische Untersuchungen*, 2ª ed., Halle: Niemeyer, 1913, pp. 40 e ss.

Mas isso é apenas uma primeira e rudimentar caracterização do conceito de valor. Para determinar com maior precisão sua relação com o conceito de princípio, é necessária uma análise mais detalhada:

1.2 Sobre o conceito de valor

O conceito de valor é utilizado de formas muito distintas tanto na linguagem coloquial, quanto no jargão filosófico, quanto na linguagem técnica das diferentes ciências.¹⁶⁴ Aqui não é necessário descrever esses diferentes usos, nem abordar suas inúmeras tentativas de classificação.¹⁶⁵ A comparação entre valor e princípio pode se basear em algumas características estruturais gerais e elementares dos valores. Elas ficam visíveis quando se observa uma diferença fundamental na utilização da expressão "valor": a diferença entre a constatação de que algo *tem* um valor e que algo *é* um valor.¹⁶⁶

1.2.1 Juízos classificatórios, comparativos e métricos

Quem diz que algo tem um valor expressa um *juízo de valor*¹⁶⁷ e realiza uma *valoração*.¹⁶⁸ Os juízos de valor e os conceitos valorativos

164. Cf., nesse sentido, William K. Frankena, "Value and valuation", in Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, v. 7, New York: Macmillan, 1967, pp. 229 e ss.

165. Além dos já mencionados trabalhos de Scheler, Hartmann e von Wright, cf., a respeito, Christian v. Ehrenfels, *System der Werttheorie*, 2ª v., Leipzig: Reissland, 1897/1898; Ralph B. Perry, *General Theory of Value*, New York: Longmanns, 1926; Victor Kraft, *Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre*, 2ª ed., Wien: Springer, 1951; Rüdiger Lautmann, *Wert und Norm: Begriffsanalysen für die Soziologie*, 2ª ed., Opladen: Westdeutscher Verlag, 1971; Milton Rokeach, *The Nature of Human Values*, New York: Free Press, 1973; Ervin Laszlo/James B. Wilbur (eds.), *Value Theory in Philosophy and Social Science*, New York: Gordon and Breach, 1973.

166. Sobre essa diferenciação, cf. Victor Kraft, *Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre*, 2ª ed., Wien: Springer, 1951, pp. 10-11; Ralph B. Perry, *Realms of Value*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1954, pp. 1-2.

167. O contraponto para o juízo de valor situado no nível axiológico (protótipo: "x é bom") é o juízo de dever atribuível ao nível deontológico (protótipo: "x deve ser"). Sobre os conceitos de juízos de valor e de dever, cf. Paul Edwards, *The Logic of Moral Discourse*, New York: Free Press, 1955, p. 141; William K. Frankena, *Analytische Ethik*, München: DTV, 1972, pp. 27-28; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 84 e ss.

168. O termo "valoração" é ambíguo. Suponha-se que *a* expresse o juízo de valor "x é bom". Há, então, três coisas que podem ser chamadas de valoração: (1)

neles utilizados podem ser classificados em três grupos: classificatório, comparativo e métrico.¹⁶⁹ Um juízo de valor *classificatório* é externado quando, por exemplo, uma determinada constituição é classificada como boa ou ruim.¹⁷⁰ O aporte dos conceitos valorativos classificatórios limita-se à classificação dos objetos a serem valorados entre aqueles que têm um valor positivo, aqueles que têm um valor negativo e, caso os critérios para a valoração assim permitam, aqueles que têm um valor neutro.¹⁷¹ Já os conceitos valorativos *comparativos* permitem uma valoração mais diferenciada. Eles são utilizados quando se afirma que, dentre dois objetos, um tem maior valor que o outro ou que ambos têm o mesmo valor. Enunciados valorativos comparativos, como “a constituição X é melhor que a constituição Y” ou “ambas as constituições são igualmente boas”, expressam juízos de preferência ou de igualdade valorativa. A valoração mais exata é possível por meio de um conceito valorativo *métrico*, que é utilizado quando aos objetos a serem valorados é atribuído um número que indica seu valor. Um exemplo paradigmático de valoração métrica ocorre quando o valor de um terreno é expresso por meio de uma soma em dinheiro.¹⁷² Com o auxílio de conceitos valorativos classificatórios é possível afir-

aquilo que o enunciado expresso por *a* significa, ou seja, que “*x* é bom” (conceito semântico de valoração); (2) o ato lingüístico que *a* realiza ao expressar o enunciado mencionado (conceito pragmático de valoração); (3) o ato físico que, em geral, antecede ou acompanha a expressão de um juízo de valor, e cujo conteúdo é expresso pelo juízo de valor (conceito psicológico de valoração). Aqui, apenas o conceito semântico de valoração será utilizado.

169. Cf. sobre isso, Franz v. Kutschera, *Einführung in die Logik der Normen, Werte und Entscheidungen*, pp. 85 e ss.

170. Sobre o procedimento classificatório baseado em critérios valorativos, cf. James O. Urmson, “Einstufen”, in Günther Grewendorf/Georg Meggle (Orgs.), *Seminar: Sprache und Ethik*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974, pp. 140 e ss.

171. O conceito de neutralidade deve ser distinguido do conceito de indiferença. De acordo com o critério “sabor”, os alimentos podem ser divididos naqueles que têm um valor positivo, um valor negativo ou um valor neutro. Alimentos têm um valor neutro quando não têm um sabor nem bom, nem ruim. Mas nem tudo aquilo que não é nem bom nem ruim receberá, com base no critério “sabor”, uma avaliação neutra. A uma poesia, por exemplo, à qual esse critério não é aplicável, não será atribuído nenhum valor. Em relação ao critério “sabor”, ela é indiferente. Cf., a respeito, mas com outra terminologia, Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, p. 151.

172. Sobre conceitos valorativos métricos, cf. Franz von Kutschera, *Einführung in die Logik der Normen, Werte und Entscheidungen*, pp. 87 e ss.

mar que algo tem um valor positivo, negativo ou neutro; com o auxílio de conceitos valorativos comparativos, que um objeto a ser valorado tem um valor maior ou o mesmo valor que outro; e com o auxílio de conceitos valorativos métricos, que algo tem um valor de determinada magnitude. Em todos os casos trata-se de juízos sobre algo que *tem* um valor. Mas o que significa que algo *é* um valor? A diferenciação entre o objeto e o critério da valoração conduzirá a uma resposta a essa questão.

1.2.2 Valores como critérios de valoração

Muitas coisas podem ser *objeto* de valoração. Entre elas, podem ser valorados objetos naturais, artefatos, idéias, acontecimentos, ações e situações. Também os *critérios* de valoração são de natureza variada. Um carro pode ser valorado, por exemplo, com base nos critérios de rapidez, segurança, conforto, preço, economia e beleza. Os critérios de valoração podem colidir – basta pensar, por exemplo, nos critérios rapidez e economia. Nesses casos, para que se possa realizar uma *valoração global* de determinado carro, é necessário determinar a relação entre esses critérios. Na já mencionada decisão Spiegel os objetos da valoração são, dentre outras coisas, situações de regulação jurídica, que são avaliadas com base sobretudo em dois critérios, o da liberdade de imprensa e o da segurança nacional. Uma das situações de regulação jurídica valoradas nesse caso refere-se à existência de “um direito, garantido à imprensa, de manter sigilo acerca de seus informantes, mesmo nos casos (...) em que (...) o objeto da investigação seja um crime doloso de traição à pátria e os redatores sejam suspeitos de serem os autores do crime, e os informantes, seus cúmplices”.¹⁷³ Se se parte somente do critério da liberdade de imprensa, então, essa situação pode ser considerada como “boa”; se se parte somente da segurança nacional, ela pode ser classificada como “ruim”. Ambos os critérios colidem. Para fazer uma valoração global, é necessário definir a relação entre eles.

Não se pode dizer nem do carro, nem da mencionada situação de regulação jurídica, que eles são um valor em si. Como objetos da va-

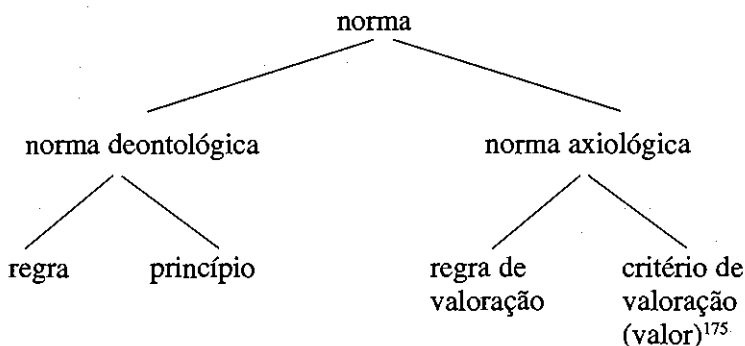
173. BVerfGE 20, 162 (219).

loração, eles têm um valor e, com certeza, um valor distinto, dependendo de qual dos critérios contrapostos a valoração toma como ponto de partida. Não são os objetos, mas os *critérios da valoração* que devem ser designados como “valor”. Isso está em concordância não apenas com considerações sistemáticas, mas com o próprio uso coloquial da linguagem. Ainda que soasse um pouco pomposo, não seria incorreto dizer que um dos carros está mais à altura do valor segurança que o outro; mas ninguém diria que um dos carros é um maior valor que o outro. No contexto jurídico, sempre um pouco mais abstrato, é normal dizer que uma regulação respeita em maior medida o valor da liberdade de imprensa que outra.

Uma valoração pode se basear em um ou mais critérios de valoração. Quem classifica um carro como “bom”, e fundamenta essa classificação exclusivamente no fato de que ele é seguro, faz uma valoração baseada em apenas um critério. O critério da segurança pode ser preenchido em diferentes medidas por diferentes carros. Isso abre diversas possibilidades de ordenação classificatória com base em apenas um critério. É possível, por exemplo, classificar como “bons” todos os carros que, em comparação com outros carros, demonstrem um grau relativamente elevado de segurança; ou todos os carros a partir de um determinado grau de segurança, que não se baliza no alcançado até então; ou, e essa é a forma rigorosa de avaliação, somente aqueles carros que ofereçam o máximo de segurança imaginável. Valorações baseadas em apenas um critério podem ter um certo traço de fanatismo.

Em geral, valorações baseiam-se em diversos critérios, entre os quais é necessário sopesar, porque esses critérios competem entre si. A classificação como “bom” é, então, expressão de uma valoração global. A aplicação de critérios de valoração entre os quais é necessário sopesar corresponde à aplicação de *princípios*. Daqui em diante serão classificados como *critérios de valoração* somente aqueles critérios que sejam passíveis de sopesamento. Seu contraponto são os critérios de valoração que, como as *regras*, são aplicáveis independentemente de sopesamento. Esses critérios serão chamados de *regras de valoração*. Nas ordenações classificatórias baseadas em apenas um critério, como as mencionadas anteriormente, pressupõe-se um tipo de regra de valoração que tem a seguinte forma: sempre que um carro apresenta um grau de segurança *i*, ele é bom. Com base nessa regra de valoração, o preenchimento de um critério de valoração em um grau

determinado é um motivo suficiente para a classificação definitiva como “bom”. Em geral, as regras de valoração englobam vários pressupostos. Elas têm, por isso, a seguinte forma: se x apresenta as características $F_1, \dots, F_n$, então, x é bom. Regras de valoração desse tipo são como as regras definidas no sentido apresentado anteriormente.¹⁷⁴ A diferença estrutural entre regras e princípios também se verifica, portanto, no nível axiológico. Aos princípios correspondem os critérios de valoração; às regras, as regras de valoração. Se, como mais uma precisão terminológica, é acrescentado que somente os critérios de valoração podem ser designados como “valores”, então, é possível fazer a seguinte divisão, que utiliza o termo “norma” como supraconceito:



É facilmente demonstrável que também os juízos métricos de valor podem ter critérios de valoração como base. O grau de segurança de um carro pode ser expresso em uma escala de 0 a 1. Quem afirma que a um carro corresponde um valor de segurança de 0,7 pode, dessa

174. A partir delas, em conjunto com premissas adicionais, pode ser deduzido o juízo concreto de valor. Cf. Richard M. Hare, *The Language of Morals*, pp. 145-146; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 93-94.

175. Os objetos dessa divisão são em parte designados por meio de outros termos; os termos aqui utilizados são, em parte, também usados com outro significado; e, em parte, são outros os objetos utilizados para esse tipo de divisão. Diante das diversidades conceitual e classificatória, esse esquema não pode pretender refletir o uso majoritário da linguagem. A terminologia escolhida só pode ser encarada como uma tentativa de dar nomes – que, na medida do possível, correspondam ao uso corrente da linguagem – a coisas que, por razões sistemáticas, têm que ser diferenciadas.

forma, realizar, com meios métricos, uma valoração a partir do critério ou do valor "segurança". No direito constitucional metrificações são de pouca ou nenhuma valia, como ainda será analisado mais adiante. Para resolver um sopesamento entre a liberdade de imprensa e a segurança nacional por meio de uma metrificação seria necessário que às alternativas de decisão fossem atribuídos valores numéricos comparáveis e, com isso, calculáveis. De pronto, deve-se afirmar que uma tal metrificação não é possível no direito constitucional.

Das três formas de juízos de valor, são os juízos comparativos que têm a maior importância para o direito constitucional. A relação entre eles e os critérios de valoração conduz à definição da relação entre princípio e valor. Com base no critério de valoração "liberdade de imprensa", uma situação Z_1 , na qual a liberdade de imprensa é realizada em maior grau que em Z_2 , deve ser valorada como melhor que Z_2 .¹⁷⁶ A medida mais elevada não precisa ser exprimível em números. É possível que Z_1 possa realizar a liberdade de imprensa em maior medida que Z_2 porque Z_1 é caracterizada por *circunstâncias* que não estão presentes em Z_2 . Assim é que a situação Z_1 , na qual o segredo de redação é protegido de forma ilimitada, deve ser valorada, a partir do critério de valoração "liberdade de imprensa", como melhor que uma situação semelhante Z_2 , na qual essa proteção não ocorre. A partir do critério de valoração "segurança nacional" pode ser que o contrário ocorra. Como não se pode renunciar a nenhum dos dois critérios de valoração, e como não é possível um cálculo baseado em uma metrificação, resta apenas o sopesamento. Isso significa, contudo, que uma

176. Um enunciado como "quanto mais liberdade de imprensa houver, melhor" expressa o critério de valoração ou o valor da liberdade de imprensa caso seja compreendido da seguinte forma: "Se em uma situação Z_1 houver mais liberdade de imprensa que em uma situação Z_2 , então, no aspecto 'liberdade de imprensa', Z_1 é melhor que Z_2 ". Em geral, sobre esses enunciados, cf. Gerhard Otte, "Komparative Sätze im Recht", *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie* 2 (1972), pp. 301 e ss. Seria possível pensar em compreender esses enunciados como formulações de regras para valorações. Contudo, o conceito de regra será aqui utilizado apenas para designar normas que conduzem a resultados definitivos. Os enunciados mencionados, no entanto, possibilitam apenas uma valoração *prima facie*. Por isso, aquilo que eles expressam não deve ser designado como "regra". Sobre a definição de valores como regras, cf., com referências adicionais, Adalbert Podlech, "Wertung und Werte im Recht", *AöR* 95 (1970), pp. 195-196 (regras de precedência), e Werner Kirsch, *Einführung in die Theorie der Entscheidungsprozesse*, v. 2, 2ª ed., Wiesbaden: Gabler, 1977, p. 121 ("uma espécie de regra de decisão").

situação que, segundo o critério de valoração "liberdade de imprensa", é melhor que outra, ou é a melhor de todas, é melhor apenas *prima facie*. A decisão acerca da situação definitivamente melhor é obtida somente após uma valoração global, na qual todos os critérios válidos de valoração sejam levados em consideração.

1.3 A diferença entre princípios e valores

O que se acabou de afirmar corresponde exatamente ao modelo de princípios. A diferença entre princípios e valores é reduzida, assim, a um ponto. Aquilo que, no modelo de valores, é *prima facie* o melhor é, no modelo de princípios, *prima facie* devido; e aquilo que é, no modelo de valores, definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente devido. Princípios e valores diferenciam-se, portanto, somente em virtude de seu caráter deontológico, no primeiro caso, e axiológico, no segundo.

No direito o que importa é o que deve ser. Isso milita a favor do modelo de princípios. Além disso, não há nenhuma dificuldade em se passar da constatação de que determinada solução é a melhor do ponto de vista do direito constitucional para a constatação de que ela é constitucionalmente devida. Se se pressupõe a possibilidade dessa transição, então, é perfeitamente possível, na argumentação jurídica, partir de um modelo de valores em vez de partir um modelo de princípios. Mas o modelo de princípios tem a vantagem de que nele o caráter deontológico do direito se expressa claramente. A isso soma-se o fato de que o conceito de princípio suscita menos interpretações equivocadas que o conceito de valor. Ambos os aspectos são importantes o suficiente para que se dê preferência ao modelo de princípios.

2. Objeções às teorias de princípios e de valores

O modelo de princípios e o modelo de valores mostraram-se, na sua essência, estruturalmente iguais, exceto pelo fato de que o primeiro se situa no âmbito deontológico (no âmbito do dever-ser), e o segundo, no âmbito do axiológico (no âmbito do bom). Diante disso, as objeções às teorias valorativas dos direitos fundamentais podem atingir também a teoria dos princípios.

Teorias valorativas dos direitos fundamentais eram defendidas já na época da Constituição de Weimar. Um dos autores mais influentes nesse sentido foi Rudolf Smend. De acordo com sua conhecida formulação, o “sentido substancial de um catálogo de direitos fundamentais” consiste na sua pretensão de “normar uma série substantiva com um certo grau de unidade, isto é, um sistema de valores ou de bens, um sistema cultural”.¹⁷⁷ Sob a Constituição atual as idéias e as formas de expressão das teorias de valores ingressaram de forma intensa na jurisprudência constitucional, tendo como ponto culminante a decisão no caso Lüth. Ainda que o Tribunal Constitucional Federal parta do pressuposto, também nessa decisão, de que “os direitos fundamentais são destinados, em primeira instância, a proteger a esfera de liberdade do indivíduo contra intervenções dos poderes públicos”, ou seja, de que eles são “direitos de defesa do cidadão contra o Estado”,¹⁷⁸ ele acrescenta, na mesma decisão, que “[i]gualmente correto é o fato de que a Constituição, que não pretende ser uma ordenação axiologicamente neutra, (...) também estabeleceu, na seção dedicada aos direitos fundamentais, uma ordem objetiva de valores (...). Esse sistema de valores, em cujo centro se encontra o livre desenvolvimento da personalidade humana e de sua dignidade no seio da comunidade social, deve valer, como decisão constitucional fundamental, para todos os ramos do direito”.¹⁷⁹ No desenrolar da fundamentação da decisão, a ordem de valores é qualificada como “*hierarquia de valores*”, no âmbito da qual um “sopesamento” se faz necessário.¹⁸⁰ Com isso, foram mencionados os conceitos centrais da teoria dos valores sustentada em diver-

177. Rudolf Smend, “Verfassung und Verfassungsrecht (1928)”, in *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1968, p. 264. Também deve ser mencionado Albert Hensel, *Grundrechte und politische Weltanschauung*, Tübingen: Mohr, 1931, p. 10: “assim, o conteúdo de todos os ordenamentos jurídicos é a realização de um sistema de valores políticos fundados nos direitos fundamentais”. Cf. também Hans Gerber, *Die weltanschaulichen Grundlagen des Staates*, Stuttgart: Enke, 1930, pp. 13 e ss.; Gerhard Leibholz, *Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert*, 3ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1966, pp. 46 e ss.; Günther Holstein, “Von Aufgaben und Zielen heutiger Staatsrechtswissenschaft”, *AöR NF* 11 (1926), pp. 29 e ss.; Erich Kaufmann, “Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung”, *VVDStRL* 3 (1927), pp. 3 e ss.

178. *BVerfGE* 7, 198 (204).

179. *BVerfGE* 7, 198 (205).

180. *BVerfGE* 7, 198 (215).

sas decisões do tribunal: valor, ordem de valores, hierarquia de valores, sistema de valores e sopesamento.¹⁸¹

A avaliação que se faz dessa teoria valorativa dos direitos fundamentais vai desde a rejeição radical até a aceitação enfática. A posição de rejeição é defendida de forma mais marcante por Forsthoff. Segundo ele, a teoria dos valores levaria à “dissolução da clareza conceitual em falatório”,¹⁸² a uma “perda não apenas de racionalidade, mas também de nível científico”,¹⁸³ a uma “dissolução da lei constitucional” e a uma eliminação do conteúdo de liberdade dos direitos fundamentais.¹⁸⁴ O constitucionalista norte-americano Kommers expressou-se mais recentemente de forma exatamente contrária acerca de um “pensamento constitucional enraizado em um sistema de valores”; segundo ele, “a genialidade do pensamento constitucional alemão está na identificação de um tal sistema na ordem hierárquica de valores do Tribunal Constitucional Federal”.¹⁸⁵

As objeções à teoria dos valores podem ser classificadas em três grupos: filosóficas, metodológicas e dogmáticas.

2.1 Objeções filosóficas

As objeções filosóficas dirigem-se sobretudo contra o conceito de *objetividade* da teoria dos valores. O desenvolvimento mais original e

181. Para uma exposição da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, cf. Helmut Goerlich, *Wertordnung und Grundgesetz*, Baden-Baden: Nomos, 1973, pp. 29 e ss.; Harald Schneider, *Die Güterabwägung des Bundesverfassungsgerichts bei Grundrechtskonflikten*, pp. 43 e ss.; Waldemar Schreckenberger, *Rhetorische Semiotik*, Freiburg: Alber, 1981, pp. 191 e ss. Dentre os diversos defensores de uma teoria dos valores sob a atual Constituição alemã, basta mencionar Günter Dürig, “Art. 1 Abs. 1”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz*, §§ 1 e ss.

182. Ernst Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft*, 2ª ed., München: Beck, 1971, p. 69.

183. Ernst Forsthoff, “Zur heutigen Situation einer Verfassungslehre”, in Hans Barion et al. (Orgs.), *Epirrhosis, Festgabe für Carl Schmitt*, Berlin: Duncker & Humblot, 1968, p. 209.

184. Ernst Forsthoff, “Die Umbildung des Verfassungsgesetzes”, in Hans Barion et al. (Orgs.), *Festschrift für Carl Schmitt*, p. 47.

185. Donald P. Kommers, “Der Gleichheitssatz: Neuere Entwicklungen und Probleme im Verfassungsrecht der USA und der Bundesrepublik Deutschland”, in Christoph Link (Org.), *Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat, Symposium zum 80. Geburtstag von Gerhard Leibholz*, Baden-Baden: Nomos, 1982, p. 50.

mais amplo da idéia de uma ordem objetiva de valores pode ser encontrado em Max Scheler.

Segundo Scheler, valores não somente *valem*, eles têm também um *ser* independente, um “ser dos valores”.¹⁸⁶ Por isso, Scheler acredita que valores podem ser qualificados como fatos (“fatos independentes da vida moral”).¹⁸⁷ Ao enunciado valorativo “A é bom” deve corresponder um fato moral, da mesma forma que ao enunciado descritivo “A é verde” deve corresponder um fato empírico. “A diferença consiste apenas na *matéria* do predicado.”¹⁸⁸ Havendo correspondência com os fatos, ambos os enunciados são igualmente verdadeiros.¹⁸⁹

A *cognição* dos valores deve ocorrer por meio de uma faculdade cognoscitiva específica, descrita por Scheler com as seguintes palavras: “A verdadeira sede de todo valor *a priori* (e também da Moral) é a *cognição do valor* ou *intuição do valor*, construída a partir do sentimento, da preferência e, sobretudo, do amar e do odiar, bem como a partir da conexão entre valores, do seu ‘ser superior’ ou ‘ser inferior’, isto é, da ‘cognição moral’. Essa cognição ocorre, então, por meio de funções e atos *específicos*, que são *toto coelo* diferentes de toda percepção e pensamento, e o único *acesso* ao mundo dos valores”.¹⁹⁰

Uma teoria desse tipo, que, em primeiro lugar, pressupõe que “há qualidades valorativas que representam um âmbito próprio de *objetos*”¹⁹¹ e, em segundo lugar, que supõe que esses objetos são acessíveis a um conhecimento direto, que não tem nem caráter empírico, nem analítico, e que podem ser mais bem descritos como um sentimento de valores ou experiência de evidências, deve ser classificada como “intuicionista”.¹⁹² O argumento mais forte contra o intuicionismo afirma que, diante da observação de que diferentes pessoas percebem diferentes valorações como evidentes, mesmo sob condições ideais para a percepção de evidências (como, por exemplo, ausência de emo-

186. Max Scheler, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, p. 195.

187. Idem, pp. 173, 192 e 195.

188. Idem, p. 192.

189. Idem, p. 196.

190. Idem, p. 87.

191. Idem, p. 37.

192. Sobre o intuicionismo, cf., com mais referências, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 58 e ss.

ção e clareza mental), o intuicionismo não tem condições de fornecer nenhum critério definitivo para evidências corretas ou equivocadas, verdadeiras ou falsas.¹⁹³ Na falta de um tal critério, o intuicionismo iguala-se a uma posição subjetivista. Esse argumento epistemológico tem conseqüências para a tese ontológica do ser dos valores. A impossibilidade de que algo seja conhecido com certeza intersubjetiva não constitui ainda um argumento contra sua existência. Mas é um argumento contra a possibilidade de fundamentar uma teoria científica a partir de sua existência.

Essas objeções fundamentam a rejeição das teorias valorativas intuicionistas, mas não das teorias valorativas em geral. Teorias intuicionistas – como a de Scheler – são apenas uma variante dentro do espectro das possíveis teorias valorativas. Concepções assim tão marcadas e vulneráveis, como aquelas sobre o ser e a evidência dos valores, não estão necessariamente vinculadas com o conceito de valor. O fato de o Tribunal Constitucional Federal falar de valores, de uma ordem ou de um sistema de valores não significa, por si só, que ele aceite as concepções acima rejeitadas.¹⁹⁴ Como não há nenhum motivo determinante para uma tal suposição, a interpretação das teses valorativas do tribunal sugere uma teoria valorativa menos marcada e, por isso, menos vulnerável. Uma tal teoria é obtida quando se pressupõe que valores são critérios de valoração, os quais, como as normas em geral, ou são válidos, ou não. Tanto a validade desses critérios quanto as valorações que a partir deles são possíveis não são objetos de alguma forma de evidência, mas uma questão de fundamentação. A fundamentação depende do tipo de validade de que se trata: jurídica, social ou ética. Daqui em diante partir-se-á de uma forma de teoria de valores livre de suposições ontológicas e epistemológicas questionáveis, que, por isso, não é afetada pelas objeções filosóficas acima descritas.

193. Cf., por exemplo, Peter F. Strawson, "Ethical intuitionism", *Philosophy* 24 (1949), p. 27; Adalbert Podlech, *Werte und Wertung im Recht*, p. 205; do mesmo autor, "Recht und Moral", *Rechtstheorie* 3 (1972), p. 135.

194. Isso ocorre, por exemplo, com Horst Harnischfeger, *Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Grundrechten*, Hamburg: Christen, 1966, pp. 233-234. Em sentido contrário, cf. Erwin Stein, "Werte und Wertewandel in der Gesetzesanwendung des öffentlichen Rechts", in Josef Esser/Erwin Stein, *Werte und Wertewandel in der Gesetzesanwendung*, Frankfurt am Main: Evangelischer Presseverband für Hessen und Nassau, 1966, pp. 40 e ss.

2.2 *Objecções metodológicas*

As objecções metodológicas devem ser levadas mais a sério. Em razão de suas referências a valores e a uma ordem de valores, o Tribunal Constitucional Federal é censurado por deixar de lado os postulados da fundamentação racional.¹⁹⁵ Por meio do recurso ao conceito de ordem de valores poderia ser justificado qualquer resultado. O discurso dos valores destruiria a transparência da decisão judicial¹⁹⁶ e conduziria a um “arcano da interpretação constitucional”.¹⁹⁷ Decisões sobre colisões e sopesamentos tomadas de outra maneira seriam camufladas, revestidas por uma “aparência racional” e “dispensadas de uma real fundamentação”. “Pelo aspecto prático”, o recurso a uma ordem e a um sopesamento de valores seria uma “fórmula de ocultar o decisionismo judicial e interpretativo”.¹⁹⁸

O argumento metodológico contra a teoria dos valores dirige-se contra duas concepções: contra a concepção de ordem de valores no sentido de ordem *hierarquizada* de valores e contra o sopesamento. As objecções contra a possibilidade de uma ordem hierarquizada de valores são quase todas elas procedentes; já aquelas contra o sopesamento podem ser respondidas no âmbito do modelo dos princípios aqui defendido.

2.2.1 A concepção de uma ordem hierarquizada de valores

Quem faz menção a uma ordem hierarquizada de valores tem que dizer, em primeiro lugar, que valores deverão ser ordenados com base nessa hierarquia. Aqui interessam os valores relevantes para uma decisão no âmbito dos direitos fundamentais. Portanto, quando se fala em uma ordem hierarquizada de valores só se pode querer fazer menção a esses valores. Com isso surge um primeiro problema: como deve

195. Cf., por exemplo, Helmut Goerlich, *Wertordnung und Grundgesetz*, p. 64.

196. Idem, pp. 133 e 189.

197. Idem, pp. 140, 134 e 189.

198. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, *NJW* 27 (1974), p. 1.534. Em sentido semelhante, cf. Ernst Forstthoff, “Zur heutigen Situation einer Verfassungslehre”, pp. 190 e ss.; Erhard Denninger, *Staatsrecht*, v. 2, Reibek: Rowohlt, 1979, p. 184; Ulrich K. Preuss, *Die Internalisierung des Subjekts*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979, pp. 151 e ss.

ser delimitada a classe desses valores? Acima foi demonstrado que uma tal delimitação não é simples, sobretudo no âmbito das restrições. É possível discutir que valores são relevantes do ponto de vista dos direitos fundamentais e quais não o são. A possibilidade de uma polêmica desse tipo dificulta a elaboração de uma ordem de valores que contenha todos e somente os valores relevantes no âmbito dos direitos fundamentais, ou seja, uma ordem de valores *completa e fechada*. Em um nível alto de generalidade, essa completude e essa hermeticidade são relativamente fáceis de serem alcançadas. Assim, com poucos conceitos, como “dignidade”, “liberdade”, “igualdade”, “proteção” e “bem-estar da comunidade”, é possível abarcar quase tudo aquilo que tem que ser levado em consideração em um sopesamento de direitos fundamentais. Aquele que, nesse nível de generalidade, procura estabelecer uma hierarquia tem, portanto, poucos problemas com a identificação dos elementos a serem ordenados. Mas terá também poucas chances de obter um sistema significativo. Essa chance aumenta quando se caminha na direção de níveis mais concretos. Mas, ao mesmo tempo, aumentam também os problemas na identificação dos elementos a serem ordenados. Já é questionável se uma única pessoa consegue indicar os valores concretos que, segundo seu modo de ver, podem ser relevantes para o julgar e o decidir no âmbito dos direitos fundamentais. Um catálogo completo, acerca do qual todos estejam de acordo, seria praticamente impossível de estabelecer. Isso já é suficiente para colocar em dificuldades o conceito de ordem hierarquizada de valores. Se não é possível estabelecer um catálogo exaustivo, é, então, necessário ordenar algo conhecido de maneira apenas incompleta.

Ainda mais difícil que o problema da identificação daquilo que deve ser ordenado são os problemas relativos à ordenação em si mesma. Essa ordenação pode ser levada a cabo de duas formas: de forma cardinal ou de forma ordinal. Uma ordenação *cardinal* ocorre quando aos valores são atribuídos números a partir de uma escala, os quais expressam sua hierarquia ou seu peso. Nesse sentido, seria possível pensar em expressar a hierarquia dos valores por meio de números de uma escala que vá de 0 a 1. Já uma ordenação *ordinal* é menos exigente. Ela exige apenas que sejam estabelecidas relações de superioridade valorativa (preferência) e de igualdade valorativa (indiferença)

entre os valores a serem ordenados.¹⁹⁹ É fácil perceber que uma ordenação abstrata de valores constitucionais, não importa se cardinal ou ordinal, é inaceitável.

É possível utilizar como exemplo uma situação como a do caso Lebach, na qual dois valores (princípios) são relevantes, o da proteção da personalidade e o da liberdade de informar por meio de radiodifusão.²⁰⁰ Em primeiro lugar, é possível considerar a tentativa de se chegar a uma conclusão a partir de uma ordenação desses valores em uma escala cardinal. Em uma escala como essa é possível ordenar esses dois valores de duas formas: por meio da atribuição de números iguais (igual hierarquia) ou por meio da atribuição de números diversos (diferente hierarquia). Se se atribuem números iguais, então, a ordenação cardinal, sozinha, não tem nenhuma utilidade. Se se atribuem números distintos – como, por exemplo, 0,8 para a proteção da personalidade e 0,4 para a liberdade de informar por meio de radiodifusão –, então, o caso está decidido. A atribuição desses números expressa uma importância duas vezes maior da proteção da personalidade em face da liberdade de informar por meio de radiodifusão.²⁰¹ Se se parte apenas de uma tal ordenação hierárquica *abstrata*, isso significa que, nos casos de colisão, a proteção da personalidade sempre prevalecerá sobre a liberdade de informar por meio de radiodifusão. Uma tal hierarquia abstrata não apenas contradiria a correta constatação do Tribunal Constitucional Federal, segundo a qual nenhum dos dois valores pode ter pretensão a uma precedência abstrata;²⁰² ela teria também consequências fatais. Uma precedência da proteção da personalidade sobre a liberdade de informar por meio de radiodifusão em *todos* os casos significaria que um mínimo fomento à proteção da personalidade justificaria a mais intensa restrição à liberdade de informar. Com isso, estaríamos diante daquilo que Carl Schmitt, na esteira de Hartmann,²⁰³ chamou de “tirania dos valores”: “a partir da lógica dos valores, é sem-

199. Sobre os conceitos de ordenação cardinal e ordinal, cf. Gérard Gäfgen, *Theorie der wirtschaftlichen Entscheidung*, 3ª ed., Tübingen: Mohr, 1974, pp. 150 e ss.

200. BVerfGE 35, 202 (219 e ss.)

201. A tese de Steiner, segundo a qual “é difícil atribuir qualquer significado a uma tal afirmação”, tem alguma procedência. Cf. Joseph M. Steiner, “Judicial discretion and the concept of law”, *Cambridge Law Journal* 35 (1976), p. 153.

202. BVerfGE 35, 202 (225).

203. Cf. Nicolai Hartmann, *Ethik*, pp. 523 e ss.

pre correto que o maior preço nunca é demasiadamente alto para o valor máximo, e tem que ser pago".²⁰⁴

É necessário colocar em dúvida, no entanto, se isso é algo que derive da "lógica dos valores". A consequência apontada não é algo que resulta do conceito de valor (ou de princípio), mas sim de uma determinada e equivocada concepção acerca da relação entre valores (princípios) colidentes, que, de resto, contradiz a definição anteriormente fixada para o conceito de princípio, a qual inclui uma referência àquilo que o princípio contraposto exige. Na medida em que se aceita uma relação absoluta de precedência entre dois valores, esses são equiparados às regras naquilo que diz respeito ao seu comportamento em casos de colisão.

Aquilo que vale para as escalas cardinais abstratas vale também para as escalas abstratas ordinais. Nos casos de igualdade hierárquica não se obtém resultado algum; nos casos de diferença hierárquica vale o que foi dito acerca do estabelecimento de uma hierarquia abstrata por meio de escalas cardinais.

Nas escalas cardinais esse resultado pode ser evitado se se estabelece não apenas uma escala da hierarquia do valor (princípio), mas também uma escala com a intensidade de sua realização.²⁰⁵ Suponhamos uma colisão entre a proteção da personalidade (P_1) e a liberdade de radiodifusão (P_2). A P_1 seria atribuída a importância abstrata de 0,8; a P_2 a importância abstrata de 0,4. Neste ponto, a questão a ser respondida é: o que deve ter precedência, uma proibição da radiodifusão de um programa (R_1) ou a permissão dessa radiodifusão (R_2)? As intensidades da realização de ambas as alternativas, R_1 e R_2 , são expressas na seguinte tabela:

	P_1 (proteção da personalidade) = 0,8	P_2 (liberdade de radiodifusão) = 0,4
R_1 (proibição)	0,4	0,3
R_2 (permissão)	0,3	0,9

204. Carl Schmitt, "Die Tyrannei der Werte, in Sergius Buve (Org.), *Säkularisation und Utopie – Festschrift für Ernst Forsthoff*, Stuttgart: Kohlhammer, 1967, p. 60.

205. Cf. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 131 e ss.

A proibição da radiodifusão contribui só um pouco mais para a realização da proteção da personalidade que a sua permissão (0,4 contra 0,3). Já para a liberdade de radiodifusão há uma considerável diferença (0,3 contra 0,9). A qual das alternativas deve ser dada preferência é algo que pode ser calculado por meio de uma simples operação. As intensidades de realização devem ser multiplicadas pelo valor abstrato dos princípios. Em seguida devem ser somados os produtos de ambas as alternativas.²⁰⁶ Para R_1 , isso significa: $0,32 (0,4 \times 0,8) + 0,12 (0,3 \times 0,4) = 0,44$; para R_2 : $0,24 (0,3 \times 0,8) + 0,36 (0,9 \times 0,4) = 0,6$. Com 0,6, R_2 tem o maior valor global e deve, por isso, ser escolhida, ainda que R_1 seja exigida pelo princípio de maior hierarquia abstrata. A "tirania dos valores" fica superada. No entanto, essa também não é uma solução. O resultado é, de fato, rapidamente calculável após a atribuição de valores numéricos. O problema, no entanto, está na atribuição desses valores. É questionável a possibilidade de atribuir valores hierárquicos abstratos a cada um dos valores ou princípios. De qualquer forma, parece estar excluída uma atribuição intersubjetiva inequívoca de números para as intensidades de realização. Não é possível inferir um resultado a partir de uma quantificação fixa; no máximo, é possível *ilustrar* de forma quantitativa a decisão, independentemente de como se tenha chegado a ela. A concepção de uma hierarquia de valores que trabalhe com escalas cardinais fracassa, portanto, diante dos problemas da metrificação dos pesos e das intensidades de realização dos valores ou princípios.²⁰⁷

Tampouco constitui uma alternativa partir da igualdade hierárquica dos valores ou princípios para, então, trabalhar com intensidades cardinais de realização. O problema seria simplesmente deslocado para questões insolúveis da metrificação das intensidades de realização.

Por isso, pode-se dizer, de forma geral, que é impossível uma ordenação dos valores ou princípios que, em todos os casos e de forma intersubjetivamente cogente, defina a decisão no âmbito dos direitos fundamentais.²⁰⁸ A impossibilidade de uma tal ordenação "rígida"

206. Sobre esse procedimento, cf. Karl Haag, *Rationale Strafzumessung*, Köln: Heymann, 1970, pp. 45 e ss.; Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 132-133.

207. Cf. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 134-135.

208. A possibilidade, suscitada por Schlink, de se resolver o problema da ordem de valores por meio de uma função — no estilo da economia do bem-estar —, que

não implica a impossibilidade de uma ordenação "flexível" e, sobretudo, não diz nada contra o conceito de sopesamento. Ordenações flexíveis podem surgir de duas formas: (1) por meio de preferências *prima facie* em favor de um determinado princípio ou valor; e (2) por meio de uma rede de decisões concretas sobre preferências. Uma ordenação flexível dos valores constitucionalmente relevantes por meio de preferências *prima facie* é obtida, por exemplo, quando se pressupõe uma carga argumentativa em favor da liberdade individual, ou da igualdade, ou de interesses coletivos. Uma ordenação flexível por meio de uma rede de decisões concretas sobre preferências é obtida por meio da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Ambas estão intimamente ligadas ao conceito de sopesamento, o qual será analisado a seguir.

2.2.2 A idéia de sopesamento

Contra a idéia de sopesamento é muitas vezes levantada a objeção de que ela não é um modelo aberto a um controle racional. Valores

permitiria inferir utilidades sociais (ou preferências coletivas ou concepções coletivas de valor) a partir de utilidades individuais (ou preferências individuais ou concepções individuais de valor), será aqui examinada apenas marginalmente (cf., a respeito, Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 154 e ss.). Um enfoque nesses termos pressupõe que aquilo que é válido como direito constitucional pode ser equiparado às utilidades coletivas na forma de uma função de utilidades individuais. Embora essa equiparação tenha —como Schlink ressalta—tendências tanto individualistas como democráticas, ela vincularia por completo o direito constitucional às concepções de valor generalizadas em cada momento. Contudo, o fato de que uma concepção de valor seja generalizada não significa que seja válida do ponto de vista do direito constitucional. Mesmo que se desconsidere esse problema, esse enfoque fracassa diante da dificuldade de se agregar as utilidades individuais às utilidades sociais. Se as utilidades individuais forem mensuradas em uma escala cardinal, surgem, pelo menos no que diz respeito a questões jurídico-constitucionais, dificuldades insuperáveis em relação à mensuração e à comparação dessas utilidades (cf. Schlink, pp. 166-167). É certo que esses problemas podem ser evitados com a utilização de uma escala ordinal, mas, nesse caso, a agregação fracassaria diante do teorema da impossibilidade de Arrow. A esse respeito, cf. Kenneth J. Arrow, *Social Choice and Individual Values*, 2ª ed., New York: Wiley, 1963; R. Duncan Luce/Howard Raiffa, *Games and Decisions. Introduction and Critical Survey*, New York: Wiley, 1957, pp. 327 e ss.; Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen des allgemeinen verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes*, pp. 274 e ss.; Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 180 e ss.

e princípios não disciplinam sua própria aplicação, e o sopesamento, portanto, ficaria sujeito ao arbítrio daquele que sopesa. Onde começa o sopesamento terminaria o controle por meio de normas e métodos. Ele abriria espaço para o subjetivismo e o decisionismo dos juízes. Essas objeções são procedentes se com elas se quiser dizer que o sopesamento não é um procedimento que conduza, em todo e qualquer caso, a um resultado único e inequívoco. Mas elas não são procedentes quando daí se conclui que o sopesamento é um procedimento não-racional ou irracional.

Anteriormente foi demonstrado que as colisões entre princípios devem ser resolvidas por meio da definição de uma relação de precedências condicionadas. Como exemplo foi utilizado o caso Lebach, no qual o Tribunal Constitucional Federal solucionou a colisão entre a proteção da personalidade (P_1) e a liberdade de informar via radio-difusão (P_2) por meio da aceitação de uma precedência de P_1 no caso de uma "repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um interesse atual pela informação", que "coloca em risco a ressocialização do autor" (C_2).²⁰⁹ A partir daí, o tribunal elaborou um enunciado de preferências com a seguinte forma:

$$(1) (P_1 \text{ P } P_2) C_2.$$

Segundo a lei de colisão,²¹⁰ desse enunciado decorre uma regra:

$$(2) C_2 \rightarrow R,$$

a qual, sob as condições C_2 , comina a consequência jurídica de P_1 (R).

2.2.2.1 O modelo decisionista e o modelo fundamentado

Se o sopesamento se resumisse à formulação de um tal enunciado de preferências e, com isso, à determinação da regra relacionada ao caso – que decorre desse enunciado –, o sopesamento, de fato, não representaria um procedimento racional. O estabelecimento da preferência condicionada poderia ocorrer de forma intuitiva. Aquele que

209. BVerfGE 35, 202 (237)

210. Cf., neste Capítulo, I.3.2.1.

sopesa teria a possibilidade de seguir única e exclusivamente suas concepções subjetivas. Não seria possível falar em sopesamentos corretos e sopesamentos equivocados.

No entanto, a um tal modelo *decisionista* de sopesamento pode ser contraposto um modelo *fundamentado*. Em ambos os modelos o resultado do sopesamento é um enunciado de preferência condicionada. No modelo decisionista a definição do enunciado de preferência é o resultado de um processo psíquico não controlável racionalmente. O modelo fundamentado, por sua vez, distingue entre o processo psíquico que conduz à definição do enunciado de preferência e sua fundamentação.²¹¹ Essa diferenciação permite ligar o postulado da racionalidade do sopesamento à fundamentação do enunciado de preferência e afirmar: um sopesamento é racional quando o enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamentado de forma racional. Com isso, o problema da racionalidade do sopesamento leva-nos à questão da possibilidade de fundamentação racional de enunciados que estabeleçam preferências condicionadas entre valores ou princípios colidentes.

2.2.2.2 A fundamentação de enunciados de preferências condicionadas não relacionada especificamente ao sopesamento

De acordo com a lei de colisão, dos enunciados de preferências condicionadas decorrem regras que, diante de determinadas condições, cominam a consequência jurídica do princípio prevalente. Nesse sentido, a fundamentação de enunciados de preferências é uma fundamentação de regras relativamente concretas, que devem ser atribuídas às disposições de direitos fundamentais. Para sua fundamentação podem ser utilizados todos os argumentos possíveis na argumentação constitucional. Mas a possibilidade de uso de argumentos semânticos fica excluída nos casos em que com a própria constatação da colisão já se decide, a partir do teor literal da Constituição, acerca da aplicação das

211. Isso equivale à frequentemente citada diferenciação entre o processo de descoberta (*process of discovery*) e o processo de justificação (*process of justification*). Cf., por exemplo, Richard A. Wasserstrom, *The Judicial Decision*, Stanford: Stanford University Press, 1961, p. 27.

disposições constitucionais em questão. Já os demais cânones da interpretação e argumentos dogmáticos, precedentes, argumentos práticos e empíricos em geral, além de formas específicas de argumentação jurídica, podem sempre ser utilizados.²¹² Assim, para a fundamentação de um enunciado de preferências condicionadas e, com isso, para a fundamentação da regra que a ele corresponde, pode-se recorrer à vontade do constituinte, às consequências negativas de uma fixação alternativa das preferências, a consensos dogmáticos e a decisões passadas. Nesses termos, a fundamentação de um enunciado de preferências condicionadas não é diferente da fundamentação de regras semânticas criadas para tornar conceitos vagos mais precisos. E a diferença desaparece ainda mais quando se leva em consideração que também no âmbito da interpretação tradicional, com frequência, são realizados sopesamentos. Basta pensar em um caso no qual uma interpretação estrita de um conceito teria como consequência uma menor proteção de um direito fundamental, enquanto a interpretação extensiva do mesmo conceito levaria a uma maior proteção desse direito. Diante da variedade de possíveis argumentos a favor de enunciados de preferência, é possível afirmar que a freqüente recomendação para que se levem em consideração apenas as consequências²¹³ constitui uma redução injustificável.

2.2.2.3 A fundamentação relacionada especificamente ao sopesamento

O que foi dito acerca da utilização de argumentos jurídicos gerais ainda não diz respeito ao que há de específico na fundamentação de enunciados de preferências. Se houvesse apenas esses argumentos, seria possível cogitar de abrir mão do enunciado de preferência e basear a fundamentação exclusivamente na regra que dele decorre.

A existência de argumentos relacionados especificamente ao sopesamento é sugerida por formulações do Tribunal Constitucional Federal, como as seguintes: "A pretensão de liberdade dos indivíduos

212. Sobre isso, cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 285 e ss.

213. Cf., por exemplo, Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 181, 192 e 199; Adalbert Podlech, *Wertung und Werte im Recht*, p. 208.

manifesta-se (...) tanto mais intensamente quanto mais se colocar em questão seu direito à liberdade de escolha profissional; a proteção da comunidade torna-se tanto mais premente quanto maior forem as desvantagens e os perigos que para ela possam advir da total liberdade de exercício profissional";²¹⁴ "[q]uanto mais a intervenção legal afetar as manifestações elementares da liberdade de ação humana, tanto mais cuidadoso deve ser o sopesamento das razões contrárias à pretensão elementar de liberdade do cidadão";²¹⁵ "[a]lém disso resulta (...) que o necessário sopesamento deve levar em consideração, de um lado, a intensidade da intervenção na esfera da personalidade por meio da transmissão de um programa televisivo desse tipo; de outro lado, deve ser avaliado o interesse concreto a que o programa satisfaz e que, para tanto, é adequado".²¹⁶ Essas manifestações²¹⁷ fazem referência a uma regra que é constitutiva para os sopesamentos do Tribunal Constitucional Federal, que pode ser formulada da seguinte forma:

- (A) "Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro".²¹⁸

Essa regra expressa uma lei que vale para todos os tipos de sopesamento de princípios e pode ser chamada de *lei do sopesamento*. Segundo a lei do sopesamento, a medida permitida de não-satisfação ou de afetação de um princípio depende do grau de importância da satisfação do outro. Na própria definição do conceito de princípio, com a cláusula "dentro das possibilidades jurídicas", aquilo que é exigido por um princípio foi inserido em uma relação com aquilo que é exigi-

214. BVerfGE 7, 377 (404-405).

215. BVerfGE 20, 150 (159). Cf. também BVerfGE 17, 306 (314).

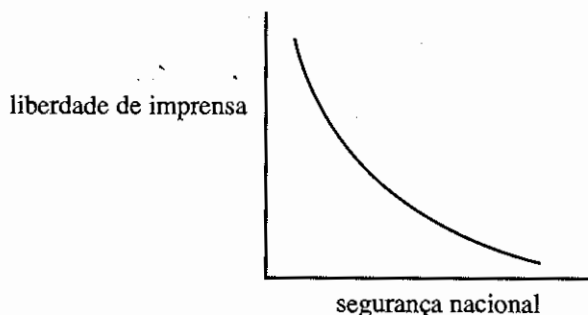
216. BVerfGE 35, 202 (226).

217. Cf. também BVerfGE 41, 251 (264), decisão na qual o tribunal faz menção a "um sopesamento global entre a intensidade da intervenção e o peso e a urgência das razões que a justificam".

218. Para uma formulação um pouco diferente, cf. Robert Alexy, "Die logische Analyse juristischer Entscheidungen", p. 206. Aqui é possível abrir mão de especificações adicionais acerca dessa regra. Parte-se, neste ponto, do pressuposto de que os princípios em questão colidem, ou seja, de que um princípio pode ser satisfeito às custas de outro. Colisões surgem apenas quando da solução de casos. Aquilo que é colocado em relação por meio de uma regra é, por conseguinte, a afetação de um dos princípios em razão de uma determinada solução de um caso e a importância da satisfação do outro princípio nesse mesmo caso.

do pelo princípio colidente. A lei de colisão expressa em que essa relação consiste. Ela faz com que fique claro que o peso dos princípios não é determinado em si mesmo ou de forma absoluta e que só é possível falar em pesos relativos.²¹⁹

As idéias que estão por trás da lei do sopesamento podem ser ilustradas com o auxílio de curvas de indiferença, como aquelas que são utilizadas nas ciências econômicas.²²⁰ Uma curva de indiferença é um meio para representar a relação de substituição de bens. Suponhamos que *a* seja favorável tanto à liberdade de imprensa quanto à segurança nacional e que ele esteja disposto a aceitar tanto uma certa diminuição na segurança nacional, para que haja uma certo aumento na liberdade de imprensa, quanto uma certa diminuição na liberdade de imprensa, para que haja um certo aumento na segurança nacional. As situações julgadas por *a* como igualmente boas ou indiferentes podem, então, ser representadas por pontos em uma curva:



Curvas de indiferença como essa correspondem à lei da taxa marginal decrescente de substituição.²²¹ Conforme a liberdade de expres-

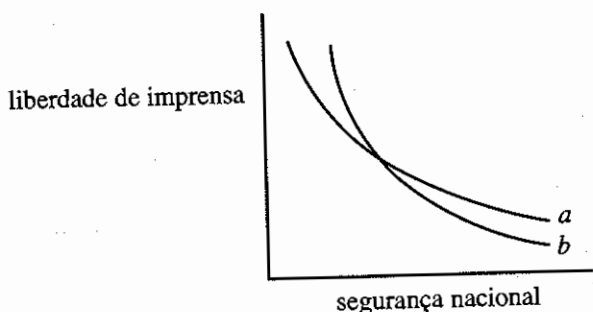
219. Cf. Brian M. Barry, *Political Argument*, London: Routledge, 1965, p. 7.

220. Sobre o conceito de curva de indiferença, cf., por todos, Tibor Scitovsky, *Welfare and Competition*, London: Allen and Unwin, 1952, pp. 30 e ss. Para uma utilização de curvas de indiferença na filosofia prática, cf. Brian Barry, *Political Argument*, pp. 4 e ss.; John Rawls, *A Theory of Justice*, pp. 37 e ss. No âmbito do direito constitucional, foi Schlink quem tentou fazer com que fosse frutífero um enfoque indiferencialista (cf. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 168 e ss. e 169 e ss.).

221. Cf. Brian M. Barry, *Political Argument*, pp. 6 e ss.; Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, p. 168.

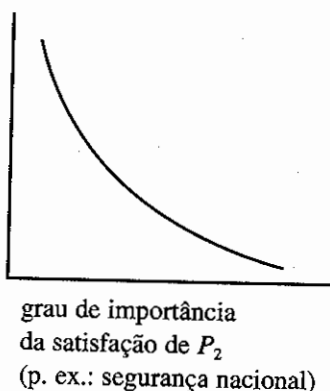
são diminuí, exige-se um aumento cada vez maior na segurança nacional, para compensar cada diminuição adicional na liberdade de imprensa, e vice-versa.

Mas curvas de indiferença como essa não são diretamente equivalentes à lei do sopesamento. A lei do sopesamento aponta, em primeiro lugar, para a *importância* da satisfação do princípio colidente e formula, em segundo lugar, um dever. A curva apresentada acima, por sua vez, apenas descreve as substituições que são indiferentes para *a*. O traçado da curva expressa o quão importante é, para *a*, a segurança nacional em relação à liberdade de imprensa. Uma outra pessoa *b* pode ter uma outra concepção acerca dessa importância relativa. O fato de que para *b* a segurança nacional seja mais importante que para *a* pode ser representado da seguinte maneira:



O sopesamento constitucional não diz respeito à importância que alguém confere à liberdade de imprensa ou à segurança nacional, mas à definição de qual *deve ser* a importância que se deve conferir a ambas. Ainda que seja possível tentar representar a relação de substituição aceita pelo Tribunal Constitucional Federal por meio de uma curva de indiferença, do ponto de vista do método, o sopesamento diz respeito a uma regra que prescreve como se deve sopesar. Portanto, a lei do sopesamento é formulada como uma regra, que prescreve a definição de curvas de indiferença corretas (importâncias relativas corretas). Nesse sentido, diante das curvas de indiferença dos tipos apresentados acima, a lei do sopesamento deve ser inserida em um metanível. Nesse metanível ela pode ser representada pela seguinte *curva de indiferença de segundo nível*:

grau de satisfação
(grau de não-afetação) de P_1
(p. ex.: liberdade de imprensa)



Essa curva tem uma interessante característica: mesmo aquelas pessoas cuja concepção é representada por distintas curvas de indiferença de primeiro nível são aqui representadas de forma sobreposta. Se a e b aceitam ambos os princípios como abstratamente de mesma hierarquia, eles não podem divergir acerca do fato de que um grau muito reduzido de satisfação ou uma afetação muito intensa da liberdade de expressão em favor da segurança nacional somente são admissíveis se o grau de importância relativa da segurança nacional for muito alto. No entanto, eles podem ter diferentes opiniões sobre o momento em que o grau de importância relativa da segurança nacional passa a ser muito alto, o que é expressado pelas diferentes curvas de indiferença de primeiro nível.

Curvas de indiferença fazem com que fiquem claras as idéias que estão por trás da lei do sopesamento. Mas elas não oferecem um procedimento decisório definitivo.²²² As curvas de primeiro nível repre-

222. Aqui interessam apenas sopesamentos no sentido de atribuições de pesos a princípios, ou seja, interessa apenas aquilo que é exigido pela máxima da proporcionalidade em sentido estrito. Como já foi mencionado acima, é necessário distinguir entre a quantificação dos princípios – que se relaciona às possibilidades jurídicas de sua realização – e a questão da necessidade das afetações à sua satisfação – que se relaciona às possibilidades fáticas de sua realização. No âmbito de um enfoque indiferencialista, a estrutura do exame da necessidade pode ser representada com o auxílio do critério de eficiência de Pareto. De acordo com esse critério, uma constelação A é preferível a uma constelação B “se, com a passagem de B para A , nenhum dos envolvidos tem sua situação piorada em relação à situação anterior e ao menos um dos envolvidos tem sua situação melhorada” (Werner Kirsch, *Einführung in die Theorie der Entscheidungsprozesse*, v. 3, p. 77). A conexão entre esse critério e a

sentam apenas diferentes sopesamentos. De acordo com a lei do sopesamento — que corresponde à curva de indiferença de segundo nível —, a decisão acerca da correção desses sopesamentos deve ser tomada com base nos graus de importância da satisfação de um princípio e de satisfação/não-satisfação (não-afetação/afetação) do outro. Mas esses conceitos são infensos a uma metrificação que possa levar a um cálculo de resultados intersubjetivamente inequívoco.

A lei do sopesamento não é, contudo, despida de importância. Ela diz o que é importante no sopesamento: de um lado, o grau ou a intensidade da não-satisfação ou da afetação de um princípio e, de outro lado, o grau de importância da satisfação do outro princípio. Aquele que afirma que uma afetação muito intensa só pode ser justificada por meio de um grau muito alto de importância da satisfação do princípio colidente ainda não diz quando essa afetação muito intensa e quando esse alto grau de importância estão presentes. Mas ele diz o que deve ser fundamentado para se justificar o enunciado de preferência que representa o resultado do sopesamento: enunciados sobre graus de afetação e de importância. Os argumentos que podem ser utilizados na fundamentação desse tipo de enunciados não são relacionados especificamente ao sopesamento. É possível levar em consideração qualquer argumento típico da argumentação jurídica. A decisão no caso *Lebach* oferece um exemplo de uma fundamentação de enunciados sobre graus de afetação e de importância. A tese de que a emissão televisiva representava uma afetação demasiadamente intensa²²³ na proteção da personalidade é fundamentada, por exemplo, fazendo-se menção ao

máxima da necessidade é clara. Para uma reconstrução do exame da necessidade com o auxílio da eficiência de Pareto, cf. Bernhard Schlink, *Abwägung im Verfassungsrecht*, pp. 181 e ss.

223. Como exemplo de fundamentação de um enunciado sobre um *menor* grau de intensidade de uma afetação pode ser utilizada a decisão no caso sobre co-gestão. No âmbito do exame do direito fundamental à liberdade profissional das sociedades de empresas afetadas pela lei de co-gestão, a decisão afirma: “A influência que a participação dos trabalhadores no Conselho Fiscal tem na direção da empresa não é, em princípio, determinante; ao contrário, a competência para a decisão final cabe aos membros do Conselho Fiscal indicados pelos acionistas da sociedade como seus representantes. Mesmo nos casos em que decisões do órgão de representação dependam de decisão do Conselho Fiscal, estas continuam a ser decisões que, em princípio, podem ser consideradas como decisões dos membros da sociedade. Por conseguinte, trata-se de uma restrição de *menor intensidade*” (*BVerfGE* 50, 290 (365) — sem grifos no original).

alcance²²⁴ das emissões de televisão, aos efeitos do formato documentário,²²⁵ ao alto grau de credibilidade que os programas de TV têm junto ao público,²²⁶ à ameaça à ressocialização do autor, decorrente dessa credibilidade²²⁷ e de outras características do documentário, e ao prejuízo adicional que implica a transmissão de um documentário depois da perda da atualidade da informação.²²⁸ No que diz respeito à importância da realização do princípio da liberdade de radiodifusão, são aduzidas, em primeiro lugar, diversas razões para a importância da transmissão de notícias atuais sobre crimes graves. A partir dessa constatação, a repetição de uma notícia é qualificada como não suficientemente importante para justificar a intensidade da afetação.²²⁹

As razões utilizadas pelo tribunal são plausíveis. Mesmo sem uma análise mais detida, pode-se perceber que dentre essas razões se encontram coisas muito diversas, como a referência a fatos (alcance das emissões de televisão), a regularidades empíricas (causar risco à ressocialização) e juízos normativos (caracterização da ressocialização como urgentemente exigida pelo art. 1º, § 1º, combinado com o art. 2º, § 1º, da Constituição alemã). Um tal conjunto de razões – que inclui valorações – é algo característico da fundamentação jurídica. E é, além disso, necessário quando se trata de estabelecer definições no âmbito de conceitos vagos, ou seja, no âmbito da interpretação clássica. Por isso, o simples argumento de que os valores desempenham um papel no sopesamento não constitui uma objeção à possibilidade de fundamentação racional das decisões ponderativas, a não ser que se diga que a argumentação jurídica se torna sempre não-racional ou irracional tão logo se adentre o âmbito das valorações não definidas de forma cogente. Uma tal concepção não apenas teria como consequência a necessidade de qualificar como não-racional ou irracional muito daquilo que a Ciência do Direito, desde sempre, encara como sua tarefa; é também possível aduzir boas razões contra a tese a ela subjacente, segundo a qual juízos de valor e de obrigação

224. BVerfGE 35, 202 (227).

225. BVerfGE 35, 202 (228).

226. BVerfGE 35, 202 (229).

227. BVerfGE 35, 202 (236-237).

228. BVerfGE 35, 202 (234).

229. BVerfGE 35, 202 (234).

não são fundamentáveis.²³⁰ O argumento contra a racionalidade dos sopesamentos não poderia, assim, basear-se simplesmente no fato de que valorações não definidas de forma cogente desempenham algum papel; ele teria que se referir à extensão desse papel. Neste ponto, é preciso salientar, em primeiro lugar, que há inúmeros sopesamentos que, no que diz respeito às valorações envolvidas, suscitam menos dificuldades que a interpretação clássica e, em segundo lugar, que esse argumento é, quando muito, adequado para demonstrar que sopesamentos têm um grau de racionalidade menor que interpretações. Mas ele não tem a força necessária para demonstrar a irracionalidade ou não-racionalidade dos sopesamentos.

O modelo fundamentado apresentado aqui evita uma série de dificuldades que estão freqüentemente associadas ao conceito de sopesamento. Ele faz com que fique claro que o sopesamento não é um procedimento por meio do qual um interesse é realizado às custas de outro "de forma precipitada".²³¹ De acordo com esse modelo, o sopesamento é tudo, menos um procedimento abstrato ou generalizante. Seu resultado é um enunciado de preferências condicionadas, ao qual, de acordo com a lei de colisão, corresponde uma regra de decisão diferenciada. Do próprio conceito de princípio decorre a constatação de que os sopesamentos não são uma questão de tudo-ou-nada, mas uma tarefa de otimização. Nesse sentido, o modelo de sopesamento aqui defendido é equivalente ao assim chamado *princípio da concordância prática*.²³² Também não é procedente a objeção segundo a qual não haveria um parâmetro com base no qual o sopesamento pudesse ser decidido²³³ e que, por isso, a máxima do sopesamento de interesses seria uma "fórmula vazia".²³⁴ Ainda que o *sopesamento em si* não estabeleça um parâmetro com o auxílio do qual os casos possam ser decididos de forma definitiva, o *modelo de sopesamento como um todo* oferece um critério, ao associar a lei de colisão à teoria da argu-

230. Cf., sobre isso, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 53 e ss.

231. Cf. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 72.

232. Idem.

233. Christian v. Pestalozza, "Kritische Bemerkungen zu Methoden und Prinzipien der Grundrechtsauslegung in der Bundesrepublik Deutschland", *Der Staat* 2 (1963), p. 447.

234. Idem, p. 448.

mentação jurídica racional. A lei de colisão diz o que deve ser fundamentado de forma racional. Nesse sentido, não se pode dizer que ela nada diz e que é, portanto, uma fórmula vazia. A recorrente objeção do irracionalismo já foi refutada.²³⁵ Já a tese segundo a qual os sopesamentos conduziriam a “decisões particulares”²³⁶ é, no mínimo, equivocada. Na medida em que as decisões de sopesamentos são decisões judiciais, é claro que elas são proferidas, em geral, para a solução de casos particulares. Mas, com base nessas decisões e nos termos da lei do sopesamento, é sempre possível formular uma regra. Por conseguinte, nada há de inconciliável entre o sopesamento no caso particular e sua universalizabilidade. No modelo aqui defendido, ambos estão associados.²³⁷ Também não é procedente a objeção segundo a qual, no limite, o sopesamento nada mais é que uma palavra contra outra.²³⁸ Um princípio é contraposto a outro princípio, e a consequência é aquilo que é previsto na lei de colisão e de sopesamento.

O modelo de sopesamento aqui proposto não apenas evita os problemas mencionados, mas tem também vantagens, que são válidas também para modelos alternativos; e os problemas dessas alternativas não afetam o modelo aqui defendido. Isso é demonstrável a partir do conceito de análise do âmbito da norma, que Müller contrapõe ao sopesamento de interesses.²³⁹ Com esse conceito, Müller sublinha a importância de argumentos empíricos (dados reais) no âmbito da fundamentação constitucional. Ele clama, além disso, por uma dogmática diferenciada para o âmbito de cada direito fundamental.²⁴⁰ Esses dois postulados são satisfeitos pelo modelo de sopesamento aqui defendido. No âmbito da fundamentação dos enunciados sobre intensidades de afetação e sobre a importância da realização de princípios colidentes, tornam-se relevantes argumentos empíricos que digam respeito às peculiaridades do objeto da decisão, bem como às consequências das

235. Cf., por exemplo, Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 54.

236. Idem, p. 54.

237. Sobre a universalizabilidade como postulado fundamental da racionalidade prática, cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 91 e ss., 234 e ss. e 274. Sobre a elaboração de regras como postulado jurídico-constitucional, cf. *BVerfGE* 66, 116 (138).

238. Cf. Friedrich Müller, *Normstruktur und Normativität*, Berlin: Duncker & Humblot, 1966, p. 209.

239. Cf. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, pp. 49 e 117 e ss.

240. Cf. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 87.

possíveis decisões. Em relação aos argumentos empíricos, vale também para a fundamentação de decisões de sopesamento tudo que é válido para a argumentação em geral.²⁴¹ E a lei de colisão demonstra que o sopesamento conduz a uma dogmática diferenciada dos diferentes direitos fundamentais: nos casos de colisão é necessário definir uma relação condicionada de preferência. A ela corresponde uma regra de grau de concretude relativamente alto. Por meio dos sopesamentos da jurisprudência e de propostas de sopesamento aceitas pela Ciência do Direito, surge, com o passar do tempo, uma rede de regras concretas atribuídas às diferentes disposições de direitos fundamentais, as quais representam uma importante base e um objeto central da dogmática.

Portantó, o modelo de sopesamento apresentado possibilita, de um lado, a satisfação das justificadas exigências de consideração das relações fáticas e das regularidades empíricas e de uma detalhada dogmática dos direitos fundamentais específicos; de outro lado, ele evita as dificuldades em torno da idéia de análise do âmbito da norma. Essas dificuldades decorrem do *status* ambivalente dos elementos do âmbito da norma na teoria de Müller. Como já se sublinhou anteriormente,²⁴² esses elementos podem se referir ou somente a argumentos empíricos ou a argumentos empíricos associados a argumentos valorativos. Se se tratar apenas de argumentos empíricos, então, a análise do âmbito da norma não é suficiente para fornecer respostas às questões de direitos fundamentais. Questões de direitos fundamentais são questões normativas, e de enunciados empíricos não decorrem diretamente enunciados normativos. Se se tratar de uma mistura de elementos normativos e valorativos, então, surge a questão acerca da procedência dos elementos valorativos e, de sua controlabilidade. Essa questão fica ainda mais premente na medida em que o próprio Müller sublinha que uma “Ciência do Direito sem decisão e sem valoração (...) não [seria] nem prática nem real”.²⁴³ Ainda que as formulações de Müller – nas quais ele iguala a “estrutura do âmbito da norma” à “natureza do âmbito da vida regulado”²⁴⁴ – possibilitem reconhecer uma certa afimidade de sua concepção de análise do âmbito da norma com a teoria da na-

241. Cf., sobre isso, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 285 e ss.

242. Cf. Capítulo 2, II.3.

243. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 134.

244. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, p. 40.

tureza das coisas,²⁴⁵ mesmo assim elas não fornecem uma resposta suficiente para o problema da valoração. Uma tal resposta pode ser fornecida pelo modelo de sopesamento baseado na teoria dos princípios, na medida em que ele vincula a estrutura formal do sopesamento a uma teoria da argumentação jurídica que inclui uma teoria da argumentação prática geral.²⁴⁶

2.3 *Objecções dogmáticas*

As objeções dogmáticas são mais fáceis de refutar que as objeções metodológicas. Uma primeira objeção sustenta que uma teoria valorativa dos direitos fundamentais conduziria a uma destruição da liberdade constitucional em sentido liberal. A “liberdade ligada à subjetividade [seria] substituída pela objetividade dos valores”;²⁴⁷ ocorreria um alinhamento substancial da liberdade constitucional,²⁴⁸ uma “vinculação” aos valores.²⁴⁹ Essa interpretação seria procedente so-

245. Cf. também Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 28 (nota 59), no qual se fala do “cunho substancial do âmbito da norma de direito fundamental” como uma “versão especial da ‘natureza das coisas’”. A afinidade entre os conceitos de âmbito da norma e de natureza das coisas é salientada por Larenz (cf. Karl Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 4ª ed., Berlin: Springer, 1979, p. 323). A esse respeito, cf. também Hans Ryffel, “Rezension von Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung*, Berlin, 1967 und Friedrich Müller, *Normstruktur und Normativität*, Berlin, 1966”, *DVBl* 86 (1971), p. 84. O próprio Müller rejeita a equiparação entre sua teoria e concepções tradicionais da natureza das coisas (cf. Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, pp. 34-35 e 86; do mesmo autor, “Theses zur Struktur von Rechtsnormen”, *ARSP* 61 (1970), p. 498). A despeito dessa rejeição, sua tentativa de substituir “coisas” pelo âmbito da norma e “natureza” pela sua “estrutura básica seletivamente requerida pelo aspecto do programa da norma” (idem, *Juristische Methodik*, p. 88) está sujeita às mesmas objeções feitas a teorias sobre a natureza das coisas, visto que tão-somente das normas de direitos fundamentais estabelecidas diretamente (programa da norma) e dos enunciados empíricos sobre aquilo que deve ser regulado pelas normas de direitos fundamentais não decorre um juízo concreto de dever-ser em todos os casos duvidosos envolvendo direitos fundamentais. Para uma análise e crítica das teorias sobre a natureza das coisas, cf. Ralf Dreier, *Zum Begriff der “Natur der Sache”*, Berlin: Duncker & Humblot, 1965.

246. Cf., sobre isso, Capítulo 10, III.3.

247. Ernst Forsthoff, “Zur heutigen Situation einer Verfassungslehre”, p. 190.

248. Ernst-Wfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, p. 1.533.

249. Helmut Goerlich, *Wertordnung und Grundgesetz*, p. 37.

mente se liberdade e valor fossem coisas antagônicas. Mas não são. A liberdade jurídica – é somente disso que aqui se trata – é, na verdade, um valor dentre outros. Como ainda será exposto com maiores detalhes adiante,²⁵⁰ a liberdade jurídica consiste na faculdade jurídica de fazer e deixar de fazer o que se deseja. Ela é restringida por toda norma proibitiva ou mandatória. Quanto mais se ordena ou se proíbe, tanto menor é a liberdade jurídica. O princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível. Sua realização máxima é uma situação na qual nada é juridicamente proibido ou ordenado, ou seja, na qual tudo é juridicamente permitido. Que uma tal situação não é desejável é algo sobre o qual é fácil obter um consenso. A polêmica surge quando se trata de definir o que e quanto se deve ordenar e proibir. Essa é uma polêmica acerca do grau ótimo de realização do princípio da liberdade jurídica em face de princípios colidentes. A esses princípios podem ser conferidos pesos diferentes, em uma escala que se estende desde teorias liberais radicais, que conferem a esses princípios colidentes um peso maior que ao princípio da liberdade jurídica apenas em poucos – e extremos – casos, até teorias radicalmente não-liberais, que chegam a uma quantificação inversa e têm à disposição, para quase toda alternativa de ação, um dever jurídico ou uma proibição jurídica. Isso põe às claras o fato de que, enquanto tal, a teoria dos princípios ou dos valores relaciona-se de forma neutra com a liberdade jurídica. Embora a atribuição de um peso reduzido ao princípio da liberdade jurídica possa ter como consequência sua superação, uma atribuição inversa pode, da mesma forma, levar a um excesso de liberdade jurídica.

Mas, com isso, as objeções dogmáticas contra uma teoria dos princípios no âmbito dos direitos fundamentais não foram de todo refutadas. Mesmo aquele que aceita que a objeção liberal pode ser afastada pode se apegar a uma objeção baseada na idéia de Estado de Direito. A interpretação das normas de direitos fundamentais como princípios cria a possibilidade de que os mais distintos resultados de sopesamentos sejam considerados como constitucionalmente obrigatórios. Seria possível acompanhar Forsthoff e afirmar que, “dessa maneira, (...) os direitos fundamentais estariam à mercê de possibilidades manipuladoras de sobrevalorização, subvalorização e revalori-

250. Cf. Capítulo 4, II.2.2.

zação, transformando, assim, a decisão fundamental do constituinte em uma outorga de plenos poderes ao intérprete da Constituição. O resultado é a insegurança constitucional (...).²⁵¹ Essa objeção associa dois aspectos. O primeiro sustenta que uma teoria dos princípios não leva a sério a vinculação à Constituição; o segundo, que uma tal teoria conduziria a um arbítrio interpretativo e, com isso, a uma insegurança constitucional.

A objeção relacionada à vinculação à Constituição somente atingiria a teoria aqui defendida se o modelo puro de regras garantisse um maior grau de vinculação que um modelo de regras e princípios. Mas o modelo puro de regras mostrou-se inadequado. Ficou claro que esse modelo, nos casos de direitos fundamentais garantidos com reserva simples, teria como consequência desde uma grande dificuldade na definição dos limites do conteúdo essencial até um esvaziamento desses direitos e, com isso, uma total ausência de vinculação à Constituição. A complementação do nível das regras com um nível dos princípios é necessária exatamente para garantir a vinculação à Constituição. A referência de Forsthoff a um necessário respeito à “decisão fundamental do constituinte” dá a impressão de que ele não se dirige tanto contra uma teoria dos princípios enquanto tal, mas contra a possibilidade de teorias dos princípios com alguns conteúdos específicos. Uma decisão fundamental de um legislador constituinte não pode ser outra coisa senão a decisão por um ou por alguns determinados princípios. Mas, se isso é assim, então, a objeção relacionada à vinculação à Constituição perde seu caráter de objeção contra a teoria dos princípios como teoria estrutural. Ela se converte em uma objeção a determinadas atribuições de pesos aos princípios e, com isso, em um apelo em favor de uma determinada teoria material dos direitos fundamentais, diante da qual a teoria dos princípios, enquanto teoria estrutural, se comporta de forma neutra.

Permanece a objeção ligada à segurança jurídica. Também aqui é necessário fazer referência à carência de alternativas aceitáveis, que poderiam garantir uma maior medida de segurança jurídica que o modelo de regras e princípios. Mas isso é apenas a primeira faceta da questão. A outra diz respeito ao fato de que, embora o caráter principiológico dos direitos fundamentais implique uma freqüente presença

251. Ernst Forsthoff, “Zur heutigen Situation einer Verfassungslehre”, p. 190.

de conteúdos excedentes, isso é compatível com um grau suficiente de segurança jurídica. O modelo de regras e princípios não tem apenas o nível dos princípios, mas também o nível das regras.²⁵² Mais adiante será demonstrado²⁵³ que a segurança jurídica que pode ser criada no nível das regras tem como base não somente a exigência elementar de respeito ao teor literal do texto constitucional e à vontade do legislador constituinte, mas sobretudo também a força dos precedentes do Tribunal Constitucional Federal.

252. Isso significa que no modelo de regras e princípios a dedução não é suplantada pelo sopesamento. Ao contrário, nesse modelo ambos são associados. Sobre duas formas para essa associação, cf., de um lado, Robert Alexy, "Die logische Analyse juristischer Entscheidungen", pp. 195 e ss., e, de outro, Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, pp. 97 e ss.

253. Cf. Capítulo 10, III.3.2.2.

DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO DIREITOS SUBJETIVOS

I – SOBRE A DISCUSSÃO ACERCA DOS DIREITOS SUBJETIVOS

A despeito de sua considerável longevidade e de intensos e amplos esforços,¹ a discussão sobre o conceito de direito subjetivo não caminhou na direção de um consenso. Uma importante razão para tanto pode ser vista já em Kelsen, que censurava a “carência de questionamento concreto e preciso”: “Ninguém se deu conta do que o conceito de direito subjetivo deve proporcionar ao jurista; não há clareza suficiente sobre a que questionamento ele deveria fornecer respostas”.² Também na atual discussão são suscitadas questões as mais diversas em conexão com o conceito de direito subjetivo. É possível diferenciar três tipos de questões: normativas, empíricas e analíticas.

1. Direitos subjetivos e questões normativas

Dentro do grupo das questões normativas é possível distinguir entre questões ético-filosóficas e jurídico-dogmáticas e suas respectivas respostas.

1. Kelsen constatava, em 1911: “Certamente não é um exagero afirmar que, de todos os conceitos jurídicos fundamentais, o mais discutido na literatura teórica é exatamente o conceito de direito subjetivo” (Hans Kelsen, *Hauptprobleme der Staatslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, Tübingen: Mohr, p. 568). Embora essa constatação não seja mais procedente no que diz respeito à literatura contemporânea, o conceito de direito subjetivo não está longe do topo. Como se perceberá pelo que se segue, ele ainda pertence ao grupo dos conceitos mais discutidos na literatura teórico-jurídica.

2. Hans Kelsen, *Hauptprobleme der Staatslehre*, p. 618.

Trata-se de uma questão *ético-filosófica* quando se pergunta, independentemente da validade de um ordenamento jurídico positivo, por que os indivíduos têm direitos e que direitos eles têm. Uma resposta clássica a essa questão é a de Kant, segundo a qual “a liberdade (independência de ser coagido pelo arbítrio de outrem), desde que possa existir em conjunto com a liberdade dos outros com base em uma lei geral”, é o direito “único, original e conferido a todos”, e isso “por força de sua humanidade”,³ o que, segundo Kant, é caracterizado pelo atributo do ser humano como ser racional.⁴ Um outro exemplo de resposta àquela questão é oferecido por Larenz: “Nós entendemos que a relação jurídica fundamental é o direito de alguém a ser respeitado por todos como pessoa e, ao mesmo tempo, o seu dever, em relação aos outros, de respeitá-los como pessoas (...). Nessa relação, o ‘direito’ de uma pessoa é aquilo que lhe cabe ou lhe é devido enquanto pessoa, e aquilo que os outros são obrigados ou vinculados a lhe garantir ou a respeitar”.⁵

Acima se demonstrou que a dogmática dos direitos fundamentais, tanto quanto a dogmática jurídica em geral, é uma disciplina tridimensional e que uma de suas dimensões diz respeito a questões normativas.⁶ Por isso, o objeto da questão ético-filosófica pode desempenhar um papel também no âmbito da dogmática dos direitos fundamentais. A diferença entre questões ético-filosóficas e jurídico-dogmáticas está no fato de que estas últimas dizem respeito àquilo que é válido no sistema jurídico, enquanto as primeiras podem ser suscitadas independentemente desse sistema.

Portanto, quando se indaga se, em um determinado sistema jurídico, um sujeito de direito tem determinado direito subjetivo, está-se diante de uma questão *jurídico-dogmática*. Neste ponto interessam apenas duas situações nas quais essa questão pode ser suscitada. Na primeira situação não há dúvida de que uma norma *N*, caso seja aplicável ao caso de *a*, confere a este um direito subjetivo; mas é duvidoso se ela é realmente aplicável ao caso de *a*, o que significa que é

3. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, p. 237.

4. Immanuel Kant, “Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”, in *Kants gesammelte Schriften (Akademie-Ausgabe)*, v. IV, Berlin: Reimer, 1903/1911, pp. 446 e ss.

5. Karl Larenz, *Allgemeiner Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, München: Beck, 1967, p. 60.

6. Cf. Capítulo 1, I.2.

duvidoso se, diante das condições presentes, ela confere a *a* um direito subjetivo. Responder a esta questão envolve um problema corriqueiro de interpretação. Os problemas que afetam o conceito de direito subjetivo não têm, aqui, nenhuma importância. A segunda situação é, ao contrário, caracterizada pelo fato de que não há nenhuma dúvida de que *N* é aplicável ao caso de *a*, mas é duvidoso se *N* garante algum direito subjetivo. O caso clássico sobre essa questão é o caso da proteção aduaneira, utilizado por Jhering: "a lei que, no interesse de alguns ramos industriais, introduz proteções aduaneiras *beneficia* os fabricantes e os *promove e protege* em sua atividade negocial, mas, apesar disso, não confere a eles nenhum direito (...). O que existe aqui é um simples *efeito reflexo*, uma relação que tem enorme semelhança com o direito e que, contudo, deve ser com ainda mais cuidado dele apartada".⁷

Saber quando uma norma jurídica confere direitos subjetivos é uma questão que tem importância prática sobretudo sob o aspecto processual. Assim é que, de acordo com os §§ 42, 2, e 113, 1, da Lei sobre os Tribunais Administrativos, a alegação e a demonstração de uma violação de um direito subjetivo do demandante são condição de admissibilidade e de êxito de uma demanda.⁸ Aqui interessa apenas a constatação de que saber se uma norma confere ou não um direito subjetivo é um problema normativo. Esse problema surge quando o texto normativo deixa essa questão em aberto, como ocorre, por exemplo, quando o teor literal do texto determina que a norma *N* obriga o Estado a realizar a ação *h*, mas não define se *a* tem um direito à realização dessa ação estatal. Para demonstrar que *a* tem um tal direito são necessárias premissas adicionais, que podem ser, na esteira

7. Rudolf v. Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Parte 3, 5ª ed., Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1906, p. 351. Sobre esse caso, cf. Otto Bachof, "Reflexwirkungen und subjektive Rechte im öffentlichen Recht", in Otto Bachof et al. (Orgs.), *Gedächtnisschrift für Walter Jellinek*, München: Isar, 1955, p. 288; H. L. A. Hart, "Bentham on legal rights", in A. W. B. Simpson (ed.), *Oxford Essays in Jurisprudence*, Second Series, Oxford: Oxford University Press, 1973, p. 189.

8. Sobre a discussão acerca do direito subjetivo no direito administrativo, cf., por exemplo, Otto Bachoff, "Reflexwirkungen und subjektive Rechte im öffentlichen Recht", pp. 287 e ss.; Hans H. Rupp, *Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre*, Tübingen: Mohr, 1965, pp. 246 e ss.; Wilhelm Henke, *Das subjektive öffentliche Recht*, Tübingen: Mohr, 1968; Manfred Zuleeg, "Hat das subjektive öffentliche Recht noch eine Daseinsberechtigung?", *DVBZ* 91 (1976), pp. 510 e ss.

da teoria das normas de proteção do Tribunal Administrativo Federal, aquelas da interpretação teleológica.⁹ Mas, com isso, adentra-se um campo no qual deduções a partir do material normativo preexistente não são mais suficientes, no qual passam a ser necessárias valorações independentes.¹⁰ É necessário fundamentar enunciados normativos que vão além do já estabelecido.

2. *Direitos subjetivos e questões empíricas*

O conceito de questão empírica abarca coisas as mais diversas. Isso vale também para as questões empíricas que dizem respeito aos direitos subjetivos. Nesse sentido, é possível distinguir entre proposições sobre o surgimento de direitos subjetivos,¹¹ sobre a história do conceito de direito subjetivo¹² e sobre a função social dos direitos subjetivos,¹³ como, por exemplo, sobre sua “função específica para a organização e a legitimação das relações de dominação”.¹⁴

Depois do que se disse anteriormente acerca da tridimensionalidade da Ciência do Direito,¹⁵ não é preciso gastar muitas palavras acerca da importância de questões empíricas para uma teoria jurídica dos direitos subjetivos. Ela é especialmente perceptível no âmbito dos argumentos históricos e teleológicos. Nesse sentido, a criação de determinado direito subjetivo *R*, no momento *t*₁, para evitar a situação *Z*, considerada como negativa, e o fato de *R* ter evitado, com sucesso, essa situação são fortes argumentos para a manutenção de *R*, desde que *R* continue a ser, no momento *t*₂, adequado para evitar *Z* e que *Z*

9. Cf., por exemplo, *BVerwGE*, 1, 83; 27, 29 (32); 28, 268 (270); 32, 173 (175); 41, 58 (63); 52, 122 (128). Cf., além disso, *BVerfGE* 27, 297 (307).

10. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 295 e ss.

11. Cf. Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, 5ª ed., Tübingen: Mohr, 1980, pp. 397 e ss.

12. Cf. Helmut Coing, “Zur Geschichte des Begriffs ‘subjektives Recht’”, in Helmut Coing, *Zur Geschichte des Privatrechtsystems*, Frankfurt am Main: Klostermann, 1962, pp. 29 e ss.

13. Cf. Niklas Luhmann, “Zur Funktion der ‘subjektiven Rechte’”, *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie* 1 (1970), pp. 321 e ss.; Jan Schapp, *Das subjektive Recht im Prozeß der Rechtsgewinnung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1977, p. 14.

14. Ulrich K. Preuß, *Die Internalisierung des Subjekts*, p. 30.

15. Cf. Capítulo 1, I.2.

continue a ser avaliado como algo negativo.¹⁶ Em sentido semelhante, o fato de que um determinado direito subjetivo *R*, a partir da interpretação *I*, ou leva à consequência fática *K* ou tem a função social *F*, é um forte argumento para interpretar *R* no sentido de *I*, desde que *K* e *F* sejam avaliadas como algo positivo. Essa série de exemplos poderia ir adiante. Neles sempre se verá que *tão-somente* a partir de enunciados empíricos sobre a história, as consequências sociais ou as funções dos direitos subjetivos nada é possível inferir para a problemática jurídico-dogmática. Para esse fim, é necessário associá-los a enunciados normativos.

3. Direitos subjetivos e questões analíticas

3.1 Norma e posição

Em uma teoria estrutural dos direitos fundamentais o que importa são sobretudo questões analíticas. Para o tratamento analítico dos direitos subjetivos, a diferenciação entre *norma* e *posição* é de importância basilar.¹⁷ Uma norma é aquilo que um enunciado normativo expressa.¹⁸ O enunciado:

- (1) "Todos têm o direito de expressar livremente (...) a sua opinião (...)" (art. 5º, § 1º, 1, da Constituição alemã)

expressa uma norma universal.¹⁹ Como não pode haver dúvida de que ela garante um direito em face do Estado, é possível, com base nela, formular a seguinte norma individual:

- (2) *a* tem, em face do Estado, o direito de expressar livremente a sua opinião.

Se esse enunciado é correto, ou seja, se a norma individual expressa por meio de (2) é válida, então, *a* encontra-se, em face do Es-

16. Sobre esse tipo de argumento histórico, cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, p. 294.

17. Sobre a utilização do termo "posição" pelo Tribunal Constitucional Federal, cf. *BVerfGE* 45, 63 (76); 53, 30 (58).

18. Cf. Capítulo 2, I.2.

19. Sobre esse conceito, cf. Capítulo 3, I.1, nota de rodapé 11.

tado, em uma posição que consiste exatamente no direito que *a* tem, em face do Estado, de expressar livremente sua opinião. Essa posição pode ser expressa pelo mesmo enunciado por meio do qual a norma individual foi expressa. Se a *norma* individual, segundo a qual *a* tem, em face de *b*, um direito a *G*, é válida, então, *a* encontra-se em uma posição jurídica caracterizada pelo direito a *G* que ele tem em face de *b*; e se uma *posição* jurídica de *a* consiste no fato de *a* ter, em face de *b*, um direito a *G*, então, é válida a norma individual segundo a qual *a* tem, em face de *b*, um direito a *G*. É possível se perguntar, diante disso, que sentido tem falar em posições. Parece ser supérfluo.

A resposta é que falar em posições é necessário a partir de um determinado ponto de vista: a partir da perspectiva que se interessa pelas *características normativas* de pessoas e ações e pelas *relações normativas* entre pessoas ou entre pessoas e ações. Normas podem ser consideradas, de forma bastante geral, como qualificações de pessoas ou ações. Nesse sentido, pode-se dizer que uma norma que proíbe *a* de fazer *h* confere a *a* a característica jurídica de ser alguém ao qual é proibido fazer *h*. Essa característica de *a*, que pode ser expressa por meio do predicado monádico complexo "alguém ao qual é proibido fazer *h*", é uma posição, na qual *a* é colocado por meio da norma. Se houvesse apenas posições desse tipo, com certeza não valeria a pena falar de posições. O interesse surge apenas quando não se trata mais de características, mas de relações, que podem ser expressas por predicados diádicos como "... tem um direito a *G* em face de ..." ou por predicados triádicos como "... tem em face de ... um direito a ...". A seguir será demonstrado que é aconselhável conceber os direitos subjetivos como posições e relações desse tipo.

3.2 Um modelo de direitos subjetivos em três níveis

Se direitos subjetivos são compreendidos como posições e relações jurídicas no sentido apresentado acima, então, é possível distinguir entre (a) razões para direitos subjetivos, (b) direitos subjetivos como posições e relações jurídicas e (c) a exigibilidade jurídica dos direitos subjetivos. A insuficiente distinção entre essas três questões é uma das principais causas da interminável polêmica acerca do conceito

de direito subjetivo, sobretudo aquela travada entre as diferentes variantes das teorias do interesse e da vontade.²⁰

Os pólos em redor dos quais gira a polémica sobre os direitos subjetivos foram caracterizados com insuperável concisão por Jhering: "Dois são os momentos que constituem o conceito de direito: um *substancial*, no qual reside a finalidade prática do próprio direito, a saber, a utilidade, a vantagem, o lucro, a qual deve ser garantida pelo direito; e um *formal*, o qual se relaciona com aquela finalidade apenas como meio, a saber, a *proteção* jurídica, a *ação judicial*".²¹ Enquanto

20. Essas teorias encontram sua formulação clássica em Windscheid e Jhering. Segundo Windscheid, o direito subjetivo é "um poder ou um domínio da vontade, outorgado pelo ordenamento jurídico" (Bernhard Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, p. 156); segundo Jhering, direitos subjetivos são "interesses juridicamente protegidos" (Rudolf v. Jhering, *Geist des römischen Rechts*, Parte 3, p. 339). A discussão sobre essas teorias conduziu a inúmeras teorias combinadas (cf., sobre isso, Ludwig Enneccerus/Hans C. Nipperdey, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, 15ª ed., t. 1, Tübingen: Mohr, 1959, pp. 428-429: "Conceitualmente, o direito subjetivo é um poder jurídico, conferido ao indivíduo pelo ordenamento jurídico, cuja finalidade é ser um meio para a satisfação de interesses humanos"; e Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, 2ª ed., Tübingen: Mohr, 1905, p. 44: "O direito subjetivo é, portanto, um poder da vontade humana, reconhecido e protegido pelo ordenamento jurídico e dirigido a um bem ou interesse"). Sobre a polémica acerca dessas posições, cf., por todos, Hans Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, pp. 572 e ss.; Otto Bachoff, "Reflexwirkungen und subjektive Rechte im öffentlichen Recht", pp. 291 e ss.; Ludwig Raiser, "Der Stand der Lehre vom subjektiven Recht im Deutschen Zivilrecht", *JZ* 16 (1961), p. 465; Franz Kasper, *Das subjektive Recht - Begriffsbildung und Bedeutungsmehrheit*, Karlsruhe: Müller, 1967, pp. 49 e ss.; Josef Aicher, *Das Eigentum als subjektives Recht*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, pp. 24 e ss.

No mundo anglo-saxão a controvérsia entre Jhering e Windscheid encontra seu contraponto nas posições de Bentham (teoria do interesse) e Austin (teoria da vontade). Cf., de um lado, Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (ed. J. H. Burns/H. L. A. Hart), London: Athlone, 1970, p. 206 (cf., a respeito, H. L. A. Hart, "Bentham on legal rights", p. 177) e, de outro lado, John Austin, *Lectures on Jurisprudence*, 4ª ed., v. 1, London: Murray, 1873, p. 410. Recentemente a polémica entre as teorias da vontade e do interesse voltou a se inflamar. Do lado da teoria da vontade está Hart (H. L. A. Hart, "Bentham on legal rights", pp. 183 e ss.); do lado da teoria do interesse estão MacCormick e Lyons (Neil MacCormick, "Rights in legislation", in Peter M. S. Hacker/Joseph Raz (eds.), *Law, Morality and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart*, Oxford: Clarendon, 1977, pp. 189 e ss.; David Lyons, "Rights, claimants and beneficiaries", *American Philosophical Quarterly* 6 (1969), pp. 173 e ss.).

21. Rudolf v. Jhering, *Geist des römischen Rechts*, Parte 3, p. 339.

para Jhering a finalidade está no centro, a teoria da vontade vê como central o controle do titular do direito – expresso entre outras coisas pela capacidade de demandar – sobre a posição a ele outorgada por uma norma. Ele pode, mas não tem que demandar; o que ele faz depende de sua livre escolha, de sua vontade.²²

Enunciados sobre a finalidade de direitos, da mesma forma que enunciados sobre finalidades de normas em geral, são enunciados sobre razões para direitos ou normas. Portanto, no âmbito da teoria de Jhering é necessário distinguir entre duas espécies de enunciados: enunciados sobre razões para direitos e enunciados sobre a proteção ou a exigibilidade de direitos. Um típico enunciado sobre razões é o enunciado “os direitos existem (...) para servir aos interesses, necessidades e finalidades do comércio”.²³ A esses enunciados gerais sobre razões correspondem *enunciados concretos sobre razões*, como:

- (1) *G* é uma “necessidade imperiosamente ligada à natureza animal do ser humano”.²⁴

Que podem ser utilizados como argumento a favor da tese de que *a* tem um direito a *G*.²⁵ Um *enunciado sobre a proteção* é:

- (2) *a* pode alegar a violação de seu direito a *G* por meio de uma demanda judicial.

Nem enunciados sobre razões (1) nem enunciados sobre a proteção (2) são, por si mesmos, iguais em sentido a *enunciados sobre direitos*, como:

- (3) *a* tem um direito a *G*.

22. Cf., sobre isso, H. L. A. Hart, “Bentham on legal rights”, pp. 196 e ss. O aspecto da livre escolha pode se referir não apenas à demanda, isto é, à exigibilidade do direito, mas também à disposição sobre o direito. Cf., a esse respeito, Bernhard Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, v. 1, p. 156. Se esse aspecto é encarado como constitutivo para o direito subjetivo, surgem, então, consideráveis dificuldades nos casos de direitos inalienáveis. Cf., sobre isso, Neil MacCormick, “Rights in legislation”, pp. 195 e ss.

23. Rudolf v. Jhering, *Geist des römischen Rechts*, Parte 3, p. 338.

24. Idem, pp. 333-334.

25. Deixo em aberto, aqui, a questão acerca da correção desse argumento.

Com isso, suscita-se a questão acerca da relação entre esses enunciados. Essa questão expressa um dos problemas nucleares da teoria dos direitos subjetivos.

A relação entre enunciados sobre razões (1) e enunciados sobre direitos (3) é relativamente simples de ser definida. Trata-se de uma relação de fundamentação. A razão para um direito é *uma* coisa, outra é o direito que se baseia nessa razão. Ambas têm ser consideradas em uma análise abrangente que, como afirmado por Jhering, pretenda "alcançar o interior do direito, a sua essência".²⁶ Isso não impede, contudo, que em um primeiro momento se tenha a estrutura lógica do direito em si como objeto da análise; pelo contrário, isso é até mesmo exigível, pois a indagação acerca da razão para algo pressupõe o conhecimento daquilo que deve ser fundamentado.

Não tão simples é a relação entre enunciados sobre direitos, como "*a* tem um direito a *G*" (3), e enunciados sobre proteção, como "*a* pode alegar a violação de seu direito a *G* por meio de uma demanda judicial" (2). Os enunciados sobre proteção também expressam posições jurídicas, a saber, a capacidade jurídica (o poder jurídico, a competência)²⁷ para a exigibilidade de um direito. Essa posição também pode ser designada como "direito". Trata-se, portanto, de uma relação entre duas posições ou direitos. Os freqüentemente discutidos problemas dessa relação decorrem da grande plausibilidade da tese segundo a qual só é possível falar em um direito subjetivo se existir uma capacidade jurídica para exigí-lo. Autores como Kelsen definem o direito subjetivo em sentido técnico ou específico justamente por meio de uma tal capacidade: "o direito subjetivo em sentido específico é o poder jurídico de fazer valer a satisfação de um dever existente".²⁸ Para essa definição é suficiente o conceito de poder jurídico (capacidade jurídica, competência), em conjunto com o conceito de dever, a cuja satisfação ou exigência o poder jurídico se refere. Significa isso que seria supérfluo falar de uma posição que consiste no fato de *a* ter, em face de *b*, um direito a *G* e, com isso, seria supérflua também a utilização de enunciados como "*a* tem, em face de *b*, um direito a *G*"?

26. Rudolf v. Jhering, *Geist des römischen Rechts*, Parte 3, p. 328.

27. Sobre esses conceitos, cf. Capítulo 4, II, 3.

28. Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 269. Cf., ademais, na mesma obra, pp. 110-111 e, do mesmo autor, *Reine Rechtslehre*, pp. 139 e ss.

Esta pergunta deve ser respondida de forma negativa, por duas razões. A primeira razão baseia-se em uma consideração de conveniência. A utilização de enunciados sobre direitos é possível e conveniente mesmo quando se pressupõe que um direito subjetivo somente existe se existir uma capacidade jurídica para exigí-lo. Não se elimina a possibilidade de se utilizar enunciados como “*a* tem, em face de *b*, um direito a *G*”; apenas se limita a admissibilidade da utilização desses enunciados somente àqueles casos nos quais está presente a capacidade jurídica para a exigí-los. A conveniência da utilização desses enunciados fica clara pela constatação de que, se assim não fosse, casos simples teriam que ser expressos por meio de complicadas formulações sobre a capacidade jurídica para a exigibilidade e a violação de deveres. Mesmo se o conceito de direito subjetivo fosse definido nos termos de Kelsen, ainda assim seria justificado fazer boa parte da Ciência do Direito com o auxílio de enunciados sobre direitos. E a essa razão técnica deve ser ainda adicionada uma razão sistemática. Não parece ser imprescindível que se fale em direitos somente se estiver presente a capacidade jurídica para sua exigibilidade, por exemplo, por meio de uma demanda judicial. Embora seja possível definir o conceito de direito subjetivo dessa maneira, uma tal definição estipulativa não apenas não reflete o uso corrente da linguagem,²⁹ como também não seria frutífera para o conhecimento dos sistemas jurídicos. É possível perceber que ela não reflete o uso corrente da linguagem por meio de normas como a do art. 19, § 4º, da Constituição alemã, que abre a via judicial para todo aquele que tenha tido um direito violado pelos Poderes Públicos; uma tal norma seria supérflua diante de uma definição que já incluísse no conceito de direito subjetivo o poder para demandar judicialmente.³⁰ Normas como essa sugerem que direitos devem ser considerados como fundamentos da capacidade jurídica de sua exigibilidade, o que, de acordo com a relação de fundamentação entre enunciados sobre razões para direitos e enun-

29. Cf., sobre isso, Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, Gotha: Perthes, 1883, pp. 62-63.

30. Um problema semelhante suscita a inclusão da capacidade para demandar judicialmente no conceito de direito subjetivo no caso do § 42, 2, da Lei sobre os Tribunais Administrativos, segundo o qual a alegação de violação de um direito subjetivo é *condição* para a capacidade processual ativa (cf., neste ponto, Wilhelm Henke, *Das subjektive öffentliche Recht*, Tübingen: Mohr, 1968, pp. 2-3).

ciados sobre direitos, conduz a uma segunda relação de fundamentação entre enunciados sobre direitos e enunciados sobre sua proteção.³¹ Na base disso está um problema mais profundo, relacionado à estrutura do ordenamento jurídico. A um ordenamento jurídico pertence somente aquilo que é passível de ser exigido judicialmente, ou podem a ele pertencer também posições que não sejam exigíveis judicialmente, seja porque o papel que elas desempenham no ordenamento é incompatível com essa exigibilidade, seja porque essa exigibilidade não é reconhecida, mesmo que possa ser exigida a partir da perspectiva do ordenamento jurídico? Não é possível, neste ponto, responder a essa questão.³² Mas mesmo sem essa resposta é possível dizer que uma definição estipulativa não é uma resposta suficiente.³³

Se se combinam razão técnica e razão sistemática, então, tudo milita a favor de considerar o nível dos enunciados sobre direitos como o nível central para a dogmática jurídica.

3.3 A diversidade de direitos subjetivos

A mais importante contribuição analítica da discussão sobre direitos subjetivos consiste na análise e na classificação daquelas posições jurídicas que, leiga ou tecnicamente, são chamadas de "direitos". Nesse âmbito são possíveis distinções como aquela entre direitos patrimoniais absolutos e relativos, de um lado, e direitos formativos, de outro;³⁴ ou a distinção proposta por Jellinek entre direitos de *status*

31. Sobre essa última, cf. Neil MacCormick, "Rights in legislation", p. 204.

32. A resposta a essa pergunta depende de se saber se o conceito de norma jurídica válida implica que aquilo que por ela é ordenado pode ser exigido por meio de atos de coerção previstos no sistema jurídico. O fato de que isso seja verdadeiro para a maioria das normas válidas não justifica a conclusão de que isso decorre do conceito de norma jurídica válida. Também da necessária existência, em todo ordenamento jurídico, de normas garantidas por sanções estatais (H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, pp. 195 e 212) não resulta que todas as normas jurídicas, em todos os ordenamentos jurídicos, sejam assim garantidas.

33. Sobre a constatação de que da falta de exigibilidade não se pode concluir por uma não-existência de um direito, cf. Gerhard Leibholz, *Die Gleichheit vor dem Gesetz*, 2ª ed., München: Beck, 1959, p. 236: "Incorreto é apenas (...) querer concluir do possível fato de que o direito estatal não proteja, ou proteja de forma inadequada, os direitos subjetivos que esses direitos simplesmente não existem".

34. Cf. Heinrich Lehmann, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches*, 13ª ed., Berlin: de Gruyter, 1962, pp. 75 e ss.

negativo, positivo e ativo;³⁵ ou, ainda, a distinção de Kelsen entre direitos reflexos, direitos subjetivos em sentido técnico, permissões administrativas positivas, direitos políticos e direitos fundamentais e de liberdade.³⁶ Ainda nesse âmbito podem ser incluídas diferenciações, como a proposta por Windscheid, entre casos nos quais a vontade do titular do direito é “determinante para a exigibilidade da ordem emanada pelo ordenamento jurídico” e os casos nos quais essa vontade é “determinante (...) para o surgimento de direitos (...) ou para sua extinção ou modificação”,³⁷ bem como a diferenciação de Bucher: “[o] direito em sentido subjetivo é uma competência para a criação de normas outorgada ao seu titular pelo ordenamento jurídico”.³⁸

Esses poucos exemplos mostram com clareza a diversidade daquilo que é designado por “direito subjetivo”. Além disso, eles dão ensejo à suposição de que as posições resumidas sob esse conceito poderiam ser mais complexas do que as respectivas classificações, diferenciações e definições permitem reconhecer; isso poderia explicar as dificuldades que o conceito de direito subjetivo sempre suscitou e ainda suscita para sua análise.

Nesse contexto, são instrutivas as diferenciações feitas por Lindahl.³⁹ Teorias tradicionais são caracterizadas por tentar, com os meios da linguagem coloquial e da linguagem técnico-jurídica, e de forma mais ou menos direta, compreender as posições efetivamente criadas pelo ordenamento jurídico. A teoria de Lindahl diferencia-se substancialmente desse enfoque. Nela intenta-se abranger todas as possíveis posições normativas não contraditórias.⁴⁰ Para tanto são construídas todas as possíveis combinações entre dois operadores: o operador deontico (*shall operator*) e um operador de ação (*do operator*).⁴¹ Am-

35. Cf. Georg Jellinek, *System des subjektiven öffentlichen Rechts*, pp. 87 e 95 e ss.

36. Cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 130 e ss.

37. Bernhard Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, v. 1, p. 156.

38. Eugen Bucher, *Das subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis*, Tübingen: Mohr, 1965, p. 55.

39. Cf. Lars Lindahl, *Position and Change*, Dordrecht: Reidel, 1977.

40. Lindahl apóia-se, nesse âmbito, sobretudo nos trabalhos de Kanger. Cf. Stig Kanger, “New foundations for ethical theory”, in Risto Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht: Reidel, 1970, pp. 36 e ss.; Stig Kanger/Helle Kanger, “Rights and parliamentarism”, *Theoria* 32 (1966), pp. 85 e ss.

41. Cf. Lars Lindahl, *Position and Change*, p. 84.

bos os operadores são introduzidos no âmbito de um sistema lógico elementar. Dessa forma Lindahl obtém sete tipos básicos de posições normativas de *um* sujeito (*basic types of one-agent legal positions*),⁴² trinta e cinco tipos de relações normativas entre *dois* sujeitos, as quais se referem a ações que podem ser realizadas por cada um dos sujeitos separadamente (*individualistic two-agent types*),⁴³ e cento e vinte e sete tipos de relações normativas entre dois sujeitos, as quais se referem a ações que pressupõem uma coordenação entre esses sujeitos separadamente (*collectivistic two-agent types*).⁴⁴ Com base nisso Lindahl desenvolve sua teoria sobre a modificação das posições normativas, que diz respeito ao campo designado por meio de termos como “aptidão jurídica”, “poder jurídico”, “competência” e “capacidade jurídica”; disso resulta um número tão grande de possibilidades⁴⁵ que Lindahl procura distinguir, com ajuda de regras não lógicas (*rules of feasibility*), entre aquelas que merecem ser analisadas e aquelas que não merecem.⁴⁶

As análises de Lindahl não levantam nenhuma objeção às construções conceituais de tipo tradicional. Pelo contrário, a diversidade de constelações lógicas possíveis parece fazer com que, a partir da perspectiva da funcionalidade, seja obrigatório o desenvolvimento de conceitos que, sem que se adentre cada uma das possibilidades imagináveis de distinção, permitam apreender o campo dos direitos subjetivos de forma econômica e adequada. No mínimo, essas análises demonstram que mesmo um modelo simples, como o que será aqui proposto, não pode prescindir de uma olhada nas estruturas lógicas.

A diversidade daquilo que é designado como “direito (subjetivo)” cria um problema terminológico. Deve a expressão “direito (subjetivo)”, de plurivocidade e vagueza quase insuperáveis, ser reservada apenas para algumas posições, ou deve ser ela utilizada em um sentido o mais amplo possível? A primeira alternativa traz consigo o perigo de polêmicas estéreis sobre o que pode ser designado corretamente como “direito (subjetivo)”. Mais importante que essa questão é conhecer a estrutura das diferentes posições. Por isso, é recomendável

42. Idem, p. 92.

43. Idem, pp. 128-129.

44. Idem, pp. 162 e ss.

45. 2⁷ *one-agent legal positions*, 2³⁵ *individualistic two-agent types* e 2¹²⁷ *collectivistic two-agent types*. Cf. Lars Lindahl, *Position and Change*, p. 218.

46. Idem, pp. 225 e ss.

que a expressão "direito (subjetivo)" seja utilizada, seguindo seu uso corrente, como um supraconceito para posições em si bastante distintas, para que, a partir daí, sejam feitas diferenciações e classificações terminológicas.

II – UM SISTEMA DE POSIÇÕES JURÍDICAS FUNDAMENTAIS

A base da teoria analítica dos direitos é uma tríplice divisão das posições que devem ser designadas como "direitos" em (1) direitos a algo, (2) liberdades e (3) competências.⁴⁷

1. Direitos a algo⁴⁸

1.1 A estrutura básica do direito a algo

A forma mais geral de um enunciado sobre um direito a algo é a seguinte:

47. Essa divisão está associada tanto à diferenciação, proposta por Bentham, entre "direitos a serviços" (*rights to services*), "liberdades" (*liberties*) e "poderes" (*powers*) (Jeremy Bentham, *Of Laws in General*, London: Athlone, 1970, pp. 57-58, 82 e ss., 98, 119 e 173 e ss.) quanto àquela proposta por Bierling, entre "pretensão jurídica", "simples permissão jurídica" e "faculdade jurídica" (Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, pp. 49 e ss.).

48. A expressão "direito a algo" pode soar um pouco estranha. Alternativas possíveis seriam "direito (subjetivo)" e "pretensão". Mas direitos (subjetivos) incluem também liberdades e competências. Por isso, essa expressão parece pouco adequada para designar posições que devem ser claramente distinguidas das liberdades e competências. A expressão "pretensão" é mais adequada. O conceito de "direito a algo" compartilha com o conceito de "pretensão" um caráter relacional. Tanto quanto uma pretensão, um direito a algo dirige-se sempre contra alguém, e o objeto é, em ambos os casos, sempre um fazer ou uma abstenção. Contudo, aqui se renunciará à utilização do conceito de pretensão em um sentido técnico. Esse conceito está onerado por inúmeras controvérsias que, no presente contexto, pouco interessam (cf., por exemplo, Ludwig Enneccerus/Hans C. Nawiasky, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, 15ª ed., v. 2, Tübingen: Mohr, 1960, pp. 1363 e ss.). Se se deixam de lado as controvérsias acerca do conceito de pretensão, as quais dizem respeito, por exemplo, à atualidade, à determinação da parte contrária e à exigibilidade judicial, então, o direito a algo poderia, sem problemas, ser designado como "pretensão". De resto, é necessário salientar que falar em "direitos a algo" perde um pouco de seu caráter insólito quando se trata da formulação de direitos específicos. Por uma perspectiva lingüística, o enunciado "a tem, em face de b, um direito a G" não é inferior ao enunciado "a tem, em face de b, uma pretensão a G".

(1) *a* tem, em face de *b*, um direito a *G*.

Esse enunciado deixa claro que um direito a algo pode ser compreendido como uma relação triádica, cujo primeiro elemento é o *portador* ou o titular do direito (*a*), o segundo elemento é o *destinatário* do direito (*b*) e o terceiro elemento é o *objeto* do direito (*G*).⁴⁹ Essa relação triádica deve ser representada por *R*. A forma mais geral de um enunciado sobre um direito a algo pode, então, ser expressa da seguinte maneira:

(2) *RabG*.

Desse esquema decorrem coisas diversas, dependendo do que se coloque no lugar de *a*, *b* e *G*. São extremamente importantes, do ponto de vista da dogmática dos direitos fundamentais, as diferenças entre as relações obtidas se se insere como *a* – o titular do direito – uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito público; ou como *b* – o destinatário – o Estado ou um particular; ou como *G* – o objeto – uma ação positiva ou uma abstenção. Aqui interessa apenas a estrutura do objeto do direito a algo.

O objeto de um direito a algo é sempre uma *ação* do destinatário. Isso decorre da sua estrutura como relação triádica entre um titular, um destinatário e um objeto. Se o objeto não fosse uma ação do destinatário, então, não faria sentido incluir o destinatário na relação.

A referência a uma ação e a estrutura triádica não são diretamente expressas por meio das diferentes disposições de direitos fundamentais. Um exemplo é o art. 2º, § 1º, 1, da Constituição alemã:

(3) “Todos têm direito à vida (...)”.

Se se olha apenas para o texto desse dispositivo, seria possível pensar que por meio dele é garantido um direito que tem a estrutura de uma relação diádica entre um titular e um objeto, o qual, nesse caso, consistiria em um determinado estado do titular: estar vivo. Um tal direito equivaleria àquilo que na terminologia tradicional é chamado de *jus in rem*, que é contraposto ao *jus in personam*. Não pode haver dúvida de que, por razões de simplicidade, freqüentemente é conve-

49. Sobre o caráter triádico dessa relação, cf. Alan R. Anderson, “Logic, norms, and roles”, *Ratio* 4 (1962), p. 42.

niente falar em direitos como relações entre um sujeito de direito e um objeto. Contudo, como salientava Kant com precisão,⁵⁰ e como desde então se tem demonstrado com frequência,⁵¹ a menção a esse tipo de relação nada mais é que uma designação abreviada para um complexo de direitos a algo, liberdades e/ou competências.⁵² Assim, segundo o Tribunal Constitucional Federal, o art. 2º, § 1º, 1, da Constituição alemã estabelece tanto “*negativamente* um direito à vida”, que exclui “sobretudo o homicídio estatalmente organizado”,⁵³ como também *positivamente* um direito a que o Estado intervenha “de modo a proteger e fomentar essa vida”, o que significa sobretudo “protegê-la contra intervenções ilegais por parte de terceiros”.⁵⁴ Ambos os direitos têm a estrutura representada por *RabG* e se referem a uma ação do destinatário:

(4) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este não o mate.

(5) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este proteja sua vida contra intervenções ilegais por parte de terceiros.

Os direitos apresentados diferenciam-se exclusivamente em relação ao seu objeto. Um dos direitos – (4) – tem como objeto uma ação negativa (abstenção) do destinatário; o outro – (5) –, uma ação positiva (um fazer).⁵⁵ A distinção entre ações negativas e positivas é o principal critério para a divisão dos direitos a algo com base em seus objetos. No âmbito dos direitos em face do Estado, que serão analisados em seguida, os direitos a ações negativas correspondem àquilo que co-

50. Cf. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, pp. 247, 260 e 274.

51. Cf., por exemplo, Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 135 e ss.

52. Contra a concepção de que, no caso do *jus in rem*, trata-se de um complexo de direitos a algo, liberdades e/ou competências manifestaram-se, recentemente, Anthony M. Honoré, “Rights of exclusion and immunities against divesting”, *Tulane Law Review* 34 (1960), pp. 453 e ss., e Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, Oxford: Clarendon, 1970, p. 180. Para uma crítica a essas concepções, cf., com argumentos convincentes, Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 34 e ss.

53. *BVerfGE* 1, 97 (105).

54. *BVerfGE* 46, 160 (164). Nessa decisão fala-se não em um direito à proteção da vida, mas somente em um dever estatal de proteção. Mais adiante (Capítulo 9, II.2) será demonstrado que, ao menos quando não há problemas em relação à titularidade do direito fundamental – o que não era o caso na decisão sobre o aborto (*BVerfGE* 31, 1 (41)) –, ao dever constitucional de proteção corresponde, em princípio, um direito subjetivo.

55. Sobre os conceitos de ação negativa ou de abstenção, cf., por todos, Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 45 e ss.

mumente é chamado de "direitos de defesa". Já os direitos em face do Estado a uma ação positiva coincidem apenas parcialmente com aquilo que é chamado de "direitos a prestações", como será demonstrado mais adiante.⁵⁶

1.1.1 Direitos a ações negativas (direitos de defesa)

Os direitos dos cidadãos, contra o Estado, a ações estatais negativas (direitos de defesa) podem ser divididos em três grupos. O primeiro grupo é composto por direitos a que o Estado não impeça ou não dificulte determinadas *ações* do titular do direito; o segundo grupo, de direitos a que o Estado não afete determinadas *características* ou *situações* do titular do direito; o terceiro grupo, de direitos a que o Estado não elimine determinadas *posições jurídicas* do titular do direito.

1.1.1.1 Direitos ao não-embaraço de ações

A locomoção, a manifestação da crença, a expressão da opinião, a criação de uma obra de arte, a educação dos filhos, a reunião em uma rua e a escolha de uma profissão são exemplos de ações de um titular de um direito fundamental que podem ser impedidas ou dificultadas. A distinção entre impedir e dificultar tais ações pode ser explicada da seguinte forma: o *impedimento* de uma ação de *a* por parte de *b* ocorre quando *b* cria circunstâncias que tornam faticamente impossível para *a* realizar ação. Nesse sentido, *b* impede a locomoção de *a* se colocar *a* na prisão; *b* impede que *a* eduque seus filhos se os tomar de *a*. É possível falar em *dificultação* de uma ação de *a* por parte de *b*, se *b* cria circunstâncias que podem deter a ação de *a*. Se se definem os conceitos de impedimento e dificultação dessa maneira, uma ampliação dos requisitos subjetivos para o acesso a uma profissão que *a* consegue, ainda que com dificuldade e sacrifício, satisfazer não impede a escolha dessa profissão por parte de *a*; essa escolha é, contudo, dificultada. Uma concepção completamente diferente do conceito de impedimento é obtida se se leva em consideração não a situação de *a*, mas o êxito da ação dificultadora de *b*. Por esse aspecto, é possível afirmar que *b*

56. Cf. Capítulo 9, I.4.

impede a ação de *a* se o obstáculo faz com que *a* deixe de realizar a ação. Ao que foi dito é ainda possível acrescentar uma segunda diferenciação. A partir do ponto de vista da impossibilidade fática, uma proibição jurídica não representa um impedimento, mas apenas uma dificuldade: *a* pode aceitar os riscos ligados a uma violação da lei e, a despeito da proibição, realizar a ação proibida. Por outro lado, se se pressupõe a fidelidade de *a* ao direito, então, a proibição não apenas dificulta a realização da ação proibida, ela a impede.

A distinção entre os conceitos de impedimento e dificuldade somam-se diferenciações no interior desses conceitos. Existem espécies muito distintas de impedimentos e de dificuldades, e as dificuldades podem ter intensidades muito diferentes. Esse último fator é a razão por que os limites entre o impedir e o dificultar são fluidos, o que, no entanto, não constitui um argumento contra a distinção. Se se busca um supra-conceito para as diferentes espécies de impedimentos e dificuldades, seria possível recorrer ao conceito de *embaraço*.⁵⁷ Esse conceito deve ser utilizado sempre que não forem necessárias diferenciações adicionais.

O Estado pode ainda ter influência sobre ações de uma outra maneira além da descrita: ele pode torná-las *juridicamente impossíveis*. Direitos a que isso não ocorra devem ser diferenciados dos direitos ao não-embaraço. Nesse sentido, uma ação somente pode ser tornada juridicamente impossível se ela for um *ato jurídico*. Atos jurídicos são ações que não existiriam sem as normas jurídicas que para eles são constitutivas. Assim, o ato *jurídico* da celebração de um contrato não seria possível sem as normas do direito contratual; o ato *jurídico* da criação de uma associação não seria possível sem as normas do direito associativo; o ato *jurídico* da celebração de um casamento não seria possível sem as normas do direito matrimonial; o ato *jurídico* da propositura de uma ação judicial não seria possível sem as normas do direito processual; e o ato *jurídico* de votar não seria possível sem as normas do direito eleitoral.⁵⁸ O caráter constitutivo das normas que

57. Cf., por exemplo, a formulação de Bühler, segundo a qual os direitos fundamentais são, "enquanto direitos a uma abstenção (...) pretensões, contra o Estado, a que ele se abstenha de embaraçar certas ações dos indivíduos" (Ottmar Bühler, *Die subjektiven öffentlichen Rechte und ihr Schutz in der deutschen Verwaltungsrechtssprechung*, Berlin: Kohlhammer, 1914, p. 63).

58. Sem as normas *jurídicas* que os constituem, esses atos seriam possíveis, no máximo, como atos *sociais*.

possibilitam esses atos caracteriza essas ações como *ações institucionais*.⁵⁹ Ações jurídico-institucionais tornam-se impossíveis se as normas que são para elas constitutivas são derogadas. Entre a derrogação dessas normas e a impossibilidade das ações institucionais existe, portanto, uma relação *conceitual*. No entanto, ações jurídico-institucionais podem não apenas ser impossibilitadas juridicamente, elas podem ser também dificultadas. Se isso ocorre, então, existe uma relação *fática* entre a ação dificultadora e seu êxito. O ato jurídico ou a ação jurídico-institucional da celebração do casamento tornam-se juridicamente impossíveis se a norma do direito matrimonial é derogada. No entanto, um determinado casamento de *a* é apenas dificultado se esse casamento tiver como consequência a impossibilidade de *a* ingressar no serviço público. O espectro das possíveis dificuldades de atos jurídicos é amplo. Assim é que a propositura de uma ação é dificultada se ela estiver associada a custas judiciais muito altas, e o ato de votar é dificultado se a seção de votação estiver localizada em local de difícil acesso para aqueles que moram em uma determinada área e se não for possível o voto por correspondência.

Se um ato jurídico se torna impossível porque a norma para ele constitutiva foi derogada, então, os indivíduos são privados de uma posição jurídica: a capacidade jurídica ou a competência para modificar determinada situação jurídica.⁶⁰ Por isso, os direitos a que isso não ocorra pertencem ao terceiro grupo de direitos a ações negativas, isto é, ao grupo dos direitos a que o Estado não elimine determinadas posições jurídicas dos titulares. Ao primeiro grupo pertencem somente os direitos a que o Estado não embarace qualquer tipo de ações dos titulares do direito, ou seja, não as impeça ou dificulte, por qualquer que seja o meio.

Ao enunciado sobre um tal direito é possível dar a seguinte formulação padrão:

- (6) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este não o embarace na realização da ação *h*.⁶¹

59. Cf., a esse respeito, John R. Searle, *Speech Acts*, pp. 33 e ss., 50 e ss.; Neil McCormick, "Law as institutional fact", pp. 105 e ss.

60. A esse respeito, cf Capítulo 4, II.3.

61. Se se escreve *s* para o Estado e *Ha* para "*a* realiza a ação *h*", então, a estrutura desse enunciado, com a utilização do símbolo " $\neg$ " para a negação, pode ser representada da seguinte forma:

(6') *Ras* ($\neg$ embaraca *s* (*Ha*)).

1.1.1.2 *Direitos à não-afetação de características e situações*

O segundo grupo de direitos a ações estatais negativas é constituído pelos direitos a que o Estado não afete determinadas características e situações do titular do direito. Exemplos de propriedades de um titular de um direito fundamental que podem ser afetadas são viver e ser saudável; um exemplo de uma situação é a inviolabilidade do domicílio.⁶²⁻⁶³ Ao enunciado sobre um tal direito pode ser dada a seguinte formulação padrão:

- (7) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este não afete a característica A (a situação B) de *a*.⁶⁴

1.1.1.3 *Direitos à não-eliminação de posições jurídicas*

O terceiro grupo de direitos a ações estatais negativas é constituído pelos direitos a que o Estado não elimine determinadas posições jurídicas do titular do direito. O protótipo de uma posição jurídica complexa é o do proprietário. O Tribunal Constitucional Federal observava corretamente que a propriedade, “para ser praticável na vida jurídica, [carece] necessariamente de conformação jurídica”.⁶⁵ Essa con-

62. Ao invés de características e situações, frequentemente se fala em bens, como, por exemplo, no bem da vida. Contra essa forma de expressão não há nada a objetar; mas ela pode induzir a erro. O fato de que *a* viva não significa que existem *a* e algo mais, o bem, e que entre ambos exista uma relação de posse; significa, na verdade, que *a* é conferida uma característica: viver. Cf., nesse sentido, Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 83, nota 1: “Em si mesmas, vida, saúde, liberdade, honra etc. não são objetos que o ser humano tem, mas características que definem sua existência concreta”.

63. Uma interpretação do art. 13 da Constituição alemã explicitamente relaciona a a situações e não a ações pode ser encontrada em *BVerfGE* 7, 230 (238). Merten contrapõe tais direitos, enquanto “direitos de defesa” ou “direitos a proteção”, aos “direitos a ações” (Detlef Merten, “Handlungsgrundrechte als Verhaltensgarantie”, *VerwArch* 73 (1982), p. 103). Essa não parece ser uma terminologia feliz. Também os direitos ao não embaraço de ações podem ser caracterizados como “direitos de defesa”, e isso ocorre com frequência. Por isso, é mais apropriado fazer a distinção entre direitos relacionados a situações e direitos relacionados a ações no interior do conceito de direito de defesa.

64. Se se utiliza *Sa* tanto para “*a* tem a característica A” quanto para “*a* encontra-se na situação B”, então, a estrutura desse enunciado pode ser representada da seguinte forma:

(7') *Ras* ($\neg$ afeta *s* (*Sa*)).

65. *BVerfGE* 58, 300 (330) – sem grifos no original.

formação se dá por meio de normas jurídicas que definem o instituto jurídico da propriedade. Às normas jurídicas que definem o instituto jurídico da propriedade pertencem normas sobre a criação e o desfazimento da posição de proprietário, bem como normas que prevêm consequências jurídicas a essa posição.⁶⁶ Podem ser eliminados tanto, de um lado, “posições jurídicas subjetivas concretas”⁶⁷ ou “direitos concretos de propriedade”,⁶⁸ que surgiram porque foram cumpridas as condições estabelecidas pelas normas do instituto jurídico da propriedade (por exemplo: acordo e entrega; sucessão), quanto, de outro lado, as próprias normas do instituto jurídico da propriedade. Neste último caso, são eliminadas posições jurídicas abstratas, tais como a possibilidade jurídica ou a competência para adquirir ou transferir a propriedade sobre determinados objetos, ou ainda a possibilidade ou a competência para realizar determinadas ações jurídicas baseadas na posição de proprietário.⁶⁹ A eliminação de uma posição jurídica abstrata ocorre, por exemplo, quando a aquisição de terrenos rurais ou florestais depende de uma autorização, o que a torna impossível sob certas circunstâncias.⁷⁰ A garantia constitucional do instituto jurídico da pro-

66. Cf. Neil MacCormick, “Law as institutional fact”, pp. 106-107.

67. *BVerfGE* 52, 1 (27).

68. *BVerfGE* 58, 300 (331).

69. Um exemplo nesse sentido é a capacidade ou a competência do proprietário de um apartamento alugado para aumentar o valor do aluguel. Acerca de sua proteção constitucional, cf. *BVerfGE* 37, 132 (139 e ss.).

70. Para um caso desse tipo, cf. *BVerfGE* 21, 73. Nesse caso, o Tribunal Constitucional Federal deixou explicitamente em aberto se o “direito de aquisição de propriedades agrária e florestal” é protegido por meio do art. 14, § 1º, 1, da Constituição alemã, e resolveu o caso no âmbito do art. 2º, § 1º (*BVerfGE* 21, 73 (76-77, 79, 86-87)). Sobre essa questão, cf., por todos, Michael Kloepper, *Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandsschutz*, pp. 37 e ss., o qual sustenta, com argumentos respeitáveis, que “a subordinação da liberdade de aquisição da propriedade ao art. 14 da Constituição alemã” é “uma exigência constitucional” (idem, p. 48; no mesmo sentido, Otto Kimminich, “Art. 14”, in Rudolf Dolzer (Org.), *Bonner Kommentar zum Grundgesetz*, Heidelberg: Müller, 1984, § 88; em sentido contrário, Peter Wittig, “Der Erwerb von Eigentum und das Grundgesetz”, *NJW* 20 (1967), pp. 2185 e ss.). É necessário salientar que aqui se está falando apenas da possibilidade jurídica, e não da possibilidade fática, da aquisição da propriedade; ou seja, não se está falando de “chances e possibilidades de ganhar dinheiro” (sobre isso, cf. *BVerfGE* 30, 292 (335)). Se estas estiverem em jogo, então, trata-se – no âmbito dos direitos a ações negativas – de um embaraço de ações e de uma afetação de situações, o que com certeza pode ocorrer paralelamente à eliminação de posições jurídicas.

priedade é subjetivada na medida em que existem direitos individuais à não-eliminação de posições abstratas que se relacionem à criação, ao desfazimento e às consequências jurídicas da posição de proprietário.

A eliminação de posições não ocorre somente em contextos institucionais como o da propriedade. Quando se proíbe a expressão de determinadas opiniões, elimina-se uma posição de *a*: a permissão de expressar essas opiniões. Uma tal proibição pode ser encarada sob dois aspectos: sob o aspecto do embaraço de uma ação e sob o aspecto da eliminação de uma posição. No caso de ações que não são atos jurídicos, o primeiro aspecto é o decisivo.

Mais uma vez é aconselhável reduzir a diversidade a uma forma padrão simples, como a seguinte:

- (8) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este não elimine a posição jurídica *RP* de *a*.⁷¹

A existência de uma posição jurídica significa que uma norma correspondente (individual ou universal) é válida. O direito do cidadão, contra o Estado, a que este não elimine uma posição jurídica sua é, nesse sentido, um direito a que o Estado não derogue determinadas normas.⁷²

1.1.2 Direitos a ações positivas

Os direitos que o cidadão tem, contra o Estado, a ações estatais positivas podem ser divididos em dois grupos: aquele cujo objeto é uma ação fática e aquele cujo objeto é uma ação normativa.

71. Se se utiliza *RP_a* para "*a* encontra-se na posição jurídica *RP*", então, a estrutura desse enunciado pode ser representada da seguinte forma:

(8') *Ras* ($\neg$ elimina *s* (*RP_a*)).

72. Quando se trata de normas como, por exemplo, as que constituem o instituto jurídico da propriedade, isso conduz a interessantes problemas relacionados ao caráter positivo ou negativo das ações estatais às quais o direito se refere. *a* tem um direito à não-eliminação da norma *N*, se *a* tiver um direito a que *N* exista. Se *a* tem um direito a que *N* exista, então, o caráter positivo ou negativo de seu direito depende tão-somente da constatação sobre se *N* já existe, ou não. Se se consideram como ação legislativa não apenas os atos de criação e revogação normativa, mas também a manutenção da vigência da norma, então, ao direito à não-eliminação como direito a uma ação negativa corresponde sempre um direito à manutenção da vigência, o qual é um direito a uma ação positiva. Os problemas que com isso se suscitam terão um papel quando da análise dos direitos à prestação normativa do Estado (Capítulo 9, III.4).

Trata-se de um direito a uma ação positiva *fática* quando se supõe um direito de um proprietário de escola privada a um auxílio estatal por meio de subvenções,⁷³ quando se fundamenta um direito a um mínimo existencial⁷⁴ ou quando se considera uma “pretensão individual do cidadão à criação de vagas nas universidades”.⁷⁵ O fato de a satisfação desse tipo de direitos ocorrer por meio de alguma forma jurídica não muda nada no seu caráter de direito a uma ação *fática*. É indiferente para a satisfação do direito de que forma ela ocorre. Decisivo é apenas o fato de que, após a realização da ação, os proprietários de escolas privadas disponham de meios suficientes, que os necessitados disponham do mínimo para sua existência e que exista uma vaga na universidade para aquele que quer estudar. A irrelevância da forma jurídica na realização da ação para a satisfação do direito⁷⁶ é o critério para a distinção entre direitos a ações positivas *fáticas* e direitos a ações positivas *normativas*.

Direitos a ações positivas *normativas* são direitos a atos estatais de criação de normas. Se se pressupõe uma titularidade de direitos fundamentais por parte do nascituro – algo que é deixado em aberto pelo Tribunal Constitucional Federal⁷⁷ –, o direito do nascituro à proteção por meio de normas do direito penal é um direito dessa espécie. Um outro exemplo é o direito de um titular do direito fundamental à liberdade científica “àquelas medidas estatais, também de caráter organizacional, que sejam imprescindíveis para a proteção de sua esfera de liberdade constitucionalmente protegida”.⁷⁸

Quando se fala em “direitos a prestações” faz-se referência, em geral, a ações positivas *fáticas*. Tais direitos, que dizem respeito a prestações *fáticas* que, em sua essência, poderiam ser também realizadas por particulares, devem ser designados como *direitos a prestações em sentido estrito*. Mas, além de direitos a prestações *fáticas*, pode-se também falar de prestações *normativas*. Nesse caso, também os direitos a ações positivas *normativas* adquirem o caráter de direitos a prestações. Eles devem ser designados como *direitos a prestações em sen-*

73. BVerwGE, 27, 360 (362 e ss.).

74. Cf. Günter Dürig, “Art. 1”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz*, §§ 43-44.

75. BVerfGE 33, 303 (333).

76. Dessa irrelevância para a satisfação do direito não decorre a irrelevância para a satisfação de outras normas.

77. BVerfGE 39, 1 (41).

78. BVerfGE 35, 79 (116).

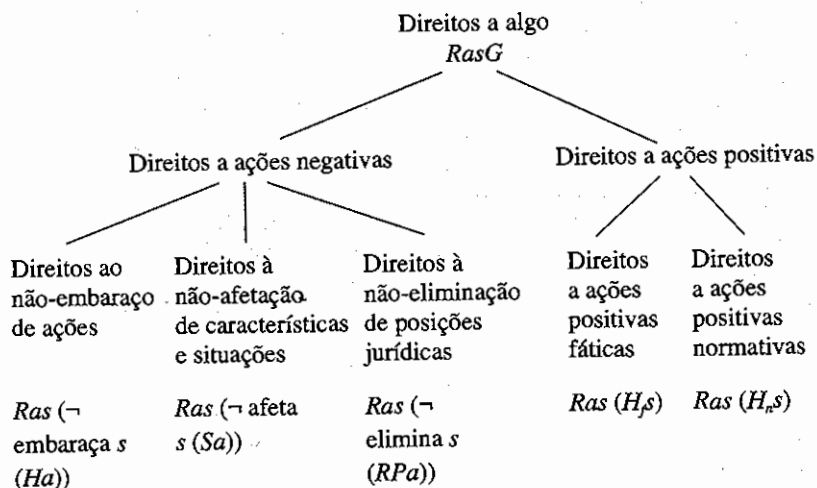
tido amplo.⁷⁹ Um exemplo de direito a uma prestação normativa é o direito ao estabelecimento de uma determinada competência de co-gestão em uma instituição, como, por exemplo, na universidade. O fato de o objeto desse direito ser uma competência, a qual, enquanto tal, deve ser atribuída ao *status* ativo, não dá ensejo a nenhuma objeção contra a classificação do direito a essa competência como um direito a uma prestação normativa positiva. A prestação normativa positiva consiste na garantia de uma competência de co-gestão.

Como se vê, o conceito de direito a uma ação positiva fática e o conceito de direito a uma ação positiva normativa abarcam coisas muito diversas. Aqui, interessa apenas fixar suas estruturas mais básicas:

(9) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este realize a ação positiva fática h_f .

(10) *a* tem, em face do Estado, um direito a que este realize a ação positiva normativa h_n .⁸⁰

É possível, agora, apresentar o seguinte quadro dos direitos a algo em face do Estado (s):



79. Cf., a esse respeito, Capítulo 9, I.4.

80. Se se utiliza $H_f s$ para "o Estado realiza a ação positiva fática h_f ", e $H_n s$ para "o Estado realiza a ação positiva normativa h_n ", então, a estrutura desses enunciados pode ser representada da seguinte forma:

(9') *Ras* ($H_f s$);

(10') *Ras* ($H_n s$).

1.2 Acerca da lógica do direito a algo

Até agora tratou-se de uma classificação dos direitos a algo naquilo que dizia respeito a seus objetos. Não menos importante para a dogmática dos direitos fundamentais é a definição da relação entre o conceito de direito a algo e os conceitos de dever e de liberdade. Neste ponto, são úteis algumas noções elementares de lógica deôntica.

1.2.1 As modalidades deônticas básicas

A lógica deôntica⁸¹ é a lógica dos conceitos e dos enunciados deônticos.⁸² Os conceitos deônticos básicos são os conceitos de dever, de proibição e de permissão. Enunciados deônticos são enunciados construídos com o auxílio desses conceitos. São exemplos de enunciados deônticos:

81. Em vez da expressão consagrada "lógica deôntica", que deriva da expressão grega τὸ δεόν ("o que deve ser"), seria possível utilizar também as expressões "lógica do dever-ser" ou "lógica normativa". O termo "deôntico" foi utilizado pela primeira vez por Mally (cf. Ernst Mally, *Grundgesetze des Sollens: Elemente der Logik des Willens*, Graz: Leuschner und Lubensky, 1926, republicado em Ernst Mally, *Logische Schriften*, Dordrecht: Reidel, 1971, pp. 227-324, p. 232). Sobre a história da lógica deôntica, cf. Georges Kalinowski, *Einführung in die Normenlogik*, Frankfurt am Main: Athenäum, 1973, pp. 15 e ss.

82. Um dos estímulos mais importantes para o estabelecimento da lógica deôntica como disciplina especial da lógica foi o artigo de Georg H. v. Wright, "Deontic Logic", de 1951 (cf. Georg H. v. Wright, "Deontic Logic", *Mind* 60 (1951): 1-15, republicado em Georg H. v. Wright, *Logical Studies*, London: Routledge & Kegan Paul, 1957, pp. 58-74). Outros importantes trabalhos da mesma época são: Oskar Becker, *Untersuchungen über den Modalkalkül*, Meisenheim/Glan: Westkulturverlag Hain, 1952; Georges Kalinowski, "Théorie des propositions normatives", *Studia Logica* 1 (1953): 147-182; e Ota Weinberger, "Úvaly o logice normativních vět", *Filosofický Časopis ČSAV* 4 (1956): 918-926. Dentre os predecessores mais antigos devem ser mencionados sobretudo Leibniz (Gottfried W. Leibniz, *Elementa juris naturalis*, 1671, esboço manuscrito B (Hannover), manuscrito final C (Hannover), republicados em Gottfried W. Leibniz, *Sämtliche Schriften und Briefe*, 6ª série, v. 1, Darmstadt: Reichl, 1930, pp. 465 e ss. e 480 e ss.) e Bentham (cf. Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), pp. 299-300; do mesmo autor, *Of Laws in General*, p. 15). Sobre a discussão mais recente, cf. Risto Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht: Reidel, 1970; Hans Lenk (Org.), *Normenlogik*, Pullach: Verlag Dokumentation, 1974; Rainer Stuhlmann-Laeisz, *Das Sein-Sollen-Problem*, Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1983, pp. 54 e ss.

(1) É obrigatório que *a* expresse a sua opinião.

(2) É proibido que *a* expresse a sua opinião.

(3) É permitido que *a* expresse a sua opinião.

O contraposto de enunciado deôntico é o enunciado declarativo. Se a este último se dá a seguinte forma:

(4) *a* expressa a sua opinião,

então, fica muito difícil fazer uma comparação estrutural. No entanto, se se dá a ele a seguinte forma:

(5) É o caso que *a* expresse a sua opinião,

então, fica claro que os enunciados deônticos e os enunciados declarativos, por mais que sejam coincidentes em seu conteúdo descritivo (... que *a* expresse a sua opinião), diferenciam-se, no entanto, em seu *modus*.⁸³ O mesmo conteúdo descritivo – Wittgenstein chama-o de “radical do enunciado”;⁸⁴ Hare, de “frástica”⁸⁵ – está presente em (5) em um *modus* indicativo, e em (1) a (3) em um *modus* deôntico. Os conceitos deônticos devem ser concebidos, por essa razão, como *modalidades deônticas*.⁸⁶ Se se representa o radical do enunciado por meio de *p* e as modalidades deônticas por meio dos operadores deônticos *O* (operador de dever), *F* (operador de proibição) e *P* (operador de permissão), então, é possível representar os enunciados (1) a (3), apresentados anteriormente, da seguinte forma:

(6) *Op*.

83. Cf., a esse respeito, Erik Stenius, *Wittgensteins Traktat*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, pp. 206 e ss.

84. Ludwig Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen*, p. 299.

85. Richard M. Hare, “Meaning and speech acts”, p. 90. Cf., a esse respeito, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 87 e ss. Alf Ross utiliza o termo “topic” (cf. Alf Ross, *Directive and Norms*, pp. 9 e ss. e 34 e ss.).

86. Sobre o paralelismo estrutural entre as modalidades deônticas e aquelas da lógica modal geral (necessidade/impossibilidade/possibilidade), cf. Georg H. v. Wright, *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, Amsterdam: North-Holland, 1968, pp. 13-14, bem como, de forma fundante, Gottfried W. Leibniz, *Elementa juris naturalis*, p. 466: “Omnes ergo Modalium complicationes et transpositiones et oppositiones, ab Aristotele aliisque in Logicis demonstratae ad haec nostra Iuris Modalia non inutiliter transferri possunt” (em tradução livre: “Portanto, todas as imbricações, transposições e oposições dos conceitos modais, demonstrados, na Lógica, por Aristóteles e outros, podem ser utilmente transferidos para as nossas modalidades jurídicas” [N. do T.]).

(7) Fp .

(8) Pp .⁸⁷

Os três operadores deônticos podem ser definidos reciprocamente. Ser obrigatório expressar sua opinião (Op) significa que não é permitido não expressar sua opinião. Isso pode ser escrito, com o auxílio do símbolo de negação “ $\neg$ ”,⁸⁸ como $\neg P\neg p$. Nesse sentido, vale:

(9) $Op =_{df} \neg P\neg p$.

O dever e a permissão são, portanto, definíveis reciprocamente. O mesmo vale para a relação entre a permissão e a proibição. Ser proibido expressar sua opinião significa que não é permitido expressá-la:

(10) $Fp =_{df} \neg Pp$.

A possibilidade de definição recíproca dos conceitos deônticos básicos faz com que fique claro que não seria necessário utilizar todos eles. Apenas um deles, não importa qual, seria suficiente.

Para a teoria dos direitos fundamentais o conceito de permissão tem especial interesse. Se se aceitam as definições apresentadas, que correspondem ao sistema padrão da lógica deôntica,⁸⁹ então, a permissão consiste na negação da proibição:

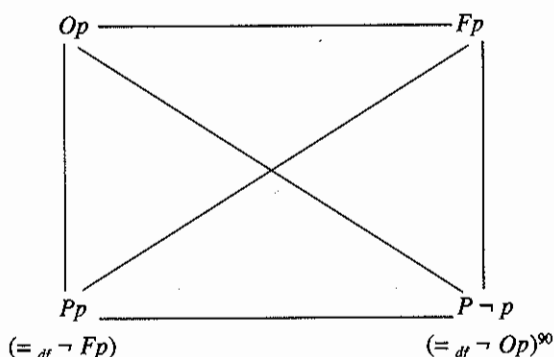
(11) $Pp =_{df} \neg Fp$.

Ser permitido expressar a sua opinião significa, nesse sentido, que não é proibido fazê-lo. Esse conceito de permissão é relativamente fraco. O que é permitido no sentido de não-proibido pode ser obrigatório. Quem defende a concepção de que o exercício de um direito é, ao mesmo tempo, um dever aponta para essa vinculação entre permissão e dever. O que esse conceito de permissão não abarca é a ausência tanto de uma proibição quanto de uma obrigação. A forma como essas posições devem ser construídas é demonstrada pelo assim chamado quadrado deôntico:

87. Não raro, Op é interpretado como a ligação entre operador deôntico e enunciado descritivo (p). Cf., por exemplo, Maximilian Herberger/Dieter Simon, *Wissenschaftstheorie für Juristen*, Frankfurt am Main: Metzner, 1980, p. 183. Aqui, p representa o radical do enunciado.

88. Sobre a negação, cf. W. V. O. Quine, *Grundzüge der Logik*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, pp. 25-26.

89. Cf., a esse respeito, a apresentação de Dagfinn Føllesdal/Risto Hilpinen, “Deontic Logic: an introduction”, in Risto Hilpinen, *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, pp. 13 e ss.



A permissão aparece duas vezes no quadrado acima: uma vez como negação da proibição (Pp) e uma vez como negação do dever ($P\neg p$). Pp pode ser interpretado como a permissão de um fazer, $P\neg p$, como a permissão de uma abstenção. A primeira pode ser designada como “permissão positiva”, e a segunda como “permissão negativa”. Da conjunção das permissões positiva e negativa resulta uma posição composta, que pode ser designada por “faculdade e simbolizada por Lp ”.⁹¹ Por meio da utilização do símbolo de conjunção “ $\wedge$ ” para “e”,⁹² é possível defini-la da seguinte forma:

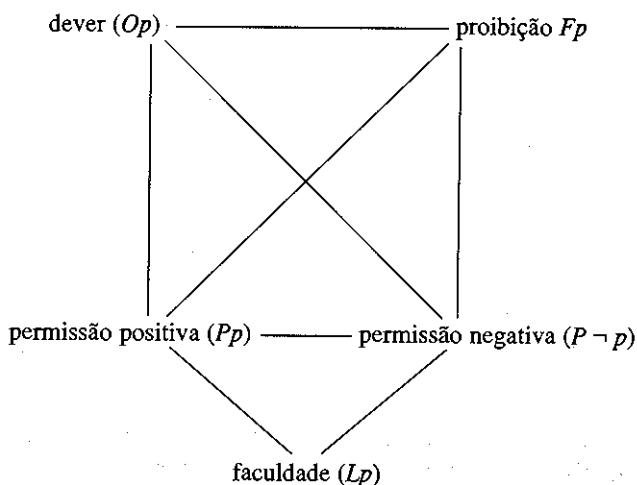
$$(12) Lp =_{df} Pp \wedge P\neg p.$$

A “faculdade” desempenhará um importante papel quando da análise da liberdade. Complementado com o conceito de faculdade, o que havia sido dito acerca dos conceitos deonticos básicos pode ser, agora, resumido da seguinte forma:

90. Entre os enunciados deonticos desse esquema existem as seguintes relações: Op e Fp são *contrários*. Eles são logicamente incompatíveis; mas da negação de um não decorre o outro. Op e $P\neg p$, tanto quanto Fp e Pp , são *contraditórios*, isto é, da negação de um decorre o outro. Op e Pp , tanto quanto Fp e $P\neg p$, são *subalternos*, isto é, de cada um dos primeiros decorre cada um dos segundos. Pp e $P\neg p$ são *subcontrários*, isto é, Pp e $P\neg p$ são logicamente compatíveis. Sobre as correspondentes relações no quadrado da lógica de predicados, cf. Gottlob Frege, *Begriffsschrift*, Halle: Nebert, 1879, p. 24.

91. Adomeit utiliza o termo “faculdade” para a permissão negativa expressa por meio de $P\neg p$ (cf. Klaus Adomeit, *Rechtstheorie für Studenten*, 2ª ed., Heidelberg: von Decker, 1981, pp. 42-43). Já Herberger e Simon utilizam o termo como aqui, mas usam o símbolo I (cf. Maximilian Herberger/Dieter Simon, *Wissenschaftstheorie für Juristen*, pp. 184 e ss.).

92. A respeito da conjunção, cf. W. V. O. Quine, *Grundzüge der Logik*, p. 27.



1.2.2 Direitos a algo como relações jurídicas

Para poder, com base nas modalidades deônticas apresentadas, analisar o conceito de direito a algo e sua relação com outros conceitos, é necessário proceder a uma modificação desses conceitos que é fundamental para a teoria dos direitos subjetivos: a eles deve ser conferido um *caráter relacional*.

Acima foi demonstrado que direitos a algo devem ser concebidos como uma relação triádica entre um titular (a), um destinatário (b) e um objeto (G). A chave para a análise da correspondência entre direito e obrigação está na equivalência lógica entre a relação triádica dos direitos e uma relação triádica das obrigações ou dos deveres.⁹³ De:

- (1) a tem, em face de b , um direito a que b o ajude
decorre:
- (2) em face de a , b está obrigado a ajudá-lo,
e vice-versa. (2) expressa uma *obrigação relacional*. Uma obrigação não-relacional seria, por outro lado, expressa por:
- (3) b está obrigado a ajudar a .

93. Sobre o conceito de equivalência lógica, cf. Rudolf Carnap, *Meaning and Necessity*, p. 11.

A existência dessa obrigação não significa que *a* tenha, em face de *b*, um direito a ajuda. Pode ser que ninguém, ou um terceiro, tenha um direito a isso. É possível expressar a obrigação não-relacional da seguinte forma:

(4) *OG*.⁹⁴

Já à obrigação relacional expressa por (2) deve ser dada a seguinte forma:

(5) *ObaG*.

Nessa fórmula, *O* é um operador *triádico*, que expressa uma modalidade deôntica *relacional*.⁹⁵ Que

(6) *RabG*

é equivalente a (5) é algo que mostra que enunciados sobre direitos a algo e enunciados sobre obrigações relacionais descrevem a mesma coisa, de um lado a partir da perspectiva de *a* e, de outro, da perspectiva de *b*.

Enunciados sobre obrigações não-relacionais – como (4) – são enunciados que *omitem* o aspecto relacional. Eles não devem ser confundidos com enunciados sobre obrigações que existem em face de todos. Esses últimos não omitem o caráter relacional; eles o contêm em sua forma mais forte. É possível designar as obrigações por eles expressas como *obrigações relacionais absolutas*.

A moderna discussão sobre as relações jurídicas foi fortemente estimulada e influenciada pelo trabalho de Wesley Newcomb Hohfeld, publicado em duas partes nos anos de 1913 e 1917, chamado "(Some) fundamental legal conceptions as applied in judicial

94. *G* representa o radical do enunciado "que *b* ajude *a*". O enunciado (4) expressa a obrigação de *b* de forma não relacionada a pessoas. Uma expressão relacionada a pessoas é obtida se se escreve:

(4') *ObG*.

No enunciado (4'), *O* é um operador diádico, que se refere à relação entre um sujeito de direito e uma ação, mas não a uma ação entre diferentes sujeitos de direito. Por isso, ele deve ser denominado somente como "pessoal", e não como "relacional". A utilização de operadores pessoais é redundante no caso de mandamentos de ação se o sujeito da ação é o sujeito da obrigação.

95. Sobre o conceito e sobre a lógica das modalidades relacionais, cf. Risto Hilpinen, "An analysis of relativised modalities", in J. W. Davis *et al.* (eds.), *Philosophical Logic*, Dordrecht: Reidel, 1969, pp. 181 e ss.

reasoning".⁹⁶⁻⁹⁷ Segundo Hohfeld, existem oito "relações jurídicas estritamente fundamentais (...) *sui generis*" (*strictly fundamental legal relations ... sui generis*).⁹⁸ Ele as designa com as expressões "direito" (*right*), "dever" (*duty*), "não-direito" (*no-right*), "privilégio" (*privilege*), "poder" (*power*), "sujeição" (*liability*), "incapacidade" (*disability*) e "imunidade" (*immunity*). Os quatro primeiros dizem respeito ao âmbito dos direitos a algo; os quatro últimos, ao das competências. Neste ponto, interessam apenas os quatro primeiros.

No sistema de Hohfeld as expressões "direito", "dever", "não-direito" e "privilégio" representam relações jurídicas (*legal relations*) en-

96. Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", *Yale Law Journal* 23 (1913/14), pp. 16 e ss.; do mesmo autor, "Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", *Yale Law Journal* 26 (1916/17), pp. 710 e ss., ambos republicados em Wesley N. Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays*, New Haven: Yale University Press, 1923, pp. 23 e ss. e 65 e ss. Muitas das idéias de Hohfeld foram antecipadas por Bentham, sobretudo em sua obra *Of Laws in General*, finalizada em 1782 (cf. H. L. A. Hart, "Bentham's *Of Laws in General*", *Rechtstheorie* 2 (1971), p. 57). Esse trabalho só foi publicado, contudo, em 1945, sob o título *The Limits of Jurisprudence Defined* (Jeremy Bentham, *The Limits of Jurisprudence Defined* (ed. by C. W. Everett), New York: Columbia University Press, 1945). Bentham é superior a Hohfeld em um ponto decisivo: ele baseia sua análise em um sistema de lógica deontica, o qual, em muitos pontos, pode ser considerado como precursor dos modernos sistemas (cf. H. L. A. Hart, "Bentham's *Of Laws in General*", pp. 60 e ss.; Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 4 e ss.). O fato de que aqui se tenha escolhido a análise de Hohfeld como ponto de partida é justificado não apenas porque seu trabalho influenciou em enorme medida o debate sobre o tema, mas também porque, de um lado, supera em simplicidade e clareza as análises de Bentham e, de outro, embora não utilize explicitamente o sistema padrão da lógica deontica, o pressupõe de forma implícita, razão pela qual representa uma base ideal para futuras investigações.

97. Da ampla literatura sobre Hohfeld, cf. Arthur L. Corbin, "Legal analysis and terminology", *Yale Law Journal* 29 (1919), pp. 163 e ss.; Manfred Moritz, *Über Hohfelds System der juristischen Grundbegriffe*, Lund: Gleerup, 1960; Alf Ross, *On Law and Justice*, London: Stevens, 1958, pp. 161 e ss.; do mesmo autor, *Directives and Norms*, pp. 118 e ss.; D. J. Hislop, "The Hohfeldian system of fundamental legal conceptions", *ARSP* 53 (1967), pp. 53 e ss.; Julius Stone, *Legal System and Lawyer's Reasoning*, London: Stevens, 1964, pp. 136 e ss.; Jürgen Schmidt, *Aktionsberechtigung und Vermögensberechtigung*, Köln: Heymanns, 1969, pp. 32 e ss.

98. Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", p. 36.

tre dois sujeitos de direito. Aqui, direitos são concebidos como relações triádicas entre o titular, o destinatário e o objeto. No entanto, isso implica a não-aplicabilidade das concepções de Hohfeld, pois, no lugar da relação

(7) (...) tem, em face de (...), um direito a (...),

à qual corresponde um enunciado sobre direitos na forma

(8) *RabG*,

sempre é possível falar da relação

(9) (...) tem um direito a *G* em face de (...),

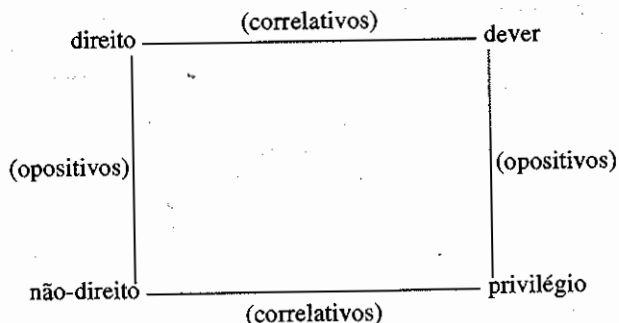
à qual corresponde um enunciado sobre direitos na forma

(10) *RGab*,

e vice-versa.

O núcleo da teoria de Hohfeld é formado por suas teses sobre as correspondências lógicas entre as relações jurídicas. A teoria de Hohfeld pode, nesse sentido, ser qualificada como uma teoria sobre as correspondências lógicas entre as relações jurídicas. As relações lógicas no âmbito dos direitos a algo podem ser representadas, segundo Hohfeld, por meio do seguinte esquema:

I.



Como ilustração, podem ser utilizados os seguintes exemplos no esquema apresentado:

I. <i>a</i> tem, em face de <i>s</i> , um direito a que <i>s</i> lhe garanta asilo	(corr.)	<i>s</i> está, em face de <i>a</i> , obrigado a lhe garantir asilo
(RasG/direito)		(OsaG/dever)
(op.)		(op.)
<i>a</i> não tem, em face de <i>s</i> , um direito a que <i>s</i> lhe garanta asilo	(corr.)	<i>s</i> não está obrigado, em face de <i>a</i> , a lhe garantir asilo
(¬RasG/não-direito)		(¬OsaG/privilégio)

As relações lógicas entre essas quatro posições são facilmente identificáveis. O não-direito (*no-right*) é a negação do direito (*right*) e o privilégio (*privilege*) é a negação do dever (*duty*).⁹⁹ Hohfeld designa essa relação como uma relação entre *opositivos* jurídicos (*jural oppositives*).

99. Idem, p. 39: "um dado privilégio é a mera negação de um dever". É sintomático que Hohfeld às vezes fale em "não-dever" em vez de em "privilégio" (idem, p. 48, nota 59). Discute-se se privilégio e não-direito sejam relações, já que dizem respeito a algo negativo. Essa questão é respondida de forma negativa, dentre outros, por Albert Kocourek, "Non-legal-content Relations", *Illinois Law Quarterly* 4 (1922), p. 234; do mesmo autor, *Jural Relations*, 2ª ed., Indianapolis: s.e., 1928, pp. 91 e ss.; e Manfred Moritz, *Über Hohfelds System der juristischen Grundbegriffe*, p. 84. De forma afirmativa ela é respondida, dentre outros, por Geo W. Goble, "Affirmative and negative legal relations", *Illinois Law Quarterly* 4 (1922), pp. 94 e ss.; do mesmo autor, "Negative legal relations re-examined", *Illinois Law Quarterly* 5 (1922), pp. 37-38. É possível que, em face do Estado, uma ação *h* seja permitida a *a* mas que, em relação a terceiros, seja proibida. Nessa situação, é conveniente falar em duas relações jurídicas na qual *a* se encontra, das quais uma – a relação com o Estado – é o complemento, isto é, a negação, da relação de dever. Isso – e o fato de que com a aceitação de uma tal relação não está associada qualquer desvantagem – justifica tratar como relação também aquilo que surge da negação de uma relação, o que, de resto, corresponde à lógica geral das relações, de acordo com a qual "a negação (ou o complemento) de uma relação *R* (*R'*) é a relação que existe entre *x* e *y*, se '*xRy*' não for verdadeiro" (Günther Patzig, "Relation", in Hermann Krings/Michael Baumgartner/Christoph Wild (Orgs.), *Handbuch philosophischer Grundbegriffe*, v. 4, München: Kösel, 1973, p. 1.229).

Semelhantemente elementar é a segunda relação no quadrilátero de Hohfeld, que é a relação entre os correlativos jurídicos (*jural correlatives*), ou seja, entre o direito (*right*) e o dever (*duty*), de um lado, e o não-direito (*no-right*) e o privilégio (*privilege*), de outro lado. Como esclarecimento dessas relações será utilizada a possibilidade, mencionada anteriormente, de se tratar os direitos a algo como relações diádicas. No lugar de *RabG* utiliza-se, então, *RGab*, e no lugar de *ObaG* utiliza-se *OGba*. É facilmente perceptível que a correlatividade das relações *RG* e *OG* consiste tão-somente no fato de que *OG* é a relação conversa¹⁰⁰ a *RG*. Se *a* tem um direito em face de *b*, então, *b* tem o dever correspondente em face de *a*, e vice-versa. Nesse sentido, a relação expressa por *RG* é a relação conversa àquela expressa por *OG*, da mesma forma que a relação professor/aluno é conversa à relação aluno/professor. Se *a* é o professor de *b*, então, *b* é o aluno de *a*, e vice-versa. Isso corresponde ao que Hohfeld diz: "se X tem um direito contra Y que obrigue o último a ficar longe das terras do primeiro, o correlativo (e equivalente) é que Y tem o dever em relação a X de ficar fora de sua propriedade".¹⁰¹

A parte mais interessante do esquema de Hohfeld é aquilo que ele denomina "privilégio" (*privilege*). Um privilégio é, para usar as palavras de Hohfeld, "a mera negação de um dever", a qual, como visto acima, deve ser representado por $\neg ObaG$. Na explanação acerca das modalidades deônticas básicas ficou claro que a negação de um dever de fazer algo é equivalente à permissão de não fazê-lo, ou seja, que vale:

$$(11) \neg Op \leftrightarrow P \neg p.^{102}$$

Essa lei pode ser representada com operadores triádicos:

$$(12) \neg OabG \leftrightarrow Pab \neg G.^{103}$$

100. Sobre o conceito de relação conversa, cf. Günther Patzig, "Relation", p. 1.229; Alfred Tarski, *Einführung in die mathematische Logik*, 2ª ed., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966, p. 102.

101. Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", p. 38.

102. O privilégio de Hohfeld é, portanto, nada mais que uma permissão. Como designação para uma simples permissão, o termo "privilégio" pode gerar confusões. Sobre isso, cf. Glanville Williams, "The concept of legal liberty", in Robert S. Summers (ed.), *Essays in Legal Philosophy*, Oxford: Blackwell, 1968, pp. 124-125.

103. Contra a equivalência entre a negação de um dever e a negação do privilégio, defendida por Hohfeld, Anderson suscita a objeção de que a segunda implica a

Um exemplo:

(13) Se, e somente se, em face do Estado *a* não está obrigado a se associar, a *a* é, então, permitido, em face do Estado, associar-se.

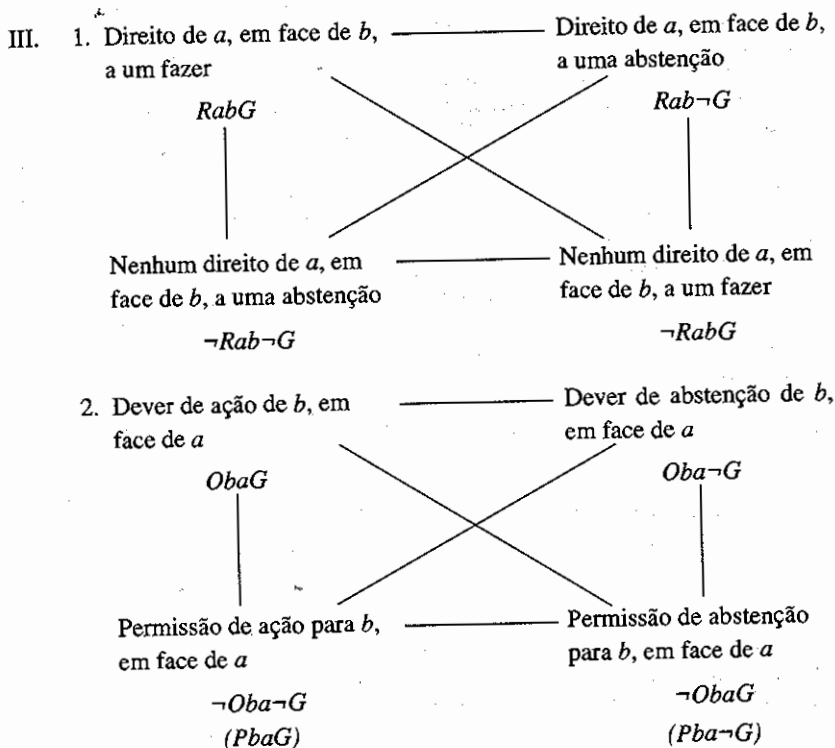
O esquema de Hohfeld pode, então, ser representado da seguinte forma:

II.	<i>RabG</i>	$\leftrightarrow$	<i>ObaG</i>
	$\neg$		$\neg$
	$\neg RabG$	$\leftrightarrow$	<i>Pba</i> $\neg G$

Ao se escrever dessa forma, surge uma peculiar desordem. Isso é assim menos porque uma posição é representada por um novo símbolo

primeira, mas a primeira não implica a segunda. Como exemplo, ele alega que do fato de que *a* não esteja obrigado a zelar para que a grama de *b* não seja aparada não decorre que a *a* seja permitido aparar a grama de *b* (cf. Alan R. Anderson, "Logic, norms, and roles", pp. 44-45 e 48). De fato, a permissão utilizada no exemplo não decorre da proposição que a precede sobre a negação de uma obrigação. Isso reside no fato de que os objetos da obrigação e da permissão são de espécies bastante distintas. Para demonstrar isso será utilizado o operador de ação *Do* para a cláusula "zelar para que" (*see to it that*) (cf., nesse sentido, Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 65 e ss.). Para o objeto desse operador, utilizar-se-á simplesmente *p*. O primeiro enunciado, então, tem a forma $\neg OaDo\neg p$; o segundo, a forma *PaDop*. $\neg OaDo\neg p$ é equivalente a *Pa* $\neg Do\neg p$, e isso é também pressuposto por Anderson. *PaDop* decorreria de *Pa* $\neg Do\neg p$, se $\neg Do\neg p$ e *Dop* dissessem a mesma coisa. Mas é fácil perceber que $\neg Do\neg p$ significa algo diverso de *Dop*, já que não se pode zelar para que o vizinho não beba mesmo que não se zele para que ele beba; o primeiro pode ser também realizado quando nada se faz. Isso faz com que fique claro que o problema suscitado por Anderson se baseia em problemas da lógica das ações. Desde que se tome o cuidado de que, nas transformações no esquema de Hohfeld, os objetos de direitos, deveres e permissões sejam sempre negados em sua inteireza (externamente) e que nenhuma negação seja inserida nos enunciados de ação (negação interna), então, as transformações deixam de criar dificuldades. Se *a* não está obrigado a zelar para que a grama de *b* não seja aparada, então, é permitido a *a* não zelar para que a grama de *b* não seja aparada, e se *a* não está obrigado a zelar para que a grama de *b* seja aparada, então, a *a* é permitido não zelar para que a grama de *b* seja aparada. Essa solução evita os problemas suscitados por Anderson, mas também mostra que a lógica do esquema de Hohfeld não capta a estrutura do objeto do direito, a não ser por meio de negações externas bastante rudimentares. Como aqui não é necessária uma lógica de ações que torne isso possível, essa limitação pode ser aceita. Além disso, essa renúncia custa pouco, porque uma inclusão da lógica das ações não significaria uma modificação, mas apenas um refinamento do modelo. Sobre esse tipo de modelo mais refinado, cf. Stig Kanger/Helle Kanger, "Rights and parliamentarism", pp. 87 e ss., e Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 66 e ss.

lo, o operador triádico de permissão, e mais porque o objeto da permissão aparece como negado ($\neg G$).¹⁰⁴ Isso aponta para uma incompletude fundamental do esquema. Permitido pode ser não apenas uma abstenção, mas também um fazer. Uma incompletude equivalente também pode ser constatada nas três outras posições do esquema de Hohfeld. Mas a eliminação dessas incompletudes não derruba o esquema; na verdade, ela conduz a um esquema duplo, que demonstra a fecundidade das concepções de Hohfeld.¹⁰⁵ Nesse esquema duplo, a ação e a abstenção são sempre uma ação e uma abstenção de b .



104. Isso equivale exatamente à explicação feita por Hohfeld para a sua constatação de que "um dado privilégio é a mera negação de um dever": "a menção é, obviamente, a um dever que tenha um conteúdo ou um sentido exatamente *oposto* àquele do privilégio em questão" (Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", p. 39).

105. Cf., a respeito, Frederic B. Fitch, "A revision of Hohfeld's theory of legal concepts", *Logique et Analyse* 10 (1967), pp. 270 e ss.

As relações *no interior* de ambos os esquemas parciais correspondem às relações do quadrado da lógica deôntica, apresentado anteriormente;¹⁰⁶ as relações *entre* ambos os esquemas parciais são caracterizadas pela equivalência entre as posições no interior de um e a posição correspondente no interior do outro, porque elas se referem à respectiva relação conversa.¹⁰⁷ Por isso, em seu conjunto, os esquemas parciais podem ser designados como “conversos”.¹⁰⁸

106. Cf., neste Capítulo, II.1.2.1.

107. Hohfeld considera que suas relações são “relações jurídicas estritamente fundamentais (...) *sui generis*” (cf. Wesley N. Hohfeld, “Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning”, p. 36). Como o esquema demonstra, isso não pode significar que elas não sejam mutuamente definíveis.

108. Com isso demonstra-se, para o âmbito do direito a algo, a correção da tese da redução, a qual sustenta que é suficiente apenas *uma* modalidade deôntica básica (cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 117-118). Visto que todas as posições no esquema parcial relativo aos direitos são equivalentes a posições no esquema parcial relativo aos deveres, e visto que todas as posições no esquema parcial relativo aos deveres podem ser expressas com o auxílio do operador deôntico triádico de mandamento, então, todos os enunciados sobre direitos a algo podem ser transformados em enunciados sobre obrigações relacionais formuladas com o auxílio do operador deôntico triádico de mandamento. Mas isso mostra apenas a possibilidade da redução ao operador deôntico triádico de mandamento. É necessário indagar como este se relaciona com o operador monádico do sistema padrão. Isso depende da interpretação dos enunciados formados por operadores monádicos. São possíveis uma interpretação fraca e uma interpretação forte. Limitando-se apenas aos dois enunciados mais importantes, na interpretação *fraca*, *OG* e *PG* são, em relação a *OabG* e *PabG*, apenas abstrações que dizem respeito ao aspecto relacional. Nessa interpretação, pode-se dizer que *OabG* implica *OG* e que *PabG* implica *PG*. Na interpretação *forte*, *OG* e *PG* dizem que *G* – por exemplo, a realização da ação *h* por parte de *a* – é, em sua inteireza, respectivamente obrigatória ou permitida pelo sistema jurídico. Nessa interpretação, embora *OabG* implique *OG*, *PabG* não implica *PG*. Se *a* está juridicamente obrigado, em face de *b*, a realizar a ação *h* (*OabG*), então, é obrigatório, nesse sistema jurídico, que *a* realize *h* (*OG*). Se, nesse sistema jurídico, não for obrigatório que *a* realize *h*, então, *a* não está obrigado a isso, mesmo em face de *b*. A referência a obrigações relacionais reciprocamente contraditórias não constitui uma objeção contra a implicação de *OG* por *OabG*. Se, em um mesmo momento, *a* está obrigado a *G* em face de *b* e, em face de *c*, a $\neg G$, o que significa que tanto *OabG* quanto *Oac $\neg G$ são verdadeiros, é mesmo assim possível aceitar que tanto *OG* quanto *O* $\neg G$ sejam verdadeiros na interpretação forte, pois o sistema jurídico, como um todo, contém, então, uma contradição. Se a contradição entre as obrigações relacionais é solucionada, também o é aquela entre obrigações não-relacionais. Já a relação entre a permissão relacional (*PabG*) e a permissão não-relacional (*PG*) não é tão simples na interpretação forte. O fato de que, em face de *b*, a *a* seja permitido realizar *h* não significa que o sistema jurídico como um todo permita a realização de *h* por parte*

O esquema duplo pode ser visto como uma explicação do conceito de direito a algo no âmbito de um sistema lógico que, embora elementar, em geral é suficiente para fins práticos.¹⁰⁹ É certo que os conhecimentos que dele se extraem – por exemplo, de que a negação de um direito (o não-direito) de *a* em face de *b* a uma abstenção ($\neg Rab \rightarrow G$) é equivalente à permissão, para *b*, de uma ação em face de *a* ($PbaG$) – não conduzem a uma decisão em casos polêmicos – o que, de resto, nunca ocorre com conhecimentos analíticos –, já que, para tanto, são imprescindíveis valorações e conhecimento empírico; mas eles constituem a base necessária para uma argumentação jurídica racional que tenha pretensões de um máximo de clareza. Isso vale em medida muito especial para o segundo grupo de posições jurídicas fundamentais, o grupo das liberdades, que será tratado a seguir, do qual um aspecto essencial já foi abordado quando foram feitas considerações sobre o conceito de privilégio de Hohfeld, que se mostrou reduzível ao conceito de permissão.

de *a*. O sistema jurídico como um todo proíbe a realização de *h* por parte de *a* se *a* estiver obrigado, em face de *c*, a se abster de realizar *h* ($Oac \rightarrow G$). Aquele que, em uma relação, viola uma proibição desrespeita o sistema jurídico. Aquele que, em uma relação, exercita uma permissão não precisa fazer algo que seja permitido pelo sistema jurídico como um todo. Se houver ao menos um sujeito de direito em face do qual *a* esteja juridicamente obrigado a realizar *h*, então, o sistema jurídico como um todo contém o mandamento para que *a* realize *h* (OG). Por outro lado, *a* é somente então permitido, pelo sistema jurídico como um todo, realizar *h* (PG), se houver para tanto uma permissão a *a* em todas as relações.

As relações entre modalidades deonticas relacionais e não-relacionais são, portanto, complexas. Ainda assim fica claro que as modalidades relacionais não podem ser substituídas pelas não-relacionais e, nesse sentido, ser a elas reduzidas. Tudo aquilo que pode ser dito com o auxílio de modalidades não-relacionais pode também o ser com o auxílio das modalidades relacionais. Com isso, fica clara a correção da tese da redução. A redução a uma modalidade deontica é possível; é certo que essa modalidade deve ser internamente diferenciada (relacionada), mas isso não requer nenhum conceito normativo adicional. Para o âmbito dos direitos a algo demonstrou-se, portanto, que existe aquilo que se pode chamar de “unidade do dever-ser”.

109. Estruturas sensivelmente mais complexas são obtidas quando, para o objeto do direito, não é utilizado apenas *G*, mas se decompõe essa expressão em partes menores. Esse caminho é trilhado por Kanger/Kanger e por Lindahl, que baseiam suas análises não apenas em uma lógica das modalidades deonticas, mas em uma combinação da lógica deontica com uma lógica das ações (cf. Stig Kanger/Helle Kanger, “Rights and parliamentarism”, pp. 87 e ss., e Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 66 e ss.). Aqui, o modelo simples apresentado é suficiente.

2. *Liberdades*

2.1 *Sobre o conceito de liberdade*

O conceito de liberdade é, ao mesmo tempo, um dos conceitos práticos mais fundamentais e menos claros. Seu âmbito de aplicação parece ser quase ilimitado. Quase tudo aquilo que, a partir de algum ponto de vista, é considerado como bom ou desejável é associado ao conceito de liberdade.¹¹⁰ Isso vale tanto para disputas filosóficas quanto para polêmicas políticas. Isso é expresso de maneira aguçada por Aldous Huxley, em seu *Eyeless in Gaza*: "Liberdade é um nome maravilhoso. É por isso que você está tão ansioso para fazer uso dele. Você acha que, se você chamar o encarceramento de verdadeira liberdade, as pessoas ficarão atraídas pela prisão. E o pior de tudo é que você tem razão".¹¹¹ A conotação emotiva da palavra "liberdade" dificilmente poderia ser caracterizada de forma mais precisa. Em geral, quem denomina algo como "livre" não faz apenas uma descrição, mas expressa também uma valoração positiva e suscita, no ouvinte, um estímulo para compartilhar desse valor.¹¹² A conotação emotiva positiva, relativamente constante, pode ser associada a significados descritivos cambiantes. Isso abre a possibilidade de uma definição persuasiva (*persuasive definition*).¹¹³ Quem quer induzir alguém a uma determinada ação pode tentar fazê-lo dizendo que liberdade é realizar essa ação. Essa deve ser uma das razões para a perenidade da polêmica acerca do conceito de liberdade e a popularidade de sua utilização.

Uma análise de tudo aquilo que esteve ou está associado ao termo "liberdade" conduziria a uma extensa filosofia jurídica, social e moral. Aqui interessam apenas as posições jurídicas fundamentais. Nesse contexto, o primeiro plano é ocupado por um determinado conceito de liberdade: o conceito de *liberdade jurídica*. Esse conceito pode ser

110. Isaiah Berlin ("Two concepts of liberty", in Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, 1969, p. 121) fala de "mais de duzentos sentidos, registrados pelos historiadores das idéias, para essa palavra multifórmica".

111. Aldous Huxley, *Eyeless in Gaza*, London: Chatto & Windus, 1955, p. 123.

112. Cf. Charles L. Stevenson, *Ethics and Language*, New Haven: Yale University Press, 1944, pp. 20 e ss. e 206 e ss.

113. Cf. Charles L. Stevenson, "Persuasive definitions", *Mind* 47 (1938), pp. 331 e ss. Cf. já Thomas Hobbes, *Leviathan*, II, 21 (Oxford: Oxford University Press, 1960, p. 140): "é fácil o homem ser induzido a erro pelo enganoso nome da liberdade".

explicado de duas maneiras. É possível representá-lo como uma manifestação especial de um conceito mais amplo de liberdade, mas é também possível fundamentá-lo diretamente a partir do conceito que para ele é constitutivo, o conceito de permissão jurídica.

O primeiro caminho pode ser trilhado não apenas se se perguntar o que é liberdade *em si* – isso conduziria, como já foi salientado, a um ambicioso projeto de uma filosofia da liberdade; ele pode também ser trilhado a partir da indagação acerca da *estrutura* do conceito de liberdade – isso é menos ambicioso, mas, por isso, as perspectivas de êxito são maiores e, além disso, são criadas condições para uma resposta a questões mais amplas. A pergunta acerca da estrutura da liberdade pode ser dada, em um primeiro momento, uma resposta de cunho negativo. A liberdade não é um objeto como, por exemplo, um chapéu. É certo que é possível falar da liberdade que alguém *tem*, da mesma forma que se fala de um chapéu que se tem. Mas, no caso da liberdade, esse “ter” não se refere a uma relação de posse entre uma pessoa e um objeto. Por isso, parece plausível supor que a liberdade é uma qualidade, uma qualidade que, por exemplo, pode ser atribuída a pessoas, ações e sociedades. Essa seria, no entanto, uma perspectiva bastante rudimentar e superficial. Quem diz que uma pessoa é livre pressupõe que, para essa pessoa, não existem embaraços, restrições ou resistências de qualquer espécie.¹¹⁴ Com isso, poder-se-ia considerar liberdade como uma relação diádica entre uma pessoa e um embaraço à liberdade. Mas isso também não é suficiente. Se se imagina que o Estado (*s*) quer obstruir *a* de visitar *b* no exterior, *s* poderia fazer isso simplesmente ao proibir a visita de *a*, mas *s* pode também fazê-lo negando-lhe divisas, impedindo-o de comprar passagens de avião, excluindo-o do exercício de uma profissão caso a visita se concretizar ou convocando-o para exercícios militares. Nesses casos, a ausência de liberdade tem características diferentes. Um enunciado com a estrutura “*a* não é livre para visitar *b*” não contempla essa diversidade. Mesmo enunciados como “*a* não é livre para comprar uma passagem de avião” não descrevem a situação de forma completa. A situação só

114. A ausência de obstáculos, restrições ou resistências constitui o cerne do conceito de liberdade. Cf. a definição clássica em Thomas Hobbes, *Leviathan*, II, 21 (p. 136): “Liberdade [*liberty or freedom*] designa exatamente a ausência de oposição”. O que se deve indagar é o que deve ser identificado como obstáculo e a que ele se refere.

O que aqui interessa é a liberdade jurídica. Como será visto adiante, só se falará em liberdade jurídica quando o objeto da liberdade for uma alternativa de ação. Se o objeto da liberdade é uma alternativa de ação, falar-se-á em uma "liberdade *negativa*". Uma pessoa é livre em sentido negativo na medida em que a ela não são vedadas alternativas de ação. O conceito negativo de liberdade nada diz acerca daquilo que uma pessoa que é livre em sentido negativo deve fazer ou, sob certas condições, irá fazer; ele diz apenas algo sobre suas *possibilidades* de fazer algo.¹²² O conceito mais amplo de liberdade, do qual a liberdade jurídica é uma manifestação especial, é, por isso, uma relação triádica, cujo terceiro elemento é uma *alternativa de ação*. Partindo-se disso, um enunciado sobre liberdade ou tem a seguinte forma:

(1) x é livre (não-livre) de y para fazer z ou para não fazer z ,¹²³

ou pode ser reduzido a um enunciado dessa forma.¹²⁴ Aqui, x simboliza o titular da liberdade (ou da não-liberdade), y simboliza o obstáculo à liberdade e z simboliza a ação cuja realização ou não-realização é o objeto da liberdade.

De acordo com o que foi até agora afirmado, a distinção entre liberdade positiva e liberdade negativa reside somente no fato de que no caso da primeira o objeto da liberdade é uma única ação, enquanto no caso da segunda ele consiste em uma alternativa de ação. Esses conceitos de liberdades positiva e negativa não coincidem sob todos os aspectos com seu uso na linguagem corrente. O conceito de liberdade

with negative liberty", in Alan Ryan, *The Idea of Freedom: Essays in Honour of Isaiah Berlin*, Oxford: Oxford University Press, 1979, pp. 175 e ss.

122. Cf. Isaiah Berlin, "Introduction", in *Four Essays on Liberty*, p. XLII: "A liberdade da qual eu falo é, mais que a ação em si mesma, a oportunidade para a ação".

123. A relação que subjaz a esse enunciado não deve ser confundida com a relação triádica de liberdade de von Freytag Löringhoff. Segundo ele, a relação de liberdade tem a seguinte forma: "X é livre em face da vinculação inferior Y por meio da vinculação superior Z" (Bruno v. Freytag Löringhoff, "Die logische Struktur des Begriffs Freiheit", in Josef Simon (Org.), *Freiheit*, Freiburg: Alber, 1977, p. 43). Essa concepção expressa a hipótese substancial de que alguém "só pode se libertar [de uma vinculação] por meio da aceitação de uma vinculação nova, e de hierarquia superior" (idem, p. 42). Aqui, não se compartilha com essa hipótese. A relação de liberdade que aqui se pressupõe é neutra não apenas em face da questão "por meio de quê", mas também em face da questão "para quê", a qual introduz um elemento de dever no conceito de liberdade.

124. Sobre a redução de enunciados sobre liberdade a enunciados dessa forma, cf. Gerald C. MacCallum Jr., "Negative and positive freedom", pp. 315 e ss.

negativa aqui fixado é mais amplo que o habitual, enquanto o conceito de liberdade positiva é mais restrito. O já utilizado exemplo da emigração pode tornar isso claro. O objeto da liberdade é a alternativa de ação emigrar ou não emigrar. Aqui, interessam apenas dois dos diversos obstáculos a que uma pessoa *a* pode ser submetida em relação a essa alternativa de ação. A emigração de *a* pode ser juridicamente proibida, mas pode ser também que ela não seja possível em razão de falta de dinheiro. No primeiro caso existe uma não-liberdade jurídica; no segundo caso, uma econômica. Ambos os casos, contudo, enquadram-se no conceito de liberdade negativa aqui desenvolvido. A partir de um uso lingüístico muito difundido, somente a liberdade jurídica seria caracterizada como "liberdade negativa". A econômica seria, quando muito, classificada como liberdade positiva. A distinção corrente tem sua justificativa. Para que *a* passe de uma situação de não-liberdade econômica para uma situação de liberdade econômica, ele tem que obter ou adquirir algo. Se a transformação da situação de não-liberdade econômica em uma situação de liberdade econômica tiver que ocorrer de uma forma juridicamente garantida pelo Estado, então, a ele pode ser concedido um direito a uma prestação em face do Estado, ou seja, um direito a uma ação estatal *positiva*. Já para a criação de uma situação de liberdade jurídica é necessária, ao contrário, apenas uma abstenção estatal, ou seja, uma ação *negativa*. Para a garantia da liberdade não é necessário um direito a prestações, apenas um direito de defesa. É inegável que essa diferença tem grande importância. O que se deve indagar é como as construções conceituais devem reagir a essa diferença. Com base na tradição, tanto a concepção ampla de liberdade negativa, apresentada anteriormente, quanto a concepção restrita, que se acaba de mencionar, podem suscitar uma pretensão ao predicado "negativa", e em ambos os casos a distinção entre liberdade positiva e liberdade negativa tem um significado fundamental. Nessa situação, parece ser apropriado que se fale em *liberdade negativa em sentido amplo* e *liberdade negativa em sentido estrito*. A liberdade negativa em sentido estrito equivale à concepção liberal de liberdade. Uma liberdade negativa em sentido estrito é sempre também uma liberdade negativa em sentido amplo, mas nem toda liberdade negativa em sentido amplo é também uma liberdade negativa em sentido estrito.

Uma liberdade negativa em sentido estrito deriva da relação triádica de liberdade quando o objeto da liberdade são alternativas de ação

e o obstáculo à liberdade são ações obstaculizadoras de terceiros, sobretudo do Estado. A fecundidade da concepção triádica de liberdade é demonstrada pelo fato de que diferentes conteúdos x , y e z fazem surgir diferentes liberdades. Com base nessa concepção é possível organizar a confusão de conceitos de liberdade, pois ela possibilita a criação de uma classificação abrangente, por meio de substituições cada vez mais diferenciadas para o titular da liberdade (x), para o obstáculo à liberdade (y) e para o objeto da liberdade (z). Apenas dois exemplos: se se utiliza y como uma situação de escassez econômica, surge um conceito de liberdade que pode ser denominado de conceito sócio-econômico de liberdade.¹²⁵ Esse conceito sócio-econômico de

125. Que uma situação de escassez econômica pode obstaculizar a em relação a uma alternativa de ação é algo de que não se duvida. Mas é possível questionar se isso justifica designar a como "não-livre". Nesse ponto, três observações são necessárias. (1) Normas de direitos fundamentais devem garantir liberdade. Se se denomina a ausência de uma situação de escassez econômica como "liberdade", daí parece decorrer que normas de direitos fundamentais devem garantir isso também, ou seja, devem ser interpretadas no sentido dessa garantia. Aquele que pretendesse fazer objeções à conclusão desse argumento, esboçado aqui de forma rudimentar, poderia sustentar que não seria possível falar em liberdade ou em não-liberdade no contexto de situações de escassez econômica. Mas isso não é de forma alguma necessário. A conclusão mencionada pode também ser rejeitada se se define com mais precisão que tipo de liberdade as normas de direitos fundamentais devem garantir. (2) Em inúmeros contextos o conceito de liberdade está associado a uma conotação emotiva positiva. Por isso, qualquer definição do conceito de liberdade é suspeita de ser uma definição persuasiva, por meio da qual se pretende, sem argumentos, conquistar apoio em relação a uma valoração. Isso não exclui, contudo, a possibilidade de um uso explicitamente não-valorativo do conceito de liberdade. Se a não dispõe de meios para comprar um carro maior, a é, em um determinado sentido, economicamente não-livre, mas isso não é algo a ser necessariamente condenado. Se, em relação à compra do automóvel, a é designado, sem juízos de valor, como "economicamente não-livre", então, esse conceito é utilizado de forma puramente analítica ou classificatória. Uma tal utilização é possível e apropriada se uma análise da estrutura dos objetos a serem valorados precede à valoração. (3) Com frequência a ausência de determinadas situações de escassez é designada não como liberdade, mas como condição para o exercício ou para o valor da liberdade (cf. Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty*, pp. XLVI e LIII-LIV; John Rawls, *A Theory of Justice*, pp. 204-205; Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, Stuttgart: Kohlhammer, 1974, p. 50). Esses conceitos expressam uma preferência por um determinado tipo de liberdade: a liberdade em sentido estrito negativa ou liberal. Mas também aquele que queira manter essa preferência pode dizer – caso utilize o conceito de liberdade de forma não valorativa, mas analítica – que a liberdade econômica é condição para o exercício ou o valor da liberdade liberal.

liberdade deve ser claramente distinguido do conceito liberal-econômico de liberdade, o qual surge quando se substitui y por ações obstaculizadoras de terceiros, sobretudo do Estado, e z por alternativas econômicas de ação. Se se representa y por obstáculos na formação da vontade política e z por alternativas de ação política, obtém-se, então, um conceito negativo e democrático de liberdade.¹²⁶ Isso é suficiente para mostrar como, por meio de substituições cada vez mais diferenciadas na relação triádica, pode surgir uma tabela de todas as liberdades possíveis. É inegável a utilidade de uma tal tabela em um âmbito conceitualmente tão instável quanto o da liberdade. Equivocado seria pensar que com uma tal tabela, por meio de uma clarificação conceitual, as valorações seriam antecipadas. O que ocorre é o contrário. Dentre as posições em uma tabela de liberdades, algumas podem ser avaliadas como positivas; outras podem ser avaliadas como negativas e descartadas. Algumas podem ser atribuídas a normas de direitos fundamentais ou à constituição como um todo; outras, não. Entre as posições podem ser estabelecidas relações de preferência e, não menos importante, torna-se possível analisar as relações lógicas e empíricas entre as diferentes posições sobre uma base conceitualmente segura.

No que se segue, o interesse recai apenas sobre uma posição na tabela de liberdades, a liberdade *jurídica*. Como exemplo, utilizar-se-á a seguinte liberdade, construída a partir de substituições no enunciado relacional (1):

(2) *a* está livre de proibições jurídicas para expressar ou não expressar sua opinião.

Esse enunciado é equivalente a:

126. O conceito negativo e democrático de liberdade é, enquanto subespécie do conceito negativo de liberdade, um *conceito baseado em possibilidades*. Ao conceito democrático de liberdade enquanto conceito baseado em possibilidades é possível contrapor um conceito democrático de liberdade como *conceito baseado na realidade*. De acordo com este último, liberdade democrática não existe com a simples inexistência de obstáculos às ações de participação política; ela surge apenas quando essas ações são de fato realizadas. Um tal conceito de liberdade democrática baseado na realidade é uma variante do conceito *positivo* de liberdade. Um exemplo de conceito democrático de liberdade como conceito baseado na realidade é oferecido por Ulrich Scheuner, "Pressefreiheit", *VVDStRL* 22 (1965), p. 20: "Liberdade não [é] (...) apenas defesa e fuga para uma esfera livre do Estado e sem responsabilidades, mas uma participação viva no todo, configuração e responsabilidade compartilhadas".

- (3) É (juridicamente) permitido que *a* expresse sua opinião, e é (juridicamente) permitido que *a* deixe de expressar sua opinião.

O enunciado (3) expressa a liberdade jurídica da forma mais simples e clara. A transformação de (2) em (3) é possível porque entre o obstáculo à liberdade e o objeto da liberdade existe uma relação *analítica*. A proibição jurídica é exatamente a proibição do objeto da liberdade. No caso de liberdades não-jurídicas a questão é mais complicada. Entre o obstáculo e o objeto existe apenas uma relação *empírica*. É essa especificidade da liberdade jurídica que possibilita que a análise do conceito de liberdade jurídica se baseie diretamente no conceito de permissão, em vez de baseá-lo na relação triádica geral de liberdade.

Apoiando-se e, ao mesmo tempo, apartando-se do conceito de liberdade jurídica é possível construir um conceito de liberdade *fática*, o qual tem especial importância para as análises jurídicas, como um conceito contraposto ao conceito de liberdade jurídica:

- (4) Em relação a uma alternativa de ação juridicamente livre, *a* é faticamente livre na medida em que tem a possibilidade real de fazer ou deixar de fazer aquilo que é permitido.

2.2 Liberdades jurídicas

A conexão entre os conceitos de liberdade jurídica e de permissão no sentido de negação de deveres e proibições é frequentemente descrita, e de diversas formas. Hobbes afirmava: "Nos casos nos quais o soberano não prescreveu nenhuma regra, o sujeito tem a liberdade de agir ou de se abster de acordo com a sua própria discricionariedade".¹²⁷ Segundo a formulação de Bentham, desde que o legislador "não tenha ordenado ou proibido nenhum ato (...) todos os atos são livres: todas as pessoas estão em liberdade em face da lei".¹²⁸ Em Jellinek se lê: "Se se examina essa liberdade em sua face jurídica, então, chega-se à conclusão de que ela coincide com as ações dos súditos que são *juridicamente irrelevantes* para o Estado".¹²⁹ No entanto, uma olhada mais atenta deixaria claro que, apesar das semelhanças, as posições que

127. Thomas Hobbes, *Leviathan*, II, 21, p. 143.

128. Jeremy Bentham, *Of Laws in General*, p. 253.

129. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 104.

podem ser designadas como “liberdade jurídica” são de tipos bastante diversos. Para compreendê-las, é necessário distinguir entre liberdades jurídicas *protegidas* e *não-protegidas*.¹³⁰

2.2.1 Liberdades não-protegidas

As liberdades não-protegidas podem ser totalmente reduzidas às permissões no sentido definido anteriormente. Permitidos podem ser tanto um *fazer* quanto um *não-fazer*. Se a liberdade jurídica for uma liberdade negativa no sentido explicado acima, então, ela não pode se esgotar nem em um, nem em outro.¹³¹ A simples permissão para professar uma crença, que pode coexistir com a obrigação de fazê-lo, não cria uma liberdade jurídica, tanto quanto não a cria a simples permissão de não professar uma crença, que é conciliável com a proibição de professá-la. Uma liberdade jurídica de professar uma crença surge apenas quando – mas também sempre quando – é não apenas permitido fazê-lo, mas também não o fazer.¹³² Nesse sentido, a liberdade jurídica não-protegida, que é totalmente reduzível a permissões, pode ser definida como uma conjugação de uma permissão jurídica de se fazer algo e uma permissão jurídica de não o fazer. Essa conjugação foi designada acima como “faculdade” e simbolizada por *Lp*.¹³³ Se, para facilitar a comparação com o direito a algo (*RabG*), se utiliza a letra *G* ao invés de *p*, e se se pressupõe que *P* simboliza uma permissão *jurídica*, então, a definição da liberdade jurídica não-protegida toma a seguinte forma:

$$(1) LG =_{df} PG \wedge P \neg G.$$

A negação da liberdade não-protegida é a *não-liberdade*. Por meio da utilização do símbolo de disjunção “ $\vee$ ” no lugar de “ou”, ela deve ser definida da seguinte forma:

130. Jeremy Bentham diferencia entre liberdades “nuas” (*naked*) e “cobertas” (*vested*) (Jeremy Bentham, in *The Work of Jeremy Bentham* (ed. J. Bowring), fac-símile da edição de 1835-1843, v. 3, New York: Russell & Russell, 1962, p. 218). Essa diferenciação aproxima-se da diferenciação utilizada aqui entre liberdade protegida e liberdade não protegida.

131. Um conceito estrito de liberdade jurídica é utilizado por Glanville Williams, “The concept of legal liberty”, pp. 132-133. Para ele a liberdade jurídica consiste somente na negação da proibição e é, por isso, compatível com um mandamento.

132. Cf. *BVerfGE* 12, 1 (4).

133. Cf., neste Capítulo, II.1.2.1.

$$(2) \neg LG =_{df} O \neg G \vee \neg OG.$$

Nesse sentido, um sujeito de direito *a* não é juridicamente livre ($\neg LG$), no que diz respeito a uma determinada ação, se a abstenção ($O \neg G$) ou a realização dessa ação lhe é juridicamente obrigatória.

2.2.1.1 *Liberdades não-protegidas absolutas e relativas relacionadas a pessoas e objetos*

Em (1), *L* é um operador não-relacional (monádico) Mas liberdades podem ser relacionais. Assim é que *a* pode ser livre, em face do Estado, para fazer *h*, mas não ser livre em face de um terceiro, e vice-versa. Para expressar que um sujeito de direito se encontra em uma posição de liberdade não-protegida em face de outro sujeito de direito é necessário utilizar um operador triádico, como no caso do direito a algo. A liberdade não-protegida relacional tem a seguinte estrutura:

$$(3) LabG =_{df} PabG \wedge Pab \neg G.$$

Esse enunciado (3) expressa uma liberdade não-protegida apenas em face de um sujeito de direito, como, por exemplo, o Estado ou uma determinada pessoa privada. Um contraponto a isso é a liberdade não-protegida em face de todos os sujeitos de direito. Essa liberdade é um feixe composto exatamente do mesmo número de relações de liberdade correspondente ao número de sujeitos de direito no sistema jurídico. Ela deve ser denominada "liberdade absoluta em relação a pessoas".¹³⁴ Do outro lado está a liberdade relativa em relação a pessoas, que não existe em face de todos, mas somente de alguns – no mínimo, um – sujeitos de direito.

Os contrapontos aos conceitos de liberdade absoluta e de liberdade relativa em relação a pessoas são os conceitos de liberdade absoluta e de liberdade relativa em relação a objetos. *a* tem, em face de *b*, uma liberdade absoluta em relação a objetos se a *a* é permitido, em face de *b*, realizar ou não realizar toda e qualquer ação; ele tem, em face de *b*, uma liberdade relativa em relação a objetos se a ele é permitido, em

134. A liberdade absoluta em relação a pessoas pode ser simbolizada, com o auxílio do quantificador universal (*x*) (para todo *x*...; cf., a esse respeito, W. V. O. Quine, *Grundzüge der Logik*, pp. 121 e ss.), da seguinte forma:

(*x*)*LaxG*.

face de *b*, realizar ou não realizar pelo menos uma ação. Se todos forem jurídica e absolutamente livres em relação a pessoas, está-se diante da situação normativa suposta por Hobbes no estado de natureza.¹³⁵

2.2.1.2 A liberdade não-protégida como mera negação do dever-ser

A definição de liberdade não-protégida (*LG*) por meio da conjunção entre a permissão de um fazer e a permissão de um não-fazer ($PG \wedge P \neg G$) torna claro que a liberdade não-protégida consiste na mera ligação da permissão positiva com a permissão negativa. Mas essas permissões nada mais são que a negação dos deveres (*OG*) e proibições ($P \neg G$) correspondentes. Em vez de $PG \wedge P \neg G$, *LG* poderia ser igualmente definida como $\neg O \neg G \wedge \neg OG$. Isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, que a introdução do conceito de liberdade não-protégida não significa a introdução de uma categoria independente em relação ao dever-ser no sentido de um mandamento. Do ponto de vista lógico, liberdades não-protégidas nada mais são que uma determinada combinação de negações do dever-ser. Não se toma, com isso, partido na disputa sobre se, em ordenamentos normativos, o conceito primário é a liberdade, a qual é restringida pelo dever-ser, ou se o conceito primário é o dever-ser, o qual cria a liberdade por meio de não-deveres e não-proibições. A neutralidade do conceito de liberdade não-protégida diante dessa questão pode ser percebida no fato de que para o conceito de liberdade negativa não faz diferença se as liberdades são concebidas como negação do dever-ser ou o dever-ser como negação das liberdades. A possibilidade de se definir *LG* por meio de $\neg O \neg G \wedge \neg OG$ demonstra, em segundo lugar, que as liberdades não-protégidas não implicam o direito de não ser embaraçado no gozo dessas liberdades.¹³⁶ Um tal direito é um direito a algo e se distingue fundamentalmente de uma combinação de permissões. Se esse direito

135. Thomas Hobbes, *Leviathan*, I, 13, p. 85.

136. Cf., a esse respeito, Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions", p. 43, bem como Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, p. 324: "eu vou além e sustento que, ao mero poder fazer ou ser permitido nunca é contraposto um dever especial, específico, que a ele corresponde, mas, ao contrário, sempre que esse pareça ser o caso, está-se diante não de um mero poder fazer, mas também de uma pretensão".

estiver presente, a liberdade não-protetida transforma-se em liberdade protegida.

2.2.1.3 Normas constitucionais permissivas

Uma liberdade não-protetida existe caso tanto uma ação quanto a abstenção correspondente são qualificadas como permitidas. A qualificação de uma ação como permitida pode ocorrer por duas razões: ela pode basear-se em uma norma permissiva expressa ou ela pode ser fundamentada por meio da inexistência, no sistema jurídico, de normas mandatórias ou proibitivas no âmbito das quais se enquadrasse a ação ou a abstenção em questão.¹³⁷ No primeiro caso é possível falar

137. Neste caso, a qualificação baseia-se no enunciado "o que não é proibido é permitido" ($\neg O \neg p \rightarrow Pp$ ou $\neg Op \rightarrow P \neg p$). Este enunciado parece ser trivial, mas uma simples olhada na discussão a seu respeito faz com que surja a impressão oposta (cf., por exemplo, Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 85 e ss.; do mesmo autor, *An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action*, pp. 82 e ss.; Carlos E. Alchourrón/Eugenio Bulygin, *Normative Systems*, Wien: Springer, 1971, pp. 119 e ss.; Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 81; Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, pp. 170 e ss.). Um dos problemas que sempre dá ensejo a que se duvide do enunciado "o que não é proibido é permitido" é aquele que se refere à abertura do ordenamento jurídico. Assim, lê-se em Christiane Weinberger/Ota Weinberger (*Logik, Semantik, Hermeneutik*, p. 116): "O enunciado 'o que não é proibido é permitido' é válido apenas se se pressupõe que o sistema de normas é algo fechado, isto é, que, nesse sistema, devido é apenas aquilo que expressamente foi definido como tal". Isso é correto apenas a partir do pressuposto de que o enunciado "o que não é proibido é permitido" deva ser interpretado da seguinte forma: "o que não é expressamente proibido é permitido". Mas uma tal interpretação não é nem necessária, nem apropriada. Ao contrário, parece ser mais apropriado compreender o enunciado "o que não é proibido é permitido" da seguinte forma: "o que não é expressa ou tacitamente proibido é permitido". A partir dessa interpretação, esse enunciado é válido também em sistemas normativos abertos no que diz respeito à explicitação da normação. Ele expressa que, em um sistema normativo livre de contradições, uma ação deve ser sempre qualificada ou como proibida ou como permitida. Um problema adicional é suscitado por qualificações normativas retrospectivas. Mas também nesse ponto deve ser dito que toda ação deve ser qualificada, por um sistema jurídico livre de contradições *S*, no momento *ti*, apenas ou como proibida ou como permitida. Embora aquele que entende serem possíveis qualificações normativas retrospectivas possa afirmar que a ação *h*, até o momento *ti*, era permitida por *S* e que, depois do momento *ti*, passou a ser qualificada por *S* como proibida, ele não pode afirmar que ela, em um mesmo momento, por meio do mesmo sistema jurídico, era qualificada tanto como permitida quanto como proibida. Portanto, ele terá que aceitar $\neg(O \neg p \wedge Pp)$, do qual decorre $\neg O \neg p \rightarrow Pp$.

em uma permissão *explícita*; no segundo, em uma permissão *implícita*. Normas de direitos fundamentais são, na medida em que por meio delas algo é permitido, *normas permissivas explícitas*.

O conceito de norma permissiva sempre suscitou problemas. Sua formulação clássica pode ser encontrada em Kant: "Uma ação que não seja nem obrigatória nem proibida é meramente permitida, porque, em relação a ela, não há nenhuma lei restritiva da liberdade (competência) e, portanto, também nenhum dever. (...). Seria possível perguntar (...) se, para que alguém seja livre para fazer ou se abster segundo lhe aprouver, é necessária, além da lei mandatória (*lex praeceptiva*, *lex mandati*) e da lei proibitiva (*lex prohibitiva*, *lex vetiti*), também uma lei permissiva (*lex permissiva*)".¹³⁸ Uma resposta clara a essa pergunta pode ser encontrada em Thon. Segundo ele, a norma permissiva é "um enunciado completamente inútil e supérfluo".¹³⁹ O ordenamento jurídico cria "direito apenas por meio da imposição de deveres e proibições".¹⁴⁰ Permissões não seriam nada mais que a ausência de proibições. Direitos consistiriam apenas de deveres e proibições, os quais protegeriam a realização do que não é nem obrigatório, nem proibido.¹⁴¹ Contra essa tese da superfluidade das normas permissivas são suscitadas objeções, especialmente no que diz respeito às normas de direitos fundamentais. Normas de direitos fundamentais permissivas são normas de hierarquia constitucional, ou seja, normas do mais alto nível hierárquico. Normas proibitivas e normas mandatórias de nível inferior, que proíbem ou obrigam algo que as normas de direitos fundamentais permitem fazer ou deixar de fazer, são a elas *contrárias*, e, por isso, inconstitucionais. Nesse sentido, no âmbito da

138. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, p. 223.

139. August Thon, *Rechtsnorm und subjektives Recht*, Weimar: Böhlau, 1878, p. 292. Semelhante é a concepção de Joseph Raz, *The Concept of a Legal System*, pp. 172 e ss. Segundo Raz, a norma permissiva é aceitável somente se ela estabelecer exceções a normas mandatórias e proibitivas. Cf. também Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre*, 2ª ed., Einsiedeln: Benziger, 1948, p. 109 – o qual encara a norma permissiva como algo "juridicamente sem importância".

140. August Thon, *Rechtsnorm und subjektives Recht*, p. 288.

141. No âmbito dos direitos fundamentais essa concepção é defendida por Schwabe: "A permissão é, como já mencionado, objetivo e objeto protegido da pretensão de abstenção, mas não é uma categoria normativa independente. Portanto, ela não pode ser parte do direito fundamental subjetivo" (Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 46).

estrutura escalonada do ordenamento jurídico, as normas de direitos fundamentais permissivas têm a importantíssima função de estabelecer "os limites do dever-ser"¹⁴² em relação às normas de nível inferior. Essa função não pode ser realizada por meio da mera ausência de normas mandatórias ou proibitivas. Ela pode, contudo, ser realizada por meio de normas permissivas de proteção, ou seja, por meio de normas que proíbem ao Estado ordenar ou proibir determinadas ações, e por meio de normas negativas de competência, que retiram do Estado a competência para ordenar ou proibir determinadas ações. No entanto, esse tipo de normas permissivas de proteção não autoriza que se fale de uma contradição de uma norma infraconstitucional mandatória ou proibitiva em relação a uma norma de direito fundamental permissiva. Em relação a elas é possível falar apenas de uma violação, por parte do criador da norma, da norma proibitiva a ele endereçada, bem como de uma extrapolação de competência. Mas por que se deveria renunciar a falar em contradições entre normas infraconstitucionais mandatórias e proibitivas e normas constitucionais permissivas? A esse argumento teórico soma-se ainda um argumento prático. Da perspectiva do titular de um direito fundamental as normas de direitos fundamentais apresentam-se, dentre outras, como normas que outorgam permissões. A partir de uma perspectiva orientada pela compreensão geral e pelo uso comum da linguagem, parece ser plausível supor a existência de normas constitucionais permissivas. Embora isso não seja um argumento conclusivo a favor de uma construção dogmática, sua vinculação ao argumento teórico exposto acima cria uma fundamentação suficiente para que a existência de normas constitucionais permissivas no âmbito dos direitos fundamentais não seja considerada nem sem sentido, nem supérflua.

2.2.2 Liberdades protegidas

A posição da liberdade jurídica não-protégida, que nada mais é que a permissão de fazer algo e a permissão de se abster de fazê-lo, não inclui, em si, uma proteção por meio de normas e direitos garan-

142. Christiane Weinberger/Ota Weinberger, *Logik, Semantik, Hermeneutik*, p. 115.

titulares de liberdade. No caso das liberdades jurídicas não-protegidas de nível constitucional, contudo, isso não significa uma desproteção total. Como foi demonstrado acima, são inconstitucionais as normas infraconstitucionais que ordenam ou proíbem algo que uma norma de direito fundamental permite fazer ou deixar de fazer. Contudo, a proteção constitucional da liberdade não se limita a isso. Ela é constituída por um feixe de direitos a algo e também por normas objetivas que garantem ao titular do direito fundamental a possibilidade de realizar a ação permitida. Se uma liberdade está associada a um tal direito e/ou norma, então, ela é uma *liberdade protegida*.

2.2.2.1 Sobre a estrutura básica da proteção

A estrutura da proteção das liberdades é mais simples nas relações entre iguais. Tanto o comerciante *a* quanto o comerciante *b* são livres para conquistar *c* como comprador. No entanto, nenhum deles tem, em face do outro, um direito a que o outro não frustre seus esforços, por meio de múltiplas ações, como, por exemplo, por meio de melhores ofertas. Eles não estão, contudo, desprotegidos no exercício de sua liberdade. Assim, para atrapalhar as ações de *a*, *b* não pode matá-lo ou feri-lo ou, ainda, praticar atos de concorrência desleal. Nesse contexto, Hart fala de um “perímetro protetor” que, nos ordenamentos jurídicos, circunda cada liberdade em maior ou menor grau.¹⁴³ Um tal perímetro protetor deve ser distinguido da proteção – *de igual conteúdo* – de uma liberdade. Uma proteção de igual conteúdo ocorreria se *a* tivesse, em face de *b*, um direito a que este não o atrapalhasse na conquista de *c* como comprador. Liberdades que são protegidas exclusivamente por um perímetro protetor são liberdades protegidas *indiretamente*.

Liberdades que são protegidas por uma proteção substancialmente equivalente são liberdades protegidas *diretamente*. Tanto a proteção indireta quanto a proteção direta podem ocorrer seja por meio de normas que conferem direitos subjetivos (proteção subjetiva), seja por meio de normas que não conferem direitos subjetivos (proteção objetiva). Há, portanto, quatro tipos básicos de liberdade protegida.

143. H. L. A. Hart, “Bentham on legal rights”, pp. 180 e ss.

2.2.2.2 Sobre a proteção das liberdades fundamentais

Toda liberdade fundamental é uma liberdade que existe ao menos em relação ao Estado. Toda liberdade fundamental que existe em relação ao Estado é protegida, no mínimo, por um direito, garantido direta e subjetivamente, a que o Estado não embarace o titular da liberdade no fazer aquilo para o qual ele é constitucionalmente livre. Se se combinam liberdade e proteção no conceito de liberdade protegida, então, esse tipo de liberdade protegida é composto pela associação entre uma liberdade não-protegida e um direito ao não-embaraço de ações.¹⁴⁴ O direito ao não-embaraço é um direito a uma ação negativa. Aos direitos a ações negativas correspondem proibições dessas ações. Proteções por meio de proibições podem ser chamadas de “proteções *negativas*”. Quando se fala em direitos fundamentais como “direitos de defesa”, quer-se, em geral, fazer referência aos direitos, contra o Estado, a ações negativas que protegem liberdades fundamentais. Esses direitos estão ligados à *competência* para questionar judicialmente sua violação. Quando se juntam essas três posições – uma *liberdade* jurídica, um *direito* contra o Estado a um não-embaraço e uma *competência* para questionar judicialmente a violação desse direito –, é possível falar em um direito negativo de liberdade em face do Estado que seja totalmente desenvolvido.

Uma proteção *positiva* de uma liberdade em face do Estado surge da combinação de uma liberdade com um direito a uma ação positiva. O conceito de proteção positiva é pouco problemático quando se trata de coisas como a proteção contra terceiros por meio de normas do direito penal. Os problemas surgem nos casos de direitos a prestações, como, por exemplo, subvenções. Se, em ambos os casos, se trata de tornar faticamente possível ao portador da liberdade aquilo que a ele é permitido e, nesse sentido, juridicamente possível, então, existe uma coincidência estrutural. Essa coincidência estrutural justifica, a despeito do uso ordinário da linguagem, chamar de proteção da liberdade também a ligação entre uma liberdade e um direito a uma prestação

144. A estrutura dessa espécie de liberdade protegida pode ser representada por:

(1) $LasHa \wedge Ras (\neg \text{embaraca } s (Ha/\neg Ha))$.

O enunciado (1) deve ser lido da seguinte forma:

(2) A *a* é facultado, em relação ao Estado (*s*), realizar *h*, e *a* tem, em face do Estado, um direito a que este não o embarace em relação à alternativa de ação $h/\neg h$.

em sentido estrito, a qual torna possível o real gozo daquilo que é facultativo. Com isso ainda não se toma partido acerca da existência e da eventual extensão de normas sobre proteções positivas na Constituição alemã.¹⁴⁵

3. Competências

3.1 Questões terminológicas

Os direitos a algo e as liberdades representam apenas uma parcela das posições que são chamadas de "direitos". Um terceiro e não menos importante grupo é constituído pelas posições que são designadas por termos ou expressões como "poder" ou "poder jurídico"¹⁴⁶ (*power*),¹⁴⁷ "competência"¹⁴⁸ (*competence*),¹⁴⁹ "autorização",¹⁵⁰ "capacidade",¹⁵¹ "direito formativo"¹⁵² e "capacidade jurídica".¹⁵³ As posições que pertencem a esse grupo serão aqui chamadas de "competências". A escolha desse termo justifica-se porque os outros candidatos são todos eles menos adequados. "Poder" ou "poder jurídico" apontam para algo fático, "capacidade" está muito próxima da permissão, "direitos formativos" são apenas um segmento do âmbito das competências e "capacidade jurídica" seria adequada, mas é um termo muito trabalhoso.¹⁵⁴

145. Cf., a esse respeito, Capítulo 9, IV.

146. Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 82.

147. Jeremy Bentham, *Of Laws in General*, pp. 80 e ss.; Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", p. 36.

148. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 153-154.

149. Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 119; Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, p. 192.

150. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 150 e ss.

151. Klaus Adomeit, *Rechtstheorie für Studenten*, p. 49; Manfred Moritz, *Über Hohfelds System der juridischen Grundbegriffe*, Lund: CWK Gleerup, 1960, p. 85.

152. Klaus Adomeit, *Gestaltungsrechte, Rechtsgeschäfte, Ansprüche*, Berlin: Duncker & Humblot, 1969, pp. 7 e ss.

153. Alois v. Brinz, *Lehrbuch der Pandekten*, v. 1, 2ª ed., Erlangen: Deichert, 1873, p. 211; Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, p. 85; Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 48.

154. Uma desvantagem do conceito de competência (*Kompetenz*) é a facilidade de confundi-lo com a competência no sentido organizacional (*Zuständigkeit*). Essa última é definida por Wolff da seguinte forma: "A competência no sentido organiza-

3.2 Competência e permissão

Competências existem tanto no direito público quanto no direito privado.¹⁵⁵ Assim, tanto a celebração de um contrato ou de um casamento quanto a promulgação de uma lei ou a edição de um ato administrativo são o exercício de uma competência.¹⁵⁶ O que é comum a esses casos é o fato de que, por meio de determinadas ações do titular ou dos titulares da competência, uma situação jurídica é alterada. A alteração de uma situação jurídica por meio de uma ação pode ser descrita de duas formas diversas. Ela pode ser descrita como a criação de *normas* individuais ou gerais,¹⁵⁷ as quais sem essa ação não seriam válidas; mas ela pode ser também descrita como alteração das *posições* jurídicas dos sujeitos de direito submetidos à norma.¹⁵⁸

O conceito de competência deve ser claramente distinguido do conceito de permissão.¹⁵⁹ Ainda que uma ação que seja o exercício de

cional é, portanto, o *dever* e a *legitimidade*, fundados em enunciados jurídicos organizacionais e atos jurídicos complementares, de/para tratar de determinados assuntos de uma entidade organizacional, em geral de determinadas formas e maneiras" (Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, II, 4ª ed., München: Beck, 1976, p. 15 – sem grifos no original). Desse conceito de competência ele diferencia um conceito de "competência em sentido estrito", que consiste em *capacidades*, as quais são fundamentadas por meio de *autorizações*. Como exemplo ele utiliza a autorização para dispor e regulamentar (*idem*). A distinção proposta por Wolff não é muito clara, especialmente no que diz respeito a seu conceito de legitimação. Ainda assim, é possível afirmar que a competência em sentido estrito de Wolff corresponde, em linhas gerais, ao conceito de competência aqui utilizado. Já a sua competência no sentido organizacional é algo que consiste essencialmente de deveres e permissões para o exercício de tarefas, bem como de proibições dirigidas a outras entidades organizacionais em relação ao exercício da mesma tarefa. Como "competência" (*Kompetenz*) Wolff não denomina nem uma nem outra, mas o "objeto do dever de exercício, ou seja, da tarefa a ser realizada" (*idem*). Essas definições conceituais, de um autor tão preocupado com a precisão, fazem com que fique clara a ambigüidade do conceito de competência, que só pode ser enfrentada por meio de uma análise dos conceitos jurídicos fundamentais.

155. Uma sistematização ainda hoje interessante pode ser encontrada em Alois v. Brinz, *Lehrbuch der Pandekten*, pp. 214 e ss.

156. Cf., nesse sentido, H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, pp. 27 e ss.; Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 130 e ss.

157. Nesse sentido, cf. Hans Kelsen, *Allgemeine Theorie der Normen*, p. 42.

158. Cf. Lars Lindahl, *Position and Change*, p. 193, que, com precisão, fala da "dinâmica" da teoria das posições jurídicas.

159. Cf., a respeito, Alois v. Brinz, *Lehrbuch der Pandekten*, p. 211; Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions", p. 58. Tentativas de compreender o conceito de competência com o auxílio do conceito de permissão podem ser

uma competência seja, em geral, também permitida,¹⁶⁰ uma ação que seja meramente a realização de algo permitido não é, por si só, o exercício de uma competência, o que é perceptível pela diversidade de ações permitidas que não implicam alteração de uma situação jurídica.¹⁶¹ A diferença entre as permissões e as competências manifesta-se também em suas negações. A negação de uma permissão é uma proibição; a negação de uma competência, uma não-competência.¹⁶²

A permissão nada adiciona à capacidade de ação, que existe independentemente dela. É igualmente possível fumar e não fumar, indepen-

encontradas em Georg H. v. Wright, *Norm and Action*, pp. 192-193; Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 212 e ss. Cf. também Hans Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, p. 639: “‘Capacidade’ e ‘permissão’ são, portanto, (...) conceitualmente coincidentes”.

160. Mas ela pode também ser proibida. Isso é válido ao menos quando se trata de uma proibição relativa, ou seja, de um dever, em face de outros sujeitos de direitos específicos, de não realizar essa ação (cf., a respeito, Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, p. 50). Já a relação entre a competência e a proibição absoluta é problemática. Em geral, no caso de uma proibição absoluta parece ser conveniente retirar daquele atingido pela proibição a competência correspondente. Mas isso não precisa necessariamente ocorrer. Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal (BGH) considerou válido um contrato sobre determinado medicamento embora sua comercialização violasse a lei sobre produtos farmacêuticos (BGH, NJW 68, 2.286). Também o § 134 do Código Civil alemão pressupõe que uma competência e uma proibição que diga respeito ao seu exercício possam coexistir: “Um negócio jurídico que contrarie uma proibição legal é nulo, se da lei não se depreender algo diverso”. Um exemplo clássico da coexistência entre uma proibição e uma competência era a proibição de casamento para os casos em que um dos cônjuges tivesse mantido relações sexuais com parentes do outro (§ 4, 2, da Lei 16 do Conselho de Controle – lei sobre matrimônio –, de 20.2.1946 (ABIKR, p.77)), sobre a qual o Tribunal Constitucional Federal observou: “o matrimônio celebrado em contrariedade com a proibição é válido desde o início” (BVerfGE 36, 146 (148, 160)).

161. Isso fica especialmente claro no caso de ações não-proibidas que, realizadas por uma outra pessoa ou sob outras circunstâncias, consubstanciariam o exercício de uma competência. Cf. Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, p. 54: “Embora seja certo que, de acordo com nossas leis, os contratos celebrados por incapazes não os vinculam, mesmo que o incapaz tenha pretendido gerar tais efeitos jurídicos, não se pode afirmar que a ele é proibido celebrar contratos, que não pode aceitar empréstimos, que não pode prometer restituição, que uma tal promessa seria ilegal”. No mesmo sentido, Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 47: “Não seria correto afirmar que ao incapaz não é permitido celebrar um contrato; na verdade, ele não é capaz de fazê-lo, já que, não importa o que ele faça, disso não decorre um contrato”.

162. Cf. Klaus Adomeit, *Rechtstheorie für Studenten*, p. 49.

dentemente do fato de uma ou outra ação ser permitida ou proibida. Mas normalmente alguém fuma somente se fumar for permitido, e não proibido e associado a sanções legais. Mas se, apesar da proibição, essa pessoa fuma, a ação que ela realiza é a mesma que realizaria se fumar fosse permitido – a única diferença consiste no fato de que no primeiro caso a ação é uma ação proibida. Completamente diferentes são as coisas nos casos de competências. Como Jellinek afirmava, competências crescem, “à capacidade de ação do indivíduo, algo (...) que ele por natureza não possui”. “O indivíduo pode manter as relações sexuais que quiser, mas elas convertem-se em casamento somente sob as condições estabelecidas pelo direito objetivo; não importa que disposições foram manifestadas para um caso de morte, elas só se convertem em testamento com base nas previsões legais. Aqui a liberdade natural encontra seus limites. Pois todas as disposições que dizem respeito à validade de atos e de negócios jurídicos estabelecem uma *capacidade jurídica* conferida expressamente pelo ordenamento jurídico. Essa capacidade encontra-se em nítido contraste em relação àquilo que é simplesmente permitido”.¹⁶³

3.3 Competência e capacidade fática

O critério da alteração da situação jurídica é adequado para a distinção entre a competência e a permissão, mas é inadequado para a distinção entre a capacidade fática e a competência. Nem toda ação por meio da qual se produz uma alteração de posições jurídicas pode ser considerada como exercício de uma competência. Quando *a* realiza um ato delituoso contra *b*, tanto a posição de *a* quanto a de *b* são modificadas. A partir desse momento, *a* está obrigado, em face de *b*, a compensá-lo pelos danos, e *b* tem, também a partir daquele momento, um direito correspondente contra *a*. No entanto, a realização do ato delituoso não é considerada como o exercício de uma competência.¹⁶⁴

163. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 47.

164. Cf. Ernst R. Bierling, *Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe*, Parte 2, p. 50. A tentativa de Hohfeld de definir o conceito de “poder” (*power*) com o auxílio do conceito de “controle volitivo” (*volitional control*) deve ser, por essa razão, rejeitada (cf. Wesley N. Hohfeld, “Some fundamental legal conceptions”, p. 51). Quando Hislop afirma: “A, ao assaltar B, tem o poder legal de criar uma *pretensão* de reparação para B, mas esse *poder* está vinculado com o dever de não ser usado”

3.4 Exercícios de competência como ações institucionais

Um problema central do conceito de competência é, portanto, o de responder à questão sobre como diferenciar as ações que são o exercício de uma competência das ações que, ainda que alterem situações jurídicas, não constituem o exercício de uma competência. A resposta é: ações que constituem o exercício de uma competência são *ações institucionais*. Ações institucionais são ações que podem ser realizadas não somente em razão de capacidades naturais; elas pressupõem a existência de regras que lhes são constitutivas.¹⁶⁵ O exemplo clássico de regras constitutivas são as regras do jogo de xadrez. Sem essas regras poder-se-ia fazer referência apenas a movimentos de figuras em um tabuleiro, mas não a “lances” ou a um “xeque-mate”. Semelhante é o caso de uma promessa. Sem as regras que lhe são constitutivas, uma manifestação como “eu lhe prometo que (...)” poderia ser interpretada como uma informação acerca de uma intenção ou como um predição de um comportamento futuro, mas não como promessa. O contraponto a essas regras constitutivas, que criam a possibilidade de uma determinada ação, são as regras regulativas, que se referem a ações que são possíveis independentemente dessas mesmas regras.¹⁶⁶

(D. J. Hislop, “The Hohfeldian system of fundamental legal conceptions”, p. 64), ele utiliza o conceito de poder (*power*) no sentido de uma capacidade fática de produzir consequências jurídicas, não no sentido de uma competência. A tentativa de encontrar uma definição do conceito de competência por meio do conceito de capacidade fática no âmbito de um sistema formal pode ser encontrada, por exemplo, em Frederic B. Fitch, “A revision of Hohfeld’s theory of legal concepts”, pp. 273 e ss. Cf. também Manfred Moritz, *Über Hohfelds System der juristischen Grundbegriffe*, p. 102, o qual, também em relação a uma ação delituosa, faz menção a uma “capacidade” no sentido de uma competência.

165. Cf., a respeito, John R. Searle, *Speech Acts*, pp. 33 e ss.; John L. Austin, “Performative utterances”, in, do mesmo autor, *Philosophical Papers*, 2ª ed., London: Oxford University Press, 1970, pp. 233 e ss.; Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 53 e ss.; Neil MacCormick, “Law as institutional fact”, pp. 105 e ss., o qual, ao invés de ações institucionais, fala de “atos institucionais”. John L. Austin (*How to do Things with Words*, p. 19) utiliza a expressão “atos convencionais”.

166. John R. Searle, *Speech Acts*, p. 33. Também essas ações podem ser descritas fazendo-se referência a uma regra. Isso ocorre, por exemplo, quando uma determinada ação é descrita como “assassinato”. Essa ação continua a ser o que é mesmo sem o § 211 do Código Penal alemão; sua qualificação como assassinato é apenas uma dentre as inúmeras formas possíveis de descrição geral de uma ação natural, a qual foi escolhida para, por meio do estabelecimento de uma norma, transformá-la em uma ação proibida e associar a ela uma consequência jurídica.

O mesmo vale para o âmbito do direito. Quem interpreta o comportamento de duas pessoas como uma celebração de contrato ou o comportamento de um grupo de pessoas como um ato legislativo pressupõe regras que tornam as ações naturais ou sociais observáveis em ações jurídicas.¹⁶⁷ Essas regras jurídicas constitutivas serão aqui denominadas "normas de competência".¹⁶⁸ A elas são contrapostas as normas de conduta. As *normas de competência* criam a possibilidade de atos jurídicos e, por meio deles, a capacidade de alterar posições jurídicas. As *normas de conduta* não criam alternativas de ação que, sem essas normas, seriam impossíveis; elas apenas qualificam ações, ao estabelecer obrigações, direitos a algo e liberdades.

Já houve diversas tentativas de reduzir as normas de competência a normas de conduta, ou de reduzir a modalidade jurídica da competência às permissões, deveres e proibições. Essas tentativas podem ser divididas em dois grupos. No primeiro grupo estão os esforços em se considerar como sanção a não-satisfação de normas de competência — em geral, a nulidade ou anulabilidade da norma produzida —, para depois, então, encarar a satisfação das normas de competência como um dever de evitar essa sanção. Essa perspectiva, que para algumas questões pode até mesmo ser adequada, não consegue captar o caráter constitutivo das normas de competência. No caso das normas de conduta enquanto regras regulativas há um comportamento que, em primeiro lugar, pode existir sem a existência da regra e que, em segundo lugar, é qualificado por meio da norma como obrigatório, proibido ou permitido e, eventualmente, associado a uma sanção. A conduta que é possível independentemente da norma poderia não ter, sem ela, a característica de ser obrigatória, proibida ou permitida e não teria, em vários casos, nomes como "lesão corporal", "constrangimento" etc., os quais são utilizados para associá-la a uma sanção; mas essa conduta não é, com a existência da norma, diferente do que seria sem ela,

167. Cf., nesse ponto, Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 56-57.

168. Uma outra expressão, tão adequada quanto, seria "norma autorizadora"; cf. Klaus Adomeit, *Rechtstheorie für Studenten*, pp. 48 e ss. As normas de competência podem ser subdivididas em normas que estabelecem quem tem determinada competência (normas sobre o titular da competência), normas que regulam o procedimento do exercício de competências (normas procedimentais de competência) e normas que definem os objetos da competência (normas substanciais de competência). A respeito, cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 130.

com a exceção de que, com a existência, ela passa a ter as características de obrigatória, proibida ou permitida e passa a ser designada como "lesão corporal", "constrangimento" etc. No caso das normas de competência, por causa de seu caráter constitutivo, a situação é muito diferente. Sem as regras do processo legislativo seria possível que, em uma assembléia, ocorresse a ação física de levantar os braços; seria também possível que essa ação fosse interpretada como a manifestação de uma vontade; mas ela não seria um ato de legislação.¹⁶⁹ A diferença entre normas de conduta e normas de competência é especialmente clara nos casos de seu descumprimento. O descumprimento de uma norma de competência não implica a ilegalidade, mas a nulidade ou a deficiência do ato. Se uma conduta que é o descumprimento de uma norma de competência é, ainda assim, classificada como ilegal, isso ocorre porque se pressupõe que, ao lado da norma de competência, há uma norma de conduta que obriga o correto exercício da competência.

Mais importante que o primeiro é o segundo grupo de tentativas de redução. A ele pertencem os esforços de conceber todos os fatos naturais ou sociais que constituem o suporte fático da norma de competência como pressupostos para a validade das normas de conduta. Ross expressa isso da seguinte forma: "Normas de competência são logicamente redutíveis a normas de conduta, na seguinte forma: normas de competência fazem com que seja obrigatório agir de acordo com as normas de conduta, as quais foram criadas de acordo com o procedimento por elas prescrito".¹⁷⁰ Essa redução é possível,¹⁷¹ mas com ela se perde algo essencial para o sistema jurídico.¹⁷² A posição do titular da competência deixa de ser compreendida. Essa posição é, contudo, de importância fundamental, pelo menos para os sistemas jurídicos desenvolvidos.¹⁷³ Nem a estrutura escalonada do ordenamen-

169. Para um desenvolvimento desse argumento, cf. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, pp. 34-35.

170. Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 118.

171. As objeções de Hart contra tentativas de redução do segundo grupo apóiam-se sobretudo no fato de que "o direito sem sanção é perfeitamente concebível" (H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, p. 38). Essa objeção não atinge a versão aqui considerada. Ela prescinde do conceito de sanção.

172. Cf. Klaus Adomeit, *Gestaltungsrechte, Rechtsgeschäfte, Ansprüche*, p. 19.

173. Hart designa a introdução de competências legislativas e judiciais como um "avanço tão importante para a sociedade quanto a invenção da roda" (H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, p. 41).

to jurídico nem a autonomia privada podem ser representadas adequadamente por um modelo que se limita a desenvolver cadeias de pressupostos para deveres, proibições e permissões. Sem o conceito de competência, ou algo equivalente, seria apenas possível descrever as posições de um cidadão como o destinatário de deveres, proibições e permissões (relacionais e não-relacionais), mas não como um legislador privado (*private legislator*).¹⁷⁴ Sua competência privada para a conformação do direito seria compreensível apenas como uma possibilidade fática para desencadear consequências jurídicas por meio de alguma conduta. Com isso, perder-se-ia de vista aquilo que diferencia a competência da mera possibilidade de desencadear consequências jurídicas por meio de alguma ação delituosa.

A tese reducionista é procedente a partir de outra perspectiva. O conteúdo normativo de uma competência é idêntico à classe dos deveres, proibições e permissões (relacionais e não-relacionais) que são possíveis de acordo com ela.¹⁷⁵ Da mesma forma que a introdução de modalidades relacionais em nada altera a unidade do dever-ser e apenas implica uma qualificação desse dever-ser como dever-ser relacional, também a introdução do conceito de competência em nada altera esse cenário. O conceito de dever-ser recebe apenas uma qualificação adicional: a de dever-ser *possível*.

3.5 Competência, sujeição, não-competência, não-sujeição

Uma competência é a posição criada por uma norma de competência. Aqui será examinada apenas a posição que um sujeito de direito (a) tem quando ele pode alterar a posição jurídica de outro sujeito de direito (b) sem que, para isso, sejam necessárias ações de outros sujeitos.¹⁷⁶ O fato de a poder alterar a posição jurídica de b significa que a, por meio de um ato seu, pode criar uma posição jurídica de b, a

174. Cf. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, p. 40.

175. Os possíveis deveres, proibições e permissões baseados em uma competência K_1 incluem não apenas os deveres, proibições e permissões diretamente possíveis, mas também os indiretamente possíveis. Um dever é indiretamente possível de acordo com K_1 se, de acordo com K_1 , uma outra competência K_2 puder ser fundamentada e o dever for possível de acordo com K_2 . Em tese, a cadeia de subcompetências é ilimitada.

176. O principal exemplo de uma competência para cujo exercício é necessária uma ação de outro sujeito de direito é a competência para celebrar um contrato.

qual, em iguais circunstâncias, não existiria sem esse ato. Nesse sentido, a posição de *a* pode ser descrita da seguinte forma:

- (1) *a* tem, em face de *b*, a competência para criar uma posição jurídica *RP* de *b*.

Se, em correspondência com a relação triádica dos direitos, se utiliza *K* como o operador triádico de competência e *RPb* como enunciado sobre a posição de *b*, então (1) pode ser representado como:

- (2) $Kab(RPb)$.

RP pode simbolizar uma posição jurídica de qualquer natureza, como, por exemplo, uma simples obrigação não relacional (*OaG*), um direito a algo (*RabG*) ou uma liberdade (*LabG*), mas pode simbolizar também competências de nível inferior ($K'bc(RPc)$).

Da mesma forma que ocorre nos casos de direitos a algo, também no caso das competências é possível construir relações conversas. A relação conversa à competência será chamada de *sujeição*.¹⁷⁷ Se *a* tem, diante de *b*, a competência para alterar uma posição jurídica de *b*, *b* encontra-se, em face de *a*, e no que diz respeito a essa posição, em uma relação de sujeição, e vice-versa. Se se utiliza *S* para representar a relação de sujeição, então, vale:

- (3) $Kab(RPb) \leftrightarrow Sba(RPb)$.

Duas outras posições são obtidas se se negam *Kab(RPb)* e *Sba(RPb)*:

- (4) $\neg Kab(RPb)$

simboliza um enunciado segundo o qual *a* não tem, em face de *b*, uma competência em relação a *RPb*. Essa posição deve ser denominada de *não-competência*.

- (5) $\neg Sba(RPb)$

representa um enunciado segundo o qual *b*, em face de *a* e em relação a *RPb*, não se encontra em uma relação de sujeição. Essa posição deve ser denominada de *não-sujeição*. Seguindo o esquema de Hohfeld, as quatro posições apresentadas podem ser sistematizadas da seguinte forma:

177. Cf., sobre isso, Alf Ross, *Directives and Norms*, pp. 119 e 132. Hohfeld fala em *liability* (Wesley N. Hohfeld, "Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning", p. 36).

IV.	<i>Kab (RPb)</i> (competência)	$\leftrightarrow$	<i>Sba (RPb)</i> (sujeição)
	$\neg$		$\neg$
	$\neg K_{ab} (RPb)$ (não-competência)	$\leftrightarrow$	$\neg S_{ba} (RPb)$ (não-sujeição). ¹⁷⁸

3.6 Direitos fundamentais e competências

O conceito de competência é imprescindível para a compreensão da estrutura dos direitos fundamentais. Isso vale tanto em relação às competências do cidadão quanto em relação às competências do Estado.

3.6.1 Competências do cidadão

Não há dúvidas de que existem competências do cidadão que gozam de proteção no âmbito dos direitos fundamentais. O legislador violaria uma norma de direito fundamental se revogasse as competências para contrair matrimônio, criar associações, adquirir propriedade ou manifestar disposições testamentárias. Isso não diz ainda muita coisa acerca do papel das competências no âmbito das posições de direitos fundamentais. Para poder avaliá-lo com mais exatidão, é necessário determinar a relação das competências com os direitos a algo e as liberdades. Instrutiva é a decisão do Tribunal Constitucional Federal sobre a lei de transações imobiliárias, de 1969.¹⁷⁹ a lei sobre transações imobiliárias restringe a competência para a *livre* alienação e aquisição de propriedades rurais e florestais. Enquanto o tribunal havia deixado em aberto, em uma decisão anterior, se a competência para a *aquisição* de propriedade – ele falava de “liberdade de aquisição” – era protegida pelo art. 14, § 1º, da Constituição alemã,¹⁸⁰ na decisão de 1969 ele in-

178. Cf. Wesley N. Hohfeld, “Some fundamental legal conceptions”, pp. 36 e 50 e ss. Hohfeld utiliza os conceitos *power* (competência), *liability* (sujeição), *disability* (não-competência) e *immunity* (não-sujeição). Uma terminologia próxima à aqui utilizada pode ser encontrada em Ross: *competence* (competência), *subjection* (sujeição), *disability* (não-competência) e *immunity* (não-sujeição). Cf. Alf Ross, *Directives and Norms*, p. 119.

179. BVerfGE 26, 215.

180. BVerfGE 21, 73 (76-77).

cluiu a competência para alienar propriedades na proteção do art. 14, o que tem como consequência o fato de que para a revogação de determinadas competências — como a de alienar livremente propriedades rurais e florestais — seja exigida uma justificação. Aqui interessa apenas o fato de que, com isso, se aceita a existência de um direito fundamental *prima facie*¹⁸¹ a uma competência. Esse direito tem a estrutura do direito à não-eliminação de uma posição, exposto anteriormente. É interessante como o tribunal fundamenta esse direito a uma competência: “Essa capacidade é também um componente elementar da liberdade de ação no âmbito da ordenação da propriedade. Por isso, uma proibição de alienação é uma das intervenções mais graves nesse âmbito de liberdade dos cidadãos”.¹⁸² Imediatamente antes dessa passagem, afirma que o art. 14, § 1º, 1, da Constituição alemã garante “a propriedade privada como um instituto jurídico”. E acrescenta: “Essa garantia assegura um conjunto básico de normas, que definem a propriedade no sentido desse dispositivo de direito fundamental”. Com isso, o direito a uma competência é associado tanto ao conceito de garantia de institutos quanto ao conceito de liberdade.

O núcleo dogmático da teoria da garantia de institutos, criada por Martin Wolff,¹⁸³ desenvolvida por Carl Schmitt¹⁸⁴ e recepcionada pelo Tribunal Constitucional Federal,¹⁸⁵ é uma proibição, endereçada ao legislador, contra a eliminação ou a alteração substancial de determinados institutos jurídicos de direito privado. Institutos jurídicos de direito privado são complexos de normas formados essencialmente por normas de competência. Portanto, a garantia de institutos é, sobretudo, uma proibição, endereçada ao legislador, contra a eliminação de determinadas competências dos cidadãos. Se a essa proibição não corresponde nenhum direito, então, a proteção é (meramente) *objetiva*. A teoria das garantias de institutos restringe-se à alegação de que existe

181. Sobre o conceito de direito fundamental *prima facie*, cf. Capítulo 3, I.5, e, no mesmo Capítulo, II.3.1.

182. BVerfGE 26, 215 (222).

183. Cf. Martin Wolff, “Reichsverfassung und Eigentum”, in Berliner Juristischen Fakultät (Org.), *Festgabe für W. Kahl*, Tübingen: Mohr, 1923, pp. 5-6.

184. Cf. Carl Schmitt, “Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der Reichsverfassung”, in Carl Schmitt, *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 160 e ss.

185. Cf., por exemplo, BVerfGE 6, 55 (72).

uma tal proteção objetiva. Se à proibição correspondem direitos dos cidadãos, então, a proteção é (também) *subjetiva*. Na medida em que o Tribunal Constitucional Federal aceita a existência de um direito *prima facie* à não-eliminação da competência para alienar propriedades, decorrente do art. 14, § 1º, da Constituição alemã, ele subjetiviza um pouco mais a proteção do instituto jurídico. Em que extensão a proteção de institutos jurídicos de direito privado deve ser subjetivizada por meio do reconhecimento de direitos a competências é algo que será analisado mais adiante.¹⁸⁶

Quanto mais individualista for uma teoria normativa dos direitos fundamentais, mais direitos a competências ela reconhecerá. A razão para isso está na relação entre liberdade e competência. Como já se salientou, o tribunal afirma, na decisão mencionada: “Essa capacidade é também um componente elementar da liberdade de ação no âmbito da ordenação da propriedade”.¹⁸⁷ Acima foi mencionada a tese de Jellinek segundo a qual competências jurídicas crescem, “à capacidade de ação do indivíduo, algo (...) que ele por natureza não possui”.¹⁸⁸ Isso expressa o ponto central para a relação entre liberdade e competência: por meio do reconhecimento de competências, a margem de ação do indivíduo é expandida. Uma expansão das competências do indivíduo significa – desde que se pressuponha que o exercício da competência não é nem obrigatório, nem proibido – um aumento da sua liberdade jurídica. Por essa razão, o não-reconhecimento ou a eliminação de uma competência é um obstáculo para a liberdade – e, sem dúvida, um obstáculo especialmente eficaz. Ele faz com que o objeto da liberdade (realizar ou não realizar o ato jurídico) seja eliminado por razões *conceituais*. A liberdade jurídica de realizar um ato jurídico pressupõe necessariamente a competência para fazê-lo.

A relação entre a competência e a liberdade jurídica é interessante também em outro ponto. Enquanto nos casos de garantia de uma liberdade jurídica, ou seja, quando se permite que algo seja realizado ou deixe de ser realizado, o ordenamento jurídico comporta-se de forma passiva em relação às alternativas de ação, ele se comporta de forma ativa no caso da garantia de uma competência: ele cria uma alternativa de

186. Cf. Capítulo 9, III.5.1.

187. BVerfGE 26, 215 (222).

188. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 47.

ação. O reconhecimento de competências, sejam elas de direito privado (por exemplo: aquisição da propriedade), sejam elas de direito público (por exemplo: direito de votar), é apenas uma das três formas por meio das quais o ordenamento jurídico pode ativamente ampliar a margem de ação – e, com isso, a liberdade negativa – de um indivíduo. As outras duas são a criação de normas de proteção, sobretudo aquelas do direito penal, que zelam para que terceiros não embaracem o exercício de alternativas de ação, e a concessão de direitos a prestações positivas em sentido estrito, que devem assegurar a possibilidade fática do exercício de alternativas de ação. Na medida em que o direito ativamente cria liberdades, ele cria também sempre – direta ou indiretamente – não-liberdades. O exercício de competências leva à imposição de obrigações, não-direitos e não-competências; normas de direito penal que asseguram liberdades excluem a liberdade jurídica de se fazer aquilo que elas proíbem; e a satisfação de direitos a prestações sociais pressupõe que o Estado retire de outros os meios necessários para tanto, o que restringe sua liberdade fática de ação. É certo que isso em nada altera o fato de as liberdades ativamente criadas serem liberdades, mas suscita a questão acerca da *correta* distribuição das liberdades.

3.6.2 Competências do Estado

O contraponto à competência do cidadão é a competência do Estado ou de seus órgãos. Neste ponto, as normas de direitos fundamentais entram em jogo como normas negativas de competência.¹⁸⁹ Uma norma negativa de competência é uma norma que restringe uma norma positiva de competência.¹⁹⁰ É possível também dizer que normas

189. Sobre a classificação das normas de direitos fundamentais como normas negativas de competência, cf., por exemplo, Horst Ehmke, *Wirtschaft und Verfassung*, Karlsruhe: Müller, 1961, pp. 29 e ss.; do mesmo autor, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation", *VVDStRL* 20 (1963), pp. 89 e ss.; Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 291; Friedrich Müller, *Die Einheit der Verfassung*, p. 142; Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 291; Peter Häberle, "Grundrechte im Leistungsstaat", p. 135; Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation", p. 1.530.

190. Os problemas que podem surgir a partir da classificação das normas de direitos fundamentais como normas negativas de competências podem ser percebidos na seguinte manifestação de Goerlich: "direitos fundamentais como liberdades são capacidades originárias; as competências, por sua vez, são capacidades derivadas da

negativas de competência introduzem cláusulas de exceção nas normas positivas de competência. Dessa forma, elas colocam o Estado em uma posição de não-competência, e o cidadão em uma posição de não-sujeição. É possível indagar se é necessário falar nesses tipos de posição e, por conseguinte, em normas negativas de competência. Quando o cidadão se encontra em uma posição constitucional de não-sujeição diante do Estado, ele tem sempre um direito a que o Estado não atue no âmbito da não-sujeição. A esse direito corresponde uma proibição, dirigida ao Estado, de agir no âmbito de sua não-competência, definido pelas normas de direitos fundamentais. Contudo, não é apenas possível e não-prejudicial falar de normas negativas de competência e, por conseguinte, de não-sujeições e não-competências, mas é também conveniente. Caso contrário seria possível explicar apenas de forma incompleta a deficiência de atos de criação normativa que se encontrem no âmbito de uma não-competência. Em um primeiro momento eles seriam apenas classificados como proibidos. A deficiência teria que ser interpretada como a consequência jurídica não de uma extrapolação de competência, mas de uma violação de uma proibição. Caso se aceitem tanto uma norma proibitiva quanto uma norma negativa de competência, é possível explicar, com a ajuda da primeira, a qualificação como proibida e, com a ajuda da segunda, a qualificação como deficiente.

III – O DIREITO FUNDAMENTAL COMPLETO

Até este ponto o que interessava eram as posições de direitos fundamentais na sua expressão individual. Quem fala de um direi-

ordem democrática e federal. Como 'normas negativas de competência', os direitos fundamentais não seriam primariamente liberdades, mas apenas direitos subjetivos a capacidades demarcadas, ou seja, como competências, eles seriam determinados apenas de forma negativa, não a partir de sua substância" (Helmut Goerlich, *Grundrechte als Verfahrensgarantie*, p. 20). Mas por que deveriam os direitos fundamentais (normas de direitos fundamentais), enquanto normas negativas de competência, ser (garantir) "apenas direitos subjetivos a capacidades demarcadas"? Enquanto normas negativas de competências, eles restringem a competência do Estado. Na medida em que o fazem, eles colocam o titular do direito fundamental na posição de não-sujeição (cf., acima, II.3.5). Essa posição é tudo menos uma "capacidade demarcada". Na verdade, dentro dos limites da norma negativa de competência, ela é caracterizada pela não sujeição do titular da posição a deveres e proibições, isto é, por sua liberdade.

to fundamental, como do direito à vida ou da liberdade de expressão, normalmente não quer fazer menção a uma posição individual, mas ao direito fundamental completo. Mas o que é um direito fundamental completo? A resposta mais simples seria aquela segundo a qual um direito fundamental completo é um feixe de posições de direitos fundamentais. Permanece, no entanto, a questão acerca daquilo que faz com que as posições individuais se unam em um direito fundamental. Aqui também a resposta mais simples seria: sua atribuição a uma disposição de direito fundamental. Às posições jurídicas sempre correspondem normas que as reconhecem. Nesse sentido, a *união* de um feixe de posições em um direito fundamental equivale à atribuição de um feixe de normas a uma disposição de direito fundamental. Com isso, no entanto, é contemplado somente um dos aspectos de um conceito inteiramente desenvolvido de direito fundamental completo, como se verá a seguir.

Para complementar o cenário, é recomendável uma breve olhada em um exemplo. Em razão da diversidade de posições a que nela se faz referência, um bom exemplo é a decisão da Lei Provisória sobre o Ensino Superior Integrado na Baixa Saxônia.¹⁹¹ No que diz respeito aos cidadãos, fala-se em três posições de espécies diferentes: uma *liberdade jurídica* para realizar atos no âmbito científico,¹⁹² um direito a que o Estado não embarace os atos no âmbito científico,¹⁹³ ou seja, um *direito a uma ação negativa* do Estado que garanta essa liberdade jurídica (direito de defesa), e um *direito a uma ação positiva* do Estado que proteja essa mesma liberdade. Esse último direito tem um papel central na decisão, e o tribunal o resume com as seguintes palavras: “Ao indivíduo titular do direito fundamental do art. 5º, § 3º, surge, a partir de uma decisão valorativa, um direito àquelas medidas estatais, também de caráter organizacional, que sejam imprescindíveis para a proteção de sua esfera de liberdade constitucionalmente protegida, porque só a partir dessas medidas é que se torna possível a atividade

191. BVerfGE 35, 79. A respeito, cf. Andreas Sattler, “Die Pflicht des Gesetzgebers zum Erlaß von Vorschriften über die Organisation von Hochschulen”, in Hans Schneider et al. (Orgs.), *Im Dienst an Recht und Staat: Festschrift für Werner Weber*, Berlin: Duncker & Humblot, 1974, pp. 325 e ss.

192. BVerfGE 35, 79 (112-113).

193. Idem.

científica livre".¹⁹⁴ Nessa citação a formulação do direito está ligada à sua fundamentação. De início, interessa aqui apenas o direito. O que é digno de nota é a forma como são descritas as ações estatais que constituem seu objeto. A descrição insere as ações estatais em uma relação meio-fim.¹⁹⁵ O titular do direito fundamental tem um direito a uma ação estatal, que é "imprescindível para a proteção de sua esfera liberdade constitucionalmente protegida". Dificilmente seria possível expressar melhor o fato de que se trata de uma proteção positiva subjetiva¹⁹⁶ de uma liberdade.

No que diz respeito ao Estado, o tribunal formulou, em um nível abstrato, o dever de, "por meio de adequadas estruturas universitárias livres, garantir aos titulares do direito individual do art. 5º, § 3º, da Constituição alemã tanta liberdade na sua atividade científica quanto for possível levando-se em consideração as tarefas da universidade e os interesses dos diferentes titulares de direitos fundamentais que nela atuam".¹⁹⁷ Esse dever expressa com clareza o *caráter principiológico* das normas de direitos fundamentais. Chega-se à concretização do mencionado direito a uma ação positiva por meio da formulação de *deveres definitivos* relativamente específicos para o Estado. Nesse sentido, estabelece-se, em primeiro lugar, o dever de considerar a especial posição dos professores universitários na organização da liberdade científica.¹⁹⁸ No que diz respeito à docência, isso é concretizado por meio de um dever de influência determinante, e, no que diz respeito à pesquisa, por meio de uma influência decisiva.¹⁹⁹ No nível diretamente ligado ao caso foram estabelecidas proibições que se referem às relações majoritárias e aos procedimentos decisórios nos órgãos colegiados das universidades, bem como a composição dos grupos neles representados.²⁰⁰ Tais proibições, como, por exemplo, a que veda que professores universitários sejam voto minoritário em comis-

194. BVerfGE 35, 79 (116).

195. O tribunal fala expressamente em uma "conexão causal entre normas organizacionais (...) e interferências no livre exercício da pesquisa e da docência" (BVerfGE 35, 79 (120)).

196. Cf., neste Capítulo, II.2.2.2.2.

197. BVerfGE 35, 79 (123-124).

198. BVerfGE 35, 79 (126-127).

199. BVerfGE 35, 79 (131-132).

200. BVerfGE 35, 79 (139 e ss.).

sões julgadoras de concursos, têm um caráter de regra²⁰¹ que não poderia ser mais claro.

Esses poucos exemplos já demonstram o quão abrangente e multifacetado é aquilo que se pode reunir no conceito de *direito fundamental completo*. As normas e posições mencionadas podem ser divididas a partir de três perspectivas: (1) de acordo com as posições de que se trate no sistema de posições jurídicas fundamentais; (2) segundo seu grau de generalidade; e (3) segundo se trate de posições com caráter de regra ou de princípio ou, respectivamente, de posições definitivas ou *prima facie*. Entre essas normas e posições existem relações das mais variadas. Três relações, que extrapolam a simples coexistência no feixê de posições, são facilmente diferenciáveis: uma relação de especificação, uma relação meio-fim e uma relação de sopesamento. Um exemplo de *relação de especificação* é aquela entre a liberdade jurídica de se fazer tudo aquilo "que deve ser interpretado, segundo seu conteúdo e sua forma, como uma tentativa séria e planejada para se atingir a verdade" e a liberdade de escolha do enfoque do problema e dos princípios da metodologia científica.²⁰² Uma *relação meio-fim* já foi mencionada de passagem acima. Com frequência desempenha ela um papel decisivo, sobretudo nos casos de normas de organização e de procedimento. Relações de maioria não têm, em si, uma ligação direta com atividades de pesquisa, mas elas podem ter efeitos nessas atividades. Para mencionar mais um exemplo: não informar um candidato, em um exame estatal para estudantes de Direito, acerca das consequências de seus atos durante a prova oral não tem, por si só, relação com a escolha e com o exercício da profissão daquele que está sendo examinado, mas pode ter efeitos neles.²⁰³ Uma grande parte das discussões sobre direitos fundamentais como garantias de procedimento²⁰⁴ diz respeito à incorporação de posições procedimentais no direito fundamental completo, por meio de uma relação meio-fim. Mas mais interessante que as anteriores é a *relação de sopesamento*. Ela pode desempenhar um papel no âmbito da relação de especificação, na fundamentação de uma definição de significado e também no âm-

201. BVerfGE 35, 79 (145).

202. BVerfGE 35, 79 (113).

203. Cf. BVerfGE 52, 380 (388 e ss.).

204. Cf., com diversas referências, Helmut Goerlich, *Grundrechte als Verfahrensgarantien*, Baden-Baden: Nomos, 1981.

bito de uma relação meio-fim, na identificação e na exclusão de fins ou, ainda, na exclusão de meios. Mas ela pode também existir fora dessas relações. A relação de sopesamento consiste na relação – que corresponde à lei de colisão – entre uma posição *prima facie* e uma posição definitiva. Para se passar de uma para a outra é necessário estabelecer a relação da posição *prima facie* com outras posições *prima facie* e com princípios que não dizem respeito a posições jurídicas individuais, mas a interesses coletivos. Na decisão mencionada o Tribunal Constitucional Federal expressa isso com as seguintes palavras: “Contudo, o dever estatal de realizar um grau possível de liberdade científica encontra os limites naturais que resultam da confluência das pretensões de diversos titulares de direitos fundamentais e da consideração de outros interesses significativos da comunidade”.²⁰⁵

Se se parte do pressuposto de que o grau de generalidade não é razão favorável ou contrária à inclusão de uma posição no direito fundamental completo, então, há quatro coisas que podem ser chamadas de “direito fundamental completo”: (1) um feixe de posições definitivas; (2) um feixe de posições definitivas, incluindo as relações que existem entre elas; (3) um feixe de posições definitivas e *prima facie*; e (4) um feixe de posições definitivas e *prima facie*, incluindo as relações que existem entre elas. Já foi demonstrado acima que as normas de direitos fundamentais têm um duplo caráter, o que significa, entre outras coisas, que às disposições de direitos fundamentais podem ser atribuídos tanto regras quanto princípios.²⁰⁶ Isso significa que no feixe que constitui o direito fundamental completo se incluem tanto posições definitivas quanto posições *prima facie*. Incluir nele as relações nas quais as posições se encontram reciprocamente é algo não apenas possível e não-prejudicial, mas também necessário, se se pretende construir um conceito teoricamente interessante de direito fundamental completo, ou seja, um conceito cujo conteúdo é mais que a simples reunião aditiva de posições. Um direito fundamental completo é, por essa razão, um feixe de posições definitivas e *prima facie*, relacionadas entre si por meio das três formas apresentadas e que são atribuídas a uma disposição de direito fundamental.

205. BVerfGE 35, 79 (122).

206. Cf. Capítulo 3, II.3.3.

Um direito fundamental completo desse tipo é algo fundamentalmente diverso do direito fundamental completo que é constituído somente por uma conjunção de posições definitivas. Este tem um caráter estático; aquele, um caráter dinâmico. Um é o resultado provisório de um processo decisório e argumentativo, que se localiza fora do direito fundamental; o outro inclui exigências que extrapolam esse resultado e, por isso, colide com outros direitos fundamentais e com princípios que dizem respeito a interesses coletivos e, dessa forma, está necessariamente ligado com seu ambiente normativo. Além disso, ele contém razões para sua própria posição definitiva. Em um a decisão valorativa da qual fala o Tribunal Constitucional Federal²⁰⁷ é algo internalizado na forma de princípios; no outro a decisão valorativa é algo externo.

O direito fundamental completo é algo bastante complexo, mas em hipótese alguma um objeto inescrutável. Ele é composto de elementos de estrutura bem definida – das posições individuais dos cidadãos e do Estado –, e entre essas posições há relações claramente definíveis – as relações de especificação, de meio-fim e de sopesamento. Isso não significa que não pode haver polêmica acerca daquilo que faz parte do direito fundamental completo. A polêmica acerca daquilo que faz parte do direito fundamental completo tem seu contraponto na polêmica acerca de que normas devem ser atribuídas às disposições de direitos fundamentais como normas de direitos fundamentais. Assim, com base no dever formulado pelo Tribunal Constitucional Federal segundo o qual o Estado não deve criar apenas meios organizacionais, mas também pessoais e financeiros, para o “livre desenvolvimento da ciência”,²⁰⁸ é possível chegar a deveres concretos muito distintos. É possível também ser ainda mais radical e pôr em dúvida que um tal dever deva ser atribuído ao art. 5^a, § 3^a, 1, da Constituição alemã, e afirmar que ao Estado é permitido, mas não obrigatório, cuidar do bom funcionamento das instituições acadêmicas; ele poderia deixar o fomento da ciência totalmente nas mãos da iniciativa privada, cuja ação ele não poderia embarçar. Isso faz com que fique claro que no âmbito do questionamento acerca do que faz parte do direito fundamental completo todos os problemas da interpretação dos direitos fundamentais vêm à tona.

207. Cf. *BVerfGE* 35, 79 (114, 116).

208. *BVerfGE* 35, 79 (115).

DIREITO FUNDAMENTAL E STATUS

I – A TEORIA DOS STATUS DE JELLINEK

Como o último exemplo mencionado demonstrou, o direito fundamental completo é um feixe de posições de diferentes conteúdos e diferentes estruturas. Desse tipo de posições globais concretas é necessário distinguir posições globais abstratas. O paradigma de uma teoria de posições globais abstratas é a teoria dos status, de Jellinek. Sua análise aqui não se justifica somente pela sua importância histórica como exemplo de uma grande construção jurídica, conceitual e teórica. Ela ainda tem grande relevância como fundamento de classificações dos direitos fundamentais.¹ Como ainda será demonstrado, partes substanciais da teoria dos status estão entre os conhecimentos sedimentados no âmbito dos direitos fundamentais, o que, em um campo tão controverso, com certeza significa algo. A vitalidade da teoria de Jellinek pode ser percebida em tentativas, como a de Häberle, de, como ele mesmo diz, “colocar sua cabeça de absolutismo tardio em pés democráticos”,² ou ainda na construção de status concorrentes ou complementares, como o *status constituens*, de Denninger,³ o status constitucional e o

1. Cf., por todos, Friedrich Klein, “Vorbemerkung”, in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, A II 3, pp. 58 e ss.; Walter Schmitt Glaeser, *Missbrauch und Verwirkung von Grundrechten im politischen Meinungskampf*, Bad Homburg: Gehlen, 1968, pp. 83 e ss.; Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 10 e ss., 201 e ss., 278 e ss.; Christian Starck, “Die Grundrechte des Grundgesetzes”, *JuS* 21 (1981), pp. 239 e ss.

2. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, *VVDStRL* 30 (1972), p. 80.

3. Erhard Denninger, *Polizei in der freiheitlichen Demokratie*, Frankfurt am Main: Metzner, 1968, p. 33.

status geral civil-estatal, de Hesse,⁴ o *status activus processualis*, de Häberle,⁵ e o *status libertatis*, de Grabitz.⁶

Jellinek diferenciava quatro status: o *status passivo* ou *status subiectionis*, o *status negativo* ou *status libertatis*, o *status positivo* ou *status civitatis* e o *status ativo* ou *status da cidadania ativa*.⁷

Jellinek descreve de formas diversas o que é um status. Importância central tem sua caracterização como “uma relação com o Estado que qualifica o indivíduo”.⁸ Nesse sentido, um status é alguma forma de ~~relação~~ entre cidadão e Estado. Como uma relação *que qualifica o indivíduo*, o status deve ser uma *situação*,⁹ e, como tal, diferenciar-se de um direito.¹⁰ Isso porque o status, na forma como Jellinek o expressa, tem como conteúdo o “ser” e não o “ter” jurídico da pessoa.¹¹ Alguns exemplos podem esclarecer o que Jellinek entende, nesse caso, por “ser” e “ter”. Por meio da concessão do direito de votar e do direito de livremente adquirir propriedade, modifica-se o status de uma pessoa e, com isso, o seu ser,¹² enquanto a aquisição de um determinado terreno diz respeito apenas ao seu “ter”. Essas descrições gerais são bastante obscuras. O conceito de status é definido com mais acuidade a partir de sua divisão em quatro “relações de status”.¹³

4. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 280.

5. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, pp. 52 e 81.

6. Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, Tübingen: Mohr, 1976, p. 245.

7. Cf. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, 2ª ed., Tübingen: Mohr, 1905, pp. 86-87. Cf. também, do mesmo autor, *Allgemeine Staatslehre*, 2ª ed., 7ª tir., Bad Homburg: Gentner, 1960, pp. 418 e ss.

8. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 83: “Teoricamente, a personalidade é uma relação com o Estado que qualifica o indivíduo. Assim, juridicamente ela é uma situação, um status”. Na p. 118 Jellinek fala em uma “relação entre indivíduo e Estado, que se condensa em um ser”. A ela corresponde a caracterização, feita por Wolff, como “uma qualificação essencial de uma pessoa” (Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, I, § 32 IV a).

9. Idem, p. 83.

10. Idem, pp. 83-84.

11. Idem, p. 84.

12. Idem.

13. Idem, p. 86.

1. O status passivo

O status passivo (*status subiectionis*) é tratado de forma relativamente breve. Nele encontra-se o indivíduo em razão de sua "sujeição ao Estado (...) no âmbito da esfera de obrigações individuais".¹⁴ Isso dá ensejo a duas interpretações. De acordo com a primeira, o fato de que *a* se encontra no status passivo significa simplesmente que existe *algum* dever ou proibição estatal ao qual *a* esteja sujeito, ou que poderia legitimamente existir *algum* dever ou proibição, ou seja, que o Estado teria uma competência diante de *a* para estabelecer algum dever ou proibição que o afetasse, o que significa que *a* se encontra, em relação ao Estado, em uma posição de sujeição, na forma como definida anteriormente.¹⁵ De acordo com a segunda interpretação, o status passivo de uma pessoa é composto pela *totalidade* ou pela classe dos deveres e proibições que o Estado lhe impõe ou da totalidade ou da classe dos deveres e proibições para cuja imposição o Estado tem competência. De acordo com a primeira interpretação o status não se altera quando se alteram os deveres e proibições individuais ou a competência do Estado para estabelecê-los; o status passivo somente pode deixar de existir quando o indivíduo deixar de estar submetido a qualquer dever ou proibição e o Estado não tiver mais a competência para estabelecê-los. Já, de acordo com a segunda interpretação, qualquer modificação nos deveres e proibições ou na competência para estabelecê-los implica uma mudança no status.

Algumas manifestações de Jellinek – como aquelas segundo as quais "a relação entre indivíduo e Estado condensada em um ser (...) permanece, enquanto tal, inalterada, não importa que conteúdo concreto a ela se atribua",¹⁶ ou "o conteúdo de um status (...) não pode, portanto, nunca, ser definido"¹⁷ – demonstram que apenas a primeira interpretação mencionada acima corresponde às suas intenções.

Há, contudo, uma ligação entre a primeira e a segunda interpretações. Se *a* não está sujeito ao menos a um determinado dever ou a uma determinada proibição estatal, e se o Estado não tem competência para estabelecer pelo menos um dever ou uma obrigação que afete *a*,

14. Idem.

15. Cf. Capítulo 4, II.3.5.

16. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 118.

17. Idem.

então, *a* não se encontra em um status passivo. Portanto, estar em um status passivo nada mais significa que se encontrar em uma determinada posição que possa ser descrita com o auxílio das modalidades de dever, proibição e competência – ou de seu converso, a sujeição. Aquilo que é obrigatório ou proibido pode variar tanto quanto o objeto da competência ou da sujeição. Por isso, é necessário diferenciar entre o conteúdo do status e o próprio status enquanto tal. O conteúdo do status passivo de *a* pode sempre ser descrito por meio da indicação de um feixe de posições do tipo mencionado acima. O status passivo de *a*, enquanto tal, é aquilo que permanece inalterado quando se altera o número ou o conteúdo das posições que formam aquele feixe. O conceito de status passivo é, portanto, uma *abstração* acerca de determinadas posições, que podem ser inteiramente descritas com o auxílio das modalidades anteriormente mencionadas, e, nesse sentido, reduzíveis a essas modalidades normativas.¹⁸

18. Segundo Wolff, o status é “um conceito de direitos e deveres potenciais” (Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, I, § 32 IV a; em edições anteriores: “essência”); o status passivo é a “essência de todos os deveres potenciais das pessoas civis perante o Estado” (idem, § 32 IV c 1). A expressão “dever potencial” é ambígua. Em seu significado mais amplo, ela implica todo dever *imaginável* a que um indivíduo possa estar sujeito. Não parece ser possível imaginar que Wolff a tenha usado nessa acepção, senão o status passivo seria a classe de todos os deveres possíveis. Um sentido mais estrito é obtido se se compreende “deveres potenciais” como a classe de todos os deveres que o Estado, em virtude das *competências* que ele tenha em determinado sistema jurídico, possa impor aos indivíduos a ele submetidos. Mas visto que Wolff, na análise do caráter potencial, não fala em competências e sujeições, mas apenas que os deveres potenciais se atualizam “de formas variadas de acordo com as diversas situações sociais” (idem, § 32, IV a), uma terceira acepção deve ser levada em consideração: a de que os deveres potenciais sejam deveres *condicionados* ou hipotéticos, normalmente de caráter relativamente geral. Assim, todo proprietário de algo tem o dever condicionado ou hipotético de eliminar qualquer perigo para a segurança ou para a ordem pública que possa por ele ser causado. Enquanto dever condicionado, ele existe mesmo quando sua propriedade se encontra em bom estado. Esse dever condicionado torna-se incondicionado ou categórico quando surge uma situação de perigo. Saber se a definição de Wolff para o status passivo, em uma dessas interpretações do conceito de dever potencial, reflete a intenção de Jellinek é algo que depende do que Wolff entende por “essência”. Se for uma totalidade no sentido de uma classe – o que equivaleria ao uso comum desse conceito –, então, ele não corresponde à intenção de Jellinek. O status passivo não é nem a classe dos deveres potenciais condicionados, nem dos incondicionados, nem dos relativos a uma competência, nem dos simplesmente possíveis, mas uma *abstração* sobre classes de deveres. Se Wolff entende por “essência” uma tal abstração – o que, embora não seja sugerido pelo

2. O status negativo

O conceito de status passivo não é muito problemático. O mesmo não pode ser dito, contudo, do conceito de status negativo. Um problema teórico-estrutural central desse conceito pode ser expresso por meio da seguinte indagação: o status negativo é algo composto exclusivamente de faculdades, ou seja, de liberdades jurídicas não-protegidas, no sentido definido anteriormente,¹⁹ ou a ele pertencem também proteções por meio de direitos a um não-embaraço? Quando se fala, na literatura, em status negativo, faz-se menção, na maioria das vezes, aos direitos de defesa, ou seja, aos direitos, em face do Estado, a ações negativas. No entanto, isso seria contraditório com as considerações feitas por Jellinek.

Jellinek explica o conceito de status negativo com as seguintes, e muito citadas, palavras: "Ao membro do Estado é concedido um status, no âmbito do qual ele é o senhor, uma esfera livre do Estado, que nega o seu *imperium*. Essa é a esfera individual de liberdade, do *status negativo*, do *status libertatis*, na qual os fins estritamente individuais encontram a sua satisfação por meio da livre ação do indivíduo".²⁰ Nesse sentido, um status negativo é formado por uma esfera individual de liberdade. Mas essa esfera individual de liberdade é, segundo Jellinek, a classe das "ações dos súditos que são juridicamente irrelevantes para o Estado".²¹ Irrelevante para o Estado seria uma ação que, ao menos no que diz respeito à relação Estado/cidadão, "não tenha condições de produzir um efeito juridicamente relevante".²² Como exemplos de ações juridicamente irrelevantes Jellinek utiliza a publicação de um impresso, o saborear de um vinho e o passeio em sua própria propriedade. Ainda que a publicação de um impresso possa

termo, é ao menos possível —, então, sua definição reflete a intenção de Jellinek apenas se disser respeito não apenas aos deveres potenciais na terceira acepção, mas também na segunda, bem como na acepção de um dever incondicionado. Portanto, a definição de Wolff para o status passivo corresponde àquela fornecida no texto apenas se se entender "essência" como abstração e se seu conceito de deveres potenciais abranger tanto os deveres potenciais na segunda e na terceira acepções quanto os deveres incondicionados.

19. Cf. Capítulo 4, II.2.2.1.

20. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 87.

21. Idem, p. 104.

22. Idem, p. 46.

estar associada à celebração de um contrato, essa ação teria relevância apenas em face de terceiros. A irrelevância da publicação de um impresso na relação com o Estado não é alterada por esse fato.

Aquilo que Jellinek denomina "irrelevância jurídica"²³ nada mais é que a faculdade apresentada anteriormente, a qual, por sua vez, enquanto faculdade jurídica, é o mesmo que a liberdade juridicamente não-protégida.²⁴ Uma ação é facultativa quando ela não é nem obrigatória nem proibida, ou seja, quando tanto sua realização quanto sua não-realização são permitidas. No entanto, Jellinek pretende utilizar os termos "permitir" e "ter permissão" para algo diverso: para as ações juridicamente relevantes nas relações entre iguais, ou seja, nas relações cidadão/cidadão.²⁵ Não é, aqui, necessário analisar os muitos problemas dessa tese.²⁶ Em todo caso, ao se referir à remoção de uma proibição, ele também fala em uma permissão "puramente negativa",²⁷ e também em seu sistema é correto afirmar que ações juridicamente irrelevantes não são nem obrigatórias, nem proibidas. Por isso, é possível, aqui, estabelecer que a modalidade da irrelevância de Jellinek é o mesmo que a modalidade da faculdade, desenvolvida anteriormente.

A constatação de que o status negativo de Jellinek é formado exclusivamente por faculdades, ou seja, por liberdades jurídicas não-protégidas, é confirmada por manifestações do próprio Jellinek acerca de sua proteção por meio de direitos ao não-embaraço em face do Estado, isto é, acerca daquilo que comumente é chamado de "direito de defesa". Segundo Jellinek, o status negativo está "protegido pela

23. Em vez de "irrelevância jurídica", Jellinek utiliza também a expressão ações "juridicamente indiferentes" (idem, p. 46).

24. A irrelevância jurídica no sentido dado por Jellinek não pode, portanto, ser igualada à irrelevância fática. Se é tanto permitido participar quanto não participar da vida política, então, a participação na vida política, no sentido dado por Jellinek, é juridicamente irrelevante para o Estado. Para um Estado Democrático, contudo, é de extrema relevância fática a existência de pelo menos alguns cidadãos que participem da vida política. Mas da relevância fática não decorre uma relevância jurídica no sentido dado por Jellinek. Mesmo assim, ações faticamente relevantes podem tornar-se ações juridicamente relevantes. Se isso ocorrer por meio de interpretação, então, a relevância fática pode ser utilizada como argumento a favor da relevância jurídica.

25. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, pp. 46 e 49.

26. Cf., a esse respeito, Hans Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, pp. 632 e ss.

27. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 46.

pretensão do indivíduo ao seu *reconhecimento* e pela proibição de que as autoridades estatais o perturbem, ou seja, pela proibição em relação a qualquer imposição de ordem ou de coação não legalmente fundamentada";²⁸ mas essa pretensão pertence, "como qualquer outra, [pretensão] a uma determinada conduta estatal, ao *status positivo* do indivíduo".²⁹ Adiante será demonstrado que a inclusão do direito ao não-embaraço no status positivo, feita por Jellinek, não é despida de problemas, o que tem como consequência um caráter peculiarmente errante dos direitos de defesa em seu sistema.

Se se parte do pressuposto de que somente liberdades jurídicas não-protégidas fazem parte do status negativo, então, o conceito de status negativo é facilmente definível, por sua correspondência com o de status passivo. Da mesma forma que ocorre no caso do status passivo, também no caso do status negativo é possível diferenciar entre a totalidade das liberdades (jurídicas não-protégidas) de um indivíduo e aquilo que permanece igual quando ele tem alguma liberdade (jurídica não-protégida). Tanto quanto o conceito de status passivo, o conceito de status negativo é uma abstração; uma abstração sobre determinadas liberdades jurídicas não-protégidas. Portanto, é mais uma vez necessário distinguir entre o status negativo enquanto tal e o seu conteúdo. O conteúdo do status negativo pode modificar-se; o status negativo enquanto tal permanece o mesmo. A isso corresponde a observação de Jellinek segundo a qual "a liberdade existe apenas no singular" e que "a situação individual que deriva das leis que reconhecem e disciplinam a liberdade (...) é substancialmente unitária para todos os casos".³⁰

O conteúdo do status negativo de um indivíduo *a*, no momento *ti*, é composto pela totalidade ou pela classe de todas as liberdades (jurídicas não-protégidas) que *a* têm, no momento *ti*, em relação ao Estado. A classe dessas liberdades não-protégidas pode ser denominada como o "*espaço de liberdade* de *a*, no momento *ti*, em relação ao Estado". Em vez de "espaço de liberdade" é possível falar tam-

28. Idem, p. 105.

29. Idem (sem grifos no original).

30. Idem, p. 104.

bém, como o faz Jellinek, em "esferas de liberdade" ou em "campos de liberdade".³¹

As teses de Jellinek sobre a relação entre o status negativo e o status passivo são instrutivas e confirmam o que se expôs até aqui. Segundo Jellinek, "submissão e liberdade em face da submissão" são as duas possibilidades, mutuamente excludentes, que estão à disposição do Estado em todas as regulações de sua relação com os súditos.³² Isso corretamente expressa que os status passivo e negativo se encontram em uma relação de contradição entre si. Todas as ações que a um indivíduo não são nem obrigatórias nem proibidas pertencem ao seu espaço de liberdades. E pode-se dizer que todas as ações que ou lhe são obrigatórias ou proibidas pertencem ao seu *espaço de obrigações*. Da mesma forma que o espaço de liberdades é o conteúdo do status negativo, o espaço de obrigações é o conteúdo do status passivo.³³ Toda negação de uma liberdade que faça parte do conteúdo do status negativo implica um dever ou uma proibição equivalente, que faz parte do conteúdo do status passivo; toda negação de um dever (ou uma proibição) que faça parte do conteúdo do status passivo implica uma liberdade equivalente, que faz parte do conteúdo do status negativo, desde que não seja estabelecida uma nova proibição (ou um novo dever) de conteúdo equivalente.³⁴ Toda ampliação do espaço (jurídico) de obrigações é, por razões lógicas, uma redução do espaço (jurídico) de liberdade. O fato de Jellinek encarar o conteúdo dos status passivo e negativo como possibilidades que se excluem mutuamente em um mesmo nível é um argumento adicional em favor da tese de

31. Idem, pp. 87 e 104.

32. Idem, p. 104.

33. De forma mais precisa, seria necessário diferenciar entre espaços de obrigações real e potencial. O espaço potencial de obrigações é formado pela classe dos deveres e proibições para cuja imposição o legislador tem competência. A essa diferenciação pode ser acrescida uma diferenciação equivalente para o espaço de liberdades.

34. Essa cláusula é necessária porque, no lugar de um dever, pode ser também imposta uma proibição, o que excluiria o surgimento de uma liberdade jurídica. Não é necessário fazer maiores comentários acerca do pressuposto de que o conteúdo do status passivo deva ser isento de contradições. Se dele fizerem parte tanto o dever quanto a proibição em relação à mesma ação, a negação ou do dever ou da proibição pode conduzir a uma eliminação da contradição, mas não a uma liberdade.

que, segundo ele, apenas liberdades jurídicas não-protégidas fazem parte do status negativo.

As teses de Jellinek acerca da relação entre status e direito suscitam problemas. Jellinek fala que de um status *decorrem* direitos públicos subjetivos,³⁵ que esses se *baseiam* naquele,³⁶ que estão a ele *ligados*,³⁷ que *provêm* dele,³⁸ e que o status os *gera*.³⁹ Aquele que diz que o status negativo cria direitos à não-perturbação pode querer dizer duas coisas. Ele pode querer dizer que o direito decorre logicamente do status, mas ele pode também querer dizer que entre status e direito há alguma relação mais débil. A primeira idéia seria equivocada, pois de liberdades não-protégidas, ou seja, de faculdades, não decorrem logicamente nem um direito a algo nem um direito ao não-embaraço daquilo que é permitido, como foi demonstrado anteriormente. Por isso, a relação tem que ser uma relação não-lógica. Uma relação de tipo não-lógico pode ser estabelecida a partir da finalidade da faculdade. Se se pretende garantir ao indivíduo um espaço de liberdade da forma mais segura possível, então, é necessário fazê-lo por meio de direitos ao não-embaraço e à não-eliminação.

Assim, a vinculação entre o status negativo e sua proteção é estabelecida por meio de considerações substanciais. A partir de um ponto de vista formal, aquilo que é vinculado por meio de considerações substanciais são posições que, no sistema de Jellinek, são de espécies bastante diversas, a saber, aquelas que pertencem ao status negativo e aquelas que pertencem ao status positivo. Isso, em si, não é algo contrário ao sistema de Jellinek; apenas faz com que fique claro que esse sistema é relativamente rudimentar e que necessita fundar-se em uma teoria das posições jurídicas fundamentais.⁴⁰

35. Jellinek freqüentemente faz menção não a direitos, mas a pretensões. Por pretensões ele compreende direitos concretos e atuais, como o direito do proprietário, contra um determinado perturbador, a uma não-realização da perturbação (Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, pp. 54-55). De acordo com a terminologia aqui utilizada, esse é um direito a algo.

36. Cf. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 86.

37. Idem, p. 84.

38. Idem, p. 106.

39. Idem, p. 106. Em sentido semelhante, cf. também, Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, v. I, § 32 IV a.

40. A reconstrução levada a cabo aqui diferencia-se em pontos essenciais da teoria de Rupp, um dos mais interessantes desenvolvimentos da teoria dos status de

3. O status positivo

Sobre os status passivo e negativo foi dito que eles se encontram em uma relação de contradição, da mesma forma que ocorre com o dever e a proibição, de um lado, e a faculdade, de outro. Jellinek, ao falar do status positivo como “exatamente o contrário do negativo”,⁴¹ parece querer fazer referência a uma relação semelhantemente estreita entre eles. Para se compreender o que se quer dizer com isso, é necessário analisar brevemente aquilo que Jellinek denomina status positivo ou *status civitatis*.

O indivíduo está inserido nesse status sempre que o Estado a ele “reconhece a capacidade jurídica para recorrer ao aparato estatal e utilizar as instituições estatais, ou seja, [quando] garante ao indivíduo

Jellinek. A análise de Rupp limita-se aos status negativo e positivo. No que diz respeito ao status negativo, Rupp – como Jellinek – salienta que esse status deve ser estritamente distinguido do direito subjetivo: “no caso do status, trata-se na verdade apenas de uma situação delimitada por um feixe de ‘deveres de abstenção’ normativos por parte da Administração, que, por si só, não gera direitos subjetivos – e muito menos direitos absolutos; quando muito, gera direitos subjetivos em casos de violação” (Hans H. Rupp, *Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre*, p. 162). Assim, ao contrário do que ocorre aqui, o status não é definido como uma abstração sobre faculdades ou sobre liberdades jurídicas não-protetidas, e não se parte de uma proteção por meio de direitos a um não-embaraço. Além disso, Rupp concorda inteiramente com Jellinek acerca do fato de que o status pode “gerar” direitos subjetivos (idem). Contudo, ao contrário de Jellinek, Rupp deixa claro que esses direitos não decorrem automaticamente do status (idem, p. 172). Para que isso ocorra é necessária uma “norma fundamental material jurídico-administrativa” que fundamente esse direito (idem, pp. 250, 221, 253). Como demonstram as considerações apresentadas no texto acima, é possível, em princípio, concordar com essa tese. Mas não é possível concordar com a configuração que Rupp dá a essa norma fundamental. Segundo ele, ela não deve conduzir a direitos a abstenções, como ocorre com o direito ao não-embaraço, de Jellinek, mas apenas a pretensões reativas, que surgem nos casos de violação do status (idem, p. 164). Segundo Rupp, somente essas pretensões reativas podem ser levadas em consideração como direitos subjetivos (idem, pp. 164-165). Por pretensões reativas ele entende pretensões a eliminações (idem, pp. 254 e ss.). Nada há a objetar na idéia de que a violação do status tem como consequência pretensões reativas. No entanto, não é facilmente compreensível por que somente elas deveriam ser qualificadas como “direitos subjetivos”. Não haveria problema algum em considerar as liberdades do status negativo como protegidas por meio de direitos subjetivos a um não-embaraço e, nos casos de violações desses direitos – as quais são sempre também uma violação do dever estatal que a eles correspondem –, aceitar a pretensão à eliminação como um direito subjetivo secundário.

41. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 121.

pretensões positivas".⁴² O que se quer dizer com isso não é algo muito claro. Fica mais claro quando Jellinek afirma que o Estado confere ao indivíduo o "status cívico" quando (1) lhe garante "pretensões à sua atividade" e (2) "cria meios jurídicos para a realização desse fim".⁴³ Jellinek chama de "pretensões jurídicas positivas formais"⁴⁴ os direitos que o indivíduo pode fazer valer em um procedimento legal. O fato de o indivíduo ter esse tipo de pretensão em face do Estado significa, em primeiro lugar, que ele tem *direitos a algo* em face do Estado e, em segundo lugar, que tem uma *competência* em relação ao seu cumprimento. Segundo Jellinek, a existência de uma tal competência é uma condição necessária para que o indivíduo se encontre no status positivo.⁴⁵ A fórmula utilizada por Jellinek para resumir "as pretensões jurídicas individualizadas, reconhecidas formalmente, que surgem do status positivo", ou seja, "a capacidade protegida juridicamente para exigir prestações positivas do Estado",⁴⁶ deve ser compreendida nesse duplo sentido.⁴⁷

42. Idem, p. 87.

43. Idem, p. 114.

44. Idem, p. 70.

45. Idem, pp. 115-116.

46. Idem, p. 121.

47. Nos detalhes as coisas são mais complicadas. Jellinek diferencia entre três pretensões básicas do status positivo: as pretensões à proteção jurídica, à satisfação de interesses e à consideração de interesses (*System der subjektiven öffentlichen Rechte*, pp. 124 e ss., 128 e ss., 130 e ss. e 132). A pretensão à proteção jurídica serve, de um lado, à proteção de posições de direito privado e, de outro, "à proteção das pretensões publicísticas, que nascem das relações públicas do status" (idem, p. 126). Segundo Jellinek, a pretensão à proteção jurídica deve existir "sempre na capacidade juridicamente garantida de criar normas de direito público no interesse dos indivíduos" (idem, p. 127). Isso deve ser interpretado como uma competência. Ao mesmo tempo, há uma série de formulações que sugerem uma interpretação da pretensão à proteção jurídica como direito a algo em face do Estado. Jellinek fala, por exemplo, de "uma pretensão, contra o próprio Estado, para que ele vincule a realização de atos jurisdicionais às demandas dos indivíduos" (idem, p. 127). Portanto, já no âmbito da proteção jurídica surge uma duplicação. É possível demonstrar o que isso significa para as pretensões formais jurídico-constitucionais por meio do exemplo de uma pretensão à satisfação de interesses, a saber, do direito "à admissão para frequentar instituições de ensino superior" (idem, p. 129). Para ser uma pretensão formal, esse direito tem que estar associado à pretensão à proteção jurídica. Presente essa associação, tem-se como resultado a seguinte estrutura tripla: (i) um direito, em face do Estado, a frequentar instituições de ensino superior; (ii) uma competência para exigir judicialmente esse direito; e (iii) um direito, em face do Estado, a que o Estado exe-

Deixando de lado o aspecto da competência e outros refinamentos adicionais, o cerne do status positivo revela-se como o direito do cidadão, em face do Estado, a ações estatais. É a esse ponto que Jellinek se refere quando declara que o status positivo é “exatamente o contrário do negativo”. Ao direito de *a*, em face do Estado, à ação estatal *h* corresponde o dever do Estado, em face de *a*, de realizar essa ação. Da mesma forma que uma discussão acerca do conteúdo do status negativo de *a* diz respeito a se saber se a *a* é proibido realizar ou se abster de realizar uma ação *h'*, ou se ele está livre em relação a essa ação, uma discussão sobre o conteúdo de seu status positivo diz respeito a se saber se ao Estado é proibido realizar ou se abster de realizar uma ação *h*, ou se ele está livre em relação a essa ação; trata-se, portanto, de se “decidir acerca da liberdade do Estado”.⁴⁸ Falar em “contrário” aponta para a idéia de que a extensão do status positivo do cidadão corresponde àquilo que se poderia chamar de “status passivo do Estado”, e também à idéia de que, na relação Estado/cidadão, tudo o que não pertença ao status positivo do cidadão pertence àquilo que se poderia chamar de “status negativo do Estado”.⁴⁹

Da mesma forma que ocorre com os status passivo e negativo, o status positivo também não é idêntico ao direito que dele “provém”.⁵⁰⁻⁵¹ Mas se o status positivo não é composto por determinados direitos a algo, então, da mesma forma que ocorre com os status já discutidos, ele só pode ser composto por aquilo que permanece igual quando indivíduos têm diferentes direitos a algo em face do Estado, associados a possibilidades de proteção legal. Se se interpreta o status positivo como uma abstração desse tipo, então, não se pode falar que dele “provêm” direitos.⁵²

cute o procedimento judicial ativado em razão da competência mencionada. A pretensão à proteção jurídica relacionada a posições de direito privado, mencionada por Jellinek, deve ser interpretada de forma a que o primeiro elemento da associação apresentada acima consista não em um direito a algo em face do Estado, mas em um direito a algo em face de uma pessoa privada.

48. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 121.

49. Ambas as idéias estão representadas nas equivalências analisadas anteriormente: $RabG \leftrightarrow ObaG$ e $\neg RabG \leftrightarrow \neg ObaG$.

50. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, pp. 124, 121 e 128.

51. Idem, p. 118.

52. Rupp entende que a tese de Jellinek, segundo a qual do status surgem direi-

Na discussão acerca do status negativo foi mencionado que Jellinek inclui a “pretensão ao não-embaraço em face das autoridades estatais”⁵³ como “pertencente ao status positivo dos indivíduos, como qualquer outra pretensão a uma ação estatal específica”.⁵⁴ Essa pretensão é um direito em face do Estado a uma ação negativa, isto é, a uma abstenção. A atribuição de um tal direito ao status positivo – algo coerente com a definição de status negativo de Jellinek – é, no entanto, contraditória com sua tese de que o conteúdo dos direitos do status positivo é formado por “um *fazer positivo* do Estado”.⁵⁵ Embora abster-se de embaraçar possa ser considerado como um “fazer”, certamente não pode ser considerado como um “fazer positivo”. Se se leva a sério a afirmação de Jellinek acerca do fazer positivo, o direito ao não-embaraço, que corresponde àquilo que comumente é denominado de “direito de defesa”, não seria incluído em nenhum dos status. Chegar-se-ia à conclusão de que uma das posições mais importantes no âmbito dos direitos fundamentais não teria lugar no sistema de Jellinek. Isso só pode ser evitado por meio de sua inclusão no status negativo ou no status positivo.

O problema é que ambas as soluções têm conseqüências indesejáveis. Se se inclui o direito ao não-embaraço no status negativo, seu caráter é alterado de forma significativa. A arquitetura do sistema de Jellinek entraria em colapso. Se se inclui esse direito no status positivo, a distinção entre direitos a ações estatais negativas e positivas, tão importante para a dogmática dos direitos fundamentais, deixaria de ter expressão na teoria dos status. Além disso, uma inclusão dos direitos de defesa no status positivo seria contraditória com a difundida – e justificada – terminologia da dogmática dos direitos fundamentais. Esse dilema é uma conseqüência da natureza relativamente rudimentar do sistema de Jellinek. A partir da teoria das posições jurídicas funda-

tos subjetivos, “vale na verdade somente para o *status negativus* ou *libertatis*” (Hans H. Rupp, *Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre*, p. 265). Já se demonstrou que nos casos de “surgimento” ou “nascimento” de direitos a partir do status negativo trata-se de uma *adição* de direitos a algo às liberdades não-protégidas. Se se parte disso, então, há, de fato, uma diferença fundamental entre os status positivo e negativo. Os direitos do status positivo não são adicionados a algo; eles compõem, em sua totalidade, o conteúdo do status positivo.

53. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 111.

54. Idem, p. 105.

55. Idem, p. 121 (sem grifos no original).

mentais, esse dilema pode ser resolvido por meio da divisão dos status negativo e positivo em status negativo e positivo em sentidos estrito e amplo. O status negativo em sentido *estrito* – e original de Jellinek – diz respeito exclusivamente a liberdades jurídicas não-protégidas. O status negativo em sentido *amplo* – que extrapola a sistemática de Jellinek – diz respeito aos direitos a ações negativas do Estado (direitos de defesa), que protegem o status negativo em sentido estrito. Ao status positivo em sentido *amplo* pertencem direitos tanto a ações positivas quanto a ações negativas. Já ao status positivo em sentido *estrito* pertencem somente direitos a ações positivas. As consequências sistemáticas dessa divisão para o sistema de Jellinek são simples e claras. Os direitos que são acrescentados ao status negativo em sentido estrito para que se possa convertê-lo em um status negativo em sentido amplo (direitos de defesa) são uma subespécie dos direitos do status positivo em sentido amplo.

Contra essa solução é possível suscitar, quando muito, objeções pragmáticas, porque ela supostamente complicaria a linguagem dos direitos fundamentais. Sempre que se falasse em status negativo ou positivo seria necessário acrescentar se se pretende fazer referência a um status em sentido estrito ou em sentido amplo, e qualificações como essas não seriam auto-explicáveis. Mas essa objeção é fácil de ser refutada. Na argumentação habitual no âmbito dos direitos fundamentais, em geral o contexto faz com que fique claro o que se quer dizer com as expressões “status negativo” e “status positivo”. Na maioria das vezes quer-se fazer menção ao status negativo em sentido amplo e ao status positivo em sentido estrito. Esses termos podem, portanto, ser utilizados sem qualificações extras, e é isso que será feito aqui também. As dúvidas que surgirem poderão ser rapidamente esclarecidas a partir do recurso à teoria das posições jurídicas fundamentais, na qual as divisões propostas acima se baseiam. Quando se tratar, contudo, de questões complexas de direitos fundamentais, que envolvam problemas da própria teoria dos status, as distinções estabelecidas são imprescindíveis.

4. O status ativo

Aquilo que o dever e a obrigação impostos ao indivíduo representam para o status passivo, que a faculdade representa para o status

negativo e que o direito a algo representa para o status positivo é representado para o status ativo ou status da cidadania ativa pelo conceito de competência.⁵⁶ Para que o indivíduo seja inserido nesse status, a ele “devem ser outorgadas capacidades que estejam além de sua liberdade natural”,⁵⁷ como, por exemplo, o direito de votar.⁵⁸ Não é necessário, aqui, iniciar uma discussão pormenorizada acerca da estrutura formal desse status. É patente a possibilidade de reconstruí-lo — na medida em que seja relevante no âmbito dos direitos fundamentais — com o auxílio da modalidade jurídica da competência, e já se fez referência suficiente ao problema geral da distinção entre o status e os direitos que dele “provêm”.

Mas, ao contrário do que ocorre com sua estrutura formal, que pode ser adequadamente caracterizada com o auxílio do conceito de competência, uma consideração acerca do conteúdo do status ativo se faz necessária. Nem toda competência existente em um determinado sistema jurídico deve ser atribuída ao status positivo, caso contrário também a competência para celebrar um contrato teria que pertencer a esse status. Segundo Jellinek, do status positivo devem fazer parte somente as competências que tenham como objeto uma “participação no Estado”,⁵⁹ que tem como escopo a “formação da vontade estatal”.⁶⁰ Isso acrescenta à construção formal da teoria dos status um momento substancial, que traz consigo problemas de delimitação. Embora seja fácil afirmar que a competência para celebrar um contrato não faz parte do status ativo e não haja dúvidas de que o direito de votar (art. 38 da Constituição alemã) seja o protótipo de uma competência atribuível a esse status, para além desses casos claros há uma série de casos duvidosos. Assim, a competência para se propor uma demanda na justiça administrativa é uma competência que se localiza na relação cidadão/Estado; no entanto, seguindo-se o critério de participação no Estado proposto por Jellinek, é duvidoso que ela pertença ao status ativo. Nesse ponto são mais uma vez perceptíveis o caráter rudimentar da teoria de Jellinek e a necessidade de desenvolvê-la e corrigi-la com

56. Cf., a respeito, Capítulo 4, II.3.

57. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 138.

58. Idem, pp. 159 e ss.

59. Idem, p. 137.

60. Idem, p. 136.

o auxílio de uma teoria das posições jurídicas fundamentais mais precisamente definida.

De importância significativa para o status ativo é a conexão entre as posições que pertencem aos outros status. As posições do status ativo estão sempre ligadas às posições dos outros status, pois o exercício de uma competência é sempre obrigatório ou proibido (status passivo) ou facultativo (status negativo). Segundo Jellinek, o indivíduo é incorporado ao status ativo quando sua esfera "não é restringida por uma obrigação e, ao contrário, sua capacidade de agir juridicamente é ampliada".⁶¹ Isso não pode ser compreendido como se os status ativo e passivo fossem incompatíveis entre si. Também àquele que está submetido ao dever de votar é reconhecida a competência ou "a capacidade de agir para o Estado",⁶² também ele é "incluído como membro da organização estatal", também ele "age para o Estado".⁶³ Em geral, contudo, o exercício de uma competência que faça parte do conteúdo do status ativo é algo "facultativo ao indivíduo".⁶⁴ Nesses casos, então, o status ativo é combinado com o status negativo. Por fim, uma combinação do status positivo com o status ativo é representada pelo direito à capacidade ou a competência para votar. Quando Jellinek fala em uma "pretensão jurídica a uma posição em um órgão",⁶⁵ a referência é a esse tipo de combinação.

II – SOBRE A CRÍTICA À TEORIA DOS STATUS DE JELLINEK

A despeito de suas inúmeras obscuridades e algumas deficiências, a teoria dos status de Jellinek é o mais formidável exemplo de construção teórica analítica no âmbito dos direitos fundamentais. Os conceitos centrais dessa teoria – os quatro status – são abstrações sobre posições de caráter elementar. Isso fundamenta tanto seus pontos fortes quanto seus pontos fracos. Seus pontos fracos são as nem sempre claras relações entre as posições elementares e o status e as também nem sempre claras relações das diferentes posições elementares

61. Idem, p. 139.

62. Idem, p. 87.

63. Idem, p. 139.

64. Idem.

65. Idem, p. 140.

entre si. Mas essas deficiências podem ser suprimidas se se recorrer a uma teoria das posições jurídicas fundamentais como fundamento da teoria dos status. E se a teoria das posições jurídicas fundamentais estiver baseada em uma teoria das modalidades deontológicas básicas, então, é possível obter um sistema totalmente claro, que possibilita, em seu âmbito, um grau máximo de uma imprescindível percepção analítica dos direitos fundamentais. Pode-se ressaltar também, de passagem, que esse sistema tem também uma certa beleza.

Essa avaliação da parte analítica ou formal da teoria de Jellinek ainda não diz respeito, contudo, ao conteúdo substancial que Jellinek a ela associa. As objeções que são suscitadas dizem respeito sobretudo às teses de Jellinek acerca do conteúdo substancial do status negativo, entendido, a seguir, como status negativo em sentido estrito. Seu conteúdo é definido a partir daquilo que ao indivíduo não é nem obrigatório nem proibido. Segundo Jellinek, é tarefa do legislador decidir sobre essa questão: "todas essas liberdades [são] reconhecidas apenas dentro dos limites legais".⁶⁶ Nesse sentido, o conteúdo do status negativo está à disposição do legislador. De forma coerente, Jellinek protege o status negativo somente por meio do direito do cidadão, em face do Estado, a não ser "obrigado a realizar nenhuma atividade ilegal": "Toda liberdade é simplesmente liberdade em relação a coações ilegais".⁶⁷

Essas teses sobre o conteúdo do status negativo contradizem o direito constitucional atualmente vigente, de acordo com o qual também o legislador está vinculado aos direitos fundamentais. Por essa razão, tais teses não podem ser sustentadas sob a vigência da Constituição alemã. Mas isso não significa que o conceito de status negativo tenha se tornado obsoleto. Quando da discussão acerca do conceito de liberdade jurídica não-protetida foi demonstrado que as normas de direitos fundamentais devem ser concebidas também como normas permissivas.⁶⁸ A partir dessa base é possível construir o conceito de status negativo *fundamental*. O conteúdo do status negativo fundamental de *a* é constituído pela totalidade daquilo que lhe é facultado em virtude de uma norma constitucional permissiva. O status negativo fundamental

66. Idem, p. 103.

67. Idem (sem grifos no original).

68. Cf. Capítulo 4, II.2.2.1.3.

pode ser violado também pelo legislador, como, por exemplo, por meio do estabelecimento de normas proibitivas que contradigam uma norma de direito fundamental permissiva. O problema do conteúdo do status negativo é solucionável, portanto, por meio da introdução do conceito de status negativo fundamental.⁶⁹

Freqüentemente são levantadas objeções categóricas à teoria dos status de Jellinek, dirigidas sobretudo contra seu caráter formal. Nesse sentido, Hesse critica um caráter “puramente formal” do status negativo de Jellinek e sustenta que a pessoa que ele toma por base não seria “o ser humano ou o cidadão da vida real” e que a liberdade que ele garante “não se refere a relações de vida concretas específicas”. Mas, visto que as normas de direitos fundamentais contêm “uma garantia e um fundamento concretos”, o status formal de Jellinek deveria, então, ser substituído por um “status jurídico material”, que seria fundamentado e garantido pelos direitos fundamentais da Constituição.⁷⁰ Já Häberle⁷¹ critica o fato de a teoria dos status de Jellinek excluir dos direitos fundamentais um “momento cívico-ativo”. Os diferentes status estariam “isolados e estanques lado-a-lado em um modo de pensar espacial”. Dessa forma, não seria possível perceber que a garantia dos direitos fundamentais coloca os “titulares dos direitos fundamentais ‘efetivamente’ e ‘socialmente’ na posição de cidadãos ativos”. Perder-se-ia aquilo que Smend definiu como “sentido de uma constituição”, isto é, “organizar seres humanos em uma comunidade política”.⁷² Preuß – para citar um terceiro ponto de vista – inclui sua crítica à teoria dos status de Jellinek⁷³ em uma crítica fundamental à

69. Cf. Hans H. Rupp, “Grundrechtlicher Freiheitsstatus und ungesetzlicher Zwang”, *DÖV* 27 (1974), p. 194, o qual salienta que as teses de Jellinek sobre o conteúdo do status negativo não impedem uma aplicação desse conceito no âmbito dos direitos fundamentais: “Nada impede compreender o status de liberdade específico dos direitos fundamentais como liberdade individual contra coerção *inconstitucional*”.

70. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, §§ 280-281.

71. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, pp. 18-19. Cf., além disso, Erhard Denninger, *Rechtsperson und Solidarität*, Frankfurt am Main: Alfred Metzner, 1967, p. 294; Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, p. 64.

72. Rudolf Smend, “Bürger und Bourgeois im deutschen Staatsrecht”, in Rudolf Smend, *Staatsrechtliche Abhandlungen*, p. 320, nota 15.

73. Cf. Ulrich K. Preuß, *Die Internalisierung des Subjekts*, pp. 23, 119, 131 e 136.

categoria de direitos subjetivos. Uma de suas teses centrais sustenta que “as relações sociais dos seres humanos (...) não podem ser organizadas por meio de um sistema de atribuições de esferas de vida individualmente dominadas. As atuais ordenações das relações sociais – acentuadamente interdependentes e organizacionalmente mediadas – exigem categorias jurídicas que abarquem conceitualmente essa mediação social e superem a concepção de esferas de vida individualmente dominadas”.⁷⁴ O conceito de direito subjetivo e, por conseguinte, também a teoria dos status de Jellinek não estariam aptos a essa tarefa.⁷⁵ Por isso, Preuß propõe uma compreensão das “liberdades constitucionalmente garantidas não como direitos subjetivos, mas como normas de organização da liberdade social”, uma “concepção de direitos fundamentais como garantias da liberdade concreta na sociedade”.⁷⁶

Com esses comentários, aos quais seria possível adicionar vários outros, foram introduzidos os principais tópicos de uma crítica geral ao caráter formal da teoria dos status de Jellinek. São eles: formalismo, abstração, espacialização, indivíduo isolado, obsoletismo. As contrapartes são: realidade, concretude, mediação, comunidade/sociedade, atualidade. Essa contraposição demonstra que, em última instância, trata-se da velha oposição entre teorias formais e teorias materiais. Mas com essa qualificação do problema já está implícito que a polêmica fundamental acerca da teoria (formal) dos status não é uma questão de verdadeiro e falso, mas de relevância e irrelevância. Se as normas jurídicas regulam a relação entre o indivíduo e o Estado, então, isso somente pode ocorrer se determinadas condutas, individuais ou estatais, forem obrigatórias, proibidas ou facultadas e se ao indivíduo forem concedidos determinados direitos a algo e determinadas competências. Se isso ocorre, é possível fazer abstrações sobre classes de obrigações e proibições, de facultades, de direitos a algo e de com-

74. Idem, p. 28.

75. Cf. a crítica de Preuß à versão de Rupp para a teoria dos status (Ulrich K. Preuß, *Die Internalisierung des Subjekts*, pp. 198-199).

76. Idem, p. 193. Cf. também pp. 165-166: “Atualmente não há mais a necessidade de fundamentar que a dimensão liberal ‘clássica’ dos direitos fundamentais – o *status libertatis*, segundo a teoria de Jellinek – não se esgota em sua função de limitação do poder de dominação estatal. Prevalece a compreensão segundo a qual os direitos de liberdade da Constituição alemã postulam espaços sociais de liberdade organizada, sem que haja, no entanto, um acordo acerca das consequências dessa constatação”.

petências. Mas se assim é, então, é possível falar em quatro status. As qualificações das posições jurídicas dos cidadãos assim realizadas têm um caráter puramente *analítico*. Não se afirma nem se pressupõe nada acerca da questão substancial e *normativa* sobre como suas posições jurídicas devem ser constituídas. O mesmo vale para a questão *empírica* acerca do que significa para o indivíduo e para a sociedade o fato de os cidadãos estarem inseridos em um determinado status jurídico.

Por meio de normas de direitos fundamentais o cidadão é inserido em status com determinados conteúdos, dentre eles o status negativo fundamental. Nesse sentido, é correta a tese de Hesse acerca do "status jurídico material". Mas dela não é possível derivar uma objeção a um caráter formal da teoria dos status. A posição jurídica global de um cidadão pode ser examinada tanto a partir de uma perspectiva formal quanto a partir de uma perspectiva material. Häberle tem razão quando afirma que a teoria dos status não compreenderia a situação real e social do cidadão ativo, na qual as normas de direitos fundamentais inserem o indivíduo. Mas esse não é, em primeiro lugar, seu objetivo e, além disso, esse objetivo não é por ela excluído. O objeto da teoria dos status é a estrutura formal da posição jurídica global do cidadão. Pode-se, então, perceber que seu estudo é útil também no âmbito dos problemas mencionados por Häberle, quando se leva em conta que não se deve somente questionar que conteúdo as normas de direitos fundamentais têm que ter para que o indivíduo seja colocado no status ativo, mas também que estrutura essas normas devem ter para alcançar esse objetivo. Por exemplo: são suficientes faculdades e competências do cidadão, ou também são necessárias obrigações dos cidadãos ou, ainda, obrigações estatais relativas à criação de determinadas relações fáticas? Clareza sobre esse tipo de questão é pressuposto indispensável para uma discussão racional sobre teses como a de Häberle. O mesmo vale para a concepção de direitos fundamentais como "normas de organização da liberdade social", sustentada por Preuß. Se as normas de organização são normas jurídicas, devem elas expressar deveres, proibições, faculdades, direitos a algo e competências. Preuß confirma isso quando afirma que no âmbito da liberdade social, criada pelas "normas de organização", "obviamente se encontram as pretensões individuais".⁷⁷ Ele não parece ser contrário ao conceito de direito

77. Ulrich K. Preuß, *Die Internalisierung des Subjekts*, p. 193.

subjetivo como modalidade jurídica, mas sim a determinados conteúdos dos direitos subjetivos e às teorias que estão por trás deles. Isso fica claro quando ele afirma que “o problema dos direitos subjetivos não está (...) na sua função de atribuição de bens e competências individuais”, mas em uma individualização e subjetivização de interesses coletivos.⁷⁸ Ou seja: o problema é um problema de conteúdo.

Não há dúvidas de que os problemas substanciais sublinhados pelos autores mencionados são da maior importância para uma teoria tridimensional⁷⁹ dos direitos fundamentais. Mas isso não significa, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista prático, que uma teoria analítica dos status tenha uma menor importância ou não tenha importância alguma. Como tentativa de compreender estruturas complexas, ela tem uma legitimidade científica que independe de sua utilidade prática. Ainda assim, sua grande utilidade prática é demonstrada a partir da constatação de que nas áreas mais complexas dos direitos fundamentais, quando teorias deixam de lado o formal para se concentrarem apenas no conteúdo, elas não conseguem evitar inúmeras obscuridades e contradições.

A crítica a uma “forma de pensar espacializante”⁸⁰ parece ir além da questão formal. Segundo Rupp, “o pensamento em categorias espaciais [*mostra-se*] inimigo de qualquer esforço jurídico-científico de se compreender o direito como um fenômeno social”.⁸¹ Na análise da teoria dos status introduziu-se expressamente o conceito de espaço de liberdade. Um espaço de liberdade nada mais é que uma classe de determinadas liberdades. Se se compreende o conceito de espaço de liberdade dessa forma, ele demonstra ser não simplesmente inofensivo, mas imprescindível. Fazer referência às classes dos objetos analisados é uma característica geral do pensar e do falar. O que pode ser criticado é, quando muito, a utilização do termo “espaço”. No entanto, sua utilização para caracterizar determinadas classes é perfeitamente pos-

78. Idem, p. 200.

79. Sobre a tridimensionalidade da teoria dos direitos fundamentais, cf. Capítulo 1, I.2.

80. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 18.

81. Hans H. Rupp, *Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre*, p. 258, nota 425; cf. também Eike v. Hippel, *Grenzen und Wesensgehalt der Grundrechte*, p. 19.

sível e freqüente. Nesse sentido, em contextos cotidianos fala-se “espaços de ação”, e em contextos filosóficos em “espaço do possível”. Por isso, não é apenas inofensivo, mas correto, quando o Tribunal Constitucional Federal fala de um “espaço jurídico livre”,⁸² de um “espaço jurídico”⁸³ ou de um “espaço de liberdade”.⁸⁴

82. *BVerfGE* 32, 98 (106).

83. *BVerfGE* 33, 23 (28).

84. *BVerfGE* 35, 79 (112).

DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS RESTRIÇÕES

I – CONCEITO E TIPOS DE RESTRIÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS

O conceito de restrição a um direito parece familiar e não problemático. Que direitos tenham restrições e que possam ser restringidos parece ser uma idéia natural, quase trivial, que encontra expressão na Constituição alemã sobretudo quando se fala expressamente em restrições (arts. 5º, § 2º; 8º, § 2º; 10, § 2º; 11, § 2º; 13, § 3º; 14, § 1º, 2; 17a, §§ 1º e 2º; 19, § 1º; 104, § 1º). O problema parece não estar no conceito de restrição a um direito fundamental, mas exclusivamente na definição dos possíveis conteúdo e extensão dessas restrições e na distinção entre restrições e outras coisas como regulamentações, configurações e concretizações.

1. A possibilidade lógica de restrições a direitos fundamentais

Como freqüentemente ocorre com conceitos fundamentais, também aqui a primeira impressão de simplicidade é enganosa. Dentre aqueles que ajudaram a destruir essa impressão deve ser mencionado o nome de Friedrich Klein. Klein opõe-se à concepção, “associada ao termo ‘restrição’ a direitos fundamentais (...) a partir de uma perspectiva superficial ‘naturalista’”, segundo a qual “os direitos fundamentais – enquanto algo permanente por força de sua pré-estatalidade ou por força de sua garantia jurídico-constitucional – seriam restringidos (relativizados)”. Uma “tal relação entre o estabelecimento e a restringibilidade de disposições de direitos fundamentais” não poderia exis-

tir “nos termos das leis da lógica pura”. “de acordo com a lógica pura [não haveria] restrições das disposições de direitos fundamentais, mas apenas definições dessas disposições”.¹ É necessário perguntar se Klein tem razão.

O conceito de restrição a um direito sugere a existência de duas coisas – o direito e sua restrição –, entre as quais há uma relação de tipo especial, a saber, uma relação de restrição. Se a relação entre direito e restrição for definida dessa forma, então, há, em primeiro lugar, o *direito em si*, não restringido, e, em segundo lugar, aquilo que resta do direito após a ocorrência de uma restrição, o *direito restringido*. Essa é a concepção que, normalmente de forma crítica, é denominada de *teoria externa*.² Embora a teoria externa possa admitir que, em um ordenamento jurídico, os direitos apresentam-se sobretudo ou exclusivamente como direitos restringidos, ela tem que insistir que eles são também concebíveis sem restrições. Por isso, segundo a teoria externa, entre o conceito de direito e o conceito de restrição não existe nenhuma relação necessária. Essa relação é criada somente a partir da exigência, externa ao direito em si, de conciliar os direitos de diversos indivíduos, bem como direitos individuais e interesses coletivos.

Um cenário completamente diferente é a base de sustentação da *teoria interna*.³ Segundo ela, não há duas coisas – o direito e sua restrição –, mas apenas uma: o direito com um determinado conteúdo. O conceito de restrição é substituído pelo conceito de limite.⁴ Dúvidas acerca dos limites do direito não são dúvidas sobre quão extensa pode

1. Friedrich Klein, “Vorbemerkung”, in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, B XV 1 b (p. 122).

2. Cf. Wolfgang Siebert, “Vom Wesen des Rechtsmißbrauchs”, in Georg Dahm et al., *Grundfragen der Neuen Rechtswissenschaft*, Berlin: Junker & Dünhaupt, 1935, p. 195.

3. Cf., sobre isso, Wolfgang Siebert, *Verwirkung und Unzulässigkeit der Rechtsausübung*, Marburg: Elwert, 1934, pp. 85 e ss.; do mesmo autor, “Vom Wesen des Rechtsmißbrauchs”, pp. 195 e 200 e ss. Siebert faz referência à “concepção germânica [de Gierke] (...) de que todo direito tem uma restrição imanente” (Otto v. Gierke, *Die soziale Aufgabe des Privatrechts*, Berlin: Springer, 1889, p. 20; cf. também, do mesmo autor, *Deutsches Privatrecht*, v. 2, Leipzig: Duncker & Humblot, 1905, p. 358). Dentre outros autores, Siebert é seguido por: Karl Larenz, “Rechtsperson und subjektives Recht”, in Georg Dahm et al., *Grundfragen der Neuen Rechtswissenschaft*, pp. 230 e ss. No campo dos direitos fundamentais, Häberle tentou aplicar a teoria interna (cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, pp. 179-180).

4. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 126.

ser sua restrição, mas dúvidas sobre seu conteúdo. Quando eventualmente se fala em "restrições" no lugar de "limites", então, se fala em "restrições imanentes".

A polêmica entre a teoria interna e a teoria externa não é, de forma alguma, uma polêmica exclusivamente acerca de questões conceituais e problemas de construção teórica. Entre teorias sobre restrições e hipóteses normativas gerais existem conexões claras. Nesse sentido, alguém que defenda uma teoria individualista do Estado e da sociedade tenderá mais à teoria externa, enquanto alguém para o qual o importante é o papel de membro ou participante de uma comunidade tenderá mais para a teoria interna. Antes de uma análise mais detalhada da relação entre direito e restrição não é possível, contudo, estabelecer mais que essas meras tendências gerais.

Saber se correta é a teoria externa ou a teoria interna é algo que depende essencialmente da concepção de normas de direitos fundamentais como regras ou como princípios, ou seja, da concepção das posições de direitos fundamentais como posições definitivas ou *prima facie*. Se se parte de posições definitivas, então, a teoria externa pode ser refutada; se se parte de posições *prima facie*, então, é a teoria interna que o pode ser.

Partindo-se exclusivamente de *posições definitivas*, um caso simples pode ilustrar de que forma a teoria externa pode ser refutada e, com isso, ao mesmo tempo, de que forma se pode confirmar a teoria de Klein acerca da impossibilidade lógica de restrições a direitos fundamentais. Trata-se de uma reclamação constitucional contra a imposição de multa em razão de desrespeito à obrigação de uso de capacete para motociclistas.⁵ A obrigação de se usar capacete restringe a liberdade jurídica geral, na medida em que se elimina a liberdade jurídica específica de, como motociclista, usar ou não usar capacete. O Tribunal Constitucional Federal fala corretamente em uma "restrição (...) [da] liberdade de ação".⁶ Mas algum direito fundamental é restringido? Os únicos candidatos possíveis são as posições atribuíveis ao art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Como demonstrado anteriormente,⁷

5. BVerfGE 59, 275.

6. BVerfGE 59, 275 (279).

7. Cf. Capítulo 3, II.3.3.

uma posição *abstrata definitiva* é obtida se se combinam o suporte fático e a cláusula de restrição. A posição *abstrata definitiva* que aqui é relevante consiste no direito do indivíduo a não ter sua liberdade de ação restringida por normas que não façam parte da ordem constitucional, isto é, que não sejam nem formal nem materialmente constitucionais.⁸ Pode-se pressupor, como fez o Tribunal Constitucional Federal, que a norma em questão é formal e materialmente compatível com a Constituição. Isso significa que o direito *abstrato definitivo* do art. 2º, § 1º, não pode ser concretizado em um direito em face do Estado a que este não produza aquelas normas. Se se parte do pressuposto de que existe apenas o direito *abstrato definitivo*, então, *não existe* um tal direito concreto. Mas se um tal direito concreto não existe, então, as normas em questão não podem restringir um direito do art. 2º, § 1º. Além disso, ainda que essas normas fossem formal ou materialmente incompatíveis com a Constituição, mesmo assim não poderia ocorrer uma restrição. Neste caso, elas violariam o mencionado direito *abstrato* e seriam, por isso, inconstitucionais. Mas a violação de um direito fundamental é algo muito diferente de sua restrição. Com isso fica estabelecido que, sempre que se parte exclusivamente de posições definitivas, é impossível uma restrição dos direitos do art. 2º, § 1º. Isso pode ser generalizado: se, como resultado (definitivamente), é admissível obrigar ou proibir uma ação *h*, então, não existe, como resultado (definitivamente), um direito a que *h* seja facultativa. Normas que excluam algo sobre o qual não existe um direito não podem restringir direito algum. Mas se, como resultado (definitivamente), existe um direito a que *h* seja facultativa, então, as normas que obriguem ou proíbam *h* não restringem esse direito, elas o violam.⁹

Mantendo-se a hipótese de que existem apenas posições definitivas seria possível sustentar que não são os direitos, mas as liberdades fundamentais, que podem ser restringidos. Essa posição faz sentido apenas se se fizer distinção entre liberdade jurídica geral e liberdade fundamental, já que é trivial a possibilidade de se restringir a liber-

8. BVerfGE 59, 275 (278), com referência a BVerfGE 6, 32 (37 e ss.).

9. Cf., para uma fundamentação semelhante, Karl Brinkmann, *Grundrechts-Kommentar*, Bonn: Bouvier, 1967, Art. III a B, Art. 19 I 1 b; Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 64 e ss.

dade jurídica geral, que consiste na mera ausência de obrigações ou proibições jurídicas.¹⁰ Uma liberdade de direito fundamental existe, então, quando uma alternativa de ação se torna possível *em virtude de uma norma de direito fundamental*. Aqui também é necessário distinguir entre posições definitivas e *prima facie*. Mantido o pressuposto da existência apenas de posições definitivas, então, não é correta a suposição de que as liberdades fundamentais podem ser restringidas. Não existe uma liberdade fundamental definitiva para o uso de capacete, ou seja, uma permissão constitucional de usá-lo ou não. Assim, uma liberdade fundamental não pode ser restringida pela obrigação de se usar capacete. O que pode ser – e, de fato, é – restringido é a liberdade jurídica geral, que pode ser designada como “bem protegido” pelo art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Se se parte exclusivamente de posições definitivas chega-se à conclusão de que posições de direitos fundamentais nunca podem ser restringidas, mas que os bens constitucionalmente protegidos podem.

A uma conclusão completamente diferente se chega, no entanto, se se pressupõe, nos termos da teoria dos princípios, que aquilo que é restringido não são posições definitivas, mas posições *prima facie*. Ao art. 2º, § 1º, é atribuível um princípio que exige a maior medida possível de liberdade geral de ação. No direito fundamental *prima facie* que corresponde a esse princípio há algo de excedente, que pode ser restringido. Esse excedente não é nem algo externo ao ordenamento jurídico – como, por exemplo, um direito natural, uma liberdade natural ou uma situação natural –, nem algo localizável abaixo da Constituição, mas algo que pertence ao acervo de normas constitucionais. Se se parte do modelo de princípios, o que é restringido não é simplesmente um bem protegido pela norma de direito fundamental, mas um direito *prima facie* garantido por essa norma. No modelo de princípios, portanto, é correto falar em restrição a direitos fundamentais.¹¹ Por conseguinte, nesse modelo vale a teoria externa, e a objeção de Klein não é a ele aplicável.

10. Cf. Capítulo 4, II.2.2.1.

11. Se é correto falar em restrição a direitos fundamentais *tão-somente* no âmbito do modelo de princípios, então, aqueles que falam em restrições a direitos fundamentais ou o fazem apenas de forma metafórica, ou pressupõem o modelo de princípios.

2. O conceito de restrição a direitos fundamentais

Uma vez que se tenha estabelecido que – e em qual sentido – se pode falar em “restrição a direitos fundamentais”, é necessário indagar o que são essas restrições. Restringíveis são os bens protegidos por direitos fundamentais (liberdades/situações/posições de direito ordinário) e as posições *prima facie* garantidas por princípios de direitos fundamentais. Entre esses dois objetos de restrições há relações estreitas. Princípios de direitos fundamentais exigem a proteção mais abrangente possível dos bens protegidos, como, por exemplo, a proteção mais ampla possível da liberdade geral de ação, da integridade física ou da competência para alienar a propriedade. Por isso, uma restrição a um bem protegido é sempre também uma restrição a uma posição *prima facie* garantida por um princípio de direito fundamental. Nesse sentido, pode-se dar a seguinte resposta simples à questão acerca do que são restrições a direitos fundamentais: restrições a direitos fundamentais são normas que restringem uma posição *prima facie* de direito fundamental. Essa resposta tem, contudo, um caráter circular, na medida em que utiliza o conceito de restrição para definir o conceito de restrição a direito fundamental. Mas ela oferece um pequeno avanço, ao afirmar que as restrições a direitos fundamentais são *normas*. Então, é possível indagar o que faz com que normas sejam restrições a direitos fundamentais.

É recomendável iniciar a resposta com uma observação geral. Uma norma somente pode ser uma restrição a um direito fundamental se ela for compatível com a Constituição. Se ela for inconstitucional, ela até pode ter a natureza de uma intervenção, mas não a de uma restrição. Com isso, fica estabelecida uma primeira característica: normas são restrições a direitos fundamentais somente se forem *compatíveis com a Constituição*.

Na resolução do problema de se saber o que faz com que normas compatíveis com a Constituição sejam restrições a direitos fundamentais é necessário fazer uma diferenciação entre diversas espécies de normas. Importância especial tem a distinção entre normas de competência que fundamentam a competência do Estado para criar normas e normas mandatórias e proibitivas dirigidas aos cidadãos. As *normas de competência* mais importantes para a teoria das restrições são estabelecidas por meio das reservas legais constitucionais. Por meio delas

o legislador é autorizado a estabelecer restrições aos direitos fundamentais. A essa competência do legislador corresponde a sujeição do titular de direitos fundamentais.¹² É preciso distinguir as competências para a criação de normas que são fundamentadas pelas reservas legais constitucionais – competências diretamente estabelecidas pela Constituição – das competências constitucionais indiretas, que surgem, por exemplo, quando o legislador autoriza a edição de decretos ou quando o poder regulamentar autoriza a edição de atos administrativos. Esses tipos de normas de competência não *restringem* os direitos fundamentais, apenas fundamentam sua *restringibilidade*. Por isso, as reservas legais não são, enquanto tais, restrições; elas apenas fundamentam a *possibilidade jurídica* das restrições. Isso pode ser claramente percebido na possibilidade de haver uma competência para estabelecer restrições sem que dela se faça uso. Nesse sentido, é possível dizer que, não importa em que nível do ordenamento jurídico elas se encontrem, as normas de competência que fundamentam a competência para criar normas não são restrições a direitos fundamentais. Mas, neste ponto, é necessário admitir que a competência para estabelecer restrições tem algo de restritivo para o titular do direito fundamental. A extensão da competência dos órgãos estatais equivale a extensão de sua sujeição às normas criadas de acordo com essa competência. Mas as competências para estabelecer restrições têm algo de restritivo somente porque são restrições cujo estabelecimento está autorizado pelas normas de competência. O caráter restritivo é, portanto, apenas potencial e indireto, e se baseia na natureza restritiva das normas que podem ser criadas em razão da competência.¹³

Um pouco acima foram contrapostas as normas de competência que dizem respeito às competências estatais para estabelecer restrições e os deveres e as proibições dirigidos aos cidadãos. Relevantes não são apenas normas mandatórias e proibitivas, mas também normas que restrinjam ou eliminem competências dos cidadãos. Aquilo

12. Cf. Capítulo 4, II.3.5, no qual a relação entre a competência e a sujeição foi apresentada por meio da equivalência *Kab (RPb) ↔ Sba (RPb)*.

13. Peter Lerche (*Übermaß und Verfassungsrecht*, p. 106) designa também a lei autorizadora como “norma ‘interventora’”. Isso é correto na medida em que uma autorização para o estabelecimento de restrições, a qual sempre é uma autorização para uma intervenção, é algo *potencial e indiretamente* restritivo ou interventivo, no sentido exposto acima.

que pode ser dito acerca do caráter restritivo das normas mandatórias e proibitivas é também aplicável, em sua essência, a outras espécies de normas. Em razão disso, aqui serão analisadas apenas as normas mandatórias e proibitivas. Neste ponto, de fundamental importância é a distinção entre regras e princípios. Início com uma breve análise das regras que estabelecem restrições. Uma *regra* (compatível com a Constituição) é uma restrição a um direito fundamental se, com sua vigência, no lugar de uma liberdade fundamental *prima facie* ou de um direito fundamental *prima facie*, surge uma não-liberdade definitiva ou um não-direito definitivo de igual conteúdo.¹⁴ Alguns exemplos podem esclarecer isso. Enquanto não existe o dever de usar capacete, dirigido aos motociclistas, o titular do direito fundamental tem, em razão do princípio da liberdade geral de ação, uma liberdade fundamental *prima facie* para, como motociclista, usar ou não usar um capacete. Assim que o dever passa a existir, passa o titular a estar em uma posição de não-liberdade definitiva, em face do Estado, no que diz respeito a usar ou não usar capacete. A regra que obriga os motociclistas a usar capacete é uma restrição a um direito fundamental, porque em virtude de sua vigência surge, no lugar da liberdade *prima facie*, uma não-liberdade definitiva de igual conteúdo.

Como exemplo da relação entre uma regra que estabelece uma restrição e um não-direito definitivo pode ser utilizado o § 17, 2, do Regulamento sobre Artes e Ofícios, que “autoriza” o representante da Câmara de Ofícios a entrar em locais de trabalho com o objetivo de examiná-los e vistoriá-los; isso é qualificado expressamente como uma restrição ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.¹⁵ Se se estende a proteção do art. 13 da Constituição alemã também aos locais de trabalho, da forma como o faz o Tribunal Constitucional Federal, então, o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio garante ao indivíduo um direito *prima facie* a não ter seu local de trabalho adentrado pelo representante da Câmara de Ofícios. A esse direito *prima facie* a uma ação negativa corresponde uma proibição *prima facie* de entrar nos locais de trabalho, que atinge o representan-

14. Sobre os conceitos de não-liberdade e não-direito, cf. Capítulo 4, II.1.2.2 e II.2.2.1.

15. Cf., a esse respeito, BVerfGE 32, 54.

te da Câmara de Ofícios.¹⁶ Na medida em que o § 17, 2, do Regulamento sobre Artes e Ofícios permite (“autoriza”) ao representante da Câmara de Ofícios essa visita, a proibição *prima facie* é substituída por uma permissão definitiva. Mas essa permissão é equivalente a um não-direito definitivo à abstenção de visitar.¹⁷ O direito *prima facie* é, assim, substituído por um não-direito definitivo de igual conteúdo. A regra do § 17, 2, é, portanto, uma restrição a um direito fundamental.

Até aqui, o conceito de restrição a direitos fundamentais foi definido somente em relação às regras. Também princípios podem ser restrições a direitos fundamentais. Quando o Tribunal Constitucional Federal afirma que “direitos fundamentais de terceiros e outros valores jurídicos de hierarquia constitucional” também podem restringir direitos fundamentais,¹⁸ ele faz referência a restrições a direitos fundamentais que têm caráter de princípios. Princípios restritivos, por si sós, não são capazes de colocar o indivíduo em determinadas posições definitivamente restringidas (não-liberdades, não-direitos). Para se alcançar uma restrição definitiva é necessário um sopesamento entre o princípio constitucional atingidos e o(s) princípio(s) que o restringe(m). Por essa razão, seria possível imaginar que não são os princípios que podem ser restrições, mas somente as regras que, de acordo com a lei de colisão, expressam o resultado do sopesamento.¹⁹ Em um certo sentido, essa concepção equipararia os princípios às normas de competências, ao encará-los como meros criadores potenciais de restrições. Contra uma tal equiparação há, contudo, um argumento de peso. Princípios colidentes restringem materialmente as possibilidades jurídicas de realização de outros princípios. Se os princípios colidentes não vigessem ou se não tivessem hierarquia constitucional, essas possibilidades seriam mais amplas. Por isso, o problema não reside na sua natureza restritiva, mas na definição da extensão em que restringem outros princípios.

Por isso, também os princípios fazem parte das normas que podem restringir direitos fundamentais. Um *princípio* é uma restrição a

16. Sobre a equivalência entre o direito a uma ação negativa ($Rab \rightarrow G$) e a proibição (relacional) ($Oba \rightarrow G$), cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

17. Acerca da equivalência $PbaG \leftrightarrow \neg Rab \rightarrow G$, cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

18. *BVerfGE* 28, 243 (261).

19. Cf. Capítulo 3, I.3.2.1.

um direito fundamental se há casos em que ele é uma razão para que, no lugar de uma liberdade fundamental *prima facie* ou de um direito fundamental *prima facie*, surja uma não-liberdade definitiva ou um não-direito definitivo de igual conteúdo.

Ambas as definições do conceito de restrição a direitos fundamentais – relativas às regras e aos princípios – têm um caráter relativamente técnico. Não é possível abrir mão disso se se pretende atingir uma clara distinção entre normas de natureza restritiva e normas sem natureza restritiva. Mas o desejo por definições que sejam mais próximas da linguagem usual permanece. Com base nas definições aqui fornecidas, diversas reformulações são possíveis. Aqui é possível mencionar uma, que vai além das normas restritivas mandatórias e proibitivas e diz respeito a todas as normas restritivas: restrições a direitos fundamentais são normas que restringem a realização de princípios de direito fundamental. O que significa restringir a realização de um princípio de direito fundamental é algo demonstrado de forma paradigmática por meio das normas mandatórias e proibitivas.

3. *Espécies de restrições a direitos fundamentais*

Inúmeras e de tipos diversos são as propostas de classificação das restrições a direitos fundamentais. Essa diversidade decorre tanto dos diferentes objetivos das classificações quanto da falta de clareza dos conceitos básicos nos quais elas se baseiam, especialmente do conceito de restrição. Dois objetivos de tipo formal podem ser facilmente distinguidos. O primeiro é perseguido quando se expõem as possíveis diferenciações *no interior* da classe das restrições. Um exemplo de destaque é a extremamente detalhada classificação de Friedrich Klein, construída a partir da diferenciação entre restrições de garantia e restrições de reserva.²⁰ O segundo tipo de objetivo formal é perseguido quando se trata da diferenciação *entre* normas que impõem restrições e normas conformadoras, definidoras de conteúdo ou reguladoras no âmbito dos direitos fundamentais. Aqui deve ser mencionada sobretudo a diferenciação feita por Lerche entre normas interventoras, esclarecedoras, conformadoras, protetoras de abuso e solucionadoras de

20. Cf. Friedrich Klein, "Vorbemerkung", in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, B XV 2, 3.

conflitos.²¹ Apesar dos inúmeros esforços, que levaram a inúmeras e importantes idéias, não se pode dizer que já exista uma sistemática das restrições que seja satisfatória. Uma razão para tanto pode ser o fato de que até agora se abdicou de um fundamento teórico-estrutural para a teoria das restrições. A seguir procurar-se-á desenvolver algumas importantes classificações para a teoria estrutural dos direitos fundamentais, a partir da distinção entre regras e princípios e da teoria das modalidades jurídicas, as quais já constituíram a base da definição do conceito de restrição a direitos fundamentais. Nesse ponto, o que importa são somente as distinções no interior da classe das restrições. O problema da delimitação entre as restrições e outras normas no âmbito dos direitos fundamentais será abordado mais adiante.

3.1 Restrições diretamente constitucionais

Como direitos de hierarquia constitucional, direitos fundamentais podem ser restringidos somente por normas de hierarquia constitucional ou em virtude delas. Restrições a direitos fundamentais são, portanto, ou normas de hierarquia constitucional ou normas infraconstitucionais, cuja criação é autorizada por normas constitucionais. As restrições de hierarquia constitucional são restrições *diretamente constitucionais*, e as restrições infraconstitucionais são restrições *indiretamente constitucionais*. Além dessa distinção, para a compreensão do sistema de restrições da Constituição alemã é imprescindível a distinção entre *restrição* e *cláusula restritiva*. O conceito de restrição pertence à perspectiva do direito, enquanto que o conceito de cláusula restritiva pertence à perspectiva da norma. Uma cláusula restritiva é parte de uma norma de direito fundamental completa, que diz como aquilo que, *prima facie*, é garantido pelo suporte fático do direito fundamental foi ou pode ser restringido. Cláusulas restritivas podem ser *escritas* ou *não escritas*. Serão consideradas, em primeiro lugar, as cláusulas restritivas escritas que contêm restrições diretamente constitucionais.

No caso de algumas cláusulas é questionável se são cláusulas restritivas ou parte do suporte fático. O paradigma é a expressão "pacificamente e sem armas", no art. 8º, § 1º, da Constituição alemã. É muito

21. Cf. Peter Lerche, *Übermaß und Verfassungsrecht*, pp. 106 e ss.

difundida a concepção segundo a qual, no caso de uma tal cláusula, trata-se “não de uma restrição ao direito fundamental, mas de uma descrição diretamente constitucional da extensão substancial da proteção do dispositivo de direito fundamental”.²² Se se parte apenas do teor do texto normativo, essa expressão pode ser interpretada tanto como uma parte do suporte fático quanto como a formulação de uma cláusula restritiva. No primeiro caso o caráter pacífico e a ausência de armas são encarados como condições para que se dê ensejo à proteção constitucional; no segundo caso a cláusula expressa de forma negativa (nem não-pacífica, nem com armas) as condições para a exclusão da proteção constitucional. Com isso fica claro que uma decisão sobre o caráter restritivo não é possível somente a partir do nível do texto normativo. Uma decisão seria possível caso se concordasse com a tese segundo a qual as restrições estabelecidas pelo constituinte não são restrições, mas apenas descrições daquilo que é protegido. Isso teria como consequência a inexistência de restrições diretamente constitucionais. Nesse caso, todas as restrições diretamente constitucionais seriam apenas descrições do conteúdo daquilo que é protegido – exatamente como sugerido pela teoria interna – e poderiam, por isso, ser consideradas como “imanescentes”. Contudo, uma tal interpretação não é obrigatória por razões conceituais e nem são desejáveis suas consequências. A cláusula “pacificamente e sem armas” pode ser interpretada como uma formulação resumida de uma regra, que transforma os direitos *prima facie* decorrentes do princípio da liberdade de reunião em não-direitos definitivos. Isso corresponde exatamente à definição de restrição fornecida acima. A regra expressa pela cláusula restringe a realização de um princípio constitucional. Sua peculiaridade consiste no fato de que foi o próprio constituinte que estabeleceu a restrição definitiva. A disposição constitucional tem, nesse sentido, a natureza de regra. Mas, por trás do nível da regra, o nível do princípio mantém sua importância. Se está claro que uma reunião não é pacífica, ela não goza da proteção do art. 8º.²³ No entanto, para se avaliar se uma reu-

22. Friedrich E. Schnapp, “Grenzen der Grundrechte”, *JuS* 18 (1978), p. 730. Nesse contexto, Konrad Hesse (*Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 310) fala de “limites imanescentes do direito fundamental”.

23. Esse resultado somente poderia ser evitado por meio da inserção de uma cláusula de exceção não escrita na cláusula de restrição, ou seja, por meio de uma decisão contra o teor literal do texto.

ção não é pacífica é necessária, em todos os casos duvidosos, uma interpretação do conceito de não-pacificidade. No âmbito dessa interpretação é sempre também necessário um sopesamento entre o princípio constitucional da liberdade de reunião e os princípios com ele colidentes, os quais deram ensejo a que o constituinte estabelecesse a cláusula restritiva definitiva diretamente constitucional. Isso mostra que a cláusula nada mais é que uma decisão do constituinte a favor de determinadas razões contra a proteção constitucional. Essas razões contra a proteção constitucional – não importa como estejam individualmente constituídas – pertencem, contudo, ao âmbito das restrições. Se se abre mão dessa forma de compreender a questão, haveria o perigo de que o jogo de razões e contra-razões fosse substituído por compreensões mais ou menos intuitivas.

Os problemas suscitados pelo caráter restritivo da cláusula “pacificamente e sem armas” fundam-se essencialmente no fato de que essa cláusula é uma parte do enunciado que garante o direito fundamental. Problemas semelhantes suscitam cláusulas como “todos os alemães” (por exemplo: art. 8º, § 1º), “armado” (art. 4º, § 3º, 1) e “fontes acessíveis a todos” (art. 5º, § 1º, 1). Com base no que foi dito, essas cláusulas devem ser consideradas como expressão de restrições definitivas a direitos fundamentais estabelecidas diretamente pela Constituição. Menos problemas suscita a identificação como cláusula restritiva quando a cláusula aparece em um parágrafo à parte. Assim, a proibição de associações que se “voltem contra a idéia de entendimento entre os povos”, expressa no art. 9º, § 2º, é reconhecida, sem grandes questionamentos, como uma restrição definitiva estabelecida diretamente pela Constituição.

Não tão simples é a classificação de cláusulas que, de um lado, não contêm nenhuma autorização expressa para o estabelecimento de restrições mas que, de outro, fazem referências a normas que, pelo menos em parte, têm caráter infraconstitucional. Um exemplo instrutivo é oferecido pelo art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Direitos de terceiros são restrições diretamente constitucionais apenas na medida em que forem direitos de hierarquia constitucional. Direitos que não têm hierarquia constitucional – cuja existência, portanto, depende de decisões do legislador ordinário, que os pode criar, manter ou eliminar – não são restrições diretamente constitucionais. O mesmo vale para a ordem constitucional. Segundo a interpretação do Tribunal Consti-

tucional Federal, pertencem à ordem constitucional todas as normas de hierarquia constitucional, bem como “toda norma jurídica que, formal e materialmente, seja compatível com a Constituição”.²⁴ Restrições diretamente constitucionais são somente as normas de hierarquia constitucional. Na medida em que a cláusula “ordem constitucional” permite a restrição por meio de normas infraconstitucionais, ela é uma cláusula de reserva: ela confere poderes ao legislador para estabelecer restrições indiretamente constitucionais. A terceira parte da tríade de restrições do art. 2º, § 1º, a moral pública,²⁵ faz referência a normas não-jurídicas. A restrição a um direito fundamental por meio de normas não-jurídicas abarcadas pelo conceito de moral pública não pressupõe uma intermediação de normas infraconstitucionais. Falta, portanto, a referência à competência do legislador ordinário, inerente às restrições indiretamente constitucionais. Por isso, as normas não-jurídicas abarcadas pelo conceito de moral pública podem ser classificadas como restrições diretamente constitucionais.

Problemas especiais geram as cláusulas que se referem a determinadas normas do direito infraconstitucional. Exemplos são a proibição de associações “cujo objetivo ou cuja atividade sejam contrários às lei penais” (art. 9º, § 2º, da Constituição alemã) e as “prescrições das leis gerais”, as “disposições legais para a proteção da juventude” e o “direito à honra pessoal”; segundo o disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição alemã, os direitos do art. 5º, § 1º, encontram suas restrições nessas cláusulas. Na medida em que as normas a que se faz referência estão à disposição do legislador ordinário – que as pode, portanto, manter, eliminar ou alterar –, devem elas ser classificadas como restrições indiretamente constitucionais; e as cláusulas que as garantem, como cláusulas de reserva fundamentadoras de competências para estabelecer restrições. Os problemas surgem a partir do momento em que se pressupõe que a Constituição ordena que haja determinadas normas restritivas do tipo mencionado. Aqui é possível pressupor, sem grandes questionamentos, que o legislador violaria normas constitucionais se revogasse todo o direito à honra pessoal. Significa isso

24. BVerfGE 59, 275 (278); 6, 32 (41).

25. Cf., a respeito, e com mais referências, Christian Starck, “Das ‘Sittengesetz’ als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit”, in Gerhard Leibholz *et al.* (Orgs.), *Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung: Festschrift für Willi Geiger*, Tübingen: Mohr, 1974, pp. 259 e ss.

que aquelas normas destinadas à proteção da honra pessoal, que segundo a Constituição têm que existir, são restrições constitucionais diretas? A resposta a essa questão é negativa. Se o legislador revoga normas destinadas à proteção da honra pessoal, essas normas deixam de existir.²⁶ O que continua a existir é o dever estabelecido constitucionalmente e dirigido ao legislador de que a honra pessoal seja protegida na medida exigida pela Constituição, bem como direitos fundamentais à proteção que correspondem a esse dever. A competência para estabelecer restrições concedida ao legislador por meio da cláusula "direito à honra pessoal" é, portanto, uma competência associada a deveres de proteção. Isso nada muda na existência da competência e, nesse sentido, no caráter indiretamente constitucional das normas que o legislador, para exercer sua competência na forma devida, deve criar ou não revogar.

Até aqui o que interessou foram as cláusulas de restrição escritas que estabelecem restrições constitucionais diretas. O exemplo paradigmático de uma cláusula *não-escrita* é a fórmula do Tribunal Constitucional Federal segundo a qual "os direitos fundamentais colidentes de terceiros e outros valores jurídicos de hierarquia constitucional (...) estão em condições de, excepcionalmente e com a devida consideração à unidade da Constituição e à ordem de valores por ela protegida, restringir, em relações individualizadas, também os direitos fundamentais irrestringíveis".²⁷ Essa cláusula faz referência a restrições com caráter de princípios, a saber, a princípios de direitos fundamentais (direitos fundamentais colidentes de terceiros) e a outros princípios de hierarquia constitucional (outros valores jurídicos de hierarquia constitucional).

Seria possível objetar que a aceitação de restrições constitucionais diretas com natureza de princípios teria como consequência a possibilidade de que todos os órgãos estatais, baseados apenas em princípios constitucionais – ou seja, sem autorização legal –, interviesses nos direitos fundamentais. Mas esse não é o caso, pois às disposições

26. Em uma situação análoga, o Tribunal Constitucional Federal recorreu a uma ordem nos termos do § 35 da Lei do Tribunal Constitucional Federal (*BVerfGE* 39, 1 (2-3, 68)); sobre isso, cf. Jörn Ipsen, *Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt*, Baden-Baden: Nomos, 1980, pp. 241 e ss.

27. *BVerfGE* 28, 243 (261).

de direitos fundamentais não são atribuíveis apenas posições *materiais*, mas também *formais*. Essa distinção corresponde à distinção proposta por Schwabe entre um aspecto material e um aspecto modal da proteção dos direitos fundamentais. O aspecto modal diz respeito “à forma da afetação do bem protegido”.²⁸ Por “forma” Schwabe entende as condições formais da atuação dos três Poderes no âmbito dos direitos fundamentais. Dessas condições fazem parte, dentre outros, o respeito à ordenação constitucional de competências, a autorização por meio de uma norma suficientemente determinada e o cumprimento dos preceitos procedimentais. Um exemplo de uma posição constitucional formal é o direito – que o Tribunal Constitucional Federal atribui ao art. 12, § 1º, da Constituição alemã – a que o poder regulamentar não discipline o exercício profissional sem que haja uma autorização legal suficiente.²⁹ As posições constitucionais formais, que têm importância sobretudo em conexão com as reservas legais no âmbito dos direitos fundamentais,³⁰ significam que um peso preponderante de princípios constitucionais colidentes não confere a eles, por si só, o status de autorizações suficientes para a intervenção. Assim, por exemplo, o Executivo tem que poder se apoiar em uma restrição constitucional indireta, na forma de uma lei, mesmo quando princípios constitucionais colidentes, como restrições constitucionais diretas, fundamentam materialmente uma intervenção.

3.2 Restrições indiretamente constitucionais

Restrições indiretamente constitucionais são aquelas que a Constituição autoriza alguém a estabelecer. A expressão mais clara da competência para impor restrições indiretamente constitucionais encontra-se nas cláusulas de reserva explícitas. Cláusulas de reserva explícitas são aquelas disposições constitucionais – ou parte de disposições constitucionais – que expressamente autorizam intervenções e restrições (art. 2º, § 2º, 3; art. 8º, § 2º; art. 10, § 2º; art. 11, § 2º; art. 13, §§ 2º e

28. Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 23.

29. BVerfGE 53, 1 (15-16).

30. Cf., sobre isso, Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, pp. 102 e ss., 110 e ss.; Thomas Wülfing, *Grundrechtliche Gesetzesvorbehalt und Grundrechtsschranken*, pp. 36 e ss.

3ª, e art. 17a, todos da Constituição alemã). Nesse ponto deve ser feita uma distinção entre reservas simples e qualificadas; no primeiro caso a competência para estabelecer restrições é pura e simplesmente garantida (por exemplo: art. 2º, § 2º, 3, da Constituição alemã) e no segundo caso há uma limitação ao conteúdo da restrição (por exemplo: art. 11, § 2º).³¹ As discussões anteriores demonstraram que a competência para impor restrições não existe apenas quando a ela se faz menção expressa. Sempre que se faz menção a leis ordinárias como forma de restrição, é estabelecida uma competência para impor restrições. Disso são exemplos os arts. 2º, § 1º (segunda parte), 5º, § 2º, e 9º, § 2º, da Constituição alemã. Na medida em que neles se faz referência a leis ordinárias, esses dispositivos podem ser considerados como "cláusulas implícitas de reserva".

O principal problema das reservas é sua delimitação. Neste ponto é necessário distinguir entre os aspectos formal e material. O aspecto formal diz respeito sobretudo à competência para impor restrições, ao seu procedimento e à sua forma. Aqui, no entanto, interessa apenas o aspecto material, e apenas na medida em que diga respeito à competência atribuída ao legislador para impor restrições. Essa competência não é limitada apenas pelas condições expressas nas reservas qualificadas e pela barreira do conteúdo essencial – se se parte de uma garantia absoluta do conteúdo essencial –,³² mas também pela máxima da proporcionalidade e, com isso, pelo dever de sopesamento.³³ A partir dessa associação entre competência e sopesamento evita-se, de um lado, que os direitos fundamentais, ao menos na parte que esteja além da barreira do conteúdo essencial, fiquem à mercê do legislador e, nesse sentido, tenham seu conteúdo esvaziado – resultado, este, incom-

31. A classificação do art. 8º, § 2º, da Constituição alemã suscita problemas. Às vezes ele é tratado como uma reserva simples (cf., por exemplo, Thomas Wülfing, *Grundrechtliche Gesetzesvorbehalt und Grundrechtsschranken*, p. 27), às vezes como uma reserva qualificada (cf., por exemplo, Theodor Maunz/Reinhold Zippelius, *Deutsches Staatsrecht*, 24ª ed., München: Beck, 1982, p. 150). No que diz respeito à liberdade de reunião enquanto tal, ele é uma reserva qualificada, pois autoriza restrições apenas sob a condição de que a reunião ocorra em local aberto. Se se faz referência a reuniões em local aberto, então, ele é uma reserva simples. Como o princípio de direito fundamental representa o ponto de referência para o conceito de restrição, deve-se dar preferência à primeira interpretação.

32. A esse respeito, cf., logo adiante, o tópico I.4 deste capítulo.

33. Cf. Capítulo 3, I.8.

patível com a submissão do legislador aos direitos fundamentais —, mas, de outro lado, cria-se um problema. De maneira sintética, o problema seria o seguinte: o perigo de uma submissão muito frágil é substituído pelo perigo de uma submissão muito forte aos direitos fundamentais. O perigo de uma submissão muito forte pode ser mais claramente ilustrado a partir da tese segundo a qual as reservas conferem ao legislador apenas a competência para expressar aquilo que, de qualquer forma, já é o resultado do sopesamento entre os princípios relevantes. Se isso estivesse correto, todas as restrições indiretamente constitucionais que fossem permitidas apenas reproduziriam as restrições diretamente constitucionais; elas teriam um caráter meramente declaratório, e nunca constitutivo. Na medida em que as restrições diretamente constitucionais também exigem uma determinação por parte do legislador, as diferenças entre restrições indiretamente constitucionais e restrições diretamente constitucionais desapareceriam por completo. A legislação sob reserva constitucional nada mais seria que interpretação das restrições já existentes em virtude do texto constitucional. Como expresso por Häberle, “todas as restrições admissíveis aos direitos fundamentais [*seriam*] imanescentes a eles”.³⁴ As reservas não estabeleceriam uma competência para a imposição de restrições, mas apenas uma competência para a interpretação. A razão para a atribuição dessa competência ao legislador residiria sobretudo na existência de uma discricionariedade interpretativa.³⁵

Uma importante debilidade da teoria interpretativa das reservas é a existência de inúmeros casos nos quais o legislador pode *decidir* se quer, ou não, impor restrições a um direito fundamental. Nesse contexto, é necessário distinguir entre dois grupos de casos. Um caso do primeiro grupo ocorre quando não é claro se, diante do peso dos princípios colidentes, uma restrição *S* é admissível, ou não. Nessas circunstâncias, a competência decisória do legislador é uma competência

34. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 126. Na mesma linha, cf. Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, p. 115.

35. Cf. Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, p. 116. Ao contrário do que defende Wolfgang Kries (*Schranken der Kunstfreiheit als verfassungsrechtliches Problem*, München: Beck, 1967, p. 102), a teoria interpretativa não tem necessariamente como consequência que, em princípio, o legislador seja privado da prerrogativa para a definição de restrições. A competência interpretativa pode ser conferida ao legislador.

para a fixação de uma interpretação vinculante. Um caso do segundo grupo ocorre quando está definido que, em face do peso dos princípios colidentes, a restrição *S* é admissível, mas o legislador tem, mesmo assim, a liberdade de decidir se impõe, ou não, essa restrição. A existência desse tipo de casos somente poderia ser excluída se todas as restrições admissíveis (permitidas) fossem também obrigatórias. Mas isso não é aceitável. Há casos nos quais o legislador pode ser mais generoso do que teria que ser em favor de direitos individuais, em detrimento de interesses coletivos. Um exemplo é a decisão sobre artes e ofícios, na qual o Tribunal Constitucional Federal declarou, de um lado, que a exigência de comprovação de capacidade profissional é compatível com a Constituição mas, de outro lado, que permanecia aberta ao legislador a possibilidade de "deixar ao livre jogo das forças econômicas a garantia e o fomento de padrões de desempenho e da capacidade profissional dos proprietários de oficinas".³⁶ Em ambos os casos é possível falar que o legislador tem uma competência constitutiva para a imposição de restrições. No primeiro caso isso ocorre na medida em que ao legislador é concedido o poder de decisão sobre as interpretações concorrentes; no segundo caso, porque a reserva legal dá ao legislador a possibilidade de realizar o direito fundamental em um grau maior que aquele que a Constituição exige em vista de princípios colidentes. O legislador tem, portanto, uma competência constitutiva para a imposição de restrições.

Com isso, fica demonstrado que as reservas não conferem somente poderes ao legislador para estabelecer aquilo que já existe. Permanece, contudo, a questão acerca da existência de uma autorização para que o legislador estabeleça aquilo que Bachof chama de uma "real restrição à liberdade", ou seja, "estabelecer restrições com efeito constitutivo no âmbito da liberdade para além do ponto estabelecido diretamente pela própria Constituição".³⁷ Se o legislador, no contexto da primeira das situações expostas acima, decide a favor de *S*, isso significa que ele decidiu por uma restrição interpretativamente possível em face do peso dos princípios colidentes. Nesse caso não é possível afir-

36. *BVerfGE* 13, 97 (113-114).

37. Otto Bachof, "Freiheit des Berufs", in Kar-August Bettermann *et al.* (Orgs.), *Die Grundrechte*, v. 3/1, Berlin: Duncker & Humblot, 1958, p. 208; cf. também Theodor Maunz, *Deutsches Staatsrecht*, p. 123, o qual fala de uma autorização "para intervir no conteúdo propriamente dito do direito fundamental".

mar que o legislador foi além do estabelecido diretamente pela Constituição como restrição, mas apenas que ele foi além daquilo que, a partir de uma interpretação alternativa, poderia ser concebido como restrição diretamente estabelecida pela Constituição. O segundo tipo de caso é exatamente o oposto da “real restrição” mencionada por Bachof. O legislador mantém-se aquém daquilo que a própria Constituição estabelece como restrição. Parece, portanto, que nenhum dos dois tipos de casos relaciona-se com as intenções de Bachof e que há um terceiro grupo de casos, caracterizados pelo estabelecimento, por parte do legislador, de uma restrição que extrapola aquilo que é admissível em face do sopesamento dos princípios relevantes. Mas é inadmissível uma restrição a um princípio de direito fundamental que extrapole aquilo que é admissível em face do peso dos princípios colidentes.

Essa refutação da teoria da restrição real é assim tão facilmente possível porque não são feitas diferenciações no âmbito dos princípios colidentes. Se essas diferenciações forem feitas, seria possível perceber que a teoria da restrição real é em certa medida procedente. Anteriormente foi demonstrado que nos sopesamentos devem ser levados em consideração não apenas princípios substanciais, mas também princípios formais.³⁸ Assim, em um sopesamento, ao lado do princípio substancial da liberdade de profissão e do princípio também substancial da ordem política, o princípio formal da decisão por parte do legislador democraticamente legitimado também pode desempenhar um papel. Esse princípio, que diz respeito à competência decisória do legislador – e, por isso, formal –, é o fundamento de uma competência legislativa constitutiva para a imposição de restrições, mesmo que essa competência seja limitada por princípios substanciais. A teoria da restrição real é procedente apenas na medida em que faça referência a essa idéia.

4. Da garantia do conteúdo essencial como restrição das restrições

Até aqui falou-se em restrições a direitos fundamentais. Da natureza principiológica das normas de direitos fundamentais decorriam não apenas a restrição e a restringibilidade dos direitos fundamentais

38. Cf. Capítulo 3, I.4 e II.3.1.

em face de princípios colidentes, mas também que sua restrição e sua restringibilidade têm limites. Uma restrição a um direito fundamental somente é admissível se, no caso concreto, aos princípios colidentes for atribuído um peso maior que aquele atribuído ao princípio de direito fundamental em questão.³⁹ Por isso, é possível afirmar que os direitos fundamentais, enquanto tais, são restrições à sua própria restrição e restringibilidade.

O art. 19, § 2º, da Constituição alemã parece estabelecer um limite adicional à restrição e à restringibilidade dos direitos fundamentais ao proibir a afetação desses direitos em seu conteúdo essencial. A interpretação desse dispositivo é polêmica. Deixando de lado as variações das nuances do debate, é possível sistematizar as teorias acerca do conteúdo essencial por meio da utilização de dois pares conceituais: de acordo com o primeiro par, as teorias sobre o conteúdo essencial são diferenciadas segundo relacionem a garantia do conteúdo essencial a uma situação *subjettiva* ou a uma situação *objetiva* de regulação constitucional; já de acordo com o segundo par, essas teorias são diferenciadas segundo interpretem essa garantia em um sentido *absoluto* ou *relativo*. Aqui não interessa uma exposição detalhada acerca da discussão sobre a garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais.⁴⁰ Aqui se pretende apenas mostrar os efeitos da teoria dos princípios nesse âmbito.

Em uma de suas primeiras decisões o Tribunal Constitucional Federal deixou em aberto a questão acerca de uma interpretação subjetiva ou objetiva do art. 19, § 2º, da Constituição alemã: "Não é necessário decidir se o art. 19, § 2º, proíbe a privação total de um direito fundamental em um caso específico ou se ele apenas pretende evitar que o núcleo do direito fundamental, enquanto tal, seja afetado, por exemplo, por meio da eliminação da garantia geral ancorada na Constituição".⁴¹ Mas nas decisões que se seguiram o tribunal sempre asso-

39. Cf. a esse respeito e com detalhes, Capítulo 3, III.2.2.2.3.

40. Para isso, cf. as apresentações de Theodor Maunz, "Art. 19", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz*, 5ª ed., München: C. H. Beck, 1983; Hartmut Jäckel, *Grundrechtsgeltung und Grundrechtssicherung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1967, pp. 49 e ss.; Joachim Chlosta, *Der Wesensgehalt der Eigentumsgewährleistung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, pp. 39 e ss.; Ludwig Schneider, *Der Schutz des Wesensgehalts von Grundrechten nach Art. 19 Abs. 2 GG*, Berlin: Duncker & Humblot, 1983.

41. *BVerfGE* 2, 266 (285).

ciou a garantia do conteúdo essencial a posições individuais.⁴² Nesse ponto é preciso concordar com o tribunal. Como será analisado adiante, direitos fundamentais são primariamente posições individuais. Se a Constituição estabelece algo tão importante quanto uma proibição de afetação do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, então, isso diz respeito *no mínimo também* a posições de direitos fundamentais individuais.

Uma interpretação objetiva como, por exemplo, a de Friedrich Klein, segundo a qual o art. 19, § 2º, proíbe “que a validade de uma disposição de direito fundamental seja de tal forma reduzida que se torne insignificante para todos os indivíduos ou para a maior parte deles ou ainda para a vida social”,⁴³ pode até coexistir com as interpretações da teoria subjetiva, mas não poderá substituí-la. Que o problema da garantia do conteúdo essencial seja provavelmente mais facilmente solucionável no âmbito de uma teoria objetiva que no âmbito de uma teoria subjetiva não é uma razão suficiente para desprezar essa última. A natureza dos direitos fundamentais como direitos dos indivíduos milita, no mínimo, a favor de uma coexistência de uma teoria subjetiva e de uma teoria objetiva.⁴⁴

As teorias subjetivas acerca do conteúdo essencial podem ser absolutas ou relativas. Segundo a teoria relativa,⁴⁵ o conteúdo essencial é aquilo que resta após o sopesamento. Restrições que respeitem a máxima da proporcionalidade não violam a garantia do conteúdo essencial nem mesmo se, no caso concreto, nada restar do direito fun-

42. Cf. BVerfGE 6, 32 (41); 7, 377 (411); 13, 97 (122); 15, 126 (144); 16, 194 (201); 21, 92 (93); 22, 180 (219); 27, 344 (352); 30, 1 (24); 31, 58 (69); 32, 373 (379); 34, 238 (245); 45, 187 (242, 270-271).

43. Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, Art. 19, Anm. V 2a. Como representantes da teoria objetiva podem ser mencionados, dentre outros: Ernst R. Huber, “Der Streit um das Wirtschaftsverfassung”, *DÖV* 9 (1956), pp. 143-144; Hans Peters, “Elternrecht, Erziehung, Bildung und Schule”, in Karl A. Bettermann/Hans C. Nipperdey/Ulrich Scheuner (Orgs.), *Die Grundrechte*, v. IV/1, Berlin: Duncker & Humblot, 1960, p. 383; Hartmut Jäckel, *Grundrechtsgeltung und Grundrechtssicherung*, pp. 49 e ss.; Sigurd Hendrichs, “Art. 19”, in Ingo v. Münch (Org.), *Grundgesetz: Kommentar*, v. 1, 2ª ed., München: Beck, 1981, §§ 23 e ss.

44. Para uma associação das teorias subjetiva e objetiva, cf. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, §§ 332 e ss.

45. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, pp. 47 e ss.; Eike v. Hippel, *Grenzen und Wesensgehalt der Grundrechte*, pp. 47 e ss. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, §§ 332-333; BGH, *DVB* 1953, p. 371; BGHSt 4, 375 (377).

damental. A garantia do conteúdo essencial é reduzida à máxima da proporcionalidade. Diante da inquestionável vigência da proporcionalidade, o art. 19, § 2º, teria simplesmente um significado declaratório. Já, segundo a teoria absoluta,⁴⁶ cada direito fundamental tem um núcleo, no qual não é possível intervir em hipótese alguma.

Diversas manifestações do Tribunal Constitucional Federal sugerem que ele defende uma teoria absoluta. Na decisão sobre gravações secretas afirma-se, nesse sentido, que “nem mesmo interesses preponderantes da coletividade podem justificar uma intervenção na esfera nuclear da configuração da vida privada, protegida de forma absoluta; não há lugar para um sopesamento nos termos da máxima da proporcionalidade”.⁴⁷ Em outras decisões o tribunal fala de um “limite absoluto, cuja superação violaria o conteúdo essencial do direito fundamental”,⁴⁸ de um “limite extremo”⁴⁹ e de uma “última área intocável”.⁵⁰ Há decisões, contudo, que só podem ser interpretadas nos termos de uma teoria relativa. Na decisão sobre o bem-estar dos adolescentes e a assistência social⁵¹ o tribunal tinha que controlar, dentre outros, dispositivos da Lei de Assistência Social federal que previam a internação em instituições estatais para pessoas que tivessem uma especial fraqueza de vontade ou um descontrole em seus desejos naturais, ou fossem abandonadas, ou corressem o risco de ser abandonadas, e para aqueles que pudessem ser ajudados somente no âmbito de tais instituições estatais. Segundo a interpretação do tribunal, essas previsões afetavam o art. 2º, § 2º, 2, da Constituição alemã em seu conteúdo essencial. Na fundamentação estabelece-se, em primeiro lugar, que “a liberdade da pessoa é um bem jurídico tão elevado que somente pode ser restringida por razões especialmente importantes”. Em um segundo passo o tribunal menciona a proteção da coletividade e do afetado como uma dessas razões especialmente importantes. Neste ponto, é interessante que o tribunal subsome a essas razões a internação, em

46. Cf. Herbert Krüger, “Der Wesensgehalt der Grundrechte i. S. des Art. 19 GG”, *DÖV* 8 (1955), pp. 597 e ss.; Jörg Paul Müller, *Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie*, Bern: Stämpfli, pp. 152 e ss.

47. *BVerfGE* 34, 238 (245).

48. *BVerfGE* 16, 194 (201).

49. *BVerfGE* 31, 58 (69).

50. *BVerfGE* 6, 32 (41). Cf. também *BVerfGE* 32, 373 (379).

51. *BVerfGE* 22, 180.

instituições fechadas, de doentes mentais que impliquem perigo para a comunidade e a internação de pessoas declaradas juridicamente incapazes por razões de sanidade mental, casos, esses, que estão entre os casos problemáticos clássicos da teoria absoluta subjetiva. Em um terceiro passo, o tribunal estabelece que o caso em questão não diz respeito nem à proteção da coletividade, nem à proteção do afetado, mas somente a uma tratamento deste último.⁵² A partir disso, em um quarto passo, é definido o resultado: “Visto que o objetivo de tratar um adulto não é suficiente enquanto razão relevante para a privação da liberdade pessoal”, o direito fundamental da liberdade pessoal resta afetado em seu conteúdo essencial.⁵³ Essa argumentação corresponde exatamente à lei do sopesamento e, nesse sentido, à terceira parte da máxima da proporcionalidade: a máxima da proporcionalidade em sentido estrito. Uma intervenção intensa somente é justificada se estiver fundamentada com base em razões relevantes. No caso concreto há uma intervenção intensa, mas não uma razão fundamentadora relevante. A intervenção é, portanto, injustificada. A proibição de afetação do conteúdo essencial, na forma como o tribunal concebe nessa decisão, nada acrescenta a esse raciocínio.⁵⁴ Se o tribunal defendesse uma teoria absoluta, teria ele que partir de alguma posição fixa. Como exemplo de uma tal posição poderia ser suscitado o direito a não ser internado permanentemente ou por longo período em uma instituição estatal. Mas o tribunal não pressupõe uma tal posição. Ao contrário, ele faz com que a posição abarcada pelo conteúdo essencial dependa das razões relevantes contrárias a uma proteção. Mas essa é exatamente a concepção da teoria relativa.⁵⁵

52. *BVerfGE* 22, 180 (219).

53. *BVerfGE* 22, 180 (220).

54. Além da violação do art. 19, § 2º, o Tribunal identifica ainda uma violação da máxima da proporcionalidade (*BVerfGE* 22, 180 (220)). Ele poderia de pronto ter iniciado com essa máxima.

55. Uma associação ilustrativa entre a garantia do conteúdo essencial e a máxima da proporcionalidade pode ser encontrada na decisão sobre o envio dos autos de um processo de divórcio. Esse envio foi qualificado como uma intervenção no direito de personalidade dos cônjuges. A seguir, lê-se: “Sem a concordância dos cônjuges, isso somente é admissível se for justificado nos termos da máxima da proporcionalidade. Se isso não ocorrer, então, essa medida viola o art. 2º, § 1º, em conjunto com o art. 19, § 2º, da Constituição alemã” (*BVerfGE* 27, 344 (352)).

A decisão que se acaba de apresentar é contraditória com enunciado extraído da decisão acerca das gravações clandestinas, mencionado anteriormente, o qual contém uma clara tomada de posição em favor da teoria absoluta. Na discussão acerca dos princípios absolutos já foi demonstrado⁵⁶ que esse enunciado ou é contraditório ou nada adiciona à teoria absoluta. Nem mesmo interesses significativos da coletividade devem poder justificar uma intervenção no núcleo absolutamente protegido da configuração da vida privada.⁵⁷ Se os interesses da coletividade têm, a partir da *perspectiva do direito constitucional*, um peso maior que o da proteção da configuração da vida privada, então, esses interesses suplantam necessariamente essa proteção. Se eles tiverem um peso maior a partir de alguma outra perspectiva, não podem suplantar a proteção, que, em virtude da Constituição, é obrigatória, e não importa, aqui, se se pressupõe uma teoria absoluta ou uma teoria relativa. Disso decorre que uma teoria absoluta do conteúdo essencial não pode afirmar que razões mais importantes não prevalecem, mas apenas que não existem razões mais importantes.

Quando a teoria absoluta afirma que há posições em relação às quais não há razões mais importantes que justifiquem sua restrição, ela está, em certa medida, correta. No entanto, ela está correta exatamente na medida em que se apóia na teoria relativa. Acima foi demonstrado⁵⁸ que, quanto mais um princípio é restringido, mais ele fica resistente. A força das razões contrapostas tem que crescer de forma sobreproporcional. Isso corresponde à lei da taxa marginal decrescente de substituição, representável por meio de curvas de indiferenças. Nesse sentido, há condições sob as quais é possível afirmar com enorme segurança que nenhum princípio colidente prevalecerá. Essas condições definem o "âmbito nuclear da configuração da vida privada".⁵⁹ Mas o caráter absoluto dessa proteção permanece como uma questão que diz respeito à relação entre os princípios envolvidos. Assim, não é possível excluir uma constelação na qual os princípios contrapostos

56. Cf. Capítulo 3, I.7.2.

57. BVerfGE 34, 238 (245).

58. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.3.

59. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 64: "O que é descrito como 'núcleo' intangível da liberdade de ação ou da liberdade contratual é aquele âmbito dentro do qual, sem dúvidas, não há mais nenhum bem jurídico legítimo de igual ou maior valor capaz de limitar direitos fundamentais".

prevaleçam. Contudo, a segurança da proteção é tão grande que, em condições normais, é possível falar em proteção absoluta. Mas não se pode perder de vista o fundamento relativo dessa proteção. A extensão da proteção "absoluta" depende de relações entre princípios. A impressão de que ela poderia ser identificada direta ou intuitivamente, independentemente de sopesamentos, decorre da segurança na relação entre os princípios. A convicção de que existem direitos que não são relativizados nem mesmo sob circunstâncias as mais extremas – e apenas esses direitos são direitos genuinamente absolutos⁶⁰ – pode ser defendida como vinculante pelo indivíduo que tenha a liberdade de se sacrificar em nome de determinadas máximas, mas não pode ser válida a partir da perspectiva do direito constitucional.

Com isso, chega-se à conclusão de que a garantia do conteúdo essencial, prevista no art. 19, § 2º, da Constituição alemã, não cria, em relação à máxima da proporcionalidade, nenhum limite adicional à restringibilidade dos direitos fundamentais. Visto que ela é equivalente a uma parte da proporcionalidade, fornece ela mais uma razão a favor da vigência dessa máxima.

II – SUPORTE FÁTICO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E RESTRIÇÕES A ESSES DIREITOS

Até aqui os olhares estavam direcionados às restrições a direitos fundamentais, ou seja, àquilo que leva a uma exclusão da proteção do direito fundamental e, nesse sentido, àquilo que constitui o lado negativo das normas de direitos fundamentais. A partir de agora a análise volta-se ao lado positivo da garantia dos direitos fundamentais. Neste ponto, dois conceitos são centrais: o conceito de suporte fático dos direitos fundamentais e o conceito de âmbito de proteção desses direitos. A seguir será analisada, em primeiro lugar, a relação entre os conceitos de suporte fático e de âmbito de proteção. Logo em seguida passar-se-á à fundamentação de uma teoria do suporte fático ou do âmbito de proteção amplo.

60. Sobre o problema da existência de direitos absolutos, cf. Alan Gewirth, "Are there any absolute rights?", *The Philosophical Quarterly* 31 (1981), pp. 1 e ss.; Jerrold Levinson, "Gewirth on absolute rights", *The Philosophical Quarterly* 32 (1982), pp. 73 e ss.; Alan Gewirth, "There are absolute rights", *The Philosophical Quarterly* 32 (1982), pp. 348 e ss.

1. Âmbito de proteção e suporte fático

Os conceitos de âmbito de proteção⁶¹ e de suporte fático devem ser definidos de forma diversa, dependendo da espécie de norma de direito fundamental de que se trate. Mas há algo em comum entre suas diferentes formulações quando ambos são utilizados – como ocorre aqui – como contraparte ao conceito de restrição: eles dizem respeito àquilo que a norma de direito fundamental garante *prima facie*, ou seja, sem levar em consideração as possíveis restrições.⁶² Aqui, ambos os conceitos serão analisados somente no que tange às normas de direitos fundamentais permissivas e às normas que garantem direitos de defesa. A estrutura das normas de direitos fundamentais que garantem direitos a uma ação positiva do Estado e as particularidades do princípio geral da igualdade serão analisadas posteriormente.⁶³

No âmbito dos direitos fundamentais as *normas permissivas*⁶⁴ são aquelas que oferecem menos dificuldades no que diz respeito aos conceitos de suporte fático e de âmbito de proteção. À norma constitucional que permite a cooptação religiosa⁶⁵ pode ser dada a seguinte forma condicional:

- (1) Se uma conduta constitui cooptação religiosa, então, ela é *prima facie* constitucionalmente permitida.⁶⁶

61. Em vez de “âmbito de proteção” são utilizadas também as expressões “âmbito de validade” (cf. Jörg Paul Müller, *Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie*, pp. 89 e ss.) e “âmbito da norma” (cf. sobretudo Friedrich Müller, *Juristische Methodik*, pp. 117 e ss.). Em parte, esses termos são usados como sinônimos; em parte, não.

62. Jürgen Schwabe (*Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 152) fala, nesse contexto, de um “âmbito de proteção potencial ao direito fundamental”.

63. Cf. Capítulo 8, nota 91; Capítulo 9, II.3 e IV.3.

64. Cf., a esse respeito, Capítulo 4, I.2.2.1.3.

65. Cf. *BVerfGE* 12, 1 (4).

66. Segundo Koch, as normas de direitos fundamentais, quando autorizam algo ao titular do direito, estabelecem permissões incondicionadas (Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, p. 20). Isso é correto apenas na medida em que uma norma como a norma (1) possa ser reformulada, sem grandes problemas, como uma norma permissiva incondicionada: (1') A todos é *prima facie* permitido cooptar pessoas de outras crenças. Mas toda norma incondicionada pode tornar-se condicionada. A maneira mais simples de fazê-lo é por meio da quantificação de ações. Com isso, obtém-se o seguinte esquema: (1'') $(x) (Fx \rightarrow PVx)$. x é uma variável de ação sobre indivíduos que agem, (x) é o quantificador universal (para todo

O suporte fático dessa norma é constituído pela cooptação religiosa e pertencem ao seu âmbito de proteção todas as condutas que representam uma cooptação dessa espécie. Suporte fático e âmbito de proteção coincidem totalmente: aquilo que é incluído no suporte fático é incluído também no âmbito de proteção. E há ainda outra congruência: é possível definir a cooptação religiosa como um "bem protegido" da norma mencionada.

Não tão simples é a relação entre suporte fático e âmbito de proteção no caso das normas que garantem direitos de defesa. Direitos de defesa são *direitos a ações negativas* por parte do destinatário do direito fundamental. Acima, os direitos a ações negativas foram divididos em direitos ao não-embaraço de ações do titular do direito fundamental (por exemplo: ao não-embaraço da escolha de uma profissão), direitos à não-afetação de características e situações (por exemplo: à não-afetação da esfera privada física) e direitos à não-eliminação de posições jurídicas de direito ordinário (por exemplo: à não-eliminação de determinadas posições como proprietário).⁶⁷ É possível reduzir os conceitos utilizados para a formulação desses direitos a apenas dois conceitos: o conceito de bem protegido e o conceito de intervenção. *Bens protegidos* são ações, características ou situações, ou ainda posições de direito ordinário, que não podem ser embaraçadas, afetadas ou eliminadas. O conceito de *intervenção* constitui o supraconceito para os conceitos de embaraço, afetação e eliminação.⁶⁸ Os direitos a ações negativas são, portanto, direitos à não-realização de intervenções em determinados bens protegidos. A esse direito à não-realização de uma intervenção corresponde, como já demonstrado,⁶⁹ o dever de não realizar essa intervenção.

$x, \dots$), $\rightarrow$ é o sinal para o condicional (sempre que ..., então, ...), F é um predicado de ação, P é o operador de permissão e V é um operador de ação. Assim, ($1''$) deve ser lida da seguinte forma: Para toda ação x , se x tem a característica F , então, é permitido realizar x . A vantagem de tornar condicionada a permissão está na obtenção de um suporte fático claramente delimitado. Sobre o conceito do indivíduo que age, cf. Donald Davidson, "The logical form of action sentences", in Nicholas Rescher (ed.), *The Logic of Decision and Action*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967, pp. 84 e ss. Sobre a concepção de um operador de ação, cf. Lars Lindahl, *Position and Change*, pp. 50 e ss.

67. Cf. Capítulo 4, II.1.1.1.

68. Sobre esses conceitos, cf. Capítulo 4, II.1.1.1.

69. Cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

É possível dar às normas que garantem direitos a ações negativas uma formulação na qual aparece na cláusula condicional apenas o bem protegido. Um exemplo seria:

- (2) Se uma ação constitui uma escolha profissional, então, há um direito *prima facie* a que nela não se intervenha.

A formulação equivalente para o dever correspondente seria:

- (3) Se uma ação constitui uma escolha profissional, então, intervenções nessa ação são *prima facie* proibidas.

A vantagem dessa construção é que a partir dela se obtém um suporte fático bastante simples. O suporte fático simplesmente descreve o bem protegido; no exemplo, a ação protegida pelo direito fundamental. Essa descrição pode ser interpretada ao mesmo tempo como descrição do âmbito de proteção. Nessa construção o suporte fático e o âmbito de proteção das normas de direitos fundamentais permissivas e das normas garantidoras de direitos de defesa coincidem totalmente. O suporte fático dessa construção pode ser designado como "suporte fático composto pelo bem protegido".

No entanto, essa construção não é recomendável, porque, com ela, o conceito de suporte fático perde seu caráter de contraponto ao conceito de restrição. Uma tal relação entre esses conceitos existe somente se com a satisfação do suporte fático, e caso não ocorra nenhuma restrição, o direito *prima facie* ou a proibição *prima facie* tornam-se direito definitivo ou proibição definitiva. Se se escolhe o suporte fático do bem protegido, o dualismo entre suporte fático e restrição é substituído por um trialismo entre suporte fático, intervenção e restrição. Uma análise mais detida demonstra, no entanto, que isso nada mais significa que a divisão do suporte fático em dois elementos. Assim, (3) pode ser reformulado como:

- (4) Se uma medida é uma intervenção na escolha profissional, então, essa medida é *prima facie* proibida.

E a (4) se pode dar a seguinte forma:

- (5) Se uma ação *h*, realizada por um titular de um direito fundamental, é uma escolha profissional, e se a medida *m* intervém em *h*, então, *m* é *prima facie* proibida.

Embora possa soar um pouco estranho, isso põe às claras sua estrutura. Ora, nada há que milite contrariamente à estrutura triádica (bem protegido/intervenção/restrrição); pelo contrário, ela é até mesmo sugerida por (5). Mas isso ainda não é uma razão suficiente a favor de uma construção do suporte fático somente com base no interesse protegido. A idéia do conceito de suporte fático como um conceito contraposto ao conceito de restrição tem como tarefa abranger todos os pressupostos materiais para a ocorrência da consequência jurídica *prima facie*. No caso das normas que garantem direitos de defesa essa tarefa só pode ser satisfeita por meio de um suporte fático que, diferente do que ocorre no caso das normas permissivas simples, seja composto por dois elementos: o bem protegido e a intervenção. Um tal suporte fático deve ser chamado de "suporte fático composto pelo bem protegido e pela intervenção".

A necessidade de que o conceito de intervenção seja incorporado ao conceito de suporte fático é demonstrada também pelo fato de que a abrangência da proteção *prima facie* depende, em igual medida, da extensão do conceito de bem protegido e da extensão do conceito de intervenção. A decisão do Tribunal Constitucional Federal sobre o direito de entrar e vistoriar oficinas de trabalho mostra com clareza essa relação. O tribunal parte, em primeiro lugar, de uma interpretação tão ampla do conceito de domicílio que até mesmo oficinas de trabalho e escritórios são por ele abrangidos;⁷⁰ depois, no entanto, o tribunal pressupõe um conceito restrito de intervenção, que não abrange a visita e a vistoria desses locais. Apesar da concepção ampla do bem abstratamente protegido, como resultado tem-se uma concepção restrita do suporte fático.

No caso dos direitos de defesa, se se pressupõe um suporte fático composto pelo bem protegido e pela intervenção, então, surgem problemas em relação à coincidência de conteúdo entre o conceito de suporte fático e o conceito de âmbito de proteção. Quando se fala, usualmente, em intervenções no âmbito protegido por um direito fundamental, pressupõe-se um conceito de âmbito de proteção que equivale ao conceito de bem protegido. Não há congruência de conteúdos entre esse conceito de âmbito de proteção e um conceito de suporte fático no qual o conceito de intervenção esteja incorporado. Para se chegar a essa

70. BVerfGE 32, 54 (68 e ss.).

congruência de conteúdos é necessário, ao âmbito de proteção que se refere exclusivamente ao bem protegido (que será chamado, aqui, de “âmbito de proteção em sentido estrito”), contrapor um âmbito de proteção em sentido amplo. O âmbito de proteção em sentido amplo abrange tudo aquilo que é *prima facie* proibido. Entre esse conceito amplo de âmbito de proteção e o conceito de suporte fático composto pelo bem protegido e pela intervenção há uma congruência de conteúdos. Ambos os conceitos de âmbito de proteção têm sua justificação. Como o que aqui nos ocupa é a relação entre suporte fático e âmbito de proteção, de um lado, e restrição, de outro, em geral será feito uso do conceito de âmbito de proteção em sentido amplo.

A construção do suporte fático composto pelo bem protegido e pela intervenção baseia-se nas relações entre os conceitos de intervenção, de bem protegido, de restrição e de proibição definitiva e *prima facie* (direito definitivo e *prima facie*), as quais podem ser expressas por meio das duas leis que se seguem – denominadas *leis de intervenção* –, bem como por meio de suas contraposições:

- (I) Todas as medidas que sejam intervenções em um bem protegido por um direito fundamental são *prima facie* proibidas pelo direito fundamental.
- (II) Todas as medidas que sejam intervenções em um bem protegido por um direito fundamental, e que não sejam justificadas por uma restrição, são definitivamente proibidas pelo direito fundamental.
- (I') Todas as medidas que não sejam *prima facie* proibidas pelos direitos fundamentais não constituem intervenções em um bem protegido por um direito fundamental.
- (II') Todas as medidas que não sejam definitivamente proibidas pelos direitos fundamentais ou não constituem intervenções em um bem protegido por um direito fundamental ou estão justificadas por meio de uma restrição.⁷¹

71. É facilmente perceptível que (I') decorre logicamente de (I) e que (II') decorre logicamente de (II), pois, expresso de forma abreviada, de *E* (intervenção) → *F* (proibição) decorre $\neg F \rightarrow \neg E$. Para o conceito de intervenção, é uma questão interessante – que, no entanto, não será aqui decidida – saber se é válido que “(III) Todas as medidas que sejam *prima facie* proibidas pelos direitos fundamentais constituem intervenções em um bem protegido por um direito fundamental”.

Essas leis fazem com que fique claro que os conceitos de bem protegido e de intervenção não têm necessariamente que determinar os primeiros passos sistemáticos em um controle de constitucionalidade no âmbito dos direitos fundamentais. A partir de uma intervenção em bens protegidos é possível inferir uma proibição *prima facie* (I), mas é também possível, a partir da inexistência de uma proibição *prima facie*, inferir a não-ocorrência de uma intervenção em um bem protegido (I'). O primeiro é recomendável nos casos em que a ocorrência de uma intervenção é clara. No entanto, nos casos em que não é claro se algo deve ser qualificado como uma intervenção – tais casos são discutidos sobretudo sob a rubrica “afetações fáticas”⁷² – é preferível o outro caminho. A decisão sobre se algo é proibido, ou não, pelos direitos fundamentais deve ser tomada, então, com o recurso direto aos princípios envolvidos. É justamente nessa direção que se aponta quando se propõe, na esteira da teoria civilista da finalidade da norma,⁷³ que a ocorrência de uma intervenção não dependa de características como a imediatidade ou a finalidade, mas do objetivo normativo dos direitos fundamentais.⁷⁴

2. Teorias restritas e amplas sobre o suporte fático

A consequência jurídica de uma norma é produzida quando todas as suas condições são satisfeitas. É possível construir um conceito de suporte fático do direito fundamental que abarque a totalidade das condições para uma consequência jurídica definitiva desse direito. Esse

72. Cf. Hans-Ullrich Gallwas, *Faktische Beeinträchtigungen im Bereich der Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1970; Ulrich Ramsauer, *Die faktischen Beeinträchtigungen des Eigentums*, Berlin: Duncker & Humblot, 1980; Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 176 e ss.; Albert Bleckmann, *Allgemeine Grundrechtslehre*, pp. 230 e ss.

73. Cf., por exemplo, Ernst v. Caemmerer, *Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht*, Freiburg: Schulz, 1956; Joseph G. Wolff, *Der Normzweck im Deliktsrecht*, Göttingen: Schwartz, 1962; Hans Stoll, *Kausalzusammenhang und Normzweck im Deliktsrecht*, Tübingen: Mohr, 1968; Erwin Deutsch, *Haftungsrecht*, Köln: Heymanns, 1976, pp. 234 e ss.; Josef Esser/Eike Schmidt, *Schuldrecht*, v. 1/2, 5ª ed., Heidelberg: Müller, 1976, pp. 184 e ss.

74. Ulrich Ramsauer, “Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck”, *VerwArch* 72 (1981), pp. 99 e ss.; Jörg Paul Müller, *Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie*, p. 90.

conceito de suporte fático do direito fundamental deve ser denominado "suporte fático em sentido amplo". No interior do suporte fático em sentido amplo é necessário distinguir entre o suporte fático em sentido estrito, que é aquilo que até agora foi chamado simplesmente de "suporte fático", e a cláusula de restrição. Daqui em diante a menção a "suporte fático" deve ser sempre entendida como suporte fático em sentido estrito.

Para que a consequência jurídica definitiva (proteção definitiva) de um direito fundamental ocorra, o suporte fático tem que ser preenchido e a cláusula de restrição, não; para que ela não ocorra é necessário ou que o suporte fático não seja preenchido ou que a cláusula de restrição o seja. Essa simples constatação é a base lógica para dois tipos muito distintos de construções fundamentadoras no âmbito dos direitos fundamentais: a da *teoria do suporte fático amplo* e a da *teoria do suporte fático restrito*.

Quando se trata de se saber se uma determinada forma de agir é protegida pelos direitos fundamentais – por exemplo, se é por eles permitida –, há duas respostas possíveis: ou ela é permitida, ou não. A partir da divisão entre suporte fático e restrição, a essas duas respostas é possível atribuir quatro construções fundamentadoras, que podem ser representadas pelo seguinte esquema:

- (1) Suporte fático (+), restrição (+): não permitida.
- (2) Suporte fático (+), restrição (-): permitida.
- (3) Suporte fático (-), restrição (+): não permitida.
- (4) Suporte fático (-), restrição (-): não permitida.

Na primeira linha, a forma de agir (*h*) preenche o suporte fático (+) e é abrangida pela restrição (+) e, por isso, não é permitida; na segunda linha, *h* preenche o suporte fático e não é abrangida pela restrição (-) e, por isso, é permitida; etc. É perceptível que para a fundamentação de uma permissão apenas uma das construções serve como argumento, mas para a fundamentação de uma não-permissão, três. Essas três construções são *equivalentes no resultado*. Quem defende uma teoria *ampla* do suporte fático escolherá, se possível, a primeira construção. Quem prefere uma teoria *restrita* irá se decidir, se possível, pela terceira ou pela quarta. A terceira construção tem a estrutura de uma dupla fundamentação: o suporte fático não foi preenchido e, se o tivesse sido, a ação teria sido abrangida por uma restrição.

A freqüente observação de que quanto mais amplo for o suporte fático mais ampla terá que ser a restrição⁷⁵ diz respeito à relação entre a primeira e a quarta construções. Isso vale, contudo, apenas quando se pretende obter o mesmo resultado independentemente de uma concepção ampla ou restrita do suporte fático, como ocorre nas construções (1) e (4) do esquema acima. Aquele que quiser proteger definitivamente o máximo possível dos direitos fundamentais poderá tentar fazê-lo por meio de uma concepção ampla de suporte fático e uma concepção restrita de restrição. Um suporte fático amplo não está necessariamente associado a uma restrição ampla. Decidir se ele deve estar associado a essa restrição ampla é uma questão normativa.

Por isso, é necessário distinguir entre uma teoria ampla do suporte fático como uma *teoria estrutural* e uma teoria ampla do suporte fático como uma *teoria normativa* orientada pelo resultado. Mas, na medida em que o caminho ou a construção de uma fundamentação podem ter influência no seu resultado, uma teoria ampla do suporte fático também tem, mesmo que na forma de uma teoria estrutural, um significado normativo.

Como já foi salientado anteriormente, aqui será defendida uma teoria ampla do suporte fático como uma teoria estrutural. Para fundamentá-la, inicio com uma visão crítica de duas versões de teorias restritas do suporte fático: a teoria do alcance material, de Friedrich Müller, e a teoria da limitação do suporte fático em virtude de leis gerais, de Rübner.

2.1 Teorias restritas do suporte fático

2.1.1 A teoria do alcance material, de Friedrich Müller

A teoria do suporte fático dos direitos fundamentais de Müller é baseada em sua teoria da norma, já exposta e criticada anteriormen-

75. Cf. Wilfried Berg, *Konkurrenzen schrankendivergender Freiheitsrechte im Grundrechtsabschnitt des Grundgesetzes*, Berlin: Vahlen, 1968, p. 42; Ulrich Scheuner, "Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat", p. 508; Michael Klopfer, *Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandsschutz*, p. 44.

te.⁷⁶ A rejeição de sua teoria da norma não implica necessariamente a rejeição de suas teses sobre aquilo que é *prima facie* protegido pelos direitos fundamentais e que, nesse sentido, pertence ao seu suporte fático. A resposta de Müller a essa questão será objeto das considerações que se seguem.

Segundo Müller, “nenhum direito fundamental é garantido de forma ilimitada”.⁷⁷ Isso decorre “da única restrição realmente ‘imaneente’: a sua natureza jurídica”.⁷⁸ Müller justifica essa “reserva da natureza jurídica dos direitos fundamentais” em razão do pertencimento dos direitos fundamentais à ordem constitucional e da impossibilidade de sua ilimitação, daí decorrente: “Enquanto direitos, eles são fundamentados pela Constituição. Por isso, é necessário, como perspectiva irrenunciável a qualquer teoria constitucional ou, se assim se prefere, como elemento não-escrito de todos os programas normativos dos direitos fundamentais, sustentar o ponto de vista sistemático-material de seu pertencimento à ordem jurídica (constitucional), do qual decorre a impossibilidade de uma ilimitabilidade ‘em todas as direções’. É possível classificar essa reserva como a reserva da natureza jurídica dos direitos fundamentais”.⁷⁹

De acordo com Müller, contudo, essa “reserva da qualidade jurídica” não significa de forma alguma que todas as normas de direitos fundamentais ou têm uma cláusula de restrição escrita ou devem ser providas com uma cláusula não-escrita. Isso é exatamente o que ele rejeita taxativamente.⁸⁰ Na verdade, o que se afirma é que “à garantia de cada direito fundamental são impostos limites materiais, em razão de sua qualidade jurídica”.⁸¹ Por isso, de acordo com a “concepção de norma, [que subjaz à sua teoria] (...) a definição dos limites das garantias materiais dos direitos fundamentais, (...) não é feita por meio de anexos não-escritos, mas por meio de um conteúdo normativo expresso, isto é, da *extensão material-normativa* do *âmbito normativo*

76. Cf. Capítulo 2, II.3.

77. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 41.

78. Idem.

79. Idem, p. 44.

80. Idem, pp. 40 e 50. Esse deve ser o motivo por que o próprio Müller declara que o termo “reserva”, em sua fórmula “reserva da qualidade jurídica”, é “dispensável e equivoco” (idem, p. 67).

81. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 32.

formulado, sugerido (...) ou inequivocamente pressuposto pelo texto do dispositivo".⁸² "A definição de 'limites' e a definição de 'conteúdos'" deve, portanto, "expressar substancialmente a mesma coisa".⁸³ "A questão dogmática primária não [deve ser] de forma alguma a maneira pela qual um direito fundamental pode ser restringido, mas sim o quão extenso é o seu conteúdo de validade, a ser desenvolvido a partir da análise do *âmbito da norma* (...) e de sua expressão por meio do programa normativo do direito fundamental".⁸⁴

Assim, em consonância com a teoria geral das normas de Müller, o decisivo para a "extensão material de um direito fundamental"⁸⁵ é o âmbito da norma. As transcrições feitas acima fazem com que fique claro que o conceito de âmbito da norma desempenha duas funções: uma de suporte fático (extensão material-normativa do âmbito da norma) e uma de fonte de argumentos (a partir da análise do âmbito da norma). Aqui interessa apenas a primeira delas,⁸⁶ que é desempenhada pelo âmbito da norma quando, por exemplo, Müller afirma que pintar quadros em um cruzamento viário não "pertence" ao âmbito normativo do art. 5º, § 3º, 1, da Constituição alemã.⁸⁷

O que foi dito até aqui já sugere que a teoria da extensão material de Müller se inclui entre as teorias do suporte fático restrito. Isso fica completamente claro a partir de sua teoria das modalidades materialmente específicas. Do âmbito normativo devem fazer parte apenas as modalidades "materialmente específicas",⁸⁸ "específicas",⁸⁹ "constitucionalmente específicas",⁹⁰ protegidas ou "materialmente" pertencentes,⁹¹ mas não aquelas "modalidades não específicas de exercício de direitos fundamentais".⁹² O conceito "específico" – central nas expressões acima – é definido por Müller da seguinte maneira: "Específica é uma forma de exercício quando se pode demonstrar que a ela

82. Idem (sem grifos no original).

83. Idem, pp. 32-33.

84. Idem, p. 87 (sem grifos no original).

85. Idem, p. 20. Essa formulação foi extraída de *BVerfGE* 12, 45 (53).

86. Sobre a segunda, cf. Capítulo 2, II.3.

87. Friedrich Müller, *Freiheit der Kunst*, p. 59.

88. F. Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 74. Cf. também pp. 93 e 98.

89. Idem, p. 73.

90. Idem, p. 64.

91. Idem, p. 74.

92. Idem, p. 88.

não falta a conexão material com a estrutura do âmbito normativo do direito fundamental (a ser antes dogmaticamente desenvolvida)".⁹³ Se uma modalidade de ação é, ou não, específica para um determinado direito fundamental é algo que deve ser decidido com base no critério de "conexão com a estrutura do âmbito normativo". As exigências para essa conexão, fixadas por Müller, são relativamente grandes. Essa conexão existe se a modalidade de ação é abrangida pelo âmbito "do estruturalmente necessário e essencial para o âmbito da norma substancialmente definido".⁹⁴ Müller oferece um teste simples para se saber se isso ocorre, ou não. Segundo ele, uma modalidade de ação não é específica se ela for *intercambiável*, se permanece aberta uma "possibilidade específica (...) equivalente e intercambiável, abrangida pelo âmbito normativo",⁹⁵ àquele a quem, então, a modalidade "não específica" deve ser rejeitada. Esse teste de intercambiabilidade corresponde à distinção entre o exercício de direitos fundamentais e as "circunstâncias acidentais 'casualmente associadas' a um exercício de direito fundamental".⁹⁶⁻⁹⁷

93. Idem, p. 100.

94. Idem, p. 99.

95. Idem, p. 101.

96. Idem, p. 96.

97. Müller procura preencher esse critério extremamente formal por meio de critérios adicionais. Isso ocorre sobretudo na sua teoria sobre o *típico*. De acordo com ela, na determinação do "âmbito da norma materialmente específico (...) " deve-se partir "inicialmente das formas de exercício e das situações típicas" (*Die Positivität der Grundrechte*, p. 98). O típico não pode, contudo, ser reduzido "ao convencional ou normal" (idem, p. 98; do mesmo autor, *Freiheit der Kunst*, p. 64), pois "exatamente o atípico, individual, o novo e espontâneo pode ser protegido de forma materialmente específica" (do mesmo autor, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 99). Mas se também o não-típico pode ser incluído no suporte fático, então, o conceito de típico, embora possa ser um critério para a inclusão no suporte fático, não pode ser um critério para a exclusão dele.

Interessante é um segundo critério, que faz referência à *finalidade* da garantia do direito fundamental e que inclui aquilo "em razão do qual, de acordo com a experiência histórica, com a convicção política e com a concepção jurídica, o direito fundamental foi garantido" no "estruturalmente necessário e essencial para o âmbito da norma substancialmente definido" (idem). Para fins de delimitação do suporte fático, as finalidades dos direitos fundamentais poderiam somente ser utilizadas se elas fossem definidas de tal maneira que fosse possível a elas atribuir elementos característicos do suporte fático que possibilitassem a decisão também nos casos duvidosos de exclusão. Mas há fortes dúvidas a esse respeito, e não somente pelas razões que em geral já tornam difícil a atribuição de finalidades a normas (sobre isso, cf. Robert Alexy,

O que Müller quer dizer com isso pode ser percebido por meio de seus exemplos. Especialmente instrutivo é o caso do pintor que pinta em um cruzamento viário movimentado.⁹⁸ A solução proposta por Müller é a seguinte: pintar, enquanto tal, é protegido pelo art. 5º, § 3º, 1, da Constituição alemã; o aspecto “pintar em um cruzamento viário” não é, contudo, protegido. Por conseguinte, uma lei que proíba o pintar em um cruzamento viário não estreitaria qualquer “forma de ação específica protegida pelo direito fundamental”,⁹⁹ ela não restringiria qualquer “possibilidade específica de ação” do âmbito normativo.¹⁰⁰ Essa lei seria dirigida “contra uma ação inserida nos arredores da liberdade artística (...), mas que não pertence a seu âmbito normativo”.¹⁰¹ Uma tal lei não representaria ou possibilitaria, portanto, uma intervenção e não seria necessária, por isso, qualquer reserva legal.¹⁰² O mesmo valeria “para uma proibição de pregação ou uma proibição de expressão de opinião política no cruzamento viário já reiteradamente mencionado”¹⁰³ ou para um “músico que à noite, na rua ou em um apartamento com paredes finas, improvisa suas composições para trombone”.¹⁰⁴

As debilidades dessa construção ficam claras quando se realiza uma subsunção sob o art. 5º, § 3º, 1. Não pode haver dúvidas de que por meio desse dispositivo, independentemente do que mais ele protege, são permitidas no mínimo ações que configurem uma expressão artística. Se se orienta pelo teor literal do art. 5º, § 3º, 1, que garante a liberdade artística sem restrições e de forma irrestringível, então, é natural que, em um primeiro momento, a esse dispositivo seja atribuída a seguinte norma permissiva:¹⁰⁵

“Teleologische Auslegung und Gesetzesbindung”, *Sprache und Recht – Loccumer Protokolle* 31 (1980), pp. 143 e ss.), mas também porque as finalidades a serem atribuídas às disposições de direitos fundamentais têm em geral a natureza de princípios.

98. Cf. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, pp. 64 e 73; do mesmo autor, *Freiheit der Kunst*, pp. 56-57.

99. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 64; do mesmo autor, *Freiheit der Kunst*, pp. 56 e 65.

100. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 73.

101. Friedrich Müller, *Freiheit der Kunst*, p. 59. Cf. também p. 124.

102. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 64.

103. Friedrich Müller, *Freiheit der Kunst*, p. 60.

104. Idem, p. 124.

105. Sobre o conceito de atribuição, cf. Capítulo 2, II.2.

- (1) Se uma ação é uma expressão artística, então, a sua realização é permitida.¹⁰⁶

Se se parte dessa norma, então, a questão decisiva para o preenchimento do suporte fático é se o pintar no cruzamento viário é uma ação de expressão artística, ou não. A resposta é fácil: ela é uma expressão artística mas é, ao mesmo tempo, outra coisa – uma perturbação do fluxo de veículos e uma ameaça ao trânsito. Essa segunda característica é uma razão para proibir a ação; mas aquilo que é proibido continua a ser uma expressão artística. No entanto, isso significa que pintar no cruzamento viário preenche o suporte fático da norma permissiva. Mas se, mesmo assim, essa ação deve ser proibida, então, a norma tem que ser modificada. Ela não pode ser expressa pelo conteúdo veiculado em (1).

Aqui se deve indagar como a teoria das modalidades específicas de Müller se comporta diante dessa simples constatação. Afirmar que “modalidades não-específicas de exercício de direitos fundamentais”¹⁰⁷ não pertencem ao âmbito da norma significa dizer que, mesmo que reúnam as características do suporte fático de normas de direitos fundamentais permissivas, as ações em questão não gozam de proteção constitucional caso tenham outras características que possam ser classificadas como não-específicas. Isso significa simplesmente a inclusão de uma cláusula de exceção – que se refira à modalidade não-específica – na norma permissiva formulada anteriormente:

- (2) Se uma ação é uma expressão artística e não tem nenhuma característica que seja uma modalidade não-específica, então, sua realização é permitida.

Se se quer modificar a norma dessa maneira e, ao mesmo tempo, se se quer sustentar que nenhuma cláusula restritiva não-escrita foi criada, é necessário sustentar que cláusulas de exceção não são cláusulas restritivas, mas sim uma parte do suporte fático. Mas essa tese é insustentável tanto por razões substanciais quanto por razões formais.

Ela é insustentável por razões substanciais porque tanto o critério da especificidade quanto o critério da intercambiabilidade são inade-

106. Sobre a estrutura lógica de normas permissivas como essa, cf. a nota de rodapé 66, neste capítulo.

107. Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, p. 88.

quados para a delimitação entre proteção e não-proteção no âmbito dos direitos fundamentais.

A ação de pintar no cruzamento seria também uma modalidade não-específica, e, com isso, excluída da proteção do direito fundamental, mesmo se ele estivesse bloqueado aos veículos – isto é, mesmo se pintar no cruzamento não incomodasse ninguém – ou seja, se não houvesse qualquer motivo razoável para a exclusão da proteção do direito fundamental?¹⁰⁸ Se também nesse caso fosse possível uma retirada do pintor do cruzamento viário, com o fundamento de que permanecer nesse local não seria específico da ação de pintar – isto é, o lugar seria intercambiável –, então, toda e qualquer ação poderia ser proibida sempre que houvesse uma possibilidade de realizá-la em outro lugar, em outro horário e de outra forma. Isso significaria, contudo, retirar do titular do direito fundamental o direito de definir autonomamente a forma pela qual ele faz uso de sua liberdade fundamental. Esse direito é, no entanto, uma posição essencial de direito fundamental.¹⁰⁹

A razão formal está diretamente relacionada à razão substancial. Se, como ocorre no exemplo do pintor do cruzamento viário, não são a não-especificidade e a intercambiabilidade que excluem a proteção, então, deve ser algo diverso. E é facilmente perceptível o que é esse algo. São direitos de terceiros e interesses coletivos como a segurança e a fluidez do tráfego viário. Com isso fica claro que, se os critérios

108. Cf. Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 160.

109. O direito de determinar autonomamente a forma de exercício dos direitos fundamentais não deve ser confundido com um direito do titular de direitos fundamentais de definir autonomamente o suporte fático das normas de direitos fundamentais, direito, esse, que, com certeza, não existe (cf. Josef Isensee, *Wer definiert die Freiheitsrechte?*, Heidelberg: Müller, 1980, pp. 10 e ss.). O primeiro direito mencionado, enquanto direito *prima facie*, alcança apenas aquilo que é abrangido pelo suporte fático que a ele se refere; e, enquanto direito definitivo, apenas aquilo que não é abrangido por uma restrição.

Definir autonomamente no âmbito do suporte fático não significa definir autonomamente sobre o suporte fático. Sobre o direito de se determinar autonomamente a forma de exercício dos direitos fundamentais, cf. Walter Schmitt Glaeser, "Die Freiheit der Forschung", *Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, Wissenschaftsförderung* 7 (1974), p. 119, que salienta, no que se refere à liberdade científica, que é o titular do direito fundamental que deve decidir sobre aquilo que é necessário para essa liberdade.

de Müller conduzem a um resultado correto em um determinado caso, isso ocorre apenas porque por trás deles encontram-se razões relevantes para restrições. Se isso é assim, então, a racionalidade da argumentação jurídica exige que essas razões sejam declaradas. Isso significa, por sua vez, que é necessário incluir na norma permissiva uma cláusula de restrição referente às razões permitidas para restrições. Mas como a liberdade artística é garantida sem reservas pela Constituição, essa cláusula de exceção somente pode se referir a normas restritivas de hierarquia constitucional. Seguindo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, é possível estabelecer uma tal cláusula com o objetivo de restringir direitos fundamentais garantidos sem qualquer reserva.¹¹⁰⁻¹¹¹ Se incluída essa cláusula na norma permissiva, ela passaria a ter a seguinte forma:

- (3) Se uma ação é uma expressão artística, então, sua realização é permitida, a não ser que sua proibição seja uma exigência de princípios de hierarquia constitucional que, diante das circunstâncias do caso, tenham precedência em relação ao princípio da liberdade artística.¹¹²

Com isso, a norma – com sua cláusula de exceção – faz referência expressa ao jogo de razões e contra-razões, que os critérios de Müller ocultavam, mas não tornavam supérfluos. Para que esse jogo ocorra, e para que a definição das restrições definitivas ocorra de forma racional, é necessário manter o suporte fático amplo. A versão de Müller de uma teoria restrita do suporte fático não pode, portanto, ser aceita.

2.1.2 Restrição ao suporte fático em virtude de leis gerais

Um segundo grupo de teorias restritas do suporte fático é constituído pelas teses que retiram do âmbito de proteção aquilo que for abrangido por leis gerais. A generalidade de uma lei pode ser compre-

110. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 28, 243 (261); 30, 173 (193).

111. Cf. Capítulo 3, II.3.3, e, neste Capítulo 6, I.3.1.

112. Uma cláusula de conteúdo semelhante é proposta por Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 163, que pretende acrescentar à “garantia constitucional da liberdade artística” a restrição geral: “nos casos concretos, a liberdade artística tem que ceder em favor de bens jurídicos que tenham maior valor”.

endida de diversas formas.¹¹³ Aqui, interessam apenas duas formas de generalidade, que são aquelas que Smend denominou de “generalidade material” e “generalidade objetiva”.¹¹⁴

Segundo Smend – que elaborou sua distinção no âmbito de sua interpretação do art. 118 da Constituição de Weimar –, *materialmente* gerais são todas as “leis que tenham prioridade em relação ao art. 118 porque o bem social por elas protegido é mais importante que a liberdade de expressão”.¹¹⁵ Häberle – que estendeu a teoria da generalidade material para todos os direitos fundamentais – denomina nesse mesmo sentido como “materiais” aquelas “leis que, em virtude da Constituição, são consideradas como de mesma hierarquia ou de hierarquia superior em relação ao direito fundamental em questão”.¹¹⁶ A partir de ambas as manifestações fica claro que a generalidade material é uma questão de prioridades e de sopesamento. Isso significa, por sua vez, que a teoria da generalidade material não pode ser uma teoria restrita do suporte fático. Para se chegar a um sopesamento é preciso que a conduta a ser avaliada seja, em primeiro lugar, abarcada pelo direito fundamental. É preciso que ela seja protegida *prima facie*. E isso significa que ela é abrangida pelo âmbito de proteção. O conceito de generalidade material é um conceito dependente do sopesamento. Ele representa o resultado de um sopesamento entre as razões – no âmbito do suporte fático – a favor da proteção constitucional definitiva e as razões – no âmbito das restrições – contrárias a essa proteção.

Já o conceito de generalidade objetiva pode conduzir a uma teoria restrita do suporte fático. Segundo Smend, uma lei é *objetivamente* geral quando ela não contém “restrições legais específicas à liberdade de expressão”.¹¹⁷ Para deixar claro que se trata de um conceito contraposto ao conceito de generalidade material, é possível também falar

113. Cf. Christian Starck, *Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes*, Baden-Baden: Nomos, 1970, pp. 49 e ss.

114. Rudolf Smend, “Das Recht der freien Meinungsäußerung”, in Rudolf Smend, *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1968, pp. 96 e ss. Sobre essa distinção, cf., com amplas referências bibliográficas, Eberhard Schwark, *Der Begriff der “Allgemeinen Gesetze” in Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes*, Berlin: Duncker & Humblot, 1970.

115. Rudolf Smend, “Das Recht der freien Meinungsäußerung”, pp. 97-98.

116. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 32.

117. Rudolf Smend, “Das Recht der freien Meinungsäußerung”, p. 96.

em "generalidade *formal*".¹¹⁸ O conceito de generalidade objetiva ou formal pode gerar uma teoria restrita do suporte fático porque com base nele é possível obter, sem sopesamentos, uma exclusão definitiva da proteção de um direito fundamental. Diversas são as propostas de exclusão definitiva da proteção de um direito fundamental em virtude de leis gerais (formais ou objetivas).¹¹⁹ Uma versão especialmente bem desenvolvida, que se apresenta explicitamente como teoria restrita do âmbito de proteção e do suporte fático, pode ser encontrada na obra de Rübner.

Rübner inicia com a constatação de que uma "proteção ilimitada da liberdade em face da lei (...) não é a intenção da Constituição alemã e de qualquer Constituição de um Estado Democrático de Direito".¹²⁰ Neste ponto deve-se concordar com ele. Necessário é indagar sobre a forma como a limitação deve ser construída. A construção proposta por Rübner consiste em uma associação entre os conceitos de lei geral e de ordem jurídica geral com o conceito de âmbito de proteção. O apelo a um direito fundamental não garantiria "qualquer privilégio em face da *ordem jurídica geral*"; ao contrário, "as leis gerais devem ser respeitadas também no-exercício de um direito fundamental".¹²¹ Isso não significaria que "se postula uma reserva geral de lei para todos os direitos fundamentais".¹²² As leis gerais, que Rübner define como as leis "que não se relacionam com o exercício do direito fundamental em questão", não devem – e isso é decisivo para sua construção – "afetar o âmbito de proteção do – limitado! – direito fundamental". Elas dizem respeito a "condutas não incluídas no âmbito de proteção". A inserção na ordem jurídica geral inicia-se exatamente onde os direi-

118. Cf. Rupert Scholz, *Die Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem*, München: Beck, 1971, pp. 335 e ss.

119. Cf. Otto Bachof, *Freiheit des Berufs*, pp. 195-196; Karl-August Betermann, *Grenzen der Grundrechte*, pp. 26 e ss.; Ulrich Scheuner, *Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat*, pp. 510-511; Peter Selmer, "Generelle Norm und individueller Grundrechtsschutz", *DÖV* 25 (1972), p. 558; Ulrich Schwäble, *Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 176 e ss.; Helmut Ridder, *Die soziale Ordnung des Grundgesetzes*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975, p. 78.

120. Wolfgang Rübner, "Grundrechtskonflikte", in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, II, Tübingen: Mohr, 1976, p. 456.

121. Idem, p. 457.

122. Idem.

tos fundamentais encontram seu "limite objetivo". Dessa forma, as leis gerais não estabeleceriam "qualquer restrição adicional aos direitos fundamentais".¹²³ Por conseguinte, um sopesamento não seria nem necessário, nem permitido.¹²⁴ "A tarefa mais importante e mais difícil do intérprete é, nesses casos, simplesmente delimitar corretamente o âmbito de proteção do direito fundamental".¹²⁵

A partir dessa idéia, os conceitos de âmbito de proteção e de lei geral dizem respeito a dois aspectos do mesmo objeto. Se uma lei não intervém no âmbito de proteção de um determinado direito fundamental, então, em relação a esse direito fundamental essa lei é geral; e se ela é geral para um determinado direito fundamental, então, ela não intervém em seu âmbito de proteção. Nesse sentido, do âmbito de proteção é possível inferir a generalidade, e da generalidade é possível inferir o âmbito de proteção. Quando Rűfner afirma que se trata de "identificar o âmbito de proteção de cada direito fundamental",¹²⁶ ele expressa uma certa preferência pela via do âmbito de proteção. Neste ponto, a questão consiste em saber como o âmbito de proteção pode ser identificado. Rűfner propõe o seguinte teste: "Imaginemos que o direito contraposto ao (suposto) exercício de um direito fundamental não fosse previsto pela Constituição e não encontrasse nela qualquer apoio. Seria possível realmente defender (...) que uma procissão não poderia ser proibida em face do risco de uma epidemia (...) ? Formular essa pergunta significa ao mesmo tempo responder a ela de forma negativa".¹²⁷

As debilidades desse critério ficam claras quando se amplia essa especulação teórica. Imagine-se que evitar o risco de uma epidemia

123. Idem, p. 458.

124. Isso seria diferente apenas no caso do art. 5º, § 2º, da Constituição alemã. A reserva de lei geral ali estabelecida teria uma dupla função. De um lado, ela expressaria a máxima geral segundo a qual o agir fora do âmbito de proteção encontra seus limites nas leis gerais e, de outro lado, abriria a possibilidade de intervenções no âmbito de proteção do art. 5º, § 1º. Somente nesse último caso o sopesamento seria admissível. Rűfner abandona expressamente (cf. Wolfgang Rűfner, "Grundrechtskonflikte", p. 457, nota 16) sua antiga concepção segundo a qual um sopesamento poderia ser necessário em todos os casos de leis gerais (cf. Wolfgang Rűfner, "Überschneidung und gegenseitige Ergänzungen der Grundrechte", *Der Staat* 7 (1968), pp. 57-58).

125. Wolfgang Rűfner, "Grundrechtskonflikte", p. 458.

126. Idem, p. 460 (sem grifos no original).

127. Idem, pp. 460-461.

não apenas não é uma razão de proibição prevista ou suportada pela Constituição, mas tampouco uma razão sustentável independentemente da própria Constituição. A procissão seria, então, uma conduta religiosa contra cuja proteção constitucional não haveria argumento. Sob essas condições, ela com certeza estaria incluída no âmbito de proteção do direito fundamental. Isso faz com que fique claro que, se ocorre uma exclusão do âmbito de proteção por causa do risco de epidemia, essa exclusão se dá com base em uma *razão contra a proteção constitucional*. Mas, se há proteção na ausência de uma contra-razão, então, essa contra-razão tem que possuir características que justifiquem a restrição à proteção constitucional que ocorreria se não existisse a contra-razão. Essas características estão presentes quando a contra-razão satisfaz as exigências de uma cláusula – como aquela desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal – para a restrição de direitos fundamentais garantidos sem reservas. Mas essas características estão ausentes se a contra-razão não pode ser considerada tão importante quanto o princípio de direito fundamental que milita em favor da proteção constitucional.

Essa simples reflexão não apenas afasta o fundamento do teste de Rűfner, como também suscita sérios problemas para a teoria restrita do suporte fático em geral, visto que ela mostra que a proteção de um direito fundamental sempre depende da relação entre uma razão a favor dessa proteção e uma razão admissível contrária à proteção, e não de alguma característica do âmbito de proteção identificável independentemente dessa relação entre razões e contra-razões, de algum objeto protegido que deve ou não ser incluído nesse âmbito, ou de leis gerais. Para a teoria restrita há apenas uma saída para escapar desse problema. Ela pode aceitar que, embora a exclusão de algo do suporte fático ou do âmbito de proteção tenha alguma relação com um jogo de razão e contra-razão, ela não tem qualquer relação com um sopesamento. Nos casos de exclusão, a prevalência da contra-razão é tão clara que a realização de um sopesamento se torna completamente supérflua. Os casos do artista que furta seu material de trabalho e do homicídio em pleno palco seriam uma prova disso.¹²⁸ Mas nem todos os casos para os quais Rűfner defende uma exclusão do suporte fático são assim tão claros. Não se duvida de que se possa proibir uma pro-

128. Cf. Wolfgang Rűfner, "Grundrechtskonflikte", p. 460.

cissão se houver um sério risco de epidemia, mas será que um risco relativamente pequeno também excluiria a possibilidade de se recorrer ao direito fundamental à liberdade religiosa? Em caso afirmativo, mesmo nos casos de um ínfimo risco de epidemia – que pode facilmente ocorrer – não seria possível invocar o direito fundamental contra atos de perseguição religiosa. Para a compreensão desse tipo de casos a teoria restrita do suporte fático é muito rudimentar. Ela consegue aceitar uma exclusão definitiva do suporte fático nos casos de alto risco de epidemia e sustentar uma proteção constitucional definitiva nos casos em que não há risco algum; mas para os casos intermediários, que são aqueles juridicamente mais interessantes e nos quais é necessário um sopesamento, a teoria restrita ou não tem nenhuma resposta, ou é contraditória, ou conduz a construções excessivamente complicadas. Ela é contraditória quando permite que a exclusão do suporte fático dependa de um sopesamento, já que sua tese principal é a da possibilidade de exclusão do suporte fático independentemente de sopesamentos. Ela conduz a construções excessivamente complicadas quando pressupõe nos casos de clara prevalência das contra-razões uma exclusão do suporte fático, e nos casos duvidosos defende uma solução do problema da restrição que se baseie no sopesamento. Diante disso, a solução da teoria ampla do suporte fático é consistente e simples. Se uma razão milita em favor da proteção de um direito fundamental, então, deve-se aceitar sua tipicidade, não importa o quão fortes sejam as contra-razões. Isso não significa que em todos os casos seja necessária a realização de extensos sopesamentos. Mas significa que mesmo os casos claros de não-proteção são o produto de um sopesamento, que a *possibilidade* de um sopesamento deve ser mantida para todos os casos e que em nenhum caso o sopesamento pode ser substituído por evidências de qualquer espécie.

2.2 *Uma teoria ampla do suporte fático*

As debilidades das duas teorias restritas analisadas acima consistem na não-fundamentação da exclusão definitiva da proteção do direito fundamental como um jogo de razões e contra-razões, ou seja, como o resultado de um sopesamento entre princípios, mas – pelo menos em uma série de casos – como o resultado da aplicação de critérios supostamente independentes do sopesamento. Foi possível de-

monstrar acima que esses critérios, quando conduzem a resultados justificados, são o resultado de um sopesamento corretamente realizado. Isso pode ser generalizado. No âmbito dos direitos fundamentais, juízos são corretos somente se puderem ser o resultado de um sopesamento corretamente realizado. Se esses juízos forem fundamentados de forma independente de um sopesamento, sua correção depende de se saber se o resultado poderia também ser o resultado de um sopesamento corretamente realizado.

Essa idéia exige uma teoria ampla do suporte fático. Uma teoria ampla do suporte fático é uma teoria que inclui no âmbito de proteção de cada princípio de direito fundamental tudo aquilo que milite em favor de sua proteção. A forma pela qual tanto essa inclusão no âmbito de proteção quanto a inclusão no suporte fático ocorrem pode variar muito. Nesse sentido, a teoria ampla contém um feixe de regras que se referem às diferentes formas dessa inclusão. Menciono aqui apenas duas especialmente importantes:

- (1) Tudo aquilo que apresentar uma característica que – considerada isoladamente – seja suficiente para a subsunção ao suporte fático é considerado como típico, não importa que outras características estiverem presentes.

Exemplos são os casos acima mencionados do pintor no cruzamento viário e da procissão em caso de risco de epidemia.

- (2) No campo semântico dos conceitos de suporte fático devem ser adotadas interpretações amplas.¹²⁹

Como exemplo pode ser utilizado o conceito de imprensa. Uma série de autores propõe uma interpretação restrita. Nesse sentido, “imprensa [é] apenas a publicação de notícias e opiniões de cunho político, cultural ou filosófico, bem como outras reportagens objetivas em jornais e revistas”.¹³⁰ O Tribunal Constitucional Federal, ao contrário, defende uma interpretação ampla: “O conceito ‘imprensa’ deve ser interpretado de forma ampla e formal; ele não pode ficar dependente

129. Sobre o conceito de campo semântico, cf. Robert Alexy, “Die logische Analyse juristischer Entscheidungen”, *ARSP Beih.* 14 (1980), pp. 186 e ss.

130. Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, Art. 5, Anm. VI 3. Para outras interpretações restritas, cf. Herbert Krüger, *Der Wesensgehalt der Grundrechte*, p. 58; Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 394.

de uma valoração – baseada em qualquer que seja o critério – de cada produto impresso. A liberdade de imprensa não se limita à imprensa ‘séria’”.¹³¹ Interessantes são as conseqüências que o tribunal tira para o âmbito das restrições. A concepção ampla não significa que se tenha que conferir uma idêntica proteção constitucional a “qualquer órgão de imprensa, em qualquer contexto legal e em relação a qualquer conteúdo de sua expressão”. Ao contrário, as características específicas de cada produto da imprensa podem ser levadas em consideração “no sopesamento entre a liberdade de imprensa e outros bens jurídicos constitucionalmente protegidos”.¹³² Isso corresponde exatamente à teoria ampla do suporte fático.

Acima foi salientado que no suporte fático composto pelo bem protegido e pela intervenção a extensão do suporte fático não depende apenas da extensão do conceito de bem protegido, mas também da extensão do conceito de intervenção.¹³³ A regra (2) exige, portanto, um conceito amplo de intervenção. Um exemplo de decisão nesse sentido é a decisão acerca da lei sobre o horário de funcionamento do comércio, na qual o Tribunal Constitucional Federal considerou a norma sobre os horários de funcionamento do comércio, cujos destinatários eram os proprietários de lojas comerciais, como um embaraço ao consumidor em suas compras e, por isso, como uma intervenção em sua liberdade geral de ação.¹³⁴⁻¹³⁵

A teoria ampla do suporte fático é objeto de várias críticas. Um primeiro grupo delas aponta para um dilema. Segundo essa crítica,

131. *BVerfGE* 34, 269 (283).

132. *BVerfGE* 34, 269 (283). *Idem*.

133. Cf., neste capítulo, II.1.

134. *BVerfGE* 13, 230 (232-233).

135. Como já foi mencionado, a análise da teoria ampla do suporte fático será aqui limitada aos direitos de defesa. Os suportes fáticos de normas que garantem direitos de igualdade serão analisados mais adiante. E a possibilidade de caracterizar também as normas que garantem direitos a ações positivas por meio da divisão entre suporte fático e cláusula de restrição é algo que fica claro pela “reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade”, à qual o Tribunal Constitucional Federal contrapõe uma – por ele deixada em aberto – “pretensão individual do cidadão à criação de vagas em instituições universitárias” (*BVerfGE* 33, 303 (333)). No momento em que, no âmbito dos direitos a prestações positivas, é feita a distinção entre suporte fático e restrição, necessariamente surge a indagação acerca de uma teoria restrita ou uma teoria ampla do suporte fático.

uma teoria ampla do suporte fático ou garantiria uma proteção constitucional excessiva – o que levaria a uma paralisação da legislação¹³⁶ e a uma ameaça a outros bens jurídicos¹³⁷ – ou, então, se quisesse manter um grau adequado de proteção dos direitos fundamentais, não levaria a sério a vinculação ao texto constitucional.¹³⁸ Além disso, a teoria ampla seria desonesta, porque eliminaria, por meio das restrições, aquilo que anteriormente havia protegido por meio do suporte fático.¹³⁹

De fato, essas objeções podem se basear no fato de que uma teoria ampla tem que excluir mais por meio de restrições que uma teoria restrita. Isso tem uma importância prática sobretudo nos casos de direitos fundamentais garantidos sem reservas. Uma teoria restrita do suporte fático tem a vantagem de poder renunciar totalmente – ou em grande parte – a cláusulas restritivas não-escritas. Para isso, no entanto, ela tem que pagar um alto preço. Ela tem que excluir condutas que, nos termos do texto constitucional, estariam abrangidas pelo suporte fático. Uma procissão, mesmo com o risco de epidemia, continua a ser uma prática religiosa, e a pintura em locais que causem perigo ou atrapalhem outras pessoas também continua a ser uma ação artística. Nesse sentido, o argumento segundo o qual a vinculação ao texto constitucional não é levada a sério pode ser usado também contra a teoria restrita do suporte fático. De forma contraditória com o texto constitucional, a teoria restrita retira do suporte fático condutas que são típicas. Assim, é necessário se perguntar o que é preferível: um relaxamento da vinculação ao texto no âmbito do suporte fático ou um relaxamento da vinculação ao texto no âmbito das restrições, que pode ser orientado por cláusulas como a desenvolvida pelo Tribunal Constitucional Federal acerca da restrição de direitos fundamentais garantidos sem reservas?

Responder a essa questão traz à tona o problema da honestidade. Para analisá-lo, é necessário salientar que ela não diz respeito apenas aos direitos fundamentais garantidos sem reservas, mas a todos os direitos fundamentais, isto é, também àqueles garantidos com reservas.

136. Cf. Wolfgang Rüdner, "Grundrechtskonflikte", p. 456.

137. Cf. Josef Isensee, *Wer definiert die Freiheitsrechte?*, p. 30.

138. Cf. Wolfgang Rüdner, "Grundrechtskonflikte", p. 456.

139. Cf. Josef Isensee, *Wer definiert die Freiheitsrechte?*, p. 31.

A técnica de garantia dos direitos fundamentais sempre deu motivos para considerações críticas. Fechner, por exemplo, fala de uma “dubiedade extremamente inquietante” e de uma “penumbra dos direitos fundamentais”, que saltariam à vista sobretudo quando um primeiro parágrafo desperta “a ilusão de uma validade ilimitada, que é frustrada com a continuação da leitura”.¹⁴⁰ Em seu relato sobre a Constituição da República Francesa, Marx classifica como “um ardis a promessa de liberdade total e a garantia dos mais belos princípios se se deixa a sua aplicação, os *detalhes*, para a decisão da ‘legislação posterior’”.¹⁴¹ Walter Jellinek, no início de seu estudo sobre a reserva legal, indaga de que adiantaria “a primeira frase de um artigo sobre direito fundamental solenemente garantir um direito, se a segunda frase autorizar sua restrição por meio de lei”.¹⁴² Se se quisesse eliminar por completo o problema suscitado nessas citações, seria necessário substituir o catálogo de direitos fundamentais por um abrangente sistema de regras concretas. Isso conduziria a uma codificação de uma amplitude que possivelmente nada deixaria a dever ao Código Civil alemão. Uma tal estratégia, que faria com que os direitos fundamentais deixassem de ser o que são hoje, não é, contudo, a única solução para a questão da honestidade. A insegurança que existiria se nos orientássemos por nada mais que pelo teor literal das cláusulas de restrição pode ser eliminada por meio de uma jurisprudência constitucional que se oriente de forma contínua e racional pela máxima da proporcionalidade. Quando isso ocorre não é mais possível falar seriamente em penumbras, ardis, inutilidade e desonestidade. Partindo-se desse ponto de vista, basta apenas mais um pequeno passo para se perceber que a objeção da desonestidade não atinge a teoria ampla do suporte fático. Pelo contrário: um cidadão que não se interesse apenas pelo resultado, mas também por sua construção e sua fundamentação, considerará mais honesto e convincente se a não-garantia de uma proteção no âmbito dos direitos fundamentais for fundamentada com base na existência

140. Erich Fechner, *Die soziologische Grenze der Grundrechte*, Tübingen: Mohr, 1954, pp. 1 e ss.

141. Karl Marx, “Die Konstitution der Französischen Republik, angenommen am 4. November 1848”, in Karl Marx/Friedrich Engels, *Werke*, v. 7, Berlin: Dietz, 1960, pp. 503-504.

142. Walter Jellinek, “Grundrechte und Gesetzesvorbehalt”, *Deutsche Rechts-Zeitschrift* 1 (1946), p. 4.

de direitos fundamentais de outras pessoas ou interesses comunitários constitucionalmente protegidos que se contrapõem ao seu direito que por meio do argumento segundo o qual sua conduta ou não é materialmente específica, ou é abarcada por uma lei geral, ou é de alguma forma excluída de antemão da proteção constitucional, por não fazer parte do âmbito de proteção do direito fundamental.

Um segundo grupo de objeções deve ser levado mais a sério. Quanto mais amplamente for definido o suporte fático, tanto maior será o número de casos nos quais alguma norma de direito fundamental será relevante e, com isso, tanto maior será o número de colisões de direitos fundamentais. Diante desse cenário, é levantada a objeção de uma "constitucionalização de todo o direito", uma "expansão dos direitos fundamentais" que encerra em si o perigo de uma ampliação excessiva da competência do Tribunal Constitucional Federal.¹⁴³

Já se salientou anteriormente que uma teoria ampla do suporte fático, enquanto teoria construtiva, não conduz necessariamente a uma maior proteção definitiva de direitos fundamentais que uma teoria restrita. Aquilo que uma teoria restrita exclui do suporte fático pode ser, pelo menos em princípio, objeto de uma restrição no âmbito de uma teoria ampla. Mesmo assim, a tese da expansão tem algo de correto. É certo que a proteção definitiva não é necessariamente expandida, mas a proteção *prima facie* o é. Isso significa que aumenta o número de casos cuja solução deve ser representada como o resultado de um sopesamento entre uma razão – no âmbito do suporte fático – para a proteção constitucional e uma razão – no âmbito das restrições – contrária a essa proteção. A questão resume-se a saber se isso deve ser considerado como negativo.

Isso poderia ser considerado negativo por diversas razões. De acordo com uma primeira, como quase todo problema jurídico se transformaria em um caso envolvendo direitos fundamentais, haveria um deslocamento supérfluo e confuso da argumentação jurídica ordinária para a argumentação constitucional. Essa objeção pode ser refutada por meio da distinção entre casos de direitos fundamentais reais e potenciais. Um caso deve ser considerado como um caso *potencial* se uma argumentação no âmbito dos direitos fundamentais, embora pos-

143. Christian Starck, "Die Grundrechte des Grundgesetzes", *JuS* 21 (1981), pp. 245-246.

sível, for totalmente dispensável, por não haver dúvidas acerca da compatibilidade da argumentação jurídica ordinária com os direitos fundamentais. Um caso constitucional *real* diferencia-se dessa situação porque nele são suscitadas dúvidas acerca da proteção ou da não-proteção de direitos fundamentais, de forma que não há como não se recorrer a uma argumentação no âmbito dos direitos fundamentais. Se sempre fosse claro se um caso é um caso real ou potencial, a teoria restrita teria algo a seu favor. Nos casos potenciais a tipicidade poderia ser negada, enquanto a solução dos casos reais ocorreria por meio de restrições ao direito fundamental. Mas entre os casos reais e potenciais não há uma fronteira claramente demarcada. Pelo contrário: entre a completa certeza da proteção ou da não-proteção do direito fundamental e a completa incerteza a esse respeito é de se supor a existência de uma escala de graus de certeza e incerteza. A existência de graus diversos de certeza e incerteza é apenas a face objetiva da questão. A ela se soma uma face subjetiva. Diferentes pessoas inseririam diferentes casos em diferentes posições na escala de certeza e incerteza. Diante dessa constatação, a teoria restrita do suporte fático se vê diante de uma situação difícil. Por mais plausível que ela seja nos casos em que qualquer pessoa – ou, pelo menos, qualquer pessoa minimamente bem-informada e razoável – decidiria com total certeza pela não-proteção, a teoria restrita torna-se problemática nos casos em que alguém não compartilhe dessa sensação de certeza. Os defensores de uma exclusão da proteção podem tentar convencer seus oponentes por meio de argumentos que façam referência à vontade do legislador constituinte, à tradição, ao caráter materialmente não-específico de um exercício de um direito fundamental ou argumentos semelhantes. Enquanto isso ocorrer, eles podem permanecer no âmbito da teoria restrita. Mas, se esses argumentos não forem suficientemente convincentes, a única coisa razoável a ser feita para contrariar os argumentos substanciais em favor da proteção – utilizados pelos oponentes da exclusão dessa proteção – é se utilizar de razões substanciais contra essa proteção que façam referência a direitos de terceiros ou a interesses coletivos. Mas, no momento em que se inicia esse jogo de razões e contra-razões, adentra-se o campo da teoria ampla do suporte fático, a qual defende a tipicidade constitucional de uma conduta mesmo nos casos em que as razões a favor de sua proteção são facilmente refutáveis. Isso significa que a teoria restrita só é adequada para os casos em

que não pode haver dúvidas acerca da não-proteção. Mas uma teoria jurídica que oferece nada ou quase nada para os casos duvidosos é de pouca utilidade.

Diante disso, a teoria ampla do suporte fático tem vantagens claras. Ela pode tratar os casos em que não há dúvidas acerca da não-proteção como casos meramente potenciais, nos quais uma fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais, embora possível, seria totalmente dispensável. Com isso, ela evita o risco de um deslocamento excessivo da argumentação jurídica ordinária na direção de uma argumentação constitucional. Além disso, sempre que surgirem dúvidas acerca da proteção ou da não-proteção constitucional, a teoria ampla pode pressupor a existência de um caso real de direitos fundamentais, o que abre o caminho para uma argumentação substancial, orientada pela máxima da proporcionalidade. Com isso, ela evita o risco de um sufocamento da argumentação constitucional pela argumentação jurídica ordinária.

A teoria ampla do suporte fático conduz a um *modelo em dois âmbitos*. O primeiro âmbito é o âmbito dos casos *potenciais*; o segundo, o âmbito dos casos *reais*. Sempre que um princípio de direito fundamental for relevante, o caso é pelo menos um caso potencial de direitos fundamentais, não importa com que grau de certeza o princípio em questão possa ser superado por princípios colidentes. Um exemplo disso é a proibição de furto. O indivíduo tem sua liberdade geral de ação restringida por essa proibição. A liberdade geral de ação é *prima facie* constitucionalmente protegida pelo princípio da liberdade de ação.¹⁴⁴ No caso do furto esse princípio é, sem dúvida, corretamente superado por princípios colidentes. Ele é, portanto, um caso meramente potencial de direitos fundamentais. Mas mesmo um caso meramente potencial não deixa de ser um caso de direitos fundamentais. Com isso, o ordenamento jurídico assume o caráter de um sistema abrangente de soluções para colisões de direitos fundamentais. A maioria das normas do sistema jurídico pertence ao âmbito dos casos meramente potenciais. O âmbito dos casos potenciais forma o substrato do verdadeiro âmbito dos problemas de direitos fundamentais e da argumentação no

144. Sobre o fato de que "o mandamento 'não furtarás' reduz as possibilidades de uso da minha liberdade", cf. Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, p. 89 (nota 59).

campo desses direitos: o âmbito dos casos *reais* de direitos fundamentais. Esse último âmbito, que abarca tudo aquilo que é duvidoso e polêmico, está apoiado naquele primeiro, no qual se inclui a massa daquilo que é livre de dúvidas e consensual. O mais importante no modelo em dois âmbitos é o fato que a inclusão em um ou outro desses âmbitos não é algo que possa ser decidido de forma definitiva. Se houver alguma dúvida, um caso pode deixar o âmbito do indubitado, ou seja, o âmbito dos casos potenciais; da mesma forma, o outrora duvidoso pode, por meio de decisão, argumentação e/ou práxis, deixar o âmbito dos casos reais e voltar a ser um caso potencial. A possibilidade de se ultrapassar a fronteira de um lado para outro deve permanecer aberta em ambos os sentidos. Não se deve evitar, por meio de uma concepção restrita do suporte fático, que um caso se torne um caso real de direitos fundamentais.

A plausibilidade desse modelo pode ser questionada, sobretudo em casos como o do furto. Nesse sentido, Starck fala em uma “concepção grotesca – e degenerante da consciência jurídica – de um direito fundamental ao homicídio, ao furto e à receptação” e defende uma exclusão do suporte fático nesses casos.¹⁴⁵ Essa objeção não pode ser refutada simplesmente com a referência ao caráter construtivo da teoria ampla do suporte fático ou ao fato de que há um consenso quanto ao resultado, já que Starck salienta, em outra obra, que a ele “não importa o resultado, mas o caminho até esse resultado”.¹⁴⁶ É preciso se questionar, no entanto, se a consciência jurídica é degenerada pela construção jurídica de casos potenciais, ou seja, por formas de fundamentação daquilo que, no cotidiano jurídico, não necessita ser fundamentado. Isso vale sobretudo quando, nos casos mencionados (homicídio, furto, receptação), dificilmente se poderia superar a correção das fundamentações compatíveis com a construção. A impressão do grotesco é suscitada sobretudo em razão da plurivocidade da expressão “direito fundamental”. Não se pode falar em um direito definitivo ao furto etc. O que a teoria ampla aceita é um direito *prima facie* a fazer ou a deixar de fazer o que se deseja. Esse direito é restringido, dentre outras, pela proibição de furtar. Uma tal construção pode ser

145. Christian Starck, “Die Grundrechte des Grundgesetzes”, pp. 245-246.

146. Christian Starck, “Noch einmal: Die Grundrechte des Grundgesetzes”, *JuS* 21 (1981), p. 644.

supérflua no caso do furto, mas grotesca ela não é. Ela adquire sentido quando é concebida como a expressão de um ponto lógico final em uma escala de graus de certeza no estabelecimento de restrições. Mas por que não deveria ser possível às construções jurídicas – caso elas conduzam a conclusões as mais racionais possíveis pelas vias as mais racionais – desvincular-se das concepções intuitivas existentes e seguir suas próprias leis?

Intimamente relacionada às críticas abordadas até aqui está a objeção segundo a qual a teoria ampla do suporte fático conduziria a um aumento no número de colisões e concorrências entre direitos fundamentais.¹⁴⁷ Esse fato é inegável. Além disso, é de se constatar que a solução de concorrências e colisões sempre causou sérias dificuldades à dogmática dos direitos fundamentais. De certa forma, todas as tentativas de solução envolvem questões de valoração. Mas valorações estão também presentes nas concepções restritas do suporte fático. Se isso é assim, então é questionável que o aumento no número de colisões – que, de qualquer forma, têm importância somente quando um caso for um caso real de direitos fundamentais – seja algo negativo. Não seria justamente o contrário, ou seja, não seria exatamente a diminuição no número de colisões e concorrências que seria algo negativo, em razão do postulado segundo o qual todos os pontos de vista relevantes para um determinado caso devem ser levados em consideração? Para que a satisfação desse postulado não conduza a uma sobrecarga daquele que argumenta no âmbito dos direitos fundamentais é necessário que se leve em consideração um postulado de racionalidade contraposto, segundo o qual aquilo que não é duvidoso, ou aquilo sobre o qual há consenso, não necessita de fundamentação. As

147. Sobre os conceitos de colisão e concorrência entre direitos fundamentais, bem como sobre sugestões de soluções, cf. Wilfried Berg, *Konkurrenzen schranken-divergenter Freiheitsrechte im Grundrechtsabschnitt des Grundgesetzes*, pp. 49 e ss.; Manfred Lepa, "Grundrechtskonflikte", *DVBt* 87 (1972), pp. 161 e ss.; Heiner Blaesing, *Grundrechtskollisionen*, Bochum: Dissertation, 1974; Peter Schwacke, *Grundrechtliche Spannungslage*, Stuttgart: Kohlhammer, 1975; Wolfgang Rüfner, "Grundrechtskonflikte", pp. 453 e ss.; Herbert Bethge, *Zur Problematik von Grundrechtskollisionen*, München: Vahlen, 1977; Lothar H. Fohmann, *Konkurrenzen und Kollisionen im Verfassungsrecht*, Berlin: Duncker & Humblot, 1978; Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 304 e ss.

exigências desses dois postulados são mais bem satisfeitas por uma teoria ampla do suporte fático baseada no modelo em dois âmbitos do que por uma teoria restrita.

Ainda permanece, contudo, uma objeção relativa a competências. Essa objeção atingiria a teoria ampla do suporte fático se essa teoria acarretasse um inadmissível “aumento na competência da jurisdição constitucional”, seja em detrimento do legislador, seja em detrimento da jurisdição ordinária.¹⁴⁸ Mas essa consequência não está necessariamente associada à teoria ampla do suporte fático. De início, é duvidoso se a teoria ampla de fato conduz a um aumento do número de ações perante o Tribunal Constitucional Federal. Quem recorre a esse tribunal está interessado em uma proteção definitiva de um direito fundamental, e não em uma constatação dogmática de que sua conduta se insere em um suporte fático, mas é abrangida por uma restrição. Mesmo se uma reclamação constitucional se orientar unilateralmente pelo suporte fático, a comissão de juízes do tribunal poderá rejeitar o recurso por não haver suficiente perspectiva de êxito (§ 93a (3) da Lei do Tribunal Constitucional Federal). A decisão acerca da aceitação do recurso pela turma (§ 93a (4) da Lei do Tribunal Constitucional Federal) impõe ainda um filtro adicional. Se a rejeição do recurso é fundamentada, então, a referência a uma restrição é pelo menos tão convincente quanto a referência a uma não-inclusão no suporte fático. Se a reclamação constitucional é aceita, então, a teoria ampla não apenas não conduz necessariamente a decisões que extrapolem as competências do Tribunal, ela tampouco exerce pressões nesse sentido. Como se demonstrou anteriormente, os princípios formais – isto é, aqueles que expressam questões de competência – fazem parte do grupo de princípios contrapostos. Extrapolar ou não extrapolar determinadas competências não depende da construção da fundamentação, mas da definição do peso dos princípios envolvidos e, com isso, do conteúdo da fundamentação. É certo que em alguns casos uma teoria restrita pode evitar, de antemão, decisões que extrapolem a competência da jurisdição constitucional, ao determinar o conteúdo dos direitos fundamentais com base em uma concepção restrita do suporte fático; contudo, para além dos casos triviais, nos quais não há dúvidas de que

148. Cf. Christian Starck, “Die Grundrechte des Grundgesetzes”, p. 246.

o resultado de ambas as teorias será o mesmo, o preço a ser pago é muito alto. Seria necessário assumir o risco de que uma proteção substantiva a direitos fundamentais seja desconsiderada mesmo nos casos em que possa ser relevante. Questões de competência não podem conferir um peso excessivo a um único aspecto, qual seja, à não-interferência nas decisões do legislador e da jurisdição ordinária. A proteção substancial dos direitos fundamentais também tem que ser levada em consideração.¹⁴⁹ Para que ambos os aspectos sejam otimizados, ou seja, para que se chegue a uma decisão correta tanto do ponto de vista substancial quanto do ponto de vista da competência, o caminho oferecido pela teoria ampla do suporte fático é mais promissor que aquele oferecido pela teoria restrita.

III – RESTRIÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Nem todas as normas de direito ordinário que tenham como objeto algo que é abarcado por um direito fundamental podem ser consideradas como restrições a esse direito. Nesse sentido, o § 1.922, 1, do Código Civil alemão – “Com a morte de uma pessoa (sucessão) seu patrimônio (herança) é totalmente transferido para uma ou mais pessoas (herdeiros)” – não restringe a proteção constitucional do direito de herança. Isso suscita a questão acerca de como se diferenciariam as normas restritivas das não-restritivas no âmbito dos direitos fundamentais. Essa questão tem enorme significado prático: uma norma que não restringe um direito fundamental não necessita ser justificada enquanto restrição a um direito fundamental.

No âmbito dos direitos fundamentais, as normas de direito ordinário podem ser classificadas de diversas formas. Um exemplo é a já mencionada classificação, proposta por Lerche, entre normas interven-toras, esclarecedoras, conformadoras, protetoras de abuso e solucionadoras de conflitos.¹⁵⁰ Por mais esclarecedoras que tais classificações possam ser, a diferenciação entre normas *restritivas* e normas *não-restritivas* continua a ser fundamental, em razão das consequências para a justificação constitucional que acabam de ser mencionadas.

149. Cf. Capítulo 10, III.2.

150. Cf. Peter Lerche, *Übermaß und Verfassungsrecht*, pp. 106 e ss.

Uma norma não-restritiva *no âmbito* de um direito fundamental é uma norma que tem alguma relação com aquilo que é abarcado pelo direito fundamental. Na esteira de uma terminologia muito difundida, seria possível dizer que ela *configura* esse direito.¹⁵¹ Normas que nada tenham a ver a ver com um direito fundamental não são, em relação a esse direito, normas restritivas, mas também não são normas configuradoras. A questão a ser respondida é: o que diferencia restrição de configuração.

A discussão sobre a distinção entre restrição e configuração tende a encontrar um primeiro ponto de partida nas disposições de direitos fundamentais nas quais se diz que algo deve ser “regulado” ou “determinado” por meio ou em virtude de uma lei (por exemplo: arts. 4º, § 3º, 2; 12, § 1º, 2; 12a, § 2º, 3; 14, § 1º, 2; 38, § 3º; e 104, § 2º, 4, todos da Constituição alemã). Mas ela vai além da interpretação desses enunciados. E é Häberle aquele que vai mais além. Segundo ele, *todos* os direitos fundamentais são não apenas passíveis e carentes de restrição legal como também de uma “configuração legal”.¹⁵² Häberle não apenas estende a esfera de configuração a todos os direitos fundamentais, como também utiliza um conceito bastante amplo de configuração. Segundo ele, a configuração diz respeito “ao objetivo constitucional de realizar os direitos fundamentais na vida social”. Para se atingir esse fim, a Constituição necessitaria “da legislação como um *medium* e um meio para a realidade social”.¹⁵³ O legislador configurador teria que realizar uma “configuração criadora”¹⁵⁴ e dar “contribuições constitutivas para o conteúdo dos direitos de liberdade”.¹⁵⁵ Também a

151. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, pp. 180 e ss.; Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, §§ 303 e ss.

152. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 181.

153. Idem, p. 184.

154. Idem, p. 186.

155. Idem, p. 187. Segundo Häberle, as “contribuições constitutivas” do legislador para o conteúdo dos direitos fundamentais não excluem sua vinculação a esses direitos. Mas isso suscita problemas conceituais. Na definição de conteúdos para os direitos fundamentais o legislador não pode estar vinculado ao conteúdo que ele mesmo constitutivamente confere aos direitos fundamentais por meio da criação de normas. Portanto, a vinculação tem que ser estabelecida por outros meios. Uma possibilidade seriam os princípios de direitos fundamentais. Mas uma criação constitutiva de normas é definida pelo fato de os princípios relevantes não definirem obrigatoriamente uma única regra, pois se não fosse assim seria possível apenas uma única “dado de conteúdo” por meio da legislação, o que retiraria desse processo o caráter constitui-

atividade do legislador penal é considerada como uma configuração: "quando o legislador penal age de forma a garantir os direitos fundamentais de um contra os mesmos direitos fundamentais de outros, ele configura os direitos fundamentais como um todo, independentemente do fato de também determinar o conteúdo do direito fundamental do indivíduo".¹⁵⁶ Deste ponto até uma extensão do conceito de configuração ao âmbito do conceito de restrição basta apenas um passo: "a legislação que restringe os direitos fundamentais no interesse de bens jurídicos de igual valor ou de valor superior não prescinde do momento configurador. Não apenas os direitos fundamentais, mas também os limites a esses direitos são o objeto da atividade configuradora do legislador".¹⁵⁷

Nada haveria a censurar em relação a um conceito tão amplo de configuração se o conceito de configuração fosse um supraconceito que englobasse tanto a atividade legislativa restritiva quanto a atividade legislativa não-restritiva. Mas se ele for (também) usado como um conceito contraposto ao conceito de restrição (delimitação), então, há razões para críticas. Se algo, não importa a partir de que ponto de vista, é restritivo, ele permanece restritivo mesmo que, a partir de algum outro ponto de vista, seja também configurador.

Os problemas das teorias sobre configuração decorrem sobretudo da falta de clareza nas diversas formas de utilização do conceito de configuração. Aqui é necessário distinguir duas dessas formas. No caso da primeira o conceito de configuração diz respeito à totalidade da regulamentação no âmbito dos direitos fundamentais. É isso o que Häberle tem em mente quando diz que, na medida em que o legislador penal garante "os direitos fundamentais de um contra os mesmos direitos fundamentais de outros", ele configura "os direitos fundamentais

vo. Mas se várias regras forem igualmente compatíveis com os princípios, então, a escolha de uma delas não estaria sujeita a uma vinculação a eles. O legislador teria, então, uma discricionariedade, no seio da qual poderia escolher de forma constitutiva mas, exatamente por isso, não-vinculada. Nesse sentido, agir de forma constitutiva e vinculação dizem respeito a duas coisas muito distintas: o constitutivo, a uma discricionariedade; a vinculação, aos seus limites.

156. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 189.

157. Idem, pp. 190-191.

como um todo".¹⁵⁸ É perceptível que esse tipo de configuração abarca também restrições. Por meio de uma proibição jurídico-penal elimina-se a liberdade de fazer aquilo que é proibido. Nesse sentido, a proibição de constrangimento ilegal elimina a liberdade jurídica que *a* teria de constranger outras pessoas. E esse cenário não é alterado pelo fato de se tratar de uma proibição dirigida a todos e de que, com isso, se garante ao mesmo tempo a própria liberdade geral de ação de *a*,¹⁵⁹ na medida em que se protege *a* contra constrangimentos por parte de outros cidadãos. Também não deixam de ser restrições as proibições jurídico-penais com as quais qualquer pessoa razoável concordaria ou se houver um direito, baseado em um direito fundamental, a que o Estado garanta a liberdade dos indivíduos contra atos de seus concidadãos por meio de leis penais.¹⁶⁰ Em resumo: o fato de que, por razões de direitos fundamentais, uma norma restritiva seja razoável e exigível para a garantia de liberdades não retira dela a qualidade de restrição.

A segunda forma de utilização do conceito trata a configuração como um conceito contraposto ao conceito de restrição. Nesse caso é possível falar em uma utilização do conceito de configuração em sentido próprio e estrito. Como contraposto à restrição, o conceito de configuração não pode dizer respeito a normas mandatórias ou a normas proibitivas, mas tão-somente a normas de competência,¹⁶¹ visto que normas que expressam deveres ou proibições têm, por definição, um caráter restritivo.¹⁶² Um exemplo paradigmático de normas de competência configuradoras são as normas sobre institutos jurídicos de direito civil. Garantias constitucionais como as referentes ao matrimô-

158. Idem, p. 189. Scholz provavelmente refere-se à primeira forma de utilização do conceito quando denomina a "criação de normas 'compatíveis com a Constituição' como uma configuração substancial (conformação) da liberdade geral de ação" (Rupert Scholz, "Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts", *AöR* 100 (1975), p. 100).

159. Sobre o conceito de proteção de uma liberdade, cf. Capítulo 4, II.2.2.2.

160. Cf. Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, p. 57. Klein salienta que normas "não perdem o seu caráter de restrição porque — e na medida em que — criam condições fáticas para o gozo de liberdades individuais".

161. Sobre o conceito de competência, cf. Capítulo 4, II.3.

162. Aqui se trata do caráter restritivo e do caráter não-restritivo (configurador) de normas. Se se pretende fazer menção ao conceito de configuração para o caso das posições, é possível fazer diferenciações adicionais. Assim, a proibição de constrangimento configura a proteção da liberdade jurídica, mas também intervém nessa liberdade. O primeiro ocorre por meio do segundo.

à luz da teoria dos princípios, é possível falar em uma restrição, carente de fundamentação, ao direito fundamental à propriedade.

A decisão do Tribunal Constitucional Federal acerca do direito de rescisão nos contratos de locação, de 1974,¹⁶⁹ deve ser interpretada exatamente nesse sentido. O tribunal parte de uma colisão entre princípios. Na decisão afirma-se que o legislador, “no âmbito da legislação de direito privado, nos termos do art. 14, § 1º, 2, da Constituição alemã, (...) deve considerar de forma equitativa ambos os elementos da relação dialética, presente na Constituição, entre a liberdade constitucionalmente garantida (...) e o dever de uma ordem socialmente justa da propriedade, e tem que propiciar um equilíbrio justo e uma relação equilibrada aos interesses dignos de proteção de todos os envolvidos”.¹⁷⁰ Isso é uma clara descrição de uma colisão entre princípios. Com relação à “revogação da assim chamada rescisão contratual com proposição de novo contrato”, a decisão afirma que ela, “em certa medida, *restringe* a liberdade de ação do locador”, o que, no entanto, “é justificado pelo art. 14, § 2º, da Constituição alemã, levando-se em consideração a grande importância que a moradia tem para o indivíduo e para a família”.¹⁷¹ Isso expressa um sopesamento que tem como resultado uma restrição. Embora se fale em uma restrição à liberdade de ação, e não ao direito fundamental à propriedade, essa restrição ocorre por meio da eliminação de uma competência de direito civil,¹⁷² à qual o princípio da propriedade privada garante um direito *prima facie*.¹⁷³ A eliminação da rescisão contratual com proposição de novo contrato não deve, por isso, ser qualificada como mera configuração, mas como restrição.¹⁷⁴

169. BVerfGE 37, 132.

170. BVerfGE 37, 132 (140).

171. BVerfGE 37, 132 (141) – sem grifos no original.

172. Sobre a conexão entre liberdade e competência, cf. Capítulo 4, II.3.6.1.

173. Sobre a estrutura desse tipo de direitos, cf. Capítulo 4, II.1.1.1.3.

174. O Tribunal Constitucional Federal classifica as disposições da Lei de Saneamento – que foram examinadas na decisão sobre a extração de cascalho úmido (BVerfGE 58, 300) – como regulações do conteúdo da propriedade e restrições a ela, nos termos do art. 14, § 1º, 2, da Constituição alemã, embora a ênfase recaia às vezes na determinação de conteúdo, às vezes no estabelecimento de restrições (BVerfGE 58, 300 (332 e ss.)). O objeto e a extensão da proteção outorgada pelo art. 14, § 1º, 1, devem resultar, dentre outras, dessa regulação (BVerfGE 58, 300 (336)). Alguém poderia pensar que o conceito de restrição, acima definido, não seria compatível com

O que foi dito acima sobre a rescisão contratual com proposição de novo contrato pode ser generalizado. Sempre que a eliminação de uma competência iniba a realização de um princípio de direito fundamental não se trata de uma simples configuração, mas de uma restrição, que, enquanto tal, necessita ser justificada.

Em todos os casos o critério da não-inibição da realização de um princípio de direito fundamental pode ser utilizado para diferenciar entre configuração e restrição. Nesse sentido, embora o Tribunal Constitucional Federal pressuponha que, em si, a criação de um procedimento para que alguém seja reconhecido como objeto de consciência é permitida pelo art. 4º, § 3º, 2, da Constituição alemã, o mesmo não se pode dizer da restrição do efeito desse reconhecimento apenas para o período posterior à entrada em vigor desse procedimento. Essa limitação é tratada como uma restrição que deve analisada no âmbito de um sopesamento entre o princípio constitucional cuja realização é obstaculizada por essa limitação e o princípios constitucionais contrapostos relevantes para o caso concreto.¹⁷⁵

O critério da não-inibição da realização de um princípio de direito fundamental pressupõe que sempre que um sopesamento orientado pela máxima da proporcionalidade seja necessário (caso real de direitos fundamentais) ou simplesmente possível (caso potencial) não se pode falar em uma configuração, pois se trata de uma restrição. Os sopesamentos realizados pelo Tribunal Constitucional Federal no âmbito de sua jurisprudência sobre a liberdade de escolha e de exercício profissionais¹⁷⁶ demonstram que a autorização de regulamentação feita pelo art. 12, § 1º, 1, da Constituição alemã não é por ele concebida como autorização para configuração, mas sim como autorização para restrição.

essa concepção. Mas esse não é o caso. O fato de o tribunal pressupor uma restrição no sentido aqui definido é demonstrado pela sua fundamentação para a norma impugnada em face das exigências do direito fundamental, fundamentação, essa, que inclui também um exame de proporcionalidade (*BVerfGE* 58, 300 (338 e ss.)). O ponto decisivo da decisão é o fato de que o ponto de referência da desapropriação não é constituído pelo direito *prima facie*, que, por definição, é ilimitado, mas por um direito já definitivamente restringido por meio de leis compatíveis com a Constituição, ou seja, restringido de forma permitida (*BVerfGE* 58, 300 (336)). Isso não contradiz o conceito de restrição aqui defendido; pelo contrário, ele o pressupõe.

175. *BVerfGE* 28, 243 (260-261).

176. Cf. sobretudo *BVerfGE* 7, 377 (399 e ss.).

Apenas uma concepção assim restrita do conceito de configuração, à qual corresponde um conceito amplo de restrição, é compatível com as exigências de racionalidade na fundamentação dos casos envolvendo direitos fundamentais. Aquilo que é qualificado como configuração não necessita de fundamentação em face dos direitos fundamentais. Ainda que, por meio de um conceito restrito de configuração, que mantenha amplo o âmbito daquilo que é carente e passível de fundamentação, não se possa assegurar que ocorram somente restrições permitidas, com isso se garante, ainda assim, que nenhuma restrição esteja isenta de fundamentação, o que é um pressuposto essencial para que sejam estabelecidas somente restrições permitidas.

O DIREITO GERAL DE LIBERDADE

O direito constitucional da República Federal da Alemanha não garante apenas direitos a determinadas liberdades, como, por exemplo, a liberdade de expressão ou a liberdade de profissão, ou direitos contra determinadas discriminações, como, por exemplo, aquelas baseadas no gênero ou na raça, mas também um direito geral de liberdade e um direito geral de igualdade. Com isso, no entanto, dois dos objetos mais polêmicos da Filosofia Política transformaram-se diretamente em objetos de direitos positivos. Não é de se admirar que isso tenha suscitado uma série de questionamentos dogmáticos. Neste ponto pretende-se demonstrar, a partir de alguns problemas, em que as teses até aqui desenvolvidas acerca da estrutura das normas de direitos fundamentais e da estrutura desses direitos podem contribuir para seu esclarecimento. Em primeiro lugar será analisado o direito geral de liberdade.

I – O CONCEITO DE DIREITO GERAL DE LIBERDADE

Em uma das mais importantes decisões de seus primeiros anos, a decisão no caso Elfes,¹ o Tribunal Constitucional Federal interpretou o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, previsto no art. 2º, § 1º, da Constituição alemã, como um direito à liberdade geral de ação. Desde então, a despeito de inúmeros refinamentos dogmáticos, o tribunal se tem mantido fiel a essa concepção.² Dessa maneira, ele

1. *BVerfGE* 6, 32.

2. Para decisões mais recentes, cf. *BVerfGE* 59, 275 (278).

claramente rejeitou as tentativas de controlar a extensão – considerada frequentemente como uma fórmula vazia³ – tanto do suporte fático quanto da cláusula de restrição do art. 2º, § 1º, por meio de restrições ao suporte fático ou por meio de modificações no caráter geral desse dispositivo. Um exemplo dessas tentativas pode ser encontrado, de um lado, nas teorias *objetivas*, que rejeitam que a norma do art. 2º, § 1º, garanta diretamente um direito subjetivo;⁴ de outro lado, podem ser mencionadas as teorias *restritas*, que se esforçam em limitar o suporte fático do direito, o que, em sua forma mais extrema, é o caso da teoria do núcleo da personalidade de Peters, segundo a qual o art. 2º, § 1º, protege apenas “expressões da verdadeira natureza humana no sentido de uma concepção cultural ocidental”.⁵⁻⁶ Ao invés disso, o

3. Cf. Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, p. 113. Nipperdey fala de um problema de “distinção entre duas cláusulas gerais”. Cf. Hans C. Nipperdey, “Freie Entfaltung der Persönlichkeit”, in Karl A. Bettermann/Hans C. Nipperdey (Orgs.), *Die Grundrechte*, v. 4/2, Berlin: Duncker & Humblot, 1962, p. 789.

4. Cf. Friedrich Klein, “Art. 2º”, in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, v. 1, Anm. III 5 a, b; Diether Haas, “Freie Entfaltung der Persönlichkeit”, *DÖV* 7 (1954), pp. 70-71; Herbert Wehrhahn, “Systematische Vorfragen einer Auslegung des Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes”, *AöR* 82 (1957), pp. 250 e ss.; Wilhelm Wertenbruch, “Der Grundrechtsbegriff und Art. 2 Abs. 1 GG”, *DVBl* 73 (1958), pp. 481 e ss. Todas essas teorias estão sujeitas à forte objeção de que com a cláusula “os direitos fundamentais seguintes”, do art. 1º, § 3º, a própria Constituição qualifica o art. 2º, § 1º, como uma norma garantidora de um direito fundamental.

5. Cf. Hans Peters, “Die freie Entfaltung der Persönlichkeit als Verfassungsziel”, in Dimitri S. Constantopoulos/Hans Wehberg (Orgs.), *Gegenwartsprobleme des internationalen Rechtes und der Rechtsphilosophie: Festschrift für Rudolf Laun*, Hamburg: Girardet, 1953, p. 673; do mesmo autor, *Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in den höchstgerichtlichen Rechtsprechung*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1963. Para uma crítica a essa concepção, cf. Hans-Ulrich Evers, “Zur Auslegung von Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, insbesondere zur Persönlichkeitskerntheorie”, *AöR* 90 (1965), pp. 94-95, o qual suscita a precisa objeção de que a teoria de Peters procura positivar uma determinada antropologia filosófica – que, do ponto de vista da Constituição, não pode ser aceita – às custas de outras concepções de ser humano compatíveis com a Constituição. Em sentido semelhante, cf. Hans C. Nipperdey, “Freie Entfaltung der Persönlichkeit”, in Gerhard Leibholz et al. (Orgs.), *Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung: Festschrift für Willi Geiger*, Tübingen: Mohr, 1974, pp. 771 e ss.

Outras teorias, como a de Hesse, não são afetadas por essa objeção. Hesse vê no art. 2º, § 1º, “a garantia da esfera de vida mais estritamente pessoal, ainda que não limitada ao desenvolvimento puramente intelectual e moral” (Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 428). Contra essa variante filosoficamente neutra de uma teoria restrita é possível, na esteira de Starck, suscitar a objeção de que na definição dessa “esfera de vida, [ela escancararia] a porta para restrições incontroláveis

Tribunal Constitucional Federal – que, desde as suas primeiras decisões, nunca colocou em dúvida o caráter garantidor de direitos subjetivos do art. 2º, § 1º⁷ –, com sua interpretação do livre desenvolvimento da personalidade como uma “liberdade de ação humana no sentido mais amplo”,⁸ enfrentou o problema e se decidiu por uma teoria extremamente ampla e ao mesmo tempo subjetiva: por um direito geral de liberdade.⁹

A tese segundo a qual o art. 2º, § 1º, contém “um direito fundamental autônomo, que garante a liberdade geral de ação humana”,¹⁰ tem enormes conseqüências. A liberdade geral de ação é uma liberdade de se fazer ou deixar de fazer o que se quer. Pressupor que essa liberdade é garantida pelo art. 2º, § 1º, significa duas coisas. De um lado, a cada um é *prima facie* – ou seja, caso nenhuma restrição ocorra – *permitido* fazer ou deixar de fazer o que quiser (norma permissiva). De outro, cada um tem *prima facie* – ou seja, caso nenhuma restrição ocorra – o *direito*, em face do Estado, a que este não embarace sua ação ou sua abstenção, ou seja, a que o Estado nelas não intervenha (norma de direitos). Dessa forma, o suporte fático do art. 2º, § 1º, é bastante ampliado. Ele inclui todas as ações dos titulares de direitos fundamentais (norma permissiva) e todas as intervenções do Estado nas ações desses titulares (norma de direitos).

Por mais ampla que seja a concepção do direito geral de liberdade definida a partir dessas normas permissivas e de direitos, ela ainda não é a concepção mais ampla possível. Tanto a norma permissiva quanto a norma de direitos dizem respeito apenas a *ações* do titular de direitos fundamentais. Mas, segundo o Tribunal Constitucional Federal, o direito geral de liberdade pode, para além da proteção de ações,

à liberdade”, porque desapareceria sua justificação como restrição (Christian Starck, “Das ‘Sittengesetz’ als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit”, p. 261).

6. Para uma exposição e a crítica das diferentes tentativas de solução, cf. Jürgen Müller, *Auswirkungen der unterschiedlichen Auffassungen zum Rechtscharakter des Art. 2 Abs. 1 GG und dessen Schranken*, Hamburg: Hansischer Gildenverlag, 1972.

7. BVerfGE 1, 7 (8); 1, 246 (273).

8. BVerfGE 6, 32 (36).

9. Quando o Tribunal Constitucional Federal às vezes fala de um “enunciado geral de liberdade” (BVerfGE 13, 21 (26)) ele se refere a uma norma que garante o direito geral de liberdade.

10. BVerfGE 6, 32 (36).

ser estendido à proteção de situações¹¹ e posições jurídicas¹² do titular de direitos fundamentais.¹³ Portanto, esse direito não protege apenas o seu “fazer”, mas também o seu “ser” fático e jurídico. Somente após essa ampliação é que o direito geral de liberdade se torna um direito exaustivo à liberdade geral contra intervenções.

É possível fundamentar a inclusão da proteção de situações e posições jurídicas por meio da constatação de que intervenções em situações e posições jurídicas de um titular de direitos fundamentais sempre afetam indiretamente sua liberdade de ação. Nesse sentido, a interferência na situação de livre comunicação, por meio de gravações secretas,¹⁴ e a eliminação da posição jurídica de um membro de um conselho de empregados¹⁵ têm efeitos nas possibilidades de ação dos titulares de direitos fundamentais envolvidos. Por esse ponto de vista, o direito geral de liberdade tem o caráter de um direito protetor da liberdade geral de ação tanto direta quanto indiretamente (por meio da proteção de situações e posições jurídicas). Se se restringisse o direito a uma liberdade geral de ação apenas à proteção direta de ações, ele representaria, então, apenas uma parte do direito geral de liberdade. Aqui, é importante apenas não perder de vista essas distinções.

Um suporte fático tão amplo como o do direito geral de liberdade exige uma equivalente amplitude na concepção da cláusula de restrição.¹⁶ Nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal foi simplesmente coerente ao adotar a cláusula restritiva mais ampla possível sob a vigência da atual Constituição, com sua fórmula “toda e qualquer norma jurídica compatível formal e materialmente com a Constituição”.¹⁷

11. Cf. *BVerfGE* 34, 238 (246): liberdade de comunicação. À proteção de situações dizem respeito sobretudo as diferentes concepções do direito geral da personalidade. Cf. *BVerfGE* 54, 148 (153-154).

12. Cf. *BVerfGE* 51, 77 (89): posição jurídica de um membro do conselho de empregados.

13. O trinômio ações, situações e posições jurídicas pode ser resumido por meio da fórmula da desvantagem, elaborada pelo Tribunal Constitucional Federal. Cf. *BVerfGE* 9, 83 (88); 19, 206 (215); 29, 402 (408). Sobre a diferença entre direitos relacionados a ações, a situações e a posições, cf. Capítulo 4, II.1.1.1.

14. *BVerfGE* 34, 238 (246).

15. *BVerfGE* 51, 77 (89).

16. Cf. Capítulo 6, II.2.

17. *BVerfGE* 6, 32 (38).

A contraposição entre aquela concepção extremamente ampla do suporte fático e esta cláusula extremamente ampla tem enormes consequências jurídico-procedimentais: "Qualquer um pode argüir, por meio de uma reclamação constitucional, que uma lei que restrinja sua liberdade de ação não pertence ao ordenamento constitucional, porque ela (formal ou materialmente) contraria determinados dispositivos constitucionais ou princípios constitucionais gerais; nesse sentido, seu direito fundamental garantido pelo art. 2º, § 1º, teria sido violado".¹⁸

A concepção de um direito geral de liberdade acima esboçada foi e continua sendo objeto de diversas objeções. De um lado, essas objeções são dirigidas contra a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal; de outro, afirma-se que esse tribunal não segue essa concepção de forma consistente, visto que a substitui cada vez mais por uma interpretação mais substancial e menos formal.¹⁹ Aqui será demonstrado que a concepção de um direito geral de liberdade tem mais vantagens que desvantagens e também que as decisões do Tribunal Constitucional Federal que aparentemente não a seguem devem ser interpretadas com base nela.

II – UMA CONCEPÇÃO FORMAL-MATERIAL DO DIREITO GERAL DE LIBERDADE

Uma das principais objeções contra a idéia de um direito geral de liberdade é aquela que afirma que um tal direito seria vazio de conteúdo, sem substância,²⁰ e que não haveria, por isso, nenhum parâmetro para se decidir sobre a admissibilidade de restrições à liberdade.²¹ Seria um "direito de liberdade sem suporte fático de liberdade".²² Aquilo que o direito garantiria não decorreria de um "conteúdo de liberdade", mas tão-somente das "restrições [permitidas] às intervenções le-

18. BVerfGE 6, 32 (41).

19. Nesse sentido, cf. Rupert Scholz, "Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts", AöR 100 (1975), pp. 89 e ss.

20. Cf. Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", AöR 91 (1966), pp. 47 e 49.

21. Cf. Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, pp. 76, 120, 124 e 248.

22. Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", p. 48.

gais na liberdade".²³ Ao invés de liberdade de ação, seria possível falar apenas de uma liberdade contra intervenções.²⁴ Assim, o direito geral de liberdade transformar-se-ia em um direito fundamental à constitucionalidade da totalidade da ação estatal. O "princípio fundamental do Estado de Direito" seria alçado à condição de direito fundamental.²⁵ Isso teria enormes e indesejáveis consequências procedimentais e constitucionais, que Ehmke resume da seguinte forma: "Toda lei que restrinja a liberdade geral de ação – e qual não o faz? – pode ser impugnada por meio de uma reclamação constitucional, sob a alegação de que viola *algum* dispositivo *qualquer* da Constituição. Parece-me que o sentido do § 90 da Lei do Tribunal Constitucional Federal não é compatível com essa interpretação".²⁶

1. A objeção da falta de conteúdo

Para esse tipo de objeção a esfera jurídico-material está intimamente associada à esfera jurídico-procedimental. Começo pelo aspecto jurídico-material. Aqui, é necessário perguntar se a interpretação do art. 2º, § 1º, como um direito geral de liberdade provoca, de fato, um esvaziamento do conteúdo desse artigo. É conveniente distinguir a objeção do vazio de conteúdo em duas teses distintas: a tese da ausência de suporte fático e a tese da ausência de substância. A tese da ausência de suporte fático sustenta que a idéia de um direito geral de liberdade resultaria em uma norma de direito fundamental sem suporte fático. A tese da ausência de substância sustenta que a idéia de um direito geral de liberdade torna impossível a vinculação do legislador "à esfera da liberdade".²⁷

23. Idem, p. 49.

24. Idem.

25. Horst Ehmke, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation", *VVDStRL* 20 (1963), p. 84. Cf. a seguinte formulação do Tribunal Constitucional Federal: "Esse direito fundamental proíbe intervenções do poder estatal que não sejam compatíveis com o Estado de Direito" (*BVerfGE* 42, 20 (27)).

26. Horst Ehmke, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation", pp. 84-85.

27. Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, p. 248. Cf. também Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", p. 47; Helmut Schulz-Schaeffer, *Der Freiheitssatz des Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz*, Berlin: Duncker & Humblot, 1971, p. 28.

1.1 A tese da ausência de suporte fático

A tese de ausência de suporte fático destaca corretamente uma característica estrutural do direito geral de liberdade, mas essa característica não fundamenta qualquer objeção. Quem interpreta o art. 2º, § 1º, no sentido de um direito geral de liberdade pode a ele atribuir, dentre outras, as seguintes normas permissivas:

- (1) Toda ação (fazer ou não-fazer) é permitida, a não ser que seja proibida por meio de uma norma jurídica formal e materialmente compatível com a Constituição.

Essa norma pode ser reformulada da seguinte forma:

- (2) Se x é uma ação (um fazer ou um não-fazer) e não é proibida por meio de uma norma jurídica formal e materialmente compatível com a Constituição, *então*, a realização de x é permitida.

Em sua estrutura *externa* essa norma corresponde exatamente às demais normas constitucionais permissivas, cujo antecedente é dividido em suporte fático (T) e cláusula de restrição (S) e cujo consequente é a consequência jurídica do direito fundamental (R):

- (3) T e não- $S \rightarrow R$.²⁸

As diferenças dizem respeito à estrutura *interna*, sobretudo de T . No caso das normas constitucionais permissivas específicas, T refere-se a uma determinada ação característica, como, por exemplo, uma expressão do pensamento, uma ação artística ou a prática de uma atividade religiosa; no caso das normas constitucionais permissivas gerais, T diz respeito, ao contrário, exclusivamente à característica "ser uma ação". Seria possível afirmar que seria supérflua a inclusão, em uma norma permissiva, da característica "ser uma ação", pois o que mais poderia ser permitido se não uma ação? Tratar-se de uma ação é algo *pressuposto* pela norma permissiva, e, portanto, não necessitaria ser expresso como parte de seu conteúdo. Embora correto, isso não obriga a aceitar a tese da ausência de suporte fático. Mesmo os pressupostos evidentes de uma consequência jurídica podem ser expressos como elementos de seu suporte fático. Na maioria das vezes isso é supérfluo

28. Sobre isso, cf. Capítulo 3, II.3.3.

e, por isso, despido de qualquer finalidade. No caso do direito geral de liberdade isso tem um objetivo, e, portanto, não é supérfluo. Por meio da inclusão da característica "ser uma ação", o âmbito daquilo que é *prima facie* protegido é expresso de forma explícita e com toda a clareza desejável. E é exatamente essa a função de um elemento do suporte fático em uma norma de direito fundamental dividida entre suporte fático e cláusula de restrição. O que pode ser objeto de oposição é somente a amplitude do suporte fático. Mas isso não atinge seu conteúdo e sua adequação como meio de descrição daquilo que é *prima facie* protegido, ou seja, não atinge sua adequação como suporte fático. O mesmo vale para o suporte fático da norma de direitos que garante uma permissão.

1.2 A tese da ausência de substância

Pelo que se acaba de afirmar, a objeção que aponta para um esvaziamento do conteúdo não pode se basear na tese da ausência de suporte fático. Resta saber se essa objeção poderia ser sustentada pela tese da ausência de substância. O direito geral de liberdade não teria substância porque a liberdade geral de ação, ou seja, a liberdade de se fazer ou deixar de fazer o que quiser, não seria adequada como critério ou parâmetro para se decidir quais restrições podem ser impostas e quais não podem.²⁹ Isso teria como consequência o fato de que a liberdade geral de ação seria um direito definido apenas a partir de suas restrições. A correção dessa tese deve ser colocada em dúvida, e para tanto é necessário, em primeiro lugar, examinar duas decisões do Tribunal Constitucional Federal temporalmente distantes entre si: a decisão acerca da Lei sobre Coletas em Locais Públicos³⁰ e a decisão sobre a proibição de alimentar pombas nas ruas.³¹

Na decisão acerca da Lei sobre Coletas em Locais Públicos³² o que estava em questão era a admissibilidade de uma proibição geral

29. Cf. Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, pp. 120 e 248. Cf. também Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", p. 51.

30. BVerfGE 20, 150.

31. BVerfGE 54, 143.

32. Cf., a respeito, Hans H. Rupp, "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Sammlungs-gesetz – eine Wende in der Grundrechtsinterpretation des Art. 2 Abs. 1 GG?", *NJW* 19 (1966), pp. 2.037 e ss.

de coletas combinada com permissões individuais específicas. O tribunal parte da constatação de que a realização de coletas é uma ação abarcada pela liberdade geral de ação e que uma proibição geral e repressiva com a possibilidade de autorizações específicas restringe esse direito.³³ Segundo o tribunal, para ser admissível, a restrição teria que ser compatível com a máxima da proporcionalidade.³⁴ Nesse sentido, o tribunal exigia a satisfação do postulado sobre o sopesamento, já formulado na decisão sobre a central de caronas:³⁵ "Quanto mais a intervenção legal afetar expressões elementares da liberdade de ação humana, tanto mais cuidadosamente devem ser sopesadas as razões utilizadas como fundamentação contra a pretensão básica de liberdade dos cidadãos".³⁶ Esse postulado corresponde, com exceção do aspecto relativo ao cuidado, à lei de sopesamento formulada anteriormente,³⁷ segundo a qual o aumento no grau de afetação de um princípio exige um correspondente aumento no grau de importância na satisfação do princípio colidente.³⁸

A necessidade de sopesamentos não é expressa de forma tão explícita em todas as decisões que dizem respeito à restrição da liberdade geral de ação. Mas isso nada diz contra a validade da lei de sopesamento. Sua aplicação pelo tribunal é algo que freqüentemente só pode ser percebido por meio de algumas expressões utilizadas. Um exemplo disso é a decisão acerca da proibição de alimentar pombas nas ruas, na qual, de um lado, se faz menção a uma "intervenção muito limita-

33. *BVerfGE* 20, 150 (154).

34. *BVerfGE* 20, 150 (155).

35. *BVerfGE* 17, 306 (314).

36. *BVerfGE* 20, 150 (159).

37. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.3.

38. Com o aspecto relativo ao cuidado, o postulado sobre o sopesamento do Tribunal Constitucional Federal contém um aspecto subjetivo ou procedimental adicional, se comparado com a lei do sopesamento formulada objetivamente; mas não há dúvidas de que esse postulado inclui a lei do sopesamento. Um sopesamento que, diante de um alto grau de afetação e um baixo grau de importância do princípio colidente, conceda prioridade a esse princípio nunca poderia ser considerado como um sopesamento cuidadoso. Bernhard Schlink (*Abwägung im Verfassungsrecht*, p. 72) sustenta que com a mencionada fórmula do Tribunal Constitucional Federal coloca-se um "aspecto procedimental em primeiro plano". Essa é uma interpretação muito radical. O que ocorre é apenas a menção a um aspecto procedimental (o aspecto relativo ao cuidado), que é tão evidente que nem é mencionado na maioria dos casos de sopesamento.

da na liberdade de expressar o amor aos animais" e, de outro, a um "superior interesse da coletividade", que justificaria essa intervenção.³⁹

Ambas as decisões – e várias outras⁴⁰ – demonstram que o Tribunal Constitucional Federal, no exame de violações do direito geral de liberdade, aplica a máxima da proporcionalidade, cuja terceira máxima parcial, a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, é idêntica à lei do sopesamento.⁴¹ Mas, se um sopesamento que envolva o direito geral de liberdade é possível, então, esse direito não pode ser sem substância, já que algo que careça de substância não poderia ser sopesado. Nesse sentido, da constatação de que o Tribunal Constitucional Federal realiza sopesamentos envolvendo o direito geral de liberdade é possível depreender que esse direito não é um direito sem substância.

Um defensor da tese da ausência de substância sustentaria que esse argumento não é sólido, porque sua premissa seria falsa. O tribunal não realizaria sopesamentos envolvendo o direito geral de liberdade, mesmo que ele se expresse como se o fizesse. Os objetos do sopesamento, no lado da liberdade, seriam, na verdade, princípios concretos, introduzidos de forma sub-reptícia no procedimento. Isso seria demonstrável a partir do postulado sobre o sopesamento, mencionado acima na análise da decisão sobre a Lei de Coletas Públicas. Nessa decisão não se diz "quanto mais a intervenção legal afetar a liberdade de ação humana (...)", mas, sim, "quanto mais a intervenção legal afetar *expressões elementares* da liberdade de ação humana (...)".⁴² Isso significaria que não é a liberdade de ação pura e simples que é incluída no sopesamento, mas a liberdade *valorada* como elementar.

Essa objeção suscita a questão acerca da ponderabilidade da liberdade geral de ação. Essa questão está associada à questão acerca de sua adequação como objeto de um princípio. Que ao indivíduo deva ser garantido, diante das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, um máximo grau de liberdade para fazer ou deixar de fazer o que quiser parece ser, à primeira vista, uma exigência não problemática, pelo me-

39. BVerfGE 54, 143 (147).

40. Cf., por exemplo BVerfGE 10, 354 (364, 369); 13, 230 (235); 15, 235 (243); 17, 306 (314); 18, 315 (327); 19, 93 (96); 59, 275 (278).

41. Cf. Capítulo 3, I.8 e III.2.2.2.3.

42. Sem grifos no original.

nos do ponto de vista lógico.⁴³ Contudo, uma análise mais detida revela alguns problemas, cuja discussão pressupõe clareza acerca do conteúdo do princípio ao qual corresponde o direito geral de liberdade.

Acima,⁴⁴ na análise do conceito de liberdade, a liberdade de se fazer ou deixar de fazer tudo o que se quer, ou seja, a liberdade de escolher entre alternativas de ação, foi denominada "liberdade negativa em sentido amplo". Uma pessoa seria considerada como livre em sentido negativo na medida em que suas alternativas de ação não sejam bloqueadas por obstáculos a essas ações. Esses obstáculos foram objeto de algumas diferenciações. Se os obstáculos às ações são ações positivas de outrem, sobretudo do Estado, então, trata-se de liberdade negativa em sentido estrito ou da liberdade liberal. Estamos diante de uma liberdade negativa em sentido estrito, ou liberdade liberal, quando se proíbem ações obstaculizadoras positivas. O caso mais precisamente determinado de liberdade liberal é a liberdade jurídica. Uma liberdade jurídica existe quando é permitido tanto fazer algo quanto deixar de fazê-lo. Isso ocorre exatamente quando algo não é nem obrigatório, nem proibido.⁴⁵

A liberdade negativa em sentido amplo vai além da liberdade negativa em sentido estrito ou liberdade liberal. De um lado, ela inclui essa liberdade liberal e, de outro, abarca outras coisas, como a liberdade econômico-social, a qual não existe se o indivíduo estiver submetido a uma situação de privação econômica que o embarace em seu exercício de alternativas de ação.⁴⁶

O princípio cuja viabilidade é aqui analisada deve ter por objeto a liberdade negativa em sentido estrito, ou seja, a liberdade liberal. Ele tem como objetivo, entre outros, a maior medida possível de liberdade

43. Aqui interessa apenas esse ponto de vista. O princípio da liberdade geral de ação diz respeito à liberdade negativa em sentido estrito, liberal (cf. Capítulo 4, II.2.1). É evidente que contra o princípio da liberdade em sentido estrito, liberal, podem ser suscitadas não apenas objeções formais, mas também substanciais. Aquele que, por exemplo, entende que a liberdade faz as pessoas serem infelizes, e a ausência de liberdade felizes, pode atacar o princípio da liberdade negativa com o auxílio do argumento segundo o qual o que importa é a felicidade. No entanto, essa é uma objeção contra a existência desse princípio, não contra a adequação de liberdade geral de ação como objeto de um princípio.

44. Cf. Capítulo 4, II.2.

45. Cf. Capítulo 4, II.2.2.

46. Cf. Capítulo 4, II.2.1.

jurídica. Esse princípio deve ser denominado “princípio da liberdade negativa de ação”. Em razão do fato de o direito geral de liberdade estar relacionado não apenas a ações, mas também a situações e a posições, a esse princípio devem ser adicionados dois outros: um que exige a maior medida possível de não-afetação de situações e outro que exige a maior medida possível de não-eliminação de posições jurídicas do titular do direito fundamental. Esses três princípios podem ser agrupados em um princípio superior, o *princípio da liberdade negativa*.⁴⁷ No que se segue, será tratado apenas o mais simples dos subprincípios, o princípio da liberdade jurídica, que exige que as alternativas de ação sejam afetadas o mínimo possível por deveres e proibições.

Um ponto no qual o princípio da liberdade negativa em nada difere de outros princípios é facilmente encontrável: tudo aquilo que afeta negativamente a realização desse princípio pode ser objeto de um exame de adequação e de necessidade. Os problemas surgem, contudo, quando se trata do exame da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, do sopesamento. A lei do sopesamento exige, no caso de um aumento na intensidade da afetação da liberdade, que o peso das razões que fundamentam essa afetação também aumente. Mas o que se deve entender por intensidade na afetação da liberdade negativa? É possível falar, com base no conceito negativo de liberdade, em intensidades de afetação? Será que a proibição de se alimentar pombas na rua e a proibição de freqüentar uma missa não se igualam, do ponto de vista da liberdade negativa, ou seja, não são ambas uma afetação dessa liberdade? Como é possível decidir sobre graus de intensidade? Uma pessoa seria, por exemplo, mais intensamente afetada por uma proibição de alimentar pombas que por uma proibição de freqüentar uma missa porque, se não houvesse nenhuma das duas proibições, ela alimentaria pombas com mais freqüência do que iria a missas e, nesse sentido, *mais* ações seriam afetadas? Não seria, então, a instalação de

47. No que diz respeito ao seu conteúdo e à sua estrutura, o princípio da liberdade negativa apresenta uma diferença fundamental em relação ao “princípio constitucional da liberdade”, de Grabitz. Esse último abrange um feixe de liberdades (liberdades negativa, real, social, democrática e política – cf. Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, pp. 243 e ss.). Na medida em que o princípio de Grabitz inclui quase tudo aquilo que pode colidir em nome da liberdade, ele não expressa, em sentido estrito, um princípio, mas o ideal de estabelecer um equilíbrio racional e justo entre tudo aquilo que possa ser concebido sob o conceito de liberdade.

inúmeros semáforos uma restrição mais intensa e, por isso, carente de maior fundamentação que o fechamento de igrejas, que, em sua totalidade, afeta muito menos ações?⁴⁸ Mas se não é possível se orientar pelo número de ações, com base em quê isso deve ocorrer? Não seriam, então, necessários parâmetros de valoração que nada tenham a ver com o princípio da liberdade negativa? Em caso afirmativo, isso não significaria que são esses parâmetros que, na verdade, constituiriam o objeto do sopesamento? Nesse sentido, será que o princípio da liberdade negativa não seria supérfluo no sopesamento, por não ser sopesável?

Essas questões expõem claramente os argumentos que podem ser utilizados a favor da tese da ausência de substância. Contudo, uma análise mais detida demonstrará que esses argumentos não são procedentes. De um lado, porque é possível, em certa medida, definir a intensidade da afetação à realização do princípio da liberdade negativa sem recorrer a outros princípios substanciais. De outro, porque da simples impossibilidade de uma definição com base exclusivamente nesse princípio não decorre que o princípio da liberdade negativa não desempenhe nenhum papel. Ele pode desempenhá-lo em conexão com outros princípios.

É fácil encontrar exemplos de casos nos quais os graus de intensidade de afetação podem ser definidos sem o recurso a outros parâmetros. Nesse sentido, a intensidade da afetação aumenta com a proibição das seguintes ações: alimentar pombas na praça do mercado; alimentar pombas na área urbana; alimentar animais na área urbana; aproximar-se de animais. Cada intervenção subsequente inclui a antecedente e vai mais além. Com base nesse critério de extensão é possível afirmar que uma proibição repressiva afeta mais intensamente que uma proibição preventiva; que uma proibição de emigrar para qualquer país afeta mais que a proibição de emigrar para apenas um país; e que uma proibição de longa duração afeta mais que uma de curta duração.

É ainda possível objetar que esses tipos de juízos de intensidade comparativos não nos levam muito adiante. Com certeza há algo de verdadeiro nessa afirmação. A partir deles não é possível definir a intensidade da afetação "em si mesma". Mesmo assim, eles são um avan-

48. Cf. Charles Taylor, "What's wrong with negative liberty", in Alan Ryan, *The Idea of Freedom: Essays in Honour of Isaiah Berlin*, Oxford: Oxford University Press, 1979, p. 183.

ço, pois ao menos demonstram a existência de diferentes graus de afetação da liberdade negativa. Além disso, é possível afirmar que a proibição de uma modalidade de ação em todas as suas formas sempre constitui, *prima facie*, uma afetação realmente muito intensa. O Tribunal Constitucional Federal considerou, com razão, a proibição de alimentar pombas nas ruas e áreas públicas de Mönchengladbach “uma intervenção bastante limitada na liberdade de demonstrar o amor aos animais”.⁴⁹ Em contrapartida, uma proibição ampla de toda e qualquer forma de demonstrar o amor aos animais seria uma intervenção mais intensa na liberdade negativa.

2. A vinculação entre princípios formais e materiais

Com base no que foi até agora afirmado, não é ainda possível decidir se uma proibição de alimentar pombas é uma afetação mais intensa que a proibição de freqüentar missas. Para tanto são necessários critérios adicionais, de natureza material. Nesse exemplo é possível procurar construir um tal critério a partir da garantia jurídico-positiva da liberdade de crença. Para além desse critério, a fonte jurídico-positiva mais geral de critérios substanciais é a norma da dignidade humana. Exatamente nesse sentido, o Tribunal Constitucional Federal afirma que “na definição do conteúdo e da extensão do direito fundamental do art. 2º, § 1º, da Constituição alemã é necessário levar em consideração que, segundo a norma fundamental do art. 1º, § 1º, a dignidade da pessoa humana é inviolável e requer respeito e proteção em face de todos os poderes estatais”.⁵⁰

Neste ponto seria possível objetar que a concepção de um direito geral negativo de liberdade foi abandonada e substituída por uma concepção substancial de liberdade orientada pela dignidade humana, na qual algumas liberdades específicas, valoradas positivamente, passam a ocupar o lugar da liberdade geral de fazer ou deixar de fazer aquilo que se quer. Uma breve análise da conexão entre a liberdade negativa e a dignidade humana mostra que não é isso o que ocorre. Essa conexão pode ser descrita por meio das seguintes teses: a liberdade nega-

49. BVerfGE 54, 143 (147).

50. BVerfGE 34, 238 (245); 32 373 (379).

tiva é uma condição necessária, embora não suficiente, da dignidade humana; por isso, um recurso à dignidade humana nunca poderá levar a uma *substituição* do princípio "formal" da liberdade negativa pelos princípios materiais fomentados pela norma da dignidade humana. Algo que é necessário para a dignidade humana não se torna para ela desnecessário – e, por isso, substituível – simplesmente porque outras coisas são também necessárias para essa dignidade. Portanto, a referência à norma da dignidade humana não pode levar a uma substituição do princípio da liberdade negativa pelos princípios materiais decorrentes dessa dignidade, mas tão-somente a uma *complementação* daquele primeiro princípio por meio desses últimos. Essas teses serão explicitadas com mais detalhes e fundamentadas a seguir.

Acima foi demonstrado⁵¹ que ao art. 1º, § 1º, da Constituição alemã pode ser também atribuída pelo menos uma norma que tenha o caráter de princípio: o princípio da dignidade humana. Esse princípio é tão indeterminado quanto o conceito de dignidade humana. Para além das fórmulas genéricas, como aquela que afirma que o ser humano não pode ser transformado em mero objeto,⁵² o conceito de dignidade humana pode ser expresso por meio de um feixe de condições concretas, que devem estar (ou não podem estar) presentes para que a dignidade da pessoa humana seja garantida. Sobre algumas dessas condições é possível haver consenso. Assim, a dignidade humana não é garantida se o indivíduo é humilhado, estigmatizado, perseguido ou proscrito.⁵³ Acerca de outras condições é possível haver controvérsias, como, por exemplo, no caso de se saber se o desemprego de longa duração de alguém que tenha vontade de trabalhar ou se a falta de um determinado bem material violam a dignidade humana. É fato que diferentes pessoas expressariam o conceito de dignidade humana por meio de diferentes feixes de condições. Por outro lado, é possível constatar que tais feixes não são completamente diferenciáveis. Muitos divergem em alguns pontos e convergem em outros, e com frequência as diferenças dizem respeito apenas ao peso dado a algumas das condições dentro de um mesmo feixe. Além disso, com relação às fórmu-

51. Cf. Capítulo 3, I.7.2.

52. Cf. BVerfGE 27, 1 (6); 28, 389 (391); 45, 187 (228); 50, 125 (133); 50, 166 (175); 50, 205 (215).

53. Cf. BVerfGE 1, 97 (104).

las genéricas, como aquela sobre a transformação de pessoas em objeto, é possível alcançar um amplo consenso.⁵⁴ Isso justifica que se fale de um conceito unitário e de diferentes concepções de dignidade humana.⁵⁵ As diferentes concepções de dignidade humana são de difícil classificação; entre elas não existe um limite preciso, havendo algo próximo daquilo que Wittgenstein chamou de “semelhanças de família”: “uma complexa rede de semelhanças, que se sobrepõem e se entrecruzam mutuamente. Semelhanças em grande e em pequena escala”.⁵⁶

O Tribunal Constitucional Federal resume sua concepção por meio de sua fórmula acerca da natureza humana.⁵⁷ Segundo essa fórmula, a norma da dignidade humana está “baseada na compreensão do ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de se determinar e de se desenvolver em liberdade. A Constituição alemã não concebe essa liberdade como uma liberdade de um indivíduo isolado e autocrático, mas como um indivíduo relacionado a uma comunidade e a ela vinculado”.⁵⁸ Aqui interessa apenas o fato de que o conceito de liberdade desempenha um papel central nessa fórmula e sustentar que, se esse conceito não desempenhar nenhum papel, não se trata de uma concepção de dignidade.⁵⁹ Contudo, diante da plurivocidade do conceito de

54. Sobre as dificuldades de aplicação dessa fórmula em casos concretos, cf. *BVerfGE* 30, 1 (25-26).

55. Sobre a distinção entre conceito e concepção, cf. John Rawls, *A Theory of Justice*, p. 5; Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 134 e ss. Para uma apresentação de diferentes concepções de dignidade, cf. Bernhard Giese, *Das Würde-Konzept*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, pp. 3 e ss.

56. Ludwig Wittgenstein, *Philosophische Untersuchungen*, §§ 66 e 67.

57. Cf., por todos, Ralf Dreier, “Das Menschenbild im Recht”, in Wolfgang Böhme (Org.), *Was halten wir für Recht? (Herrenalber Texte)*, Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1981, pp. 87 e ss.; Willi Geiger, “Das Menschenbild des Grundgesetzes”, na mesma obra coletiva, pp. 9 e ss.

58. *BVerfGE* 45, 187 (227). Cf. também *BVerfGE* 4, 7 (15-16); 27, 1 (7); 30, 173 (193); 32, 98 (108); 33, 303 (334); 45, 187 (227); 50, 166 (175); 50, 290 (353).

59. Sobre a conexão entre dignidade e liberdade, cf. Günter Dürig, “Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde”, *AöR* 81 (1956), p. 125; Klaus Stern, “Menschenwürde als Wurzel der Menschen- und der Grundrechte”, in Norbert Achterberg et al. (Orgs.), *Recht und Staat im sozialen Wandel: Festschrift für Hans Ulrich Scupin*, Berlin: Duncker & Humblot, p. 632; Ernst Benda, “Die Menschenwürde”, in Ernst Benda/Werner Maihofer/Hans-Jochen Vogel (Orgs.), *Handbuch des Verfassungsrechts*, Berlin: de Gruyter, 1983, p. 112. Cf. também Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, p. 436: “Autonomia é, portanto, o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda natureza racional”.

liberdade, essa constatação não significa qualquer grande avanço. Para se alcançar alguma clareza, é necessário salientar que, nesse contexto, trata-se apenas da garantia da dignidade humana por meio do direito. Não se trata, portanto, de uma liberdade positiva interior, como aquela existente no cumprimento, por puro dever, da lei moral.⁶⁰ Só pode se tratar de uma liberdade exterior,⁶¹ que consiste na inexistência de coerção exterior sobre o indivíduo na sua escolha entre determinadas alternativas de decisão, pois, em um contexto *jurídico*, não seria possível falar em "independência da pessoa"⁶² e em "personalidade auto-responsável"⁶³ em qualquer outro sentido. Mas uma tal liberdade sempre inclui a liberdade jurídica negativa. É possível, então, afirmar que sem a liberdade jurídica negativa não há dignidade humana em um sentido juridicamente relevante.⁶⁴

O fato de a liberdade que o Tribunal Constitucional Federal associa ao conceito de dignidade humana não ser uma liberdade ilimitada, mas uma liberdade de um "indivíduo referido e vinculado a uma comunidade",⁶⁵ não fundamenta nenhuma objeção contra a conexão entre dignidade humana e liberdade negativa. A posição do tribunal é resumida nas seguintes palavras: "o indivíduo tem que se conformar com as restrições à sua liberdade de ação, impostas pelo legislador com o objetivo de manter e fomentar a convivência social dentro dos limites daquilo que é razoavelmente exigível diante das circunstâncias e desde que a independência da pessoa seja preservada".⁶⁶ Essa fórmula, na qual claramente se vislumbra a máxima da proporcionalidade, não apenas diz que a liberdade é restringível, mas também que ela é restringível somente diante da presença de razões suficientes. Esse é exatamente o conteúdo do princípio da liberdade negativa, pois, enquanto *princípio*, ele não outorga uma permissão definitiva para fazer ou deixar de fazer tudo o que se quer; ele tão-somente sustenta que

60. Cf. Immanuel Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, pp. 446 e ss.

61. Sobre a diferenciação entre liberdade interior e liberdade exterior, cf. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, pp. 214, 380, 396 e 406.

62. BVerfGE 4, 7 (16).

63. BVerfGE 45, 187 (228).

64. É necessário salientar que essa frase expressa apenas uma condição necessária, mas não uma condição suficiente.

65. BVerfGE 45, 187 (227).

66. BVerfGE 4, 7 (16).

todos podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem, desde que não existam razões suficientes (direitos de terceiros, interesses coletivos) que fundamentem uma restrição na liberdade negativa. Nesse sentido, o princípio da liberdade negativa permite considerar em toda sua plenitude a vinculação do indivíduo à comunidade.

Ainda permanece, no entanto, a peculiaridade de o princípio da liberdade negativa exigir uma razão suficiente para qualquer restrição à liberdade, por menor que seja; a partir disso, alguém poderia alegar que ele nada tem a ver com a dignidade humana. Para perceber que isso não é assim, é necessário refletir sobre o que ocorreria se não fosse exigido nenhum motivo suficiente para as restrições insignificantes à liberdade. Significaria que, nesses casos, seriam possíveis restrições arbitrárias à liberdade. Nas pequenas coisas o indivíduo poderia ser submetido a toda forma de chicanas sem fundamentos. Mas ter sua liberdade arbitrariamente restringida é algo incompatível com a dignidade humana mesmo quando se trata de pequenas coisas, independentemente da inexistência de consenso sobre a forma como se define "pequeno" ou "insignificante".⁶⁷ Diante disso, o princípio da liberdade negativa pode basear-se, em toda sua amplitude, no princípio da dignidade humana.

O princípio da liberdade negativa expressa apenas uma das condições para a garantia da dignidade humana. Do princípio da dignidade humana decorrem, além do princípio formal da liberdade negativa,

67. Bons exemplos de "casos pequenos" são casos que dizem respeito à alimentação de pássaros. Horst Ehmke e Walter Schmidt consideraram um direito fundamental a alimentar pardais uma consequência absurda e ridícula do direito geral de liberdade (cf. Horst Ehmke, *Wirtschaft und Verfassung*, p. 58; Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", p. 81). Parece quase uma ironia da história da interpretação constitucional que, quase vinte anos depois, o Tribunal Constitucional Federal tenha considerado alimentar pombas como *prima facie* protegido pelos direitos fundamentais (BVerfGE 54, 143). O Tribunal Constitucional Federal tem razão. Claro que não é apropriado considerar a alimentação de pombas como algo especialmente digno de proteção. Mas não é justificado considerá-la como não merecedora de proteção alguma. Pode haver pessoas para as quais uma tal atividade seja mais importante que ações religiosas. É claro que da importância subjetiva não decorre uma importância a partir da perspectiva da Constituição, mas a importância subjetiva tem um significado constitucional, na medida em que o respeito que a Constituição exige pelas decisões e formas de vida individuais requer, no mínimo, que nelas não se intervenha sem razões suficientes.

outros princípios materiais, que se referem às condições substanciais de cuja satisfação depende a garantia da dignidade humana. Dentre esses princípios materiais podem ser mencionados, entre outros, aqueles que têm como objetivo a proteção dos aspectos mais íntimos dos seres humanos e aqueles que conferem ao indivíduo um direito *prima facie* à sua auto-representação em face dos outros indivíduos. Os aspectos substanciais expressos por princípios materiais desse tipo coexistem *junto* com o aspecto formal da liberdade negativa e não o suplantam, porque a liberdade negativa, enquanto tal, é uma razão independente para a proteção de direitos fundamentais. Ela é uma razão independente para a proteção de direitos fundamentais porque é um *valor em si mesma*. Utilizando as palavras de Isaiah Berlin: "ser livre para escolher, e não ter a escolha feita por outrem, é um ingrediente inalienável daquilo que faz o ser humano humano".⁶⁸ Quando duas situações são iguais em todos os aspectos, menos em um, que consiste na existência de liberdade negativa na primeira situação e sua ausência na segunda, então, a primeira situação é melhor que a segunda.

O princípio da dignidade humana, portanto, pode tanto sustentar quanto complementar o princípio da liberdade negativa. Isso é possível porque é necessário refinar o princípio da dignidade humana por meio de um feixe de subprincípios, que inclui, além do princípio formal da liberdade negativa, diversos princípios materiais, que podem participar do sopesamento ao lado da liberdade negativa e determinar seu peso. Sempre que, no que se segue, se falar, de forma simplificada, que o princípio da dignidade humana participa de um sopesamento ao lado do princípio da liberdade negativa, isso deve ser compreendido no sentido que se acaba de mencionar.

A concepção do direito geral de liberdade que aqui se definiu pode ser considerada como uma *concepção formal-material*. Ela é formal na medida em que pressupõe a liberdade negativa e a encara como um valor em si mesmo. E ela é material na medida em que determina, nos casos de colisão, o peso relativo do princípio da liberdade negativa no caso concreto, levando-se em conta também outros princípios que, em face da liberdade negativa, têm um caráter material.

68. Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, 1969, p. LX.

III – ESFERAS DE PROTEÇÃO E DIREITOS DE LIBERDADE IMPLÍCITOS

A concepção formal-material pode abdicar de contrapor um “conceito de liberdade (liberdade geral de ação) formal (vazio de conteúdo)” a um “conceito de liberdade (esfera nuclear inviolável) material (substancial ou valorativamente fechada)”, nos termos de uma “interpretação cindida do art. 2º, § 1º, da Constituição alemã”.⁶⁹ Na verdade, ela permite reunir as facetas à primeira vista divergentes da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal⁷⁰ em um todo consistente e coerente. Para que isso seja possível, ela deve ser apta a controlar duas coisas: a teoria das esferas, incluindo a teoria das liberdades implícitas, a ela vinculada; e as consequências advindas da aceitação de um direito geral à liberdade de ação e à liberdade contra intervenções. A seguir será analisado o primeiro complexo de problemas. O segundo será tratado logo depois, no âmbito da discussão sobre as objeções ainda não refutadas contra o direito geral de liberdade.

1. A teoria das esferas

A teoria das esferas pode ser encontrada já na decisão do caso *Elfes*, na qual o tribunal faz menção a um “último e inviolável âmbito de liberdade humana”.⁷¹ A garantia da liberdade geral de ação é apresentada como uma extensão da proteção para além desse âmbito: “Com ‘livre desenvolvimento da personalidade’, a Constituição não pode querer se referir *tão-somente* ao desenvolvimento no interior daquele âmbito nuclear da personalidade”.⁷² A distinção entre esferas de proteção com diferentes intensidades, perceptível nessas manifestações do tribunal, foi por ele desenvolvida em diversas outras decisões.⁷³ É possível distinguir três esferas, com intensidades de proteção

69. Rupert Scholz, “Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit”, p. 91.

70. É sintomático que no repositório oficial de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal a decisão sobre a alimentação de pombas na rua seja seguida pela decisão do caso *Eppler* (cf. *BVerfGE* 54, 143; 54, 148).

71. *BVerfGE* 6, 32 (41).

72. *BVerfGE* 6, 32 (36) – sem grifos no original.

73. Cf., sobre isso, Dietwalt Rohlf, *Der grundrechtliche Schutz der Privatsphäre*, Berlin: Duncker & Humblot, 1980, pp. 70 e ss.

decrecente: a *esfera mais interior* (“último e inviolável âmbito de liberdade humana”,⁷⁴ “âmbito mais interno (íntimo)”,⁷⁵ “esfera íntima inviolável”,⁷⁶ “esfera nuclear da configuração da vida privada, protegida de forma absoluta”⁷⁷), a *esfera privada ampliada*, que inclui o âmbito privado que não pertence à esfera mais interior,⁷⁸ e a *esfera social*, que inclui tudo aquilo que não for atribuído nem ao menos à esfera privada ampliada.⁷⁹

A teoria das esferas pode, nos limites de sua correção e utilidade, ser concebida como o resultado de sopesamentos do princípio da liberdade negativa *em conjunto* com outros princípios contra princípios colidentes. Seria possível afirmar que isso não se aplicaria à *esfera mais interior*, porque sua extensão nada teria a ver com sopesamentos. Mas isso não é correto. Se se define a esfera mais interior como a esfera na qual o indivíduo *não* “influencia terceiros por meio de sua essência ou comportamento e, portanto, [não] afeta a esfera pessoal de outras pessoas ou interesses da vida social”,⁸⁰ então, a esfera mais interior é, *per definitionem*, a esfera na qual os princípios favoráveis à proteção são sempre decisivos, pois princípios colidentes – que só poderiam se referir a direitos de terceiros ou a interesses coletivos – não podem ser relevantes, visto que, nessa esfera, não são afetados direitos de terceiros ou interesses da vida social. É a uma concepção de esfera mais interior como essa que se refere o Tribunal Constitucional Federal quando afirma que “não há lugar para um sopesamento nos termos da máxima da proporcionalidade”,⁸¹ pois não há nada contra o qual os princípios que militam a favor da proteção possam ser sopesados. Contudo, esse caso também pode ser concebido como um caso – o caso mais extremo – de aplicação da lei do sopesamento. Mas é possível questionar se uma tal concepção de esfera mais interior

74. BVerfGE 6, 32 (41). De forma semelhante: BVerfGE 27, 1 (6); 27, 344 (350); 32, 373 (379); 34, 238 (245).

75. BVerfGE 27, 1 (8).

76. BVerfGE 32, 373 (379).

77. BVerfGE 34, 238 (245).

78. Cf. BVerfGE 27, 1 (7-8); 27, 344 (351); 32, 373 (379); 33, 367 (376); 34, 238 (246); 35, 202 (220).

79. Sobre essa distinção tripla, cf. Rupert Scholz, “Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit”, pp. 92, 266 e ss., 273 e ss.

80. BVerfGE 35, 202 (220).

81. BVerfGE 34, 238 (245).

teria alguma importância prática. Pode ser questionado se seria possível haver essência ou comportamento de uma pessoa que em nenhum aspecto afete a esfera de terceiros ou interesses da vida social. Independentemente da resposta a essa pergunta, é possível afirmar que, se esses casos existem, eles são casos sobre os quais nenhuma polêmica mais séria pode surgir, já que quem poderia querer restringir algo que em nenhum aspecto afeta a si mesmo, a terceiros ou a interesses da vida social? Se se quer que a menção a um "âmbito nuclear absolutamente protegido da configuração da vida privada" tenha algum sentido prático, então, ela deve estar baseada em uma concepção mais forte de esfera mais interior. Uma concepção mais forte surge quando determinadas situações e comportamentos do indivíduo são considerados como protegidos em todos os casos, ou seja, mesmo naqueles casos em que seria possível, como argumento contrário à proteção, recorrer a direitos de terceiros ou a interesses da vida social. Uma tal concepção, no entanto, é o resultado de um sopesamento. Um sopesamento que, sob certas circunstâncias (determinados comportamentos e situações do indivíduo), leva a uma precedência absoluta do princípio da liberdade negativa em conjunto com o princípio da dignidade humana contra todos os princípios colidentes imagináveis. Já se salientou acima que uma precedência absoluta, mesmo que relativa a determinadas circunstâncias, é algo não desprovido de problemas, visto que pressupõe que não é possível que surjam novas circunstâncias que, do ponto de vista do direito constitucional, poderiam atribuir aos princípios contrapostos um peso maior.⁸² Mas isso nada muda no fato de que existem circunstâncias sob as quais o resultado do sopesamento é tão certo que se pode falar de *regras* extremamente seguras que protegem uma esfera mais interior.⁸³ O Tribunal Constitucional Federal pode aplicar essas regras sem realizar um sopesamento. Mas isso não muda o fato de que essas regras são o resultado de um sopesamento e que, em todos os casos duvidosos, é necessário recorrer ao sopesamento, seja no âmbito de um refinamento, seja no âmbito de uma redução ou de uma extensão.⁸⁴

82. Cf. Capítulo 6, I.4.

83. Essas regras decorrem do estabelecimento de relações de precedências, com base na lei do sopesamento anteriormente apresentada. Cf. Capítulo 3, I.3.2.1.

84. Sobre os conceitos de refinamento, de redução e de extensão, cf. Aulis Aarnio/Robert Alexy/Aleksander Peczenik, "Grundlagen der juristischen Argumenta-

No caso da *esfera privada ampliada*, o Tribunal Constitucional Federal salienta a necessidade de um “respeito estrito ao dever de proporcionalidade”.⁸⁵ Alguém poderia imaginar que, com isso, o tribunal quer dizer que a máxima da proporcionalidade vale em menor grau na esfera social que na esfera privada. Não é esse o caso. A validade jurídica é uma questão de tudo-ou-nada, e o fato de o tribunal realizar testes de proporcionalidade na esfera social demonstra que ele entende que a máxima da proporcionalidade vale também para esse âmbito. Por isso, o postulado da aplicação estrita da proporcionalidade só pode significar que restrições no âmbito da esfera privada exigem razões especialmente relevantes. Isso é em parte correto, em parte incorreto, o que explicita as debilidades da teoria das esferas. Não há dúvidas de que uma restrição muito intensa na esfera social requer razões de maior peso que uma restrição irrelevante na esfera privada ampliada. Além disso, frequentemente é difícil decidir se um caso pertence à esfera privada ampliada ou à esfera social. Entre o mais privado e aquilo que não tem nada de privado existe uma transição gradual. Por isso, não é possível criar duas classes, gozando uma de maior proteção de direitos fundamentais que a outra; o que se deve é, na verdade, fazer diferenciações tanto com base na intensidade da afetação quanto com base no grau de privacidade. O que a diferenciação entre esferas privada e social corretamente põe em destaque é o fato de que a proteção a direitos fundamentais deve ser tão maior quanto maior for o peso dos princípios protetores da privacidade que estejam aliados ao princípio da liberdade geral de ação.

A teoria das esferas demonstra ser, portanto, uma descrição extremamente rudimentar⁸⁶ dos diferentes graus de intensidade aos quais, sob diferentes condições, a proteção de direitos fundamentais está sub-

tion”, pp. 30 e ss.; Robert Alexy, “Zum Begriff des Rechtsprinzips”, *Rechtstheorie*, Beiheft 1 (1979), pp. 68-69.

85. *BVerfGE* 32, 373 (379); 33, 367 (377); 34, 205 (209); 34, 238 (246); 35, 35 (39); 35, 202 (232).

86. Até em virtude do caráter rudimentar da divisão, deve-se concordar com a crítica de Detlef Merten, “Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit”, *JuS* 16 (1976), p. 349, segundo a qual “uma divisão rígida em esferas (...) [parece] artificial e impraticável”. Também críticos em relação à teoria das esferas são Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 314 e ss.; e Eggert Schwan, “Datenschutz, Vorbehalt des Gesetzes und Freiheitsgrundrechte”, *VerwArch* 66 (1975), pp. 147 e ss.

metida. Na parte em que é correta essa teoria sustenta que a proteção da liberdade é tão mais intensa quanto mais peso tiver o princípio da liberdade negativa em conjunto com outros princípios, sobretudo o da dignidade humana. No âmbito da esfera mais interior as relações de peso são tão certas que podem ser expressas em regras relativamente genéricas. No mais, depende-se decisivamente de sopesamentos, em cuja face de liberdade se encontra o princípio da liberdade negativa ao lado de alguns princípios adicionais. Isso corresponde exatamente à concepção formal-material.

2. Direitos de liberdade implícitos

A teoria dos direitos de liberdade implícitos⁸⁷ baseia-se, de um lado, na teoria das esferas; mas, de outro lado, vai mais além. A discussão a seu respeito exige clareza acerca do conceito de direito de liberdade implícito. É recomendável sustentar essa clarificação em três diferenciações.

Na primeira, trata-se de se saber se o bem protegido do direito de liberdade implícito é uma *ação* ou um *estado* do titular de direitos fundamentais. Trata-se de uma ação, por exemplo, nos casos de emigração,⁸⁸ coleta pública⁸⁹ e alimentação de pombas.⁹⁰ Nos casos de ações é possível formular uma norma permissiva: *a* pode realizar coletas. Trata-se de um estado, por exemplo, no caso da inviolabilidade de um âmbito confidencial⁹¹ e no caso da existência de condições sob as quais o indivíduo "pode desenvolver e manter sua individualidade".⁹² Quando se trata de um estado, embora não seja possível formular uma norma permissiva, é possível formular uma proibição, dirigida aos destinatários do direito fundamental, que corresponde a direitos de igual conteúdo do titular do direito fundamental: *a* tem, em face de *b*, um direito a que *b* não intervenha no âmbito confidencial de *a*.⁹³

87. Sobre essa terminologia, cf. BVerfGE 54, 148 (153).

88. BVerfGE 6, 32.

89. BVerfGE 20, 150.

90. BVerfGE 54, 143.

91. BVerfGE 27, 1 (7-8).

92. BVerfGE 35, 202 (220).

93. De forma mais precisa, embora mais complicada: *a* tem, em face de *b*, um direito a que *b*, caso determinados fatos sejam conhecidos apenas por *a* e por pessoas

A segunda diferenciação é aquele entre direitos de liberdade implícitos *abstratos* e *concretos*. Um direito bastante abstrato é o “direito geral, constitucionalmente garantido, à personalidade”;⁹⁴ um direito mais concreto é o “direito de controlar as representações de si próprio”;⁹⁵ e um direito bastante concreto é o direito a que não ocorra a “repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um interesse atual pela informação (...) se com isso se coloca em risco a ressocialização do autor”.⁹⁶

Por fim, a terceira diferenciação diz respeito à distinção entre posições *prima facie* e posições *definitivas*. Uma posição *prima facie* é o direito a emigrar. A emigração é garantida pelo art. 2º, § 1º, da Constituição alemã, mas pode ser objeto de uma restrição.⁹⁷ Uma posição definitiva é a permissão de que proprietários de automóveis transportem pessoas que tenham entrado em contato em virtude de anúncio ou publicidade e de exigir, por isso, um pagamento que não supere os custos da viagem.⁹⁸

2.1 Direitos relacionados a ações

Com base nessas três diferenciações é possível elaborar um quadro exaustivo das posições que podem ser atribuídas⁹⁹ ao art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Para que seja possível caracterizar algumas delas como *direitos de liberdade implícitos*, é necessária uma série de

em que ele confia, não altere a situação em que *a* se encontra, fazendo com que *b* ou terceiros passem a ter conhecimento desses fatos, embora *a* assim não queira. Se *b* pretende tornar públicos os fatos obrigando *a* a contá-los, suscita-se, ao lado de um direito à não-afetação de uma situação, uma permissão de não-realização do ato de revelar aqueles fatos. Direitos à não-afetação de uma situação são frequentemente descritos com o auxílio do conceito de *tolerância*. Se *a* não tem um direito à não-afetação, ele tem que tolerar a afetação correspondente. Se *a* tem um direito à não-afetação, ele não tem que tolerar a afetação correspondente.

94. BVerfGE 54, 148 (153).

95. BVerfGE 35, 202 (220).

96. BVerfGE 35, 202 (237).

97. Cf. BVerfGE 6, 32 (42 e ss.).

98. BVerfGE 17, 306 (313 e ss.). A caracterização dessa posição como “definitiva” não significa que ela não possa ser alterada, por exemplo, por meio de uma restrição à luz de uma nova constelação de casos. Mas, então, surge mais uma vez uma posição definitiva.

99. Sobre o conceito de atribuição, cf. Capítulo 2, II.2.

definições que, em última análise, são decididas com base em considerações de utilidade.

O problema ligado a essas definições é particularmente visível no caso das posições *prima facie* relacionadas a ações. Se todas as ações são abarcadas pelo art. 2º, § 1º, então, todas as ações específicas, como, por exemplo, a emigração, a coleta pública ou a alimentação de pombas, também são por ele abarcadas. Quando o Tribunal Constitucional Federal afirma que a liberdade de emigrar é um "resultado" da liberdade geral de ação,¹⁰⁰ isso só pode significar que o conceito de ação inclui o conceito de emigração. Se se toma somente esse tipo de relação de inclusão como base das posições *prima facie* relacionadas a ações, disso decorrem conseqüências insustentáveis para o conceito de direitos de liberdade implícitos. Haveria tantos direitos implícitos quanto o número de possíveis descrições de ações. Mas há um número infinito de descrições de ações. Com isso, o conceito de direito implícito de liberdade nos casos de posições *prima facie* relacionadas a ações perderia todo seu sentido. Isso pode ser evitado por meio de duas limitações. A primeira sustenta que direitos implícitos de liberdade podem ser aceitos apenas nos casos de descrições relativamente genéricas¹⁰¹ de ações. A partir dessa limitação, é possível fazer menção a um direito implícito de liberdade para emigrar, mas não a um direito implícito concreto de liberdade para emigrar trajando um paletó extravagante. Se se proibir a emigração de uma pessoa que esteja vestindo um paletó extravagante, ela não poderá recorrer a um direito implícito concreto de liberdade para emigrar trajando um paletó extravagante, mas tão-somente a dois direitos implícitos de liberdade relativamente abstratos: o direito a emigrar e o direito de se vestir como quiser. A segunda limitação sustenta que ações que sejam proibidas por normas sobre cuja constitucionalidade não pairam dúvidas devem ser excluídas do círculo dos direitos implícitos de liberdade *prima facie*. A proteção *prima facie* de que essas ações gozam, nos termos da teoria ampla do suporte fático, não é garantida, portanto, por um direito implícito, mas por meio do direito geral de liberdade. Dessa forma, é possível estabelecer um conceito restrito e útil de direito de liberdade *prima facie* implícito e relacionado a ações. Os direitos abar-

100. BVerfGE 6, 32 (42).

101. Sobre o conceito de generalidade, cf. Capítulo 3, nota 11.

cados por esse conceito equivalem, em sua estrutura, aos direitos "explícitos", isto é, aos direitos de liberdade escritos.

2.2 *Direitos relacionados a situações*

Mais complicados que os direitos relacionados a ações são os direitos relacionados a situações. Um exemplo extremamente abstrato de um tal direito é o "direito geral, constitucionalmente garantido, à personalidade", cuja tarefa é "garantir a esfera da vida pessoal estrita e a manutenção de suas condições básicas".¹⁰² O direito geral à personalidade, reconhecido pelo Tribunal Constitucional Federal, tem como característica distintiva basear-se tanto no art. 1º, § 1º, quando no art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Esse direito seria "garantido pelo art. 2º, § 1º, em conjunto com o art. 1º, § 1º". Contudo, e a despeito dessa conexão, o direito que surge dessa maneira permanece atribuível ao art. 2º, § 1º, o qual protege, assim, ao lado do "elemento 'ativo'" (relativo a uma ação: fazer), também o que poderia ser chamado de um elemento passivo do desenvolvimento da personalidade, na medida em que garante um "direito ao respeito do âmbito protegido" (relativo a um estado: ser).¹⁰³ Isso corresponde exatamente à teoria formal-material, segundo a qual o princípio da liberdade negativa, enquanto princípio relacionado também a um estado, interage com outros princípios.

A estreita conexão entre a teoria das esferas e o direito geral à personalidade é patente. O direito geral à personalidade pode ser visto como uma parte da teoria das esferas, elevada ao nível dos direitos. Ele é definido com precisão por meio da atribuição de um conjunto de direitos concretos. Os objetos desses direitos concretos podem ser descritos como os "bens protegidos pelo direito geral à personalidade", que o Tribunal Constitucional Federal, resumindo sua jurisprudência, definiu na decisão do caso Eppler.¹⁰⁴ Segundo o tribunal, dentre os direitos atribuídos ao direito geral abstrato à personalidade estão: o direito à esfera privada, confidencial e íntima;¹⁰⁵ o direito à honra pes-

102. BVerfGE 54, 148 (153).

103. Idem.

104. BVerfGE 54, 148 (154).

105. Com referência a: BVerfGE 27, 1 (6); 27, 344 (350-351); 32, 372 (379); 34, 238 (245-246); 47, 46 (73); 49, 286 (298).

soal e o direito de controle sobre a representação de si próprio;¹⁰⁶ o direito à própria imagem e à palavra falada;¹⁰⁷ “sob certas condições, o direito a ser protegido contra a imputação de manifestações do pensamento não realizadas”;¹⁰⁸ e o direito a não ser afetado na “pretensão social autonomamente determinada”.¹⁰⁹ Mais recentemente o Tribunal Constitucional Federal adicionou a essa lista um direito à autodeterminação informacional.¹¹⁰ A particularização do direito geral à personalidade por meio desses direitos mais concretos é um procedimento muito usual na particularização das cláusulas gerais.¹¹¹

A decisão no caso das gravações secretas,¹¹² que diz respeito a um direito garantido constitucionalmente à própria palavra, demonstra bem que – e de que forma – esses direitos concretos à personalidade dependem de sopesamentos, exatamente no sentido da concepção formal-material. Gravações secretas, que afetam “o âmbito absolutamente inviolável da configuração da vida privada”, devem ser proibidas em qualquer caso. No entanto, o tribunal imediatamente acrescenta que saber o que faz parte desse âmbito absolutamente inviolável é algo “de muito difícil definição em abstrato”, que “somente pode ser respondido caso a caso, levando-se em consideração suas particularidades”.¹¹³ Isso sugere que o “o âmbito absolutamente inviolável” deve ser encarado como um conjunto de posições concretas protegidas definitivamente, que são o resultado relativamente certo de sopesamentos. Também em outros âmbitos da personalidade a referência ao sopesamento é colocada em destaque. O tribunal fala de “tensões” entre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e as exigências de uma administração eficaz da justiça. Para a solução dessas tensões é necessário “definir (...) a qual desses dois importantes princípios de direito constitucional se atribui um maior peso no caso concreto”.¹¹⁴ O direito à própria palavra não poderia ser tratado de forma mais cla-

106. Com referência a: *BVerfGE* 35, 202 (220).

107. Com referência a: *BVerfGE* 34, 238 (246).

108. Com referência a: *BVerfGE* 34, 269 (282-283).

109. *BVerfGE* 54, 148 (155-156); 54, 208 (217).

110. *BVerfGE* 65, 1 (41 e ss.).

111. Cf. Franz Wieacker, *Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB*, Tübingen: Mohr, 1956.

112. *BVerfGE* 34, 238.

113. *BVerfGE* 34, 238 (248).

114. *BVerfGE* 34, 238 (249).

ra como um direito *prima facie* no sentido da teoria dos princípios. Assim, o suporte fático da norma que garante esse direito corresponde, em sua estrutura, ao suporte fático das normas que garantem direitos fundamentais explícitos, ou seja, direitos fundamentais escritos.

Os direitos de liberdade implícitos, portanto, não são qualitativamente distintos do direito geral de liberdade, que vale tanto para a liberdade de ação quanto para a não-afetação de situações e posições do titular do direito fundamental; pelo contrário, eles são formas da mesma coisa, mas qualificados em relação a dois aspectos. Em relação ao direito geral de liberdade, os direitos implícitos são qualificados, em primeiro lugar, por possuírem uma descrição mais detalhada do suporte fático; nesse sentido, eles são mais específicos que o direito geral de liberdade. Em segundo lugar, eles são qualificados por passarem por uma configuração e uma concretização jurisprudenciais. Eles se baseiam em normas de direito judicial, produzidas no âmbito da norma jurídica geral da liberdade e com base nela. Isso confere a eles uma certa independência e os coloca próximos aos direitos específicos e explícitos de liberdade. Nesse sentido, entre o direito geral de liberdade e os direitos de liberdade implícitos há a mesma relação que existe entre o direito geral de liberdade e os direitos de liberdade explícitos. Os direitos de liberdade explícitos são reações do constituinte a determinadas ameaças à liberdade, sofridas de forma especialmente premente. Os direitos de liberdade implícitos podem ser considerados, de forma análoga, como reações da jurisprudência constitucional a novas ameaças à liberdade, avaliadas como sendo também especialmente prementes. O art. 2º, § 1º, da Constituição alemã é, nesse sentido, uma fonte escrita de direitos de liberdade não-escritos. Mas isso não necessariamente significa, como sustentou Walter Schmidt, que o art. 2º, § 1º, se torna um "direito fundamental somente quando vinculado ao novo âmbito de proteção da liberdade".¹¹⁵ A concepção formal-material mostra que um direito geral de liberdade é construtivamente possível e aplicável na prática. Direitos implícitos de liberdade, enquanto direitos específicos, não são aptos a propiciar uma proteção exaustiva para a liberdade. Mas, como essa proteção é obrigatória, é obrigatório proteger a liberdade negativa não apenas por meio de direitos de liberdade implícitos. Nas áreas que eles não alcançam é ne-

115. Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", p. 83.

cessário aplicar diretamente o direito geral de liberdade, que conserva, além disso, uma importância como razão jurídico-positiva para os direitos implícitos.

IV – PROBLEMAS DO DIREITO GERAL DE LIBERDADE

Segundo a concepção formal-material, o direito geral de liberdade abarca um espectro que se caracteriza pela variação decrescente no peso do princípio da dignidade humana. Um dos extremos do espectro é formado pelos casos nos quais se pode falar de um âmbito último e inviolável, porque ao princípio da dignidade é atribuído o maior peso possível. Na medida em que o peso desse princípio decresce, surgem os casos que são criticados como casos de liberdade de ação e de liberdade contra intervenção “meramente formais”. Como a concepção formal-material, com a totalidade do espectro, inclui a liberdade geral de ação e contra intervenção também em seus aspectos mais formais, ela depende da aceitação de um tal direito. Essa aceitabilidade desse direito é posta em dúvida por diversas razões. A mais importante delas, a da ausência de substância, já foi refutada anteriormente. A seguir serão analisadas quatro outras objeções.

1. Direito geral de liberdade e garantias pontuais

A objeção histórica é relativamente fácil de ser refutada. Segundo ela, os direitos fundamentais surgiram “historicamente de situações específicas de demandas por segurança ou de ameaças prementes” e devem ser concebidos, por conseguinte, como “garantias específicas relacionadas a um âmbito de proteção bastante determinado”¹¹⁶ ou,

116. Ulrich Scheuner, “Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat”, *DÖV* 24 (1971), p. 509. Cf. também, do mesmo autor, “Pressefreiheit”, *VVDStRL* 22 (1965), p. 45; Horst Ehmke “Prinzipien der Verfassungsinterpretation”, p. 82; Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 428; Wolfgang Rüfner, “Grundrechtskonflikte”, in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, II, Tübingen: Mohr, 1976, p. 456; Friedrich Müller, *Die Positivität der Grundrechte*, pp. 41 e ss., 87 e ss.; Christian Graf von Pestalozza, “Kritische Bemerkungen zu Methoden und Prinzipien der Grundrechtsauslegung in der Bundesrepublik Deutschland”, *Der Staat* 2 (1963), p. 437; Walter Schmidt, “Die Freiheit vor dem Gesetz”, p. 84; Rupert Scholz, “Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit”, pp. 82-83.

como muitas vezes se diz, como “garantias pontuais”, o que seria inconciliável com a concepção de um direito geral de liberdade. Não há dúvidas de que existem inúmeros bons argumentos a favor da tese segundo a qual os diferentes direitos fundamentais surgiram como reações a ameaças concretas. Mas isso é apenas um lado da questão. Ao lado da linha de tradição “concreta” existe uma linha “abstrata”. São evidências dessa linha abstrata o art. 4º, 1, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: “A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem; assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não encontra outros limites além daqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos”; e a máxima de Kant: “Liberdade (independência de arbitrariedade coercitiva proveniente de outrem), na medida em possa coexistir com a liberdade de todos os outros com base em uma lei geral, é o único direito original conferido a todo ser humano em virtude de sua natureza humana”.¹¹⁷ Diante disso, a tese segundo a qual os direitos fundamentais, sob o aspecto histórico, devem ser concebidos como garantias pontuais deve ser encarada com certas restrições. Um segundo argumento histórico contra a objeção histórica é o argumento da *tabula rasa*, de Dürig, que chama a atenção para uma “experiência histórica de uma tabula rasa apocalíptica de direitos fundamentais, à qual a Constituição alemã responde historicamente”, e classifica as teorias da garantia pontual como “completamente a-históricas”.¹¹⁸ Esse argumento pode se apoiar na gênese histórica do art. 2º, § 1º, da Constituição alemã.¹¹⁹

Aos argumentos históricos contra a objeção histórica pode ser adicionada uma consideração de caráter sistemático. Mesmo que só

117. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, p. 237.

118. Günter Dürig, “Art. 3 Abs. 1”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 251, nota de rodapé 1.

119. Cf. *JöR NF* 1 (1951), pp. 54 e ss.; *BVerfGE* 6, 32 (38 e ss.); Dieter Suhr, *Entfaltung der Menschen durch die Menschen*, Berlin: Duncker & Humblot, 1976, p. 52. Suhr com razão faz referência ao fato de que, ao contrário da formulação do Tribunal Constitucional Federal, o teor original não era “todos podem fazer e deixar de fazer o que quiserem” (*BVerfGE* 6, 32 (36)). Mas as versões originais não eram assim tão diferentes disso. A diferença reside sobretudo na existência de uma cláusula de restrição nas versões originais. Cf., por exemplo, o art. 2º, § 2º, do Projeto Chiemsee: “Dentro dos limites do ordenamento jurídico e dos bons costumes, todos têm a liberdade de fazer tudo aquilo que não prejudique os outros” (*JöR NF* 1 (1951), p. 54).

existisse a linha de tradição concreta, e mesmo que os autores da Constituição não quisessem dar nenhuma nova resposta, que incluísse o direito geral de liberdade, mesmo assim não seria obrigatório continuar a interpretar o catálogo de direitos fundamentais sempre no sentido da linha de tradição concreta. Não é vedado, nem à Ciência do Direito, nem à jurisprudência, fundamentar as normas concretas historicamente desenvolvidas em normas mais gerais.¹²⁰ Pelo contrário, essa é uma tarefa essencial da Ciência do Direito, e para a jurisprudência esse procedimento é no mínimo útil. A questão, portanto, só pode dizer respeito a saber se o direito geral de liberdade pode ser fundamentado de forma razoável no âmbito dos direitos fundamentais. Em face da ambigüidade da tradição e da relativa clareza da gênese histórica da Constituição alemã, a objeção histórica não está em condições de colocar alguma pedra no caminho de uma tal fundamentação.

2. *Direito geral de liberdade e o sistema dos direitos fundamentais*

A segunda objeção pode ser chamada de *sistemática*. Ela é suscitada quando se associa o direito geral de liberdade à concepção de um "sistema axiomático fechado"¹²¹ que, por sua vez, é rejeitada. O principal objeto dessa crítica é o *sistema de valores e pretensões* de Dürig, no qual o direito geral de liberdade desempenha um papel central.¹²² Para a análise dessa objeção, é recomendável, portanto, uma breve olhada no sistema de Dürig.

O sistema de valores e pretensões de Dürig pode ser considerado como um modelo de direitos fundamentais em três níveis. No primeiro nível está a dignidade humana, como "princípio constitucional supremo".¹²³ No segundo nível encontram-se, de um lado, o direito geral

120. Cf. Hans-Ullrich Gallwass, *Faktische Beeinträchtigungen im Bereich der Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1970, p. 57.

121. Cf. Rupert Scholz, "Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit", pp. 82-83; do mesmo autor, *Die Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem*, München: Beck, 1971, pp. 91-92. Cf. também Ulrich Scheuner, "Pressefreiheit", pp. 38-39; Horst Ehmke, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation", p. 82.

122. Cf. Günter Dürig, "Art. 1", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, §§ 6 e ss.

123. Idem, "Art. 1", § 14.

de liberdade como “principal direito de liberdade”¹²⁴ e, de outro, o direito geral de igualdade como “principal direito de igualdade”.¹²⁵ No terceiro nível, por fim, estão os direitos de liberdade e igualdade específicos. Esses direitos específicos são um refinamento substancial dos dois direitos principais.¹²⁶ Entre os direitos principais e especiais há uma relação do tipo *lex generalis* e *lex specialis*.¹²⁷ O sistema como um todo é designado por Dürig como um sistema “fechado”.¹²⁸

Esse modelo sedutoramente simples, claramente baseado na decisão do caso Elfes,¹²⁹ foi submetido a uma série de questionamentos e críticas. Sua completude e, nesse sentido, sua hermeticidade foram colocadas em dúvida. Há ao menos alguns direitos fundamentais a prestações fáticas positivas, como o direito a um mínimo existencial¹³⁰ e o direito da mãe à proteção e à assistência (art. 6º, § 4º, da Constituição alemã), que dificilmente podem ser encarados como um refinamento de um dos dois direitos principais.¹³¹ Se isso é assim, então, o sistema de Dürig não abarca todos os direitos fundamentais, e, por isso, não é fechado. Mas isso ainda não é nenhum argumento contra o direito geral de liberdade. Como será demonstrado mais adiante, é ainda possível complementar o sistema global de Dürig. Além disso, o sistema parcial formado pelo direito geral de liberdade teria ainda assim um grande interesse dogmático, mesmo que ele não pudesse ser inserido em um sistema global.

Contra esse sistema parcial, formado com o auxílio do conceito de direito geral de liberdade, não há críticas sistemáticas persuasivas. As objeções podem se dirigir ou contra a relação entre o primeiro e o segundo níveis, ou contra a relação entre o segundo e o terceiro níveis. Como já ficou claro anteriormente,¹³² entre o primeiro e o segundo níveis, ou seja, entre a dignidade humana e o direito geral de liberdade,

124. Idem, “Art. 1º”, § 11.

125. Idem, “Art. 1º”, § 12, e “Art. 3º”, §§ 248 e ss.

126. Idem, “Art. 1º”, § 10.

127. Idem, “Art. 2º”, § 6.

128. Idem, “Art. 3º”, § 254.

129. Cf. *BVerfGE* 6, 32 (37, 40-41). Cf., para algumas divergências, Günter Dürig, “Anmerkung zum Elfes-Urteil”, *JZ* 12 (1957), pp. 169 e ss.

130. Cf. *BVerfGE* 45, 187 (228) e, abaixo, Capítulo 9, IV.3.

131. Cf. Konrad Löw, “Ist die Würde des Menschen im Grundgesetz eine Anspruchsgrundlage?”, *DÖV* 11 (1958), p. 520.

132. Cf. II.2, neste capítulo.

há duas relações: uma relação de particularização e outra de complementação. Aqui interessa apenas a primeira delas. O princípio da liberdade negativa particulariza o princípio da dignidade humana, na medida em que expressa um aspecto desse princípio mais amplo. Uma tal relação é sempre também uma relação de fundamentação, já que o ponto de vista mais amplo pode ser utilizado como fundamento de um de seus aspectos parciais. Quem utiliza o princípio da dignidade humana como fundamento para o princípio da liberdade negativa não deduz simplesmente esse daquele, ele se apóia na verdade em uma particularização, nos termos do seguinte esquema dedutivo:

- (1) É obrigatório que a dignidade humana seja respeitada e protegida.
- (2) Se o princípio da liberdade negativa não existir, a dignidade humana não será nem respeitada, nem protegida.
- (3) O princípio da liberdade negativa deve existir.

O princípio da liberdade negativa e, com isso, o direito geral de liberdade não decorrem diretamente da norma da dignidade humana, mas somente a partir de sua associação com uma premissa adicional que a particulariza (2), a qual não é dela dedutível. Alguém pode pôr em questão se a existência do princípio da liberdade negativa é uma condição necessária para o respeito e a proteção da dignidade humana no ordenamento jurídico. Se isso ocorrer, a segunda premissa tem que ser defendida com argumentos substanciais. Isso é característico da sistematização e da argumentação jurídicas, e não é nada problemático, pois demonstra que – e como – é possível a construção de um sistema que não se baseie *exclusivamente* em deduções. Se se leva em consideração que muitas outras premissas particularizadoras podem aparecer ao lado de (2) (já que (2) contém apenas uma condição necessária) e que a particularização por meio de (2) é uma particularização por meio de um princípio, que pode colidir com outros princípios particularizadores, então, a objeção de um “sistema axiomático fechado” perde toda a força, pelo menos no que diz respeito à relação entre o primeiro e o segundo níveis.

No contexto em questão, mais importante é a relação entre o segundo e o terceiro níveis, ou seja, entre o direito geral e os direitos especiais de liberdade. Dürrig salienta que sua tese, segundo a qual “di-

reitos especiais de liberdade são apenas formas de expressão do direito geral de liberdade (...), não pode ser compreendida no sentido de uma dedução lógica a partir de uma premissa maior¹³³. Para se saber o que isso pode significar, é necessário refletir sobre o que aconteceria se na Constituição alemã fosse garantido apenas o direito geral e nenhum direito especial de liberdade. Tudo aquilo que é protegido por direitos especiais de liberdade seria, então, protegido pelo direito geral de liberdade. Nessa medida, há uma relação lógica de inclusão. O suporte fático do direito geral de liberdade inclui, por definição, os suportes fáticos de todos os direitos especiais de liberdade. Da permissão *prima facie* de se fazer ou deixar de fazer o que se quer decorre logicamente a permissão *prima facie* de manifestar seu pensamento e de não o manifestar, de escolher uma determinada profissão e de não a escolher, etc. Mas, com essa relação de inclusão no que diz respeito ao suporte fático, esgotam-se as relações lógicas entre o segundo e o terceiro níveis. As particularidades do terceiro nível não decorrem logicamente do direito geral de liberdade e nem são com ele incompatíveis. Ao contrário, elas são determinações adicionais do legislador constituinte em face do direito geral de liberdade. Assim, a inviolabilidade do domicílio, com sua reserva qualificada, e a liberdade artística, garantida sem reservas, estão protegidas mais intensamente do que estariam se fosse garantido apenas um direito geral de liberdade; e haveria uma diferença menor entre a liberdade de locomoção dos alemães e dos estrangeiros se os alemães pudessem recorrer somente ao art. 2º, § 1º, como acontece com os estrangeiros.¹³⁴ Do conceito de direito geral de liberdade não apenas não se pode inferir que suas restrições sejam extensíveis a todos os outros direitos fundamentais, como também é possível dizer que uma tal extensão contrariaria o dever de levar a sério o teor literal dos dispositivos constitucionais e, com isso, as determinações do legislador constituinte. É certo que as diferenças na intensidade de proteção são fortemente relativizadas pelo dever de aplicação de testes de proporcionalidade também no âmbito do art. 2º, § 1º, bem como pelo fato de as cláusulas restritivas escritas serem passíveis de interpretação e que, na ausência dessas

133. Günter Dürig, "Art. 1", § 11.

134. Cf. BVerfGE 35, 382 (399).

cláusulas, é possível pressupor a existência de cláusulas tácitas;¹³⁵ mesmo assim, as diferenças permanecem. Há uma diferença entre os casos em que, com o objetivo de realizar uma restrição, é necessário argumentar contra o teor literal de um dispositivo constitucional e os casos em que o texto constitucional abarca até as restrições mais amplas, cujos limites são, então, definidos apenas pela máxima da proporcionalidade. Assim, os direitos de liberdade específicos contêm – nos termos exatos da tese do duplo caráter das normas de direitos fundamentais como regras e princípios¹³⁶ – especificações adicionais, na forma de regras, em relação ao direito geral de liberdade. Entre essas especificações adicionais e o direito geral de liberdade não há uma relação lógica; tampouco entre o direito geral de liberdade e as decisões tomadas quando de sua aplicação concreta. Essas decisões são o resultado de sopesamentos e, nesse sentido, de valorações.¹³⁷

Em vista disso, não se pode falar de dedução, e apenas de forma muito limitada de um sistema fechado. O sistema é fechado na medida em que a liberdade geral de ação protege *prima facie* – e de forma ampla – a liberdade negativa (em sentido estrito). Mas ele é aberto, na medida em que a existência do direito geral de liberdade deixa em aberto a possibilidade de novos direitos definitivos e de novos direitos implícitos. Ambos os aspectos são positivos. Também nesse ponto a objeção sistemática contra o direito geral de liberdade é totalmente improcedente.

3. Direito geral de liberdade e “indivíduo isolado”

A terceira objeção é de natureza substancial. Segundo ela, o direito geral de liberdade é a expressão de uma concepção equivocada de indivíduo e de sua relação com o Estado e com a comunidade. Como um direito à liberdade geral de ação e contra intervenções, o direito geral de liberdade corresponderia a uma visão do ser humano que a Constituição alemã já haveria superado, uma visão de “um indivíduo

135. Cf. Capítulo 6, I.3.1.

136. Cf. Capítulo 3, II.3.3.

137. Se em 1949 houvesse sido garantido apenas um direito geral de liberdade e nenhum direito específico, todas as definições teriam que ser feitas pela jurisprudência. É uma questão interessante, embora insolúvel, saber se e em que medida as regras concretas definidas pela jurisprudência seriam diferentes das regras hoje vigentes.

isolado e soberano", e não a de uma pessoa relacionada a uma comunidade e a ela vinculada,¹³⁸ que seria a visão da Constituição alemã.¹³⁹ A liberdade seria "erroneamente compreendida como a ausência de qualquer vínculo".¹⁴⁰ Com isso, ignorar-se-ia que "o Estado de Direito material e social (...) não é apenas o Estado 'interventor' e potencialmente limitador das liberdades civis", mas, "ao contrário, o Estado realizador, prestador, garantidor e criador de liberdades".¹⁴¹

Essa objeção dirige-se sobretudo contra duas características do direito geral de liberdade: em primeiro lugar, contra seu suporte fático ilimitado, e em segundo contra o fato de ser um direito negativo, no sentido já exposto. De fato, o direito geral de liberdade tem essas características, mas elas não conduzem às conseqüências temidas.

O fato de o suporte fático do direito geral de liberdade ser ilimitado¹⁴² é algo que, em vista de sua cláusula restritiva, não significa muita coisa. Decisivo para a posição do indivíduo é aquilo que é protegido definitivamente. Mas aquilo que é definitivamente protegido é tudo, menos ilimitado. É o resultado de sopesamentos contra princípios colidentes, que existem em grande quantidade. Decisivos são os pesos que a eles são conferidos. É possível defender o conceito de direito geral de liberdade e, ao mesmo tempo, conferir quase sempre um maior peso aos princípios ligados a interesses coletivos, de forma a que, no fim, pouco reste definitivamente para a liberdade negativa. Isso demonstra o alto grau de neutralidade do direito geral de liberdade em relação a teorias substanciais acerca da valoração dos direitos individuais e dos interesses coletivos. Mas a neutralidade do direito geral de liberdade termina em um ponto decisivo. As intervenções na liberdade negativa continuam a ser aquilo que são, ou seja, intervenções em um determinado tipo de liberdade. Isso significa que, enquanto tais, elas têm que ser fundamentadas.

138. Cf. *BVerfGE* 4, 7 (15-16).

139. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, pp. 227 e 150 e ss.

140. Ulrich Scheuner, "Pressefreiheit", p. 37, nota 110.

141. Rupert Scholz, "Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit", p. 97.

142. Para uma crítica da "ausência de limites do direito subjetivo", que para nenhum outro direito parece tão plausível quanto para o direito geral de liberdade, cf. Ulrich K. Preuss, *Die Internalisierung des Subjektes*, p. 37.

Contra a idéia de que as intervenções na liberdade negativa – por mais bem fundamentadas e por mais necessárias que sejam para a proteção de outras liberdades – continuam a ser aquilo que são, isto é, intervenções em um determinado tipo de liberdade, e que, portanto, têm que ser fundamentadas, insurge-se a tese da “inter-relação entre direito e liberdade”, que põe em destaque “a acepção criadora e mantenedora de liberdades do direito e do legislador”.¹⁴³ Tais concepções devem ser censuradas em razão de uma diferenciação deficiente no âmbito do conceito de liberdade. Em quase nenhum outro conceito essas diferenciações são tão necessárias quanto no caso do conceito de liberdade. O exemplo da vedação de constrangimento ilegal, já utilizado anteriormente,¹⁴⁴ deixa isso claro. Essa vedação elimina para todos a liberdade jurídica de constranger e, nesse sentido, restringe a liberdade negativa de todos. Mas, ao mesmo tempo, essa vedação aumenta a liberdade negativa de todos, ao fazer com que, na relação cidadão/cidadão, o indivíduo, na escolha entre variadas alternativas de ação, esteja sujeito em menor medida a constrangimentos por parte de outros indivíduos do que estaria se não existisse a vedação de constrangimento ilegal. A situação em que vige uma liberdade contra constrangimentos da parte de outros cidadãos deve ser, por razões diversas e óbvias, considerada melhor que a situação em que vige uma liberdade de constranger outros cidadãos. A primeira situação pode, por isso, ser designada como a situação mais livre, e é possível também afirmar que nela existe maior liberdade. Isso em nada altera a constatação de que a liberdade adicional é criada por meio da introdução de uma não-liberdade jurídica. Negar esse fato implicaria não designar as coisas pelo seu devido nome, o que conduziria a uma falta de clareza conceitual. É possível que isso não seja prejudicial nos casos claros, como é o caso da vedação de constrangimento. Não há dúvida de que a liberdade de constranger deve ser trocada pela liberdade de não ser constrangido. Nos casos em que essa relação de troca não é assim tão clara, os danos que a falta de clareza conceitual pode causar não devem ser subestimados. Há o risco de que restrições à liberdade não sejam reconhecidas como tais e deixem de ser fundamentadas

143. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie*, p. 152.

144. Cf. Capítulo 6, III.

simplesmente por terem como objetivo a garantia ou a criação de uma outra liberdade, considerada mais importante, do mesmo ou de outro titular de direito fundamental.

A despeito de sua simplicidade, o exemplo do constrangimento faz com que fique claro que há liberdades as mais variadas, que devem ser inter-relacionadas para que se obtenha um *estado global da liberdade* fundamentável. Parece ser totalmente equivocado incluir no conceito de liberdade apenas aquilo que, no final, é incluído nesse estado global, ou seja, aquilo que nele é protegido. Isso ignoraria o fato de que a criação e a manutenção de um estado global de liberdade implicam também o sacrifício de liberdades. A fundamentação desse estado global de liberdade pressupõe a fundamentação dos sacrifícios de liberdades a ele associados. Se um sacrifício de liberdade nem ao menos é reconhecido como tal, falar de sua fundamentação é algo impossível.

É trivial assinalar que um estado global de liberdade, que nada mais é que o estado correto ou justo da sociedade, não se resume à simples maximização da liberdade negativa, no sentido de uma ausência de deveres e proibições. Sem a liberdade contra intervenções da parte de sujeitos de direito de mesma hierarquia (liberdade negativa na relação entre iguais), sem as competências jurídicas para participar da formação da vontade coletiva (liberdade negativa democrática), sem um certo grau de inexistência de situações de privação econômica (liberdade negativa social) e também sem as ações de participação na comunidade política, baseadas ao mesmo tempo nas próprias convicções e na responsabilidade (liberdade positiva democrática),¹⁴⁵ não é possível haver um estado global de liberdade. A isso se soma o fato de que não são apenas os direitos subjetivos, as competências e as ações individuais que são condições para sua existência, mas também inúmeras características da organização estatal e da sociedade, que vão desde a separação de poderes até a estrutura plural da mídia. Mas tão certo quanto o fato de que a liberdade negativa não compõe sozinha o estado global de liberdade é o fato de que sem ela um estado global nunca poderia ostentar o predicado axiologicamente positivo "de liberdade". Um estado no qual não há liberdade negativa, ou seja, no qual qualquer ação imaginável ou é obrigatória ou é proibida, é, até

145. Sobre a classificação das liberdades, cf. Capítulo 4, II.2.2.

por razões conceituais, algo problemático em si mesmo.¹⁴⁶ De qualquer forma, um tal estado não poderia ser chamado de estado de liberdade. Mas essa constatação não representa mais que um primeiro passo na direção do reconhecimento do significado da liberdade negativa para o estado de liberdade. Um estado de liberdade não pressupõe apenas que exista alguma liberdade negativa; ele pressupõe muito mais que isso: que somente se intervenha na liberdade do indivíduo, no estado em que ele se encontra e nas posições jurídicas que ele tem se houver razões que justifiquem a intervenção. O que o direito geral de liberdade exige não é algo distinto, e, por isso, ele é um elemento necessário do estado global de liberdade.

Dessa forma, o direito geral de liberdade insere no estado global de liberdade tanto algo de liberdade do estado de natureza quanto algo de garantia do *status quo*. Isso não guarda relação alguma com a idéia de indivíduo isolado. Por meio da lei do sopesamento, o direito geral de liberdade é inserido de tal forma no estado global de liberdade que, de um lado, “a relação e a vinculação da pessoa à comunidade” são, sem maiores problemas, levadas em consideração e, de outro,

146. Essa situação não pode ser criada inserindo cada ação concreta em uma norma. Isso pressuporia a possibilidade de elaboração de uma lista completa de todas as ações imagináveis, mas isso não é possível. Por isso, essa situação somente pode ser alcançada por meio de normas de alto grau de generalidade. Excluídas estão as normas “o que não é obrigatório é proibido” e “o que não é proibido é obrigatório”. Se até então uma ação h não era nem obrigatória nem proibida, ou seja, se até então nem sua realização (h) nem sua não-realização ($\neg h$) eram obrigatórias, ou nem sua não-realização ($\neg h$) nem sua realização (h) eram proibidas, então, a primeira dessas normas tem como resultado que tanto h quanto $\neg h$ são proibidas; e a segunda, que tanto h quanto $\neg h$ são obrigatórias. Em todos os casos, portanto, há uma contradição. Essa contradição pode ser facilmente evitada por meio de uma norma como “o que não é obrigatório nem fazer nem não fazer é obrigatório fazer (proibido fazer)”. Uma tal norma eliminaria muitas liberdades, mas encontra seus limites nos casos de obrigações que podem ser satisfeitas de várias formas diferentes. Além disso, é necessário indagar se a situação por ela criada faz algum sentido. É questionável também se é possível eliminar todas as liberdades por meio de uma norma teleológica como “é obrigatório aquilo que fomenta Z melhor que todas as outras alternativas” ou por meio de uma norma deontológica como “o intrinsecamente melhor é sempre obrigatório”. Há alguns indícios a favor da hipótese segundo a qual para cada objetivo ou para cada grupo de objetivos há alternativas de ação neutras em relação ao objetivo, e que há ações sobre as quais se pode dizer que nem sua realização nem sua não-realização são intrinsecamente melhores. Assim, é possível supor que um sistema de normas livre de contradições e sensato não é possível se nele não houver liberdades.

são assegurados os conteúdos de liberdade necessários para a “independência da pessoa”¹⁴⁷ mesmo sob as condições da vida moderna.

4. *Direito geral de liberdade e outras normas constitucionais*

A quarta objeção é a que deve ser levada mais a sério. Segundo ela, o direito geral de liberdade – em razão de seu suporte fático extremamente amplo, que abarca não apenas todas as ações, mas também todos os estados e todas as posições jurídicas do titular do direito fundamental,¹⁴⁸ e em razão de sua cláusula de restrição, que não apenas *sempre*, como também *tão-somente* permite intervenções que sejam formal e materialmente compatíveis com a Constituição¹⁴⁹ – implicaria a aceitação de um direito fundamental à constitucionalidade da totalidade das ações estatais.¹⁵⁰ No entanto, um tal direito fundamental implicaria a “subjetivização dos princípios constitucionais jurídico-objetivos”¹⁵¹ e levaria a uma extensão processualmente insustentável do campo da reclamação constitucional.¹⁵²

4.1 *Normas de competência*

Os problemas associados a essa objeção são perceptíveis com toda clareza nos casos em que se pressupõe uma violação do direito fundamental do art. 2º, § 1º, em razão do desrespeito a uma norma de competência dirigida ao Estado. Nesse aspecto é instrutiva a decisão no caso da lei sobre a profissão de engenheiro.¹⁵³ Nessa decisão o

147. BVerfGE 4, 7 (15-16).

148. A amplitude do suporte fático é especialmente clara quando o Tribunal Constitucional Federal recorre à fórmula da desvantagem. Cf. BVerfGE 29, 402 (408), na qual se faz menção a um “direito fundamental do cidadão a ser afetado por uma desvantagem somente em virtude daquelas previsões que sejam formal e materialmente compatíveis com a Constituição”. Cf. também BVerfGE 9, 83 (88); 19, 206 (215); 42, 20 (27).

149. Cf. BVerfGE 6, 32 (41); 42, 20 (27).

150. Cf., por todos, Walter Schmidt, “Die Freiheit vor dem Gesetz”, p. 68.

151. Cf. Rupert Scholz, “Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit”, p. 84.

152. Idem, pp. 84-85 (com referências bibliográficas adicionais).

153. BVerfGE 26, 246.

Tribunal Constitucional Federal fundamenta a violação desse direito fundamental apenas com base no fato de que a regulamentação da designação profissional "engenheiro", levada a cabo pela lei, não seria algo de competência da União, mas dos Estados-membros. É possível, aqui, questionar o que isso tem a ver com o direito fundamental à liberdade geral de ação. Por que razão uma norma que, se aprovada pelo legislador estadual, não feriria o direito geral de liberdade, o fere se for aprovada pelo legislador federal?

Para responder a essa pergunta é necessário em primeiro lugar sublinhar que o "controle formal de intervenções"¹⁵⁴ não é nenhuma peculiaridade do direito geral de liberdade. O Tribunal Constitucional Federal o realiza também nos casos relativos aos direitos fundamentais específicos.¹⁵⁵ Por isso, a questão só pode dizer respeito à razão pela qual aos dispositivos de direitos fundamentais são atribuídas não apenas posições materiais, mas também formais, ou seja, posições que, por exemplo, têm como objetivo fazer com que sejam respeitadas as disposições procedimentais e disposições relativas à forma, bem como os requisitos formais do Estado de Direito, como o dever de clareza e precisão na elaboração da lei. Duas respostas são concebíveis. De acordo com a primeira, que pode ser chamada de *tese do Estado de Direito*, as posições formais são a expressão de um direito subjetivo a que o Estado de Direito seja respeitado em todas as intervenções estatais.¹⁵⁶ Se um direito fundamental específico é atingido, aquele direito é vinculado a este; se um direito fundamental específico não é atingido, aquele direito é garantido pelo art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Nesse caso, uma conexão interna com o princípio de direito fundamental relevante não tem qualquer interesse. Ao contrário, o direito ao Estado de Direito funda-se em uma razão própria, que é a obrigação estatal, decorrente do princípio do Estado de Direito, de

154. Sobre essa expressão, cf. Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", p. 66.

155. Cf. *BVerfGE* 13, 181 (190); 13, 237 (239); 14, 105 (116); 15, 226 (231); 24, 367 (385); 32, 319 (326); 34, 139 (146); 40, 371 (378); 53, 1 (15).

156. Quando Ingo v. Münch ("Art. 2", in Ingo v. Münch, *Grundgesetz: Kommentar*, v. 1, § 23) afirma que a posição formal funda-se, "na verdade, mais no dever do Estado de Direito que no art. 2º, § 1º", mas que ela é atribuível ao art. 2º, § 1º, porque caso contrário surgiria "uma questionável lacuna no Estado de Direito", ele chega ao menos perto dessa resposta.

respeitar as normas constitucionais; essa obrigação é subjetivizada sempre que sua não-satisfação acarretar um prejuízo para o indivíduo, por meio da violação de um direito fundamental ou, no mínimo, do direito geral de liberdade. A segunda resposta procura estabelecer uma conexão entre as posições materiais e formais. Segundo essa resposta, uma intervenção em um direito fundamental, decorrente de um desrespeito a uma norma de competência, viola esse direito fundamental, porque as normas constitucionais de competência bem como outras normas procedimentais e normas relativas a formalidades, presentes na parte organizacional da Constituição, têm como função, ao lado de outras, proteger a liberdade individual.¹⁵⁷ Essa concepção pode ser denominada *tese da proteção da liberdade*. Na maioria dos casos a tese do Estado de Direito e a tese da proteção da liberdade conduzem ao mesmo resultado, visto que o espectro de normas constitucionais que tenham alguma função de proteção da liberdade afetada é bastante amplo. A despeito dessa ampla equivalência de resultados, não é indiferente decidir por uma ou outra tese. A tese da proteção da liberdade fornece um fundamento para tratar posições formais como posições *de direito fundamental*. Esse fundamento pode se basear no *significado primário* dos direitos fundamentais como posições *individuais*¹⁵⁸ e sustentar que sem as posições formais haveria uma lacuna na proteção constitucional da liberdade. A esse fundamento pode ser acrescentado outro: a tese da proteção da liberdade exige que as normas constitucionais a serem examinadas no âmbito de um controle judicial em casos que envolvam a violação de um direito fundamental tenham uma função de proteção da liberdade individual em questão. Por isso, é necessário restringir a fórmula da decisão do caso Elfes. Não é a observância de todas as normas constitucionais que é a condição necessária para a não-violação do direito de liberdade, mas apenas que sejam observadas todas as normas constitucionais que tenham uma função protetora para a liberdade individual em questão. Ainda será demonstrado que essa restrição tem importantes consequências nos casos que dizem respeito à violação de direitos fundamentais de terceiros.

157. Cf. Jürgen Schwabe, "Mißdeutungen um das 'Elfes-Urteil' des BVerfG und ihre Folgen", *DÖV* 26 (1973), p. 623.

158. Cf. *BVerfGE* 50, 290 (337).

Por ora, no entanto, é importante que fique sedimentado que no caso das normas constitucionais formais a tese da proteção da liberdade não implica uma restrição da amplitude do controle, pois é necessário partir da concepção de que essas normas também têm uma função protetora das liberdades. A objeção de uma explosão do uso da reclamação constitucional como instrumento de controle geral de constitucionalidade das normas mantém seu objeto. Ela perde, contudo, sua fundamentação. O controle formal das intervenções também diz respeito a posições fundamentais individuais. Por isso, não é possível falar de forma pejorativa de uma expansão; pelo contrário, trata-se de uma necessária ampliação do âmbito da reclamação constitucional. Aqui, vale a máxima segundo a qual, em princípio, é o direito processual que deve acompanhar o direito material, e não o contrário. A isso se soma o fato de que o aspecto claramente objetivo do controle formal não contradiz a finalidade da reclamação constitucional. Como é corretamente sublinhado pelo Tribunal Constitucional Federal, a reclamação constitucional tem uma "função dupla". Ela é, "em primeiro lugar, um recurso processual extraordinário, conferido (...) ao cidadão para a defesa de seus direitos fundamentais" e, além disso, tem "a função de proteger o direito constitucional objetivo e contribuir para a sua interpretação e o seu desenvolvimento".¹⁵⁹ Em ambas as funções, o decisivo para sua admissibilidade é sempre a referência a um "direito constitucional subjetivo", pois "a Constituição não prevê nenhum tipo de ação popular".¹⁶⁰ Mas, segundo a tese da proteção da liberdade, é justamente a referência a um direito constitucional subjetivo e material que faz com que uma posição formal se transforme em uma posição de direito fundamental.

4.2 Normas de direitos fundamentais

Até aqui a análise resumiu-se à constitucionalidade formal. Já o postulado da constitucionalidade *material*, que o Tribunal Constitucional Federal coloca ao lado da constitucionalidade formal,¹⁶¹ suscita um tipo muito diferente de dificuldades. Os problemas da compati-

159. BVerfGE 33, 247 (258-259).

160. BVerfGE 45, 63 (74-75).

161. Cf. BVerfGE 6, 32 (41).

lidade formal com a Constituição são bem representados a partir de normas de competências; e os problemas de compatibilidade material, a partir de normas de direitos fundamentais. Toda norma de direito fundamental é uma norma constitucional material. Se se toma literalmente o postulado da constitucionalidade material, qualquer intervenção na liberdade negativa será uma violação do art. 2º, § 1º, se essa intervenção for contrária a qualquer outra norma de direito fundamental.

O primeiro problema reside na circularidade dessa constatação. O art. 2º, § 1º, é, ele mesmo, uma norma de direito fundamental material. Nesse sentido, o art. 2º, § 1º, deveria ser controlado com base no art. 2º, § 1º, e, no âmbito desse controle, mais uma vez dever-se-ia recorrer ao art. 2º, § 1º, etc. O mesmo problema surge no âmbito dos direitos fundamentais específicos, pois também nesse caso é exigível uma compatibilidade formal e material com a Constituição. Nesse sentido, o direito fundamental de propriedade seria violado se o direito fundamental de propriedade fosse violado, e a violação do direito fundamental de propriedade, da qual depende a violação do direito fundamental de propriedade, dependeria, por sua vez, da violação do direito fundamental de propriedade, etc. Esse problema óbvio tem uma solução óbvia. O Tribunal Constitucional Federal a expressa quando limita o conceito de ordem constitucional – que deve ser respeitada pela intervenção – às normas constitucionais “*para além do art. 2º, § 1º, da Constituição*”¹⁶² e quando exige, no âmbito do controle do art. 14, não uma compatibilidade com *todas*, mas apenas com “*todas as demais*”¹⁶³ ou “*todas as outras*”¹⁶⁴ normas constitucionais materiais.

Steiger criticou essa idéia porque o problema da circularidade do art. 2º, § 1º, não poderia ser solucionado dessa forma. A liberdade seria parte da dignidade humana, e a dignidade deveria ser sempre considerada quando do controle da compatibilidade material com a ordem constitucional.¹⁶⁵ A concepção formal-material do direito geral de liberdade pode resolver esse problema. Segundo ela, a norma da dignidade humana e a norma que garante a liberdade negativa não

162. BVerfGE 17, 306 (313) – sem grifos no original.

163. BVerfGE 21, 150 (155) – sem grifos no original.

164. BVerfGE 26, 215 (222) – sem grifos no original.

165. Cf. Heinhard Steiger, “Institutionalisierung der Freiheit?”, in Helmut Schelsky (Org.), *Zur Theorie der Institution*, Düsseldorf: Bertelsmann, 1970, p. 97.

devem ser controladas em níveis distintos. Ao contrário, o peso das razões favoráveis à proteção do direito fundamental é o resultado da conjunção do princípio da liberdade negativa e do princípio da dignidade humana (de forma mais precisa: dos subprincípios materiais do princípio da dignidade humana). Ambos os princípios devem ser sopesados *conjuntamente* contra os princípios que sejam favoráveis à intervenção. Mas, se os próprios subprincípios materiais do princípio da dignidade humana não devem ser controlados em um nível anterior ao do subprincípio formal da liberdade negativa, então, com maior razão, não deve o princípio da liberdade negativa, apenas por ser um subprincípio do princípio da dignidade humana, ser controlado em um nível anterior ao do princípio da liberdade negativa. Essa concepção é adotada pelo Tribunal Constitucional Federal quando, nos casos em que, no âmbito do art. 2º, § 1º, ao princípio da dignidade humana é conferido um peso especial, ele sustenta não haver uma violação do direito fundamental do art. 2º, § 1º, por causa da lesão ao art. 1º, § 1º, mas uma violação do direito fundamental do art. 2º, § 1º, em conjunto com o art. 1º, § 1º.

Dessa forma, é possível resolver o problema da circularidade, que surge quando o exame de um direito fundamental de determinado titular deve ser realizado no âmbito desse mesmo direito fundamental. Mas não se soluciona ainda o problema do exame de *outros* direitos fundamentais no âmbito do direito fundamental a ser examinado. Reiteradamente se suscita a objeção de que a inclusão de todas as normas de direitos fundamentais na ordem constitucional teria como consequência que toda lesão a um direito fundamental deveria ser controlada no âmbito do art. 2º, § 1º.¹⁶⁶ Todo controle de um direito fundamental poderia iniciar e terminar com o art. 2º, § 1º, e toda reclamação constitucional poderia se basear nesse mesmo artigo.¹⁶⁷ De fato, há decisões do Tribunal Constitucional Federal que reforçam essa impressão. Em uma decisão sobre a Lei de Transações Imobiliárias, por exemplo, o tribunal examina o art. 14 no âmbito do art. 2º, § 1º,¹⁶⁸ e em uma decisão sobre o direito de ação o tribunal conclui que o art. 2º, § 1º,

166. Cf. Walter Schmidt, "Die Freiheit vor dem Gesetz", pp. 50 e 52; Rupert Scholz, "Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit", p. 286.

167. Cf. Peter Lerche, *Übermaß und Verfassungsrecht*, p. 299, nota 158.

168. BVerfGE 21, 73 (79, 87).

dentre outros, não havia sido violado *porque* não haviam sido violados direitos fundamentais.¹⁶⁹

No que diz respeito ao problema do exame de outros direitos fundamentais no âmbito do art. 2º, § 1º, é necessário que se diferencie se se trata de outros direitos fundamentais do mesmo titular ou se se trata de direitos fundamentais (inclusive o do art. 2º, § 1º) de titulares distintos. Quando se trata de outros direitos fundamentais do mesmo titular é ainda necessário que se diferencie se se trata de direitos de liberdade ou de outros direitos que não sejam direitos de liberdade.

No caso dos outros direitos de liberdade do mesmo titular o problema do exame do direito fundamental no interior do exame do direito fundamental pode ser minimizado pela referência à subsidiariedade do art. 2º, § 1º, em face de outros direitos de liberdade específicos.¹⁷⁰ Em razão da regra da subsidiariedade, aquilo que é abrangido pelo suporte fático de um direito de liberdade específico não deve ser controlado a partir do art. 2º, § 1º. Diante disso, não há como surgir o problema do exame do direito fundamental no interior do exame do direito fundamental. Mas essa não é, de forma alguma, apenas uma solução técnica para o problema. A regra da subsidiariedade expressa uma idéia substancial. O suporte fático do direito geral de liberdade abrange todos os suportes fáticos dos direitos de liberdade específicos. Se não existissem os direitos de liberdade específicos, o art. 2º, § 1º, protegeria – ainda que, em parte, com diferente intensidade – aquilo que esses direitos específicos protegem. Os direitos específicos são expressões de decisões do legislador constituinte na esfera da liberdade negativa. Eles expressam o princípio da liberdade negativa a partir de determinadas ênfases. Essas ênfases têm caráter de regra, como já foi demonstrado anteriormente por meio da teoria do caráter duplo das normas de direitos fundamentais.¹⁷¹ Se os direitos de liberdade específicos de um mesmo titular tivessem que ser examinados no âmbito do direito geral de liberdade, de um lado haveria uma dupla inclusão do princípio da liberdade negativa no sopesamento, o que não faria sentido, e, de outro lado, existiria o risco de superar decisões do legislador constituinte que tenham natureza de regra.

169. BVerfGE 24, 220 (235); cf. também BVerfGE 10, 354 (363).

170. Cf. BVerfGE 32, 98 (107).

171. Cf. Capítulo 3, II.3.3.

O que acaba de ser dito vale também para os direitos de liberdade específicos implícitos nos casos em que estejam jurisprudencialmente tão consolidados que seja possível igualá-los aos direitos de liberdade específicos explícitos, o que é válido especialmente para o direito geral de personalidade e para as regras concretas que dele decorrem.¹⁷² Em virtude de sua consolidação jurisprudencial, o direito geral de personalidade deve ser tratado como *lex specialis* e, por isso, deve ser examinado antes, e não no âmbito do direito geral de liberdade. Sua relação com os direitos de liberdade específicos explícitos corresponde à que existe entre os direitos de liberdade específicos explícitos entre si.

Mais complicada é a questão no caso dos direitos fundamentais do mesmo titular que não sejam direitos de liberdade, sobretudo no caso do direito geral de igualdade. O exame da liberdade não inclui o exame da igualdade, e vice-versa. Uma intervenção pode violar a liberdade e não violar a igualdade, porque todos podem ter sua liberdade igualmente violada; e uma intervenção pode também violar a igualdade e não violar a liberdade, porque tratamentos desiguais, por si sós, não implicam violação da liberdade, mas, em suas relações recíprocas, podem ser violadores da igualdade. Isso é correto desde que não se interprete o enunciado geral de liberdade como uma proibição de arbítrio completamente independente de comparações, o que faria com que qualquer lesão à liberdade fosse também uma lesão à igualdade, em razão de sua arbitrariedade, e desde que não se conceba, desde o início, o direito geral de igualdade como um elemento dos direitos de liberdade. A idéia de subsidiariedade não afasta o art. 3º nem do art. 2º, § 1º, nem dos outros direitos de liberdade. Ela permitiria, portanto, controlar o direito geral de igualdade sempre no âmbito do art. 2º, § 1º – e também no âmbito de outros direitos de liberdade. Contra essa possibilidade, no entanto, há argumentos de direito positivo e de conveniência. A previsão, pelo legislador constituinte, de um direito geral de igualdade significa que ele decidiu que o cidadão deve ter a possibilidade de recorrer a esse direito como um direito fundamental autônomo. Por isso, a não ser que haja razões inafastáveis em sentido contrário, o direito geral de igualdade deve ser controlado de forma autônoma, ou seja, não no âmbito do art. 2º, § 1º, ou de outro direito de liberdade. E não há razões inafastáveis para que o direito geral de igualdade seja

172. Cf., neste capítulo, III.2.2.

controlado no âmbito do art. 2º, § 1º, pois, ainda que seja possível, não é necessário proceder dessa forma. O conceito de ordem constitucional, no sentido do art. 2º, § 1º, pode ser restringido de tal forma que ele, em geral, não abarque direitos de igualdade do mesmo titular.¹⁷³ Uma tal restrição é conveniente porque é conveniente não tratar diferentes pontos de vista no âmbito de um controle global, mas no âmbito de controles sucessivos.

Permanece, no entanto, o problema do controle de direitos fundamentais de terceiros no âmbito do art. 2º, § 1º. Instrutiva nesse sentido é a decisão sobre a lei acerca do horário de funcionamento do comércio,¹⁷⁴ na qual o Tribunal Constitucional Federal examinou, no âmbito do art. 2º, § 1º, reclamações constitucionais de consumidoras contrárias ao que, na opinião delas, seria um horário de funcionamento muito restrito. Teria sido mais apropriado realizar esse controle nos termos do art. 12, § 1º, que, sem dúvida, faz parte da ordem constitucional. O tribunal poderia ter questionado se o direito geral de liberdade das consumidoras havia sido ferido *porque* a lei sobre o horário de funcionamento do comércio viola a ordem constitucional em razão de uma lesão ao direito fundamental à liberdade profissional dos proprietários de lojas. Proceder dessa forma teria significado que a lesão a um direito fundamental qualquer, de um titular qualquer, é condição suficiente para uma violação ao direito geral de liberdade de um outro titular de direito fundamental quando a ação violadora embaraça esse último em algum sentido. Mas o Tribunal Constitucional Federal não foi por esse caminho. Ao contrário, após um controle formal da intervenção, com base em normas de competência, ele procedeu a um controle de proporcionalidade no âmbito do art. 2º, § 1º, da Constituição.¹⁷⁵ Isso é correto quando há uma razão suficiente para tratar de formas distintas as normas de competência e os direitos fundamentais

173. Aqui interessa apenas o *direito* fundamental de igualdade. Se o enunciado geral de igualdade apresenta um componente *objetivo* que deve ser separado dos direitos fundamentais de igualdade, e que deve ser examinado no âmbito do art. 2º, § 1º, é algo que pode ficar em aberto. Um tal exame não afetaria o problema de saber se o art. 2º, § 1º, torna supérfluo o exame de outros *direitos* fundamentais.

174. BVerfGE 13, 230. Cf., sobre isso, relacionado ao presente contexto, Ernst Hesse, *Die Bindung des Gesetzgebers an das Grundrecht des Art. 2 I GG*, Berlin: Duncker & Humblot, 1968, pp. 121-122.

175. BVerfGE 13, 203 (234 e ss.).

de terceiros no exame do art. 2º, § 1º. Essa razão existe. Normas de competência têm, ainda que em um sentido abstrato, um caráter protetor da liberdade *em relação ao* direito geral de liberdade de qualquer indivíduo. O direito fundamental de liberdade profissional dos proprietários de lojas tem, por sua vez, um caráter protetor da liberdade somente *em relação à* liberdade profissional dos proprietários de lojas, mas não *em relação à* liberdade de compra dos consumidores. É claro que há conexões, já que a liberdade de compra dos consumidores é ampliada caso uma lei sobre o horário de funcionamento do comércio seja declarada nula em razão de uma violação da liberdade profissional dos proprietários de lojas. Mas essa conexão não é de um tipo tal que faça com que se torne justificado inferir uma lesão do direito à liberdade de compra a partir da lesão ao direito de liberdade profissional. Embora normalmente ambos ocorram ao mesmo tempo, já que, quando faltam razões suficientes para a restrição da liberdade profissional, faltam em geral também razões suficientes para a restrição da liberdade de compra, isso não tem que ser necessariamente assim. É possível pensar em casos nos quais as razões do legislador não sejam suficientes para uma restrição da liberdade profissional, mas o sejam para uma restrição à liberdade de compra, e vice-versa. Assim, é possível que uma proibição de que os proprietários de postos de gasolina vendam, fora dos horários normais de funcionamento, mercadorias que não tenham relação com o funcionamento técnico dos automóveis viole seu direito à liberdade profissional, por exemplo, porque levaria à não-rentabilidade de alguns postos de gasolina; mas essa proibição não lesa o direito de compra dos consumidores, porque eles poderiam se prover sem grandes dificuldades durante os horários normais de funcionamento e, nesse sentido, seriam atingidos de forma muito menos intensa. Se, em casos como esse, se considerasse a lesão ao direito fundamental de um como razão suficiente para a lesão ao direito fundamental do outro, haveria uma participação na proteção do direito fundamental de outrem que não estaria abrangida pela sua própria posição material de direito fundamental. No campo processual a consequência disso seria a possibilidade de que alguém materialmente não afetado pudesse agir contra a lesão a direitos fundamentais de alguém materialmente afetado, mesmo que esse último assim não o queira.

A solução consiste em uma relativização do conceito de incompatibilidade com os direitos fundamentais. Da ilegalidade em uma relação jurídica¹⁷⁶ não decorre a ilegalidade em uma outra. Contra essa relativização não se pode alegar que toda incompatibilidade com um direito fundamental afeta a totalidade dos direitos fundamentais. Ao indivíduo são garantidos direitos fundamentais que se referem a ele enquanto indivíduo, mas não um direito fundamental a uma totalidade de direitos fundamentais livre de qualquer afetação, que inclua um direito fundamental à não-afetação dos direitos fundamentais de terceiros. Se uma ação estatal é uma intervenção não fundamentada no direito fundamental de *b* e, ao mesmo tempo, intervém também no direito fundamental de *a*, então, ela não viola o direito fundamental de *a* simplesmente porque viola o direito fundamental de *b*, mas somente se essa intervenção for também não fundamentada em face do direito fundamental de *a*.

Esse resultado não pode ser invalidado por meio de uma referência a um caráter protetor da liberdade dos direitos fundamentais de *b* para os direitos fundamentais de *a*. É certo que os direitos fundamentais de *b* têm um efeito protetor de liberdade para os direitos fundamentais de *a*, já que, no caso de uma violação de um direito fundamental de *b* que ao mesmo tempo é uma intervenção em um direito fundamental de *a*, a declaração de nulidade da norma que lesa o direito fundamental de *b* significa, ao mesmo tempo, a eliminação da intervenção no direito fundamental de *a*. Mas um efeito protetor da liberdade não é necessariamente um caráter protetor da liberdade. É pressuposto desse último que o direito fundamental de *b* tenha também o objetivo de proteger o direito fundamental de *a*. Direitos fundamentais têm certamente também o objetivo de garantir um estado global de liberdade, do qual todos se beneficiem. Nesse sentido, eles têm uma relação com a situação de outros titulares de direitos fundamentais. Mas eles não têm o objetivo de criar posições individuais de direitos fundamentais de outros titulares de direitos fundamentais. Seus próprios direitos fundamentais é que devem cumprir esse objetivo. Nesse sentido, há uma diferença fundamental entre normas de competência e direitos fundamentais de terceiros, e essa diferença justifica não examinar direitos fundamentais de terceiros no âmbito do contro-

176. Sobre o conceito de relação jurídica, cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

le de intervenções em direitos fundamentais, como fez o Tribunal Constitucional Federal na decisão do caso sobre a lei acerca do horário de funcionamento do comércio.

Para resumir o que foi dito acerca do exame de direitos fundamentais dentro do exame de direitos fundamentais, é possível estabelecer que nem a lesão de outros direitos fundamentais do mesmo titular nem a lesão a direitos fundamentais de terceiros devem ser controladas no âmbito do art. 2º, § 1º, da Constituição alemã. Ao conceito de ordem constitucional nos termos desse artigo deve ser acrescentada uma cláusula que exclua o controle de direitos fundamentais dentro do controle de direitos fundamentais; essa cláusula prevê que no âmbito do art. 2º, § 1º, devem ser controladas apenas aquelas normas constitucionais que tenham um caráter protetor da liberdade¹⁷⁷ em relação ao direito geral de liberdade dos eventuais afetados. Essa cláusula expressa uma restrição substancial aos direitos derivados do art. 2º, § 1º. Por isso, ela não tem um significado apenas técnico, mas também material.

177. Isso não exclui a possibilidade de o Tribunal Constitucional Federal, sublinhando a função da reclamação constitucional como "recurso específico para a proteção do direito constitucional objetivo" (*BVerfGE* 33, 247 (259); 45, 63 (74)), utilizar uma reclamação constitucional baseada no art. 2º, § 1º, como ocasião para examinar também direitos fundamentais de terceiros. Mas o reclamante *não tem um direito* a isso, e a decisão acerca da violação do *seu* direito decorrente do art. 2º, § 1º, não depende do resultado desse exame. Além disso, não se pode excluir a consideração de conteúdos jurídico-objetivos de outras normas de direitos fundamentais no âmbito de um exame do art. 2º, § 1º, quando elas tenham um caráter protetor da liberdade em relação às liberdades individuais envolvidas.

O DIREITO GERAL DE IGUALDADE

I – IGUALDADE NA APLICAÇÃO E NA CRIAÇÃO DO DIREITO

Da mesma forma que ocorre com os direitos de liberdade, também no caso dos direitos de igualdade é necessário diferenciar entre um direito geral de igualdade e direitos de igualdade específicos. Esses direitos específicos são garantidos, por exemplo, pelos arts. 3º, §§ 2º e 3º; 6º, § 5º; 33, §§ 1º a 3º; e 38, § 1º, da Constituição alemã e 136, §§ 1º e 2º, da Constituição de Weimar, combinados com o art. 140 da Constituição alemã; e o direito geral de liberdade é garantido pelo art. 3º, § 1º, da Constituição. Aqui interessa apenas este último.

O art. 3º, § 1º, da Constituição alemã – “Todos são iguais perante a lei” – é expresso por meio da tradicional fórmula¹ “perante a lei”. Como sugere seu teor literal, essa fórmula foi compreendida por muito tempo exclusivamente no sentido de um dever de *igualdade na aplicação do direito*.² Por definição, esse dever pode vincular somen-

1. Cf. o art. 3º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Constituição francesa de 1793; o Preâmbulo do diploma constitucional do Reino da Baviera, de 26.5.1818; o art. 6º da Constituição da Bélgica, de 7.2.1831; o art. 137, § 3º, da Constituição da Paulskirche; o art. 4º, § 1º, da Constituição prussiana de 31.1.1850; o art. 109, § 1º, da Constituição da República de Weimar. Sobre a história dessa formulação, cf. Hans Peter Ipsen, “Gleichheit”, in Franz L. Neumann/Hans C. Nipperdey/Ulrich Scheuner (Orgs.), *Die Grundrechte*, v. 2, Berlin: Duncker & Humblot, 1954, pp. 115-116; Karl Schweiger, “Zur Geschichte und Bewertung des Willkürverbots”, in Hans Domcke (Org.), *Verfassung und Verfassungsrechtsprechung: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs*, München: Boorberg, 1972, pp. 57 e ss.

2. Cf. Gerhard Anschütz, *Die Verfassung des Deutschen Reiches*, 14ª ed., Berlin: Stülke, 1933, Art. 109, Anm. 1, 2, pp. 522 e ss.; Julius Hatschek, *Deutsches und Preu-*

te órgãos de aplicação do direito, mas não o legislador.³ De forma sucinta, Anschütz expressou o sentido desse dever da seguinte maneira: "As leis devem ser executadas sem considerações pessoais".⁴ Nos detalhes, o dever de igualdade na aplicação da lei apresenta uma estrutura complicada, por exemplo quando exige a elaboração de regras vinculadas ao caso concreto, seja para a precisa determinação de conceitos vagos, ambíguos e valorativamente abertos, seja para o exercício de discricionariedade.⁵ No seu núcleo, contudo, esse dever é simples. Ele exige que toda norma jurídica seja aplicada a *todos* os casos que sejam abrangidos por seu suporte fático, e a *nenhum* caso que não o seja, o que nada mais significa que dizer que as normas jurídicas devem ser cumpridas.⁶ Mas o dever de obedecer às normas jurídicas é algo que elas mesmas já afirmam, na medida em que expressam um dever-ser. Nesse sentido, o dever de igualdade na aplicação da lei exige apenas aquilo que já é de qualquer forma aplicável se as normas jurídicas são válidas.⁷ Ele reforça a vinculação dos órgãos de aplicação do direito às normas criadas pelo legislador, sem estabelecer qualquer requisito substancial para essas normas, ou seja, sem vincular o

ßisches Staatsrecht, v. 1, 2ª ed., Berlin: Stille, 1930, p. 243; Richard Thoma, "Die juristische Bedeutung der grundrechtlichen Sätze der deutschen Reichsverfassung im allgemeinen", in Hans C. Nipperdey (Org.), *Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung*, I, Berlin: Hobbing, 1929, p. 23; do mesmo autor, "Ungleichheit und Gleichheit im Bonner Grundgesetz", *DVB* 66 (1951), pp. 457 e ss.

3. Carl Schmitt (cf. Carl Schmitt, *Unabhängigkeit der Richter, Gleichheit vor dem Gesetz und Gewährleistung des Privateigentums nach der Weimarer Verfassung*, Berlin: de Gruyter, 1926, pp. 22-23) observou que a igualdade perante uma lei pressupõe que a lei seja aplicável a mais de uma pessoa, isto é, que não seja uma norma individual (ordem individualizada) e que, nesse sentido, fundamenta um dever de uma prática legislativa universal, dirigido ao legislador. Esse dever dirigido ao legislador não é, contudo, parte do dever de igualdade na aplicação do direito, dirigido aos órgãos de aplicação do direito, mas um dever vinculado a um aspecto formal da igualdade na criação do direito.

4. Gerhard Anschütz, *Die Verfassung des deutschen Reiches*, Art. 109, Anm. 1, p. 523.

5. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 273 e ss.; Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, pp. 113-114 e 236 e ss.

6. Cf. Chaim Perelman, "Eine Studie über die Gerechtigkeit", in *Über die Gerechtigkeit*, München: Beck, 1967, p. 55: "A igualdade de tratamento é somente uma consequência lógica da obediência às leis".

7. Cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, p. 146.

legislador. O legislador pode discriminar como bem lhe aprouver; desde que suas normas discriminatórias sejam observadas em todos os casos, o dever de igualdade na aplicação da lei terá sido satisfeito.

Há argumentos decisivos contra restringir o significado do art. 3º, § 1º, da Constituição alemã apenas a um dever de igualdade na aplicação do direito. Esse artigo seria um dispositivo constitucional que não teria como vincular o legislador, que, por isso, não estaria a ele vinculado. Mas, em primeiro lugar, isso seria incompatível com o art. 1º, § 3º, da Constituição, que vincula todos os três poderes – ou seja, também o legislador – aos “direitos fundamentais subsequentes”. Seria, além disso, incompatível com a vontade do constituinte, que em um primeiro momento havia expressamente previsto a vinculação do legislador ordinário ao enunciado da igualdade,⁸ tendo renunciado a essa vinculação expressa apenas porque ela seria supérflua em virtude do art. 1º, § 3º, da Constituição. Por fim, seria incompatível com a idéia dos direitos fundamentais como expressão de uma desconfiança em relação ao legislador,⁹ o que inclui a submissão das leis por ele criadas a um controle em face dos direitos fundamentais, quando isso for racionalmente possível. Em seguida será demonstrado que esse controle racional é possível em face do enunciado da igualdade.

Nesses termos, o Tribunal Constitucional Federal, desde as suas primeiras decisões, assumiu como evidente a vinculação do legislador ao enunciado da igualdade, ou seja, assumiu uma interpretação do art. 3º, § 1º, não apenas como um dever de igualdade na *aplicação*, mas também na *criação* do direito.¹⁰ Em seus pontos principais, o tribunal pôde se apoiar em trabalhos da época da República de Weimar,¹¹ so-

8. Cf. *JöR* 1 (1951), pp. 66 e ss. Cf., sobre isso, Christian Starck, “Die Anwendung des Gleichheitssatzes”, in Christoph Link (Org.), *Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat*, Baden-Baden: Nomos, 1982, pp. 52-53.

9. Cf. John H. Ely, *Democracy and Distrust*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1980.

10. Cf. *BVerfGE* 1, 14 (52) – jurisprudência reiterada.

11. Cf. Heinrich Triepel, *Goldbilanzenverordnung und Vorzugsaktien*, Berlin: Vereinigung Wiss. Verleger, 1924, pp. 26 e ss.; Erich Kaufmann, “Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung”, *VVDStRL* 3 (1927), pp. 2 e ss.; Heinrich Aldag, *Die Gleichheit vor dem Gesetz in der Reichsverfassung*, Berlin: Heymann, 1925, pp. 51 e ss.; Günther Holstein, “Von Aufgaben und Zielen heutiger Staatswissenschaft”, *AöR* 50 (1926), pp. 3 e ss.

bretudo nos de Leibholz.¹² Com exceção de algumas poucas divergências,¹³ a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal foi recebida com grande concordância ou, ao menos, com simples aceitação. Essa jurisprudência será o objeto principal das considerações que serão feitas a seguir acerca da estrutura do direito geral de liberdade.

II – A ESTRUTURA DO DEVER DE IGUALDADE NA CRIAÇÃO DO DIREITO

O dever de igualdade na criação do direito exige que todos sejam tratados de forma igual pelo legislador. Mas o que isso significa?

É fácil dizer o que isso não pode significar. Esse dever não pode significar nem que o legislador tenha que inserir todos nas mesmas posições jurídicas, nem que ele tenha a responsabilidade de que todos tenham as mesmas características naturais e se encontrem nas mesmas condições fáticas. O legislador não apenas pode estabelecer o serviço militar somente para os adultos, penas somente para os criminosos, impostos baseados no nível de renda, assistência social somente para os necessitados e condecorações somente para os cidadãos distinguidos; ele tem o dever de assim proceder, se não quiser criar normas incompatíveis com sua finalidade (por exemplo: serviço militar para crianças), normas sem sentido (por exemplo: pena para todos), normas injustas (por exemplo: imposto *per capita*).¹⁴ A igualdade de todos em relação a todas as posições jurídicas não produziria apenas normas incompatíveis com sua finalidade, sem sentido e injustas; ela também eliminaria as condições para o exercício de competências. Todo eleitor teria que ser eleito, e todo subordinado teria que ser tam-

12. Cf. Gerhard Leibholz, *Die Gleichheit vor dem Gesetz*, 2ª ed., München; Beck, 1959 (1ª ed., 1925).

13. Cf. Niklas Luhmann, *Grundrechte als Institution*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1974, pp. 167 e ss.; Ernst Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft*, pp. 134 e ss.; Erich Eyermann, "Gleichheitssatz, Wurzel des Willkürverbots?", in Hans Domcke (Org.), *Verfassung und Verfassungsrechtsprechung: Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs*, pp. 45 e ss.; Karl Schweiger, "Zur Geschichte und Bewertung des Willkürverbots", pp. 55 e ss.

14. Cf. Hans Kelsen, "Das Problem der Gerechtigkeit", in Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, p. 391; Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen des allgemeinen verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes*, Berlin: Duncker & Humblot, 1971, pp. 44-45. Hans Peter Ipsen, "Gleichheit", p. 141.

bém chefe. Todo vendedor teria não apenas o direito ao pagamento do preço de venda, mas também o dever de pagá-lo; etc. É também claro que o enunciado da igualdade não pode exigir a igualdade de todas as características naturais e de todas as condições fáticas nas quais o indivíduo se encontre. Diferenças em relação à saúde, à inteligência e à beleza podem ser talvez um pouco relativizadas, mas sua eliminação se depara com limites naturais. A isso se soma o fato de que a igualização de todos, em todos os aspectos, seria, mesmo que possível, indesejável. A igualização de todos, em todos os aspectos, faria com que todos quisessem fazer sempre a mesma coisa. Mas, se todos fazem a mesma coisa, somente é possível atingir um nível intelectual, cultural e econômico muito limitado.

Portanto, o enunciado geral de igualdade, dirigido ao legislador, não pode exigir que todos sejam tratados exatamente da mesma forma ou que todos devam ser iguais em todos os aspectos. Por outro lado, para ter algum conteúdo, ele não pode permitir toda e qualquer diferenciação e toda e qualquer distinção. É necessário questionar se e como é possível encontrar um meio-termo entre esses dois extremos. Um ponto de partida para esse meio-termo é a fórmula clássica: “O igual deve ser tratado igualmente, o desigual, desigualmente”,¹⁵ que – em múltiplas variações e com inúmeras complementações – constitui a coluna vertebral da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre o art. 3º, § 1º, da Constituição.

A fórmula “o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente” pode ser interpretada de duas maneiras bastante distintas. A primeira interpretação restringe-a ao postulado de uma prática decisória universalizante.¹⁶ Para o legislador isso significa que as normas por ele criadas têm que ter a forma de normas universais condicionadas, ou seja: “para todo x , se x tem as propriedades $E_1, E_2, \dots E_n$, então, para x deve valer a consequência jurídica R ”.

15. Cf. Platão, *As Leis*, VI 757; Aristóteles, *Política*, III 5 (1280a): “Considera-se, por exemplo, que justiça é igualdade, e de fato o é, mas como igualdade para os iguais, não para todos. E considera-se também que a desigualdade pode ser justa, e de fato o pode, mas não para todos, somente para os desiguais entre si”; do mesmo autor, *Ética a Nicômaco*, V 6 (1.131a).

16. Sobre uma interpretação nesses termos, cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 392 e ss.

Normas com essa forma tratam todos os x de forma igual, na medida em que prevêem a mesma consequência jurídica para todos os x , se eles forem iguais no que diz respeito a $E_1, E_2, \dots E_n$. Não há dúvidas de que um tal postulado – que equivale ao princípio da universalizabilidade de Hare¹⁷ e ao princípio da justiça formal de Perelman¹⁸ – expressa um postulado básico de racionalidade prática,¹⁹ que vale tanto para o legislador quanto para o aplicador do direito; mas também não há dúvidas de que esse postulado não significa um grande avanço. Ele nada diz sobre que características, de que indivíduos, devem ser tratadas de que forma.²⁰ Se o enunciado geral de igualdade se limitasse ao postulado de uma práxis decisória universalizante, o legislador poderia, sem violá-lo, realizar qualquer discriminação, desde que sob a forma de uma norma universal, o que é sempre possível. A partir dessa interpretação, a legislação nazista sobre judeus não violaria o enunciado “os iguais devem ser tratados igualmente”.²¹

17. Cf. Richard M. Hare, *Freedom and Reason*, pp. 30 e ss.

18. Cf. Chaïm Perelman, “Eine Studie über die Gerechtigkeit”, p. 58.

19. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 90 e ss.

20. Cf. Christian Starck, “Die Anwendung des Gleichheitssatzes”, pp. 58-59; Ota Weinberger, “Gleichheitspostulate”, in Ota Weinberger, *Logische Analyse in der Jurisprudenz*, Berlin: Duncker & Humblot, 1979, p. 152.

21. Se se compreende o enunciado “o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente” no sentido de um postulado de uma práxis decisória universalizante, então, a segunda parte desse enunciado suscita problemas. Sempre que tanto a quanto b tiverem cometido uma fraude, devem ambos ser tratados de forma igual, nos termos do § 263, 1, do Código Penal alemão – sem prejuízo da aplicação de outras normas penais –, de forma a que ambos devam ser punidos com uma pena privativa de liberdade de até cinco anos ou multa. Nesse sentido, é verdadeiro que o igual deve ser tratado de forma igual. É verdadeiro também que, se a cometeu e b não cometeu uma fraude, a e b devem ser tratados de forma desigual no que diz respeito ao § 263, 1, do Código Penal alemão. Assim, é correto que o desigual deve ser tratado de forma desigual. Mas não é verdadeiro que sempre que, ao contrário de a , b não tenha cometido uma fraude, isto é, que seja desigual em face de a no que diz respeito ao § 263, 1, do Código Penal alemão, deverá b ser tratado de forma diversa daquela de a ; b pode não ter cometido fraude, mas receptação, que é, tanto quanto fraude, punível com pena privativa de liberdade de até cinco anos ou multa. Em relação a normas que expressam condições suficientes, mas não necessárias, para uma consequência jurídica, nos termos de uma interpretação como postulado de uma práxis decisória universalizante é válido somente o enunciado “o igual deve ser tratado igualmente”, mas não o enunciado “o desigual deve ser tratado desigualmente” (cf. Ota Weinberger, “Gleichheitspostulate”, p. 150).

Para se chegar a uma vinculação substancial do legislador, é necessário interpretar a fórmula "o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente" não como uma exigência dirigida à forma lógica das normas, mas como uma exigência dirigida ao seu conteúdo, ou seja, não no sentido de um dever *formal*, mas de um dever *material* de igualdade. Como o Tribunal Constitucional Federal corretamente observa,²² os problemas de uma tal interpretação decorrem do fato de que dois indivíduos ou duas situações nunca são iguais em todos os aspectos.²³ A igualdade – tanto quanto a desigualdade – entre indivíduos e situações é sempre uma igualdade – ou uma desigualdade – em relação a determinadas características. Juízos de igualdade, que constataam uma igualdade em relação a determinadas características, são juízos acerca de relações triádicas:²⁴ *a* é igual a *b* em relação à característica *E* (ou às características *E*₁, *E*₂, ... *E*_n). Juízos desse tipo são juízos sobre uma igualdade *fática parcial*, ou seja, relativos a apenas algumas e não a todas as características do par a ser comparado. Eles são verdadeiros se tanto *a* quanto *b* tiverem a característica *E* (ou as características *E*₁, *E*₂, ... *E*_n). O mesmo vale para juízos de desigualdade.

Juízos sobre igualdade fática parcial nada dizem sobre a obrigatoriedade de um tratamento igual ou desigual. A igualdade fática parcial é compatível com um tratamento desigual e a desigualdade fática parcial é compatível com um tratamento igual. O fato de que tanto *a* quanto *b* sejam marinheiros não exclui a possibilidade de que *a* seja punido por furto e *b*, não. O fato de *a* ser um marinheiro e *b* bancário não exclui a possibilidade de que tanto *a* quanto *b* sejam punidos por furto. Portanto, na fórmula "o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente", é necessário compreender "igual" e "desigual" como algo que não seja uma igualdade – ou uma desigualdade – fática parcial em relação a algum aspecto qualquer. Como não existem dois indivíduos, ou duas situações, entre os quais não exista tanto uma

22. Cf. BVerfGE 6, 273 (280); 13, 181 (202); 13, 225 (228); 50, 57 (77); 50, 177, (186); 53, 164 (178).

23. Essa constatação é, neste ponto, suficiente. Sobre os problemas lógicos e teórico-cognitivos da igualdade e da identidade, cf. Ota Weinberger, "Gleichheitspostulate", pp. 147 e ss.; Konrad Hesse, "Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht", AöR 77 (1951/52), pp. 172 e ss.

24. Cf. Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, pp. 30 e ss.

igualdade fática parcial quanto uma desigualdade fática parcial, tudo teria que ser tratado ao mesmo tempo como igual e como desigual, caso a fórmula se relacionasse a uma igualdade – ou a uma desigualdade – fática parcial em relação a algum aspecto qualquer.

Como não existe uma igualdade ou uma desigualdade em relação a todos os aspectos (igualdade/desigualdade fática universal) entre indivíduos e situações humanas, e visto que uma igualdade (desigualdade) fática parcial em relação a algum aspecto qualquer não é suficiente como condição de aplicação da fórmula, então, ela só pode dizer respeito a uma coisa: à igualdade e à desigualdade *valorativa*. Para possibilitar uma ordem jurídica diferenciada, a igualdade (desigualdade) valorativa tem que ser relativizada de duas maneiras. Ela tem que ser uma igualdade valorativa *em relação às igualdades (desigualdades) fáticas parciais*, pois, se ela se esgotasse em uma igualdade valorativa dos indivíduos, pura e simplesmente, ela em nada poderia contribuir para a fundamentação de tratamentos diferenciados. Além disso, ela tem que ser uma igualdade valorativa *em relação a determinados tratamentos*, pois, se não fosse assim, não seria possível explicar por que duas pessoas que, em um aspecto, devem ser tratadas de forma igual não são assim tratadas sob todos os aspectos. A essas duas relativizações, que são as condições de possibilidade de um tratamento diferenciado, soma-se uma terceira, *em relação ao critério de valoração*, que permite dizer o que é valorativamente igual e desigual. O enunciado “o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente” não contém, em si mesmo, um tal critério; mas sua aplicação pressupõe um. Assim, a igualdade material leva, necessariamente, à questão da valoração correta e, com isso, à questão sobre o que seja uma legislação correta, racional ou justa. Isso torna claro o principal problema do enunciado geral de igualdade. Ele pode ser expressado por meio de duas questões intimamente relacionadas. A primeira: se e em que medida os necessários juízos de valor no âmbito do enunciado de igualdade são passíveis de fundamentação racional; a segunda: no sistema jurídico, a quem compete – ao legislador ou ao juiz constitucional – decidir de forma vinculante em última instância acerca desses juízos de valor. Essas questões indicam a problemática a ser considerada por qualquer interpretação do art. 3º, § 1º, enquanto norma que vincula substancialmente o legislador.

III – AS FÓRMULAS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL

O Tribunal Constitucional Federal procura resolver o problema da valoração, inerente ao enunciado material geral da igualdade, com a ajuda do conceito de arbitrariedade. É possível encontrar duas linhas de interpretação na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre arbitrariedade. A primeira linha é fiel à idéia de que na aplicação do enunciado geral de igualdade sempre tem que haver um *par de comparação*; a segunda linha, para a qual tende a segunda turma do tribunal, reduz o enunciado geral de liberdade a uma *proibição geral de arbitrariedade*, em cuja aplicação os pares de comparação não desempenham nenhum papel necessário.²⁵ Como demonstrou Geiger,²⁶ há argumentos decisivos contrários à restrição do enunciado de igualdade a uma proibição geral de arbitrariedade. O exame da igualdade deixaria de ser o que seu nome indica: um exame de igualdade. Da realização de um exame de arbitrariedade no âmbito de um exame de igualdade não decorre uma exigência, da parte do enunciado de igualdade, de que se realizem exames de arbitrariedade independentemente dos exames de igualdade. Atribuir ao art. 3º, § 1º, uma proibição geral de arbitrariedade – ou seja, não relacionada a um par de comparação – poderia ser obrigatório, quando muito, se não fossem de outra maneira possíveis exames de arbitrariedade independentes de pares de comparação. Mas não é esse o caso. O tratamento arbitrário, por parte do Estado, de um titular de direitos fundamentais – como, por exemplo, um tratamento que “não é mais compreensível a partir de uma apreciação razoável das idéias-mestras da Constituição alemã”²⁷ – sempre viola algum direito fundamental, no mínimo aquele do art. 2º, § 2º, caso não seja possível formar nenhum par de comparação. Contra um exame geral de arbitrariedade, e a favor da vinculação do exame de arbitrariedade a dispositivos de direitos fundamentais específicos, há o fato de que um exame geral de arbitrariedade conduziria a um caldo de subsunções quase impenetrável, no qual o conteúdo dos

25. Cf. BVerfGE 42, 64 (74 e ss.); 57, 39 (42). Claramente nesse sentido: Gerhard Leibholz, *Die Gleichheit vor dem Gesetz*, p. 72.

26. Cf. BVerfGE 42, 79 e ss. (voto divergente). Cf., além disso, as contribuições de Geiger e Leibholz ao debate, em Christoph Link (Org.), *Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat*, pp. 100 e ss. e 105 e ss.

27. BVerfGE 42, 64 (74).

dispositivos de direitos fundamentais específicos desempenharia um papel que, embora importante, seria praticamente ininteligível. Diante disso, é necessário que seja estritamente mantida a restrição da aplicabilidade do enunciado geral de igualdade a pares de comparação.

O Tribunal Constitucional Federal associa o exame de arbitrariedade em parte diretamente à fórmula clássica "o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente", mas sobretudo a duas outras fórmulas, que derivam dessa fórmula clássica a partir da introdução do termo "substancialmente" ou dos termos "substancialmente" e "arbitrariamente". Neste ponto, interessa somente as primeiras partes das fórmulas, ligadas ao termo "igual". Segundo elas, ao legislador é vedado tratar

(1) "o igual desigualmente";²⁸

(2) "o substancialmente igual desigualmente";²⁹ e

(3) "o substancialmente igual arbitrariamente de forma desigual".³⁰

É necessário indagar se essas formulações distintas expressam normas distintas.

A igualdade no sentido da primeira fórmula é uma igualdade valorativa. Também a igualdade substancial, à qual a segunda fórmula faz menção, deve ser compreendida como igualdade valorativa. A consequência jurídica que a segunda fórmula associa à igualdade substancial é a proibição de tratamento desigual. Mas essa proibição pode ser associada somente a uma igualdade valorativa, independentemente de como ela seja estabelecida. Assim, no sentido da segunda fórmula, igualdade valorativa e igualdade substancial são a mesma coisa. A primeira e a segunda fórmulas expressam a mesma coisa de formas diferentes.

Os problemas surgem com a relação à segunda e à terceira fórmulas. A terceira fórmula pode ser interpretada de duas maneiras distintas. A primeira interpretação compreende-a de forma literal. De acordo com ela, uma igualdade substancial não implica necessariamente um dever de tratamento igual. Dois casos podem ser substancialmente iguais sem que seja obrigatório tratá-los de forma igual. Portanto, o

28. BVerfGE 3, 58 (135); 9, 124 (129); 42, 64 (72).

29. BVerfGE 1, 14 (52); 21, 6 (9); 21, 227 (234); 45, 376 (386).

30. BVerfGE 4, 144 (155); 22, 254 (263); 42, 64 (72); 49, 148 (165); 50, 177 (186); 51, 295 (300); 55, 114 (128); 57, 250 (271); 61, 138 (147).

enunciado segundo o qual o que é substancialmente igual deve ser tratado de forma igual não é válido. Não é qualquer tratamento desigual de casos substancialmente iguais que é vedado, mas apenas o tratamento arbitrariamente desigual de casos substancialmente iguais. Nesse sentido, igualdade substancial, na terceira fórmula, ou significa algo distinto do que na segunda fórmula, ou a terceira contradiz a segunda. De acordo com a primeira interpretação, o exame de igualdade deveria ocorrer sempre em três passos. No primeiro verificar-se-ia um tratamento desigual e uma igualdade fática parcial que possa servir como base para o exame de igualdade. Em um segundo passo indagar-se-ia se a igualdade fática parcial deve ser classificada como substancial. No terceiro passo, por fim, examinar-se-ia se o tratamento desigual do substancialmente igual foi arbitrário. A *segunda* interpretação conduz a um resultado completamente diferente. Ela não toma literalmente a fórmula "o substancialmente igual não pode ser tratado arbitrariamente de forma desigual". Segundo essa interpretação, o termo "arbitrariamente", nessa fórmula, é redundante, o que significa que a terceira fórmula tem o mesmo significado que a segunda e, com isso, também o mesmo significado que a primeira. Diante disso, o exame da igualdade deveria ocorrer em duas etapas. Na primeira deve-se verificar a existência de um tratamento desigual e uma igualdade fática parcial que possa servir como base para o exame de igualdade. Na segunda etapa deve ser indagado se a igualdade parcial é substancial, isto é, se existe uma igualdade valorativa no sentido definido acima.

Para se responder à pergunta sobre qual das interpretações é correta, é necessário, antes de mais nada, mencionar que o Tribunal Constitucional Federal condiciona a lesão ao enunciado de igualdade à arbitrariedade do tratamento, mesmo nos casos em que ele toma como ponto de partida a segunda fórmula, isto é, aquela que não menciona o termo "arbitrariamente". A jurisprudência do tribunal sobre igualdade tem como fio condutor o seguinte enunciado: "O enunciado da igualdade é violado se não é possível encontrar um fundamento razoável, que decorra da natureza das coisas, ou uma razão objetivamente evidente para a diferenciação ou para o tratamento igual feitos pela lei; em resumo, se a disposição examinada tiver que ser classificada como arbitrária".³¹ Em um primeiro momento cumpre analisar apenas

31. *BVerfGE* 1, 14 (52) – jurisprudência reiterada. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 60, 101 (108).

a parte desse enunciado que afirma que o enunciado da igualdade é violado se o tratamento desigual for arbitrário. Isso deve ser compreendido de forma a que a arbitrariedade do tratamento desigual seja uma condição tanto suficiente quanto necessária para a violação da igualdade.³² Isso significa, portanto, que o enunciado de igualdade é violado se, e somente se, o tratamento desigual é arbitrário. De outro lado, isso significa que, se se parte da segunda fórmula, o enunciado de igualdade é violado se, e somente se, no caso de uma igualdade substancial houver um tratamento desigual. É possível, assim, estabelecer o seguinte enunciado:

- (4) Uma igualdade *substancial* está presente nos casos em que um tratamento desigual for necessariamente *arbitrário*.

Na segunda fórmula, portanto, o conceito de igualdade substancial é definível com o auxílio do conceito de arbitrariedade do tratamento desigual.

Também no âmbito da terceira fórmula – “o substancialmente igual não pode ser tratado arbitrariamente de forma desigual” – é necessário pressupor que um tratamento desigual arbitrário é uma condição tanto suficiente quanto necessária para a violação do enunciado de igualdade. Isso, no entanto, suscita problemas em relação ao conceito de igualdade substancial. Se se pretende que nenhuma parte da terceira fórmula seja redundante, então, esse conceito tem que ser definido de forma a que a igualdade substancial não indique de antemão um dever de tratamento igual. Isso significa que, ao contrário do que ocorre na segunda fórmula, o conceito de substancialidade não pode ser definido com o auxílio do conceito de arbítrio. Isso suscita a questão acerca do que se deve compreender por uma igualdade substancial que – ao contrário do que ocorre na segunda fórmula – seja compatível com um tratamento desigual não-arbitrário. Três possibilidades podem ser consideradas: por igualdade substancial seria possível entender (1) igualdade fática parcial, (2) igualdade relevante ou (3) igual-

32. Às vezes é possível encontrar formulações nas quais se faz menção à arbitrariedade como uma condição necessária para a violação – cf. *BVerfGE* 60, 101 (108). Mas essas formulações *não* podem ser compreendidas de forma a que a arbitrariedade seja *somente* uma condição necessária da violação.

dade valorativa em um sentido ideal. Mas nenhuma dessas interpretações é aceitável.

A interpretação da igualdade substancial como igualdade *fática parcial* teria como consequência a necessidade de se considerar qualquer coincidência, em qualquer característica, como "substancial", o que faria com que a qualificação "substancial" se tornasse supérflua na terceira fórmula. Daí decorreria uma fórmula que poderia ser adicionada às três anteriormente mencionadas:

(5) O igual não pode ser tratado arbitrariamente de forma desigual.

Como o termo "igual", nessa fórmula, se refere à igualdade fática parcial, e como tudo aquilo que deve ser decidido juridicamente coincide, em pelo menos algum aspecto, com tudo aquilo que deve ser decidido juridicamente, ou seja, como a primeira parte da fórmula é sempre satisfeita, então, é possível reduzir essa fórmula ao enunciado segundo o qual todo tratamento arbitrariamente desigual é proibido. Mas esse enunciado, como se viu acima, pode ser utilizado para definir o conceito de igualdade substancial utilizado na segunda fórmula. Com isso, a terceira fórmula perderia o caráter de fórmula que concorre, no mesmo nível, com a segunda das fórmulas. Para que faça sentido se perguntar se a terceira fórmula é preferível à segunda, é necessário encontrar um conceito de igualdade substancial que seja, de um lado, mais forte que o conceito de igualdade fática parcial e, de outro lado, mais fraco que o conceito de igualdade substancial definido com o auxílio da idéia de arbitrariedade. Os candidatos para uma tal interpretação são os conceitos de igualdade relevante e de igualdade valorativa em um sentido ideal.

Como igualdades *relevantes* podem ser caracterizadas todas as igualdades fáticas parciais que mereçam um exame de arbitrariedade. O conceito de igualdade relevante é sedutor, porque promete uma delimitação do campo infinito das possibilidades de comparação. Seu inconveniente é a impossibilidade de cumprir essa promessa de forma racional. Com base em que critérios as igualdades fáticas parciais que não mereçam um exame de arbitrariedade devem ser excluídas? No limite, o critério pode se basear apenas na idéia de que há uma certeza de que não se está diante de um tratamento arbitrário. Mas, para se saber se esse é o caso, é necessário recorrer ao próprio critério de arbitrariedade. Não faz nenhum sentido que, antes do exame de arbitra-

riedade, se recorra a um critério que, ele mesmo orientado pelo critério de arbitrariedade, exclui o exame da arbitrariedade. Um tal filtro também não parece ser necessário por razões práticas, já que, se há uma certeza de que a diferenciação não é arbitrária, então, não há motivos para usar o critério de relevância para se livrar da necessidade de dizer que a diferenciação não é arbitrária. Nesses casos, é mais fácil expressar isso de forma direta.

Sobra, então, apenas a interpretação como igualdade *valorativa* em um sentido ideal. O Tribunal Constitucional Federal reiteradamente enfatiza que, no âmbito da igualdade de tratamento, é conferida ao legislador "uma ampla liberdade de conformação". Não é "tarefa do Tribunal Constitucional Federal examinar se o legislador se decidiu pela regulamentação mais justa ou mais conveniente, mas apenas se os limites extremos [*traçados pelo conceito de arbitrariedade.*] foram respeitados".³³ Com base nesse enunciado, claramente baseado no esforço de se restringir a competência controladora do tribunal nas questões relativas à igualdade, é possível distinguir entre uma concepção forte e uma concepção fraca do enunciado de igualdade. A concepção *forte* refere-se à solução ideal, isto é, à solução mais justa e mais adequada. Nos termos dessa concepção, dois casos seriam sempre substancialmente iguais e, por conseguinte, deveriam ser tratados igualmente se esse tratamento igual satisfizesse postulados como os da justiça ou da adequação em maior medida que um tratamento desigual. Se o Tribunal Constitucional Federal partisse dessa concepção forte, o legislador ficaria privado de toda e qualquer liberdade de conformação. Como não há uma cognição segura acerca da norma mais justa ou mais adequada, a tarefa do legislador se resumiria a aceitar o que o Tribunal Constitucional Federal entende como o mais justo ou o mais adequado. Praticamente não é necessária fundamentação alguma para demonstrar que esse não pode ser o sentido do enunciado da igualdade.

Por isso, possível é apenas uma concepção *fraca* do enunciado da igualdade, cujo objetivo é a manutenção dos limites da liberdade de conformação do legislador, definidos por meio do conceito de arbítrio; ela não diz respeito, portanto, a uma igualdade valorativa em um

33. Cf., por exemplo, BVerfGE 17, 319 (330). Na mesma direção aponta a distinção feita por Leibholz entre incorreção e arbítrio. Cf. Gerhard Leibholz, *Die Gleichheit vor dem Gesetz*, pp. 76-77.

sentido ideal, mas a uma igualdade em um sentido restrito. Mas, então, se torna supérfluo e sem sentido realizar um exame da igualdade valorativa em um sentido ideal antes do exame de arbitrariedade, para depois indagar se houve um desvio arbitrário, ou não. Isso é supérfluo porque o resultado do exame de arbitrariedade não depende do resultado do exame da igualdade valorativa em um sentido ideal; e é sem sentido porque teria como consequência a realização de algo supérfluo por parte do Tribunal Constitucional Federal, o que o sobrecarregaria.

Isso significa, portanto, que o conceito de igualdade substancial na terceira fórmula deve ser interpretado da mesma forma que na segunda. Em ambas o conceito de igualdade substancial é definível com o auxílio do conceito de arbitrariedade do tratamento desigual. No entanto, isso significa que o termo "arbitrário", na fórmula "o substancialmente igual não pode ser tratado arbitrariamente de forma desigual", é redundante. *Todas as três fórmulas expressam a mesma coisa.* A melhor forma de expressar a idéia é por meio da segunda fórmula: "o substancialmente igual não pode ser tratado desigualmente". Se se define, nessa fórmula, o conceito de igualdade substancial com o auxílio do conceito de arbitrariedade do tratamento desigual, como ocorreu em (4), então, a segunda fórmula é equivalente a:

(6) Tratamentos arbitrariamente desiguais são proibidos.

É necessário indagar como deve ser compreendida essa fórmula, que expressa a concepção necessariamente fraca do enunciado da igualdade.

IV – TRATAMENTO IGUAL E TRATAMENTO DESIGUAL

1. O dever de tratamento igual

Segundo a jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional Federal, uma diferenciação arbitrária ocorre "se não é possível encontrar um fundamento razoável, que decorra da natureza das coisas, ou uma razão objetivamente evidente para a diferenciação ou para o tratamento igual feitos pela lei".³⁴ Nesse sentido, uma diferenciação é

34. BVerfGE 1, 14 (52). No mesmo sentido, por exemplo, BVerfGE 12, 341 (348); 20, 31 (33); 30, 409 (413); 44, 70 (90); 51, 1 (23); 60, 101 (108).

arbitrária, e, por isso, proibida, se não for possível encontrar um *fundamento* qualificado para ela. A qualificação desse fundamento pode ser descrita de diversas maneiras. Na citação acima exige-se que se trate de um fundamento razoável ou que decorra da natureza das coisas ou que seja objetivamente evidente. Em outras formulações exige-se que a falta de objetividade da diferenciação não seja “evidente”;³⁵ em outras, ainda, é apenas exigido que o fundamento para a diferenciação seja “justificado”.³⁶ O pano de fundo para essas fórmulas é constituído pela exigência de “uma perspectiva orientada pela idéia de justiça”.³⁷

De tudo isso se infere a necessidade de haver uma razão *suficiente* que justifique uma diferenciação, e também que a qualificação dessa razão como suficiente é um *problema de valoração*. Neste ponto, interessa apenas a primeira questão. A necessidade de se fornecer uma razão suficiente que justifique a admissibilidade de uma diferenciação significa que, se uma tal razão não existe, é obrigatório um tratamento igual. Essa idéia pode ser expressa por meio do seguinte enunciado, que é um refinamento da concepção fraca do enunciado geral de igualdade, a que aqui se deu preferência:

- (7) Se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório.³⁸

Não existe uma razão suficiente para a permissibilidade de uma diferenciação quando todas as razões que poderiam ser cogitadas são consideradas insuficientes. Nesse caso, não há como fundamentar a permissibilidade da diferenciação.³⁹ Com isso, como já salientado di-

35. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 12, 326 (333).

36. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 38, 154 (167).

37. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 9, 334 (337) – jurisprudência reiterada.

38. Para uma versão desse enunciado que abra mão do elemento “permissibilidade”, cf. Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, p. 77.

39. O conceito de razão suficiente é, assim, relacionado ao êxito de uma fundamentação, o qual depende da decisão sobre se todas as razões relevantes devem ser consideradas como insuficientes, ou não. Isso significa que a presença de uma razão suficiente deve ser decidida em um discurso jurídico racional. Mesmo quando racionais, os discursos jurídicos não conduzem a apenas um resultado, e mesmo que, em um determinado momento, conduzam a um único resultado, o seu resultado poderá ser outro em outro momento (cf. Robert Alexy, “Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation”, in *Rechtstheorie*, Beiheft 2 (1981), pp. 180 e ss.).

versas vezes,⁴⁰ o enunciado geral de igualdade estabelece um ônus argumentativo para o tratamento desigual.⁴¹

2. O dever de tratamento desigual

A segunda parte do enunciado "o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente" é, ao mesmo tempo, uma desafio para essa tese e um instrumento para sua análise. A simetria nessa formulação sugere que o dever de tratamento desigual deva ser compreendido da mesma maneira que o dever de tratamento igual. Nesse sentido, ele deve ser explicitado pela seguinte norma de tratamento desigual, que é estruturalmente igual à norma (7), vista acima:

- (8) Se não houver razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento igual, então, é obrigatório um tratamento desigual.

Mas isso teria como consequência o estabelecimento de um ônus argumentativo tanto para o tratamento igual quanto para o desigual, o que eliminaria qualquer benefício em favor de um tratamento igual, o que, como salientou Podlech, implicaria o dever de fundamentar "que o regramento legal tem que ser assim e não de outra forma".⁴² O enunciado da igualdade tornar-se-ia, assim, uma simples exigência de fundamentação de normas. Ele perderia qualquer tendência em favor da igualdade. Por isso, Podlech sugere que se abandone a segunda parte da fórmula e que se atribua ao art. 3º, § 1º, da Constituição alemã apenas uma norma de tratamento igual, e não também uma norma de tratamento desigual.⁴³

Por presença ou existência de uma razão suficiente para uma diferenciação não se compreende, portanto, uma presença ou existência em si mesmas, mas uma presença ou uma existência para interlocutores concretos e racionais.

40. Cf., por exemplo, Niklas Luhmann, *Grundrechte als Institution*, pp. 169 e ss.; Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, pp. 85 e ss.; Christian Starck, "Die Anwendung des Gleichheitssatzes", p. 61; Manfred Gubelt, "Art. 3", in Ingo v. Münch (Org.), *Grundgesetz: Kommentar*, v. 1, § 26.

41. Sobre o ônus argumentativo para tratamentos desiguais como um postulado geral de racionalidade, cf. Marcus C. Singer, *Generalization in Ethics*, New York: Knopf, 1961, p. 31; John Rawls, "Justice as fairness", *The Philosophical Review* 67 (1958), p. 166; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, p. 243.

42. Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, p. 57.

43. Idem.

Uma solução assim radical seria recomendável somente se dela não fosse possível escapar. Mas isso não é assim. É perfeitamente possível ter uma tendência em favor da igualdade e, ao mesmo tempo, tanto uma norma de tratamento igual quanto uma norma de tratamento desigual. No entanto, para que isso ocorra, a norma de tratamento desigual não pode ter – como tem em (8) – a mesma estrutura da norma de tratamento igual (7). Por isso, ela tem que ter a seguinte forma:

- (9) Se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o tratamento desigual é obrigatório.⁴⁴

44. Uma comparação entre as normas de tratamento igual e de tratamento desigual ((7) e (9)) faz com que fique claro que seus antecedentes se diferenciam em dois pontos. A primeira diferença consiste no fato de que no antecedente de (7) se fala em *não-existência*, enquanto no de (9) se fala em *existência* de uma razão suficiente. A segunda diferença decorre do fato de o antecedente de (7) fazer menção à *permissibilidade* de um tratamento desigual, enquanto o de (9) menciona uma *obrigatoriedade* desse tratamento. É facilmente perceptível que os três antecedentes apresentados no texto – os de (7), (8) e (9) – não esgotam as alternativas possíveis. Se se pressupõe que a negação de um tratamento igual é um tratamento desigual e que a negação de um tratamento desigual é um tratamento igual ($\neg \text{TratIg} \leftrightarrow \text{TratDesig}$; $\neg \text{TratDesig} \leftrightarrow \text{TratIg}$), então, é possível estabelecer oito possíveis antecedentes de normas de tratamento igual e de tratamento desigual:

- (1) Não há nenhuma razão suficiente para a permissão de um tratamento desigual.
- (2) Não há nenhuma razão suficiente para a permissão de um tratamento igual.
- (3) Não há nenhuma razão suficiente para a obrigação de um tratamento igual.
- (4) Não há nenhuma razão suficiente para a proibição de um tratamento igual.
- (5) Há uma razão suficiente para a permissão de um tratamento desigual.
- (6) Há uma razão suficiente para a permissão de um tratamento igual.
- (7) Há uma razão suficiente para a obrigação de um tratamento igual.
- (8) Há uma razão suficiente para a proibição de um tratamento igual.

Uma análise do enunciado da igualdade mais detalhada que aquela a ser aqui realizada teria que considerar as relações lógicas entre esses enunciados e sua conexão com todas as formas imagináveis de consequências jurídicas ligadas à igualdade. Aqui deixa-se em aberto estabelecer se os oito antecedentes descrevem completamente o campo de análise. Para aqueles que não excluem que a existência (não-existência) de uma razão suficiente *a favor de p* não é a mesma coisa que a existência (não-existência) de uma razão suficiente *contra* $\neg p$, o número de antecedentes a serem analisados aumenta para dezesseis. Para aqueles que, além disso, não excluem que tratamentos iguais e tratamentos desiguais não sejam algo *contraditório*, mas algo *contrário*, o número aumenta para trinta e dois. Não importa quantos antecedentes são fixados no início da análise, cada um deles pode ser associado ao menos a quatro consequências jurídicas: permissão de tratar igualmente (P), permissão de não tratar igualmente ($P\neg$), dever de tratar igualmente ($\neg P\neg$), proibição de tratar igualmente ($\neg P$). Muito daquilo que se obtém dessa maneira pode ser prontamente descartado. Mas com frequência a

Essa fórmula distingue-se da norma de tratamento igual expressa em (7) na medida em que exige uma fundamentação procedente para o dever de tratamento desigual,⁴⁵ enquanto, de acordo com a norma de tratamento igual, para o dever de tratamento igual basta que não seja possível uma fundamentação da permissão (admissibilidade) de uma discriminação.⁴⁶ É exatamente nessa assimetria que reside o ônus argumentativo em favor do tratamento igual.

A assimetria entre a norma de tratamento igual e a norma de tratamento desigual tem como conseqüência a possibilidade de compreender o enunciado geral de igualdade como um *princípio da igualdade*, que *prima facie* exige um tratamento igual e que permite um tratamento desigual apenas se isso for justificado por princípios contrapostos.

V – ENUNCIADO DE IGUALDADE E VALORAÇÃO

A interpretação do enunciado da igualdade como uma regra de ônus argumentativo permite estruturar um pouco mais a questão da valoração, mas não consegue solucioná-la. Saber o que é uma razão suficiente para a permissibilidade ou a obrigatoriedade de uma discriminação não é algo que o enunciado da igualdade, enquanto tal, pode responder. Para tanto são exigíveis outras considerações, também elas valorativas.⁴⁷ E é exatamente a esse ponto que são direcionadas as críticas fundamentais acerca da vinculação do legislador ao enunciado geral da igualdade. Essas críticas sugerem que uma tal vinculação faria com que o Tribunal Constitucional Federal pudesse impor sua concepção acerca de uma legislação correta, razoável e justa no lugar da concepção do legislador, o que implicaria um “deslocamento de

decisão não é simples, e não raro as relações lógicas entre as normas de igualdade que podem ser formuladas são de difícil identificação. Essa é uma explicação para as dificuldades da análise do enunciado da igualdade.

45. Cf. BVerfGE 37, 38 (46).

46. Portanto, ao suporte fático da norma de tratamento igual corresponde a primeira linha do esquema apresentado na nota de rodapé 44, e ao suporte fático da norma de tratamento desigual a oitava linha, desde que se pressuponha que uma proibição de um tratamento igual seja o mesmo que uma obrigação de um tratamento desigual ($O \rightarrow \text{TratIg} \leftrightarrow O \text{ TratDesig}$).

47. Cf. Reinhold Zippelius, *Wertungsprobleme im System der Grundrechte*, München: Beck, 1962, pp. 33 e ss.

competências sistemicamente inconstitucional em favor do Judiciário e às custas do legislador".⁴⁸ Essa objeção, que, no fundo, sugere que o Tribunal Constitucional Federal se transformaria em uma corte de justiça com competências ilimitadas que decidiria sobre questões de justiça, pode, no entanto, ser refutada.

Em primeiro lugar, é necessário salientar que o enunciado da igualdade é uma *lex generalis* em relação às normas especiais sobre igualdade.⁴⁹ Isso faz com que o problema seja sensivelmente relativizado. As "decisões materiais sobre a igualdade",⁵⁰ expressas pelas normas especiais de igualdade – como, por exemplo, pelo art. 3º, § 2º, da Constituição alemã –, tornam supérflua, nos inúmeros casos por elas abarcados, a solução de um problema de valoração no âmbito do enunciado geral da igualdade.

Além disso, o enunciado geral da igualdade – se interpretado no sentido débil aqui sugerido – confere ao legislador uma ampla discricionariedade. A tese segundo a qual esse enunciado conduziria a uma substituição do legislador pelo Tribunal Constitucional Federal deve ser, por isso, encarada com grandes restrições. A discricionariedade do legislador, reiteradamente sublinhada pelo Tribunal Constitucional Federal,⁵¹ decorre de dois fatores: da estrutura das normas de tratamento igual e de tratamento desigual (7 e 9) e do conceito de arbítrio.

De acordo com (7), se existem razões suficientes para a admissibilidade de um tratamento desigual, o tratamento igual não é obrigatório. Mas, sob essas condições, um tratamento desigual também não é obrigatório, pois a fórmula (9) exige, para tanto, razões suficientes não apenas para a admissibilidade do tratamento desigual, mas também para a obrigatoriedade desse tratamento. Se há casos nos quais

48. Hans Peter Ipsen, "Gleichheit", p. 181 (cf. também pp. 156 e ss. e 178 e ss.). Além disso, cf. Wolfgang Zeidler, "Die Aktualität des Gleichheitssatzes nach dem BGG", DÖV 5 (1952), pp. 5-6; Friedrich Klein, "Zum Begriff und zur Grenze der Verfassungsgerichtsbarkeit", DÖV 17 (1964), pp. 475 e ss.; Richard Thoma, "Ungleichheit und Gleichheit im Bonner Grundgesetz", p. 459; Werner Böckenförde, *Der allgemeine Gleichheitssatz und die Aufgabe des Richters*, Berlin: de Gruyter, 1957, pp. 88-89.

49. Cf., por exemplo, Günter Dürig, "Art. 3", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 248.

50. Hans Peter Ipsen, "Gleichheit", p. 156.

51. Cf., por exemplo, BVerfGE 9, 334 (337); 57, 107 (115).

estejam presentes razões suficientes para a admissibilidade mas não para a obrigatoriedade de um tratamento desigual, então, há também casos nos quais o enunciado geral da igualdade não exige nem um tratamento igual, nem um tratamento desigual, mas permite tanto um quanto o outro. Isso significa que ao legislador é conferida uma discricionariedade.

A existência de casos nos quais estejam presentes razões suficientes para a permissibilidade mas não para a obrigatoriedade de um tratamento desigual é proporcionada pela interpretação do conceito de razão suficiente por meio do conceito de arbítrio. Uma razão é uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual se esse tratamento, em virtude dessa razão, deixa de ser arbitrário. Como definiu Leibholz, arbítrio é uma forma mais acentuada de incorreção.⁵² Nesse sentido, um tratamento desigual não deixa de ser arbitrário somente quando é a melhor ou a mais justa solução; ele já o deixa de ser se para sua admissibilidade há razões plausíveis. É possível perceber as diferenças entre uma razão plausível e a melhor razão diante da possibilidade de que um tribunal sustente que a melhor razão milita contra a permissibilidade de um tratamento desigual e, mesmo assim, aceite que existem razões plausíveis para esse tratamento. Mas uma razão plausível para a permissibilidade de um tratamento desigual não é ainda uma razão suficiente para sua obrigatoriedade. Que um tratamento desigual não seja arbitrário não implica, portanto, que um tratamento igual o seja. Ainda que o que foi dito não defina *qual* discricionariedade o legislador tem, ao menos demonstra *que* essa discricionariedade existe.

Nesse sentido, não se pode argumentar que a vinculação do legislador ao enunciado da igualdade faz com que ao Tribunal Constitucional Federal seja conferida uma competência para substituir livremente as valorações do legislador pelas suas próprias. É possível apenas argumentar que o enunciado geral de liberdade confere ao tribunal determinadas competências para definir os limites das competências do legislador. Embora isso signifique que algumas valorações do tribunal tenham precedência em relação àquelas do legislador, isso não é suficiente para fundamentar uma objeção.

52. Cf. Gerhard Leibholz, *Die Gleichheit vor dem Gesetz*, pp. 76-77: "diferença quantitativa".

Todo controle do legislador por parte do Tribunal Constitucional Federal implica que, em uma determinada extensão, algumas valorações do tribunal terão precedência em relação àquelas do legislador. Em inúmeros casos aquilo que as normas constitucionais exigem não decorre apenas logicamente do texto constitucional e também não pode ser fundamentado inequivocamente a partir desse texto e de outros dados juridicamente relevantes, mesmo que com o auxílio de regras metodológicas. A idéia de que toda interpretação constitucional implica valorações do intérprete é, ao mesmo tempo, trivial e fundamental. Por isso, se não se pretende, com a vinculação ao enunciado da igualdade, abdicar de toda e qualquer jurisdição constitucional, não se pode querer fundamentar a tese segundo a qual esse enunciado conduz a uma extensão indevida das competências do Tribunal Constitucional Federal simplesmente com base no fato de que sua aplicação pressupõe valorações. Necessário seria demonstrar que a aplicação do enunciado geral da igualdade implica um tal grau de valorações subjetivas – ou seja, não controláveis – que seria plausível exigir que esse enunciado, no que diz respeito à vinculação do legislador, seja tratado de forma diversa das outras normas de direitos fundamentais.⁵³ Não há, no entanto, razão para tal. Problemas fundamentais de valoração devem ser resolvidos na aplicação de todas as normas de direitos fundamentais. Também na interpretação dessas normas há a possibilidade de que o tribunal restrinja de maneira não fundamentada a discricionariedade que a Constituição garante ao legislador.

É claro que seria possível tentar diminuir um pouco o risco de que o Tribunal Constitucional Federal restrinja de maneira não fundamentada as competências do legislador por meio da eliminação do controle judicial da vinculação do legislador a determinadas normas de direito fundamental, como a do art. 3º, § 1º; mas o preço a ser pago por isso seria muito alto. Nem toda possibilidade de discriminação é abarcada por normas especiais sobre igualdade. Por isso, nunca se pode excluir a possibilidade de que uma maioria parlamentar decida a favor de uma discriminação não abarcada pelas normas especiais, discriminação, essa, que, no entanto, deveria ser classificada como

53. Nesse sentido, cf., por exemplo, Hans Peter Ipsen, "Gleichheit", p. 178.

vedada a partir da perspectiva do direito constitucional. Uma não-extensão da proteção constitucional a uma tal discriminação poderia ser justificada, quando muito, se as decisões acerca da admissibilidade ou inadmissibilidade constitucional de tais discriminações fossem necessariamente decisões puramente subjetivas. Mas esse não é o caso. Mesmo sem adentrar a teoria da fundamentação jurídica racional,⁵⁴ é possível afirmar que há inúmeras possibilidades de fundamentação racional para decisões sobre igualdade ou desigualdade no âmbito dos direitos fundamentais.⁵⁵ Pode-se fazer menção, por exemplo, à possibilidade de apoiar os juízos de valor, imprescindíveis no âmbito da aplicação do enunciado geral da igualdade, em outras normas constitucionais (argumentação sistemática),⁵⁶ ou à possibilidade de argumentação baseada em precedentes – sempre crescente com o transcorrer do tempo, em razão do enriquecimento da atividade da jurisdição constitucional –, ou ainda a idéias como a de justiça sistêmica.⁵⁷

VI – IGUALDADE JURÍDICA E IGUALDADE FÁTICA

Até aqui a análise centrou-se sobretudo nos pressupostos para o dever, a proibição e a permissão de um tratamento igual ou desigual. Praticamente não se tratou da questão acerca do que seja um tratamento igual ou um tratamento desigual. Há, no entanto, motivos suficientes para enfrentá-la. Ela suscita o problema de se saber se a fórmula “os iguais devem ser tratados igualmente; os desiguais, desigualmente” inclui ou não inclui obrigações para que o Estado crie uma igualdade fática.

54. Cf., sobre isso, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 273 e ss.

55. De forma geral sobre a segurança da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais, cf. Capítulo 10, III.3.

56. Cf., sobre isso, Christian Starck, “Die Anwendung des Gleichheitssatzes”, pp. 64 e ss.

57. Cf. Christoph Degenhart, *Systemgerechtigkeit und Selbstbindung des Gesetzgebers als Verfassungspostulat*, München: Beck, 1976.

1. Sobre os conceitos de tratamento igual em sentidos jurídico e fático

Os conceitos de tratamento igual e tratamento desigual têm uma ambigüidade fundamental. Eles podem compreendidos tanto em relação a atos como em relação a conseqüências. A compreensão *relacionada a atos* está ligada exclusivamente às ações estatais enquanto tais. Já, para a compreensão *relacionada a conseqüências* são as conseqüências fáticas da ação estatal que são decisivas. Para esclarecer essa diferenciação, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre assistência judiciária gratuita é particularmente adequada. Em um julgado mais antigo tratava-se de decidir se a não-garantia de assistência judiciária gratuita para um determinado procedimento judicial seria, a despeito da exigência da presença de um advogado, contrária ao art. 3º, § 1º, da Constituição alemã.⁵⁸ De acordo com a compreensão relacionada a atos, os necessitados e os não-necessitados são tratados não de forma desigual, mas igual, já que a vantagem da assistência judiciária gratuita é recusada a ambos da mesma forma. Pode-se dizer, na esteira de uma terminologia bastante difundida, que ambos foram tratados de forma *juridicamente* igual. Já segundo a compreensão relacionada a conseqüências, necessitados e não-necessitados não são tratados de forma igual, mas desigual, já que a não-garantia da assistência judiciária gratuita impede o necessitado, mas não o não-necessitado, “de se utilizar de uma via judicial prevista pela lei, apenas porque não dispõe dos meios necessários para tanto”.⁵⁹ Mais uma vez na esteira de uma terminologia bastante difundida, é possível dizer que ambos foram tratados de forma *faticamente* desigual. Em virtude do tratamento faticamente desigual, o Tribunal Constitucional Federal decidiu por uma violação do enunciado “os iguais devem ser tratados igualmente”, e fundamentou essa decisão exatamente no sentido mencionado acima, sustentando que não existe uma razão suficiente que justifique o tratamento (faticamente) desigual.⁶⁰ A distinção entre tratamento igual ou desigual em sentido jurídico e em sentido fático pode ser refinada sensivelmente. Mas para os objetivos aqui perseguidos o que foi até aqui analisado é suficiente.

58. BVerfGE 2, 336.

59. BVerfGE 2, 336 (340).

60. Idem.

2. Os princípios da igualdade jurídica e da igualdade fática

Essa decisão sobre assistência judiciária gratuita – à qual várias se seguiram,⁶¹ e cuja estrutura é muito semelhante à das decisões sobre igualdade de chances entre os partidos políticos⁶² – revela um problema fundamental de toda interpretação do enunciado geral da igualdade no sentido de um dever de criar uma igualdade fática. O Tribunal Constitucional Federal expressa esse problema com as seguintes palavras: “Promover determinados grupos já significa tratar os outros de forma desigual”.⁶³ Quem quer promover a igualdade fática tem que estar disposto a aceitar desigualdade jurídica.⁶⁴ De outro lado, é também verdade que, em razão da diversidade fática entre as pessoas, a igualdade jurídica sempre faz com que algumas desigualdades fáticas sejam mantidas e, freqüentemente, acentuadas.⁶⁵ Se se atribuem ao art. 3º, § 1º, tanto um *princípio da igualdade jurídica* quanto um *princípio da igualdade fática*, produz-se já no âmbito do enunciado da igualdade uma colisão fundamental: aquilo que segundo um princípio é um tratamento igual é segundo o outro um tratamento desigual, e vice-versa. Se se reúnem ambos os princípios em um supraprincípio da igualdade, então, é possível afirmar que esse princípio amplo da igualdade contém um “paradoxo da igualdade”. Aquele que parte de um tal princípio amplo da igualdade tem que lidar não apenas com o freqüentemente citado problema da relação entre liberdade e

61. Cf. as referências em *BVerfGE* 56, 139 (143 e ss.).

62. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 8, 51 (64 e ss.).

63. *BVerfGE* 12, 354 (367).

64. Mais precisamente: tratamento desigual no sentido relacionado a atos.

65. Cf. Konrad Hesse, “Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht”, p. 180. A afirmação de que, em razão das diferenças fáticas entre os seres humanos, a igualdade jurídica sempre faz com que sejam mantidas – e muitas vezes reforçadas – algumas desigualdades fáticas é compatível com a afirmação de que a igualdade jurídica produz igualdade fática, ou seja, de que a criação da igualdade jurídica pode ter como consequência uma igualdade fática. Como em todos os juízos sobre igualdade, é necessário não perder de vista a referência a pessoas individuais e aos diferentes aspectos da igualdade. Nesse sentido, em relação a algumas pessoas e sob alguns aspectos, a abolição de privilégios estamentais aumentou a igualdade fática. Ao mesmo tempo, em relação a algumas pessoas e sob alguns aspectos, a construção de uma igualdade civil mantém algumas desigualdades fáticas e, com freqüência, as reforça.

igualdade,⁶⁶ como tem também que solucionar uma boa parte dos problemas da igualdade já no âmbito do enunciado da igualdade.

O paradoxo da igualdade pode ser facilmente evitado se for possível uma renúncia total ou ao princípio da igualdade jurídica ou ao princípio da igualdade fática. A partir da perspectiva do direito constitucional, a possibilidade de se renunciar ao princípio da igualdade jurídica deve ser excluída, porque não é possível haver dúvida de que esse princípio é um elemento do direito constitucional vigente. Aquele que tem alguma dúvida quanto a isso pode saná-la por meio de uma simples olhada na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. A esse argumento jurisprudencial somam-se argumentos práticos gerais. A igualdade jurídica é um valor em si mesmo. De duas situações que sejam iguais em todos os aspectos, com a exceção de que na primeira há uma desigualdade jurídica e na segunda não, deve-se dar preferência à segunda. Nesse sentido, há um paralelismo entre a igualdade jurídica e a liberdade negativa. Além disso, como já foi demonstrado acima,⁶⁷ o ônus argumentativo para o tratamento desigual é um postulado fundamental da racionalidade prática. Esse postulado é com certeza válido para tratamentos desiguais no sentido relacionado a atos. A isso soma-se um argumento que apenas à primeira vista parece ser exclusivamente pragmático. O princípio da igualdade jurídica – por estar ligado ao ato de tratamento em si e não ter de levar em conside-

66. Esse problema, suscitado com frequência, não será aqui analisado. As observações acerca do direito geral de liberdade e do direito geral de igualdade, bem como aquelas referentes às teorias dos princípios e das modalidades, demonstram de que forma uma solução é possível: é necessário distinguir cuidadosamente entre as normas de liberdade e igualdade imagináveis e as posições jurídicas e situações fáticas em que os membros da comunidade jurídica são inseridos por meio dessas normas. O resultado de uma tal análise é que por “liberdade” e “igualdade” devem ser entendidas coisas que em parte estão necessariamente associadas, em parte colidem e em parte são apenas compatíveis. Da imensa bibliografia que enfatiza a complexidade dessa questão, podem ser aqui mencionadas as contribuições de David D. Raphael (“Tensions between the goals of equality and freedom”), Robert Walter (“Das Spannungsverhältnis der sozialen Ziele Freiheit und Gleichheit”), Stuart S. Nagel (“Issues regarding the tensions between goals of equality and freedom”) e Ota Weinberger (“Gleichheit und Freiheit: Komplementäre oder widerstreitende Ideale”), todos em Gray Dorsey (ed.), *Equality and Freedom*, 2, New York/Leiden: Oceana, 1977, pp. 543 e ss., 583 e ss., 603 e ss., 641 e ss.; e Martin Kriele, *Befreiung und politische Aufklärung* Freiburg: Herder, 1980, pp. 57 e ss.

67. Cf. o tópico IV deste capítulo.

ração seus múltiplos efeitos – é mais simples e mais seguro em sua aplicação que o princípio da igualdade fática. Um pai que presenteia seus dois filhos com duas bolas idênticas satisfaz plenamente, sem grandes reflexões e com segurança, a igualdade em seu sentido relacionado ao ato. Por outro lado, é altamente incerto e de difícil decisão saber se ele também promove alguma igualdade relacionada a consequências. Se um dos filhos fica feliz com o presente, e o outro não, pode-se dizer que, ao menos no que diz respeito ao critério de igualdade de felicidade, não houve a promoção de uma igualdade relacionada a consequências. O critério de igualdade de felicidade é um dos critérios mais inseguros de igualdade fática, mas ele sublinha um problema central na promoção da igualdade fática, que consiste no fato de que aquele que decide consegue ter uma visão apenas incompleta do processo de fomento dessa igualdade e pode controlá-lo apenas parcialmente. Diante disso tudo, não há dúvidas de que o princípio da igualdade jurídica não deve ser abandonado em favor do princípio da igualdade fática.

3. Sobre o papel do princípio da igualdade fática

Para evitar uma colisão de igualdades no âmbito do art. 3º, § 1º, sobra apenas a possibilidade de se renunciar à atribuição a esse artigo de um princípio de igualdade fática como princípio que garanta um direito subjetivo plenamente vinculante e também exigível judicialmente. Para isso, no entanto, não é necessário excluí-lo do ordenamento jurídico. Esse princípio pode ser interpretado como uma norma que, embora não exigível judicialmente, vincula o legislador e, enquanto tal, ou permanece atribuída ao art. 3º, § 1º, ou pode ser atribuída à cláusula do Estado Social do art. 20, § 1º, da Constituição alemã. Também no caso dessa forma de interpretação o princípio pode ter uma conexão com direitos subjetivos. Não como o fundamento de um direito subjetivo, mas como uma norma que fundamenta a restrição a outros direitos subjetivos. Essas são, no entanto, questões secundárias. A primeira questão diz respeito a se saber se é possível ou necessário renunciar à idéia do princípio da igualdade fática como um princípio – atribuído ao art. 3º, § 1º – que, em sua essência, pode também fundamentar direitos subjetivos, cuja garantia esteja submetida a um controle da jurisdição constitucional.

As opiniões são divididas,⁶⁸ e a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal é ambígua. De um lado, o tribunal afirma que o enunciado da igualdade não obriga o legislador "a legislar de forma a impedir que, *nos termos de uma desigualdade já existente*, situações fáticas desiguais gerem consequências jurídicas desiguais".⁶⁹ De outro lado, o tribunal salienta, em relação ao art. 3º, § 1º, que "o legislador não pode em princípio se satisfazer em aceitar desigualdades fáticas previamente existentes; se elas forem incompatíveis com exigências de justiça, o legislador tem que as eliminar".⁷⁰ Essa última afirmação pode ser compreendida nos termos do frequentemente citado enunciado da decisão sobre o Partido Comunista Alemão, que afirmava que o princípio do Estado Social exige "a realização paulatina da igualdade até um grau razoavelmente exigível".⁷¹

Scholler observou que a "concretização do enunciado da igualdade (...) depende do conceito e da visão de Estado".⁷² Mas, em relação a conceitos e visões de Estado, é possível dizer que eles sempre expressam uma filosofia do Direito e do Estado mais ou menos desenvolvida. É possível, então, na esteira de Dreier, afirmar: a escolha da interpretação do enunciado da igualdade depende da filosofia do Direito e do Estado que se defende.⁷³ Essa idéia pode ser estendida a

68. Para uma rejeição de uma interpretação do art. 3º, § 1º, da Constituição alemã (também) no sentido de uma igualdade fática, cf. Christian Starck, "Die Anwendung des Gleichheitssatzes", pp. 55 e ss. e 67 e ss.; Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, pp. 200 e ss.; Volkmar Götz, *Recht der Wirtschaftssubventionen*, München: Beck, 1966, p. 263. De outro lado, de forma mais ou menos clara a favor dessa interpretação, cf. Konrad Hesse, "Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht", pp. 180 e ss. e 213 e ss.; do mesmo autor, "Diskussionsbeitrag", in Christoph Link (Org.), *Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat*, p. 78; Hans F. Zacher, "Soziale Gleichheit", *AöR* 93 (1968), pp. 341 e ss.; Heinrich Scholler, *Die Interpretation des Gleichheitssatzes als Willkürverbot oder als Gebot der Chancengleichheit*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 14 e ss.; Peter Häberle, "Diskussionsbeitrag", in Christoph Link, *Der Gleichheitssatz*, pp. 84 e 105.

69. *BVerfGE* 9, 237 (244) – sem grifos no original. Cf. também *BVerfGE* 4, 193 (203).

70. *BVerfGE* 3, 58 (158).

71. *BVerfGE* 5, 85 (206).

72. Heinrich Scholler, *Die Interpretation des Gleichheitssatzes*, p. 13.

73. Ralf Dreier, "Zur Problematik der Verfassungsinterpretation", in Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, p. 114. Essa frase de Dreier diz respeito à escolha de teorias de interpretação.

todos os dispositivos de direitos fundamentais, mas para o enunciado da igualdade ela tem uma importância ainda maior, pois as questões de Filosofia do Direito e do Estado ligadas à igualdade são extremamente controversas. E controversa não é apenas a definição do correto conteúdo das exigências feitas pela igualdade, mas também se podem existir respostas racionalmente fundamentáveis às questões ligadas à igualdade ou se, pelo contrário, as disputas acerca desse conceito não seriam, na verdade, um conflito de ideologias e visões de mundo que não pode ser decidido de forma racional. Nesse sentido, parece que o problema da atribuição de um princípio de igualdade fática ao art. 3º, § 1º, é uma questão que só pode ser adequadamente respondida no âmbito de uma discussão sobre questões teórico-jurídicas, políticas e epistemológicas básicas.

No entanto, seria algo precipitado seguir essa impressão, isto é, iniciar a análise com uma discussão sobre questões normativas e teórico-epistemológicas básicas. Isso ignoraria um caminho que implica menores esforços e tem maiores perspectivas de êxito que um ingresso direto em questões básicas: o caminho de uma análise dogmática baseada em uma teoria das normas. Uma tal análise demonstra que há um modelo de solução que leva em consideração tanto a igualdade jurídica quanto a fática e que, ao mesmo tempo, deixa espaço para um amplo espectro de distintas concepções sobre o peso de ambos os princípios. Será demonstrado que esse modelo é suficiente para o esclarecimento dos problemas que aqui são relevantes. A seguir, esse modelo será apresentado e, logo após, com base nele, serão discutidas algumas objeções contra a atribuição de um princípio de igualdade fática ao art. 3º, § 1º, da Constituição alemã.

A base desse modelo é constituída pelo enunciado clássico: "O igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente". De acordo com a concepção definida anteriormente, a primeira parte desse enunciado deve ser interpretada por meio da norma de tratamento igual:

- (7) Se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório.

E a segunda parte deve ser interpretada pela norma de tratamento desigual:

- (9) Se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o tratamento desigual é obrigatório.⁷⁴

O passo decisivo na direção do modelo desejável consiste na compreensão do conceito de tratamento, em *ambas* as normas, no seu sentido *relacionado a atos*. Com isso, ambas as normas são diretamente válidas apenas para a igualdade jurídica. Consideradas em conjunto, elas expressam uma preferência básica em favor do princípio da igualdade jurídica. O segundo passo consiste em, na aplicação de ambas as normas, levar em consideração o princípio da igualdade fática sob a luz do conceito de razão suficiente. Pode ser tanto uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual quanto uma razão suficiente para sua obrigatoriedade. No primeiro caso trata-se de uma razão para um não-direito⁷⁵ a um determinado tratamento jurídico igual; no segundo caso, de uma razão para um direito definitivo a um determinado tratamento jurídico desigual, que serve ao fomento de uma igualdade fática. O primeiro caso é familiar. Nele, o princípio da igualdade fática desempenha o papel – freqüentemente sob o nome de “princípio do Estado Social” – de uma razão para a restrição do direito geral à igualdade jurídica.⁷⁶ O segundo caso é mais interessante. Nele, o princípio da igualdade fática desempenha o papel de uma razão para um direito a um determinado tratamento jurídico desigual que, nesse caso específico, está a serviço da promoção de uma igualdade fática. Nele se funda, portanto, um direito subjetivo à criação de alguma igualdade fática.

Esse é o ponto crítico. Para avaliá-lo corretamente, é imprescindível atentar para o que significa afirmar que a igualdade fática é o objeto de um *princípio*. Como já foi mencionado anteriormente,⁷⁷ princípios não são razões definitivas, mas *prima facie*. Eles podem, em um caso concreto, ceder em favor de princípios contrapostos. Por isso, o princípio da igualdade fática é uma razão suficiente para um direito subjetivo definitivo a um tratamento jurídico desigual, a serviço da criação de uma igualdade fática, somente se prevalecer sobre todos os outros princípios relevantes e colidentes. E é necessário atentar para

74. Cf. tópico IV, acima.

75. Sobre o conceito de não-direito, cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

76. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 29, 402 (412).

77. Cf. Capítulo 3, I.4.

todo um feixe de princípios colidentes. Sempre relevante é o princípio da igualdade jurídica, pois todo tratamento jurídico desigual para o fomento de uma igualdade fática é uma restrição à realização do princípio da igualdade jurídica.⁷⁸ Além disso, são sempre relevantes também outros princípios que têm por objeto a repartição de competências entre o Tribunal Constitucional Federal e o legislador. Por meio da definição de direitos à criação de uma igualdade fática, um tribunal constitucional restringe sensivelmente a liberdade de conformação do legislador, sobretudo porque ele não apenas lhe retira a liberdade de garantir ou de não garantir esse direito, mas também porque a garantia desse tipo de direitos freqüentemente inclui um dever de que o legislador aloque grandes meios financeiros, o que, por sua vez, retira dele a possibilidade de realizar diversas outras medidas. Nesse sentido, o princípio formal da liberdade de conformação do legislador legitimado democraticamente para a configuração social é o segundo concorrente principal do princípio da igualdade fática. A esses dois princípios mencionados, que são sempre relevantes, somam-se diversos outros que podem colidir com a igualdade fática, sobretudo aqueles que estão ligados à liberdade negativa. Tudo isso deixa claro que a classificação do princípio da igualdade fática como uma possível razão suficiente para a obrigatoriedade de um tratamento jurídico desigual que sirva ao fomento de uma igualdade fática não implica nem que a igualdade jurídica ou a liberdade negativa sejam injustificadamente suplantadas pela igualdade fática, nem que a competência para a configuração da ordem social seja transferida em um grau inadmissível do legislador para o Tribunal Constitucional Federal. Ao contrário, por meio dela é criado um modelo que permite atribuir também o princípio da igualdade fática ao art. 3º, § 1º, e, com isso, conceber esse dispositivo constitucional como expressão de um conceito amplo de igualdade, sem que com isso já se decida previamente por alguma determinada concepção de igualdade. A chave teórico-normativa e metodológica para tanto é a teoria dos princípios.

Esse modelo poderia ser criticado por ser vazio e, por isso, um simples exercício intelectual, já que os princípios colidentes, sobretu-

78. É essa colisão que o Tribunal Constitucional Federal tem em mente quando afirma: "o princípio do Estado Social também não autoriza uma configuração estatal qualquer, que elimine o dever de igualdade" (*BVerfGE* 12, 354 (367)).

do o da liberdade do legislador em configurar a ordem social, teriam, em *todos* os casos, um peso tão grande que o reconhecimento, diretamente do art. 3º, § 1º, de um direito definitivo concreto à criação de uma igualdade fática por parte do Tribunal Constitucional Federal *sempre* seria afastado. Isso demonstraria que o princípio da igualdade fática não poderia ser atribuído, como um princípio de direito fundamental em sentido pleno, ao art. 3º, § 1º, já que, para ser considerado como tal, ele teria que ter a força para, em *ao menos algum* caso, fundamentar um direito definitivo concreto.

Essa objeção pode se basear sobretudo em princípios formais. O principal argumento contra direitos à igualdade fática fundados diretamente no art. 3º, § 1º – ou seja, direitos originários⁷⁹ – sustenta que a idéia de igualdade fática é uma base muito insegura para um reconhecimento judicial de direitos concretos à igualdade fática.⁸⁰ O tribunal teria que adentrar questões não justiciáveis e fazer política social. Com isso, ele necessariamente extrapolaria suas competências. A intervenção nas competências do legislador seria tão mais grave se uma atividade jurisdicional direcionada à igualdade fática não interviesse apenas na discricionariedade jurídica do legislador, mas também em sua discricionariedade financeira.

Esses argumentos têm algo de procedente. O conceito de igualdade fática é particularmente aberto a uma diversidade de interpretações. A razão para isso está no fato de que juízos acerca da igualdade ou da desigualdade fática podem se basear em critérios os mais variados. Exemplos são: dinheiro, educação, influência política, capacidade de se autodeterminar, desenvolvimento de talentos, reconhecimento social, chances de participação em diversos âmbitos sociais, respeito próprio, realização de planos de vida e satisfação.⁸¹ Com isso fica cla-

79. O oposto de direitos originários à igualdade fática são os direitos derivados, os quais estão associados a uma ação autorizadora prévia do Estado (cf. Wolfgang Martens, "Grundrechte im Leistungsstaat", *VVDStRL* 30 (1972), pp. 21 e ss.). No caso dos direitos derivados, a única questão que se suscita é aquela ligada à igualdade jurídica.

80. Cf. Christian Starck, "Die Anwendung des Gleichheitssatzes", p. 68; Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, pp. 202 e ss.

81. Em um plano abstrato, e seguindo a proposta de Dworkin, esses critérios podem ser divididos em "igualdade de bem-estar" e "igualdade de recursos". A primeira está presente quando recursos (por exemplo: dinheiro) são distribuídos de tal forma que nenhuma redistribuição poderia produzir um grau maior de igualdade de bem-

ra a possibilidade de uma diversidade de teorias sobre igualdade fática que sejam incompatíveis entre si. Mas uma teoria da igualdade fática é, entre outras coisas, um programa para a distribuição dos bens socialmente distribuíveis. Não são apenas razões metodológicas, mas também sistêmico-constitucionais, que excluem a possibilidade de derivar da Constituição alemã apenas um programa distributivo. Questões distributivas são um objeto central da disputa entre os partidos que concorrem por uma maioria no parlamento. Sob uma Constituição que se decidiu por uma democracia parlamentar fica excluída a possibilidade de se pressupor uma única e ampla teoria acerca da igualdade fática, ancorada constitucionalmente, à qual toda decisão parlamentar que diga respeito a questões distributivas esteja ou não esteja conforme.

Mas isso joga luzes em apenas um lado da questão. O outro lado diz respeito à existência de direitos, e o fato de que a simples constatação de que sua cognição é incerta e de que seu reconhecimento por parte do Tribunal Constitucional Federal elimina a discricionariedade do legislador não constitui argumento decisivo para sua não-existência. O sentido dos direitos fundamentais é exatamente o de retirar da maioria parlamentar as decisões sobre determinadas posições dos indivíduos, ou seja, restringir a discricionariedade dessa maioria; e é característica das posições de direitos fundamentais a existência de polêmicas acerca de seu conteúdo. Se se entende que não é impossível resolver essas polêmicas com fundamentos racionais, e se não se pretende deixar à maioria parlamentar a decisão acerca da configuração da sua própria discricionariedade – já que isso seria contrário à idéia de que ninguém deve ser juiz em causa própria –, então, sobra apenas a possibilidade de se deixar essa decisão para o Tribunal Constitucional Federal.⁸² Por isso, o que se deve indagar é se as especificidades ligadas à igualdade fática – um especial alto grau de incerteza cogni-

estar (por exemplo: satisfação). A segunda, quando os recursos estão distribuídos de tal forma que nenhuma redistribuição poderia produzir um grau maior de igualdade de recursos (cf. Ronald Dworkin, "What is equality?", *Philosophy & Public Affairs* 10 (1981), pp. 186 e ss.).

82. Cf. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 140 e ss. Cf. também Hans F. Zacher, "Soziale Gleichheit", p. 359, que salienta, em relação ao enunciado da igualdade, que a "tarefa clássica dos direitos fundamentais na democracia" é a proteção das minorias. No mesmo sentido, cf. também Hans P. Schneider, "Diskussionsbeitrag", in Christoph Link (Org.), *Der Gleichheitssatz*, pp. 86-87.

tiva (diversidade de teorias distributivas) e a especialmente intensa restrição da discricionariedade do legislador (meios financeiros) – conferem ao princípio da liberdade do legislador para a configuração social um tal peso que, por si só, excluiria qualquer aceitação de um direito concreto à igualdade fática que seja passível de controle por parte do Tribunal Constitucional Federal. Esse simples questionamento já faz com que fique claro que não se trata de se saber se o Tribunal Constitucional Federal pode, ou não, impor, contra a decisão do legislador, sua própria teoria de uma distribuição justa. O que está em jogo é saber se é possível, em alguns casos, impor limites à liberdade do legislador na configuração da ordem social por motivos ligados à igualdade fática. Nesse ponto, é necessário não perder de vista a assimetria entre a igualdade jurídica e a igualdade fática, presente no modelo do enunciado geral da igualdade. Há uma carga argumentativa a favor da igualdade jurídica; a favor da igualdade fática, não. Nesse sentido, uma discriminação com o objetivo de fomentar a criação de uma igualdade fática somente é obrigatória se houver razões suficientes para tanto.

Exemplos de casos nos quais o princípio da igualdade fática tem precedência em face de princípios colidentes podem ser extraídos das decisões do Tribunal Constitucional Federal sobre assistência judiciária gratuita, citadas anteriormente. Seria possível contra-argumentar e afirmar que esses casos não demonstram muita coisa, porque eles têm algumas especificidades que impediriam uma generalização. Já se salientou que, nesses casos, a garantia de acesso à Justiça, do art. 19, § 4º, é um ponto de vista condutor adicional,⁸³ e que neles a questão da igualdade é passível de ser analisada pelo Judiciário, ao contrário do que ocorre em outros casos de igualdade fática.⁸⁴ Acima já foi mencionado que um dos principais problemas da igualdade fática é a definição do aspecto em relação ao qual essa igualdade deve existir. A

83. Christian Starck, "Die Anwendung des Gleichheitssatzes", p. 68, nota 84. De forma bastante geral, Starck exige que se preencha substancialmente o enunciado da igualdade com o auxílio das "proibições de diferenciação e das obrigações de diferenciação, expressas direta ou indiretamente na Constituição" (p. 64). Nesse ponto deve-se concordar com ele. O problema reside em saber em que medida é possível extrair da Constituição alemã, com segurança suficiente, critérios suficientemente precisos para esse objetivo.

84. Cf. Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen*, pp. 220 e ss.

associação, nos casos de assistência judiciária gratuita, do princípio da proteção jurídica ao princípio da igualdade fática significa que foi determinado o aspecto em relação ao qual a igualdade fática deve existir. Mas isso em nada muda a definição dos casos de assistência judiciária gratuita como casos de igualdade fática, e também não quer dizer absolutamente nada acerca da possibilidade de a Constituição obrigar à criação de igualdades fáticas também em outros aspectos. Além disso, é certo que as decisões nos casos de assistência judiciária gratuita são relativamente simples, o que faz com que esses casos se tornem casos razoavelmente certos de precedência do princípio da igualdade fática. Mas também isso não exclui sua aplicação a outros casos. Isso tudo demonstra que os casos de assistência judiciária gratuita, embora apenas limitadamente adequados como base indutiva para outros casos, têm que ser considerados como casos de aplicação do princípio da igualdade fática, e que de suas peculiaridades não decorre uma não-aplicabilidade do princípio da igualdade fática em outros casos.

A tese segundo a qual não existem casos nos quais o princípio da igualdade fática tenha precedência em face de todos os outros princípios relevantes e colidentes é, como toda tese acerca da não-existência de algo, de difícil fundamentação. Não seria suficiente para essa fundamentação a demonstração de que, em face do atual estado da legislação, não existe nenhum caso no qual o Tribunal Constitucional Federal tenha decidido por um direito originário a uma igualdade fática. O estado da legislação pode se modificar e a Constituição não vale apenas para a atual situação da legislação. Como não é possível conhecer todos os casos possíveis, a tese da não-existência deve ser encarada como uma simples suposição, que será refutada assim que se encontrar um caso no qual o princípio da igualdade fática seja aplicável e tenha prioridade.

O caso do mínimo existencial pode ser considerado como um exemplo de um caso nesses termos.⁸⁵ Sem recorrer a comparações é praticamente impossível determinar o que faz parte do mínimo existencial garantido constitucionalmente. Como a História e outros países demonstram, o mínimo existencial absoluto pode ser fixado em um patamar extremamente baixo. Sob a Constituição alemã o que importa é o mínimo existencial relativo, ou seja, aquilo que sob as con-

85. Sobre isso, sob o aspecto do direito a prestações, cf. Capítulo 9, I.2.

dições de cada momento na República Federal da Alemanha seja considerado como mínimo existencial. Simplesmente aceitar aquilo que o legislador garante em cada momento seria renunciar a um padrão jurídico-constitucional para aquilo que o legislador tem o dever de garantir. Nesses casos, o conceito de dignidade humana praticamente não oferece nenhum padrão racionalmente controlável. Mas esse padrão pode ser oferecido, em nível constitucional, pelo princípio da igualdade fática. Esse princípio exige uma orientação baseada no nível de vida efetivamente existente, mas, por força de princípios colidentes, o padrão poderá ficar abaixo desse nível. Claro que, com isso, tudo passa a ser uma questão de sopesamento, mas, em primeiro lugar, isso não é incomum em questões envolvendo direitos fundamentais e, além disso, sopesamentos podem ser realizados de forma racional. Nesse sentido, o enunciado da igualdade, que inclui a igualdade fática, pode, nos casos de mínimo existencial, fundamentar direitos definitivos concretos à criação de uma igualdade fática.⁸⁶

Seria possível argumentar que esse exemplo demonstra justamente que a igualdade fática é derivada mais do princípio do Estado Social que do enunciado geral de igualdade. A favor desse ponto de vista milita a possibilidade de que o princípio da igualdade fática seja, de fato, visto como um subprincípio do princípio do Estado Social. Contudo, o ponto decisivo está no fato de a cláusula do Estado Social não ser, ao contrário do que ocorre com o enunciado geral da igualdade, um dispositivo de direito fundamental. No caso de uma derivação exclusivamente a partir do princípio do Estado Social não haveria nem mesmo a possibilidade de uma fundamentação de um direito subjetivo concreto à igualdade fática que fosse baseada em direitos fundamentais, por mais restrito que esse direito subjetivo fosse. No entanto, não há nenhuma razão para se renunciar a essa possibilidade; pelo contrário.

Se aceito o modelo aqui defendido, seria possível garantir, de um lado, a repartição de competências entre Tribunal Constitucional Federal e legislador, prevista pela Constituição, e, ao mesmo tempo, respeitar os inúmeros princípios (especialmente a liberdade negativa e a

86. Aqui será analisado apenas o princípio da igualdade fática. A análise dos direitos sociais demonstrará que esse princípio pode atuar em conjunto com a liberdade fática. Cf. Capítulo 9, IV.2.

igualdade jurídica) que colidem com a igualdade fática. De outro lado, nos casos em que o peso da igualdade fática é suficiente para superar as razões a ela contrapostas, é possível garantir um direito definitivo concreto à criação de uma determinada igualdade fática. Tudo isso se encaixa sem contradições em um modelo com grau de complexidade relativamente baixo, o qual, além disso, deixa espaço para valorações das mais variadas espécies.

VII – A ESTRUTURA DOS DIREITOS DE IGUALDADE COMO DIREITOS SUBJETIVOS

Segundo Leibholz, os direitos subjetivos decorrentes do enunciado geral da igualdade são, como os direitos de defesa, direitos a uma abstenção, a saber, “a uma abstenção em relação a perturbações ilegais da igualdade jurídica”.⁸⁷ O enunciado geral da igualdade teria, portanto, “uma natureza negativa”.⁸⁸ É fácil suscitar uma objeção a esse paralelismo entre direitos de liberdade e de igualdade, por ser possível atribuir ao enunciado geral de igualdade direitos que devem ser encarados como direitos pertencentes ao status positivo. Um exemplo disso é dado pela decisão sobre auxílio-moradia para beneficiários da assistência social.⁸⁹ Isso suscita a necessidade de se indagar acerca da estrutura dos direitos de igualdade como direitos subjetivos.

É possível distinguir três tipos de direitos que derivam do enunciado geral da igualdade: os direitos de igualdade definitivos abstratos, os direitos de igualdade definitivos concretos e os direitos de igualdade *prima facie* abstratos.

Há dois tipos de *direitos de igualdade definitivos abstratos*: o direito de ser tratado igualmente, se não houver razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual; e o direito de ser tratado desigualmente, se houver uma razão suficiente para o dever de tratamento desigual. Esses dois direitos equivalem às duas normas sobre o tratamento igual e desigual, estabelecidas anteriormente:⁹⁰

87. Gerhard Leibholz, *Die Gleichheit vor dem Gesetz*, p. 235.

88. Idem, p. 118.

89. BVerfGE 27, 220 (230).

90. Cf. tópico IV, neste capítulo.

- (7) Se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento igual é obrigatório.
- (9) Se houver uma razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o tratamento desigual é obrigatório.⁹¹

91. A formulação dessas normas não permite identificar uma diferença entre suporte fático (em sentido estrito) e cláusula de restrição. É necessário indagar se é viável uma construção na qual seja possível identificar essa diferença. Aqui será analisada apenas a norma de tratamento igual (7). Para se chegar a uma norma que diferencie entre suporte fático (*T*) e cláusula de restrição (*S*) como condições positiva e negativa da consequência jurídica (*R*), ou seja, uma norma que corresponda ao esquema $T \wedge \neg S \rightarrow R$, é possível a seguinte reformulação de (7): Se uma ação estatal *x* constitui um tratamento desigual, e se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade desse tratamento desigual, então, a realização de *x* é proibida. O suporte fático dessa norma é extremamente amplo. Ele abarca toda diferenciação jurídica e, com isso, quase todas as ações estatais. Isso não é, contudo, uma desvantagem. Se se pretende que o enunciado geral de igualdade seja um critério a partir do qual possa ser mensurada a totalidade das ações estatais, levando-se em consideração todos os pares de comparação, então, essa amplitude – que equivale à do suporte fático do direito geral de liberdade (cf. Capítulo 7, II.1.1) e à teoria ampla do suporte fático, apresentada anteriormente (cf. Capítulo 6, II.2.2) – é imprescindível. O cerne da cláusula de restrição é o conceito de razão suficiente. Para se demonstrar que algo tem ou não a qualidade de razão suficiente para uma diferenciação, é possível utilizar argumentos bastante diversos. Esses argumentos podem ser estruturados no âmbito do modelo de princípios, que, como já foi demonstrado, implica a máxima da proporcionalidade (cf. Capítulo 3, I.8). Como justificação para uma diferenciação *D* é alegado que *D* é um meio para se alcançar o objetivo *Z*. Para que isso seja qualificado como uma razão insuficiente é possível, por exemplo, demonstrar (1) que *D* não é adequado para alcançar *Z*, (2) que *D* não é necessário para alcançar *Z* ou (3) que, embora *D* seja adequado e necessário para alcançar *Z*, e embora a obtenção de *Z* sirva à realização do princípio *P*₁, que colide com a igualdade jurídica, os princípios *P*₂, ..., *P*_n, aos quais pertence, entre outros, a igualdade jurídica, prevalecem, no que diz respeito a *Z* e a *D*, sobre o princípio *P*₁ (proporcionalidade em sentido estrito). Nesse sopesamento é preciso levar em consideração o princípio da liberdade de conformação do legislador.

De acordo com essa construção, os problemas da aplicação da norma de tratamento igual devem ser resolvidos no âmbito da cláusula de restrição. Uma construção completamente diferente foi proposta por Kloepper. Segundo ela, o suporte fático não consiste simplesmente em um tratamento desigual, mas em um tratamento desigual do que for substancialmente igual. A cláusula de restrição é preenchida pela reserva de restrição da liberdade de conformação do legislador. Assim, a proibição de arbítrio e a máxima da proporcionalidade encontram-se juntas em uma cláusula de restrição da restrição (Michael Kloepper, *Gleichheit als Verfassungsfrage*, Berlin: Duncker & Humblot, 1980, pp. 54 e ss.). Há algumas objeções contra essa construção. Um primeiro problema suscita a utilização, no suporte fático, do conceito de igualdade *substancial*. Como foi demonstrado acima, por igualdade substancial pode ser entendida apenas

Esses direitos abstratos conduzem a direitos concretos muito diferentes. Ainda assim é possível conferir a eles uma *formulação* com base na qual eles possam ser classificados como direitos de defesa. Ao primeiro corresponde o dever do Estado de se abster de realizar determinados tratamentos desiguais; o segundo, ao dever do Estado de se abster de realizar determinados tratamentos iguais. Em relação a essas possibilidades de formulação, mas também somente em relação a elas, a tese do paralelismo de Leibholz é correta. Mas uma análise mais detida daquilo que se esconde por trás dessas formulações obriga-nos a abandoná-las.

Isso fica ainda mais claro no caso dos *direitos de igualdade definitivos concretos*. O direito à “não-realização de um tratamento desigual” pode abarcar direitos concretos de igualdade tanto do status negativo, quanto do positivo, quanto do ativo. Se alguém é afetado por uma proibição que desrespeita o enunciado da igualdade, então, ele pode ter um direito definitivo concreto, fundado no enunciado da igualdade, à cessação da intervenção, ou seja, um direito do status negativo.⁹² Nesse caso, a “não-realização de um tratamento desigual” é uma ação negativa. Se, ao contrário, alguém não é incluído em algum benefício, em desrespeito ao enunciado da igualdade, então, ele pode ter um direito definitivo concreto ao benefício, fundado no enunciado da igualdade, ou seja, um direito do status positivo.⁹³ Nesse caso, a “não-realização de um tratamento desigual” consiste em um ato positivo. Se, em desrespeito ao enunciado da igualdade, a alguém não é garantida a competência para a participação na formação da vontade estatal, então, ele pode ter um direito definitivo concreto do status ativo, fun-

uma igualdade valorativa. Mas nos casos de igualdade valorativa o tratamento igual é sempre obrigatório, de forma que a restrição e a restrição da restrição tornar-se-iam supérfluas. Além disso, não parece ser apropriado relacionar a restrição apenas ao princípio formal da liberdade de conformação do legislador. Em si mesma, a liberdade de conformação do legislador nunca é uma razão suficiente para uma diferenciação. A essa liberdade deve ser sempre acrescentada uma razão que se baseie em um princípio material. Por isso, os aspectos materiais não devem ser removidos da cláusula de restrição e atribuídos a uma cláusula de restrição da restrição; eles devem fazer parte da cláusula de restrição. O “caldo de subsunções impenetrável” que Kloepfer teme (p. 56) pode ser evitado, como já se indicou acima, por meio de uma estruturação da argumentação favorável e contrária à existência de uma razão suficiente.

92. Cf., por exemplo, BVerfGE 21, 292 (301 e ss.).

93. Cf., por exemplo, BVerfGE 27, 220 (230).

dado no enunciado da igualdade. O fato de que, nos três casos, aquele que é afetado pelo desrespeito ao enunciado da igualdade apenas *pode* ter um direito de igualdade concreto e definitivo é uma consequência do fato de a violação do direito de igualdade definitivo abstrato frequentemente poder ser afastada de formas muito distintas. Um exemplo é a alternativa entre a não-realização do ato violador da igualdade e a extensão a todos os sujeitos de direitos substancialmente iguais, sendo a primeira opção uma abstenção, e a segunda uma ação positiva. Aqui não é necessário questionar como devem ser classificados, no âmbito da teoria dos status, os direitos à realização de uma dentre essas alternativas;⁹⁴ basta constatar que há pelo menos alguns casos nos quais o enunciado geral da igualdade garante direitos que não são direitos do status negativo.

Esse quadro fica ainda mais refinado quando se analisam os *direitos de igualdade "prima facie" abstratos*, dos quais, da mesma forma que ocorre com os direitos definitivos abstratos, há dois tipos. O primeiro corresponde ao princípio da igualdade jurídica; o segundo, ao da igualdade fática. O direito *prima facie* à igualdade jurídica pode ser formulado como um direito *prima facie* à não-realização de um tratamento desigual; o direito *prima facie* à igualdade fática, por seu turno, é um direito *prima facie* a uma ação positiva do Estado.

Diversas outras diferenciações e refinamentos são possíveis. No entanto, estas breves considerações são suficientes para demonstrar o que interessa: é insuficiente interpretar o art. 3º, § 1º, da Constituição alemã no sentido de um direito do status negativo; na verdade, a esse dispositivo de direito fundamental deve ser atribuído um feixe de direitos subjetivos com as estruturas mais variadas. Somente esse feixe é que define o direito fundamental do art. 3º, § 1º, como um direito completo.⁹⁵

94. Cf., sobre a questão, Michael Sachs, "Zur dogmatischen Struktur der Gleichheitsrechte als Abwehrrechte", *DÖV* 37 (1984), pp. 414 e ss.

95. Sobre o conceito de "direito fundamental completo", cf. Capítulo 4, III.

DIREITOS A AÇÕES ESTATAIS POSITIVAS (DIREITOS A PRESTAÇÕES EM SENTIDO AMPLO)

I – CONCEITOS FUNDAMENTAIS E CONCEPÇÃO FUNDAMENTAL

De acordo com a interpretação liberal clássica,¹ direitos fundamentais são “destinados, em primeira instância, a proteger a esfera de liberdade do indivíduo contra intervenções dos Poderes Públicos; eles são direitos de defesa do cidadão contra o Estado”.² Direitos de defesa do cidadão contra o Estado são direitos a ações *negativas* (abstenções) do Estado.³ Eles pertencem ao status negativo, mais precisamente ao status negativo em sentido amplo.⁴ Seu contraponto são os direitos a uma ação *positiva* do Estado, que pertencem ao status positivo, mais precisamente ao status positivo em sentido estrito.⁵ Se se adota um conceito amplo de prestação, todos os direitos a uma ação estatal positiva podem ser classificados como direitos a prestações estatais em um sentido mais amplo; de forma abreviada: como direitos a prestações em sentido amplo. Saber se e em que medida se deve atribuir⁶ aos dispositivos de direitos fundamentais normas que garantam direitos a prestações em sentido amplo é uma das questões mais polêmicas da atual dogmática dos direitos fundamentais. Especialmente intensa é a discussão sobre os assim chamados direitos fundamen-

1. Cf. a respeito Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, pp. 163 e ss.

2. *BVerfGE* 7, 198 (204).

3. Cf. Capítulo 4, II.1.1.1.1.

4. Sobre essa qualificação, cf. Capítulo 5, I.3.

5. Cf. Capítulo 5, I.3.

6. Sobre o conceito de atribuição, cf. Capítulo 2, II.2.

tais sociais, como, por exemplo, direitos à assistência social, ao trabalho, à moradia e à educação. Como será demonstrado, esses direitos constituem, de fato, uma importante parte daquilo que é denominado "direitos a prestações", mas o âmbito desses direitos a prestações é mais amplo.

1. O texto constitucional e a história de sua elaboração

A Constituição alemã é bastante cautelosa ao formular direitos a prestações. Nesse sentido, ela claramente se aparta de uma série de Constituições dos Estados-membros, nas quais, ao lado dos direitos de defesa clássicos, podem ser encontrados direitos como o direito ao trabalho,⁷ o direito à moradia,⁸ o direito a meios de subsistência,⁹ o direito à educação¹⁰ e o direito à participação;¹¹⁻¹² e ela também se aparta de Constituições de outros países.¹³ Baseando-se apenas no texto da Constituição alemã, é possível encontrar como formulação explícita de um direito fundamental social no sentido de um direito

7. Art. 166 da Constituição da Baviera; art. 12 da Constituição de Berlim; art. 8 da Constituição de Bremen; art. 28 da Constituição de Hessen; art. 24 da Constituição da Renânia Setentrional-Vestfália; art. 53 da Constituição da Renânia-Palatinado; art. 45 da Constituição do Sarre.

8. Art. 106 da Constituição da Baviera; art. 19 da Constituição de Berlim; art. 14 da Constituição de Bremen.

9. Art. 168 da Constituição da Baviera; art. 14 da Constituição de Berlim; art. 58 da Constituição de Bremen; art. 28 da Constituição de Hessen.

10. Art. 11 da Constituição de Baden-Württemberg; art. 128 da Constituição da Baviera; art. 27 da Constituição de Bremen; art. 8 da Constituição da Renânia Setentrional-Vestfália.

11. Art. 175 da Constituição da Baviera; art. 17 da Constituição de Berlim; art. 47 da Constituição de Bremen; art. 37 da Constituição de Hessen; art. 26 da Constituição da Renânia Setentrional-Vestfália; art. 67 da Constituição da Renânia-Palatinado.

12. Cf., sobre a questão, Hans Friedrich Zacher, *Sozialpolitik und Menschenrechte in der Bundesrepublik Deutschland*, München/Wien: Olzog, 1968, pp. 11 e ss.

13. Catálogos de direitos a ações estatais positivas são encontrados tanto em constituições de países industrializados ocidentais (cf. a Constituição da República Italiana, de 27.12.1947), quanto em Constituições de países socialistas (cf. a Constituição da Alemanha Oriental, de 6.4.1968), quanto em constituições de países do terceiro mundo (cf. a Constituição da Índia, de 26.11.1949, reproduzida em *JÖR N.F.* 4 (1955), pp. 183-254).

subjetivo a uma prestação apenas o direito da mãe à proteção e à assistência da comunidade (art. 6º, § 4º, da Constituição alemã).¹⁴ Nesse sentido, uma interpretação dos direitos fundamentais da Constituição alemã que pretenda fundamentar direitos subjetivos a prestações no nível constitucional está obrigada a atribuir tais normas a dispositivos que não expressam normas que garantem direitos subjetivos a prestações.

A renúncia consciente do legislador constituinte à formulação de normas garantidoras de direitos subjetivos a prestações¹⁵ é, no entanto, apenas um lado da questão. O outro consiste na possibilidade de encontrar na Constituição uma série de pontos de apoio, formulados de forma *objetiva*, para uma interpretação orientada a direitos a prestações. Em primeiro lugar devem ser mencionadas “a obrigação de todos os poderes estatais” de “proteger” a dignidade humana (art. 1º, § 1º, 2, da Constituição alemã) e a cláusula do Estado Social (art. 20, § 1º, e art. 28, § 1º, 1). Além disso, são também dignos de menção a garantia de proteção ao matrimônio e à família (art. 6º, § 1º) e o mandamento constitucional no sentido de equiparação de filhos ilegítimos (art. 6º, § 5º). Contudo, esses dispositivos – tanto quanto a possibilidade de que o enunciado geral da igualdade fundamente direitos derivados a prestações, além de poder ser interpretada como um princípio da igualdade fática, o qual, em casos especiais também pode fundamentar direitos originários a prestações¹⁶ – não podem ocultar o fato de que a Constituição, a partir de seu texto e da história de sua elaboração, tem caráter de uma Constituição de um Estado de Direito burguês, precipuamente orientada por direitos de defesa.

2. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal

Isso não impediu o debate sobre os direitos a prestações sob a Constituição alemã. Essa discussão recebeu impulsos fundamentais

14. Cf. BVerfGE 55, 154 (157-158).

15. Cf. JöR N.F. I (1951), pp. 54 e ss.; Hermann v. Mangoldt, “Grundrechte und Grundsatzfragen des Bonner Grundgesetzes”, AöR 75 (1949), pp. 275-276; Werner Weber, “Die verfassungsrechtlichen Grenzen sozialstaatlicher Forderung”, Der Staat 4 (1965), pp. 411 e ss.

16. Cf. Capítulo 8, VI.3.

por meio da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Para o problema dos direitos subjetivos a prestações são particularmente interessantes as decisões nas quais se faz menção não somente a um dever objetivo do Estado – o que ocorre com frequência –, mas também a direitos subjetivos a ações positivas. Três decisões devem necessariamente ser mencionadas: a decisão acerca da assistência social, de 1951; a primeira decisão sobre *numerus clausus*; e a decisão sobre a Lei Provisória sobre o Ensino Superior Integrado na Baixa Saxônia.

Na decisão sobre a assistência social o tribunal manifestou-se, ao mesmo tempo, de forma cautelosa e ambígua. De início afirma-se que o art. 1º, § 1º, da Constituição alemã não obriga o Estado à proteção contra necessidades materiais e que o art. 2º, § 2º, 1, não outorga ao indivíduo um direito fundamental a uma assistência correspondente por meio do Estado. Logo após, contudo, o tribunal salienta que com isso não se pretende dizer “que o indivíduo não tem nenhum direito constitucionalmente garantido à assistência”. Ainda que, em geral, ao dever do legislador de “realização do Estado Social” não correspondam direitos subjetivos, se “o legislador se abstém arbitrariamente, isto é, sem razões objetivas, de realizar esse dever, daí poderia surgir para o indivíduo uma pretensão, assegurável por meio de reclamação constitucional”.¹⁷ Um claro passo adiante foi dado pelo tribunal em uma decisão de 1975, na qual ele afirma: “[c]laro que a assistência aos necessitados é um dos deveres inquestionáveis do Estado Social. Isso necessariamente inclui o auxílio social aos cidadãos que, em virtude de fragilidades físicas ou psíquicas, enfrentam obstáculos para o seu desenvolvimento pessoal e social, e não estão em condições de se sustentar sozinhos. A comunidade estatal tem que lhes garantir no mínimo as condições básicas para uma existência humana digna (...)”.¹⁸ Se se consideram ambas as decisões em conjunto, não há dúvidas de que o Tribunal Constitucional Federal pressupõe um direito fundamental a um mínimo existencial. Nesse sentido, ele acompanha a jurisprudência reiterada do Tribunal Administrativo¹⁹ e a opinião majoritária na literatura jurídica.²⁰ Diante disso, é possível afirmar que existe ao

17. BVerfGE 1, 97 (104-105).

18. BVerfGE 40, 121 (133).

19. BVerwGE 1, 159 (161-162); 5, 27 (31); 27, 58 (63); 52, 339 (346).

20. Cf., por exemplo, Günter Dürig, “Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde”, in AöR 81 (1956), pp. 131-132; do mesmo autor, “Art. 1 Abs. 1”, in Theodor

menos um direito fundamental social não-escrito, isto é, que se funda em uma norma atribuída por meio de interpretação a um dispositivo de direito fundamental. Já se afirmou que “seria perder tempo querer iniciar uma polêmica dogmática a partir desse exemplo”.²¹ Se com isso se pretendeu dizer que o direito ao mínimo existencial é dogmaticamente desinteressante, então, não há como concordar com a afirmação. Não é nenhuma obviedade que, sob uma Constituição que não o garante expressamente, a existência de um direito subjetivo ao mínimo existencial, em nível constitucional, seja maciçamente sustentada pela jurisprudência e pela doutrina. Contudo, seria um conclusão equivocada inferir automaticamente outros direitos a prestações a partir desse exemplo. Embora a existência de *um* direito a prestação, corretamente atribuído a dispositivos constitucionais, implique a rejeição da tese segundo a qual não se pode atribuir *nenhum* direito a prestações a esses dispositivos, daí não decorre que a esses dispositivos possam ser atribuídos *outros* direitos a prestações.

Com o segundo exemplo, a primeira decisão sobre *numerus clausus*, adentra-se um campo extremamente polêmico.²² Nessa decisão o tribunal diferencia entre dois direitos: um direito – como o tribunal o denomina – à “participação” nas instituições de ensino existentes e um direito à criação de novas vagas universitárias. Por enquanto a análise limitar-se-á ao primeiro deles. O tribunal fundamenta esse direito no enunciado da igualdade, em conjunto com o art. 12, § 1º, e com o princípio do Estado Social, bem como na constatação de que o

Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, §§ 43-44, e “Art. 2 Abs. 2”, § 27; Josef M. Wintrich, *Zur Problematik der Grundrechte*, Köln: Westdeutscher Verlag, 1957, p. 19; Christian Starck, “Staatliche Organisation und staatliche Finanzierung als Hilfen zur Grundrechtsverwirklichungen”, in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, 2, Tübingen: Mohr, 1976, p. 522; Rüdiger Breuer, “Grundrechte als Anspruchsnormen”, in Otto Bachof *et al.* (Orgs.), *Verwaltungsrecht zwischen Freiheit, Teilhabe und Bindung*, pp. 95 e ss.

21. Hans Hugo Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, p. 90 (nota 73), fazendo referência a Günter Dürig, “Art 2 Abs. 2”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 26.

22. Cf. as referências bibliográficas reunidas pelo Tribunal Constitucional Federal em *BVerfGE* 43, 291 (314-315); cf. também Fritz Ossenbühl, “Die Interpretation der Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, *NJW* 29 (1976), pp. 2104-2105; Rüdiger Breuer, “Grundrechte als Anspruchsnormen”, p. 112; Gunnar F. Schuppert, *Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation*, Königstein/Ts.: Athenäum, 1980, pp. 10 e ss.

Estado tomou para si “um monopólio fático, não afastável por pura vontade”, na formação para as profissões acadêmicas, a qual é, “por sua vez, pressuposto necessário para a realização de direitos fundamentais”.²³ Importante para a teoria dos direitos a prestações é, antes de mais nada, que dentre os três dispositivos constitucionais nos quais o tribunal se baseia se encontra – e não poderia ser diferente – um direito de liberdade – formulado pelo art. 12, § 1º – que é imprescindível para garantir o resultado da decisão. Sem uma referência à liberdade de escolha da instituição de ensino e da profissão ficaria de fora uma peça importante da fundamentação do dever de uma utilização exaustiva da capacidade das instituições de ensino.²⁴ Em si mesmo considerado, o enunciado da igualdade, ao menos em sua interpretação como proibição de arbítrio, é compatível também com uma utilização não exaustiva dessa capacidade.²⁵ Nesse sentido, o direito à livre escolha do estabelecimento de ensino e da profissão tem um peso decisivo contra argumentos que podem ser utilizados para justificar um tratamento desigual, como, por exemplo, argumentos ligados à eficiência. Em relação ao princípio do Estado Social, é de se duvidar se ele, isoladamente considerado ou combinado com o enunciado da igualdade, garante um direito à educação para uma carreira acadêmica. É significativa a utilização de um direito de liberdade na fundamentação do tribunal, porque essa utilização pressupõe que o direito de liberdade não tenha sido interpretado apenas como direito de defesa. Apenas como direito de defesa, ele em nada teria como auxiliar a fundamentação. Ele se torna uma parte fundamental da fundamentação apenas quando passa a se referir aos “pressupostos necessários para a realização” do direito de liberdade,²⁶ ou seja, quando interpretado como uma garantia de uma parte da liberdade fática, o que o tribunal fundamenta, entre outras, com as seguintes palavras: “o direito

23. BVerfGE 33, 303 (331-332).

24. BVerfGE 33, 303 (338); de forma reforçada, cf. BVerfGE 43, 291 (326).

25. Sobre isso, cf., com mais detalhes, Rüdiger Breuer, “Grundrechte als Anspruchsnormen”, pp. 115 e ss.; Gunnar F. Schuppert, *Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation*, p. 25. Não é possível seguir a concepção de que um recurso ao enunciado geral da igualdade teria sido suficiente (cf. Ernst Friesenhahn, “Der Wandel des Grundrechtsverständnisses”, in *Verhandlungen des fünfzigsten Deutschen Juristentages*, v. II, p. G32; Fritz Ossenbühl, “Die Interpretation der Grundrechte in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts”, p. 2.104).

26. BVerfGE 33, 303 (337).

de liberdade não teria valor sem os pressupostos fáticos para o seu exercício".²⁷ Com isso, no entanto, abre-se uma nova dimensão na fundamentação de direitos atribuídos.

Em relação ao direito à participação nas possibilidades de ensino existentes as consequências são relativamente pequenas. A questão fica mais interessante no caso de um direito à criação de novas vagas universitárias. Em sua decisão de 8.2.1977²⁸ o tribunal diferencia, de forma mais clara que na primeira decisão sobre *numerus clausus*, entre um direito abstrato, "garantido constitucionalmente ao cidadão que preencha os pressupostos subjetivos de admissão (...), a ser admitido no curso universitário de sua escolha", direito, este, submetido "à reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade";²⁹ e uma "pretensão individual [concreta] e justificável do cidadão a uma ampliação da capacidade das instituições universitárias".³⁰ Sob a luz da teoria dos princípios, o primeiro direito é facilmente reconhecível como um direito *prima facie*, que se torna definitivo somente se outras razões colidentes não exigirem o contrário.³¹ Isso é expresso de forma precisa pelo tribunal quando afirma que a todo cidadão que tenha concluído o ensino médio é conferido, "em si", ou seja, antes de se levar em consideração as restritas possibilidades jurídicas e fáticas, um direito à admissão em um curso superior de sua escolha.³² Já o segundo direito tem um caráter de direito *definitivo*. O tribunal deixa expressamente aberta a questão sobre "se e sob quais pressupostos" o direito *prima facie* pode "eventualmente" se tornar um direito definitivo.³³ Mas, na medida em que sustenta a existência de um direito *prima facie* e que a possibilidade de um direito definitivo não é excluída, o tribunal, de forma exemplar, deixou a porta aberta para a atribuição de direitos a prestações.

Um caráter muito diferente tem o direito subjetivo a medidas estatais de caráter organizacional, atribuído, na decisão sobre o ensino universitário, ao art. 5º, § 3º, da Constituição alemã. Nessa decisão

27. BVerfGE 33, 303 (331).

28. BVerfGE 43, 291.

29. BVerfGE 43, 291 (313-314); pela primeira vez em BVerfGE 33, 303 (333).

30. BVerfGE 43, 291 (315); 33, 303 (333).

31. Cf. Capítulo 3, I.5.

32. BVerfGE 43, 291 (315).

33. BVerfGE 43, 291 (315, 325); 33, 303 (333).

afirmou-se que: “[a]o indivíduo titular do direito fundamental do art. 5º, § 3º, surge, a partir de uma decisão valorativa, um direito àquelas medidas estatais, também de caráter organizacional, que sejam imprescindíveis para a proteção de sua esfera de liberdade constitucionalmente protegida, porque só a partir dessas medidas é que se torna possível a atividade científica livre. Se não fosse assim, o efeito protetor da norma fundamental e de suas decisões axiológicas seria em grande parte desconsiderado. Essa capacidade do titular individual do direito fundamental de poder exigir, contra os poderes públicos, o respeito às decisões axiológicas da norma fundamental faz parte do conteúdo do direito fundamental individual, cuja efetividade fica desse modo reforçada”.³⁴ O direito a medidas estatais de caráter organizacional é um direito à criação de determinadas normas jurídicas. Com isso, surge um novo aspecto no círculo dos direitos a prestações: o direito a prestações normativas.³⁵

3. *A polêmica sobre os direitos a prestações e sua natureza*

As manifestações relevantes do Tribunal Constitucional Federal sobre direitos a prestações estão longe de se esgotar com essas três decisões citadas. Mas elas fazem com que fique claro que sua jurisprudência oferece pontos de apoio para a discussão sobre os direitos a prestações na Constituição alemã que são muito mais ricos que aqueles presentes apenas no texto constitucional ou na história de sua elaboração. Se se inclui o tribunal como um participante dessa discussão, então, é possível afirmar que ele ocupa uma posição intermediária no espectro de pontos de vista, que se estende desde uma rejeição total – “direitos fundamentais não *[podem]* ser as duas coisas ao mesmo tempo (...): pretensões à ação estatal e à sua negação”³⁶ – até uma enfática aceitação – “[e]m uma sociedade industrial extremamente

34. BVerfGE 35, 79 (116). Para uma crítica ao reconhecimento de um tal direito subjetivo, cf. sobretudo o voto divergente dos Juízes Simon e Rupp-von Brünneck, BVerfGE 35, 148 (155).

35. Cf. Capítulo 4, II.1.1.2.

36. Hans Hugo Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, p. 65.

complexa, os direitos fundamentais ou são direitos à participação ou eles não são nada".³⁷

A polêmica sobre os direitos a prestações é marcada por uma profunda divergência de opiniões acerca da natureza e da função do Estado, do Direito e da Constituição – e também dos direitos fundamentais³⁸ –, bem como acerca da percepção da atual situação da sociedade. Visto que essa polêmica se relaciona, entre outros, a problemas distributivos, seu “caráter politicamente explosivo”³⁹ é facilmente compreensível. Em quase nenhuma área a conexão entre o efeito jurídico e as valorações práticas gerais ou políticas é tão clara, em quase nenhum campo a polêmica é tão tenaz. Diante disso, é natural que se fale, de forma crítica ou favorável, de uma “mudança na compreensão dos direitos fundamentais”⁴⁰ e que se clame por uma “desdemonização, uma desideologização e uma desemocionalização do conceito de direitos fundamentais sociais”.⁴¹ A isso se soma uma segunda peculiaridade. Na polêmica acerca dos direitos a prestações um acordo é dificultado não apenas em razão de concepções fundamentais diversas, mas também em virtude de obscuridades conceituais e dogmáticas fundamentais, caracterizadas, entre outras coisas, por um caos terminológico frequentemente criticado.

No que diz respeito ao problema conceitual/terminológico, as considerações a seguir serão feitas no âmbito de uma divisão tripla dos direitos a prestações; no que concerne ao problema da existência e do conteúdo dos direitos a prestações, essas considerações baseiam-se em uma única idéia condutora formal. Ambas serão apresentadas a seguir.

37. Helmut Willke, *Stand und Kritik der neueren Grundrechtstheorie*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, p. 216.

38. Cf. Peter Badura, “Das Prinzip der sozialen Grundrechte und seine Verwirklichung im Recht der Bundesrepublik Deutschland”, *Der Staat* 14 (1975), p. 17.

39. Cf. Walter Schmidt, “Soziale Grundrechte im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland”, *Der Staat*, Beiheft 5 (1981), p. 12.

40. Cf., por todos, Ernst Friesenhahn, “Der Wandel des Grundrechtsverständnisses”, p. G1 e ss.; Peter Saladin, *Grundrechte im Wandel*, 2ª ed., Bern: Stämpfli, 1975; Hans H. Rupp, “Vom Wandel der Grundrechte”, *AöR* 101 (1976), pp. 161 e ss.

41. Luzius Wildhaber, “Soziale Grundrechte”, in Peter Saladin *et al.* (Orgs.), *Der Staat als Aufgabe: Gedenkschrift für Max Imboden*, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1972, p. 390.

4. Conceito e divisão dos direitos a prestações

Aqui, e como já mencionado, o conceito de direito a prestações será compreendido de forma ampla. Todo direito a uma ação positiva, ou seja, a uma ação do Estado, é um direito a uma prestação. Nesse sentido, o conceito de direito a prestações é exatamente o oposto do conceito de direito de defesa, no qual se incluem todos os direitos a uma ação negativa, ou seja, a uma abstenção estatal.

A escala de ações estatais positivas que podem ser objeto de um direito a prestação estende-se desde a proteção do cidadão contra outros cidadãos por meio de normas de direito penal, passa pelo estabelecimento de normas organizacionais e procedimentais e alcança até prestações em dinheiro e outros bens. Esse conceito de direito a prestações é mais amplo que o usual.⁴² Na maioria das vezes a expressão "direito a prestações" é associada à idéia de um direito a algo que o titular do direito poderia obter de outras pessoas privadas se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse no mercado uma oferta também suficiente. No entanto, há dois motivos decisivos para estender o conceito de direito a prestações, para além desses direitos a prestações fáticas, também aos direitos a prestações normativas,⁴³ como a proteção por meio de normas de direito penal ou a criação de normas organizacionais e procedimentais.⁴⁴

O primeiro motivo consiste no fato de que, no caso de muitos dos assim chamados direitos fundamentais sociais, que são considerados direitos a prestações por excelência, há um feixe de posições que dizem respeito em parte a prestações fáticas e em parte a prestações

42. Isso não significa que a concepção ampla seja inteiramente impréstável. Nesse sentido, Scholz fala de "uma prestação estatal sob a forma de uma intervenção soberana contra terceiros como perturbadores (potenciais)" (Rupert Scholz, "Nichtraucher contra Raucher", *JuS* 16 (1976), p. 234). Sobre a proposta de uma concepção ampla do conceito de prestação no direito administrativo, cf. Erich Becker, "Verwaltung und Verwaltungsrechtsprechung", *VVDStRL* 14 (1956), p. 109; Gerd Beinhart, "Das Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in seinem Verhältnis zur Eingriffs- und Leistungsverwaltung", *DVBt* 76 (1961), pp. 612-613.

43. Sobre os conceitos de prestações fática e normativa, cf. Capítulo 4, II.1.1.2.

44. Em última instância, como em toda questão terminológica, trata-se de uma questão funcionalidade; cf. Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, III, 4ª ed., München: Beck, 1978, p. 181.

normativas. Especialmente claro é o caso do intensamente debatido direito ao meio ambiente,⁴⁵ que não raro é classificado como um direito fundamental social, ou ao menos como algo a ele próximo.⁴⁶ Uma análise mais detida demonstra que esse direito, não importa se introduzido como um novo direito fundamental no catálogo de direitos ou atribuído por interpretação a um dispositivo de direito fundamental existente, tem uma estrutura muito diferente daquela de um direito como o direito à assistência social, que essencialmente se esgota em um simples direito a uma prestação fática. Um direito fundamental ao meio ambiente corresponde mais àquilo que acima se denominou "direito fundamental completo".⁴⁷ Ele é formado por um feixe de posições de espécies bastante distintas. Assim, aquele que propõe a introdução de um direito fundamental ao meio ambiente, ou que pretende atribuí-lo por meio de interpretação a um dispositivo de direito fundamental existente, pode incorporar a esse feixe, dentre outros, um direito a que o Estado se abstenha de determinadas intervenções no meio ambiente (direito de defesa), um direito a que o Estado proteja o titular do direito fundamental contra intervenções de terceiros que sejam lesivas ao meio ambiente (direito a proteção), um direito a que o Estado inclua o titular do direito fundamental nos procedimentos relevantes para o meio ambiente (direito a procedimentos) e um direito a que o próprio Estado tome medidas fáticas benéficas ao meio ambiente (direito a prestação fática).⁴⁸ Além disso, as posições propostas ou alegadas podem dizer respeito a direitos *prima facie* ou a direitos definitivos. O mesmo vale para outros direitos suscitados por meio da utilização da expressão "direitos fundamentais sociais". Diante disso, é sintomático que Brunner fale de um "direito ao trabalho, com seus diversos direitos específicos, como a livre escolha da profissão, os direitos a um posto de trabalho, a um salário justo, a

45. Cf., por todos, Dietrich Rauschning, "Staatsaufgabe Umweltschutz", *VVDStRL* 38 (1980), pp. 167 e ss., com inúmeras referências adicionais.

46. Cf., por exemplo, Georg Brunner, *Die Problematik der sozialen Grundrechte*, Tübingen: Mohr, 1971, p. 12; Luzius Wildhaber, "Soziale Grundrechte", p. 375; Hans H. Klein, "Ein Grundrecht auf saubere Umwelt?", in Hans Schneider *et al.* (Orgs.), *Festschrift für Werner Weber*, Berlin: Duncker & Humblot, 1974; Peter Badura, "Das Prinzip der sozialen Grundrechte", p. 23.

47. Cf. Capítulo 4, III.

48. Sobre a complexa estrutura de um direito ao meio ambiente, cf. Heinhart Steiger, *Mensch und Umwelt*, Berlin: Schmidt, 1975, pp. 40 e ss.

condições de trabalho adequadas, à proteção em favor de determinados grupos de pessoas (mulheres, jovens), ao descanso, a benefícios em caso de desemprego, o direito de sindicalização e de greve, bem como o direito de co-gestão".⁴⁹ Mesmo que se retirem dessa lista os direitos de defesa, restam ainda direitos estruturalmente muito distintos. Para poder compreender por completo essa variedade e para poder contrapô-la sistematicamente aos direitos de defesa, é recomendável o emprego de um conceito amplo de direito a prestações.

O segundo motivo consiste no fato de que os direitos a ações positivas compartilham problemas com os quais os direitos a ações negativas não se deparam, ou pelo menos não com a mesma intensidade. Direitos a ações negativas impõem limites ao Estado na persecução de seus objetivos. Mas eles não dizem nada sobre que objetivos devem ser perseguidos. Direitos a ações positivas do Estado impõem ao Estado, em certa medida, a persecução de alguns objetivos. Por isso, todos os direitos a ações positivas suscitam o problema de se saber se e em que medida a persecução de objetivos estatais pode e deve estar vinculada a direitos constitucionais subjetivos dos cidadãos. Sob uma Constituição que submete os direitos garantidos constitucionalmente a um amplo controle judicial de constitucionalidade esse problema é, em essência, um problema de repartição de competências entre o tribunal constitucional e o legislador. O fato de esse problema ser extensível a todos os direitos a ações estatais positivas é uma razão decisiva para agrupar todos eles sob a rubrica "direitos a prestações". Os direitos a prestações fáticas, ou seja, a prestações que poderiam ser realizadas também por pessoas privadas, são, portanto, apenas uma parte dos direitos a prestações. Quando for relevante, far-se-á menção a *direitos a prestações em sentido estrito* e a *direitos a prestações em sentido amplo*.

Os direitos a prestações (em sentido amplo) podem ser divididos em três grupos: (1) direitos a proteção; (2) direitos a organização e procedimento; e (3) direitos a prestações em sentido estrito. Um detalhamento e um refinamento dessa divisão serão realizados quando da análise dos direitos pertencentes a cada um desses grupos.

49. Georg Brunner, *Die Problematik der sozialen Grundrechte*, p. 11.

Os direitos dessa natureza podem ser considerados direitos a prestações somente se se tratar de direitos *subjettivos* e de *nível constitucional*. Enquanto tais, eles devem ser distinguidos, de um lado, dos direitos subjettivos que não tenham nível constitucional e, de outro, dos direitos de nível constitucional que não outorguem direitos subjettivos e que, nesse sentido, podem ser denominados como "objetivos". Os direitos subjettivos de nível não-constitucional podem ou ser direitos subjettivos outorgados pelo direito infraconstitucional ou direitos morais, que se fundam não em normas jurídicas, mas em normas morais. No caso das normas que não outorgam direitos subjettivos, elas podem ser normas constitucionais, normas infraconstitucionais ou, ainda, normas morais. E é exatamente a discussão acerca dos direitos a prestações, especialmente dos direitos sociais, que dá ensejo a que se sublinhem essas diferenças, que não raro são desconsideradas, com prejuízo para a clareza e a precisão da argumentação. Ao se sublinhar as diferenças não se quer dizer, contudo, que não haja conexões entre os diversos grupos. É exatamente porque as conexões são estreitas que as diferenças devem ser mais claramente explicitadas. Essas conexões consistem sobretudo no fato de que, em face do conteúdo moral geralmente presente nas normas de direitos fundamentais, não é totalmente excluída a possibilidade de se atribuir aos dispositivos de direitos fundamentais, por meio de interpretação, direitos morais até então não reconhecidamente de nível constitucional, e também no fato de que toda norma objetiva que seja vantajosa para um sujeito de direito é, em princípio, uma candidata a uma subjettivização.

Enquanto direitos subjettivos, todos os direitos a prestações são relações triádicas entre um titular do direito fundamental, o Estado e uma ação estatal positiva. Se o titular do direito fundamental *a* tem um direito em face do Estado (*s*) a que o Estado realize a ação positiva *h*, então, o Estado tem, *em relação* a *a*, o dever de realizar *h*.⁵⁰ Sempre que houver uma relação constitucional desse tipo, entre um titular de direito fundamental e o Estado, o titular do direito fundamental tem a competência de exigir judicialmente esse direito. Isso é assim em razão do direito constitucional positivo, por força do art. 19, § 4º, 1, da Constituição alemã. Essa exigibilidade, caracterizada por

50. Sobre a equivalência entre *RasG* e *OsaG*, cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

Wolff como “perfeita”,⁵¹ é inteiramente compatível com a possibilidade de que os direitos a prestações, tanto quanto os direitos de defesa, tenham um caráter *prima facie*, ou seja, natureza de princípios. O direito de fazer ou deixar de fazer o que quiser não é um direito com menor grau de validade ou exigibilidade apenas em razão da possibilidade de que, ao final, ou seja, definitivamente, o indivíduo, em grande medida, não possa fazer ou deixar de fazer o que deseje. Esse direito, enquanto direito *prima facie*, é simplesmente um direito necessariamente restringível.

Se às normas que conferem um direito *prima facie* é acrescida uma cláusula de restrição, essas normas adquirem o caráter de normas que, embora carentes de concretização – que ocorre geralmente por meio de sopesamentos –, garantem direitos definitivos.⁵² Se o suporte fático for preenchido e a cláusula de restrição não for, o titular tem um direito definitivo. Natureza de princípio e exigibilidade perfeita são, portanto, compatíveis. Isso vale tanto para os direitos de defesa quanto para os direitos a prestações.

5. Idéia-guia

É possível recorrer a inúmeros e variados argumentos contra e a favor da atribuição de direitos a prestações a dispositivos de direitos fundamentais. É recomendável, por isso, apreciá-los a partir de uma idéia-guia. Uma possível perspectiva ou idéia-guia seria um conceito geral e formal de direitos fundamentais, que pode ser expresso da seguinte forma: direitos fundamentais são posições que são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples. Essa definição está sujeita a uma série de refinamentos. Um deles deve ser feito de imediato: aqui se trata dos direitos fundamentais da Constituição alemã, ou seja, de posições que, do ponto de vista do direito constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples. Por isso, pode-se dizer que os direitos fundamentais da Constituição alemã são posições que, do ponto de vista do direito

51. Cf. Hans J. Wolff/Otto Bachof, *Verwaltungsrecht*, I, § 40, p. 295.

52. Cf. Capítulo 3, II.3.3.

constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples.

A concepção formal de direitos fundamentais expressa um problema central dos direitos fundamentais em um Estado Democrático. Normas de direitos fundamentais que vinculam o Legislativo, como as da Constituição alemã, definem aquilo que o legislador legitimado democraticamente pode e aquilo que ele não pode decidir. Da perspectiva desse legislador, essas normas representam proibições e deveres que restringem sua liberdade e são, além disso, normas negativas de competência, que limitam suas competências.⁵³ Nesse sentido, há necessariamente uma colisão entre o princípio da democracia e os direitos fundamentais.⁵⁴ Essa colisão não é alterada pela existência de uma série de direitos fundamentais (por exemplo: o direito de voto e a liberdade de expressão) que são exigências da própria democracia; isso apenas demonstra que o princípio democrático deve ser dividido em diversos subprincípios que podem colidir entre si, o que, cabe aqui mencionar, é a base teórico-normativa do assim chamado paradoxo da democracia,⁵⁵ que se refere ao antigo problema da abolição democrática da democracia. A necessária colisão entre o princípio democrático e os direitos fundamentais significa que o problema da divisão de competências entre o legislador com legitimação democrática direta e responsabilidade – em razão da possibilidade de não-reeleição – e o tribunal constitucional apenas indiretamente legitimado democraticamente, e não destituível eleitoralmente, é um problema inevitável e permanente. De forma precisa, Ely classificou a solução para esse problema de “tarefa traiçoeira”.⁵⁶

Essas colisões e esses problemas de competência é que são levados em consideração pela concepção formal dos direitos fundamentais. A importância que uma posição tem que ter, a partir da perspectiva do direito constitucional, para que seja classificada como uma

53. Cf. Capítulo 4, II.3.6.2.

54. Cf. BVerfGE 56, 54 (81).

55. Cf. Karl R. Popper, *Die offene Gesellschaft und ihre Feinde*, I, 2ª ed., Bern: Francke, 1970, pp. 173 e 360; Helmut Steinberger, *Konzeption und Grenzen freiheitlicher Demokratie*, Berlin: Springer, 1974, pp. 196 e ss.

56. John H. Ely, *Democracy and Distrust*, pp. 7-8.

posição de direito fundamental não é uma importância considerada em si mesma, mas uma importância em relação aos princípios que militam a favor e contra essa qualificação da posição como uma posição de direito fundamental. Dentre esses princípios é sempre possível encontrar ao menos um princípio de direito fundamental que milite em favor da proteção da posição como posição de direito fundamental, e sempre também um princípio da democracia que milite a favor da manutenção o mais ampla possível da competência do legislador democraticamente legitimado. Se tudo o que fosse importante para o indivíduo na vida política fosse determinado pelos direitos fundamentais, ao legislador sobrariam apenas questões sem importância para decidir. Mas o princípio democrático exige que o legislador decida exatamente sobre aquilo que importa. O fato de os direitos a prestações estarem ligados a questões importantes – o que, a propósito, não é negado nem mesmo por aqueles que rejeitam sua inserção dentre os direitos de nível constitucional – não é, portanto, uma razão suficiente para conferir a eles o nível de direitos fundamentais. A questão consiste em saber se e em que medida eles são, do ponto de vista do direito constitucional, tão importantes que a decisão sobre eles não possa ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples.

Essa concepção de direitos fundamentais tem natureza formal. Representantes das mais diferentes concepções substanciais podem concordar com ela. Quem com ela concorda e, ao mesmo tempo, rejeita por completo direitos a prestações em nível constitucional parte do pressuposto de que esses direitos não são tão importantes a ponto de a decisão sobre eles não poder ser deixada para a maioria. Quem com ela concorda e, ao mesmo tempo, aceita de forma ampla direitos a prestações em nível constitucional parte do pressuposto contrário.

Seria possível argumentar que isso tudo não significa muita coisa, porque a concepção baseada na importância seria inadequada. O que interessaria não seria apenas a importância relativa; decisiva seria a necessidade real de uma ancoragem constitucional dos direitos a prestações. Os direitos de liberdade estariam sempre em perigo, razão pela qual sua ancoragem constitucional como direitos exigíveis perfeitos seria necessária. Já o Estado Democrático industrial é caracterizado por uma tendência crescente das prestações estatais. Nele, os direitos a prestações não estariam em perigo. Por mais importantes que sejam, não haveria uma necessidade de uma ancoragem constitu-

cional. A fragilidade desse argumento reside no fato de que a satisfação de um direito nada diz acerca de sua existência. Um direito fundamental que seja satisfeito em todas as situações e em todos os sentidos ainda assim tem um significado sistemático. Aquele que quiser obter uma imagem completa dos direitos fundamentais não pode deixar um deles de lado apenas porque ele já foi satisfeito. Como a satisfação de um direito fundamental frequentemente implica a não-satisfação parcial de outro direito fundamental, o direito fundamental satisfeito continua a ter importância como um fundamento constitucional dessa não-satisfação. Mas, acima de tudo, é possível afirmar que da satisfação de um direito no passado ou no presente não se pode inferir sua satisfação no futuro. Se não houvesse direitos fundamentais, o legislador teria uma parcela de competência que ele não tem quando esses direitos existem. Como ninguém conhece o legislador futuro e também as circunstâncias sob as quais ele agirá, ninguém pode ter certeza de que ele não utilizará – diferentemente do que ocorreu no passado e no presente – aquelas liberdades e competências de forma desfavorável aos indivíduos.

Tão simples quanto facilmente refutável é a objeção segundo a qual o conceito de importância, na fórmula apresentada acima, seria completamente indeterminado. Essa não é uma deficiência da fórmula, mas pressuposto de sua adequação como idéia-guia. A concepção formal pode e deve ser preenchida por meio de concepções substanciais.

A concepção apresentada é uma concepção básica ampla e *formal*. A seu lado pode coexistir uma concepção básica ampla e *substancial*. Sob a Constituição alemã essa concepção ampla e substancial é determinada pelo conceito de dignidade humana.⁵⁷ Não há grande necessidade de se mencionar que não é possível derivar enunciados concretos de direitos fundamentais apenas da concepção básica formal ou apenas da concepção básica substancial, ou de uma simples conexão entre ambas. Tanto o preenchimento da concepção formal quanto a explicação da concepção substancial são tarefas de uma argumentação jurídico-constitucional substancial. Aqui interessa apenas a importância da concepção básica formal. Ela consiste no fato de que toda concepção substancial dos direitos a prestações inclui uma resposta à

57. Basta mencionar, da jurisprudência, a decisão *BVerfGE* 5, 85 (204); da literatura, basta Günter Dürig, "Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde", p. 119.

questão de se saber se as posições de direitos a prestações em análise são, ou não, do ponto de vista do direito constitucional, tão importantes que a decisão sobre elas não possa ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples. No âmbito desse questionamento, a concepção básica substancial ganha relevância.

A concepção formal subjaz a todos os direitos fundamentais. Para os direitos a prestações, em razão de sua natureza controversa, ela tem uma importância especial. Com base nela é possível estabelecer o seguinte enunciado geral sobre os direitos a prestações:

- (L) Em virtude de normas de direitos fundamentais, todos encontram-se em posições de direitos a prestações que são, do ponto de vista do direito constitucional, tão importantes que a decisão sobre elas não possa ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples.

Esse enunciado expressa um *direito geral a prestações*.

II – DIREITOS A PROTEÇÃO

1. Sobre o conceito de direito a proteção

Por “direitos a proteção” devem ser aqui entendidos os direitos do titular de direitos fundamentais em face do Estado a que este o proteja contra intervenções de terceiros. Direitos a proteção podem ter os mais diferentes objetos. Desde a proteção contra homicídios na forma mais tradicional, até a proteção contra os perigos do uso pacífico da energia nuclear. Não são apenas a vida e a saúde os bens passíveis de serem protegidos, mas tudo aquilo que seja digno de proteção a partir do ponto de vista dos direitos fundamentais: por exemplo, a dignidade, a liberdade, a família e a propriedade. Não menos diversificadas são as possíveis formas de proteção. Elas abarcam, por exemplo, a proteção por meio de normas de direito penal, por meio de normas de responsabilidade civil, por meio de normas de direito processual, por meio de atos administrativos e por meio de ações fáticas. O que há de comum em meio a essa diversidade é o fato de que os direitos a proteção são direitos subjetivos constitucionais a ações po-

sitivas fáticas ou normativas em face do Estado, que têm como objeto demarcar as esferas dos sujeitos de direito de mesma hierarquia, bem como a exigibilidade e a realização dessa demarcação. A delimitação das esferas dos sujeitos de direito de mesma hierarquia, bem como a garantia da exigibilidade e da realização dessa demarcação, é uma das tarefas clássicas da ordem jurídica. A conhecida formulação de Kant tem-na como objeto: "o direito é, portanto, o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode ser conciliado com o arbítrio do outro, de acordo com uma lei geral de liberdade".⁵⁸ Direitos a proteção são, nesse sentido, direitos constitucionais a que o Estado configure e aplique a ordem jurídica de uma determinada maneira no que diz respeito à relação dos sujeitos de direito de mesma hierarquia entre si.

Uma análise dos direitos a proteção deve levar em consideração três problemas intimamente relacionados: a existência, a estrutura e a justiciabilidade desses direitos. Esses problemas ficam mais claros quando os direitos a proteção têm o legislador como destinatário. Por isso, os direitos a proteção dirigidos ao legislador ficarão em primeiro plano na discussão que segue.

2. A existência de direitos a proteção

O problema da existência tem um aspecto substancial e um aspecto estrutural. O aspecto substancial diz respeito ao que deve ser protegido e como o deve. Fornecer respostas a essa pergunta é uma tarefa da dogmática de cada um dos direitos fundamentais. Aqui interessa sobretudo o aspecto estrutural, que, à luz do problema da existência, pode ser dividido em duas questões. A primeira diz respeito a saber se existem direitos subjetivos a proteção ou apenas normas que prescrevem que o Estado proteja os indivíduos, sem a eles conferir um direito subjetivo. Essa questão diz respeito, portanto, ao conhecido problema: direito *subjetivo* ou (mera) norma *objetiva*. A segunda questão é: caso os direitos a proteção existam, sua natureza é, de fato, distinta da dos direitos de defesa de tipo clássico? Essa questão diz respeito à distinção entre *direitos de defesa* e *direitos a proteção*.

58. Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, p. 230.

2.1 Direito subjetivo ou (mera) norma objetiva

A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal não é muito clara em relação à alternativa direito subjetivo ou (mera) norma objetiva. O tribunal prefere formulações e construções objetivas. Na decisão sobre o aborto ele deixa em aberto a titularidade de direitos fundamentais por parte do nascituro e escolhe uma solução objetiva em vez de uma subjetiva.⁵⁹ Na decisão do caso Schleyer fala-se exclusivamente em dever do Estado, e não em direitos do indivíduo a proteção.⁶⁰ Na decisão do caso Kalkar distingue-se entre direitos fundamentais e “deveres jurídico-objetivos de proteção, que podem ser derivados da ordem de direitos fundamentais”,⁶¹ o que é repetido na decisão Mülheim-Kärlich, considerada como uma continuação da linha aborto/Schleyer/Kalkar.⁶² Mas a tendência objetiva, que fica clara nessas quatro decisões, é apenas um lado da questão. Na decisão sobre o aborto, no contexto de um sopesamento, fala-se em um “direito do nascituro”.⁶³ Na decisão do caso Schleyer é feita uma distinção entre um “dever de proteção (...) *em face* do indivíduo” e um dever de proteção “*em face* da totalidade dos cidadãos”.⁶⁴ Se, como parece plausível, o primeiro é compreendido como um dever relacional,⁶⁵ então, ao dever do Estado corresponde um direito do indivíduo.⁶⁶ Extremamente carente de interpretação é a tese suscitada na decisão Kalkar, segundo a qual das garantias de direitos fundamentais poderiam decorrer deveres “que exigissem uma regulação legal configurada de tal forma que também os riscos de violações a direitos fundamentais sejam reprimidos”.⁶⁷ Com essa fórmula o tribunal parece pressupor a possibilidade de violações a direitos fundamentais cometidas por terceiros em igual hierarquia. Mas isso é possível apenas se entre iguais existem relações de direitos fundamentais caracterizadas pela possibilidade de que terceiros sejam destinatários de direitos fundamentais, o que

59. BVerfGE 39, 1 (41 e ss.).

60. BVerfGE 46, 160 (164-165).

61. BVerfGE 49, 89 (140).

62. BVerfGE 53, 30 (57). Cf. também BVerfGE 56, 54 (73).

63. BVerfGE 39, 1 (50).

64. BVerfGE 46, 160 (165) – sem grifos no original.

65. Sobre esse conceito, cf. Capítulo 4, I.1.2.2.

66. Essa correspondência decorre da lei RabG ↔ ObaG.

67. BVerfGE 49, 89 (142).

é uma tese forte e problemática no âmbito dos efeitos dos direitos fundamentais perante terceiros.⁶⁸ Muito mais fraca e, por isso, menos problemática é a tese segundo a qual o indivíduo tem, em face do Estado, um direito fundamental à proteção contra terceiros. Seria, então, possível falar de uma violação a direito fundamental por parte do Estado, que surge quando ele não cumpre de forma suficiente seu dever de proteção. Mas isso significaria uma subjetivização do dever de proteção. Na decisão Mülheim-Kärlich essa subjetivização é inevitável, pois esse caso dizia respeito a uma reclamação constitucional, que só pode se basear em uma violação de direitos. Se se pretende abrir mão da construção – artificial e dogmaticamente duvidosa – que considera que a violação do dever de proteger a vida e a saúde – decorrente do art. 2º, § 2º – deve ser controlada, nos termos do art. 2º, § 1º, sob o aspecto de uma lesão à ordem constitucional, então, a única alternativa é atribuir um direito de proteção, correspondente àquele dever, ao art. 2º, § 2º, da Constituição alemã.

Os exemplos fazem com que fique claro que, a despeito da tendência objetiva, na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal também podem ser percebidas indicações claras no sentido de uma interpretação subjetiva.⁶⁹ Resta indagar se é possível encontrar fundamentos melhores para a atribuição ou para a não-atribuição de direitos subjetivos a proteção. Para responder a essa questão é conveniente dar uma olhada nos casos em que a existência de um dever de proteção é certa e que, portanto, as dúvidas só podem dizer respeito à sua subjetivização. Um exemplo desse tipo de caso, corretamente caracterizado pelos juízes divergentes no caso do aborto como “acadêmico”,⁷⁰ é a proteção estatal ao indivíduo contra homicídio. Não há dúvidas de que o Estado tem o dever de proteger o indivíduo contra homicídio. Também não parece haver dúvidas de que o Estado tem o dever de levar

68. Sobre os efeitos dos direitos fundamentais perante terceiros, cf. Capítulo 10, II.2.

69. Em relação à jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal é possível afirmar, portanto, que o problema da subjetivização dos deveres de proteção ainda está em aberto. Para uma análise do problema da subjetivização na literatura, cf. Eberhard Schmidt-Aßmann, “Anwendungsprobleme des Art. 2 Abs. 2 GG im Immisionsschutzrecht”, *AöR* 106 (1981), pp. 214 e ss.; Josef Isensee, *Das Grundrecht auf Sicherheit*, Berlin: de Gruyter, 1983.

70. *BVerfGE* 39, 1 (78).

isso a cabo, dentre outras, por meio de proibições de direito penal e da imposição de sanções. O que se pergunta é se o indivíduo tem um direito subjetivo constitucional a essa proteção, e como esse direito deve ser fundamentado. Duas construções dogmáticas podem ser suscitadas. A primeira está associada ao dever estatal de proteger a dignidade humana, previsto pelo art. 1º, § 1º, 1, da Constituição alemã, e transfere o dever de proteção aos direitos fundamentais subsequentes.⁷¹ A vantagem dessa construção reside no fato de ela se apoiar diretamente no texto constitucional; sua desvantagem, no fato de que ela se vê diante do dilema de ou ampliar de forma extrema o conceito de dignidade humana, para poder abarcar tudo aquilo que seja digno de proteção, o que implica o sempre suscitado risco de trivializar a dignidade humana, ou renunciar a abarcar algumas coisas dignas de proteção. A segunda construção utiliza o argumento da dignidade humana apenas marginalmente e se apóia diretamente nos direitos fundamentais específicos. Essa construção, preferida pelo Tribunal Constitucional Federal,⁷² pressupõe que os direitos fundamentais sejam mais que direitos de defesa contra intervenções estatais. O tribunal faz referência ao "conteúdo jurídico-objetivo" dos direitos fundamentais⁷³ e à "ordem objetiva de valores" que os direitos fundamentais representam.⁷⁴ Com tudo isso, no entanto, ainda nada se disse acerca da questão que aqui interessa: se aos deveres objetivos de proteção correspondem direitos subjetivos. Mas o conceito de ordem de valores ao menos aponta na direção da solução. Acima estabeleceu-se que por meio da teoria dos princípios é possível formular uma teoria axiológica isenta de suposições insustentáveis.⁷⁵ O princípio da proteção da vida pode ser atribuído ao art. 2º, § 2º, 1, da Constituição alemã. Como todo princípio, este exige ser realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Em geral, é certo que o reconhecimento de direitos subjetivos significa um maior grau de realização que o simples estabelecimento de um dever objeti-

71. Cf. Güter Dürig, "Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde", pp. 118 e ss.; do mesmo autor, "Art. 1 Abs. 1", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 16, e "Art. 1 Abs. 3", § 102.

72. *BVerfGE* 39, 1 (41); 46, 160 (164); 49, 89 (141); 53, 30 (57).

73. *BVerfGE* 53, 30 (57).

74. *BVerfGE* 39, 1 (41).

75. Cf. Capítulo 3, III.

vo.⁷⁶ Assim, uma simples proibição objetiva de intervenção significaria menos que um direito subjetivo de defesa de conteúdo similar. Nesse sentido, a subjetivização dos deveres de proteção pode ser fundamentada por meio da natureza principiológica dos direitos fundamentais. Mas com isso não foi dito ainda nada acerca do conteúdo definitivo dos direitos a proteção. Como ocorre com todos os direitos baseados em princípios, esse conteúdo definitivo depende das possibilidades fáticas e jurídicas. E como é o caso de outras posições de direitos fundamentais, também no caso dos direitos a proteção é necessário distinguir claramente entre posições *prima facie* e posições definitivas.

Somente a subjetivização dos deveres de proteção faz justiça ao “sentido original e permanente dos direitos fundamentais” como direitos individuais.⁷⁷ Ao contrário do que ocorre com os direitos sociais, ou direitos a prestações em sentido estrito, os direitos a proteção inserem-se inteiramente na compreensão liberal tradicional dos direitos fundamentais.⁷⁸ Sua fundamentação no âmbito do modelo de Estado clássico contratualista, que nos últimos tempos tem experimentado um vigoroso renascimento,⁷⁹ é praticamente inevitável. A ampla renúncia a direitos à autoproteção efetiva, determinada pela transição (hipotética⁸⁰) de uma situação pré-estatal para uma situação estatal, só pode ser racionalmente fundamentada se o indivíduo receber, por essa renúncia, um direito à proteção estatal efetiva. Que essa idéia tem “assento na realidade” e não é, portanto, uma simples construção hipotética, é algo que é possível perceber por meio do fato de que, onde o Estado deixa de ter iniciativa ou força para a satisfação do direito a proteção, não raramente formam-se organizações privadas de proteção, com o intuito de fazer valer direitos individuais. Com a inserção dos direitos a proteção na tradição individualista liberal não se pretende afirmar que esses direitos não suscitem problemas que vão além

76. Cf. Michael D. Bayles, “Courts vs. legislatures as protectors of human rights”, *Rechtstheorie*, Beiheft 8 (1985).

77. *BVerfGE* 50, 290 (337).

78. Cf. Josef Isensee, “Verfassung ohne soziale Grundrechte”, *Der Staat* 19 (1980), p. 374.

79. Cf. apenas as duas obras principais: John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1971, e Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, New York: Basic Books, 1974.

80. Sobre o status epistemológico da teoria contratualista, cf. Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, pp. 6 e ss.

daqueles suscitados pelos direitos de defesa associados a ações estatais negativas. Ao contrário, enquanto direitos a ações estatais positivas, os direitos a proteção compartilham uma série de problemas com os direitos sociais, ou seja, com os direitos a prestações em sentido estrito. No entanto, como será demonstrado adiante, esses problemas não são um motivo para se abdicar dos direitos a proteção. A similaridade de problemas faz com que fique claro que o fosso que separa os direitos da tradição liberal e os direitos próprios do Estado Social não é assim tão fundo quanto seria possível supor à primeira vista.

2.2 Defesa e proteção

Direitos a proteção e direitos de defesa foram contrapostos porque os primeiros são direitos a ações positivas, e os segundos, a ações negativas. A correção dessa contraposição pode ser colocada em dúvida. Nesse sentido, Dürig salienta “que também a ação positiva de ‘proteção’ é ação estatal *defensiva* e não uma *configuração* positiva”.⁸¹ Nessa afirmação é correto que o direito a proteção diz respeito a uma defesa. Mas com isso esgotam-se os pontos comuns entre o direito de defesa e o direito a proteção. O primeiro é um direito em face do Estado a que ele se abstenha de intervir, o segundo é um direito em face do Estado a que ele zele para que terceiros não intervenham. A diferença entre o dever de se abster de intervir e o dever de cuidar que terceiros não intervenham é tão fundamental e repleta de conseqüências que, pelo menos do ponto de vista da dogmática, qualquer relativização nessa diferenciação é vedada. Por isso, a menção ao caráter defensivo pode, no máximo, ser compreendida no sentido de uma inserção dos direitos a proteção na tradição liberal, mas não no sentido de pertencer à classe dos direitos de defesa dirigidos contra o Estado. Não é possível concordar com Dürig quando ele afirma que os direitos a proteção não conduzem a uma configuração positiva. Na medida em que o legislador realiza demarcações entre esferas individuais, exigidas pelos direitos a proteção, ele configura uma parcela decisiva da ordem jurídica e, com isso, uma parte essencial da vida social.

81. Günter Dürig, “Art. 1 Abs. 1”, in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 3.

Schwabe põe em xeque de forma ainda mais incisiva a contraposição entre direitos de defesa e direitos a proteção.⁸² Segundo ele, a aceitação de deveres de proteção, e, com isso, também a aceitação de direitos a proteção, é em grande medida⁸³ supérflua e induz a erro. Aquilo que com eles se almeja poderia ser alcançado de forma mais simples e melhor no âmbito da “função negatória” dos direitos fundamentais.⁸⁴ Sua fundamentação é de uma simplicidade sedutora. Se o Estado não proíbe intervenções privadas nos bens protegidos pelos direitos fundamentais, como a vida ou a saúde, então, ele as *permite*. Mas a permissões estatais correspondem *deveres de tolerância*. Na medida em que o Estado, “por meio de regulação legal, ação judicial e intervenção executiva”, protege ações privadas, ele *participa* do processo de violação, que, por isso, tem que ser a ele *imputável*.⁸⁵ O problema da proteção em face de particulares transforma-se, assim, em um problema de defesa contra intervenções que, embora levadas a cabo por particulares, são, em última instância, estatais.⁸⁶ A permissão, o dever de tolerância e sua exigibilidade judicial e extrajudicial deveriam ser, então, balizados pelo direito fundamental como *direito de defesa*. Deixando-se de lado algumas raras exceções, não haveria lugar para um dever de proteção e, com isso, para um direito a proteção.

O ponto decisivo dessa teoria é a imputação das intervenções privadas ao Estado.⁸⁷ Essa imputação, que converte uma intervenção privada em estatal, é, em sua essência, baseada em três pontos: (1) a

82. Cf. Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, Darmstadt, pp. 213 e ss.

83. Para uma limitada aceitação de deveres de proteção, cf. Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 215-216.

84. Idem, p. 219; do mesmo autor, *Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte*, München: Goldmann, 1971, pp. 140, 145 e 154; ainda do mesmo autor, “Grundrechtlich begründete Pflichten des Staates zum Schutz gegen staatliche Bau- und Anlageneinigungen?”, *NVwZ* 2 (1983), pp. 523 e ss. Para uma crítica a respeito, cf. Robert Alexy, “Das Gebot der Rücksichtnahme im baurechtlichen Nachbarschutz”, *DÖV* 37 (1984), p. 958.

85. Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 213 e ss.

86. Cf. Jürgen Schwabe, *Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte*, p. 149.

87. O Tribunal Constitucional Federal é às vezes ambíguo. Assim, na decisão Mülheim-Kärlich ele fala tanto de um dever de proteção quanto de uma “co-responsabilidade própria” do Estado (*BVerfGE* 53, 30 (58, 61)). Como não é possível partir tanto da construção baseada no direito de defesa quanto da construção baseada no direito de proteção, é necessário interpretá-la no sentido dessa última.

permissão estatal; (2) os deveres de tolerância a ela associados; e (3) a imposição estatal desses deveres de tolerância. No entanto, nenhuma dessas razões é adequada para fundamentar a preferência de uma construção baseada no direito de defesa sobre uma construção baseada no direito a proteção.

O simples fato de uma ação não ser proibida, e, por isso, permitida, não fundamenta nem uma participação do Estado na sua realização, nem a imputação dessa realização ao Estado. Caso contrário, o Estado teria que ser considerado como participante de toda ação humana não proibida; toda ação humana não proibida, como, por exemplo, um convite privado para um jantar, teria que ser imputada ao Estado. Não faz sentido imaginar que seja isso o que se pretende com a teoria da imputação de Schwabe.⁸⁸ O que se pode querer dizer com ela é que o Estado tem um certo tipo de responsabilidade por determinadas ações de um cidadão em relação a outro. As ações pelas quais ele se responsabiliza são as intervenções privadas em bens de direitos fundamentais como a vida, a liberdade e a propriedade. Essa responsabilidade só pode consistir em um dever de impedir determinadas intervenções de terceiros em bens protegidos por direitos fundamentais. Mas isso faz com que o *dever* de impedir intervenções se torne o ponto crucial do argumento. De outro lado, a simples permissão nada diz sobre participação e imputação. E a mera afetação de um bem protegido por um direito fundamental também não é suficiente. Um terceiro pode ameaçar o quanto for a existência de um casamento, isso

88. A tese segundo a qual todas as ações humanas não proibidas devem ser imputadas ao Estado pressupõe um dever estatal de responsabilidade universal, o qual abarca tudo aquilo que é permitido às pessoas. Poder-se-ia até mesmo aceitar, como uma construção possível, a imputação baseada nesse dever universal de responsabilidade. O convite privado para um jantar, como mencionado no texto, seria, então, imputável ao Estado, em razão desse dever de responsabilidade; mas essa imputação, baseada na não-proibição estatal, ou não seria uma intervenção em um direito fundamental, ou essa intervenção estaria justificada. O problema dessa construção está na fundamentação substancial do dever estatal de responsabilidade universal. Aqui interessa apenas que o dever de responsabilidade – da mesma forma que a imputação – não pode ser fundamentado com base em uma *participação* do Estado no convite privado em razão de sua simples não-proibição. Se se pretende relacionar o convite privado ao Estado, isso só pode ocorrer por meio do *dever* universal de responsabilidade. Com isso, no entanto, tudo volta a ser uma questão de *dever de proteção* e de *direito de proteção*. Que sentido teria, então, a complexa construção baseada nos direitos de defesa?

não fundamenta – mesmo em conjunto com a permissão jurídica desse comportamento – uma participação do Estado. Decisivos serão sempre os deveres estatais de proteção e os direitos de proteção que a eles correspondem. A não-proibição ou a permissão estatal pode ser uma violação de um direito a proteção do status positivo. Mas não é uma intervenção em um direito de defesa.⁸⁹

Os deveres de tolerância também não passam ao largo da construção baseada no direito a proteção. O conceito de dever de tolerância pertence a um grupo de conceitos notoriamente obscuros da Teoria do Direito – o próprio Schwabe ocasionalmente observa que seria aconselhável evitá-lo.⁹⁰ No caso do dever de tolerância em face de intervenções privadas é necessário distinguir dois níveis. O primeiro é o do simples não-direito. Um não-fumante *a* tem um não-direito, em face do fumante *b*, a que *b* se abstenha de fumar ($\neg G$) sempre que, em relação a *a*, for permitido que *b* fume (*G*).⁹¹ Para essa permissão relacional e, assim, para o não-direito vale o que acaba de ser afirmado em geral sobre a permissão. Do simples fato de que, em relação a *a*, não é proibido que *b* fume, o que significa que a ele é permitido fumar, e de que *a*, no que diz respeito à proibição de fumar, se encontra, portanto, em uma posição de não-direito em relação a *b*, não decorre que o ato de fumar de *b* deva ser imputado ao Estado como uma intervenção no direito fundamental de *a*. No que diz respeito à proibição de fumar, o simples fato de o Estado deixar *a* em uma posição de não-direito em relação a *b* não implica uma intervenção estatal no direito que *a* tem a que o Estado não afete sua integridade física. O que na verdade pode ocorrer é que, ao deixar *a* na posição de não-direito, o Estado viole um direito que *a* teria em face do Estado a que este o protegesse contra intervenções de terceiros. O fato de o não-direito de *a* ser uma razão suficiente para que um tribunal civil possa rejeitar um pedido de ação de não-fazer de *a* contra *b* em nada modifica esse quadro. Essa rejeição do pedido, embora seja um ato estatal, não pode ser uma violação de um direito de defesa contra o Estado, mas apenas

89. Cf. Dietrich Rauschning, "Staatsaufgabe Umweltschutz", *VVDStRL* 38 (1980), p. 184 (com referências bibliográficas adicionais).

90. Cf. Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 16.

91. Cf., acima, Capítulo 4, II.1.2.2: $\neg Rab \neg G \leftrightarrow PbaG$.

uma violação em razão da não-satisfação de um direito a prestação dirigido contra o Estado na forma de um direito a proteção.

O segundo nível dos deveres de tolerância não é diferente. Esse segundo nível é formado pela proibição e pelos direitos que protegem a permissão (a liberdade) do particular violador.⁹² A liberdade de fumar de *b* é protegida em face de *a* e em face de todos os outros particulares, porque *a* não pode, por meio de determinadas formas de agir, impedir *b* de fumar. Nesse sentido, *a* não pode lesar, coagir ou ofender *b*. Essas proteções não se referem especificamente ao ato de fumar; elas protegem toda liberdade jurídica, como um "perímetro protetor".⁹³ Por isso, na medida em que o Estado geralmente protege dessa forma a liberdade jurídica dos particulares, necessário seria indagar se o uso dessa liberdade deve ser imputado ao Estado. A resposta é: não. Ações privadas não são imputáveis ao Estado pelo simples fato de ele proteger legalmente a permissão de sua realização. Caso contrário um número inimaginável de ações privadas teria que ser imputado ao Estado. O que é correto é, na verdade, o seguinte: *visto que* o Estado, por meio da proteção jurídica geral da liberdade, eliminou diversas possibilidades de autodefesa do cidadão prejudicado por ações de outros cidadãos, tem ele o *dever* constitucional de garantir a proteção na extensão devida. Por conseguinte, mesmo sob o aspecto dos deveres de tolerância, deve-se dar preferência à construção baseada no dever/direito de proteção, e não à construção baseada no direito de defesa.

O terceiro aspecto – a imposição estatal do dever de tolerância – não leva a outro resultado. Suponha-se que um não-fumante, usando de violência, impeça um fumante de fumar e, com isso, satisfaça o suporte fático de uma norma penal. Em razão disso, ele é condenado a uma pena privativa de liberdade. Não há dúvidas de que, com essa sanção, o Estado intervém no direito fundamental de liberdade pessoal, o qual, diante da sanção estatal, atua como um direito de defesa. Mas, mesmo que se considere que fumar geralmente prejudica a integridade física das pessoas, disso não se pode inferir que o Estado tenha também intervindo no direito fundamental à integridade física do não-fumante sob a forma de um direito de defesa. É possível que o Estado contribua para que, em determinadas situações, restem ao não-

92. Sobre o conceito de *proteção*, cf. Capítulo 4, II.2.2.2.

93. Cf. Capítulo 4, II.2.2.2.

fumante apenas as alternativas de aceitar o fumo de terceiros ou cometer um delito. Mas a decisão sobre o que fazer continua a ser uma ação privada.⁹⁴ Isso não significa, contudo, que o direito fundamental à integridade física do não-fumante não possa ser violado pelo Estado. Mas essa violação não pode ser compreendida como se o Estado – enquanto “participante” no ato de fumar – interviesse no direito fundamental à integridade física compreendido como *direito de defesa*; ela só pode ser compreendida como uma violação do direito à integridade física do não-fumante, na forma de um *direito a proteção*, decorrente da forma como o Estado regulou a relação entre fumantes e não-fumantes.

Alguém poderia sustentar que o esforço em distinguir direitos de defesa e direitos a proteção não vale a pena. As reflexões a seguir, acerca da estrutura dos direitos a proteção, demonstrarão que essa impressão é enganosa.

3. Estrutura e justiciabilidade dos direitos a proteção

Com frequência afirma-se que a justiciabilidade dos direitos a ações negativas (direitos de defesa) impõe menos problemas que a justiciabilidade dos direitos a ações positivas (direitos a prestações). Uma razão básica para tanto decorre de uma simples, porém fundamental, diferença teórico-estrutural. Para seus destinatários, direitos de defesa são, dentre outras, proibições de destruir ou afetar negativamente algo. Já os direitos a prestações são, para seus destinatários, dentre outras, obrigações de proteger ou fomentar algo.⁹⁵ Se é *proibido* destruir ou afetar negativamente algo, então, *toda e qualquer* ação que represente ou produza destruição ou afetação negativa é proibida.⁹⁶

94. Cf. Albert Bleckmann, *Allgemeine Grundrechtslehren*, p. 142.

95. Cf. Capítulo 4, II.1.1.2.

96. Na linguagem dos direitos: se existe um *direito* a que algo não seja destruído ou afetado negativamente, então, há um *direito* a uma abstenção de *toda e qualquer* ação que represente ou produza destruição ou afetação negativa. Em virtude da lei deôntica $O(p \wedge q) \leftrightarrow Op \wedge Oq$ (cf., a respeito, Dagfinn Føllesdal/Risto Hilpinen, “Deontic Logic: an introduction”, in Risto Hilpinen (ed.), *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings*, Dordrecht: Reidel, 1971, p. 13), é irrelevante se se concebe esse direito como um *direito* à abstenção das ações h_1 e h_2 e ..., ou se se divide esse direito em um *direito* à abstenção de h_1 , um *direito* à abstenção de h_2 ,

De outro lado, se é *obrigatório* proteger ou fomentar algo, *nem toda* ação que represente ou produza uma proteção ou um fomento será obrigatória.⁹⁷ Assim é que a proibição de matar implica, ao menos *prima facie*, a proibição de qualquer ação de matar; já a obrigação de salvar não implica toda e qualquer ação de salvar. Se é possível salvar alguém que está se afogando seja nadando até ele, seja atirando uma bóia, seja com o auxílio de um barco, de nenhuma forma serão as três ações simultaneamente obrigatórias. Ao contrário, obrigatória é *ou* a primeira, *ou* a segunda *ou* a terceira ação. Mas isso significa que, se não houver motivos restritivos adicionais, o destinatário do dever de salvar tem uma *discrecionarietà*, no interior da qual ele pode escolher como pretende realizar seu dever. E o termo “discrecionarietà” é o termo decisivo no que diz respeito à justiciabilidade dos direitos a ações positivas.

Alguém poderia sentir-se tentado a ver o fundamento da distinção acima apresentada no fato de que, ao contrário do que ocorre com os direitos a ações negativas, os direitos a ações positivas estão ligados a relações meio/fim. No entanto, essa não é uma explicação satisfatória. Da mesma forma que o direito a proteção exige a utilização de ao menos um *meio* de proteção, o direito de defesa exclui a utilização de todo e qualquer *meio* de destruição ou afetação negativa. O fundamento da distinção é mais profundo. Ele consiste na constatação de que a abstenção de cada uma das ações de destruição ou afetação negativa é uma condição necessária, e que somente a abstenção de todas as ações de destruição ou afetação negativa comporia uma condição suficiente para a satisfação da proibição de destruição e de afetação negativa e, com isso, para a satisfação do direito de defesa; já para a satisfação do dever de proteção ou de fomento – como para a satisfação dos direitos a prestações em geral – basta a realização de uma única ação adequada de proteção ou de fomento. Se mais de uma ação de proteção ou de fomento é adequada, nenhuma delas é, em si mesma, necessária para a satisfação do dever de proteção ou de fomento; necessário é somente que alguma delas seja adotada. Apenas se hou-

97. Esses enunciados representam formulações das mais gerais e são passíveis e carentes de qualificações adicionais. Como demonstram os exemplos que se seguem, é especialmente necessário distinguir entre proibições e deveres *prima facie* e proibições e deveres definitivos. Assim, uma proibição *prima facie* de se destruir algo implica apenas uma proibição *prima facie* de toda e qualquer ação destrutiva.

ver somente uma ação adequada de proteção ou fomento é que se pode dizer que ela é necessária para a satisfação do direito a prestação. Nesse caso, a estrutura do direito a prestação é igual à do direito de defesa.

Essa distinção encontra assento na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal quando ele, de um lado, salienta que o Estado está obrigado a proteger, mas, de outro lado, enfatiza que a decisão sobre *como* essa obrigação será satisfeita é algo que “em primeira linha”, “em grande medida” ou “em essência” cabe ao legislador.⁹⁸ Na decisão do caso Schleyer se lê: “O art. 2º, § 2º, 1, combinado com o art. 1º, § 1º, 2, da Constituição alemã obriga o Estado a proteger toda vida humana. Esse dever de proteção é amplo”. Em seguida: “A forma como os órgãos estatais transformam sua obrigação em uma proteção efetiva da vida é algo que deve ser decidido *em princípio* por eles mesmos e sob sua própria responsabilidade. Eles decidem sobre quais medidas de proteção são apropriadas e obrigatórias para garantir uma real proteção da vida”.⁹⁹ Se se deixa de lado, em um primeiro momento, a cláusula “em princípio”, que sugere uma vinculação mais ampla, então, no que diz respeito à vinculação do legislador, dessas duas citações decorrem duas proposições: (1) o Estado tem que adotar ao menos uma medida efetiva; e (2) caso haja apenas uma medida efetiva, o Estado tem que adotá-la. Na decisão do caso Schleyer essa última proposição é expressa da seguinte forma: a “liberdade na escolha do meio para a proteção da vida pode, em alguns casos especiais, resumir-se à escolha de um único meio, caso uma proteção efetiva da vida não possa ser alcançada de outra forma”.¹⁰⁰

Até este ponto a estrutura dos deveres de proteção e, assim, também dos direitos a proteção é simples e clara. Os problemas reais surgem quando são feitas mais diferenciações. A necessidade dessas diferenciações decorre de dois fatores. Em primeiro lugar, os meios de proteção não são facilmente distinguíveis em duas classes: efetivos e não efetivos. Há também meios de proteção mais ou menos efetivos. Além disso, os deveres de proteção têm natureza de princípio; eles exigem uma proteção a mais ampla possível, dentro das possibilida-

98. BVerfGE 39, 1 (42, 44); 46, 160 (164).

99. BVerfGE 46, 160 (164) – sem grifos no original.

100. BVerfGE 46, 160 (164-165); de forma semelhante, BVerfGE 39, 1 (46-47).

des fáticas e jurídicas existentes; isso significa que eles podem colidir com outros princípios. Emblemática nesse sentido é a constatação, na decisão do caso Schleyer, de que a Constituição fundamenta “um dever de proteção não apenas em face do indivíduo, mas também em face da totalidade dos cidadãos”.¹⁰¹

A possibilidade de diferentes graus de efetividade e de colisões faz com que seja necessário refinar consideravelmente o modelo básico. Um exemplo simples pode fazer com que fique claro como isso deve ocorrer. Vamos supor que existam cinco meios para a satisfação do dever de proteção P_1 , a saber, $M_1 - M_5$, e que exista também um princípio colidente P_2 . M_5 é totalmente ineficiente e, por isso, deve ser excluído, mesmo com base no modelo básico. M_1 e M_2 são igualmente efetivos e o mesmo ocorre entre M_3 e M_4 ; mas M_1 e M_2 são mais efetivos que M_3 e M_4 . Assim, isoladamente considerado, P_1 exige M_1 ou M_2 . Por isso, se se parte apenas de P_1 , então, a discricionariedade no modelo básico existe somente em relação a M_1 e M_2 . Ocorre que a realização do princípio contraposto P_2 é afetada por meio da adoção de todas as quatro medidas ainda relevantes, mas de forma mais intensa por M_1 e M_2 que por M_3 e M_4 . Nesse caso, um sopesamento tem que decidir se P_1 tem, em face de P_2 , um peso tão grande que ainda justifique a adoção de M_1 e M_2 e, se esse não for o caso, se ao menos a adoção de M_3 ou M_4 é justificada. Se nenhuma das duas alternativas for verdadeira, a escolha de qualquer uma das medidas adequadas para a satisfação do dever de proteção *prima facie* é definitivamente vedada; caso não sejam ambas as alternativas impossíveis, porque ao menos a adoção de M_3 ou M_4 pode ser justificada à luz de P_1 em face de P_2 , então, no modelo básico, a discricionariedade existe em relação a M_3 e M_4 . Mas mesmo essa discricionariedade pode facilmente encolher, pois, embora M_3 e M_4 possam ser igualmente efetivas em relação a P_1 , M_4 pode afetar P_2 de forma mais intensiva que M_3 , de modo que escolher M_4 representaria uma afetação não necessária de P_2 , o que significa que, como meio mais suave em relação a P_2 , apenas a adoção de M_3 é justificada. Assim, deixa de existir uma discricionariedade para a realização de P_1 , ainda que haja vários meios eficazes para essa realização, alguns deles, inclusive, igualmente eficazes.

101. BVerfGE 46, 160 (165).

Em si mesma considerada, a discricionariedade a que se fez menção até aqui – que pode ser classificada como *discricionariedade estrutural* – não suscita qualquer problema grave no que diz respeito à questão da justiciabilidade. Esses problemas surgem a partir da associação da discricionariedade estrutural com questões ligadas ao sopesamento e questões de efetividade. A discricionariedade estrutural está ligada a dois tipos distintos de discricionariedade: a *discricionariedade cognitiva* ligada aos problemas normativos do *sopesamento* e a *discricionariedade cognitiva* ligada aos problemas empíricos da *efetividade*. O problema da efetividade diz respeito sobretudo aos efeitos futuros de medidas presentes, ou seja, a questões de prognósticos.¹⁰² Uma avaliação do problema da justiciabilidade depende, portanto, do papel que os problemas ligados ao sopesamento e aos prognósticos desempenham no âmbito dos direitos de proteção.

Como já foi salientado diversas vezes, sopesamentos não são in-comuns no direito constitucional. No caso dos direitos de defesa eles são inevitáveis. Se os problemas do sopesamento, no âmbito dos direitos a proteção, supostamente fazem com que tais direitos sejam menos justiciáveis que os direitos de defesa, então, o sopesamento tem que ter alguma característica especial no âmbito desses direitos. Exatamente nesse sentido é a proposta de Schuppert, que diferencia entre problemas unidimensionais e problemas multidimensionais de liberdade e associa a essa distinção diferentes graus de competências de controle por parte Tribunal Constitucional Federal e, com isso, diferentes amplitudes para a discricionariedade do legislador.¹⁰³ Se “interesses da coletividade e interesses individuais protegidos por direitos fundamentais” colidem, trata-se de um problema unidimensional de liberdade. Esse seria o caso dos direitos de defesa. Schuppert sustenta que, para esse tipo de colisão, a solução devida pode “ser estabelecida com um alto grau de plausibilidade por meio de interpretação, na forma como predeterminado pela Constituição”.¹⁰⁴ Ao contrário, se o que colide “não são os interesses da coletividade nem interesses individuais protegidos por direitos fundamentais, mas posições jurídicas

102. Cf. Klaus J. Philippi, *Tatsachenfeststellungen des Bundesverfassungsgerichts*, pp. 28 e ss.

103. Cf. Gunnar F. Schuppert, *Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation*, pp. 38 e ss.

104. Idem, p. 41.

individuais ou de grupos, os quais podem invocar em igual medida uma fundamentação constitucional ou até mesmo de direitos fundamentais”, então, trata-se de um problema multidimensional de liberdade. Diferentemente do que ocorre no caso das colisões unidimensionais, nas colisões multidimensionais a solução não é “predeterminada pela Constituição”.¹⁰⁵ As consequências para a questão da justiciabilidade são claras.

Os direitos a proteção dizem respeito sobretudo à delimitação entre as posições de direitos fundamentais de diferentes titulares. Se a análise de Schuppert fosse correta, ela teria grandes consequências para a justiciabilidade desses direitos. Mas sua análise é apenas muito limitadamente correta. Em primeiro lugar, é necessário constatar que sua distinção entre problemas unidimensionais e problemas multidimensionais de liberdade é apenas parcialmente consistente – o próprio Schuppert fala em uma transição fluida.¹⁰⁶ Nos sopesamentos no âmbito dos direitos de defesa, ao lado de interesses coletivos, direitos de terceiros podem também ser relevantes; nos sopesamentos no âmbito dos direitos a proteção, ao lado dos direitos de terceiros, outros interesses coletivos podem desempenhar um papel decisivo. Essa estrutura triádica (direitos de *a*/interesses coletivos/direitos de *b*₁, *b*₂ ...) está por trás de todo problema de direitos fundamentais. Assim, uma intervenção na liberdade jurídica, a ser mensurada a partir de direitos de defesa, pode ser justificada não apenas por meio da referência à sua exigibilidade para a proteção de interesses coletivos, mas também por meio de uma referência à sua exigibilidade para a proteção de posições individuais de terceiros.¹⁰⁷ No sentido oposto, a não-garantia de proteção é justificável não somente por meio de uma referência à sua exigibilidade para o respeito de posições individuais de terceiros, mas também por meio de uma referência à sua exigibilidade para a proteção de interesses coletivos. É nesse sentido que deve ser compreendida a formulação utilizada na decisão no caso Mülheim-Kärlich, na qual o tribunal menciona a tarefa estatal de, “considerando-se os *interesses gerais*, criar um equilíbrio entre as posições de direitos fundamentais de cidadãos ameaçados, de um lado, e as posições dos fornecedores

105. Idem.

106. Idem, p. 46.

107. Cf. BVerfGE 49, 24 (53 e ss.).

de energia, de outro lado".¹⁰⁸ *Somente* com os direitos de liberdade dos fornecedores seria praticamente impossível justificar o ônus dos cidadãos ameaçados com o risco residual. Não é à toa que o tribunal faz menção ao "interesse geral no fornecimento de energia".¹⁰⁹

Portanto, a capacidade distintiva da diferenciação entre problemas unidimensionais e problemas multidimensionais não é tão alta. Ainda assim é possível dizer que a parcela de sopesamentos complexos é maior dentre os sopesamentos levados a cabo pelo Tribunal Constitucional Federal no âmbito de um questionamento ligado a direitos a proteção que dentre aqueles levados a cabo no âmbito de um questionamento ligado a direitos de defesa. Daí não se pode concluir, no entanto – e isso nos leva ao segundo ponto fraco do argumento de Schuppert –, que a diferença entre os problemas ligados aos direitos de defesa e aqueles ligados aos direitos a proteção consiste no fato de que a solução para os primeiros é predeterminada em maior medida pela Constituição. Não é, aqui, necessário ir mais a fundo no obscuro conceito de predeterminação constitucional. Aqui, basta a simples assunção de que a solução de uma questão jurídico-constitucional só pode ser considerada como predeterminada pela Constituição se não puder existir nenhuma dúvida razoável acerca da sua correção para todos aqueles que respeitem o texto constitucional e as regras de argumentação constitucional. Aqueles que se orientarem por essa premissa perceberão que também no âmbito dos direitos de defesa há inúmeras questões que não são predeterminadas constitucionalmente. Um defensor da tese de Schuppert poderia aceitar esse fato e, ao mesmo tempo, afastá-lo com a observação de que os direitos de defesa dizem respeito a polêmicas e dúvidas jurídicas cotidianas, que se mantêm dentro de uma certa zona de plausibilidade, enquanto os direitos a proteção dizem respeito a dúvidas e disputas de caráter fundamental. Mas essa diferenciação também é duvidosa. Há problemas ligados aos direitos de defesa sobre os quais se travam polêmicas fundamentais, que vão muito além da Ciência do Direito – basta pensar no direito de reunião –, e há posições relacionadas a direitos a prestações sobre as quais não pairam dúvidas, como a proteção contra lesões corporais por meio de normas penais. Isso faz com que fique claro que os limites da

108. BVerfGE 53, 30 (57-58) – sem grifos no original.

109. BVerfGE 53, 30 (58).

discrecionariedade do legislador e da competência do tribunal constitucional não podem ser orientados por distinções teórico-estruturais como aquela entre direitos de defesa e direitos a proteção, mas tão-somente por questões substanciais. A partir do conceito formal de direito fundamental apresentado anteriormente, a questão substancial diz respeito a se saber se, do ponto de vista do direito constitucional, uma determinada proteção é tão importante que a decisão sobre garanti-la ou não garanti-la não possa ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples.

Essa fórmula contém também a chave para a solução do problema dos prognósticos. É facilmente perceptível que qualquer proposta para a solução do problema dos prognósticos inclui uma proposta acerca da repartição de competências entre tribunal constitucional e legislador.¹¹⁰ O que é necessário julgar é se um meio de proteção M satisfaz, ou não, o dever de proteção P . Segundo o prognóstico Pr_1 , a resposta é sim; segundo o prognóstico Pr_2 , não. O legislador defende Pr_1 . Se o legislador tem a competência para decidir de qual prognóstico se deve partir, o tribunal constitucional não pode dizer que o dever de proteção foi violado. Se o tribunal tiver essa competência, ele pode dizer que Pr_1 é incorreto e Pr_2 é correto, e que, por isso, o dever de proteção P não é satisfeito pela medida M .

A discussão acerca da competência relativa a prognósticos fez com que ficasse claro que soluções tudo-ou-nada não são apropriadas. De um lado, o legislador não pode partir de qualquer prognóstico e o tribunal constitucional não pode, sem limites, substituir o prognóstico do legislador pelo seu próprio; de outro lado, não é possível formular uma regra simples que delimite em todos os casos a competência de prognósticos do legislador e a competência de controle do tribunal constitucional.¹¹¹ Como o Tribunal Constitucional Federal corretamente demonstrou, a solução reside muito mais no desenvolvimento de “parâmetros diferenciados (...), que vão desde um controle por evi-

110. Cf. Fritz Ossenbühl, “Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognosenentscheidungen durch das Bundesverfassungsgerichts”, in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, I, Tübingen: Mohr, 1976, pp. 467 e ss.; Gunnar F. Schuppert, *Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation*, p. 54.

111. Cf. Fritz Ossenbühl, “Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognosenentscheidungen durch das Bundesverfassungsgerichts”, p. 503.

dência (...) passando por um controle de plausibilidade (...) culminando com um controle intensificado de conteúdo”.¹¹² Aqui não é o local para analisar com mais detalhes a estrutura e os problemas desse sistema escalonado de controle. O que interessa é somente a fundamentação do postulado do escalonamento. Seu ponto de partida é o pressuposto de que a amplitude da proteção dos direitos fundamentais por meio do tribunal constitucional e, com isso, a amplitude das posições definitivas de direitos fundamentais existentes no sistema jurídico dependem significativamente da amplitude da discricionariedade legislativa no que diz respeito a prognósticos. *No resultado* essa discricionariedade não se diferencia, no que diz respeito à restrição da proteção a direitos fundamentais, da competência para impor restrições. Isso faz com que fique claro que sua amplitude só pode ser definida se se leva em consideração o princípio atingido, e que ela depende decisivamente do peso desse princípio no caso a ser decidido.¹¹³ Exatamente nesse sentido afirmou-se na decisão do caso sobre a central de caronas: “Quanto mais a intervenção legal afetar expressões elementares da liberdade de ação humana, tanto mais cuidadosamente devem ser sopesadas as razões utilizadas como fundamentação contra a pretensão básica de liberdade dos cidadãos”.¹¹⁴ A discricionariedade ligada a prognósticos torna-se, assim, um problema de sopesamento entre o princípio material de direito fundamental e o princípio formal da competência decisória do legislador, democraticamente legitimada. No âmbito desse sopesamento devem ser considerados os diversos outros pontos de vista relevantes.¹¹⁵

Neste ponto, o que é decisivo é o fato de que o problema do sopesamento ligado à discricionariedade de prognósticos surge, em igual

112. *BVerfGE* 50, 290 (333). Sobre a exigência de um “sistema de controle diferenciado e escalonado substancial e tematicamente”, cf. Fritz Ossenbühl, “Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognosenentscheidungen durch das Bundesverfassungsgerichts”, p. 501.

113. Para uma orientação baseada no “valor” ou na “força” do direito fundamental afetado, cf. Uwe Seetzen, “Der Prognosespielraum des Gesetzgebers”, *NJW* 28 (1975), pp. 432-433; Fritz Ossenbühl, “Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognosenentscheidungen durch das Bundesverfassungsgerichts”, pp. 506-507.

114. *BVerfGE* 17, 306 (314).

115. Dentre os quais se encontram, por exemplo, “a particularidade do campo temático em discussão” e a “possibilidade de se construir um juízo suficientemente seguro” (*BVerfGE* 50, 290 (333)).

medida, tanto no caso de direitos de defesa como no de direitos a proteção. É certo que no caso dos direitos a proteção o problema do sopeamento tem um peso maior, em razão da sua referência especial ao futuro; mas isso implica simplesmente uma diferença de grau. Com isso pode-se dizer que a justiciabilidade dos direitos de proteção não suscita problemas que não existam também no âmbito dos direitos de defesa.

III – DIREITOS A ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTO

1. Sobre o estágio da discussão

No recente debate sobre direitos fundamentais poucas foram as idéias que despertaram tanta atenção quanto a existência de uma conexão entre direitos fundamentais, organização e procedimento. Os marcos dessa discussão foram a proposta feita por Häberle de um *status activus processualis*, relacionado à “face procedimental da liberdade constitucional, o ‘*due process* dos direitos fundamentais””,¹¹⁶ e a proposta de Hesse, segundo a qual “organização ou procedimento [revelam-se] com freqüência o – provavelmente único – meio de se produzir um resultado conforme aos direitos fundamentais e, com isso, assegurá-los de forma eficaz também em face dos problemas modernos”.¹¹⁷ Goerlich tentou desenvolver a idéia procedimental como uma concepção abrangente de direitos fundamentais. O quão amplo o conceito tem que ser compreendido fica claro quando Goerlich fala de “direitos fundamentais materiais e formais como garantia procedimental do processo político, jurídico e social de uma comunidade”.¹¹⁸ A idéia de procedimento não despertou atenção apenas na discussão constitucional alemã. Nos Estados Unidos isso é exemplarmente perceptível na controvérsia entre Ely¹¹⁹ e Tribe.¹²⁰ Além disso, o pensa-

116. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, *VVDStRL* 30 (1972), p. 81.

117. Konrad Hesse, “Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland”, *EuGRZ* 1978, pp. 434-435.

118. Helmut Goerlich, *Grundrechte als Verfahrensgarantie*, Baden-Baden: Nomos, 1981, p. 203.

119. Cf. John H. Ely, *Democracy and Distrust*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1980.

120. Cf. Laurence Tribe, “The puzzling persistence of process-based constitutional theories”, *The Yale Law Journal* 89 (1980), pp. 1.063 e ss.

mento procedimental não está limitado ao direito, como claramente demonstra a intensa discussão sobre teorias procedimentais na Ética contemporânea.¹²¹ A dogmática dos direitos fundamentais parece ter encontrado, assim, uma “palavra-chave”,¹²² que, em primeiro lugar, promete indicar um caminho intermediário entre uma teoria axiológica levada a cabo pelo tribunal constitucional e um deixar-fazer ao legislador, fundamentado em um ceticismo axiológico subjetivista; e que, em segundo lugar, está em harmonia com o espírito de seu tempo; e, em terceiro lugar, que leva a um território tão familiar ao jurista, o território do procedimento.

Em face dessas perspectivas tão abrangentes, não é surpresa que vozes mais cautelosas tenham se elevado. Nesse sentido, Ossenbühl alerta para uma “euforia procedimental geral, orientada pelos direitos fundamentais (...), que pode ter conseqüências imprevisíveis e, como outros modismos na Ciência do Direito, levar a frustrações desnecessárias”.¹²³ Bethge fala de uma “plasticidade patente” do “topos argumentativo ‘realização e asseguarção dos direitos fundamentais por meio de organização e procedimento’”, bem como de uma “fórmula *passerpartout*”.¹²⁴ No entanto, nenhum dos dois autores rejeita uma interpretação das disposições de direitos fundamentais (também) sob a luz do pensamento procedimental. O que se exige são diferenciações, e essa exigência é procedente. Tanto a idéia de procedimento, tão central para a Filosofia prática e para a Ciência do Direito,¹²⁵ quanto os direitos fundamentais dizem respeito a coisas tão variadas e complexas, que uma simples transposição *da* idéia de procedimento *aos* direitos fundamentais levaria, na melhor das hipóteses, a resultados triviais.

Exemplos de aplicação diferenciada da idéia de procedimento podem ser encontrados na jurisprudência do Tribunal Constitucional

121. Cf., por exemplo, John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1971; Jürgen Habermas, “Diskursethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm”, in Jürgen Habermas, *Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, pp. 53 e ss.

122. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, p. 129.

123. Fritz Ossenbühl, “Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts”, *DÖV* 34 (1981), p. 6.

124. Herbert Bethge, “Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren”, *NJW* 35 (1982), p. 2.

125. Cf. Robert Alexy, “Juristische Argumentation und praktische Vernunft”, *Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen* 1982, pp. 29 e ss.

Federal. Essa jurisprudência é no mínimo interessante, porque nela já haviam sido fixadas orientações decisivas antes que a doutrina tivesse dado muita atenção a esse tema. Boa parte da discussão sobre “direitos fundamentais como garantias procedimentais” é uma tentativa de reproduzir e conceitualizar um desenvolvimento já levado a cabo na prática jurisprudencial. Por essa razão, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal tem que estar em primeiro plano no que diz respeito às questões aqui suscitadas acerca da existência e da estrutura de direitos a procedimentos.

2. O conceito de direito a organização e procedimento

A cláusula “organização e procedimento” descreve de forma extremamente ambígua o objeto desses direitos. É necessário indagar se, com o conceito de direito a organização e procedimento, é descrito *um* complexo integrado de direitos, ou se esse conceito combina *dois* complexos independentes de direitos, a saber, direitos a organização e direitos a procedimento, os quais poderiam também ser tratados de forma separada.

Chama a atenção o fato de que a fórmula “realização e asseguarção dos direitos fundamentais por meio de organização e procedimento”,¹²⁶ atualmente já consagrada, é utilizada com frequência como rubrica para reflexões nas quais nunca se distingue estritamente entre direitos a organização e direitos a procedimento. As distinções que são feitas¹²⁷ seguem não a divisão entre o conceito de procedimento e o conceito de organização, mas outros pontos de vista bastante diversos. Isso faz com que fique claro que a utilização habitual de ambas as expressões não segue um critério técnico.

126. Konrad Hesse, “Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland”, p. 434; Christian Starck, “Die Grundrechte des Grundgesetzes”, *JuS* 21 (1981), p. 242; Herbert Bethge, “Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren”, p. 1.

127. Cf., por exemplo, Konrad Hesse, “Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland”, pp. 435 e ss.; Fritz Ossenbühl, “Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts”, pp. 5-6; Herbert Bethge, “Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren”, pp. 2 e ss.

A razão para a relativa atecnicidade na utilização da fórmula é facilmente identificável. O espectro daquilo a que se faz referência é bastante amplo. Ele se estende desde direitos a uma proteção jurídica efetiva,¹²⁸ que ninguém hesitaria em denominar “direitos a procedimentos”, até aqueles direitos a “medidas estatais (...) de natureza organizacional”,¹²⁹ relevantes para a composição dos órgãos colegiados em universidades. Aglutinar coisas assim tão diferentes em um mesmo conceito – tenha ele um nome composto, ou não – é justificável apenas se for possível achar similaridades que sustentem essa aglutinação. A similaridade que a justifica é a idéia de procedimento. Procedimentos são sistemas de regras e/ou princípios para a obtenção de um resultado. Se o resultado é obtido por meio da observância dessas regras e/ou respeito aos princípios, então, ele deve, do ponto de vista procedimental, ser classificado positivamente. Se ele não é obtido dessa forma, ele é, do ponto de vista procedimental, defeituoso, e deve ser, por isso, classificado negativamente. Esse conceito amplo de procedimento engloba tudo o que está incluído na fórmula “realização e asseguarção dos direitos fundamentais por meio de organização e procedimento”. Nesse sentido, a despeito das visíveis diferenças, as normas do direito contratual e as normas do direito processual definem igualmente um procedimento: as primeiras estabelecem como se pode produzir uma obrigação contratual; as segundas, um julgamento. Ao mesmo tempo, o conceito amplo de procedimento faz com que fique claro o que é relevante na idéia de procedimento no âmbito dos direitos fundamentais. As normas de organização e procedimento devem ser criadas de forma a que o resultado seja, com suficiente probabilidade e em suficiente medida, conforme aos direitos fundamentais.¹³⁰

128. Cf. *BVerfGE* 24, 367 (401); 35, 348 (361); 37, 132 (148); 39, 276 (294); 44, 105 (120); 45, 297 (322); 45, 422 (431); 46, 325 (334); 48, 292 (297); 49, 220 (225); 49, 252 (256); 51, 150 (156); 52, 391 (408).

129. *BVerfGE* 35, 79 (116).

130. Normas de organização e procedimento podem ter não apenas esse caráter de meio, elas podem ser também um fim em si mesmas. No que diz respeito aos direitos fundamentais, uma norma procedimental *N* tem um caráter de fim em si mesma se ela continuar a ser exigível da perspectiva dos direitos fundamentais mesmo que se constate que, com a vigência de *N*, o resultado do procedimento não seria, em nenhuma situação e sob qualquer aspecto, mais compatível com os direitos fundamentais do que seria sem sua vigência. Aqui pode ficar em aberto saber se existe alguma norma de organização e procedimento com esse caráter de fim em si mesma.

Em que medida é possível estabelecer uma tal conexão entre procedimentos jurídicos e seus resultados é algo que por enquanto pode ser deixado de lado.

A idéia de procedimento justifica reunir em um conceito a pluralidade de fenômenos encontráveis no âmbito da organização e do procedimento. Já a questão terminológica é de importância secundária. Ao invés de direitos a organização e procedimento, seria possível falar simplesmente de "direitos a procedimentos" ou "direitos procedimentais", desde que se pressuponha um conceito amplo de procedimento, que inclua também normas de organização. Até por razões de simplicidade, aqui se fará uso dessas possibilidades com frequência.

Mesmo após o que foi analisado até aqui, uma ambigüidade fundamental permanece. Direitos a procedimentos podem ser tanto direitos à criação de determinadas normas procedimentais quanto direitos a uma determinada "interpretação e aplicação concreta" de normas procedimentais.¹³¹ Um exemplo desse último caso são as inúmeras decisões do Tribunal Constitucional Federal acerca das normas sobre leilão judicial, cujo tema é a interpretação de normas procedimentais conforme à Constituição.¹³² O direito a procedimentos como direito a proteção jurídica efetiva, nesse caso, tem como destinatário os tribunais. De outra parte, os direitos a procedimentos que têm como objeto a criação de normas procedimentais, por serem direitos ao estabelecimento de normas, têm como destinatário o legislador. Aqui interessam sobretudo esses últimos.

3. Sobre o problema da existência

As respostas às questões acerca da existência e da estrutura dos direitos a organização e procedimento dependem do tipo de direitos a organização e procedimento de que se trate. Apesar da necessidade de diferenciações, é recomendável que se aborde o problema da existência de forma geral, antes de se passar à análise das diferentes espécies.

131. Cf. BVerfGE 53, 30 (61).

132. Cf., por exemplo, BVerfGE 46, 325 (333 e ss.); 49, 220 (225 e ss.); 49, 252 (256 e ss.); 51, 150 (156).

No que diz respeito ao problema da existência, a questão mais importante refere-se a saber em que medida às obrigações que o legislador tem de zelar por determinados procedimentos e organizações em decorrência dos direitos fundamentais correspondem direitos subjetivos dos titulares desses direitos. Enquanto na literatura sobre o tema essa questão é muitas vezes tratada, sem muita reflexão, como um problema de deveres do legislador¹³³ e se defende expressamente uma tendência objetivista,¹³⁴ a jurisprudência contém interessantes referências para o problema da subjetivização.

A despeito de a Constituição conter direitos fundamentais diretamente relacionados a procedimentos – os direitos fundamentais ligados ao acesso à Justiça (arts. 19, § 4º; 101, § 1º; 103, § 1º; e 104) – e a despeito da ampla utilização do princípio do Estado de Direito para fundamentar exigências de criação e de configuração de procedimentos, o denominador comum na jurisprudência é atribuir direitos a procedimentos aos direitos fundamentais materiais.¹³⁵ O ponto de partida desse desenvolvimento foi a constatação, na decisão acerca da legislação sobre diques, de que, “de acordo com a concepção da Constituição alemã, uma proteção jurídica efetiva – que garanta a existência da propriedade – [é] um elemento essencial do próprio direito fundamental”.¹³⁶ O direito à proteção jurídica, inicialmente ligado apenas ao direito fundamental de propriedade, generalizou-se de duas formas distintas ao longo da atividade jurisprudencial do tribunal. De um lado, ele foi estendido cada vez mais a outros direitos fundamentais¹³⁷ e, de

133. Cf., por exemplo, Herbert Bethge, “Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung”, pp. 2 e ss.; Walter Schmidt, “Grundrechtstheorie im Wandel der Verfassungsgeschichte”, *Jura* 5 (1983), pp. 169 e ss.

134. Cf., por exemplo Hans H. Rupp, “Vom Wandel der Grundrechte”, pp. 176 e ss. e 187 e ss., bem como, de forma bastante incisiva, Ulrich K. Preuß, *Die Internalisierung des Subjekts*, pp. 189 e ss. e 194, segundo o qual não existe “qualquer pretensão jurídica contra o legislador para que ele crie estruturas liberais. O estabelecimento de estruturas liberais é função exclusiva do processo político e, nesse âmbito, função do legislador encarregado de criar normas vinculantes”.

135. Sobre alguns problemas construtivos dessa prática de atribuição, cf. Herbert Bethge, “Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung”, pp. 6-7; Dieter Lorenz, “Der grundrechtliche Anspruch auf effektiven Rechtsschutz”, *AöR* 105 (1980), pp. 639-640.

136. *BVerfGE* 24, 367 (401).

137. Sobre o art. 14 da Constituição, cf., por exemplo, *BVerfGE* 35, 348 (361); 37, 132 (148); 45, 297 (322); 46, 325 (334); 49, 220 (225); 49, 252 (256); 51, 150

outro, de um direito à proteção jurídica efetiva foi ele simplesmente estendido para um direito à proteção dos direitos fundamentais por meio de procedimentos.¹³⁸ Atualmente é possível afirmar que, segundo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, a todo direito fundamental material são atribuídos direitos a procedimentos. Mas se os direitos materiais são direitos subjetivos, por que os "direitos a procedimentos" não deveriam ser? Ancorar a proteção por meio de procedimentos nos direitos fundamentais materiais fundamenta, no mínimo, um argumento *prima facie* para sua subjetivização.

Sua natureza subjetiva não suscita grandes problemas quando se trata de direitos – dirigidos ao Judiciário – a uma interpretação e uma aplicação conformes à Constituição de normas procedimentais em si mesmas já compatíveis com a Constituição, como ocorre nas decisões sobre execução forçada.¹³⁹ Os problemas surgem quando estão em jogo direitos à existência de determinadas normas procedimentais, ou seja, direitos à criação de normas, por parte do legislador, no âmbito da organização e do procedimento. Neste ponto é suficiente fazer referência às reflexões feitas anteriormente quando da análise dos direitos a proteção e às duas decisões interessantes naquele contexto. Na primeira delas, a decisão sobre o ensino superior, é possível encontrar o já diversas vezes citado paradigma de um direito subjetivo – em face do legislador – a que determinadas normas procedimentais existam. Ao titular do direito fundamental do art. 5º, § 3º, da Constituição alemã seria conferido "um direito àquelas medidas estatais, também de caráter organizacional, que sejam imprescindíveis para a proteção de sua esfera de liberdade constitucionalmente protegida".¹⁴⁰ Partindo-se da segunda decisão, a decisão no caso da legislação sobre diques da Cidade-Estado de Hamburgo, é fácil de se estender um direito subjetivo a normas procedimentais. Nessa decisão, por razões de proteção jurídica, o tribunal aceita uma desapropriação legal apenas em casos

(156). Sobre o art. 12, cf., por exemplo, *BVerfGE* 39, 276 (294); 41, 251 (265); 44, 105 (120); 45, 422 (431); 48, 292 (297); 52, 380 (388 e ss.). Sobre o art. 2º, § 1º, cf., por exemplo, *BVerfGE* 52, 214 (219); 53, 30 (65). Sobre o art. 16, § 2º, 2, cf., por exemplo, *BVerfGE* 52, 391 (407).

138. *BVerfGE* 53, 30 (65).

139. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 49, 220 (225 e ss.); 49, 252 (256 e ss.); 51, 150 (156 e ss.).

140. *BVerfGE* 35, 79 (116).

excepcionais.¹⁴¹ Isso significa que no art. 14 da Constituição alemã é atribuído, nos casos que não sejam excepcionais, um direito a que as desapropriações sejam realizadas apenas por meio de um procedimento administrativo de desapropriação. Ambas as decisões fazem com que fique claro que o Tribunal Constitucional não exclui a possibilidade de direitos subjetivos à criação de determinadas normas no âmbito da organização e do procedimento, cujo destinatário é o legislador. No nível abstrato não é possível dizer mais que isso. Todo o resto depende do tipo de direito em questão em cada caso.

4. Direitos procedimentais e teoria do status

Um dos problemas estruturais mais interessantes dos direitos procedimentais é saber se eles realmente são direitos a ações positivas atribuíveis ao status positivo, ou se, ao contrário, pertencem ao status negativo ou ao status ativo.

4.1 Direitos procedimentais e status negativo

Os direitos à não-eliminação de posições jurídicas foram acima também classificados como direitos a ações estatais negativas.¹⁴² Inúmeras posições jurídicas procedimentais de direito ordinário existem em virtude de normas de direito ordinário. Se sua existência for exigida pelos direitos fundamentais – e isso é o que em grande medida ocorre –, o conteúdo jurídico-procedimental das normas de direitos fundamentais consiste também na proibição de sua eliminação, ou seja, em protegê-las contra atos de revogação. Significa isso que seria equivocado analisar os direitos a procedimentos no âmbito do status positivo, como aqui se faz?

A resposta a essa pergunta deve ser negativa. É certo que o conteúdo jurídico-procedimental das normas de direitos fundamentais consiste, em enorme medida, em proteger posições jurídicas procedimentais existentes por meio de uma proibição de sua eliminação pura e simples ou de sua eliminação sem compensação. É certo também

141. BVerfGE 24, 367 (402-403).

142. Cf. Capítulo 4, II.1.1.1.3.

que os direitos que correspondem a *essas* proibições são atribuíveis ao status negativo (em sentido amplo),¹⁴³ o que significa que as normas de direitos fundamentais ligadas a procedimentos podem ser discutidas em grande medida no âmbito da análise dos direitos do status negativo. Mas de tudo isso não decorre que seja inadequado, e muito menos equivocado, tratar os direitos a procedimentos no contexto do status positivo.

Um primeiro argumento nesse sentido é o fato de que quando não se trata de garantir normas já existentes, mas de algo novo, o que se indaga é sempre se o Estado tem que *fazer* algo (criar normas), ou não. Os casos dos direitos ao não-embaraço de ações e à não-afetação de estados (naturais)¹⁴⁴ são bem diferentes. Neles, o que se indaga é sempre se o Estado tem que se *abster* de algo, ou não. Mas a força desse argumento é limitada. Seria possível aceitá-lo e dizer que, quando se trata de algo novo, os direitos a procedimentos devem ser analisados no contexto do status positivo e que a garantia de posições procedimentais de direito ordinário que já existam é uma questão inserida no âmbito do status negativo, o que significaria que o aspecto procedimental seria atribuível em grande medida ao status negativo. É necessário, portanto, um argumento adicional para justificar uma ampla análise no âmbito do status positivo.

Esse argumento adicional é o fato de que direitos a posições procedimentais são direitos a que exista algo para cuja criação sejam necessárias ações positivas. Diante desse aspecto, se as ações que levam à existência de posições procedimentais em nível infraconstitucional já foram realizadas, ou não, é uma questão de mero acaso. O fato de já terem sido realizados os atos legislativos necessários para a criação das posições procedimentais em nível infraconstitucional é algo que não muda nada na constatação de que, se eles ainda não tivessem sido realizados, haveria um direito a que o fossem. Esse direito hipotético à realização tem primazia em face do direito à não-eliminação. Dentre outros, isso é perceptível por meio da constatação de que uma resposta à pergunta sobre se uma posição procedimental em nível infraconstitucional é protegida por meio de um direito à não-eliminação exige antes uma resposta à pergunta sobre se o titular

143. Cf. Capítulo 5, I.3.

144. Cf. Capítulo 4, II.1.1.1.

da posição tem, em face do legislador, um direito a que este crie essa posição.

Apenas como complemento, é possível mencionar um terceiro argumento, já exposto anteriormente.¹⁴⁵ Não parece ser possível excluir a possibilidade de que como ação do legislador sejam considerados não apenas atos de criação e de revogação normativa, mas também a manutenção da vigência de normas. Se se adota esse ponto de vista, o problema do status resolve-se de uma maneira extremamente simples: em relação às posições procedimentais em nível infraconstitucional já existentes os direitos a procedimentos são direitos a que o legislador realize a ação positiva de manutenção de sua vigência.

4.2 Direitos procedimentais e status ativo

Mais plausível que uma atribuição ao status negativo é uma classificação dos direitos procedimentais como direitos do status ativo. Exatamente nesse sentido, Häberle afirma: o "*status activus processualis* deve ser inserido no *status activus*, até então primariamente jurídico-material".¹⁴⁶

À primeira vista favorável a essa classificação é o fato de o âmbito do procedimento e da organização dizer respeito sobretudo a *competências*¹⁴⁷ e de o status ativo ser composto de competências.¹⁴⁸ Mas uma segunda olhada faz com que fique claro que as coisas não são assim tão simples. Os direitos a organização e procedimento, em face do legislador, não são competências, mas direitos a competências. Enquanto tais, não há dúvidas de que eles pertencem ao status positivo.

No entanto, essa não é ainda a última palavra acerca da conexão entre os direitos a organização e procedimento e o status ativo. Enquanto direitos a organização e procedimento, os direitos em questão não pertencem ao status ativo, mas seu objeto – organização e proce-

145. Cf. Capítulo 4, II.1.1.2.

146. Peter Häberle, "Grundrechte im Leistungsstaat", p. 81.

147. Quando se trata de competências, trata-se sempre também de sujeições, como é o caso do oposto de competências e sujeições, ou seja, de não-competências e não-sujeições. Sobre esses conceitos, cf. Capítulo 4, II.3.5.

148. Cf. Capítulo 5, I.4.

dimento, ou seja, em grande parte, competências – pode ser aquilo que pertence a esse status.

Em alguns casos isso é procedente, como demonstra o exemplo a seguir. O art. 38, § 1º, da Constituição alemã confere ao indivíduo um direito subjetivo a votar. Votar é impossível sem alguma forma de organização. Portanto, o art. 38, § 1º, confere ao indivíduo um direito contra o Estado a que este torne possível o ato de votar, por meio de alguma forma de organização. Como a Constituição alemã não prescreve nenhum sistema eleitoral específico¹⁴⁹ e como princípios eleitorais colidentes devem ser levados em consideração na configuração do direito eleitoral, é certo que o legislador tem uma discricionariedade considerável.¹⁵⁰ Mas de forma alguma está tudo à sua disposição. As competências do indivíduo – que têm que ser criadas pelo Estado, por meio de legislação ordinária, em virtude do art. 38, § 1º, da Constituição alemã, e a cuja existência os indivíduos têm um direito subjetivo com força constitucional – formam uma parcela considerável de seu status ativo no sentido clássico de Jellinek.

O problema é o quanto isso pode ser generalizado. Um exemplo que torna clara a dificuldade de generalização é o dever estatal, atribuível ao art. 9º, § 1º, da Constituição alemã, de criar normas de direito associativo, que, sempre e com razão, são inseridas no âmbito da “realização e assegurar dos direitos fundamentais por meio de organização e procedimento”. As competências fundamentadas pelas normas de direito associativo não pertencem ao status ativo clássico, porque elas não são competências para a “participação no Estado”, no sentido dado por Jellinek.¹⁵¹ Se se pretende, mesmo assim, considerá-las como parte do status ativo, é necessário ampliar esse conceito. Essa ampliação pode ocorrer de duas formas: por meio de sua ampliação a todas as competências jurídicas individuais ou por meio de sua extensão a todas as posições jurídicas cujo exercício, de alguma forma, tenha ou possa ter efeitos na formação da vontade estatal. Nem uma nem outra são, todavia, recomendáveis. Reunir em um único conceito todas as competências que os indivíduos têm em um sistema jurídico é, sem dúvida, algo interessante, mas para tanto não deve ser

149. *BVerfGE* 6, 104 (111).

150. *BVerfGE* 3, 19 (24-25).

151. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, pp. 136 e ss.

usado o conceito de status ativo. O sistema de Jellinek, focado na relação cidadão/Estado, seria destruído. Além disso, parece inconveniente incluir no status ativo todas as posições jurídicas cujo exercício, de alguma forma, possa ter efeitos na formação da vontade estatal, como, por exemplo, a liberdade jurídica de expressar sua opinião. Isso confundiria a distinção, tão importante para os sistemas jurídicos, entre as competências jurídicas que tenham como objeto a formação da vontade estatal e a liberdade jurídica de ter uma influência fática nessa vontade, distinção, essa, cuja manutenção é recomendável também para aqueles que se interessam sobretudo pela influência fática. Isso nada diz contra a possibilidade de reunir sob um único conceito os direitos que possibilitem, ou que devam possibilitar, uma influência – em seu sentido mais amplo – no processo de formação da vontade pública e/ou estatal. O que se defende é não perder de vista as diferenças teórico-estruturais que sejam importantes para a situação jurídica dos indivíduos, da qual sua situação fática em grande medida depende. Neste ponto, recomenda-se um conceito de status ativo orientado por questões teórico-estruturais, ou seja, um conceito restrito desse status. Para o conceito mais amplo pode ser utilizada a designação “direitos políticos”.

Diante disso, pode-se dizer que alguns, mas não todos, os objetos dos direitos a organização e procedimento pertencem ao status ativo. Isso leva à indagação acerca da existência de uma linha divisória entre as posições que pertencem ao status ativo e aquelas que não pertencem. A decisão no caso Mülheim-Kärlich¹⁵² parece ser adequada para um esclarecimento acerca desse problema da delimitação, sobretudo em razão dos distintos enfoques que o procedimento de autorização no âmbito do direito da energia atômica recebe na fundamentação da decisão majoritária e no voto divergente. As normas do procedimento de licença no âmbito do direito da energia atômica não conferem nenhuma competência de co-decisão popular. Essa competência, e, com isso, uma competência para a participação na formação da vontade estatal, no sentido dado por Jellinek, existiria apenas se os cidadãos afetados, ou seus representantes, fossem membros de um órgão que decidisse acerca da outorga de uma licença no âmbito do direito da exploração de energia atômica, ou se aos cidadãos afetados, ou a gru-

pos deles, fosse conferido um direito de veto. No entanto, as posições procedimentais dos cidadãos restringem-se a um feixe de direitos a informação e análise. O ponto central desses direitos é a competência para fazer objeções, cujo exercício fundamenta um dever de análise por parte do órgão responsável pelas licenças (§§ 7^a, 1, e 8^a, 1, do Regulamento sobre o Procedimento no Âmbito do Direito da Energia Atômica). Se e como essas objeções são levadas em consideração é algo que é decidido pelo próprio órgão responsável. Nesse sentido, o procedimento segue, em seus aspectos essenciais, o modelo clássico *audiatur et altera pars*, e não o modelo de votação. Se se vincula essa estrutura do procedimento ao objetivo a ele atribuído — isto é, a proteção de direitos individuais¹⁵³ —, tem-se, então, um argumento contra sua atribuição ao status ativo, no sentido dado por Jellinek.

Um cenário diverso é encontrado no voto divergente. Nele também se salienta o objetivo de proteção de direitos individuais e também se sublinha que “as prerrogativas decisórias do órgão competente [*têm*] que ser preservadas”. Mas é interessante a forma como o objetivo de proteção deve ser alcançado em conjunto com a manutenção de uma competência decisória das autoridades: “por meio de um processo de comunicação entre os exploradores das usinas nucleares, os cidadãos afetados e os órgãos competentes”, o qual deve garantir “uma consideração objetiva de todos os pontos de vista relevantes”.¹⁵⁴ Nesse contexto, fala-se também de uma “influência” dos participantes na decisão.¹⁵⁵ Essas manifestações foram interpretadas como uma tendência no sentido de um procedimento decisório de democracia direta e criticadas por causa da contradição entre a idéia de um tal procedimento e a idéia de direitos fundamentais.¹⁵⁶ O problema geral da relação entre direito fundamental e procedimento¹⁵⁷ será analisado mais adiante. Aqui interessa apenas um ponto de vista, salientado de forma procedente pelo voto divergente, bem como suas conseqüências para o problema da atribuição ao status ativo. O voto dissidente salienta, com

153. BVerfGE 53, 30 (64).

154. BVerfGE 53, 30 (77).

155. BVerfGE 53, 30 (76).

156. Cf. Fritz Ossenbühl, “Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts”, pp. 3 e 6.

157. Cf., por exemplo, Hans H. Rupp, “Vom Wandel der Grundrechte”, pp. 183 e ss.; Christian Starck, “Die Grundrechte des Grundgesetzes”, pp. 242-243.

razão, que o sentido da participação é possibilitar uma influência na decisão, por meio de um processo de comunicação. Se não houvesse a possibilidade fática de que, por meio da participação, se chegasse a outras decisões, as quais não seriam tomadas se participação não houvesse, então, essa participação seria um meio inadequado – e, portanto, sem sentido – para o objetivo da proteção ao direito fundamental. Assim, ela poderia servir apenas a objetivos não relacionados à proteção do direito fundamental, ou ao fim duvidoso de uma proteção do direito fundamental por meio de uma postergação da intervenção, não importa se legal ou ilegal. Partir-se-á, aqui, da hipótese de que, no que diz respeito à proteção do direito fundamental, a participação não é algo sem sentido. É possível afirmar que a participação cria juridicamente a possibilidade fática de uma influência no processo de formação da vontade estatal no que diz respeito à proteção do direito fundamental. Isso é menos que uma competência jurídica para a co-decisão na formação da vontade estatal, mas tem claramente mais relação com a formação da vontade estatal que a competência de direito privado para celebrar um contrato. Esse exemplo faz com que fique claro que, por mais que o conceito de status ativo, no sentido de Jellinek, constitua um ponto de partida irrenunciável para a compreensão das posições ligadas a procedimento e organização, nas áreas não abrangidas por esse conceito são necessárias diferenciações a serem levadas a cabo com o auxílio de instrumentos mais refinados.

5. Tipos de direitos a organização e procedimento

À variedade de formas e de conteúdos de organização e de procedimento no âmbito dos direitos fundamentais corresponde uma variedade de possibilidades para sua classificação. Uma classificação abrangente, que leve em consideração todas as formas e aspectos, somente é possível com base em uma dogmática detalhada dos direitos a organização e procedimento. Uma tal dogmática seria objeto de uma pesquisa à parte. Aqui, trata-se apenas de enfatizar os pontos de vista cuja análise seja útil, e por isso obrigatória, no âmbito de uma teoria geral da estrutura dos direitos fundamentais. Sob esse aspecto, e no que diz respeito ao objeto dos direitos, parece ser apropriada uma distinção em quatro grupos: (1) competências de direito privado; (2) procedimentos judiciais e administrativos (procedimento em

sentido estrito); (3) organização em sentido estrito; e (4) formação da vontade estatal.

5.1 Competências de direito privado

Direitos a competências de direito privado são direitos em face do Estado a que este crie normas constitutivas para as ações de direito privado e, com isso, constitutivas para a fundamentação, a modificação e a eliminação de posições jurídicas de direito privado. Esses direitos podem relacionar-se tanto à exigência de que essas normas existam quanto à exigência de que tenham um determinado conteúdo. Exemplos de complexos de normas que se inserem no âmbito desses direitos, e que são analisadas no contexto da realização e da asseguarção de direitos fundamentais,¹⁵⁸ são as normas de direito contratual, de propriedade, matrimonial, de sucessão e de associação.

Esses complexos de normas são exatamente aqueles que tradicional e apropriadamente são chamados de "institutos jurídicos". Isso suscita duas questões: (1) O que os institutos jurídicos de direito privado têm a ver com a idéia de procedimento? (2) Há direitos fundamentais a institutos jurídicos de direito privado, ou esses institutos são simplesmente protegidos por meio de uma garantia objetiva de institutos?

A conexão entre os institutos jurídicos de direito privado e a idéia de procedimento reside no fato de que os institutos jurídicos de direito privado são formados sobretudo de competências, que, em si mesmas, não delimitam substancialmente as esferas jurídicas dos sujeitos de direito privado, mas fundamentam a possibilidade jurídica de se realizar uma tal delimitação. Isso significa, no entanto, que elas são procedimentos para a criação do direito. E, como procedimento privado e autônomo de criação do direito, são elas variantes de um dos modelos básicos de procedimento, o modelo contratual.¹⁵⁹

Não tão fácil de ser respondida é a questão sobre se há de direitos subjetivos à existência de institutos jurídicos de direito privado, ou se

158. Cf. Konrad Hesse, "Bestand und Bedeutung der Grundrechte", p. 434; Christian Starck, "Staatliche Organisation und staatliche Finanzierung", p. 485.

159. Cf. Ralf Dreier, *Recht und Gerechtigkeit*, Weinheim/Basel: Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen (Funkkolleg Recht), 1982, pp. 28 e ss.

esses direitos são protegidos apenas objetivamente em face do legislador.¹⁶⁰ Desde os trabalhos de Martin Wolff¹⁶¹ e Carl Schmitt¹⁶² a proteção dos institutos jurídicos de direito privado é tratada, no âmbito dos direitos fundamentais, como um problema de uma garantia objetiva de institutos.¹⁶³⁻¹⁶⁴ Sob a Constituição de Weimar, em face do dilema “insignificância, de um lado, e ineficácia, de outro”,¹⁶⁵ essa doutrina tinha como objetivo garantir um pouco mais a precedência constitucional de determinados direitos fundamentais.¹⁶⁶ Com o art. 1º, § 3º, da Constituição alemã, o qual vincula também o legislador aos direitos fundamentais, como direitos de aplicação direta, essa razão para considerar as garantias institucionais como meras garantias objetivas desaparece. Com isso, abre-se o caminho para uma subjetivização da proteção constitucional das competências de direito privado, caminho, esse, que, da perspectiva dos direitos fundamentais, é obrigatório trilhar, como demonstrou Kloepper.¹⁶⁷⁻¹⁶⁸

160. Sobre esse ponto, cf. Capítulo 4, II.3.6.1.

161. Cf. Martin Wolff, “Reichsverfassung und Eigentum”, in Rudolf Smend (Org.), *Die politische Gewalt im Verfassungsstaat und das Problem der Staatsform: Festgabe für Wilhelm Kahl*, Tübingen: Mohr, 1923, pp. 5-6.

162. Cf. Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, pp. 170 e ss.; do mesmo autor, “Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der Reichsverfassung”, in Carl Schmitt, *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1973, pp. 140 e ss., 160 e ss.; do mesmo autor, “Grundrechte und Grundpflichten”, in idem, pp. 215-216.

163. Por “garantia de institutos” compreende-se, aqui, na esteira de Carl Schmitt, a garantia jurídico-constitucional de institutos jurídicos de direito privado, a qual deve ser distinguida da “garantia institucional”, que vale para instituições de direito público. Cf. Carl Schmitt, “Freiheitsrechte und institutionelle Garantien”, pp. 143, 149 e 160 e ss.

164. Sobre o estágio atual da discussão, cf. Edzard Schmidt-Jortzig, *Die Einrichtungsgarantien der Verfassung*, Göttingen: Schwartz, 1979.

165. Carl Schmitt, “Freiheitsrechte und institutionelle Garantien”, p. 141.

166. Cf. Walter Schmidt, “Grundrechtstheorie im Wandel der Verfassungsgeschichte”, pp. 174-175.

167. Cf. Michael Kloepper, *Grundrechte als Entstehungssicherung und Bestandsschutz*, pp. 37 e ss.

168. Algumas constituições estaduais demonstram que a idéia de direitos fundamentais a competências de direito privado não é algo estranho. Assim, o art. 45, § 1º, 3, da Constituição do Estado de Hessen prevê: “Todos têm o direito de adquirir propriedade e dela dispor, nos termos da lei”. Cf. também: art. 60, § 1º, 2, da Constituição do Estado da Renânia-Palatinado; art. 109, § 1º, 1, da Constituição do Estado da Baviera; bem como o art. 111, 2, da Constituição da República de Weimar.

O principal argumento para a subjetivização é o fato de que inúmeros direitos fundamentais pressupõem conceitualmente a existência de institutos jurídicos de direito privado. Sem as normas sobre propriedade não há propriedade em sentido jurídico; sem as normas do direito matrimonial não há matrimônio em sentido jurídico; etc. De forma procedente, o Tribunal Constitucional Federal salienta: "O direito fundamental do indivíduo pressupõe o instituto jurídico 'propriedade'".¹⁶⁹ Um legislador que eliminasse institutos jurídicos como o da propriedade e do matrimônio retiraria dos titulares dos direitos fundamentais algo a que eles têm um direito subjetivo.

A questão é saber, contudo, quem tem direito subjetivo a que normas. Um bom teste é oferecido pelas normas que possibilitam o surgimento de posições jurídicas de direito privado, ou seja, normas que fundamentam competências, por exemplo, para a aquisição da propriedade ou para contrair matrimônio. Segundo Klopfer, essas normas não protegem algo existente, mas garantem sua criação.¹⁷⁰ No que diz respeito a contrair matrimônio, o Tribunal Constitucional Federal fornece uma resposta clara. Ele atribui ao art. 6º, § 1º, da Constituição alemã um "direito à liberdade de contrair matrimônio".¹⁷¹ Isso significa que ao art. 6º, § 1º, deve ser atribuído, dentre outros, um direito à competência para contrair matrimônio com um parceiro livremente escolhido. Não tão simples é a questão no caso da competência para adquirir propriedade.¹⁷² Uma lei que tornasse impossível a aquisição de propriedade imóvel violaria o direito fundamental do art. 14 também de pessoas que não possuam propriedade imóvel? Klopfer responde afirmativamente, com o argumento de que "uma liberdade de alienar não é imaginável sem a liberdade de adquirir".¹⁷³ Mas da proteção da competência de alienar — à qual, sem dúvida, corresponde um

169. BVerfGE 24, 367 (389).

170. Cf. Michael Klopfer, *Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandsschutz*, pp. 24 e ss.

171. BVerfGE 36, 146 (161).

172. Sobre o estágio atual dessa polêmica, cf. Michael Klopfer, *Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandsschutz*, pp. 37 e ss.; Peter Wittig, "Der Erwerb von Eigentum und das Grundgesetz", *NJW* 20 (1967), pp. 2185 e ss.

173. Michael Klopfer, *Grundrechte als Entstehenssicherung und Bestandsschutz*, p. 47.

direito subjetivo no âmbito dos direitos fundamentais¹⁷⁴ – não se infere necessariamente uma correspondente proteção subjetiva da competência de adquirir. O direito subjetivo à competência de alienar pode ser fundamentado simplesmente a partir da constatação de que a competência de adquirir é protegida de forma meramente objetiva no âmbito de uma garantia institucional. O argumento decisivo para a subjetivização decorre muito mais de um pensamento procedimental. Na medida em que os direitos fundamentais garantem institutos jurídicos de direito privado, eles garantem procedimentos para a configuração autônoma e privada de relações jurídicas entre iguais. Tanto a idéia de equidade do procedimento quanto a idéia de liberdade individual no âmbito do direito da propriedade exigem que não apenas as posições de direito privado já existentes mas também a possibilidade jurídica de adquirir essas posições gozem de plena proteção no âmbito dos direitos fundamentais. Por isso, o art. 14 da Constituição alemã deve ser interpretado de modo a garantir um direito subjetivo também à competência para adquirir propriedade.

Essa última afirmação deve ser generalizada. Não há, antes, garantias institucionais objetivas que sirvam à asseguaração de direitos fundamentais por meio da garantia de um conjunto básico de normas para que, apenas depois, haja direitos fundamentais como direitos subjetivos a serem garantidos dessa forma; o que há, na verdade, é um direito subjetivo à existência das normas de direito privado que sejam necessárias para que aquilo que os direitos fundamentais garantem seja possível. Garantias institucionais revelam-se, assim, construções dogmáticas supérfluas. Isso não significa que não exista uma garantia de direito fundamental dos institutos jurídicos de direito privado. O fato de que *a* tenha, em face do Estado, um direito à existência das normas $N_1, \dots, N_n$, do instituto jurídico *I*, significa que o Estado tem o dever, em face de *a*, de zelar para que $N_1, \dots, N_n$ existam. Mas se o Estado tem o dever, em face de *a*, de zelar para que $N_1, \dots, N_n$ existam, então, ele tem o dever de zelar para que $N_1, \dots, N_n$ existam. Essa concepção não conduz, portanto, a uma menor garantia constitucional dos institutos jurídicos de direito privado. Ela acrescenta uma subjetivização à mera garantia objetiva. Esse acréscimo é imprescindível se se pretende levar a sério os direitos fundamentais como direitos individuais.

174. *BVerfGE* 26, 215 (222).

5.2 *Procedimentos judiciais e administrativos* (*procedimentos em sentido estrito*)

Direitos a procedimentos judiciais e administrativos são direitos essenciais a uma "proteção jurídica efetiva".¹⁷⁵ É condição de uma proteção jurídica efetiva que o resultado do procedimento proteja os direitos materiais dos titulares de direitos fundamentais envolvidos. A essa proteção de direitos materiais deve ser vinculada a fórmula do Tribunal Constitucional Federal, que descreve a tarefa do direito procedimental da seguinte forma: "O direito procedimental serve à produção de decisões que sejam conformes à lei e, por esse ponto de vista, corretas, mas, para além disso, de decisões que, no âmbito dessa correção, sejam justas".¹⁷⁶ Tudo isso indica que, no âmbito do procedimento, dois aspectos devem ser relacionados entre si: um procedimental e um material.

Há dois modelos fundamentalmente distintos para essa relação entre os aspectos procedimental e material. De acordo com o primeiro a correção do resultado depende somente do procedimento. Se o procedimento foi realizado de forma correta, então, o resultado é correto. Não há um parâmetro para a correção que seja independente do procedimento. Já de acordo com o segundo modelo existem parâmetros independentes do procedimento. O procedimento é tanto um meio de satisfazê-los na maior medida possível como uma forma de preencher a margem de discricionariedade por eles deixada.

Uma teoria procedimental geral deve ainda considerar outras diferenciações, especialmente aquelas que se relacionam a uma hierarquia dos procedimentos.¹⁷⁷ No entanto, o que está em questão, aqui, não é uma teoria procedimental geral, mas a análise da relação entre procedimentos legais e direitos fundamentais. Ao se fazer uma limitação a apenas esse ponto, é possível afirmar que apenas o segundo modelo é compatível com a idéia de direitos fundamentais. Direitos

175. Cf. *BVerfGE* 24, 367 (401); 35, 348 (361); 37, 132 (148); 39, 276 (294); 44, 105 (120); 45, 297 (322); 45, 422 (432); 46, 324 (334); 48, 292 (297); 49, 252 (256); 51, 150 (156); 53, 30 (64-65).

176. *BVerfGE* 42, 64 (73); cf. também *BVerfGE* 46, 325 (333); 49, 220 (226); 52, 131 (153).

177. Cf. Robert Alexy, "Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation", in *Rechtstheorie*, Beiheft 2 (1981), pp. 178 e ss.

fundamentais são, em alguns aspectos decisivos, não-procedimentais. Isso é perceptível com toda nitidez a partir de sua relação com o processo legislativo democrático. Nem tudo aquilo que pode ser resultado de discussões e votações no parlamento é possível na perspectiva dos direitos fundamentais. É certo que os direitos fundamentais, de um lado, garantem direta e indiretamente a participação no processo democrático. Nessa medida, eles são procedimentais. Mas, de outro lado, na medida em que estabelecem limites materiais a esse processo, eles são não procedimentais.

A idéia de que as exigências dos direitos fundamentais dirigidas ao procedimento não podem substituir suas exigências em relação ao resultado vale para todos os procedimentos jurídicos. Quando o voto divergente na decisão Mülheim-Kärlich considera “decisivo” que, “em si, o procedimento administrativo seja adequado, no caso concreto, para levar a decisões ‘corretas’ no que diz respeito à segurança”,¹⁷⁸ a isso não se pode vincular uma concepção segundo a qual o procedimento de licença no âmbito do direito da energia atômica – por mais que suas regras sejam interpretadas da forma mais conforme aos direitos fundamentais – garante, *enquanto procedimento*, um resultado correto na perspectiva dos direitos fundamentais. Isso pode ser percebido, dentre outras, por meio da constatação de que aquelas regras procedimentais não garantem, em primeiro lugar, um consenso entre todos os envolvidos e não garantem, em segundo lugar, que, respeitado o procedimento, a autoridade responsável pela licença alcançará sempre um resultado correto no âmbito dos direitos fundamentais, ou seja, que os cidadãos que, ao fim do procedimento, ainda defendam opinião distinta daquela da autoridade estejam necessariamente equivocados. Contudo, isso não significa que um tal procedimento seja inadequado para a proteção de direitos fundamentais. Mesmo que a conformidade do resultado aos direitos fundamentais não seja garantida pelo procedimento, há um aumento na *probabilidade* de um resultado nesse sentido. Por essa razão, procedimentos são necessários como meio de proteção aos direitos fundamentais. Mas é também claro que o mero aumento da probabilidade de um resultado conforme aos direitos fundamentais nunca poderá ser uma razão para se abrir

178. BVerfGE 53, 30 (76).

mão de um controle judicial da compatibilidade material dos resultados com as normas de direitos fundamentais.

O fato de que, no âmbito dos direitos fundamentais, as normas procedimentais não consigam realizar tudo não significa que elas devam ser subestimadas. Sempre que normas procedimentais puderem aumentar a proteção aos direitos fundamentais elas serão exigidas *prima facie* pelos princípios de direitos fundamentais. Se não houver princípios contrapostos, então, há um direito definitivo à sua aplicação. Assim, no que diz respeito à conexão entre direitos fundamentais e procedimentos legais, os aspectos procedimental e material devem ser reunidos em um modelo dual, que garanta a primazia do aspecto material.

Uma comparação entre os direitos a procedimentos em sentido estrito e os direitos a competências de direito privado faz com que fiquem claros os diferentes objetivos que são perseguidos no âmbito da organização e do procedimento. Enquanto os direitos a competências de direito privado asseguram sobretudo a possibilidade de que determinadas ações constitucionalmente garantidas possam ser realizadas, os direitos a procedimentos em sentido estrito servem especialmente à proteção de posições jurídicas existentes em face do Estado e de terceiros. Por isso, é possível tratar esses últimos também no âmbito dos direitos a proteção.¹⁷⁹ Sua análise neste momento é justificada pelo fato de que, do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais, seu aspecto procedimental é mais interessante que o da proteção.

5.3 Organização em sentido estrito

O terceiro grupo diz respeito às exigências que os direitos fundamentais impõem a áreas jurídicas como o direito do ensino superior, o direito da radiodifusão e o direito de co-gestão. A reunião de coisas tão distintas sob o conceito de organização em sentido estrito justifica-se porque elas têm algo em comum: elas regulam a ação conjunta de diversas pessoas na persecução de determinadas finalidades.

É necessário distinguir entre organização como um resultado da atividade legislativa, expressa por meio de normas organizacionais, e organização como uma unidade jurídica. Neste ponto, o que está em

179. Cf., neste capítulo, II.

questão são os direitos individuais, dirigidos ao legislador, à existência de normas de organização. Esses direitos, por sua vez, devem ser distinguidos, de um lado, dos direitos das organizações em face do legislador e, de outro lado, dos direitos dos indivíduos em face das organizações. Os direitos individuais à organização em sentido estrito, dirigidos ao legislador, são direitos dos indivíduos a que o legislador crie normas de organização que sejam conformes aos direitos fundamentais. Uma organização legislativa conforme aos direitos fundamentais pode ser assegurada não apenas por direitos subjetivos, mas também por deveres e proibições meramente objetivos. Na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal é possível encontrar ambos. No âmbito do amplo campo de problemas relativos às organizações exigidas pelos direitos fundamentais, aqui, mais uma vez interessa apenas a dicotomia subjetivo/objetivo.

É uma concepção corrente na dogmática dos direitos fundamentais que os direitos fundamentais têm duas faces, uma subjetiva e uma objetiva. Mas o que são exatamente essas faces é algo que está longe de ser claro.¹⁸⁰ O presente contexto exige que sejam feitas duas diferenciações. A primeira é uma diferenciação entre *normas*; e a segunda, entre *razões* para normas.

Normas podem outorgar direitos subjetivos, ou não. Como já foi demonstrado anteriormente,¹⁸¹ direitos subjetivos são relações jurídicas entre dois sujeitos de direitos. Se *a* tem um direito em face do Estado a que este garanta uma determinada organização (*RasG*),¹⁸² então, o Estado tem, em face de *a*, o dever de garantir uma determinada organização (*OsaG*). Esse dever relacional¹⁸³ implica um outro dever, não-relacional. Se o Estado tem, em face de *a*, o dever de garantir uma determinada organização (*OsaG*), então, ele tem o dever de garantir uma determinada organização (*OsG*). Todo direito subjetivo implica, portanto, um dever não-relacional e, nesse sentido, *objetivo*. Mas a recíproca não é verdadeira. Do fato de que o Estado tenha um dever (*OsG*) não decorre que haja um sujeito de direito em face do qual esse dever exista. A questão principal sobre a dicotomia subjetivo/ob-

180. Cf. Jürgen Schwabe, *Problem der Grundrechtsdogmatik*, pp. 286 e ss.

181. Cf. Capítulo 4, II.1.1.

182. Sobre essa forma de apresentação, cf. Capítulo 4, II.1.1.

183. Sobre isso, cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

jetivo pode ser formulada da seguinte maneira: em que medida a organização requerida pelos direitos fundamentais é exigida por normas que outorgam direitos subjetivos, e em que medida por normas que fundamentam apenas um dever objetivo do Estado?

A resposta a essa pergunta depende dos fundamentos possíveis para as normas de direitos fundamentais relativas a organização. Os fundamentos possíveis podem ser classificados em dois grupos. Os fundamentos do primeiro grupo estão ligados à importância que a organização requerida pelas normas de direitos fundamentais tem para o *indivíduo*, para sua situação de vida, seus interesses, sua liberdade etc. Os fundamentos do segundo grupo estão ligados à importância que a organização requerida pelas normas de direitos fundamentais tem para a *coletividade*, ou seja, para os interesses ou bens coletivos. Uma fundamentação do primeiro tipo pode ser denominada "individualista" e, nesse sentido, "*subjetiva*"; uma fundamentação do segundo tipo é não-individualista e, nesse sentido, *objetiva*. Quando se associam ambas as fundamentações, surge a pergunta acerca de como a relação entre elas deve ser definida.

Seria possível sustentar que a relação entre ambos os tipos de fundamentação e entre ambas as espécies de normas consiste simplesmente no fato de que da natureza objetiva ou subjetiva da fundamentação sempre se infere uma natureza objetiva ou subjetiva da norma. Contudo, as coisas não são assim tão simples. Aquele que fundamenta o dever do legislador de assegurar uma organização conforme aos direitos fundamentais exclusivamente – ou especialmente – por meio da referência a interesses coletivos concluirá que ela tem natureza meramente objetiva. Já aquele que a fundamenta por meio de uma referência à liberdade individual pode concluir – como claramente ocorreu na decisão sobre o ensino superior – por um direito subjetivo do titular do direito fundamental "àquelas medidas estatais, também de caráter organizacional, que sejam imprescindíveis para a proteção de sua esfera de liberdade constitucionalmente protegida",¹⁸⁴ mas essa não é uma conclusão necessária. É possível tentar fundamentar uma norma meramente objetiva a partir de uma fundamentação subjetiva de duas maneiras distintas. A primeira estratégia utiliza-se da diferença, sublinhada por Häberle, entre interesse de direito fundamental e direito fun-

damental.¹⁸⁵ O que as normas de organização requeridas pelos direitos fundamentais devem assegurar ao indivíduo é, em geral, apenas seu *interesse de direito fundamental*. Para sua garantia não é necessária, em regra, a outorga de direitos subjetivos à organização. A segunda estratégia também parte do pressuposto de que uma organização requerida por um direito fundamental está sempre a serviço do indivíduo, mas que isso com frequência é assim porque ela está a serviço do indivíduo como *membro de uma coletividade* de indivíduos, razão pela qual não se pode falar, em geral, de direitos subjetivos do indivíduo a uma organização.

Para esclarecer os problemas relacionados ao que foi dito, vale a pena uma olhada nas três decisões sobre televisão, dos anos de 1961, 1971 e 1981.¹⁸⁶ Nas três decisões pressupõe-se um dever do legislador de, “por meio de intervenções legislativas, assegurar a liberdade da radiodifusão”.¹⁸⁷ Nesse caso, considera-se liberdade da radiodifusão um *estado* no âmbito do sistema televisivo, que consiste em uma radiodifusão livre do Estado e pluralista.¹⁸⁸ É, ao mesmo tempo, típico e adequado que, na primeira decisão sobre televisão, a organização legislativa seja descrita como um “meio” para se alcançar esse “fim”.¹⁸⁹

Aqui não há espaço para abordar os inúmeros problemas associados a essas três decisões. O foco deverá estar direcionado às diferentes ênfases das faces objetiva e subjetiva nas três decisões. Nas duas primeiras a face objetiva domina. A liberdade da radiodifusão é caracterizada como “liberdade institucional”.¹⁹⁰ Não se faz apenas uma menção geral à sua “importância fundamental para a totalidade da vida pública, política e jurídico-constitucional nos Estados Federados”; dessa tese da importância são derivadas também consequências objetivas, a saber: que o “conteúdo do art. 5º da Constituição” fundamenta uma “posição jurídico-constitucional do Estado-membro no Estado Federal”, que consiste na possibilidade de que os Estados-membros exijam da União a garantia da liberdade da radiodifusão.¹⁹¹ Isso tem

185. Cf. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, p. 122.

186. BVerfGE 12, 205; 31, 314; 57, 295.

187. BVerfGE 57, 295 (322).

188. BVerfGE 12, 205 (265-266); 57, 295 (323).

189. BVerfGE 12, 205 (261).

190. BVerfGE 12, 205 (261-262); 31, 314 (326).

191. BVerfGE 12, 205 (259).

pouco a ver com direitos subjetivos individuais. Em um sentido objetivo se avança também quando, na decisão de 1971, se fala em uma "natureza especial da radiodifusão, como uma atividade com deveres perante a comunidade",¹⁹² e quando se fala que as emissoras desempenham uma "tarefa de direito público".¹⁹³

Já a decisão de 1981 é marcada por um claro enfraquecimento da face objetiva e um fortalecimento da face subjetiva. No âmbito da organização da radiodifusão a face subjetiva pode ter no mínimo quatro raízes: (1) direitos dos indivíduos a exercer a atividade de radiodifusão; (2) direitos dos indivíduos de se informar e de formar sua própria opinião; (3) direitos dos que trabalham na radiodifusão; e (4) direitos de grupos sociais de poder se expressar por meio da radiodifusão. Essa variedade de referências subjetivas é refletida na decisão, quando se afirma que na configuração legislativa da radiodifusão o que está em questão é criar um equilíbrio nas colisões entre "posições de direitos fundamentais"; como exemplos são mencionados, de um lado, a "pretensão, decorrente da liberdade de informação, a uma informação abrangente e conforme à verdade e, de outro lado, a liberdade de manifestação do pensamento daqueles que organizam a programação ou que se expressam nas emissões".¹⁹⁴ Chama também a atenção o fato de que a liberdade de radiodifusão é caracterizada, em passagem sistematicamente central, não mais como "institucional", mas como "liberdade instrumental".¹⁹⁵ Isolar esse conceito de seu contexto pode dar ensejo a diversas confusões. Uma liberdade instrumental, por definição, não é a liberdade negativa, no âmbito da qual se pode fazer ou deixar fazer o que se queira, não importa o quão estreitos sejam seus limites. Como a liberdade constitucional é, em sua essência, uma liberdade negativa, o conceito de liberdade instrumental não pode ser retirado de seu contexto, no âmbito do qual sua aplicação faz sentido. Esse contexto se faz presente quando se entende "liberdade de radiodifusão" como uma situação de liberdade em face do Estado e de pluralismo, e quando essa situação é vista como um meio a ser-

192. BVerfGE 31, 314 (328).

193. BVerfGE 31, 314 (329). Crítica a esse respeito é a opinião dissidente nessa mesma decisão - cf. BVerfGE 31, 314 (340 e ss.).

194. BVerfGE 57, 295 (321).

195. BVerfGE 57, 295 (320).

viço da finalidade de “liberdade na formação da opinião”.¹⁹⁶ Tudo isso teria muito pouco a ver com uma ênfase do subjetivo se “liberdade na formação da opinião” significasse exclusivamente um processo objetivo. Mas o tribunal deixa claro que não é esse o caso. Ele não fala de uma “livre formação da opinião pública”, mas de uma “livre formação das opiniões individual e pública”.¹⁹⁷ Além disso, é instrutivo comparar a tese da importância, da primeira decisão sobre televisão, com a formulação da terceira decisão. Na primeira, falava-se da “importância para a totalidade da vida pública, política e jurídico-constitucional”.¹⁹⁸ Na terceira, fala-se da “importância (...) para a vida *individual* e pública”.¹⁹⁹ Tudo isso mostra que o dever do Estado de zelar por uma radiodifusão livre do controle estatal e pluralista é fundamentado não apenas de forma objetiva, mas também, e em grande medida, de forma subjetiva; mas aqui, para não tornar as coisas mais complicadas, serão analisadas, como razões subjetivas, apenas as liberdades de formação da opinião e de informação.

Fundamentar o dever estatal por meio desses argumentos – dentre outros – significa que a ele correspondem direitos subjetivos? A “pretensão, decorrente da liberdade de informação, a uma informação abrangente e conforme à verdade”, à qual o tribunal faz menção,²⁰⁰ inclui um direito do cidadão, contra o Estado, a que este organize a radiodifusão de uma tal forma que predominem a liberdade em relação ao controle estatal e o pluralismo; um direito que não precisa ser tão abrangente quanto o dever, já que o dever pode ainda ser sustentado por outras razões (subjetivas e/ou objetivas), mas que seja exigível judicialmente? As opiniões divergem. Assim, contra um “direito de ação em matéria de pluralismo”, Bethge levanta a objeção da ação popular. Um tal direito de ação colocaria o indivíduo na posição de um “funcionário da ordem jurídica objetiva”.²⁰¹ Rupp, por sua vez, considera no mínimo possível “que o art. 5º, § 1º, 2, da Constituição alemã confira, a qualquer um, um direito a uma organização do mo-

196. Idem.

197. Idem.

198. *BVerfGE* 12, 205 (259).

199. *BVerfGE* 57, 295 (321) – sem grifos no original.

200. Idem.

201. Herbert Bethge, “Rechtsschutzprobleme eines rundfunkspezifischen Pluralismus”, *Ufita* 81 (1978), p. 92.

nopólio da informação que garanta a liberdade”, porque “uma organização constitucionalmente consistente da radiodifusão não serve apenas ao interesse geral, mas primariamente ao interesse de todos os indivíduos”.²⁰² Já Starck sustenta um direito do cidadão, exigível judicialmente, “a uma organização da radiodifusão e a um procedimento para a composição de seus órgãos diretores que garanta uma programação equilibrada”.²⁰³

É necessário concordar com o pressuposto do Tribunal Constitucional Federal segundo o qual os direitos fundamentais são, “em primeira instância, direitos individuais”. Utilizando-se ainda das palavras do tribunal: “A função dos direitos fundamentais, como princípios objetivos, consiste no fortalecimento básico de sua força de validade, mas tem sua raiz nesse significado primário. Por isso, não é possível afastá-los de seu núcleo propriamente dito para transformá-los em um conjunto de normas objetivas, no qual o sentido original e permanente dos direitos fundamentais é deixado em segundo plano”.²⁰⁴ Se se leva a sério a tese de que os direitos fundamentais são, em primeira instância, direitos subjetivos, não é possível escapar de uma segunda tese: se uma liberdade individual é protegida pelos direitos fundamentais, então, essa proteção tem em princípio a forma de um direito subjetivo. Mas isso significa que, em princípio, ao dever de organização do Estado correspondem direitos individuais na extensão em que a organização é obrigatória ao Estado, porque a proteção da liberdade dos indivíduos assim exige. Por isso, na medida em que uma organização da radiodifusão livre do controle estatal e pluralista é requerida pela liberdade de formação da opinião e pela liberdade de informação dos indivíduos, o Estado não está sujeito apenas a um dever objetivo; a esse dever corresponde um direito subjetivo dos indivíduos afeta-

202. Hans H. Rupp, “Urteilsanmerkung”, *JZ* 34 (1979), p. 29.

203. Christian Starck, “Teilhabeanprüche auf Rundfunkkontrolle und ihre gerichtliche Durchsetzung”, in *Studienkreis für Presserecht und Pressefreiheit* (Orgs.), *Presserecht und Pressefreiheit; Festschrift für Martin Löffler*, München: Beck, 1980, p. 388. Starck fundamenta esse direito não apenas na liberdade de informação, mas também na socialização da liberdade de radiodifusão. Além disso, defende ele uma subjetivização primordialmente em relação a um direito de grupos socialmente relevantes à representação nos conselhos de radiodifusão (p. 384). Como aqui interessa apenas a estrutura geral de uma subjetivização, não serão analisadas essas possibilidades adicionais.

204. *BVerfGE* 50, 291 (337).

dos. Mas, se existem direitos subjetivos, então, a objeção da ação popular deixa de ser procedente. O demandante individual não age como funcionário da ordem jurídica objetiva, mas com o intuito de fazer valer seus direitos.

Permanecem os dois argumentos, mencionados anteriormente, contra a inferência de uma norma subjetiva (isto é, uma norma que garanta um direito subjetivo) a partir de uma fundamentação subjetiva (isto é, uma fundamentação baseada em uma liberdade individual). O primeiro argumento tenta traçar uma linha divisória entre interesses de direitos fundamentais e direitos fundamentais; o segundo faz referência à impossibilidade de individualização.

Diante do primeiro argumento é necessário conceder que a importância de uma proteção constitucional do indivíduo pode ser tão pequena e/ou os efeitos da organização no indivíduo tão indiretos, que o reconhecimento de um direito subjetivo – como a forma mais forte de proteção – não seja obrigatório e que a mera proteção objetiva seja suficiente. No entanto, aceitar uma mera proteção objetiva é algo que depende de fundamentação. Em princípio, um direito subjetivo, no mínimo sob a forma de um direito *prima facie*, deve ser reconhecido.

O segundo argumento sugere que, embora uma organização requerida por um direito fundamental sempre sirva, em última análise, ao indivíduo, isso é assim frequentemente porque ela serve a ele como membro de uma comunidade de indivíduos, o que excluiria o reconhecimento de um direito individual. Um aspecto desse argumento pode ser encontrado em Ossenbühl, que afirma: “quando *todos* são afetados em igual medida, não se pode mais falar em uma afetação *individual*”.²⁰⁵ Essa afirmação não pode significar que sempre que todos os indivíduos de uma classe sejam afetados, então, não é afetado cada indivíduo isolado, porque o último decorre logicamente do primeiro. O que se pode querer dizer é que os indivíduos isolados não são afetados sozinhos, mas em conjunto com outros indivíduos. Mas isso não exclui a possibilidade de violação de direitos subjetivos individuais. Por meio da criação de um canal de TV estatal no qual apenas um grupo social possa se expressar, todos seriam afetados. Mas disso não decorre que um direito de cada indivíduo à liberdade em face do controle

205. Fritz Ossenbühl, “Kernenergie im Spiegel des Verfassungsrechts”, p. 7.

estatal e um direito ao pluralismo na radiodifusão não possam ser violados. Levar a sério os direitos fundamentais como direitos individuais exclui toda forma de argumentação a partir de uma coletividade. O argumento da coletividade não pode, portanto, afetar a tese segundo a qual o indivíduo, quando protegido pelos direitos fundamentais, não é protegido, em princípio, por meras normas objetivas, mas por direitos subjetivos.

5.4 Formação da vontade estatal

O quarto grupo é formado por direitos em face do Estado a que este, por meio de legislação ordinária, crie procedimentos que possibilitem uma participação na formação da vontade estatal. O principal exemplo é o direito do art. 38, § 1º, da Constituição alemã a uma regulação constitucionalmente compatível, e por meio de legislação ordinária, da competência para votar. O direito a uma competência é, como já foi salientado, um direito do status positivo, não do status ativo. Seu objeto é uma prestação normativa do Estado. Mas essa prestação normativa consiste em inserir juridicamente o indivíduo em uma situação para exercer a competência de votar, que pertence ao status ativo.

A distinção entre o direito a uma regulação, por meio de legislação ordinária, da competência para votar, dirigido ao legislador, e a própria competência para votar torna especialmente clara a conexão entre direitos fundamentais e procedimento democrático.

Em virtude da competência para votar, o titular dessa competência é, ainda que de forma indireta,²⁰⁶ um participante na legislação. Em virtude do direito a uma regulação constitucionalmente compatível, e por meio de legislação ordinária, dessa competência, pode ele ser um adversário do legislador, porque seu direito fundamental impõe limites à sua competência legislativa. Esse duplo aspecto é aplicável a todos os direitos fundamentais que possam ser exercidos com a finalidade de participar no processo de formação da vontade legislativamente relevante; ele é aplicável também, por exemplo, ao direito à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião e à li-

206. Cf., por todos, Fritz Scharpf, *Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung*, Konstanz: Universitätsverlag, 1970, pp. 29 e ss.

berdade de associação. Eles abrem, de um lado, a possibilidade de uma participação no processo de formação da vontade legislativamente relevante e, de outro lado, enquanto direitos fundamentais, impõem restrições à competência do legislador. Na medida em que possam ser exercidos para finalidades outras que não a participação no processo de formação da vontade legislativamente relevante, os direitos fundamentais dizem respeito somente a esse último aspecto. Isso já demonstra que direitos fundamentais, quando garantem o procedimento democrático, expressam uma confiança em sua racionalidade; mas também que essa confiança não é ilimitada. Nesse sentido, há tanto uma conexão intrínseca quanto uma relação de tensão entre os direitos fundamentais e o princípio democrático.

IV – DIREITOS A PRESTAÇÃO EM SENTIDO ESTRITO (DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS)

1. Conceito e estrutura

Direitos a prestação em sentido estrito são direitos do indivíduo, em face do Estado, a algo que o indivíduo, se dispusesse de meios financeiros suficientes e se houvesse uma oferta suficiente no mercado, poderia também obter de particulares. Quando se fala em direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, direitos à assistência à saúde, ao trabalho, à moradia e à educação, quer-se primariamente fazer menção a direitos a prestação em sentido estrito.

É necessário diferenciar entre direitos a prestações previstos de forma expressa, como aqueles encontrados em uma série de Constituições estaduais, e direitos a prestação atribuídos por meio de interpretação. Às vezes a expressão “direitos fundamentais sociais” é reservada para os primeiros, enquanto os últimos são denominados como “direitos fundamentais a prestações”²⁰⁷ ou “interpretações sociais dos direitos de liberdade e igualdade”.²⁰⁸ A diferença entre os direitos a prestações expressamente garantidos e aqueles atribuídos por meio de

207. Jörg Lücke, “Soziale Grundrechte als Staatszielbestimmungen und Gesetzgebungsaufträge”, *AöR* 107 (1982), p. 31.

208. Wolfgang Martens, “Grundrechte im Leistungsstaat”, *VVDStRL* 30 (1972), p. 12.

interpretação é, sem dúvida, importante. Já, no que diz respeito a seu conteúdo,²⁰⁹ sua estrutura²¹⁰ e seus problemas,²¹¹ há uma ampla coincidência entre ambas as categorias. Isso justifica designar todos os direitos a prestações em sentido estrito como “direitos fundamentais sociais” e, no interior da classe dos direitos fundamentais sociais, diferenciar entre aqueles expressamente garantidos e aqueles atribuídos por meio de interpretação.²¹²

Já se demonstrou que a Constituição alemã, com pouquíssimas exceções, não contém direitos fundamentais sociais formulados de maneira expressa; mesmo assim discute-se, com grande empenho e veemência,²¹³ se, e em caso afirmativo, quais direitos fundamentais sociais são por ela garantidos.²¹⁴ Essa polêmica, suficientemente alimentada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, é uma polêmica sobre a obrigação ou vedação de se atribuir²¹⁵ aos dispositivos de direitos fundamentais normas que garantam direitos fundamentais sociais. Saber se uma tal atribuição é obrigatória do ponto de vista do direito constitucional ou se é, do mesmo ponto de vista, vedada, depende de se saber se as melhores razões jurídico-constitucionais militam a favor da obrigatoriedade ou da vedação. A qualidade das razões só pode ser determinada quando se sabe para quê elas são razões. Por isso, é necessário, em primeiro lugar, analisar os candidatos a essa atribuição.

As normas a serem atribuídas aos dispositivos de direitos fundamentais sob a rubrica “direitos fundamentais sociais” são de tipos os mais distintos. A partir de pontos de vista teórico-estruturais, elas podem ser diferenciadas com base em três critérios. Em primeiro lugar, pode-se tratar de normas que garantam direitos *subjektivos* ou normas que apenas obriguem o Estado de forma *objetiva*. Em segundo lugar, elas podem ser normas *vinculantes* ou *não-vinculantes* – neste último

209. Idem, p. 30.

210. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Die sozialen Grundrechte im Verfassungsgefüge”, in Ernst-Wolfgang Böckenförde et al. (Orgs.), *Soziale Grundrechte*, Heidelberg: Müller, 1981, p. 12.

211. Jörg Paul Müller, *Soziale Grundrechte in der Verfassung?*, 2ª ed., Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1981, p. 166.

212. Cf. Josef Isensee, “Verfassung ohne soziale Grundrechte”, p. 373.

213. Cf. a bibliografia em Karl Hernekamp (Org.), *Soziale Grundrechte*, Berlin: de Gruyter, 1979, pp. 235 e ss.

214. Cf., neste capítulo, I.3.

215. Sobre o conceito de atribuição, cf. Capítulo 2, II.2.

sentido seriam elas enunciados programáticos. Uma norma deve ser considerada como “vinculante” se for possível uma análise de sua violação por meio do Tribunal Constitucional Federal. As normas podem, por fim, fundamentar direitos e deveres *definitivos* ou *prima facie*, isto é, regras ou princípios. Se se combinam esses critérios, obtêm-se oito normas de estrutura bastante diversa, que podem ser representadas da seguinte forma:

vinculante				não-vinculante			
subjeto		objetivo		subjeto		objetivo	
def.	p.f.	def.	p.f.	def.	p.f.	def.	p.f.
1	2	3	4	5	6	7	8

A proteção mais intensa é garantida pelas normas vinculantes que outorgam direitos subjetivos definitivos a prestações (1); a proteção mais fraca, pelas normas não-vinculantes que fundamentam apenas um dever estatal objetivo *prima facie* à realização de prestações (8). As diversas teses teórico-normativas que são sustentadas no âmbito dos direitos fundamentais sociais devem ser compreendidas à luz da tabela acima. Quatro exemplos: de acordo com Hesse, da “compreensão dos direitos fundamentais como normas objetivas supremas” resulta “para o legislador (...) uma obrigação (positiva) de fazer de tudo para realizar os direitos fundamentais, mesmo que não haja para tanto um direito subjetivo do cidadão”.²¹⁶ Com isso, quer-se fazer referência a obrigações objetivas *prima facie* vinculantes (4). von Mutius classifica o “direito de participação” originário, suscitado na primeira decisão *numerus clausus*, como “pretensões constitucionais a prestações”, que devem ser compreendidas como *leges imperfecta*, como “meros enunciados programáticos”.²¹⁷ Isso pode ser interpretado no sentido

216. Konrad Hesse, “Grundrechte: Bestand und Bedeutung”, in Ernst Benda *et al.* (Orgs.), *Handbuch des Verfassungsrechts*, Berlin: de Gruyter, 1983, p. 95.

217. Albert v. Mutius, “Grundrechte als ‘Teilhaberechte’ – zu den verfassungsrechtlichen Aspekten des *numerus clausus*”, *VerwArch* 64 (1973), p. 193.

de um direito subjetivo definitivo não-vinculante (5).²¹⁸ O Tribunal Constitucional Federal fala de um "direito a ser admitido no curso universitário de sua escolha", que, embora conferido, em princípio, ao cidadão que tenha concluído o ensino médio, está sob a "reserva do possível".²¹⁹ Como será ainda analisado em detalhes, esse direito deve ser visto como um direito subjetivo *prima facie* vinculante (2). Por fim, um direito subjetivo definitivo vinculante (1) é o direito a um mínimo existencial.²²⁰

As diferenças estruturais somam-se diferenças substanciais. Especialmente importante é a diferença entre um conteúdo *minimalista* e um *maximalista*.²²¹ O programa minimalista tem como objetivo garantir "ao indivíduo o domínio de uma espaço vital e de um status social mínimos",²²² ou seja, aquilo que é chamado de "direitos mínimos" e "pequenos" direitos sociais".²²³ Já um conteúdo maximalista pode ser percebido quando se fala de uma "realização completa" dos direitos fundamentais,²²⁴ ou quando se caracteriza o direito à educação como "pretensão a uma emancipação intelectual e cultural voltada à individualidade, à autonomia e à plena capacidade político-social".²²⁵

A diversidade acima esboçada dá ensejo à suposição de que o problema dos direitos fundamentais sociais não pode ser resumido a uma questão de tudo-ou-nada. Parece inevitável que diferenciações

218. Já os "enunciados programáticos vinculantes", suscitados por Krebs, poderiam ser vistos como normas que fundamentam deveres objetivos *prima facie* vinculantes. Cf. Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, p. 92.

219. *BVerfGE* 43, 291 (314-315).

220. Sobre isso, cf., neste capítulo, I.2.

221. Sobre essa distinção, cf., com diversas referências adicionais, Rüdiger Breuer, "Grundrechte als Anspruchsnormen", p. 95.

222. Luzius Wildhaber, "Soziale Grundrechte", p. 385.

223. Jörg Paul Müller, *Soziale Grundrechte in der Verfassung?*, p. 183; cf. também Jörg Lücke, "Soziale Grundrechte als Staatszielbestimmungen und Gesetzgebungsaufträge", p. 18.

224. Karl H. Friauf, "Zur Rolle der Grundrechte im Interventions- und Leistungsstaat", *DVB* 86 (1971), p. 676; Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, p. 122.

225. Lutz R. Reuter, "Soziale Grundrechte auf Bildung?", *DVB* 89 (1974), p. 12; cf. também Klaus Grimmer, *Demokratie und Grundrechte*, p. 259; Klaus-Dieter Heymann/Ekkehart Stein, "Das Recht auf Bildung", *AöR* 97 (1972), pp. 189 e ss.

sejam feitas.²²⁶ A partir desse pano de fundo, é necessária uma breve análise dos argumentos favoráveis e contrários aos “direitos fundamentais sociais”. A expressão “direitos fundamentais sociais” será utilizada como um supraconceito para as normas dos tipos (1) a (8). O objetivo é o desenvolvimento de uma proposta, baseada na teoria dos princípios²²⁷ e na idéia guia de caráter formal apresentada anteriormente,²²⁸ que leve em consideração tanto os argumentos favoráveis quanto os contrários.

2. *Sobre os argumentos contrários e favoráveis aos direitos fundamentais sociais*

O principal argumento a favor dos direitos fundamentais sociais é um argumento baseado na liberdade. Seu ponto de partida são duas teses.

A primeira sustenta que a liberdade *jurídica*, isto é, a permissão jurídica de se fazer ou deixar de fazer algo, não tem valor sem uma liberdade *fática* (real), isto é, a possibilidade fática de escolher entre as alternativas permitidas.²²⁹ A formulação dessa tese é bastante geral. Mas ela é ao menos necessariamente correta se interpretada de forma a que liberdade jurídica de *a* de realizar, ou não, a ação *h* não deixa de ter valor – no sentido de ser inútil – para *a* se *a*, por razões fáticas, não tem a possibilidade de escolher entre a realização e a não-realização de *h*.²³⁰

226. Sobre a necessidade de diferenciações, cf. Dieter Lonrenz, “Bundesverfassungsgericht und soziale Grundrechte”, *JBl* 1981, pp. 19-20; Walter Schmidt, “Soziale Grundrechte im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland”, p. 22; Rüdiger Breuer, “Grundrechte als Anspruchsnormen”, p. 93.

227. Cf. Capítulo 3, I.2.

228. Cf., neste capítulo, I.5.

229. Sobre os conceitos de liberdade jurídica e liberdade fática, cf. Capítulo 4, II.2.2.

230. As reflexões a seguir demonstram a necessidade de inúmeras diferenciações na tese geral segundo a qual a liberdade jurídica não teria valor sem uma liberdade fática. (1) O fato de todos terem a liberdade jurídica de escolher entre *h* e $\neg h$ pode ter valor para *a*, ainda que ele próprio não tenha a possibilidade fática de realizar essa escolha, pois *a* se beneficia do fato de que os outros têm essa possibilidade de escolha; (2) Uma liberdade jurídica de *a* pode ter valor para ele, mesmo que *a* não tenha, no presente, a possibilidade fática de exercer essa liberdade, porque ele tem a chance de poder exercê-la no futuro; (3) *a* pode considerar como valiosa sua liberdade jurídica de escolher entre *h* e $\neg h$ ainda que essa liberdade seja inútil para ele, em razão de uma ausência de liberdade fática. Ele considera, então, a liberdade jurídica

É a essa constatação que Lorenz von Stein faz referência quando afirma: "A liberdade é real apenas para aquele que tem as condições para exercê-la, os bens materiais e intelectuais que são pressupostos da autodeterminação",²³¹ ou quando o Tribunal Constitucional Federal decide que "o direito de liberdade não teria valor sem os pressupostos fáticos para o seu exercício".²³²

A segunda tese defende que, sob as condições da moderna sociedade industrial, a liberdade fática de um grande número de titulares de direitos fundamentais não encontra seu substrato material em um "espaço vital por eles controlado";²³³ ela depende sobretudo de atividades estatais.²³⁴ Com algumas qualificações adicionais,²³⁵ é possível concordar também com essa tese.

como um fim em si mesmo; (4) A necessidade de inúmeras diferenciações adicionais decorre do fato de as liberdades fáticas freqüentemente não serem uma questão de tudo-ou-nada, mas uma questão de grau. Assim, supondo leve uma vida normal, é possível que para *a* a liberdade jurídica de escolher entre *h* e $\neg h$ seja inútil mas que ele, caso abra mão de muito daquilo que é considerado como parte de uma vida normal, tenha a possibilidade fática dessa escolha.

231. Lorenz von Stein, *Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage*, v. 3 (Ausg. Salomon), München: Drei Masken, 1921 (nova edição, Darmstadt, 1959), p. 104.

232. BVerfGE 33, 303 (331).

233. Ernst Forsthoff, *Verfassungsprobleme des Sozialstaats*, Münster: Aschendorff, 1954, p. 6.

234. Cf., por todos, Ernst-Wolfgang Böckenförde, *Staat, Gesellschaft, Freiheit*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976, pp. 76-77; do mesmo autor, "Die sozialen Grundrechte im Verfassungsgefüge", pp. 8-9; Ulrich Scheuner, "Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat", DÖV 24 (1971), p. 511.

235. Importante é o alerta de Schwabe (Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 257 e ss.), segundo o qual, embora seja possível constatar uma perda de "espaço vital controlado", se se compara o tipo ideal do burguês do século XIX com o cidadão médio atual, a tese baseada nessa perda suscita algumas dificuldades se se compara o cidadão médio dos séculos XIX e XX. Isso certamente justifica uma objeção contra fundamentar a necessidade de direitos fundamentais sociais a partir de uma mudança na situação de vida do cidadão médio do século XX em comparação com a do cidadão médio do século XIX, mas não justifica uma objeção contra fundamentar essa necessidade com base na situação do indivíduo na sociedade industrial. E é preciso ir ainda além. Também nas sociedades não industrializadas é possível que o "espaço vital controlado" de inúmeros cidadãos seja tão pequeno que dê ensejo à proposta de se garantir sua situação por meio de direitos fundamentais sociais. Mas isso não é contrário à constatação de que nas sociedades industriais são necessárias ações estatais para impedir uma desvinculação muito ampla entre a liberdade jurídica garantida e a liberdade fática de muitos.

Mas essas teses não podem ser mais que apenas um ponto de partida de um argumento a favor dos direitos fundamentais sociais. Isso é facilmente perceptível a partir da constatação de que, mesmo sem aceitar a existência dos direitos fundamentais sociais, seria não apenas possível aceitar ambas as teses como, também, conceber a criação de uma liberdade fática como algo desejado pela Constituição. Seria necessário apenas aceitar uma repartição de tarefas entre os direitos fundamentais e o processo político, de acordo com a qual aos primeiros caberia zelar pela liberdade jurídica; e aos segundos, pela liberdade fática.²³⁶ Por isso, para complementar o argumento baseado na liberdade é necessário demonstrar por que a liberdade fática deve ser garantida diretamente *pelos direitos fundamentais*.

Para que isso seja fundamentado não é suficiente afirmar que os direitos fundamentais devem garantir a liberdade, que a liberdade fática também é liberdade e que, por isso, os direitos fundamentais devem garantir também a liberdade fática. A questão é justamente essa: saber se os direitos fundamentais também devem garantir a liberdade fática. Portanto, para justificar a atribuição de direitos fundamentais sociais com o auxílio de um argumento baseado na liberdade é necessário também fundamentar por que a liberdade garantida pelos direitos fundamentais inclui a liberdade fática.

Neste ponto, dois são os principais argumentos que podem ser utilizados. O primeiro baseia-se na importância da liberdade fática para o indivíduo. Para utilizar apenas três exemplos, para o indivíduo é de importância vital não viver abaixo do mínimo existencial, não estar condenado a um desemprego de longo prazo e não estar excluído da vida cultural de seu tempo. É certo que, para aquele que se encontra em uma tal situação de necessidade, os direitos fundamentais não são totalmente sem valor.²³⁷ É exatamente aquele desprovido de meios que pode valorizar especialmente aqueles direitos fundamentais que, por exemplo, o protegem contra o trabalho forçado e outras situações semelhantes e aqueles que lhe dão a possibilidade de melhorar sua situação por meio do processo político. Contudo, não é

236. Cf. Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, pp. 48 e ss.

237. Cf. Albert Bleckmann, *Allgemeine Grundrechtslehren*, p. 162.

possível negar que, para ele, a eliminação de sua situação de necessidade é mais importante que as liberdades jurídicas, que a ele de nada servem, em razão dessa situação de necessidade, e que, por isso, são para ele uma "fórmula vazia".²³⁸ Se a esse cenário se adiciona o fato de que a razão de ser dos direitos fundamentais é exatamente a de que aquilo que é especialmente importante para o indivíduo, e que pode ser juridicamente protegido, deve ser juridicamente garantido, então, o primeiro argumento para a proteção no âmbito dos direitos fundamentais está completo.

O segundo argumento está diretamente ligado ao primeiro. De acordo com ele, a liberdade fática é constitucionalmente importante não apenas sob o aspecto formal da garantia de coisas especialmente importantes, mas também sob o aspecto substancial. O Tribunal Constitucional Federal interpretou o catálogo de direitos fundamentais como expressão de um sistema de valores, "em cujo centro se encontra o livre desenvolvimento da personalidade humana e de sua dignidade no seio da comunidade social".²³⁹ À luz da teoria dos princípios,²⁴⁰ isso deve ser interpretado de forma a que o catálogo de direitos fundamentais expresse, dentre outros, princípios que exijam que o indivíduo possa desenvolver livremente sua dignidade na comunidade social, o que pressupõe uma certa medida de liberdade fática. A conclusão inevitável é a de que os direitos fundamentais, se seu escopo for o livre desenvolvimento da personalidade humana, também estão orientados para a liberdade fática, ou seja, também devem garantir os pressupostos do exercício das liberdades jurídicas,²⁴¹ sendo, assim, "não apenas a regulação das possibilidades jurídicas, mas também do *poder de agir fático*".²⁴² A questão é saber se essa hipótese, que encontra fundamen-

238. Ernst-Wolfgang Böckenförde, *Staat, Gesellschaft, Freiheit*, p. 77.

239. BVerfGE 7, 198 (205).

240. Cf. Capítulo 3, I.2.

241. Cf. Peter Saladin, "Die Funktion der Grundrechte in einer revidierten Verfassung", ZSR N.F. 87 (1968), p. 353: "A garantia de uma liberdade de ação individual autônoma somente é honesta e frutífera se, ao mesmo tempo, forem garantidos os pressupostos mais essenciais para a utilização dessa liberdade, se o constituinte não cuida apenas da garantia da *liberté* mas também da garantia da *capacité*".

242. Peter Häberle, "Das Bundesverfassungsgericht im Leistungsstaat: Die Numerus-clausus-Entscheidung vom 18.7.1972", DÖV 25 (1972), p. 731.

tos adicionais no princípio do Estado Social²⁴³ e no princípio da igualdade fática,²⁴⁴ consegue resistir aos argumentos contrários.

Dentre as inúmeras objeções contra os direitos fundamentais sociais, as principais podem ser agrupadas em dois argumentos complexos, um formal e um substancial.

O argumento *formal* aponta para um dilema: se os direitos fundamentais sociais forem vinculantes, eles deslocam a política social da competência parlamentar para a competência do tribunal constitucional; se eles não forem vinculantes, eles implicam uma violação da cláusula de vinculação do art. 1º, § 3º, da Constituição alemã. O ponto de partida desse argumento é a tese de que os direitos fundamentais sociais ou não são justiciáveis ou o são apenas em pequena medida.²⁴⁵ Essa tese pode se basear no fato de que os objetos da maioria dos direitos fundamentais sociais são extremamente indeterminados. Qual é, por exemplo, o conteúdo de um direito fundamental ao trabalho? A escala de possíveis interpretações vai desde um direito utópico de todos a qualquer trabalho que se deseje, em qualquer lugar e em qualquer momento, até um direito compensatório a um auxílio-desemprego. Mas qual deve ser o valor desse auxílio? Os problemas dos outros direitos fundamentais sociais não são muito diferentes. Até mesmo no caso do direito fundamental social mais simples, o direito a um mínimo existencial, a determinação de seu exato conteúdo suscita algumas dificuldades.²⁴⁶ Mas dificuldades na definição do exato conteúdo de direitos bem como, em geral, a precisa determinação de conceitos dos mais indeterminados não são tarefas incomuns para a jurisprudência e para a Ciência do Direito. Por isso, ao lado da indefinição semântica

243. Cf. Karl H. Friauf, "Zur Rolle der Grundrechte im Interventions- und Leistungsstaat", p. 676; Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, pp. 41 e ss.

244. Cf. Capítulo 8, VI.2. Cf. também Gerhard Leibholz, *Strukturprobleme der modernen Demokratie*, 3ª ed., Karlsruhe: C. F. Müller, 1967 (reimpr. Frankfurt am Main: Athenäum Fischer, 1974), p. 131.

245. Cf. Jörg Paul Müller, *Soziale Grundrechte in der Verfassung?*, pp. 5-6 e 20 e ss.; Christian Starck, "Die Grundrechte des Grundgesetzes", p. 241; Theodor Tomandl, *Der Einbau sozialer Grundrechte in das positive Recht*, Tübingen: Mohr, 1967, pp. 17-18; Georg Brunner, *Die Problematik der sozialen Grundrechte*, pp. 17-18; Karl Korinek, "Betrachtungen zur juristischen Problematik sozialer Grundrechte", in Katholische Sozialakademie Österreichs (Orgs.), *Die sozialen Grundrechte*, Wien: KSÖ, 1971, p. 12.

246. Cf. Albert Bleckmann, *Allgemeine Grundrechtslehre*, p. 164.

e estrutural dos direitos fundamentais sociais, a tese do déficit de justiciabilidade tem que agregar uma outra forma de indefinição: a impossibilidade de se chegar, com os meios específicos do direito, a uma determinação exata do conteúdo e da estrutura dos direitos fundamentais sociais formulados abstratamente. Ela tem que sustentar que o direito não fornece critérios suficientes para tanto. Por que, se o direito não fornece esses critérios suficientes, então, a decisão sobre o conteúdo dos direitos fundamentais sociais é uma tarefa da política.²⁴⁷ Mas isso significaria que, segundo os princípios da separação de poderes e da democracia, a decisão sobre o conteúdo dos direitos fundamentais sociais estaria inserida não na competência dos tribunais, mas na do "legislador diretamente legitimado pelo povo".²⁴⁸⁻²⁴⁹ A partir dessa idéia, no âmbito dos direitos fundamentais sociais os tribunais poderiam decidir somente após o legislador já haver decidido.

O argumento baseado na competência ganha um peso especial em virtude dos efeitos financeiros dos direitos fundamentais sociais. Por causa dos grandes custos financeiros associados à sua realização, a existência de direitos fundamentais sociais abrangentes e exigíveis judicialmente conduziria a uma determinação jurídico-constitucional de grande parte da política orçamentária.²⁵⁰ Visto que o Tribunal Constitucional Federal teria que controlar o respeito a essa determinação, a política orçamentária ficaria em grande medida nas mãos do tribunal constitucional, o que é incompatível com a Constituição.

Aquele que quiser evitar esse resultado insustentável e, mesmo assim, manter-se fiel à idéia de direitos fundamentais sociais tem apenas uma saída, caso queira se manter nos limites do argumento formal. As normas que garantem direitos fundamentais sociais teriam que ser compreendidas como normas não-vinculantes, isto é, normas não sujeitas ao controle do Tribunal Constitucional, ou seja, normas que cor-

247. Cf. Dietrich Wiegand, "Sozialstaatsklausel und soziale Teilhaberechte", *DVBf* 89 (1974), p. 660.

248. Cf. a fórmula na decisão sobre ruído de aviões, *BVerfGE* 56, 54 (81).

249. Cf., por exemplo, Wolfgang Martens, "Grundrechte im Leistungsstaat", pp. 35-36; Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Die sozialen Grundrechte im Verfassungsgefüge", pp. 11-12; Konrad Hesse, "Bestand und Bedeutung der Grundrechte", p. 434; Eberhard Grabitz, *Freiheit und Verfassungsrecht*, p. 46.

250. Cf., por todos, Christian Starck, "Staatliche Organisation und staatliche Finanzierung", p. 518.

respondam às posições (5) a (8) na tabela apresentada anteriormente. Mas normas de direitos fundamentais não-vinculantes são inconciliáveis com a cláusula de vinculação do art. 1º, § 3º, da Constituição.²⁵¹ Se o argumento formal for procedente, a aceitação de direitos fundamentais sociais fracassa frente ao dilema: deslocamento inconstitucional de competências ou violação da cláusula de vinculação.

O argumento *substantial* contra os direitos fundamentais sociais sustenta que eles são incompatíveis – ou, ao menos, colidem – com normas constitucionais materiais. Na medida em que essas normas constitucionais materiais garantam direitos de liberdade, o argumento substancial é um argumento vinculado à liberdade *contra* os direitos fundamentais sociais sustentados em um argumento vinculado à liberdade.²⁵²

A colisão entre direitos fundamentais sociais e direitos de liberdade é especialmente clara no caso do direito ao trabalho. Em uma economia de mercado, o Estado tem controle apenas limitado sobre o objeto desse direito.²⁵³ Se ele quisesse satisfazer diretamente um direito de cada desempregado a um posto de trabalho, ele teria que ou empregar todos os desempregados nos serviços públicos existentes, ou restringir ou eliminar o poder econômico privado de dispor sobre postos de trabalho. A primeira solução, pelo menos como solução geral, está fora de questão, pois conduziria, nas condições existentes, simplesmente a um desemprego disfarçado pelo serviço público. A segunda conduziria ou a uma extensa restrição da competência decisória da economia privada, ou a uma eliminação dessa forma de economia. Mas isso significaria, entre outras coisas, inter-

251. Cf. Christian Starck, “Die Grundrechte des Grundgesetzes”, p. 241; Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, pp. 58-59; Albert von Mutius, “Grundrechte als ‘Teilhaberechte’”, p. 193.

252. Sobre a tese de que os direitos fundamentais sociais se encontram em uma relação de incompatibilidade com os direitos clássicos de liberdade, cf. Hans Huber, “Soziale Verfassungsrechte?”, in Ernst Forsthoff (Org.), *Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, p. 9; Wolfgang Martens, “Grundrechte im Leistungsstaat”, p. 33; Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, pp. 64-65; do mesmo autor, “Ein Grundrecht auf sauberes Umwelt?”, pp. 657 e ss.; Ernst Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft*, pp. 73 e 78; Herbert Schambeck, *Grundrechte und Sozialordnung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1969, pp. 127-128.

253. Cf. Georg Brunner, *Die Problematik der sozialen Grundrechte*, pp. 14-15.

venções nos direitos fundamentais daqueles que dispõem da propriedade produtiva.²⁵⁴

Colisões entre direitos fundamentais sociais de uns com direitos de liberdade de outros não surgem somente quando o Estado controla apenas indiretamente uma pequena parcela do objeto do direito em uma economia de mercado, como é o caso do direito ao trabalho. Todos os direitos fundamentais sociais são extremamente custosos. Para a realização dos direitos fundamentais sociais o Estado pode apenas distribuir aquilo que recebe de outros, por exemplo na forma de impostos e taxas.²⁵⁵ Mas isso significa que os freqüentemente suscitados limites da capacidade de realização do Estado não decorrem apenas dos bens distribuíveis existentes, mas sobretudo daquilo que o Estado, para fins distributivos, pode tomar dos proprietários desses bens sem violar seus direitos fundamentais.

Com freqüência fala-se não apenas em uma colisão entre direitos fundamentais sociais de uns e direitos de liberdade de outros, mas também de uma colisão entre direitos fundamentais sociais e direitos de liberdade do mesmo titular de direitos. Nesse sentido, afirma-se que um direito ao trabalho implica um dever de trabalhar.²⁵⁶ Embora a vinculação entre um direito ao trabalho e um dever de trabalhar seja

254. Cf. Theodor Tomandl, *Der Einbau sozialer Grundrechte in das positive Recht*, pp. 30-31; Georg Brunner, *Die Problematik der sozialen Grundrechte*, pp. 14 e ss; Christian Starck, "Staatliche Organisation und staatliche Finanzierung", p. 519; do mesmo autor, "Die Grundrechte des Grundgesetzes", p. 241; Josef Isensee, "Verfassung ohne soziale Grundrechte", pp. 379-380; Rupert Scholz, "Das Recht auf Arbeit", in Ernst-Wolfgang Böckenförde et al. (Orgs.), *Soziale Grundrechte*, Heidelberg: Müller, 1981, pp. 84-85; Jörg Lücke, "Soziale Grundrechte als Staatszielbestimmungen und Gesetzgebungsaufträge", p. 39. Que uma realização plena do direito ao trabalho não é possível sem uma intervenção nos direitos fundamentais dos proprietários dos meios de produção é algo que os próprios defensores desse direito também reconhecem. Cf., por exemplo, Wolfgang Däubler, "Recht auf Arbeit verfassungswidrig?", in Udo Achten et al. (Orgs.), *Recht auf Arbeit: eine politische Herausforderung*, Neuwied: Luchterhand, 1978, p. 171, o qual propõe que essa intervenção seja fundamentada por meio do art. 15 da Constituição. Em geral sobre o direito ao trabalho, cf. Hans Ryffel/Johannes Schwartländer (Orgs.), *Das Recht des Menschen auf Arbeit*, Kehl et al.: Engel, 1983.

255. Cf. Carl Schmitt, "Nehmen/Teilen/Weiden", in Carl Schmitt, *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, p. 503; Walter Leisner, "Der Eigentümer als Organ der Wirtschaftsverfassung", *DÖV* 28 (1975), p. 74.

256. Cf. Josef Isensee, "Verfassung ohne soziale Grundrechte", p. 380.

frequente,²⁵⁷ ela não é necessária. Um Estado que introduza um direito ao trabalho pode abdicar de um dever de trabalhar, mesmo que esteja interessado em que o máximo possível de cidadãos trabalhe. O interesse em trabalhar, sobretudo o interesse em um salário, pode ser, para um número suficiente de cidadãos, um incentivo suficiente para exercer o direito ao trabalho. No entanto, algo distinto pode ser verdadeiro se o direito ao mínimo existencial já coloca o indivíduo em uma situação na qual o exercício do direito do trabalho deixa de ser atrativo para ele.

Por fim, devem ser mencionadas as colisões de direitos fundamentais sociais com outros direitos fundamentais sociais, bem como as colisões entre direitos fundamentais sociais e interesses coletivos. Um exemplo das primeiras é a colisão entre um direito ao trabalho e um direito ao meio ambiente. Já as colisões entre direitos fundamentais sociais e interesses coletivos, como, por exemplo a defesa nacional, decorrem do fato de que a realização de ambos exige uma parte considerável do orçamento, ou seja, decorrem do já mencionado efeito financeiro dos direitos fundamentais sociais.

3. Um modelo de direitos fundamentais sociais

Considerados os argumentos contrários e favoráveis aos direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os lados dispõem de argumentos de peso. A solução consiste em um modelo que leve em consideração tanto os argumentos a favor quanto os argumentos contrários. Esse modelo é a expressão da idéia-guia formal apresentada anteriormente,²⁵⁸ segundo a qual os direitos fundamentais da Constituição alemã são posições que, do ponto de vista do direito constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples. Em relação ao problema que aqui se analisa, isso significa que a todos são conferidas posições no âmbito dos direitos a prestações, na forma de direitos fundamentais sociais, que, do ponto de vista do direito constitucional, são tão importantes que a decisão

257. Cf., por exemplo, art. 24 da Constituição da República Democrática da Alemanha, de 1968.

258. Cf., neste capítulo, I.5.

sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar simples.

De acordo com essa fórmula, a questão acerca de quais direitos fundamentais sociais o indivíduo definitivamente tem é uma questão de sopesamento entre princípios. De um lado está, sobretudo, o princípio da liberdade fática.²⁵⁹ Do outro lado estão os princípios formais da competência decisória do legislador democraticamente legitimado e o princípio da separação de poderes, além de princípios materiais, que dizem respeito sobretudo à liberdade jurídica de terceiros, mas também a outros direitos fundamentais sociais e a interesses coletivos.

O modelo não determina quais direitos fundamentais sociais definitivos o indivíduo tem. Mas ele diz que ele pode ter alguns e o que é relevante para sua existência e seu conteúdo. A resposta detalhada a essa questão é tarefa da dogmática de cada um dos direitos fundamentais sociais. Mesmo assim, é possível dar, aqui, uma resposta geral. Uma posição no âmbito dos direitos a prestações tem que ser vista como definitivamente garantida se (1) o princípio da liberdade fática a exigir de forma premente e se (2) o princípio da separação de poderes e o princípio democrático (que inclui a competência orçamentária do parlamento) bem como (3) os princípios materiais colidentes (especialmente aqueles que dizem respeito à liberdade jurídica de outrem) forem afetados em uma medida relativamente pequena pela garantia constitucional da posição prestacional e pelas decisões do tribunal constitucional que a levarem em consideração. Essas condições são necessariamente satisfeitas no caso dos direitos fundamentais sociais mínimos, ou seja, por exemplo, pelos direitos a um mínimo existencial, a uma moradia simples, à educação fundamental e média, à educação profissionalizante e a um patamar mínimo de assistência médica. A seguir serão analisadas algumas objeções ao modelo aqui defendido.

Mesmo os direitos fundamentais sociais mínimos têm, especialmente quando são muitos que deles necessitam, enormes efeitos financeiros. Mas isso, isoladamente considerado, não justifica uma conclusão contrária à sua existência. A força do princípio da competência orçamentária do legislador não é ilimitada. Ele não é um princípio absolu-

259. Se também o princípio da igualdade fática exigir um direito a prestações (cf. Capítulo 8, VI.3), então, há uma dupla fundamentação.

to.²⁶⁰ Direitos individuais podem ter peso maior que razões político-financeiras. Nesse sentido, na decisão sobre o auxílio-moradia para os beneficiários da assistência social o Tribunal Constitucional Federal ampliou – com impacto financeiro – o círculo daqueles que teriam direito a essa prestação, com o objetivo de eliminar um tratamento desigual;²⁶¹ e em uma decisão sobre a duração da prisão preventiva o tribunal obrigou o Estado a criar os meios necessários para evitar uma prisão preventiva desproporcionalmente longa.²⁶² Todos os direitos fundamentais da Constituição alemã restringem a competência do legislador,²⁶³ e muitas vezes eles o fazem de forma incômoda para o próprio legislador; às vezes até mesmo sua competência orçamentária é atingida pelos direitos fundamentais, como direitos com claros efeitos financeiros.

A extensão do exercício dos direitos fundamentais sociais aumenta em crises econômicas. Mas é exatamente nesses momentos que pode haver pouco a ser distribuído. Parece plausível a objeção de que a existência de direitos fundamentais sociais definitivos – ainda que mínimos – tornaria impossível a necessária flexibilidade em tempos de crise e poderia transformar uma crise econômica em uma crise constitucional.²⁶⁴ Contra essa objeção é necessário observar, em primeiro lugar, que nem tudo aquilo que em um determinado momento é considerado como direitos sociais é exigível pelos direitos fundamentais sociais mínimos; em segundo lugar, que, de acordo com o modelo aqui proposto, os necessários sopesamentos podem conduzir, em circunstâncias distintas, a direitos definitivos distintos; e, em terceiro lugar, que é exatamente nos tempos de crise que a proteção constitucional, ainda que mínima, de posições sociais parece ser imprescindível.

Também contra o modelo aqui proposto pode ser levantada a objeção de uma justiciabilidade deficiente. Essa objeção deve ser re-

260. Sobre esse conceito, cf. Capítulo 3, I.7.2.

261. *BVerfGE* 27, 220 (228 e ss.).

262. *BVerfGE* 36, 264 (275). Cf. também Jürgen Schwabe, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, p. 266. Um exemplo de uma decisão, no âmbito dos direitos clássicos de defesa, com claros efeitos financeiros no campo das receitas é aquele oferecido pela decisão do Tribunal Constitucional Federal sobre empréstimo compulsório. Cf. *BVerfGE* 67, 256 (274 e ss.).

263. Cf. Capítulo 4, II.3.6.2.

264. Cf. Josef Isensee, "Verfassung ohne soziale Grundrechte", pp. 381-382.

jeitada com base na constatação de que os problemas de justiciabilidade que surjam no âmbito desse modelo não se distinguem, em sua essência, daqueles que existem no caso dos direitos fundamentais tradicionais.²⁶⁵ Não raro os problemas do sopesamento no âmbito dos direitos de liberdade são bastante complexos e sua solução pode ter grandes conseqüências para a vida social. Em geral, pode-se dizer: a existência de um direito não pode depender exclusivamente de sua justiciabilidade, não importa como ela seja definida; pelo contrário, se um direito existe, ele é justiciável. O fato de os direitos fundamentais sociais dependerem de uma configuração infraconstitucional não é uma objeção decisiva, pois também competências e procedimentos dependem desse tipo de regulação. O mesmo vale para outros tipos de direitos fundamentais. Razões processuais também não são capazes de sustentar a tese da não-justiciabilidade. Como demonstra a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, um tribunal constitucional não é, de modo algum, impotente em face de um legislador omissivo.²⁶⁶ O espectro de suas possibilidades processuais-constitucionais vai desde a simples constatação de uma inconstitucionalidade,²⁶⁷ passando pelo estabelecimento de um prazo dentro do qual deve ocorrer uma legislação compatível com a Constituição,²⁶⁸ até a determinação judicial direta daquilo que é obrigatório em virtude da Constituição.²⁶⁹⁻²⁷⁰

O modelo apresentado é um modelo baseado no sopesamento. É característico de todos os modelos baseados no sopesamento que aquilo que é devido *prima facie* seja mais amplo que aquilo que é devido definitivamente. Alguém poderia sustentar que essa construção é ina-

265. Cf. Friedrich Klein, "Vorbemerkung", in Hermann v. Mangoldt/Friedrich Klein, *Das Bonner Grundgesetz*, I, A IV 3; Peter Saladin, "Die Funktion der Grundrechte in einer revidierten Verfassung", p. 553; Luzius Wildhaber, "Soziale Grundrechte", p. 384; Heinhard Steiger, *Mensch und Umwelt*, pp. 40 e ss.; Dieter Lorenz, "Bundesverfassungsgericht und soziale Grundrechte", *JBl* 103 (1981), p. 21.

266. Cf. Walter Schmidt, "Soziale Grundrechte im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland", p. 29; Ernst Friesenhahn, "Der Wandel des Grundrechtsverständnisses", p. G16.

267. Cf. *BVerfGE* 39, 316 (333). Sobre a idéia de "subjetivização da constatação", cf. Friedrich Müller/Bodo Pieroth/Lothar Fohmann, *Leistungsrechte im Normbereich einer Freiheitsgarantie*, Berlin: Duncker & Humblot, 1982, pp. 165 e ss.

268. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 33, 1 (13).

269. Cf. *BVerfGE* 3, 225 (237 e ss.); 43, 154 (169-170).

270. Cf., a esse respeito, Jörn Ipsen, *Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm und Einzelakt*, Baden-Baden: Nomos, 1980, pp. 132 e ss.

ceitável quando se trata de direitos sociais. Ela conduziria, em primeiro lugar, a ilusões e, depois, a frustrações.²⁷¹ Já se refutou anteriormente o argumento baseado na objeção geral à idéia de normas de direitos fundamentais que inicialmente protegem algo *prima facie* que depois, por meio de restrições, é excluído da proteção.²⁷² A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre o problema do *numerus clausus* é instrutiva para demonstrar que a refutação desse argumento geral deve ser estendida também para os direitos fundamentais sociais. O tribunal parte de um direito subjetivo *prima facie* e vinculante, de todo cidadão que tenha concluído o ensino médio, a ser admitido no curso universitário de sua escolha. O caráter *prima facie* desse direito é expressado de forma precisa quando o tribunal afirma que o direito é conferido ao seu titular como um direito “em si”²⁷³ e que ele é restringível.²⁷⁴ Fica claro que o direito, enquanto direito *prima facie*, é um direito vinculante, e não um simples enunciado programático, quando o tribunal afirma que o direito, “em sua validade normativa, não [pode] depender de um menor ou maior grau de possibilidades de realização”.²⁷⁵ Mas a natureza de direito *prima facie* vinculante implica que a cláusula de restrição desse direito – a “reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade”²⁷⁶ – não pode levar a um esvaziamento do direito. Essa cláusula expressa simplesmente a necessidade de sopesamento desse direito. No que diz respeito à similaridade de todos os direitos fundamentais nesse ponto, é de grande interesse sistemático quando o Tribunal Constitucional Federal, na primeira decisão *numerus clausus*, estende aos direitos a prestações então envolvidos a fórmula da “tensão indivíduo/comunidade”, desenvolvida no contexto da liberdade geral de ação.²⁷⁷ Embora o sopesamento não tenha levado, na decisão *numerus clausus*, a um direito definitivo de todos à admissão no curso universitário de sua escolha, ao menos levou a um direito definitivo a um

271. Cf. Josef Isensee, “Verfassung ohne soziale Grundrechte”, pp. 382-383; Hans H. Rupp, “Vom Wandel der Grundrechte”, p. 177.

272. Cf. Capítulo 6, II.2.2.

273. BVerfGE 43, 291 (315).

274. Idem.

275. Idem.

276. BVerfGE 43, 291 (314); 33, 303 (333).

277. BVerfGE 33, 303 (334).

procedimento de seleção que dê chances suficientes a todos,²⁷⁸ o que aponta para a conexão entre os direitos fundamentais sociais e os direitos a procedimentos, analisados anteriormente. Mas, para poder mensurar a regulamentação do procedimento com base no direito fundamental, é imprescindível que se parta de um direito *prima facie* vinculante.

A estrutura argumentativa implicada pelos direitos *prima facie* é racional, porque levar a cabo a fundamentação jurídica como um jogo de razões e contra-razões é algo racional. Nesse jogo, as razões de ambos os lados têm, isoladamente consideradas, algo de excedente. Embora nunca seja possível excluir a possibilidade de que alguém aceite apenas as razões de um dos lados e, por isso, chegue a resultados excessivos, isso não é algo possível apenas no caso dos direitos fundamentais sociais, mas também no dos direitos tradicionais de liberdade. Aquele que aceita apenas o princípio da liberdade jurídica também chega a resultados excessivos, da mesma forma que aquele para o qual existe apenas o princípio da liberdade fática. A constatação de que é possível retirar partes de uma estrutura racional de fundamentação para usá-las de forma não-racional não é um motivo para que se renuncie a ela em favor de uma estrutura menos racional de fundamentação. Aquele que não se deixa convencer, após o necessário jogo de razões e contra-razões do modelo aqui proposto, de que um direito fundamental não é definitivamente protegido dificilmente se deixará convencer por alegações como aquelas que sustentam que aquilo que ele pretendia ver definitivamente protegido pelo direito fundamental não o era “desde o início”. Portanto, uma renúncia à estrutura de fundamentação requerida pela teoria dos princípios também não pode ser justificada com o recurso a argumentos pedagógico-constitucionais, cuja aceitação seria, de qualquer forma, extremamente questionável do ponto de vista de uma teoria científica.

Por fim, alguém poderia sustentar que o modelo apresentado reprime, de forma inaceitável, o objetivo em favor do subjetivo. Essa objeção poderia basear-se na tese de Häberle a respeito do caráter excedente das normas objetivas relevantes no âmbito do direito constitucional: “Assim, no Estado prestacional, o direito objetivo relevante para os direitos fundamentais ‘ultrapassa’ o direito (fundamental)

278. Cf. BVerfGE 43, 291 (316 e ss.).

subjetivo. Há tarefas constitucionais ('princípios') 'úteis aos direitos fundamentais', às quais (ainda) não corresponde qualquer direito subjetivo".²⁷⁹ Com isso, Häberle expressa, de forma concisa, o que muitos querem dizer quando classificam o problema dos direitos fundamentais sociais primariamente como um problema de meros deveres objetivos do Estado.²⁸⁰ Aqui basta mencionar Hesse, que fala de uma obrigação positiva do Estado de "fazer de tudo para realizar os direitos fundamentais, mesmo que não haja para tanto um direito subjetivo do cidadão". Dessa maneira, o legislador receberia, "dos direitos fundamentais, 'diretrizes e impulsos'". Contudo, disso não seria possível concluir, em geral, "uma obrigação concreta dos órgãos estatais para tomar determinadas medidas", o que significa que o controle judicial encontraria aí os seus limites.²⁸¹

No entanto, o modelo aqui proposto não é atingido pela crítica da não-consideração da importância da faceta objetiva. Ao contrário, ele oferece uma base para uma exata compreensão do conteúdo correto da tese do excedente do lado objetivo. A chave é a teoria dos princípios.

De acordo com o modelo proposto, o indivíduo tem um direito definitivo à prestação quando o princípio da liberdade fática tem um peso maior que os princípios formais e materiais colidentes, considerados em conjunto. Esse é o caso dos direitos mínimos. É possivelmente a esse tipo de direitos mínimos que se quer fazer referência quando direitos subjetivos públicos e judicialmente exigíveis a prestações são contrapostos ao conteúdo objetivo excedente. Em face de direitos definitivos que sejam o resultado de um sopesamento, os direitos *prima facie* correspondentes aos princípios – o direito "em si" à admissão em curso superior é um exemplo²⁸² – têm sempre algo de excedente. O conceito de excedente não está, portanto, vinculado à dicotomia subjetivo/objetivo.

279. Peter Häberle, "Grundrechte im Leistungsstaat", p. 108.

280. Cf., por exemplo, Hans H. Rupp, "Vom Wandel der Grundrechte", p. 177; Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, pp. 112 e ss.; Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Die sozialen Grundrechte im Verfassungsgefüge", pp. 12 e ss.; Peter Badura, "Das Prinzip der sozialen Grundrechte", pp. 27 e ss.; Ulrich Scheuner, "Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat", p. 513; Jörg Paul Müller, *Soziale Grundrechte in der Verfassung?*, pp. 192 e 239 e ss.

281. Konrad Hesse, "Grundrechte: Bestand und Bedeutung", pp. 95-96.

282. *BVerfGE* 43, 291 (315).

Avançar do modelo em direção a um nível objetivo é possível, porque a direitos *prima facie* correspondem deveres *prima facie*. Esses deveres são deveres estatais *prima facie* de zelar para que às liberdades jurídicas dos titulares de direitos fundamentais correspondam liberdades fáticas. Mas o plano objetivo que surge dessa forma não é um plano *meramente* objetivo, mas um plano *também* objetivo.

Os deveres estatais *prima facie* têm, em face dos deveres estatais definitivos, um conteúdo claramente excedente. Isso não significa, contudo, que eles não sejam vinculantes. Seria um equívoco considerar os deveres *prima facie*, na parte em que a eles não correspondam deveres definitivos, ou seja, no âmbito excedente, como juridicamente não-vinculantes ou meros enunciados programáticos. A existência de uma diferença fundamental entre deveres *prima facie* e deveres jurídicos não-vinculantes é perceptível no fato de que deveres *prima facie* têm que ser considerados no sopesamento, enquanto isso não ocorre no caso dos deveres jurídicos não-vinculantes. Para a não-satisfação de um dever *prima facie* é necessário que haja, do ponto de vista jurídico, razões aceitáveis; para a não-satisfação de um dever jurídico não vinculante, não. Caso não existam razões aceitáveis para sua não-satisfação, um dever *prima facie* pode levar a um dever definitivo; um dever não-vinculante nunca poderia fazê-lo.

Assim, por mais que Häberle tenha razão quando rejeita a “alternativa ou direito subjetivo ou enunciado programático” – a tabela apresentada anteriormente demonstra que essa alternativa é insuficiente²⁸³ –, ele se equivoca quando se volta contra a “identificação entre vinculação jurídica e controle judicial”.²⁸⁴ Sob a Constituição alemã, vinculação jurídica implica controle judicial. Para que a observação de Häberle fosse correta, teria ela que ser compreendida como uma referência às peculiaridades de um controle judicial da satisfação de deveres estatais *prima facie* objetivos. Essas peculiaridades são de dois tipos. Em primeiro lugar, não pode ser objeto do controle saber se foi satisfeito tudo aquilo que o dever *prima facie* exige, mas tão-somente se foi satisfeito aquilo que lhe resta, como dever definitivo, em face de deveres *prima facie* colidentes. Em segundo lugar, no caso dos princípios colidentes, desempenham um papel decisivo não apenas os prin-

283. Cf., neste capítulo, IV.1.

284. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, pp. 107-108.

cípios materiais, mas também os formais, sobretudo o princípio da competência do legislador democraticamente legitimado. Mas nenhuma dessas peculiaridades altera a possibilidade de que seja objeto do controle pelo tribunal constitucional avaliar se, à luz dos princípios colidentes, o dever *prima facie* foi satisfeito em grau suficiente.

A competência do tribunal termina nos limites do definitivamente devido. Mas os princípios contêm exigências normativas endereçadas ao legislador mesmo além desses limites. Um legislador que satisfaça princípios de direitos fundamentais além do âmbito do definitivamente devido satisfaz normas de direitos fundamentais mesmo se não está definitivamente obrigado a fazê-lo, e, por isso, não pode ser obrigado a tanto por um tribunal constitucional.

**DIREITOS FUNDAMENTAIS
E NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
NO SISTEMA JURÍDICO**

**I – A FUNDAMENTALIDADE DAS NORMAS
DE DIREITOS FUNDAMENTAIS**

O significado das normas de direitos fundamentais para o sistema jurídico é o resultado da soma de dois fatores: da sua fundamentalidade formal e da sua fundamentalidade substancial.

A *fundamentalidade formal* das normas de direitos fundamentais decorre da sua posição no ápice da estrutura escalonada do ordenamento jurídico, como direitos que vinculam diretamente o legislador, o Poder Executivo e o Judiciário. O significado disso pode ser percebido a partir da contraposição entre dois modelos constitucionais extremos: o puramente procedimental e o puramente material.

No *modelo puramente procedimental* a constituição contém apenas normas de organização e procedimento. Em relação à legislação, isso significa que a constituição não exclui diretamente nada como um possível conteúdo do direito positivo. Tudo o que for regularmente criado por meio do procedimento e da forma previstos é direito positivo.¹ Uma constituição puramente procedimental pode ter uma influência apenas indireta no conteúdo daquilo que se torna direito positivo. Fala-se em uma influência indireta quando diferentes procedimentos, que, enquanto tais, não determinam os resultados, levam a diferentes resultados em face das circunstâncias existentes. Assim, a

1. O modelo puramente procedimental corresponde ao princípio dinâmico de Kelsen. Cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 198 e ss.

experiência demonstra que um direito eleitoral em três classes conduz a um conteúdo das leis distinto daquele que existiria em um cenário com um direito eleitoral igualitário. Não importa a forma como essa influência indireta possa ser avaliada; em um modelo puramente procedimental o conteúdo das leis é decisivamente definido pela vontade do legislador, pela sua racionalidade ou irracionalidade, bem como pelos limites de suas possibilidades de ação. Se se pressupõe que o legislador pode ter quaisquer características, então, o direito positivo poderá ter qualquer conteúdo. A esse modelo corresponde uma teoria dos direitos fundamentais segundo a qual os direitos fundamentais não têm nenhuma força vinculante em face do legislador; o legislador teria, portanto, a competência para restringi-los conforme sua vontade, por mais que a forma dessa restrição esteja previamente definida. Em uma tal teoria, a liberdade constitucional transformar-se-ia, nos termos de Jellinek, em uma "liberdade contra coações ilegais",² e a importância material dos direitos fundamentais seria reduzida a zero.

O oposto de um modelo puramente procedimental é o *modelo puramente material*. Enquanto uma constituição que corresponda ao modelo puramente procedimental é algo possível, é duvidosa a possibilidade de uma constituição que corresponda ao modelo puramente material. Ainda assim, por razões sistemáticas, é interessante uma breve análise do modelo puramente material. Nesse modelo a constituição contém apenas normas materiais, a partir das quais pode ser derivado o conteúdo de qualquer norma do sistema jurídico, por meio de um método operacional qualquer.³ Uma constituição assim seria aquilo que ForsthoFF chamou de um "genoma jurídico (...) do qual tudo deriva, do código penal até a lei sobre a fabricação de termômetros para febre".⁴ Sob essa constituição a tarefa da legislação limita-se à mera declaração daquilo que, de qualquer forma, já era devido em virtude da própria constituição. Aquilo que no modelo puramente procedimental deve ser solucionado por meio de uma *decisão* no âmbito da constituição tem que ocorrer no modelo puramente material por meio de uma *cognição* de seu conteúdo.

2. Georg Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, p. 103.

3. Um modelo puramente material corresponde ao princípio estático de Kelsen. Cf. Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre*, pp. 199-200.

4. Ernst ForsthoFF, *Der Staat der Industriegesellschaft*, p. 144.

A Constituição alemã não tem natureza nem puramente material nem puramente procedimental, mas uma *natureza mista material-procedimental*. Dentre seus componentes materiais estão, ao lado das normas de direitos fundamentais, os dispositivos sobre os objetivos do Estado; já o cerne de sua parte procedimental é formado pelas normas sobre o processo legislativo.

O fato de uma constituição ter elementos procedimentais e materiais combinados entre si tem importantes conseqüências para todo o sistema jurídico. Isso significa que, ao lado dos conteúdos que, no sistema jurídico, são simplesmente *possíveis* em relação à constituição, há também conteúdos que são, também em relação à constituição, *necessários* ou *impossíveis*. O fato de as normas de direitos fundamentais estabelecerem os conteúdos constitucionalmente necessários e impossíveis para o sistema jurídico⁵ constitui o núcleo da fundamentalidade formal desses direitos.

À fundamentalidade formal soma-se a *fundamentalidade substancial*. Direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais são fundamentalmente substanciais porque, com eles, são tomadas decisões sobre a estrutura normativa básica do Estado e da sociedade. Isso vale independentemente do quanto de conteúdo é a eles conferido. Aquele que confere a eles pouco conteúdo delega muito ao legislador, o que pode ser considerado como uma decisão indireta acerca da estrutura normativa básica do Estado e da sociedade. O fato de as decisões sobre o conteúdo das normas de direitos fundamentais incluírem decisões sobre a estrutura normativa básica do Estado e da sociedade é algo que decorre dos objetos regulados. Questões relativas à liberdade e à igualdade não são questões apenas de um ramo do direito, elas permeiam todos os ramos. A forma como elas são solucionadas em cada um desses diferentes ramos do direito não é, para esses ramos do direito, uma questão específica, mas uma questão fundamental. Também nos casos de objetos regulados de forma menos abstrata o que está em jogo são questões substanciais fundamentais. Aquele que

5. Sob uma Constituição que, como a alemã em seu art. 79, § 3º, protege algumas normas contra emendas constitucionais, algumas diferenciações adicionais são necessárias. O sistema jurídico não tem apenas conteúdos necessários e impossíveis em relação ao conteúdo atualmente vigente da Constituição, mas também conteúdos necessários e impossíveis em relação à própria vigência da Constituição.

pretende dizer o que é exigido pela proteção do matrimônio e da família, garantida pela Constituição, não pode deixar de dar uma resposta à questão fundamental acerca da ordem normativa da comunidade.

Com a tese das fundamentalidades formal e substancial afirma-se que as normas de direitos fundamentais desempenham um papel central no sistema jurídico. Mas nada ainda se diz sobre como elas o fazem e o que isso significa para a estrutura do sistema jurídico. Essas questões serão analisadas a partir de agora.

II – EFEITO PERANTE TERCEIROS OU EFEITO HORIZONTAL

Um sistema jurídico pode ser analisado a partir de diferentes perspectivas. A essas diferentes perspectivas correspondem diferentes conceitos de sistema jurídico. Dois são, aqui, importantes. É possível conceber um sistema jurídico como um sistema de *normas*,⁶ mas é possível também concebê-lo como um sistema de *posições*⁷ e *relações*⁸ jurídicas. O sistema de normas e o sistema de posições e relações são duas faces da mesma coisa, na medida em que às posições e relações jurídicas sempre correspondem normas que as fundamentam. Apesar dessa correspondência, ambas as perspectivas têm seu próprio valor. Uma das vantagens da visão baseada na norma consiste na inclusão da possibilidade de se fazer uma abstração em relação às posições e relações, o que simplifica a questão e pode ser sistematicamente interessante. A vantagem da perspectiva baseada em posições e relações reside no seu poder de diferenciação. Visto que diferenciações são fundamentais na análise dos efeitos das normas de direitos fundamentais e dos direitos fundamentais no sistema jurídico, essa perspectiva deverá ser aqui, em princípio, preferida.

Se sua influência se limitasse à relação Estado/cidadão, haveria uma resposta simples à questão acerca de como as normas de direitos fundamentais influenciam o sistema jurídico. Essa resposta poderia, em grande parte, resumir-se à constatação de que as normas de direitos fundamentais influenciam o sistema jurídico na medida em que afetam a relação jurídica entre o Estado e os cidadãos, sob a forma de

6. Sobre o conceito de norma, cf. Capítulo 2, I.

7. Sobre o conceito de posição, cf. Capítulo 4, I.3.1.

8. Sobre o conceito de relação, cf. Capítulo 4, II.1.2.1.

direitos subjetivos em face do legislador, do Poder Executivo e do Judiciário. Mas é fácil perceber que essa resposta é incompleta. Como já foi demonstrado anteriormente, fazem parte dos direitos dos indivíduos em face do legislador, dentre outros, os direitos a proteção contra outros cidadãos e a determinados conteúdos da ordem jurídico-civil.⁹ Isso demonstra que as normas de direitos fundamentais também têm influência na relação cidadão/cidadão. Essa influência é especialmente clara no caso dos direitos em face da Justiça Civil. Dentre esses direitos estão os direitos a que o conteúdo de uma decisão judicial não viole direitos fundamentais.¹⁰ Isso implica algum tipo de efeito das normas de direitos fundamentais nas normas do direito civil e, com isso, na relação cidadão/cidadão.

O efeito das normas de direitos fundamentais na relação Estado/cidadão já foi abordado diversas vezes ao longo da presente pesquisa. Já seu efeito na relação cidadão/cidadão, ou seja, seu efeito perante terceiros ou efeito horizontal, não foi ainda expressamente estudado. Mas esse efeito perante terceiros, ou efeito horizontal, é extremamente útil para deixar claro o efeito dos direitos fundamentais e das normas de direitos fundamentais no sistema jurídico. Por isso, ele será analisado a partir de agora.

1. Sobre a tese da irradiação

O Tribunal Constitucional Federal procura conceber o “efeito irradiador”¹¹ das normas de direitos fundamentais no sistema jurídico com o auxílio do conceito de ordem objetiva de valores. Para usar as palavras do tribunal: “Segundo a jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional Federal, as normas de direitos fundamentais contêm não apenas direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra o Estado, elas representam também uma ordem objetiva de valores, que vale como decisão constitucional fundamental para todos os ramos do direito, e que fornece diretrizes e impulsos para a legislação, a Adminis-

9. Cf. Capítulo 9, II.2 e III 5.1.

10. *BVerfGE* 7, 198 (203). Cf. também *BVerfGE* 42, 143 (149), na qual uma decisão de um Tribunal Civil foi considerada como uma “intervenção” na “esfera de direitos fundamentais daquele que perdeu a causa”.

11. *BVerfGE* 7, 198 (207). Cf. também *BVerfGE* 34, 269 (280).

tração e a jurisprudência".¹² Os conceitos centrais dessa construção são o conceito de valor e o conceito de objetivo. A questão é saber, então, como eles devem ser compreendidos.

Já foi demonstrado acima que a teoria dos valores do Tribunal Constitucional Federal pode ser reformulada como uma teoria dos princípios, a qual ou não está sujeita às inúmeras objeções contra a teoria dos valores, ou está apta a refutá-las.¹³ Portanto, o conceito de valor da construção do tribunal pode ser substituído pelo conceito de princípio.

Mais difícil é responder à pergunta sobre o que pode significar o caráter objetivo dos princípios. É relativamente fácil dizer o que ele não pode significar. O caráter objetivo dos princípios não pode significar que os princípios de direitos fundamentais, enquanto princípios supremos do sistema jurídico, não tenham relação com posições individuais. Isso contradiria a orientação básica dos direitos fundamentais como direitos relativos aos indivíduos¹⁴ e seria também incompatível com a concepção que o Tribunal Constitucional Federal tem de ordem objetiva de valores como a expressão de um "fortalecimento básico da força de validade dos direitos fundamentais"¹⁵ e com o fato de que, a partir dela, ele fundamenta direitos individuais.¹⁶ Uma compreensão da natureza objetiva no sentido de "meramente objetiva" está fora de questão.

Além disso, esse caráter objetivo não pode simplesmente consistir na influência dos princípios de direitos fundamentais, como princípios supremos, no sistema jurídico. Isso ocorre, de alguma forma, com todas as normas de direitos fundamentais. O que importa na construção do tribunal é exatamente o fato de que os princípios de direitos fundamentais influenciam o sistema jurídico *como* princípios objetivos.

Por fim, também deve ser excluído o significado segundo o qual as normas de direitos fundamentais têm algo de objetivo porque elas não têm efeitos apenas para o indivíduo, mas também para a coletividade. Também isso vale para todas as normas de direitos fundamentais.

12. BVerfGE 39, 1 (41).

13. Cf. Capítulo 3, III.1.2.2 e III.2.

14. Cf. Capítulo 9, II.2.1, III.5.1 e III.5.3.

15. BVerfGE 7, 198 (205); 50, 290 (337).

16. Cf. BVerfGE 35, 79 (116).

Apenas uma interpretação pode ser considerada: aquela segundo a qual objetivo é aquilo que sobra quando se desconsidera ou se abstrai o lado subjetivo dos princípios de direitos fundamentais. Mas isso também não é satisfatório. Embora desconsiderar ou abstrair o lado subjetivo conduza à obtenção de algo objetivo, que se diferencia do “meramente objetivo” pelo fato de que *pode*, a qualquer tempo, ser novamente completado por sua face subjetiva, isso ainda não nos leva aos princípios objetivos supremos, construídos de forma a serem capazes de influenciar por completo e de forma abrangente o sistema jurídico. Isso é demonstrado pela seguinte reflexão: se *a* tem, em face do Estado (*s*), um direito a *G* (*RasG*), então, *s* tem, em face de *a*, um dever em relação a *G* (*OsaG*).¹⁷ Abstrair o lado subjetivo conduz a uma transformação do dever relacional em um dever não-relacional¹⁸ de *s* em relação a *G*, ou seja, um simples dever de *s* em relação a *G* (*OsG*). O objeto desse dever, *G*, é exatamente o mesmo objeto do direito do qual se partiu. Ele poderia ser, por exemplo, a abstenção de intervenções na liberdade de manifestação do pensamento. O princípio objetivo, que se obtém a partir da abstração da face subjetiva, tem como conteúdo o dever *prima facie* do Estado de se abster de intervir nas manifestações do pensamento. Mas esse princípio é muito especial para ter efeitos em todos os ramos do sistema jurídico. Ele abarca apenas o âmbito dos direitos à abstenção de intervenções estatais na manifestação do pensamento.

Com isso fica claro como pode ser estabelecida a capacidade do princípio para produzir efeitos substanciais abrangentes em todas as posições do sistema jurídico. São necessárias mais duas abstrações. A abstração em relação ao titular do direito devem ser adicionadas uma abstração em relação ao destinatário do direito (o obrigado) e uma abstração em relação a determinadas particularidades de seu objeto (aqui: a abstenção de intervenções estatais). Por meio dessa abstração tripla, o direito de *a*, em face do Estado, a que este não o embarace¹⁹ em sua manifestação do pensamento transforma-se em um simples

17. Cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

18. Sobre esse conceito, cf. Capítulo 4, II.1.2.2.

19. *Ras* ($\neg$ embaraca *s* (*Ha*)); cf., a esse respeito, Capítulo 4, nota 61.

dever-ser da liberdade de opinião.²⁰ É de se supor que se queira fazer menção a esse tipo de princípios triplamente abstraídos quando se fala em “decisões jurídico-constitucional fundamentais”,²¹ “normas axiológicas fundamentais”,²² “decisões axiológicas”²³ etc., ou simplesmente em “idéias mestras da Constituição alemã”,²⁴ que se irradiam por todos os ramos do direito. Em todo caso, esses princípios triplamente abstraídos são a reconstrução mais plausível dessas formas de expressão. No que se segue, eles serão chamados de “princípios de nível máximo de abstração”.²⁵

A adoção de princípios de nível máximo de abstração tem vantagens e desvantagens. As vantagens residem na sua flexibilidade. Eles são aplicáveis como pontos de partida para fundamentações dogmáticas das mais variadas exigências estruturais e substanciais no âmbito dos direitos fundamentais, em todos os campos do sistema jurídico. Sua desvantagem é sua indeterminação. Eles incentivam uma das formas mais obscuras de fundamentação jurídica, a “dedução” ou “derivação” de conteúdos concretos a partir de princípios abstratos.

Mas uma aplicação não-racional como essa é apenas uma possibilidade – e não uma necessidade – ligada aos princípios de nível máximo de abstração. É igualmente possível que os princípios abstratos encontrem aplicação como ponto de partida para uma fundamentação racional, na qual premissas mais precisas têm que ser indicadas e justificadas. Se isso ocorre, então, sua aceitação fomenta a racionalidade, não a diminui. A aceitação de uma ordem objetiva de valores, sob a forma de princípios objetivos supremos, não é, portanto, algo em si irracional, mas algo extremamente incompleto, que pode ser

20. Aquilo que se perde em estrutura por meio da tripla abstração fica claro quando se contrapõe a fórmula estrutural do dever-ser da liberdade de expressão – ou seja, *OM* – à fórmula do direito a partir do qual se abstraiu – ou seja, *Ras* (–embaraço *s* (*Ha*)).

21. *BVerfGE* 7, 198 (205).

22. *BVerfGE* 30, 173 (188).

23. *BVerfGE* 42, 64 (73).

24. *BVerfGE* 42, 64 (74).

25. Neste ponto, o conceito de *nível* de abstração diz respeito aos três aspectos da abstração. Em relação ao objeto do direito, é possível ainda distinguir entre *graus* de abstração. Assim, o dever-ser da liberdade tem um maior grau de abstração que o dever-ser da liberdade de expressão. Mas ambos apresentam o mesmo nível de abstração.

utilizado tanto de maneira racional quanto de maneira irracional. Por isso, a tese segundo a qual se devem associar às disposições de direitos fundamentais princípios supremos que se irradiam em todos os âmbitos do sistema jurídico não é nem certa nem errada; ela apenas diz muito pouco. Permanecem as questões acerca de como a influência deve ocorrer e que conteúdo ela tem. A essas questões serão dedicados os próximos tópicos.

2. Sobre a construção do efeito perante terceiros

Atualmente a idéia de que normas de direitos fundamentais produzem efeitos na relação cidadão/cidadão e, nesse sentido, têm um efeito perante terceiros, ou efeito horizontal, é amplamente aceita.²⁶ O que é polêmico é como e em que extensão elas o fazem. A questão sobre *como* as normas de direitos fundamentais produzem efeitos na relação cidadão/cidadão é algo que diz respeito a um *problema de construção*. A questão sobre *em que extensão* elas o fazem é uma questão que expressa um problema substancial, a saber, um *problema de colisão*.²⁷ Tanto o problema de construção quanto o de colisão resultam de uma diferença fundamental entre a relação Estado/cidadão e a relação cidadão/cidadão. A relação Estado/cidadão é uma relação entre um titular de direitos fundamentais e um não-titular.²⁸ A relação cidadão/cidadão é, ao contrário, uma relação entre titulares de direitos fundamentais.²⁹

26. Cf. a apresentação do estágio do debate em Fridel Eckhold-Schmidt, *Legitimation durch Begründung: eine erkenntniskritische Analyse der Drittwirkungs-Kontroverse*, Berlin: Duncker & Humblot, 1974, pp. 26 e ss. e 66 e ss.

27. Cf. Franz Gamillscheg, "Die Grundrechte im Arbeitsrecht", *AcP* 164 (1964), p. 420; Herbert Bethge, *Zur Problematik von Grundrechtskollisionen*, p. 400.

28. Aqui, interessa apenas essa constelação básica. Nos casos que dizem respeito a problemas como o da titularidade de direitos fundamentais por pessoas jurídicas de direito público ou da vinculação do Fisco ou de Igrejas a direitos fundamentais são necessárias diferenciações adicionais. Cf., sobre isso, Albert Bleckmann, *Allgemeine Grundrechtslehren*, pp. 77 e ss., 126 e ss. e 131 e ss.

29. Cf. Günter Dürig, "Art. 1", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 130; Hans H. Rupp, "Zum 'Mephisto-Beschluß' des Bundesverfassungsgerichts", *DVBt* 87 (1972), p. 67. Rupp fala em uma "diferença estrutural, no âmbito dos direitos fundamentais, entre a relação de uma liberdade pessoal com outra liberdade pessoal, de um lado, e de uma liberdade pessoal com uma competência de dominação estatal, de outro".

2.1 A equivalência de resultados entre as construções

É possível distinguir três teorias acerca da questão da construção: uma de efeitos indiretos perante terceiros, uma de efeitos diretos e uma de efeitos mediados por direitos em face do Estado.

Segundo a teoria de efeitos indiretos perante terceiros, cujos principais representantes são Dürig³⁰ e o Tribunal Constitucional Federal,³¹ os direitos fundamentais, enquanto “decisões axiológicas”, “normas objetivas” ou “valores constitucionais”, ou seja, como *princípios objetivos* no sentido apresentado acima, influenciam a interpretação do direito privado. Essa influência deve ocorrer sobretudo na concretização das cláusulas gerais do direito privado;³² mas ela pode também manifestar-se em toda e qualquer interpretação de uma norma de direito privado e, em casos especiais, chega até a fundamentar decisões contra o teor literal da lei.³³ Apesar da influência dos direitos fundamentais, as normas do direito privado devem permanecer como normas de direito privado, e os direitos e deveres por elas estabelecidos permanecem direitos e deveres no âmbito do direito privado.³⁴ No que diz respeito à posição do juiz, o efeito irradiador deve fundamentar o dever de levar em consideração a influência dos direitos fundamentais nas normas de direito privado, quando de sua interpretação.

Também a teoria de efeitos diretos perante terceiros, cujos principais representantes são Nipperdey³⁵ e a 1ª Turma do Tribunal Fede-

30. Günter Dürig, “Das Eigentum als Menschenrecht”, *ZGesStW* 109 (1953), pp. 339 e ss.; do mesmo autor, “Grundrechte und Zivilrechtsprechung”, in Theodor Maunz (Org.), *Festschrift für Hans Nawiasky*, München: Isar, 1956, pp. 157 e ss.; do mesmo autor, “Art. 1”, in *Grundgesetz: Kommentar*, §§ 127 e ss., e “Art. 2”, idem, §§ 56 e ss.; e “Zum ‘Lüth-Urteil’ des Bundesverfassungsgerichts vom 15.1.1958”, *DÖV* 11 (1958), pp. 194 e ss.

31. Cf. *BVerfGE* 7, 198 (203 e ss.); 52, 131 (166); e jurisprudência reiterada.

32. *BVerfGE* 7, 198 (206).

33. Cf. *BVerfGE* 34, 269 (279 e ss.).

34. *BVerfGE* 7, 198 (205).

35. Cf. Ludwig Enneccerus/Hans C. Nipperdey, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, 15ª ed., tomo 1, Tübingen: Mohr, 1959, pp. 91 e ss.; Hans C. Nipperdey, “Freie Entfaltung der Persönlichkeit”, pp. 747 e ss.; do mesmo autor, “Grundrechte und Privatrecht”, in Hans C. Nipperdey (Org.), *Festschrift für E. Molitor*, München: Beck, 1962, pp. 17 e ss. Cf. também Walter Leisner, *Grundrechte und Privatrecht*, München: Beck, 1960, pp. 356 e ss.

ral do Trabalho,³⁶ mantém-se fiel à concepção de que “os direitos fundamentais, em sentido clássico e estrito, como direitos públicos subjetivos, dirigem-se somente contra o Estado”.³⁷ Da mesma forma que ocorre no caso da teoria de efeitos indiretos, a influência das normas de direitos fundamentais no direito privado decorre da “sua característica como direito constitucional objetivo e vinculante”.³⁸ A diferença reside no fato de que não se sustenta que os princípios objetivos produzam efeitos na relação cidadão/cidadão por meio de uma influência na interpretação das normas de direito privado, mas porque deles “fluem também diretamente direitos subjetivos privados para os indivíduos”.³⁹ Segundo Nipperdey, “o efeito jurídico é muito mais um efeito normativo direto, que modifica as normas de direito privado existentes, não importa se se trata de direitos cogentes ou dispositivos, de cláusulas gerais ou normas jurídicas específicas, ou cria novas normas, sejam proibições, deveres, direitos subjetivos, leis de proteção ou motivos justificadores”.⁴⁰ Nesse sentido, os direitos fundamentais devem ter um efeito absoluto.⁴¹

De acordo com a terceira teoria, os efeitos na relação cidadão/cidadão são consequência da vinculação do Estado aos direitos fundamentais como direitos públicos subjetivos. Uma versão extrema dessa teoria foi proposta por Schwabe. Como já foi demonstrado anteriormente,⁴² Schwabe defende a concepção de que o Estado, na medida em que cria e impõe um sistema de direito privado, participa das possíveis violações cometidas por um cidadão a bens de direitos fundamentais de outro cidadão. Essas violações, ainda que realizadas por particulares, teriam que ser consideradas como intervenções estatais.⁴³ Assim, para a solução do problema dos efeitos perante terceiros seria suficiente a concepção dos direitos fundamentais como direitos do

36. Cf., por exemplo, *BAGE* 1, 185 (181 e ss.); 4, 274 (276 e ss.).

37. Hans C. Nipperdey, “Grundrechte und Privatrecht”, p. 24.

38. *Idem*.

39. *Idem*.

40. *Idem*, p. 26.

41. *Idem*, p. 24.

42. Cf. Capítulo 9, II.2.2.

43. Cf. Jürgen Schwabe, *Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte*, pp. 16 e ss., 149 e 154 e ss.; do mesmo autor, *Probleme der Grundrechtsdogmatik*, pp. 213 e ss.

status negativo dirigidos contra o Estado.⁴⁴ Já se demonstrou anteriormente⁴⁵ a insustentabilidade da teoria da imputação de violações particulares ao Estado, que subjaz a essa construção. Neste ponto interessa apenas notar que essa deficiência da versão de Schwabe não põe a perder a construção de uma concepção dos efeitos perante terceiros baseada em direitos em face do Estado. Essa construção não está fadada a trabalhar apenas com direitos do status negativo; ela pode também se utilizar de direitos do status positivo que tenham como objetivo uma proteção constitucional necessária no âmbito das relações entre cidadãos.

É facilmente perceptível que as três construções têm extensões diversas. Enquanto a construção baseada em efeitos indiretos tem como destinatário o juiz,⁴⁶ a construção dos efeitos perante terceiros mediada por direitos em face do Estado abarca tanto o legislador⁴⁷ quanto o juiz. Também a construção baseada em efeitos diretos vale primariamente para o Judiciário. Na análise que se segue, o aspecto ligado ao Judiciário estará em primeiro plano.

No que diz respeito ao Judiciário as três construções são equivalentes em resultado.⁴⁸ Duas construções jurídicas são equivalentes em resultado se todo resultado que pode ser obtido no âmbito de uma puder também ser obtido no âmbito da outra. Que o criador de uma construção a tenha criado para obter resultados diversos daqueles obtidos pelas construções já existentes, ou que os defensores de uma construção tendam a outros resultados se comparados com os defensores da outra construção, ou, ainda, que uma construção seja mais próxima de

44. Cf. Jürgen Schwabe, *Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte*, pp. 141 e ss.

45. Cf. Capítulo 9, II.2.2.

46. Cf., a esse respeito, Hans H. Rupp, "Vom Wandel der Grundrechte", *AöR* 101 (1976), p. 170.

47. Cf., a esse respeito, *BVerfGE* 14, 263 (278); 38, 132 (140).

48. A equivalência em relação aos resultados das diferentes construções sobre os efeitos dos direitos fundamentais perante terceiros já foi salientada diversas vezes: cf., por exemplo, Franz Gamillscheg, "Die Grundrechte im Arbeitsrecht", pp. 404 e 419; Franz Bydlinski, "Bemerkungen über Grundrechte und Privatrecht", *ÖZöR* 12 (1962/63), p. 441; Fridel Eckhold-Schmidt, *Legitimation durch Begründung*, pp. 71 e ss. Segundo Christian Starck ("Die Grundrechte des Grundgesetzes", *JuS* 21 (1981), p. 243), é "ainda necessário analisar em detalhes" se a construção de Dürig conduz a resultados diferentes daquela de Nawiasky.

determinados resultados que a outra, nada disso afeta a equivalência em relação aos resultados. O que importa é que, em todos os casos, o mesmo resultado *possa* ser obtido.

Nenhuma das três teorias transpõe os direitos fundamentais dirigidos contra o Estado para a relação cidadão/cidadão por meio de uma simples troca de destinatários.⁴⁹ Todas elas permitem levar em conta o fato de que, na relação cidadão/cidadão, ambos os lados são titulares de direitos fundamentais. Todas elas aceitam uma modulação da força de seus efeitos. Para todas elas a medida do efeito dos direitos fundamentais na relação cidadão/cidadão é, no final das contas, uma questão de sopesamento.⁵⁰ Segundo a teoria dos efeitos indiretos o sopesamento deve ser realizado no âmbito da aplicação do direito civil vigente, a partir de um conceito de aplicação do direito que, em casos especiais, permita também decisões contra o texto da lei (por exemplo: redução teleológica),⁵¹⁻⁵² mas não se excluem definitivamente resultados que sejam possíveis a partir das outras construções. Também segundo as outras construções, para se afastar do texto literal da lei é necessária uma justificação. Para as três teorias o sopesamento pode levar a regras relativamente genéricas, de acordo com as quais, em determinados âmbitos do direito privado, determinados direitos fundamentais podem ceder totalmente ou em grande medida. Assim, por exemplo, nenhuma das construções exclui a possibilidade de que a liberdade de testamento esteja desvinculada do princípio da igualdade. Se se analisam as coisas pelo seu resultado, o decisivo não é a construção, mas a *valoração* que a preenche. As reflexões a seguir reforçarão e aprofundarão essa idéia.

49. Cf. Hans C. Nipperdey, "Grundrechte und Privatrecht", p. 23; Günter Dürig, "Grundrechte und Zivilrechtsprechung", pp. 158 e ss.; Jürgen Schwabe, *Die sogennante Drittwirkung der Grundrechte*, pp. 75 e ss.

50. Cf. Hans C. Nipperdey, "Grundrechte und Privatrecht", pp. 28 e 32; Ludwig Enneccerus/Hans C. Nipperdey, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, p. 103; *BVerfGE* 7, 198 (210 e ss.); Jürgen Schwabe, *Die sogennante Drittwirkung der Grundrechte*, pp. 107 e ss.

51. Cf. Hans-Friedrich Brandenburg, *Die teleologische Reduktion*, Göttingen: Schwartz, 1983.

52. Cf. o "preenchimento de lacunas na proteção de valores", de Dürig, em Günter Dürig, "Art. 1", in Theodor Maunz/Günter Dürig, *Grundgesetz: Kommentar*, § 133.

2.2 *Um modelo em três níveis para os efeitos perante terceiros*

O fato de as três construções serem equivalentes nos resultados não significa que a questão acerca de sua correção seja irrelevante. A pergunta sobre como “tem que ser pensado em cada caso”⁵³ o efeito dos direitos fundamentais e das normas de direitos fundamentais no direito civil é algo que deve ser respondido não apenas porque a Ciência do Direito não se satisfaz com a simples obtenção de resultados corretos ou aceitáveis, sem considerações acerca de sua construção, mas também porque sem uma construção correta não é possível um quadro preciso do efeito dos direitos fundamentais e das normas de direitos fundamentais no sistema jurídico.

Até agora a polêmica sobre os efeitos perante terceiros foi em geral travada como se uma das três construções tivesse que ser a correta. Essa hipótese é falsa. É possível afirmar que cada uma das três construções destaca alguns aspectos das complexas relações jurídicas que são características dos casos de efeitos perante terceiros, e que se torna inadequada apenas quando se pretende que o aspecto destacado seja tomado como a solução completa. Somente um modelo que abarque todos os aspectos pode oferecer uma solução completa e, nesse sentido, adequada. Os marcos fundamentais de um tal modelo serão esboçados a seguir.

O modelo é composto por três níveis: o do dever estatal, o dos direitos em face do Estado e o das relações jurídicas entre os sujeitos privados. Entre esses níveis não há uma relação de grau, mas de mútua implicação.

A teoria dos efeitos indiretos situa-se no nível do dever estatal. O fato de as normas de direitos fundamentais valerem como princípios objetivos (ordem objetiva de valores) para todos os ramos do direito implica que o Estado tem o dever de levá-las em consideração tanto na legislação civil⁵⁴ quanto na jurisprudência civil. No que diz respeito à jurisprudência, pode-se ler na decisão do caso Lüh: “Em virtude de mandamento constitucional, o juiz deve controlar se as prescrições

53. Essa é a precisa expressão do Tribunal Constitucional Federal em *BVerfGE* 7, 198 (204).

54. Cf. *BVerfGE* 14, 263 (278); 37, 132 (140).

materiais de direito civil a serem por ele aplicadas são influenciadas pelos direitos fundamentais na forma descrita; se assim o for, ele, na interpretação e na aplicação dessas prescrições, tem que levar em consideração as modificações do direito privado que daí decorrem".⁵⁵

O segundo nível é o dos direitos em face do Estado que sejam relevantes do ponto de vista dos efeitos perante terceiros. O dever que o juiz tem de levar em consideração a ordem de valores dos direitos fundamentais, quando da interpretação e aplicação das normas de direito civil, não implica, por si só, que ele, se agir contra esse dever, viole os direitos fundamentais, na forma de direitos subjetivos. Mas, para que a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal sobre o efeito dos direitos fundamentais e das normas de direitos fundamentais no direito privado seja consistente, é necessário que uma tal conexão exista. Se essa conexão não existisse, o tribunal não poderia ter constatado, na parte dispositiva da decisão Lüth, que a decisão do Tribunal Civil violara o *direito fundamental* do recorrente, em virtude do art. 5º, § 1º, 1, da Constituição alemã.⁵⁶ Ele teria que ter rejeitado a reclamação constitucional como não-cabível, já que seu cabimento pressupõe que a violação de direitos fundamentais na forma de direitos subjetivos seja possível (art. 93, § 1º, 4a, da Constituição e § 90, 1, da lei sobre o Tribunal Constitucional Federal).⁵⁷ Para o Tribunal Constitucional Federal a conexão parece não ser problemática. Na decisão do caso Lüth, lê-se: "Se ele [*o juiz civil*] não respeitar esses critérios, e se a sua decisão se basear na desconsideração dessa influência constitucional nas normas de direito civil, então, ele viola não apenas o direito constitucional objetivo, na medida em que ignora o conteúdo da norma de direito fundamental (como norma objetiva); como titular de um poder estatal, ele viola também, por meio de sua

55. BVerfGE 7, 198 (206).

56. BVerfGE 7, 198 (199).

57. Essa consequência foi sustentada por Hans-Uwe Erichsen, *Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit*, I, 2ª ed., München: Beck, 1976, pp. 65 e ss. Na mesma linha, Detlef Merten, "Urteilsanmerkung", NJW 25 (1972), p. 1.799. Na 3ª edição de sua obra (München: Beck, 1982), Erichsen mudou sua opinião, sob o fundamento de que "o conteúdo jurídico-objetivo [*serve*] para garantir e fortalecer o conteúdo jurídico-subjetivo", o que significaria que "com uma violação do conteúdo jurídico-objetivo das normas de direitos fundamentais também [*pode*] ser atingido o seu conteúdo regulatório jurídico-subjetivo" (p. 53). Com isso, no entanto, a pergunta acerca de como essa conexão deve ser construída deve ser também endereçada a Erichsen.

decisão, o direito fundamental, a cujo respeito, inclusive por parte do Poder Judiciário, o cidadão tem um direito de natureza constitucional".⁵⁸ O que se deve indagar é em que pode consistir um direito fundamental que pode ser violado pelo conteúdo⁵⁹ de uma decisão de um tribunal civil. Essa questão tem como alvo nada mais que a relação entre o primeiro e o segundo nível do modelo.

Um direito só pode ser violado por aquele em face do qual ele existe. Se tribunais civis podem violar direitos fundamentais dos cidadãos por meio do conteúdo de suas decisões, então, os direitos violados são direitos dos cidadãos contra o Judiciário, ou seja, contra o Estado. Alguém poderia sustentar que esses direitos nada mais são que direitos de defesa contra o Estado, ou seja, direitos do status negativo. Essa concepção, defendida por Schwabe, aponta para um ponto correto, mas apresenta deficiências que impedem que seja considerada como resposta geral.

A decisão no caso Lüth demonstra que a construção baseada no direito de defesa aponta para um ponto correto.⁶⁰ O Tribunal Estadual de Hamburgo havia *proibido* Lüth de fazer determinadas declarações. Essa proibição jurídica concreta eliminava uma parte da liberdade jurídica da manifestação do pensamento de Lüth, que consiste exatamente no fato de que manifestações do pensamento não sejam nem proibidas nem obrigatórias. O fato de essa proibição ter concretizado uma norma abstrata-geral (§ 826 do Código Civil alemão) e de que essa norma é uma norma de direito privado em nada altera a constatação de que a proibição judicial, enquanto tal, é um ato do poder público que intervém na liberdade de opinião.⁶¹ Por isso, o que se deve indagar é se a intervenção está protegida pela cláusula de restrição do art. 5º, § 2º, da Constituição, ou seja, pelo § 826 do Código Civil, enquanto uma lei geral nos termos desse dispositivo constitucional.⁶² Isso demonstra que casos como o caso Lüth podem ser compreendidos por meio da construção baseada nos direitos de defesa. Isso não significa, contudo, que essa construção não tenha deficiências.

58. BVerfGE 7, 198 (206-207).

59. Cf. BVerfGE 7, 198 (203).

60. Cf., a esse respeito, Jürgen Schwabe, "Bundesverfassungsgericht und 'Drittwirkung' der Grundrechte", AöR 100 (1975), pp. 443 e ss.

61. Cf. BVerfGE 7, 198 (203).

62. BVerfGE 7, 198 (211).

Uma primeira deficiência dessa construção é o fato de ela ser aplicável apenas quando se trata de deveres ou proibições, mas não quando um titular de um direito fundamental se volta contra *permissões* explícitas ou implícitas dirigidas a outros titulares de direitos fundamentais. Isso fica claro na decisão do caso *Blinkfuer*.⁶³ A Editora Springer conclamou os vendedores de jornais e revistas a um boicote contra a revista *Blinkfuer* e, ao mesmo tempo, fez ameaças de sanções comerciais contra aqueles que não aderissem ao boicote. A ação de indenização proposta pelo editor da revista *Blinkfuer* foi rejeitada pelo Superior Tribunal Federal. Contra essa decisão foi interposta reclamação constitucional; em seu julgamento, o Tribunal Constitucional Federal anulou a decisão do Superior Tribunal Federal em razão da violação do direito fundamental que o editor da revista *Blinkfuer* teria em virtude do art. 5º, § 1º, da Constituição alemã. A rejeição da ação de indenização pelo Superior Tribunal Federal significa que ele considerava o apelo ao boicote como juridicamente *permitido*. Como foi demonstrado acima,⁶⁴ e ao contrário do que sustenta Schwabe, isso não significa que o apelo ao boicote, em razão de sua permissão e não-punição, tenha que ser imputado ao Estado, como uma intervenção estatal na liberdade de imprensa. Por meio da rejeição da ação, o Superior Tribunal Federal não interveio no direito fundamental à liberdade de imprensa. O que ele fez foi algo muito diferente: ele não garantiu ao editor da revista *Blinkfuer* uma *proteção estatal* contra uma ação *privada* que o afetava. Portanto, a violação do direito fundamental do art. 5º, § 1º, da Constituição, constatada pelo Tribunal Constitucional Federal na parte dispositiva de sua decisão, não pode ser uma violação de um direito fundamental do status negativo. Ela é uma violação de um direito, em face do Estado, à proteção contra lesões causadas por particulares;⁶⁵ e esse direito pertence ao status positivo. Com isso, fica claro que a construção baseada nos direitos de defesa, proposta por Schwabe, não é suficiente para compreender completamente o efeito, mediado pelo Estado, dos direitos fundamentais

63. BVerfGE 25, 256.

64. Cf. Capítulo 9, II.2.2.

65. Sobre isso, cf. Ernst Friesenhahn, "Der Wandel des Grundrechtsverständnisses", in *Verhandlungen des fünfzigsten Deutschen Juristentages*, v. II, p. G27: "a violação consistia no fato de que o Superior Tribunal Federal não havia garantido essa proteção".

no direito privado. Nesse ponto, a construção baseada nos direitos de defesa tem que ser complementada por uma construção baseada nos direitos a prestações⁶⁶ ou a proteção.

Mas, mesmo após essa complementação, permanece a deficiência ligada ao fato de que da simples junção das construções baseadas nos direitos de defesa e nos direitos a proteção não decorre uma construção unitária. Essa deficiência não significa que as construções analisadas sejam equivocadas ou que não tenham valor. Mas faz com que o desejo por uma construção unitária permaneça aceso. Uma tal construção pode ser obtida se se aceita um direito do cidadão, em face da jurisdição civil, a que esta leve em consideração, na medida do exigível, o princípio de direito fundamental favorável à posição alegada pelo cidadão. Se esse direito é violado, então, também é violado o direito fundamental ao qual o princípio constitucional relevante pertence. Essa construção é uma construção explicitamente *referida à jurisdição*.

Essa construção tem duas vantagens. A primeira consiste no fato de que, em relação às outras construções, o direito por ela pressuposto é mais claramente relacionado aos problemas relevantes nos casos de efeitos perante terceiros. Isso por duas razões. De um lado, o tribunal civil tem que levar em consideração os princípios de direitos fundamentais favoráveis às posições alegadas pelas partes; mas, de outro, ele também tem que aplicar o direito privado vigente, a não ser que ele seja incompatível com todas as possíveis interpretações dos princípios constitucionais. O fato de não serem apenas os princípios de direitos fundamentais que têm que desempenhar um papel nos casos de efeitos perante terceiros, mas também o direito privado, é algo que pode ser percebido a partir da constatação de que os princípios, em muitos casos, aceitam diversas soluções como constitucionalmente possíveis, e de que o juiz não está submetido apenas à vinculação a princípios materiais, mas também a diversas outras vinculações, como, por exemplo, àquela que decorre do princípio formal do respeito às decisões do legislador democraticamente legitimado e da consideração dos precedentes. Isso é satisfeito pelo já mencionado direito em face da jurisdição civil, visto que ele exige que os princípios constitucionais sejam levados em consideração "na medida do exigível".

66. Sobre o sentido amplo que esse conceito tem nesse contexto, cf. Capítulo 9, I.4.

A segunda vantagem consiste no fato de que a construção referida à jurisdição não põe a perder as construções baseadas nos direitos de defesa e nos direitos a proteção; pelo contrário, ela as sustenta. Sempre que um tribunal civil viola o direito do cidadão em face da jurisdição, ou seja, quando ele não leva em consideração, na medida do exigível, um princípio de direito fundamental favorável à posição alegada pelo cidadão, ele também viola – dependendo das circunstâncias do caso – um direito de defesa ou um direito a proteção.

A construção referida à jurisdição não pode ser acusada de uma subjetivização não justificada dos deveres do Judiciário. Ela não confere ao indivíduo um direito a que todos os resultados da atividade jurisdicional sejam, em todos os aspectos, conformes aos direitos fundamentais, nem um direito a que eles sejam pura e simplesmente corretos; ela confere tão-somente um direito a que os princípios de direitos fundamentais favoráveis à *sua* posição sejam levados em consideração na medida do exigível.

O terceiro nível do modelo diz respeito aos efeitos dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre sujeitos privados. Isso suscita o problema de um efeito direto perante terceiros. Em primeiro lugar, é necessário indagar o que se deve entender por efeitos diretos. Em face do que se disse anteriormente acerca da teoria dos efeitos diretos, duas possibilidades devem ser excluídas. Em primeiro lugar, efeito direto perante terceiros não pode significar que os direitos do cidadão em face do Estado sejam, ao mesmo tempo, direitos do cidadão contra outro cidadão. Isso é, por razões conceituais, impossível e não é defendido por qualquer dos representantes da teoria dos efeitos diretos. Por definição, um direito do cidadão contra o Estado não é um direito do cidadão contra outro cidadão. Em segundo lugar, não se pode querer obter um efeito direto por meio da simples troca de destinatário dos direitos do cidadão contra o Estado. De uma parte, isso é impossível por razões conceituais – um cidadão não pode, por exemplo, ter um direito em face de outro cidadão a que este crie ou deixe de criar determinadas leis; de outra parte, e como todos os representantes da teoria dos efeitos diretos sublinham, isso é impossível porque as normas de direitos fundamentais têm, em razão da dupla titularidade de direitos fundamentais, uma outra “intensidade de efeitos”

na relação cidadão/cidadão se comparada com a da relação cidadão/Estado.⁶⁷

Mas existe uma terceira possibilidade para compreender o que significam efeitos diretos perante terceiros. Segundo ela, por razões ligadas aos direitos fundamentais, há determinados direitos e não-direitos, liberdades e não-liberdades e competências e não-competências na relação cidadão/cidadão, os quais não existiriam sem essas razões. Se se define o conceito de efeitos diretos dessa forma, então, efeitos diretos decorrem tanto da teoria dos efeitos indiretos quanto da teoria dos efeitos mediados pelo Estado. Isso será demonstrado com o auxílio da decisão do caso *Blinkfuer*.

O Tribunal Constitucional Federal inicia sua decisão com a constatação de que a ordem objetiva de valores, que subjaz ao capítulo dos direitos fundamentais da Constituição alemã, afeta a decisão acerca do que é contrário ao direito nos termos do § 823 do Código Civil alemão.⁶⁸ Isso corresponde à teoria dos efeitos indiretos. O Superior Tribunal Federal havia concluído que o apelo ao boicote feito pela Editora Springer não era contrário ao direito. Isso significa que o editor da revista *Blinkfuer* não teria um direito contra a Editora Springer a que ela se abstinhasse de defender o boicote. Esse não-direito do editor da revista *Blinkfuer* a uma abstenção é, como foi demonstrado anteriormente, equivalente⁶⁹ a uma permissão para que a Editora Springer defenda o boicote. Segundo o Tribunal Constitucional Federal, os princípios de direitos fundamentais requerem exatamente o resultado oposto. Isso significa que, *em razão* dos princípios de direitos fundamentais, há um direito do editor da revista *Blinkfuer*, em face da Editora Springer, a que ela se abstenha de defender o boicote. Esse direito é equivalente a uma obrigação da Editora, em face do editor da revista, de se abster de defender o boicote.⁷⁰ Portanto, os princípios de direitos fundamentais conduzem a direitos e obrigações nas relações entre particulares que são necessários em razão da existência desses princípios, mas que não o seriam na sua ausência. Isso é um efeito direto dos direitos fundamentais perante terceiros. Nesse sentido, a teo-

67. Cf., por todos, Hans C. Nipperdey, "Grundrechte und Privatrecht", p. 27.

68. *BVerfGE* 25, 256 (263).

69. Cf. Capítulo 4, II.1.2.2: $\neg Rab \neg G \leftrightarrow PbaG$.

70. Cf. Capítulo 4, II.1.2.2: $Rab \neg G \leftrightarrow Oba \neg G$.

ria dos efeitos indiretos tem como consequência necessária um efeito direto.⁷¹

O mesmo vale para a teoria dos efeitos perante terceiros mediados pelo Estado. Como já foi mencionado, o Superior Tribunal Federal violou o direito do editor da revista *Blinkfuer* a uma proteção nas relações entre particulares. Ele violou esse direito porque não levou em consideração, na medida do exigível, o princípio de direito fundamental favorável à posição alegada pelo editor. Mas isso pressupõe a existência de um direito definitivo do editor da revista, em face da Editora Springer, à abstenção em relação ao boicote, direito, esse, sustentado pelo princípio de direito fundamental.

Por isso, é correta a afirmação de Leisner segundo a qual "o efeito perante terceiros será, no final das contas, sempre um efeito direto".⁷² Mas essa afirmação não pode ser compreendida como se houvesse apenas o nível dos efeitos diretos, no sentido já mencionado. Existem os três níveis. Cada um deles abarca um aspecto da mesma questão. Decidir qual deles será escolhido na fundamentação jurídica é uma questão de conveniência. Mas nenhum deles pode pretender uma primazia sobre os outros.

Contra essa forma de efeitos diretos há apenas um argumento sustentável: a rejeição a qualquer forma de efeitos perante terceiros. Todos os outros argumentos contrários aos efeitos diretos não os atingem. É fácil refutar a objeção segundo a qual todo efeito direto conduziria a uma eliminação ou a uma restrição não aceitáveis da autonomia privada.⁷³ A própria autonomia privada, e não apenas sua restrição, é objeto de garantias constitucionais e, com isso, de efeitos perante terceiros. É uma deficiência da discussão acerca dos efeitos perante terceiros que a questão da restrição à autonomia privada tenha ocupado, com frequência, o primeiro plano e que sua proteção não tenha sido tratada como uma questão de igual importância. A forma pela qual se estabelecem as restrições às competências de direito privado é uma questão substancial e, no fim das contas, uma questão de sopesamento. Essa questão não é prejudicada pela definição dos efeitos diretos perante

71. Cf. Hans H. Klein, "Öffentliche und private Freiheit", *Der Staat* 10 (1971), p. 149.

72. Walter Leisner, *Grundrechte und Privatrecht*, p. 378.

73. Cf. Günter Dürig, "Grundrechte und Zivilrechtsprechung", pp. 158 e ss.

terceiros no sentido apresentado acima. Ao contrário, ela torna mais apurada nossa percepção acerca dos problemas ligados aos direitos fundamentais.

Mais a sério tem que ser levada a objeção que sustenta que os efeitos diretos, também nos termos aqui apresentados, seriam incompatíveis com o papel do direito civil. Em uma versão radical, essa objeção sustenta que um efeito direto perante terceiros tornaria supérfluo o direito civil. No caso de um efeito direto, o juiz civil poderia decidir casos civis diretamente por meio das normas de direitos fundamentais. Não seria mais possível explicar por quê ele deveria ainda se ater às normas de direito civil.⁷⁴

No entanto, essa objeção ignora que os princípios de direitos fundamentais não determinam uma única solução para cada caso. Há inúmeros casos no âmbito do direito civil para os quais há mais de uma solução compatível com os direitos fundamentais. Nesses casos, as normas de direito civil têm uma importância basilar. Além disso, essa objeção ignora que, com frequência, não é claro o que os princípios de direitos fundamentais requerem em um caso de direito civil. Nessa situação, é necessário que o juiz civil, para o bem de uma prática decisória consistente e a serviço dos postulados da segurança jurídica e do tratamento igual, possa se apoiar em um material de decisão dotado de autoridade, ou seja, em normas postas, em precedentes e em proposições dogmáticas comumente aceitas.⁷⁵ Um tribunal civil que baseie todas as suas decisões no texto constitucional mas que, para além disso, queira decidir com base em uma *tabula rasa* normativa nunca poderia satisfazer a esses postulados. Por isso, o juiz civil está *prima facie* vinculado ao direito civil vigente, na forma de leis, de precedentes e da dogmática comumente aceita. Se ele quiser se afastar disso, em virtude de princípios de direitos fundamentais, ele tem que assumir o ônus argumentativo.⁷⁶

74. Cf. Jürgen Schwabe, *Die sogenannte Drittwirkung der Grundrechte*, pp. 140 e ss.

75. Cf., a respeito, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 305, 307 e ss., 334 e ss.

76. Sobre a exigência de uma fundamentação especial, cf. Christian Starck, "Die Grundrechte des Grundgesetzes", p. 245.

Alguém poderia sustentar que, com essa necessidade de normas de direito civil como estágio intermediário, a concepção de efeitos diretos perante terceiros não seria mais aplicável. Isso seria correto se o caráter direto desses efeitos implicasse a superfluidade das normas de direito civil. É claro que é possível definir o conceito de efeitos diretos perante terceiros dessa forma e, com isso, ou levar qualquer efeito direto *ad absurdum*, ou restringi-los apenas a novas áreas do direito civil, ainda não marcadas pela atividade jurisprudencial. Mas um tal conceito de efeito direto perante terceiros desconsideraria um ponto decisivo: princípios de direitos fundamentais, em razão de sua influência no sistema de normas de direito civil, requerem ou excluem a existência de determinados direitos e não-direitos, liberdades e não-liberdades, bem como de competências e não-competências, na relação cidadão/cidadão, os quais, sem a vigência desses princípios, ou seja, apenas com base em um sistema de direito civil não influenciado pelos direitos fundamentais, não seriam considerados como necessários ou impossíveis do ponto de vista do direito constitucional. Nesse sentido, há um efeito direto perante terceiros.

Isso faz com que seja necessário indagar se alguém que viola um direito de outra pessoa – sustentado por razões de direitos fundamentais e oponível contra si – viola também um direito fundamental dessa pessoa. Por exemplo: no caso *Blinkfuer*, a Editora Springer violou o direito fundamental à liberdade de imprensa do editor da revista *Blinkfuer*? A resposta depende de uma definição terminológica. É possível dizer que foi violado um direito privado constitucionalmente necessário; mas também é possível dizer que o direito violado, por ser exigido pelo direito fundamental, pertence a um conjunto plurifacetado que constitui o direito fundamental completo⁷⁷ e que, se uma parte do conjunto é violada, é violado o “direito fundamental”. A primeira forma tem a vantagem de evitar diversas incompreensões e simplificações que podem estar associadas à concepção de violação de um direito fundamental por meio de um particular. A segunda tem a vantagem da coerência dogmática. Talvez seja recomendável manter ambas as formas de expressão à disposição e, sempre que houver a possibilidade de incompreensões, explicar a segunda com o auxílio da primeira.

77. Cf., a esse respeito, Capítulo 4, III.

III – SISTEMA JURÍDICO E ARGUMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

1. Direitos fundamentais e a natureza do sistema jurídico

A irradiação das normas de direitos fundamentais a todos os ramos do direito, um de cujos aspectos mais problemáticos – os efeitos perante terceiros ou efeitos horizontais – acabou de ser analisado, tem amplas conseqüências na natureza do sistema jurídico. Três dessas conseqüências têm significado especial.

A primeira é a limitação dos possíveis conteúdos do direito ordinário. Embora a constituição, enquanto constituição mista material-procedimental, não determine todo o conteúdo do direito ordinário, os direitos fundamentais excluem alguns conteúdos como constitucionalmente impossíveis e exigem alguns conteúdos como constitucionalmente necessários. Isso vale para todos os procedimentos de criação do direito existentes no sistema jurídico, isto é, também para a competência privada para estabelecer obrigações jurídicas por meio de contratos, necessária do ponto de vista dos direitos fundamentais. Assim, em virtude da vigência das normas de direitos fundamentais, o sistema jurídico tem a natureza de um sistema jurídico *substancialmente determinado* por meio da Constituição.

A segunda conseqüência decorre do tipo de determinação substancial. A determinação substancial seria algo não-problemático se sempre fosse claro aquilo que é devido em razão das normas de direitos fundamentais. Mas esse não é o caso. A razão para tanto não reside apenas na abertura semântica e estrutural das disposições de direitos fundamentais, mas sobretudo na natureza principiológica das normas de direitos fundamentais. Essa natureza principiológica implica a necessidade de sopesamentos. Embora o processo de sopesamento seja, como já foi demonstrado,⁷⁸ um processo racional, ele não é um processo que sempre leva a uma única solução para cada caso concreto. Decidir qual solução será considerada como correta após o sopesamento é algo que depende de valorações que não são controláveis pelo próprio processo de sopesar. Nesse sentido, o sopesamento é um pro-

78. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.

cedimento aberto. Mas a abertura do sopesamento conduz a uma abertura do sistema jurídico substancialmente determinado pelas normas de direitos fundamentais. Assim, em virtude da vigência das normas de direitos fundamentais, o sistema jurídico adquire um caráter de sistema jurídico *aberto*, independentemente da extensão dessa abertura.

A terceira consequência diz respeito ao tipo de abertura. A vigência das normas de direitos fundamentais significa que o sistema jurídico é um sistema aberto *em face da Moral*. Isso é perceptível de forma clara no caso dos conceitos materiais básicos de direitos fundamentais, os conceitos de dignidade, de liberdade e de igualdade. Esses conceitos são, ao mesmo tempo, conceitos fundamentais da Filosofia prática. Com eles, os princípios mais importantes do direito racional moderno são incorporados à Constituição e, com isso, ao direito positivo.⁷⁹ A definição desses princípios e o sopesamento entre eles leva ao problema da justiça. Isso fica claro, de forma exemplar, a partir dos princípios da justiça formulados por Rawls,⁸⁰ que nada mais são que uma tentativa de estabelecer uma relação entre a liberdade e a igualdade. Quando o Tribunal Constitucional Federal afirma que o legislador constituinte se esforçou “em realizar a idéia de justiça na Constituição alemã”,⁸¹ isso diz respeito sobretudo aos princípios de direitos fundamentais. A irradiação dos direitos fundamentais como direito positivo em todos os âmbitos do sistema jurídico inclui, portanto, uma irradiação – requerida pelo direito positivo – da idéia de justiça a todos os ramos do Direito.

2. Sobre o problema da competência de controle do tribunal constitucional

A determinação substancial por meio de critérios abertos em face da Moral suscita uma série de questões. Em um sistema jurídico que tem uma jurisdição constitucional abrangente, como é o caso do sistema da República Federal da Alemanha, os problemas que a determi-

79. Cf. Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, p. 124; Martin Kriele, *Recht und praktische Vernunft*, p. 124.

80. Cf. John Rawls, *A Theory of Justice*, pp. 302-303.

81. BVerfGE 3, 225 (233). Cf. também Gerhard Robbers, *Gerechtigkeit als Rechtsprinzip*, Baden-Baden: Nomos, 1980.

nação substancial causam para a jurisdição constitucional têm um papel especial. No centro do longo e árduo debate acerca da jurisdição constitucional⁸² encontra-se o problema do equilíbrio entre a competência do tribunal constitucional e a do legislador. Uma solução perfeita existiria em um sistema de regras que fornecesse, em cada caso, uma única resposta à pergunta sobre se o tribunal extrapolou, ou não, sua competência nos casos em que, de alguma forma, tenha agido contra o legislador. No entanto, não apenas não se pode contar atualmente com uma solução desse tipo, como também é possível indagar, tendo em vista o enraizamento do problema em questões fundamentais, se existe alguma possibilidade de tal solução ser algum dia possível. De qualquer forma, uma coisa parece certa: fórmulas gerais como *judicial self restraint* não ajudam muito. Necessária é uma solução diferenciada.⁸³ Quando, na decisão sobre co-gestão, no que diz respeito ao controle dos prognósticos do legislador, o Tribunal Constitucional Federal distingue entre um “controle por evidência”, um “controle de plausibilidade” e um “controle intensificado de conteúdo”,⁸⁴ ele corretamente expressa a direção a ser seguida na busca de uma solução.

Não é possível, aqui, analisar em detalhes os problemas da jurisdição constitucional. Isso significaria a abertura de um novo tema.

82. Sobre isso, cf., de um lado, as conferências de Triepel e Kelsen no congresso da Associação dos Professores Alemães de Direito Público, em 1928: Heinrich Triepel, “Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit”, *VVDStRL* 5 (1929), pp. 2 e ss.; Hans Kelsen, “Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit”, *idem*, pp. 30 e ss.; de outro lado, as conferências de Korinek, Müller e Schlaich no congresso da mesma associação, em 1980: Karl Korinek, “Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen”, *VVDStRL* 39 (1981), pp. 7 e ss.; Jörg Paul Müller, “Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen”, *idem*, pp. 53 e ss.; Klaus Schlaich, “Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen”, *idem*, pp. 99 e ss.; cf. também Peter Häberle (Org.), *Verfassungsgerichtsbarkeit*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976; Klaus Stern, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, v. II, München: Beck, 1980, pp. 933 e ss.; Josef Mackert/Franz Schneider, *Bibliographie zur Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder*, vs. I, II e II, Tübingen: Mohr, 1971, 1976, 1982.

83. Sobre tentativas nesse sentido, cf. Jost Delbrück, “Quo Vadis Bundesverfassungsgericht?”, in Jost Delbrück et al. (Org.), *Recht im Dienst des Friedens: Festschrift für Eberhard Menzel*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975, pp. 89 e ss.; Gunnar F. Schuppert, *Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit*, pp. 1 e ss.; Hans P. Schneider, “Verfassungsgerichtsbarkeit und Gewaltenteilung”, *NJW* 33 (1980), pp. 2.103 e ss.

84. *BVerfGE* 50, 290 (333).

O que aqui interessa é apenas saber quais são, para esses problemas, as conseqüências de uma visão especificamente ligada aos direitos fundamentais.

O ponto de partida é a idéia de que os direitos fundamentais, enquanto direitos individuais em face do legislador, são posições que, por definição, fundamentam deveres do legislador e restringem suas competências. O simples fato de um tribunal constitucional agir no âmbito da legislação quando constata, por razões ligadas aos direitos fundamentais, um não-cumprimento de um dever ou uma violação de competência por parte do legislador não justifica uma objeção de uma transferência inconstitucional das competências do legislador para o tribunal. Se a Constituição confere ao indivíduo direitos contra o legislador e prevê um tribunal constitucional (também) para garantir esses direitos, então, a atividade do tribunal constitucional no âmbito da legislação que seja necessária à garantia desses direitos não é uma usurpação inconstitucional de competências legislativas, mas algo que não apenas é permitido, mas também exigido pela Constituição.

Isso significa que não está em discussão *se* o tribunal constitucional tem competências de controle no âmbito da legislação, mas apenas qual é a sua *extensão*. Neste ponto, é imprescindível distinguir três níveis de argumentação: o da argumentação material; o da funcional ou relativa a competências; e o da metodológica ou epistemológica.

Está-se no nível *material* quando o Tribunal Constitucional Federal, na mencionada decisão sobre co-gestão, faz com que a “prerrogativa do legislador para fazer estimativas” e, com isso, a competência de controle do tribunal dependam, dentre outros, “da importância dos bens jurídicos em jogo”.⁸⁵ Isso significa que o peso dos princípios materiais relevantes é fator que desempenha um papel na determinação da medida da competência de controle nos casos concretos ou em determinados grupos de casos.

Trata-se de argumentos do nível *funcional* ou *relativo a competências* quando são aduzidas razões para a atribuição de competências decisórias que se baseiem em características, reais ou supostas, dos tomadores de decisão, como, por exemplo, em uma legitimação democrática mais intensa por parte do legislador parlamentar, em sua maior

85. BVerfGE 50, 290 (332-333).

capacidade de avaliar situações fáticas complexas, em uma maior facilidade em corrigir suas decisões e em uma maior aceitação dessas mesmas decisões; ou, de outro lado, em um maior grau de imparcialidade do tribunal constitucional, em sua capacidade para decidir questões jurídicas e em sua menor sujeição a pressões momentâneas.

Por fim, trata-se do nível *metodológico* ou *epistemológico* quando são utilizados argumentos favoráveis ou contrários à possibilidade de fundamentação racional de decisões no âmbito dos direitos fundamentais. As teses a esse respeito vão desde um profundo ceticismo metodológico, segundo o qual questões duvidosas só podem ser resolvidas a partir de uma “decisão por meio de uma eliminação autoritária da dúvida”,⁸⁶ até um abrangente racionalismo metodológico, segundo o qual há sempre uma única resposta correta para cada questão jurídica.⁸⁷

Uma solução adequada para o problema da competência de controle é possível apenas se os argumentos dos três níveis forem suficientemente levados em consideração. As tentativas mais recentes de se chegar a uma solução com o auxílio de um “método teórico-funcional”⁸⁸ pecam pela unilateralidade. Que é necessária uma interação entre os três níveis e que, nessa interação, a partir de uma perspectiva sistemática, não há uma primazia do nível funcional, mas sim dos níveis material e metodológico, é algo que pode ser percebido no fato de que, sempre que se pode fundamentar, com suficiente certeza, a existência de um direito subjetivo do indivíduo contra o Estado, as razões contrárias a uma competência de controle do tribunal têm que ceder. Portanto, a competência de controle do tribunal depende sempre essencialmente da *certeza* com a qual a *existência* de uma posição de direito fundamental possa ser fundamentada. Os próximos tópicos serão dedicados ao problema da certeza na fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais. Esse problema leva à relação entre argumentação e decisão.

86. Carl Schmitt, “Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung”, in Carl Schmitt, *Verfassungsrechtliche Aufsätze*, p. 81.

87. Cf. Ronald Dworkin, “Hard cases”, in Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 81 e ss.

88. Cf. Hans P. Schneider, “Verfassungsgerichtsbarkeit und Gewaltenteilung”, p. 2.104; Gunnar F. Schuppert, *Funktionell-rechtliche Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit*, pp. 38 e ss.; Gerhard Zimmer, *Funktion – Kompetenz – Legitimation*, Berlin: Duncker & Humblot, 1979, pp. 68 e ss.

3. Argumentação e decisão

O tema da certeza na fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais expressa apenas um aspecto do problema geral da existência de critérios e regras que permitam, no âmbito da Ciência do Direito, diferenciar fundamentações jurídicas certas e erradas. Enfrentar essa questão é tarefa da teoria da argumentação jurídica. Já me posicionei sobre isso, com mais profundidade, em outros trabalhos.⁸⁹ Aqui interessam apenas os problemas específicos da argumentação *no âmbito dos direitos fundamentais*.

3.1 Sobre a teoria geral da argumentação jurídica

O ponto de partida da teoria da argumentação jurídica é a constatação de que, no limite, a fundamentação jurídica sempre diz respeito a questões práticas, ou seja, àquilo que é obrigatório, proibido e permitido. O discurso jurídico é, por isso, um caso especial do discurso prático geral.⁹⁰ Enquanto caso especial do discurso prático geral, ele é caracterizado pela existência de uma série de condições restritivas, às quais a argumentação jurídica se encontra submetida e que, em resumo, se referem à vinculação à lei, ao precedente e à dogmática. Mas essas condições, que podem ser expressas por meio de um sistema de regras e formas específicas do argumentar jurídico,⁹¹ não conduzem a um único resultado em cada caso concreto. Em todos os casos minimamente problemáticos são necessárias valorações que não são dedutíveis diretamente do material normativo preexistente. Assim, a racionalidade do discurso jurídico depende em grande medida de se saber se e em que medida essas valorações adicionais são passíveis de um controle racional.

89. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978; idem, "Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation", *Rechtstheorie*, Beiheft 2 (1981), pp. 177 e ss.; Aulis Aarnio/Robert Alexy/Aleksander Peczenick, "Grundlagen der juristischen Argumentation", in *Verhandlungen des fünfzigsten Deutschen Juristentages*, v. II, pp. 9 e ss.

90. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 32 e ss., 263 e ss., 349 e ss.; cf. também Martin Kriele, *Recht und praktische Vernunft*, pp. 33-34; Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, p. 272.

91. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 273 e ss. e 364 e ss.

A questão da racionalidade na fundamentação jurídica leva, então, à questão acerca da possibilidade de fundamentação racional de juízos prático ou morais gerais. Desde há muito tempo a discussão acerca dessa questão é prejudicada por uma contraposição infrutífera de duas posições básicas, que reaparecem com frequência sob novas versões; de um lado ficam as posições subjetivistas, relativistas, decisionistas e/ou irracionaisistas; e, de outro, as posições objetivistas, absolutistas, cognitivistas e/ou racionalistas. Não há razões, no entanto, para uma postura baseada no tudo-ou-nada. A recente discussão no campo da Ética, influenciada, no plano metodológico, pela moderna Lógica, pela filosofia da linguagem e por teorias da argumentação, da decisão e da ciência e, no plano substancial, fortemente orientada por idéias kantianas,⁹² demonstrou que, embora não sejam possíveis teorias morais *substanciais* que forneçam a cada questão moral uma única resposta com certeza intersubjetiva conclusiva, são possíveis teorias morais *procedimentais*, que elaborem as regras e as condições da argumentação e da decisão racional prática.⁹³ Uma versão especialmente promissora de uma teoria moral procedimental é a teoria do discurso prático racional.⁹⁴

A vantagem da teoria do discurso está no fato de que suas regras, enquanto regras da argumentação prática racional, são substancialmente mais fáceis de se serem fundamentadas que as regras morais materiais. Mas é necessário pagar um preço por isso: em si, o procedimento discursivo é compatível com resultados os mais variados. Embora haja resultados discursivamente impossíveis e discursivamente necessários, sempre sobra um amplo espaço para o discursivamente possível. Essa deficiência não pode ser sanada no nível da teoria moral. Para saná-la é necessário associar a teoria moral com a teoria do direito. Essa associação é possível no âmbito de um modelo procedi-

92. Cf., a esse respeito, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 53 e ss.

93. Cf. Robert Alexy, "Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation", pp. 178 e ss.; do mesmo autor, "Juristische Argumentation und praktische Vernunft", *Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, 1982, pp. 29-30.

94. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 221 e ss.; Jürgen Habermas, *Diskursethik – Notizen zu einem Begründungsprogramm*, pp. 53 e ss.

mental em quatro níveis.⁹⁵ Os quatro níveis do modelo são: (1) o discurso prático geral; (2) o processo legislativo; (3) o discurso jurídico; e (4) o processo judicial.

No primeiro nível está o *discurso prático geral*. Embora seu sistema de regras estabeleça algo como um código geral da razão prática,⁹⁶ ele de forma alguma conduz a apenas um resultado em cada caso. Mas a solução de conflitos sociais exige a definição de um único resultado. Isso torna necessário, no segundo nível, um procedimento institucional de criação do direito, no âmbito do qual não apenas se argumenta, mas também se decide.⁹⁷ Um exemplo paradigmático de um tal procedimento é o *processo legislativo* do Estado Democrático constitucional, o qual é definido por um sistema de regras que, diante das alternativas fáticas possíveis, garante um grau significativo de racionalidade prática e que, nesse sentido, é passível de fundamentação no âmbito do primeiro procedimento.

Mas mesmo por meio do processo legislativo não é possível determinar, de antemão e para cada caso, uma única solução, como demonstram tanto experiências históricas quanto reflexões conceituais. Isso justifica a necessidade de um terceiro procedimento, o procedimento do *discurso jurídico*. Como o primeiro, esse procedimento não é institucionalizado em um sentido estrito; por outro lado, e ao contrário dele, encontra-se sob a vinculação à lei, ao precedente e à dogmática. Essa vinculação tem como consequência uma considerável redução na incerteza quanto ao resultado do discurso prático geral. Mas, em razão da necessidade de uma argumentação prática geral no âmbito da argumentação jurídica, a incerteza quanto ao resultado não é eliminada. Isso leva à necessidade de um quarto procedimento – nes-

95. Cf. Robert Alexy, "Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation", pp. 185 e ss.

96. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, p. 234. Sobre isso, cf. Marteen Henket, "Towards a Code of Practical Reason?", *ARSP*, Beiheft 25 (1985), pp. 36 e ss.

97. A esse argumento a favor da institucionalização de um ordenamento jurídico, baseado nos limites da cognição prática, soma-se o argumento da coação. Esse argumento baseia-se no fato de que a concordância de todos os participantes do discurso acerca de uma regra não tem como consequência necessária sua obediência. Uma combinação do argumento da cognição com o da coação, no âmbito de uma fundamentação da necessidade de uma ordem jurídica institucionalizada, pode ser encontrada em Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, p. 312.

se caso, institucionalizado em sentido estrito —, a saber, o *processo judicial*, no qual, da mesma forma que ocorre no processo legislativo, não apenas se argumenta, mas também se decide. Os resultados desse procedimento são racionais se suas regras e sua execução satisfizerem os requisitos dos primeiros três procedimentos. O fato de as questões valorativas deixadas em aberto pelo material normativo existente serem, no processo judicial, objeto não apenas da argumentação, mas também da decisão, não implica uma renúncia à racionalidade. Em primeiro lugar, porque essas questões valorativas são decididas a partir de vinculações que, enquanto tais, e como demonstra o modelo, são racionais; em segundo lugar, porque essas questões valorativas podem ser decididas com base em uma argumentação prática racional, o que confere à decisão um caráter racional mesmo que mais de uma decisão seja possível nos termos das regras da argumentação prática racional.

3.2 *A base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais*

Para abranger a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais, esse modelo precisa ser complementado. O discurso nesse âmbito não está vinculado às decisões tomadas no processo legislativo; ele o precede. Isso significa que, nele, não está à disposição o fator de vinculação mais importante para a argumentação jurídica geral: a lei ordinária, em geral relativamente concreta. No seu lugar aparecem as disposições de direitos fundamentais, extremamente abstratas, abertas e ideologizadas. A questão é saber o que isso significa para a controlabilidade racional da decisão no âmbito dos direitos fundamentais. Para responder a essa pergunta, é recomendável distinguir entre a *base* e o *processo* da argumentação nesse âmbito.

Desconsiderando-se algumas poucas diferenças importantes, a base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais, da mesma forma que ocorre com a argumentação jurídica geral, pode ser identificada pelos termos “lei”, “precedente” e “dogmática”. Sobre esses termos será, aqui, discutido apenas o estritamente necessário para demonstrar que a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais pode ser uma argumentação racional.

3.2.1 Texto e vontade

No âmbito dos direitos fundamentais, por vinculação da argumentação “à lei” deve ser compreendida uma vinculação ao *texto* das disposições de direitos fundamentais e à *vontade* do legislador constituinte. Expressão dessa vinculação são, sobretudo, as regras e formas da interpretação semântica e da interpretação genética.⁹⁸ Na interpretação genética inclui-se ainda a interpretação subjetiva-teleológica, que se refere aos objetivos que o legislador constituinte associou às disposições de direitos fundamentais.⁹⁹ As regras e formas das interpretações sistemática, histórica e comparativa podem desempenhar um papel complementar na análise do texto e da vontade. Elas não serão abordadas aqui. Já a interpretação objetiva-teleológica, que se refere aos objetivos que o intérprete atribui à lei, não se insere no contexto da vinculação à lei.¹⁰⁰

Com frequência se sublinha, e com razão, que a extensão e a força da vinculação da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais a argumentos semânticos e genéticos são limitadas.¹⁰¹ A relativamente pequena *extensão* dessa vinculação decorre da abertura das disposições de direitos fundamentais e também do fato de que em muitos casos nada se pode inferir, ou apenas muito pouco, da história da gênese da constituição. A *força* dessa vinculação é relativizada pela constatação de que nem sempre os argumentos semânticos e genéticos, quando relevantes, conseguem forçar o resultado por eles requerido. Eles podem ser superados por outros argumentos. Isso faz com que fique claro que, no âmbito dos direitos fundamentais, a interpretação semântica e a interpretação genética, isoladamente consideradas, são absolutamente insuficientes para vincular a argumentação. Mas seria um erro concluir que elas em nada contribuem para essa vinculação.¹⁰²

98. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 289 e ss.

99. Idem, pp. 251-252.

100. Cf. Robert Alexy, “Teleologische Auslegung und Gesetzesbindung”, *Sprache und Recht – Loccumer Protokolle* 31 (1980), pp. 143 e ss.

101. Cf., por todos, Hans Huber, “Über die Konkretisierung der Grundrechte”, in *Der Staat als Aufgabe*, pp. 192 e ss.; Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Die Methoden der Verfassungsinterpretation”, *NJW* 29 (1976), pp. 2.090-2.091.

102. Huber defende a concepção segundo a qual, nesse âmbito, “a interpretação jurídica tradicional está fora de lugar e fracassa” (Hans Huber, “Über die Konkre-

É possível conciliar muita coisa com o texto¹⁰³ das disposições constitucionais, mas não tudo. O fato de o texto requerer ou excluir uma determinada interpretação é um argumento muito forte a favor ou contra essa interpretação. Um exemplo de uma decisão na qual um argumento semântico desempenha papel decisivo é a decisão sobre a competência do oficial de justiça para realizar buscas, para a qual o Tribunal Constitucional Federal exige uma decisão judicial,¹⁰⁴ sobretudo em razão do texto do art. 13, § 2º, da Constituição (“Buscas poderão ser decretadas apenas pelo juiz”). Mas afirmar que o argumento semântico é um argumento muito forte não significa que ele sempre prevaleça. Isso fica claro com a decisão sobre farmácias, na qual, contra o texto do art. 12, § 1º, 1, da Constituição, a liberdade de escolha da profissão foi submetida à reserva de regulamentação do art. 12, § 1º, 2.¹⁰⁵ Ainda assim, essa decisão demonstra também a força do argumento semântico. Para superá-lo não é suficiente demonstrar que a solução contrária ao texto é melhor que a com ele compatível; as razões para a solução contrária ao texto têm que ser extremamente fortes para que, do ponto de vista da Constituição, o afastamento do teor literal fique justificado.¹⁰⁶ Na decisão sobre farmácias o tribunal pôde apresentar tais razões. Assim, o texto das disposições de direitos fundamentais vinculam a argumentação por meio da criação de um ônus argumentativo a seu favor.

tisierung der Grundrechte”, p. 195). Se com isso se quer dizer que a interpretação semântica e a interpretação genética, enquanto cânones clássicos, não desempenham nenhum papel na argumentação no âmbito dos direitos fundamentais, então, essa tese é equivocada. Contudo, o próprio Huber restringe a radicalidade de sua tese: “no máximo, é possível apenas preparar o terreno para a verdadeira compreensão dos direitos fundamentais”. Com isso, no entanto, concedeu-se ao menos um certo papel aos cânones clássicos. O mesmo vale para Böckenförde, que, embora saliente a “insuficiência das regras clássicas de interpretação”, conserva seu papel ao pretender introduzir a teoria constitucional que ele considera como decisiva “na aplicação das regras clássico-hermenêuticas de interpretação” (Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Die Methoden der Verfassungsinterpretation”, p. 2.091).

103. Sobre as possibilidades e limites da interpretação semântica, cf. Hans-Joachim Koch/Helmut Rüßmann, *Juristische Begründungslehre*, pp. 126 e ss.

104. BVerfGE 51, 97 (106-107).

105. BVerfGE 7, 377 (400 e ss.).

106. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, p. 305; Martin Kriele, *Recht und praktische Vernunft*, pp. 79 e ss.

O mesmo vale para a história da gênese da Constituição. O Tribunal Constitucional Federal reiteradamente defende a tese "de que à história da gênese da Constituição não pode ser atribuído um significado decisivo na interpretação de dispositivos específicos da Constituição".¹⁰⁷ Mas afirmar que os argumentos genéticos não têm um significado decisivo não implica dizer que eles não tenham nenhuma importância. É certo que com frequência não é possível inferir algo inequívoco a partir da história da gênese constitucional. De fato, tentar se apoiar nela seria adentrar superfície instável.¹⁰⁸ Mas se dela resultar algo inequívoco a favor ou contra determinada interpretação, então, isso deve ser usado como argumento; e para que esse argumento não seja seguido são necessárias razões que justifiquem esse não-seguimento.

Assim, embora a extensão e a força da vinculação "à lei" na argumentação no âmbito dos direitos fundamentais seja limitada, ela existe. Isso não contradiz a teoria dos princípios. Como já foi demonstrado, as normas de direitos fundamentais têm um duplo caráter, como regras e princípios.¹⁰⁹ Na medida em que o legislador constituinte tenha tomado decisões na forma de regras, elas são vinculantes, a não ser que seja possível introduzir razões constitucionais suficientes contra essa vinculação.

3.2.2 Precedentes

A segunda parte da base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais é formada pelos precedentes. As palavras de Smend expressam sua importância: "na prática, a Constituição vale, atualmente, tal como interpretada pelo Tribunal Constitucional Federal".¹¹⁰ Essa importância corresponde à auto-avaliação do tribunal como "intérprete principal e guardião da Constituição".¹¹¹ Nos detalhes, contudo, há

107. *BVerfGE* 51, 97 (110); 6, 389 (431); 41, 291 (309).

108. Cf. Günter Dürig, "Anmerkung zum Elfes-Urteil", *JZ* 12 (1957), p. 169.

109. Cf. Capítulo 3, II.3.3.

110. Rudolf Smend, "Festvortrag zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts am 26. Januar 1962", in *Bundesverfassungsgericht (Org.)*, *Das Bundesverfassungsgericht*, 2ª ed., Karlsruhe: Müller, 1971, p. 16.

111. *BVerfGE* 40, 88 (93).

ainda inúmeras questões em aberto,¹¹² como mostra a discussão sobre a força jurídica das decisões do Tribunal Constitucional Federal, seu efeito vinculante sobre os órgãos estatais, nos termos do § 31, 1, da lei sobre o Tribunal Constitucional Federal, e sua força de lei, determinada, em uma série de casos, nos termos do § 31, 2, da mesma lei. Aqui, interessa apenas a força geral das decisões do Tribunal Constitucional Federal, enquanto precedentes, para a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais. A forma como essa força, conferida às decisões do Tribunal Constitucional Federal e a todas as decisões judiciais, se relaciona com a força jurídica, o efeito vinculante e a força de lei, nos termos do § 31, 1 e 2, da lei do Tribunal Constitucional Federal, é algo que ficará em segundo plano. De qualquer forma, a força jurídica manifesta-se somente nos casos de litígios com idêntico objeto,¹¹³ os efeitos vinculantes, nos termos do § 31, 1, segundo a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, não afetam ela própria¹¹⁴ e, com isso, também não afetam a argumentação que se refira às decisões da jurisdição constitucional; e a força de lei, nos termos do § 31, 2, se é que ela vincula o Tribunal Constitucional Federal,¹¹⁵ não cria nenhuma vinculação que vá além da já presente na força jurídica.¹¹⁶ Se se parte da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, então, a

112. Cf., por todos, Michael Sachs, *Die Bindung des Bundesverfassungsgerichts an seine Entscheidungen*, München: Vahlen, 1977; Norbert Wischermann, *Rechtskraft und Bindungswirkung verfassungsgewichtlicher Entscheidungen*, Berlin: Duncker & Humblot, 1979; Rüdiger Zuck, "Die Selbstbindung des Bundesverfassungsgerichts", *NJW* 28 (1975), pp. 907 e ss.; Hermann Maassen, "Probleme der Selbstbindung des Bundesverfassungsgerichts", *NJW* 28 (1975), pp. 1.343 e ss.; Klaus Vogel, "Rechtskraft und Gesetzeskraft", in Christian Starck (Org.), *Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz*, v. 1, Tübingen: Mohr, 1976, pp. 568 e ss.; Klaus Lange, "Rechtskraft, Bindungswirkung und Gesetzeskraft der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts", *JuS* 18 (1978), pp. 1 e ss.

113. *BVerfGE* 4, 31 (39); 20, 56 (86-87). Além disso, o Tribunal Constitucional Federal mantém elástica sua vinculação mesmo quando ele já decidiu anteriormente sobre uma determinada norma, como demonstram suas decisões sobre novas representações nos termos do art. 100, § 1º, 1, da Constituição alemã. Cf. *BVerfGE* 33, 199 (203-204); 39, 169 (181-182).

114. *BVerfGE* 4, 31 (38); 20, 56 (87).

115. Em sentido contrário, cf. Hans J. Wolff/Oto Bachoff, *Verwaltungsrecht*, I, p. 127; em sentido favorável, e com referências adicionais, cf. Klaus Lange, "Rechtskraft, Bindungswirkung und Gesetzeskraft", p. 8.

116. Cf. *BVerfGE* 33, 199 (203-204); cf. também Klaus Lange, "Rechtskraft, Bindungswirkung und Gesetzeskraft", p. 8.

força geral dos precedentes desempenha um papel considerável, ao lado da vinculação criada pelos institutos apresentados acima; mas, se se considera a força geral dos precedentes como já incluída na vinculação decorrente desses institutos, sobretudo a partir do § 31, 1, da lei do Tribunal Constitucional Federal,¹¹⁷ então, por mais que se confira àquela força uma fundamentação adicional de natureza jurídico-positiva, daí nada resulta de objetivamente novo.

As duas regras principais para a utilização de precedentes são:

- (1) Se é possível utilizar um precedente favorável ou contrário a uma decisão, ele deverá ser utilizado.
- (2) Aquele que pretende afastar o precedente tem o ônus argumentativo para tanto.¹¹⁸

A fundamentação dessas regras, já realizada em outro lugar, não será, aqui, repetida. Aqui, basta mencionar que os principais argumentos se baseiam na igualdade, na segurança jurídica, na proteção da confiança, na redução da carga de trabalho e na estabilidade como base do desenvolvimento.¹¹⁹ No presente contexto interessa apenas analisar o que essas regras significam para a controlabilidade racional da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais.

Em virtude do princípio da universalizabilidade,¹²⁰ é possível retirar de toda decisão do Tribunal Constitucional Federal uma regra de decisão mais ou menos concreta relativa ao caso decidido. Um exemplo paradigmático de uma tal regra de decisão é a regra da decisão Lebach, já diversas vezes mencionada: "No conjunto, portanto, a repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um interesse atual pela informação, é necessariamente inadmissível se com isso se coloca em risco a ressocialização do autor".¹²¹

117. Cf., por exemplo, Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung*, pp. 299 e ss.; Michael Sachs, *Die Bindung des Bundesverfassungsgerichts an seine Entscheidungen*, p. 139.

118. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, p. 339.

119. Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung*, pp. 258 e ss.; do mesmo autor, *Recht und praktische Vernunft*, pp. 96 e ss.; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 335 e ss.

120. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 274 e 335-336; Neil McCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, pp. 73 e ss.

121. BVerfGE 35, 202 (237).

Quando os casos são suficientemente iguais, regras de decisão dessa espécie são reiteradamente aplicadas. É possível ler em uma das diversas decisões sobre atraso dos correios: “[o] Tribunal Constitucional Federal já decidiu inúmeras vezes que, no âmbito das previsões jurídico-procedimentais sobre o restabelecimento de uma situação prévia, não é possível imputar ao cidadão os atrasos no transporte ou na entrega de correspondência por parte do Correio alemão (*BVerfGE* 45, 360 (362); 46, 404 (406), com referências adicionais)”.¹²² A força da regra de decisão, enquanto precedente, é perceptível não apenas nos casos em que o tribunal repetidamente aplica uma regra criada em decisão anterior, mas também nos casos em que ele a estende a casos com novas características, ou nos casos nos quais, em razão da existência de uma nova característica, essa extensão não é realizada. Um exemplo de extensão é oferecido pela decisão sobre a prorrogação da prisão preventiva em razão da excessiva carga de trabalho do Tribunal Estadual. O tribunal, em primeiro lugar, faz referência a uma série de decisões anteriores nas quais se concluiu que uma extrapolação do prazo fixado no § 121, 1, do Código de Processo Penal é sempre inadmissível se tiver sido causada pelo fato de que “as autoridades e tribunais responsáveis pela investigação e pelo processo penal não tenham tomado as medidas cabíveis para que o inquérito fosse concluído o mais rápido possível e para se chegar a uma decisão judicial sobre os atos imputados ao acusado”. Depois, afirmou-se: “mas o mesmo deve também valer caso o motivo da extrapolação do prazo resida no fato de que, após o início do procedimento principal, a realização da audiência principal, em um processo já pronto para essa audiência, seja atrasada consideravelmente em razão de falhas ou demoras evitáveis por parte da organização judiciária”.¹²³ Um exemplo de não-extensão é oferecido pela decisão sobre o limite de idade para a pensão para órfãos.¹²⁴ Em uma decisão anterior o tribunal havia concluído pela inadmissibilidade de uma restrição do direito à pensão apenas aos órfãos que não fossem casados;¹²⁵ na decisão posterior o que estava em questão era a admissibilidade de um limite de idade fixado em 25 anos. No que diz respeito à força do precedente, o importante é o

122. *BVerfGE* 53, 25 (28).

123. *BVerfGE* 36, 264 (273).

124. *BVerfGE* 40, 121.

125. *BVerfGE* 28, 324 (347).

fato de o tribunal fazer referência à decisão anterior e expor a razão pela qual considera que o limite de idade deve ser julgado de forma distinta daquela em relação à restrição a órfãos não-casados. Isso ilustra como a práxis decisória continuada do Tribunal Constitucional Federal conduz a pontos fixos para a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais.

Se reuníssemos todas as regras de decisão do Tribunal Constitucional Federal, seria possível obter uma rede de normas relativamente abrangente e densa. Cada nova decisão contribui para a uma maior densidade. Alguém poderia alegar, então, que a vinculação a esse sistema de normas significa um excesso de vinculação, e não o contrário. A crítica baseada em um suposto empedernimento seria o próximo passo. Mas essa crítica pode ser refutada. Em primeiro lugar, é necessário fazer referência à possibilidade de *distinção* (*distinguishing*) e *superação* (*overruling*):¹²⁶ por mais densa que seja a rede de regras de decisão, novos casos sempre apresentam novas características, que podem servir como razões para uma diferenciação. Além disso, a força vinculante das regras de decisão é apenas *prima facie*. Uma regra de decisão pode ser abandonada se forem apresentadas razões suficientes para tanto.¹²⁷ Em segundo lugar, é necessário sublinhar que, por trás do sistema de regras de decisão, os princípios mantêm sua vigência. Nos casos mais simples, isto é, naqueles em que os princípios não exijam uma decisão distinta daquela da regra de decisão, é certo que uma densa e bem estabelecida rede de regras de decisão torna supérfluo um amplo sopesamento entre princípios – isso explica por que, com o envelhecer da jurisprudência constitucional, o recurso à ordem de valores fica cada vez mais raro.¹²⁸ Mas isso não significa que os princípios percam sua vigência. Tão logo surja uma dúvida, eles logo voltam à tona, e podem desenvolver sua força modificadora e superadora de regras.

126. Cf. Martin Kriele, *Theorie der Rechtsgewinnung*, pp. 275 e ss.; Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory*, pp. 219 e ss.

127. A força vinculante das decisões do Tribunal Constitucional Federal não significa, portanto, uma “canonização de enunciados do Tribunal Constitucional Federal”; cf., nesse ponto, Klaus Schlaich, “Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen”, p. 138.

128. Cf. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 299.

Isso já faz com que fique claro que o fortalecimento racionalmente justificável da argumentação por meio da força vinculante das decisões do Tribunal Constitucional Federal não significa um empecimento. Contudo, isso implica, ao mesmo tempo, que o grau de segurança produzido pelos precedentes é limitado. Além disso, o grau de segurança é também diminuído em razão das inúmeras e extremamente abertas fórmulas utilizadas pelo Tribunal Constitucional Federal. Diante de muitas delas é possível falar em um não-fortalecimento fortalecido por meio de precedentes. Exemplos paradigmáticos são a máxima da proporcionalidade, a proibição de arbítrio e a fórmula da natureza humana. Elas significam que, no que diz respeito à vinculação a precedentes, a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais é não apenas algo aberto em um sentido negativo, em razão dos limites de toda vinculação a precedentes, mas também algo que é mantido aberto em um sentido positivo.

A contínua exclusão de possibilidades, que ocorre desde o momento da primeira decisão do Tribunal Constitucional Federal em 1951, tem, então, um duplo caráter. De um lado, muito do que foi decidido poderia ter sido decidido de outra forma; mas, de outro lado, decidiu-se também que o sistema de normas de direitos fundamentais é um sistema aberto em face das exigências dos princípios. Nesse sentido, embora os precedentes contribuam imprescindivelmente para a segurança na argumentação no âmbito dos direitos fundamentais, a argumentação neles baseada não é, sozinha, suficiente para o controle racional da fundamentação nesse âmbito.

3.2.3 Teorias materiais dos direitos fundamentais

A terceira parte da base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais foi caracterizada acima sob a rubrica "dogmática". No primeiro capítulo deste livro foi demonstrado que é possível distinguir três dimensões da dogmática jurídica: uma analítica, uma empírica e uma normativa.¹²⁹ A questão acerca da base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais tem como escopo a dimensão normati-

129. Cf. Capítulo 1, I.2.

va e, mais precisamente, as teorias normativas dogmáticas dos direitos fundamentais.

Teorias dogmáticas podem apresentar graus de abstração muito distintos.¹³⁰ Aqui, interessam apenas as teorias normativas gerais dos direitos fundamentais, ou seja, apenas teorias com grau de abstração relativamente alto. Essas teorias foram denominadas "teorias materiais dos direitos fundamentais". Nesse sentido, não são teorias materiais, de um lado, as teorias puramente analíticas e as teorias puramente empíricas e, de outro, as teorias normativas dedicadas apenas a disposições de direitos fundamentais específicas ou apenas a determinados problemas relacionados aos direitos fundamentais, e que, portanto, não são teorias gerais.

É possível indagar se é procedente considerar teorias materiais de direitos fundamentais como base da argumentação sobre esses direitos. Embora essas teorias devam ser fundamentadas a partir do texto constitucional, da vontade do legislador constituinte e dos precedentes do Tribunal Constitucional Federal, na medida em que elas são mais que uma mera repetição do texto constitucional, da vontade do constituinte e dos precedentes, elas não podem basear-se nem diretamente na autoridade da Constituição, nem diretamente nos precedentes do Tribunal Constitucional Federal. Se elas alcançam uma ampla aceitação,¹³¹ mas isso pode ser abalado a qualquer tempo por meio de argumentos. Lei, precedente e dogmática constituem uma clara linha decrescente de força dotada de autoridade. Enquanto base para a argumentação, as teorias materiais dos direitos fundamentais têm, portanto, uma natureza essencialmente argumentativa, e não uma baseada na autoridade. A idéia de uma base para a argumentação que seja ancorada argumentativamente é acusada de ser circular. Mas essa objeção pode ser afastada com o auxílio da distinção entre base e processo. Nada há de circular na concepção segundo a qual uma teoria estabelecida por meio de um processo argumentativo, ainda que seja passível de refutação, compõe, enquanto não for refutada, uma base

130. Cf. Ralf Dreier, "Theoriebildung in der Jurisprudenz", in Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, p. 73.

131. Cf. Horst Ehmke, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation", *VVDStRL* 20 (1963), pp. 71-72.

para a argumentação subsequente. Em vista disso, o que se deve indagar é como uma tal teoria material dos direitos fundamentais pode ser criada e como ela pode contribuir para um controle racional da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais.

Uma teoria material dos direitos fundamentais como teoria normativa geral é possível apenas na forma de uma teoria dos princípios. Acima já se demonstrou que princípios e valores são a mesma coisa, de um lado em uma roupagem deontológica e, de outro, em uma roupagem axiológica.¹³² Se se parte de um conceito suficientemente amplo de finalidade, torna-se também possível passar à terceira categoria de conceitos práticos, a categoria dos conceitos antropológicos,¹³³ e, ao invés de se falar, por exemplo, em princípio da liberdade ou em liberdade como valor, é possível falar em liberdade como finalidade. Portanto, teorias materiais dos direitos fundamentais podem ser expressas não apenas como teorias de princípios, mas também como teorias de valores ou teorias teleológicas gerais dos direitos fundamentais.

Segundo Böckenförde, uma teoria dos direitos fundamentais é “uma concepção sistematicamente orientada sobre o caráter geral, a determinação normativa de objetivos e a extensão substancial dos direitos fundamentais”.¹³⁴ Como já mencionado anteriormente,¹³⁵ Böckenförde identifica cinco dessas teorias: “a teoria liberal ou do Estado de Direito burguês, a teoria institucional, a teoria axiológica, a teoria democrático-funcional e a teoria do social-estatal”.¹³⁶ Essa clas-

132. Cf. Capítulo 3, III.1.3.

133. Cf. Capítulo 3, III.1.1.

134. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, *NJW* 27 (1974), p. 1.529.

135. Cf. Capítulo 1, II.

136. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, p. 1.530. Uma classificação semelhante pode ser encontrada em Klaus Kröger, *Grundrechtstheorie als Verfassungsproblem*, Baden-Baden: Nomos, 1978, pp. 15 e ss. Outras classificações são possíveis e são defendidas por outros autores. Scheuner, por exemplo, distingue entre duas “concepções básicas”: uma que segue a “tradição liberal” e uma que pretende, “ao lado do ponto de vista da garantia da liberdade, conferir validade a outros princípios de garantia dos direitos fundamentais, concebidos de forma fortemente objetiva” (Ulrich Scheuner, “Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat”, *DÖV* 24 (1971), p. 507). Uma classificação tripla pode ser encontrada em Grabitz, segundo o qual há “três modelos básicos de interpretação” dos direitos fundamentais: os modelos das teorias dos Estados de Direito liberal, material e social (cf. Eberhard Grabitz, “Freiheit als Verfassungsprinzip”, *Rechtstheorie* 8 (1977), pp. 4

sificação reúne coisas bastante distintas em um mesmo nível. Por conseguinte, ela tem um caráter menos sistemático, e mais o de uma apresentação das concepções gerais existentes na nova dogmática dos direitos fundamentais.

Três das teorias mencionadas – a liberal, a democrática e a social-estatal – podem ser facilmente identificadas como teorias teleológicas gerais ou teorias dos princípios. Uma teoria *liberal* em sua forma mais forte é defendida por aqueles que vêem na liberdade individual de ação e de decisão, no sentido de ausência de intervenção estatal, a única finalidade dos direitos fundamentais, ou seu “único bem protegido”,¹³⁷ ou seja, aqueles para os quais apenas o princípio da liberdade negativa dirigida contra o Estado é válido enquanto princípio de direito fundamental.¹³⁸ Versões mais fracas de uma teoria liberal surgem quando esse princípio não é visto como o único princípio de direito fundamental, mas apenas como um princípio que tem precedência *prima facie* em relação aos outros princípios de direitos fundamentais. Uma das versões mais fortes de uma teoria *democrática* é defendida por Krüger, segundo o qual os direitos fundamentais, desde que não digam respeito à esfera privada ou íntima, “representam acima de tudo posições de uma livre participação na comunidade”.¹³⁹ Isso significa que os princípios democráticos são incluídos nos princípios de direitos fundamentais e a eles é atribuída, no mínimo, uma precedência *prima facie*.¹⁴⁰ Características de uma teoria *social-estatal* são te-

e ss.). Por fim, uma classificação quádrupla pode ser baseada na distinção, feita por Klein, entre as “quatro dimensões do conceito jurídico-constitucional de liberdade”: o conceito de “liberdade em face do Estado”, o de “autodeterminação política”, o de “participação social” e o de “pretensão à proteção estatal contra o poder social” (cf. Hans H. Klein, *Grundrechte im demokratischen Staat*, p. 48).

137. Cf. Hans H. Klein, *Die Grundrechte im demokratischen Staat*, p. 64. Cf. também Ernst Forsthooff, “Zur heutigen Situation einer Verfassungslehre”, in Hans Barion et al. (Orgs.), *Epirrhosis, Festgabe für Carl Schmitt*, p. 195; Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, p. 164.

138. O princípio da igualdade jurídica não será considerado nesse contexto.

139. Herbert Krüger, “Der Wesensgehalt der Grundrechte i. S. des Art. 19 GG”, *DÖV* 8 (1955), p. 45. Cf. também Wolfgang Abendroth, *Das Grundgesetz*, 7ª ed., Pfullingen: Neske, 1978, p. 76; Helmut Ridder, “Meinungsfreiheit”, in Franz L. Neumann/Hans C. Nipperdey/Ulrich Scheuner (Orgs.), *Die Grundrechte*, v. 2, Berlin: Duncker & Humblot, 1954, pp. 249 e ss. e 266.

140. Smend pode ser considerado o principal autor das teorias democráticas e de outras teorias não-liberais ou ao menos não exclusivamente liberais. Cf., por exem-

ses segundo as quais “a liberdade a que fazem referência os direitos fundamentais (...) consiste em chances e escolhas reais de vida”,¹⁴¹ ou que sustentam que a função dos direitos fundamentais deve ser vista como “a manutenção ou a criação de estruturas sociais que garantam a maior chance possível de desenvolvimento da personalidade”.¹⁴² Com isso se sustenta que o princípio da liberdade fática é um princípio de direito fundamental de, no mínimo, igual hierarquia em face do princípio da liberdade jurídica.

Dessas teorias, que definem atribuições de finalidades e pesos, distinguem-se, de maneira fundamental, as outras duas teorias mencionadas por Böckenförde: a teoria axiológica e a teoria institucional. Ser uma *teoria axiológica* é algo que diz apenas que se trata de uma teoria sobre algum valor qualquer, mas nada sobre de que valor se trata. É possível formular uma teoria axiológica isenta de suposições insustentáveis e também supérfluas por meio da teoria dos princípios.¹⁴³ A partir da terminologia finalística, é também possível, embora possa suscitar mal-entendidos, expressá-la por meio de um conceito amplo de finalidade. As reflexões anteriores demonstraram que uma teoria dos princípios é imprescindível – e, com isso, também a teoria de valores que a ela corresponde. Essa tese teórico-estrutural geral significa que, independentemente da teoria material que se defenda, é necessário que se parta uma teoria de valores. Nesse sentido, uma teoria liberal dos direitos fundamentais não é, por exemplo, concorrente da teoria axiológica, mas expressão de uma teoria axiológica com determinado conteúdo. Ela não pode, portanto, concorrer com teorias axiológicas, principiológicas ou teleológicas enquanto tais, mas apenas com teorias que tenham outro conteúdo. O mesmo vale para as teorias democrática e social-estatal. Toda teoria normativa dos direitos fundamentais pressupõe alguma teoria axiológica, principiológica ou teleológica.

plo, Rudolf Smend, “Bürger und Bourgeois im deutschen Staatsrecht”, in *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 2ª ed., Berlin: Duncker & Humblot, 1968, pp. 318 e ss.

141. Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, p. 78.

142. Cf. Eberhard Grabitz, “Freiheit als Verfassungsprinzip”, *Rechtstheorie* 10 (1977), p. 10. Cf. também Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, *VVDStRL* 30 (1972), pp. 99 e 109.

143. Cf. Capítulo 3, III.1.

As coisas não são assim tão simples no caso da *teoria institucional dos direitos fundamentais*, que é a expressão de uma teoria institucional geral do direito, especialmente na forma como desenvolvida por Hauriou e Romano,¹⁴⁴ e que encontra na obra de Häberle sua aplicação mais abrangente no âmbito dos direitos fundamentais.¹⁴⁵ A teoria institucional dos direitos fundamentais é formada por um feixe de teses, de difícil destrinchamento, sobre a finalidade, a estrutura e o conteúdo das normas de direitos fundamentais, bem como de outras teses que as sustentam. Sua tese *normativa* básica é a de que os direitos fundamentais são instituições.¹⁴⁶ O que isso significa é algo que depende do ambíguo conceito de instituição.¹⁴⁷ A partir do rico catálogo, elaborado por Häberle, com as condições que devem ser satisfeitas para que os direitos fundamentais sejam aquilo que devem ser – isto é, instituições –, duas devem ser destacadas. Para serem instituições, os direitos fundamentais têm que (1) ser efetiva e continuamente invocados pelo maior número possível de pessoas e (2) ter o maior grau possível de efeito estabilizador para “o todo da Constituição e da ordem social”.¹⁴⁸ Ambas podem ser consideradas como finalidades, para cuja satisfação devem ser interpretados os direitos fundamentais. Mas essas finalidades têm caráter extremamente formal. A exigência de que se crie e assegure uma situação de estabilidade não traz nenhuma informação sobre o conteúdo dessa situação e o que

144. Cf., a respeito, as edições alemãs, com amplas bibliografias: Maurice Hauriou, *Die Theorie der Institution und zwei andere Aufsätze*, Berlin: Duncker & Humblot, 1965; Santi Romano, *Die Rechtsordnung*, Berlin: Duncker & Humblot, 1975. Cf. também Roman Schnur (Org.), *Institution und Recht*, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. Em geral sobre a teoria da instituição, cf. Helmut Schelsky (Org.), *Zur Theorie der Institution*, Düsseldorf: Bertelsmann, 1970, p. 97.

145. Cf. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, pp. 70 e ss.

146. Idem, p. 122.

147. Sobre a análise desse conceito, cf. Bernd Rüthers, *Institutionelles Rechtsdenken im Wandel der Verfassungsepochen*, Bad Homburg: Gehlen, 1970, pp. 34 e ss. Rüthers distingue entre conceitos fático, metafísico e normativo de instituição.

148. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, p. 123. Em ambos os pontos revela-se claramente a herança de Smend, segundo o qual os direitos fundamentais “perseguem a finalidade constitutiva total do direito constitucional”, a qual deve consistir na “renovação e no desenvolvimento contínuos da vontade comum estatal enquanto unidade viva real” (Rudolf Smend, “Das Recht der freien Meinungsäußerung”, in *Staatsrechtliche Abhandlungen*, pp. 90-91).

deve ser feito para sua criação e asseguuração. O que se sabe é apenas que se deve conferir um peso significativo às finalidades supra-individuais, ou, nos termos de Häberle, à “totalidade supra-individual”,¹⁴⁹ quando da interpretação das disposições de direitos fundamentais, o que é a expressão de uma tese axiológica fundamental a respeito da relação entre bens individuais e coletivos. Também a primeira condição pode ser, sem grandes problemas, interpretada a partir da perspectiva de uma teoria axiológica. O fato de os direitos fundamentais deverem ser efetiva e continuamente invocados pelo maior número possível de pessoas é algo que aponta para elementos social-estatais¹⁵⁰ e democráticos¹⁵¹ da teoria, uma tendência mais tarde seguida por Häberle.¹⁵² A tese de que o conteúdo normativo da teoria institucional dos direitos fundamentais deve ser interpretado a partir de uma teoria axiológica encontra diversas outras confirmações. Em vez de “idéias de direitos fundamentais”¹⁵³ e “imagens guias”,¹⁵⁴ a serem realizadas pelo legislador, é possível falar também em valores ou princípios. Exatamente nesse sentido, Häberle faz com frequência menção a valores e decisões sobre valores.¹⁵⁵ Por fim, é necessário mencionar que o sopesamento, que é a característica identificadora mais certa de uma teoria de valores ou de princípios – assumida ou disfarçada –, desempenha um papel central na “teoria institucional” de Häberle.¹⁵⁶

Diante do exposto, é possível afirmar que o conteúdo normativo da teoria institucional dos direitos fundamentais consiste em uma teoria dos princípios ou dos valores. É característico do conteúdo dessa teoria dos princípios que todos os princípios nela relevantes desempenham um papel, mas que o princípio liberal tem um peso relativamente pequeno e que aos princípios que se refiram a interesses coletivos é atribuído um peso relativamente grande.

149. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, p. 164.

150. Idem, pp. 15 e ss.

151. Idem, pp. 17 e ss.

152. Cf. Peter Häberle, “Grundrechte im Leistungsstaat”, pp. 43 e ss.

153. Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*, pp. 105 e 116.

154. Idem, pp. 182 e 184.

155. Idem, pp. 7, 12 e ss., 184 e 221.

156. Idem, pp. 31 e ss.

Essa breve análise das cinco teorias dos direitos fundamentais confirma a correção da tese segundo a qual as teorias materiais são teorias de princípios. Por isso, o que se deve indagar é sobre qual teoria de princípios é a correta. Três são os tipos de teorias de princípios que estão em jogo: aquelas que, em essência, se baseiam em *um* princípio de direito fundamental; aquelas que partem de um conjunto de princípios de mesma hierarquia; e aquelas que, embora partam de um conjunto de princípios de direitos fundamentais, procuram criar uma certa ordem entre eles.

Uma teoria que se baseia em um princípio de direito fundamental é a proposta de Böckenförde de uma teoria liberal modificada por meio de tarefas constitucionais, ou seja, por meio de um princípio que não é de direito fundamental.¹⁵⁷ Resta saber se é possível fundamentar essa teoria como a teoria correta.¹⁵⁸ Segundo Böckenförde, uma teoria constitucional e, nesse sentido, uma teoria dos direitos fundamentais é “possível apenas como uma teoria constitucional explícita ou implicitamente contida na Constituição, identificável, por meios racionais, no texto constitucional e na história de sua elaboração”.¹⁵⁹ Antes de se indagar se uma teoria liberal pode ser identificada, a partir dessa base, por meios racionais, como uma teoria contida na Constituição, é preciso esclarecer o que está em jogo nessa indagação. Não está em jogo saber se a Constituição se funda, ou não, no princípio da liberdade jurídica¹⁶⁰ e, como tem que ser complementado, no princípio da igualdade jurídica,¹⁶¹ enquanto princípios liberais de direitos fundamentais. O que está em jogo é saber se esses princípios são os *únicos* princípios de direitos fundamentais que encontram expressão na Constituição.

Não pode haver dúvidas de que os princípios da liberdade jurídica e da igualdade jurídica subjazem à Constituição; mas é de se duvidar que seja “identificável, por meios racionais, no texto constitucional e na história de sua elaboração”, que esses sejam os únicos princípios de direitos fundamentais. É exatamente a abertura do texto e de sua gê-

157. Cf. Ernst Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, p. 1.538.

158. Para uma crítica geral a teorias unipolares, cf. Capítulo 1, II.

159. Ernst Wolfgang Böckenförde, “Die Methoden der Verfassungsinterpretation”, p. 2.098.

160. Sobre isso, cf. Capítulo 7, II.1.2.

161. Sobre isso, cf. Capítulo 8, VI.2.

nese que faz com que seja necessária uma teoria material dos direitos fundamentais. Mas, se isso é assim, então, não se pode esperar que apenas do texto e de sua gênese seja possível derivar uma teoria que elimine essa abertura. Ao contrário, para sua fundamentação são necessárias premissas que não são derivadas de forma inequívoca do texto e de sua gênese. Uma pista acerca da natureza dessas premissas é dada pela caracterização que Böckenförde faz das teorias de direitos fundamentais como “expressão de determinadas concepções de Estado e de idéias fundamentais acerca da relação entre os indivíduos e a comunidade estatal”.¹⁶² Isso permite identificar que toda teoria dos direitos fundamentais, na medida em que não é passível de fundamentação inequívoca a partir do material dotado de autoridade preexistente, tem que se basear em uma teoria do Estado e da sociedade, o que dá ensejo a uma objeção de circularidade diante das tentativas de fundamentação baseadas apenas no texto ou em elementos imanentes à Constituição.¹⁶³ o teórico retira do texto a teoria que, segundo sua própria teoria, deve ser extraída do texto. Böckenförde enfrenta essa objeção afirmando que caracteriza sua teoria como uma hipótese de interpretação, “que está submetida a uma estrita confirmação dos enunciados (normativos), dos pressupostos, do contexto de surgimento etc. da Constituição concreta” e sobre a qual tem que ser criado um “consenso argumentativo”.¹⁶⁴ Isoladamente considerada, essa resposta é aceitável; mas, com base no que foi dito acima sobre a abertura do texto e de sua gênese, é de se duvidar se o material de confirmação mencionado por Böckenförde – *se é* que ele já não foi interpretado à luz da teoria que se quer confirmar, o que levaria de novo a uma circularidade – confirmaria apenas uma teoria puramente liberal, ou seja, não rejeitaria unicamente essa teoria.

Àquele que, nessa situação, não deseja adentrar diretamente o terreno movediço de uma filosofia do Estado e da sociedade, resta apenas a busca por mais material dotado de autoridade. Em razão da força vinculante de seus precedentes, um material desse tipo pode ser

162. Ernst Wolfgang Böckenförde, “Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation”, p. 1.537.

163. Cf. Ralf Dreier, “Zur Problematik und Situation der Verfassungsinterpretation”, in Ralf Dreier, *Recht – Moral – Ideologie*, p. 126.

164. Ernst Wolfgang Böckenförde, “Die Methoden der Verfassungsinterpretation”, p. 2.098.

encontrado nas decisões do Tribunal Constitucional Federal. Mas, seguindo-se a idéia de Böckenförde, a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal seria improdutiva para o estabelecimento de uma teoria material dos direitos fundamentais. Böckenförde fundamenta essa tese por meio da constatação de que o tribunal se apóia, "de forma cambiante, em diversas teorias de direitos fundamentais".¹⁶⁵ Se se parte da divisão proposta por Böckenförde, é certo que o tribunal, de fato, prefere às vezes uma, às vezes outra teoria. Mas daí não se pode concluir que a jurisprudência do tribunal não se funda em nenhuma teoria dos direitos fundamentais. O conceito de teoria dos direitos fundamentais não se restringe àquelas teorias que expressam apenas um princípio; como já se mencionou anteriormente, existe também a possibilidade de que uma teoria dos direitos fundamentais esteja baseada em um conjunto de princípios. Aquele que se orientar pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal obterá uma teoria combinada, que contém mais princípios de direitos fundamentais que apenas o princípio liberal (liberdade jurídica/igualdade jurídica).¹⁶⁶

Contra esse tipo de teorias combinadas pode ser suscitada a crítica da inutilidade. Nesse sentido, Böckenförde sustenta que elas não seriam mais que catálogos de *topoi*, que poderiam ser utilizados sem nenhum critério.¹⁶⁷ Contra essa objeção pode-se recorrer a três argumentos: (1) em virtude de sua estrutura lógica, princípios são mais que meros *topoi*; (2) é possível estabelecer uma certa ordem de princípios por meio de relações de precedência *prima facie*; uma teoria combinada pode ser, portanto, uma teoria de princípios do terceiro tipo mencionado acima; (3) não se pode esperar muito de uma teoria material dos direitos fundamentais.

(1) A lei do sopesamento¹⁶⁸ demonstra que princípios são mais que meros *topoi*. Não é possível, de forma não-criteriosa, recorrer ou deixar de recorrer aos princípios. Se eles são relevantes, eles devem

165. Idem, p. 1.536.

166. Sobre isso, cf. Capítulo 9, I.2. Sobre a tese de que às disposições de direitos fundamentais específicas devem ser atribuídos conjuntos de finalidades, cf. Martin Kriele, *Einführung in die Staatslehre*, Reinbek: Rowohlt, 1975, pp. 335 e ss.

167. Ernst Wolfgang Böckenförde, "Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation", p. 1.537.

168. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.3.

ser levados em consideração. No caso de uma colisão, é necessário um sopesamento, no qual se deve indagar se a importância da satisfação de um princípio justifica o necessário grau de não-satisfação de um outro. Embora isso não determine o resultado, a fundamentação é impulsionada na direção de uma estrutura racional.

(2) Já se demonstrou acima que uma ordem de princípios ou uma ordem de valores que conduza, de forma intersubjetivamente controlável, a um único resultado – essa ordem poderia ser denominada de “ordem rígida” – não é possível.¹⁶⁹ O que é possível é uma ordem flexível por meio de precedências *prima facie*. O núcleo correto da teoria material dos direitos fundamentais proposta por Böckenförde, como já foi mencionado,¹⁷⁰ consiste na possibilidade de se demonstrar uma precedência *prima facie* dos princípios da liberdade jurídica e da igualdade jurídica, ou seja, uma carga de argumentação a favor desses princípios. A precedência *prima facie* do princípio da liberdade jurídica coincide em grande medida com a “presunção básica de liberdade” do Tribunal Constitucional Federal¹⁷¹ e com a máxima *in dubio pro libertate*.¹⁷² Contra essas máximas já foram feitas inúmeras críticas, que podem ser, no entanto, refutadas. Isso pode ser demonstrado por meio de uma breve olhada em seis críticas principais. Uma primeira objeção alega que essas máximas seriam inadmissivelmente generalizantes,¹⁷³ o que excluiria as necessárias diferenciações.¹⁷⁴ Mas isso não atinge a precedência *prima facie* do princípio da liberdade jurídica. Esse princípio permite qualquer diferenciação, desde que o ônus argumentativo seja satisfeito. Uma segunda objeção sustenta que as máximas são excessivamente rudimentares, porque se baseiam “na liberdade” e, portanto, não levam em consideração o fato de que liber-

169. Cf. Capítulo 3, III.2.2.1.

170. Cf. Capítulo 8, VI.3, e Capítulo 9, IV.3.

171. BVerfGE 6, 32 (42); 13, 97 (105); 17, 306 (313-314); 32, 54 (72).

172. Cf. sobretudo Peter Schneider, “*In dubio pro libertate*”, in Ernst von Caemmerer (Org.), *Hundert Jahre deutsches Rechtsleben: Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages*, v. 2, Karlsruhe: C. F. Müller, 1960, pp. 279 e ss.; do mesmo autor, “*Prinzipien der Verfassungsinterpretation*”, VVDStRL 20 (1963), pp. 31 e ss. Cf. também Eike v. Hippel, *Grenzen und Wesensgehalt der Grundrechte*, p. 18.

173. Cf. Peter Lerche, “*Stil, Methode, Ansicht*”, DVBl 76 (1961), p. 698.

174. Cf. Rupert Scholz, *Wirtschaftsaufsicht und subjektiver Konkurrenzschutz*, Berlin: Duncker & Humblot, 1971, p. 130.

dades de diversos titulares de direitos fundamentais podem colidir, o que poderia levar a uma injustificada preferência da liberdade de um em detrimento da liberdade de outros.¹⁷⁵ Sobre esse ponto, é necessário afirmar que a precedência *prima facie* existe apenas em face de outros princípios que não os da liberdade jurídica e da igualdade jurídica. Se há uma colisão entre liberdade jurídica e liberdade jurídica, ou entre liberdade jurídica e igualdade jurídica, de titulares distintos, então, a precedência *prima facie* deixa de valer. Uma terceira crítica tem como conteúdo a constatação de que, na dúvida, não se aplicam “nem a regulamentação mais liberal nem a menos liberal, mas apenas a regulamentação correta”.¹⁷⁶ Essa crítica ignora o fato de que a precedência *prima facie* é exatamente um meio de encontrar a resposta correta nos termos da Constituição. Se, no caso de um colisão, são apresentadas razões igualmente boas a favor de uma e de outra solução, não é possível fundamentar, sem uma regra de precedência, qual é a solução correta. *Nesses* casos, a precedência *prima facie* sustenta que a solução que corresponde ao princípio da liberdade jurídica é a solução correta de acordo com a Constituição. Uma quarta objeção alega que a precedência *prima facie* não é compatível com a tarefa da otimização, imposta pela idéia de unidade da constituição.¹⁷⁷ Contudo, as precedências *prima facie* não excluem, de forma alguma, a possibilidade de sopesamentos, necessários em virtude da própria estrutura dos princípios.¹⁷⁸ Elas contêm apenas uma regra de solução para o caso de um impasse argumentativo, que pode surgir no processo de otimização. Uma quinta objeção diz que a precedência *prima facie* levaria a uma interpretação extensiva dos direitos de liberdade (direitos do status negativo)¹⁷⁹ e seria a expressão de um individualismo anarquista e de um liberalismo econômico exagerado.¹⁸⁰ Isso superes-

175. Christian Graf v. Pestalozza, “Kritische Bemerkungen zu Methoden und Prinzipien der Grundrechtsauslegung in der Bundesrepublik Deutschland”, p. 446.

176. Adolf Keller, *Die Kritik, Korrektur und Interpretation des Gesetzeswortlauts*, Winterthur: Keller, 1960, p. 279; Horst Ehmke, “Prinzipien der Verfassungsinterpretation”, p. 87.

177. Konrad Hesse, *Grundzüge des Verfassungsrechts*, § 72; Walter Krebs, *Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte*, p. 52.

178. Cf. Capítulo 3, I.2.

179. Horst Ehmke, “Prinzipien der Verfassungsinterpretation”, p. 87.

180. Adolf Keller, *Die Kritik, Korrektur und Interpretation des Gesetzeswortlauts*, p. 279.

tima a importância substancial da precedência *prima facie*. Ela não exclui uma preterição do princípio da liberdade jurídica em favor de princípios colidentes. Ela apenas exige que, nesse caso, haja razões mais fortes a favor da solução exigida pelos princípios colidentes que a favor daquela exigida pelo princípio da liberdade jurídica. Isso conduz à única objeção importante, a sexta objeção. A precedência *prima facie* tem natureza formal. Embora ela insira na teoria dos princípios uma tendência em favor da liberdade jurídica e da igualdade jurídica, ela não fornece nenhum critério¹⁸¹ que diga até que ponto essa tendência deve prevalecer. Isso depende de critérios substanciais, cuja utilização é estruturada, mas não determinada, pela precedência *prima facie*. Isso restringe o valor prático da precedência *prima facie*, mas não a torna inútil. O fato de não se obter uma determinação substancial não é um motivo para renunciar a uma estruturação.

(3) Isso conduz ao terceiro ponto: não se pode esperar muito de uma teoria material dos direitos fundamentais. A forma mais ambiciosa de uma teoria material dos direitos fundamentais seria uma teoria que contivesse uma única resposta correta para todo e qualquer caso. Nos últimos tempos foi sobretudo Dworkin quem se esforçou na direção de uma tal teoria. Ele sustenta ser possível uma “teoria do direito perfeita”, que conteria aqueles princípios – e seus pesos relativos¹⁸² – que justificariam da melhor forma os precedentes e as normas positivas¹⁸³ sobre cuja base haveria uma única resposta para cada caso.¹⁸⁴ Para se perceber que um tal programa de uma teoria material dos direitos fundamentais está condenado ao fracasso é necessário indagar como uma teoria dos princípios teria que ser construída para que fornecesse uma única resposta correta para cada caso concreto. Uma primeira possibilidade, a ordenação cardinal ou ordinal dos princípios, já foi rejeitada anteriormente.¹⁸⁵ Como acabou de se afirmar, as prece-

181. Cf. Christian Graf v. Pestalozza, “Kritische Bemerkungen”, p. 446.

182. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, p. 66.

183. Idem, pp. 116-117.

184. Idem, p. 81; do mesmo autor, “No Right Answer?”, in Peter M. S. Hacker/Joseph Raz (eds.), *Law, Morality, and Society: Essays in Honour of H. L. A. Hart*, Oxford: Clarendon Press, 1977, pp. 76 e ss. Sobre esse ponto, cf., com referências bibliográficas adicionais, Robert Alexy, “Zum Begriff des Rechtsprinzips”, *Rechtstheorie*, fascículo 1 (1979), pp. 61-62 e 82 e ss.; Aleksander Peczenik, “Is there always a right answer to a legal question?”, *Oikeustiede Jurisprudentia* 16 (1983), pp. 241 e ss.

185. Cf. Capítulo 3, III.2.2.1.

dências *prima facie* conduzem apenas a uma estruturação da argumentação baseada em princípios, mas não a uma ordem rígida, que determine apenas um resultado em cada caso. Sobra apenas a possibilidade de uma ordem a partir de relações concretas de precedência, que expressem os pesos relativos dos princípios em determinados casos ou grupos de casos. Um exemplo de uma tal relação concreta de precedência é aquela do caso Lebach, segundo a qual, sob a condição de que se trate de uma repetição do noticiário televisivo sobre um grave crime, não mais revestido de um interesse atual pela informação, e de que a ressocialização do autor seja colocada em risco, o princípio da proteção da personalidade tem precedência em face do princípio da liberdade de informar por meio de radiodifusão.¹⁸⁶ Como se demonstrou acima, essa relação de precedência, nos termos da lei de colisão, implica uma *regra* que, quando presentes as condições mencionadas, proíbe a transmissão do programa televisivo. Mas isso torna claro o dilema diante do qual se encontra qualquer tentativa de estabelecer a rigidez de uma teoria dos princípios por meio de relações concretas de precedência. Se se pretende atingir o máximo de rigidez, ou seja, a determinação da decisão de todo e qualquer caso, a teoria tem que conter uma relação concreta de precedência para todo caso imaginável no âmbito dos direitos fundamentais, e isso significa conter uma regra de decisão para cada um desses casos. Mas isso significa que a teoria se transformaria em uma lista abrangente de regras de decisão para todos os casos imagináveis no âmbito dos direitos fundamentais. Os próprios limites da capacidade imaginativa humana já excluem a possibilidade de elaboração de uma lista completa dessa espécie. A isso soma-se o fato de que as regras de decisão contidas nessa lista dificilmente poderiam contar com a aprovação geral, pois isso pressuporia a existência, para cada caso de direito fundamental, de uma única resposta que contasse com a aprovação de todos. Mas o mais importante é que as respostas contidas na lista necessitam de uma fundamentação. A questão acerca dessa fundamentação leva de volta ao problema de uma teoria material dos direitos fundamentais, para cuja solução a lista deveria ser um meio.

Em vista do exposto, é possível afirmar que uma teoria material dos direitos fundamentais que estabeleça a solução para todos os ca-

186. BVerfGE 35, 202 (237).

sos no âmbito dos direitos fundamentais não é algo viável. Isso fornece razões para que não se espere muito, de antemão, de uma teoria material dos direitos fundamentais. Não se pode exigir dela mais que a estruturação, no maior grau de racionalidade possível, da argumentação de forma substancialmente aceitável. Esses requisitos são satisfeitos por uma teoria dos princípios que contenha um conjunto de princípios de direitos fundamentais e que os organize em uma ordem flexível a partir de precedências *prima facie* a favor dos princípios da liberdade jurídica e da igualdade jurídica.

3.3 O processo da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais

As reflexões sobre a base da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais estavam voltadas à questão da controlabilidade racional dessa argumentação. O resultado é a constatação de que, a partir dessa base, a determinação e a estruturação da argumentação nesse âmbito ganham em racionalidade, mas também que a extensão e a força do controle que daí decorrem são limitadas. Uma considerável lacuna de racionalidade permanece. Essa lacuna é preenchida pelo processo da argumentação no âmbito dos direitos fundamentais: o discurso de direitos fundamentais.

O discurso de direitos fundamentais é um procedimento argumentativo que se ocupa com o atingimento resultados constitucionalmente corretos a partir da base aqui apresentada.¹⁸⁷ Como a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais é determinada apenas de forma incompleta por sua base, a argumentação prática geral torna-se um elemento necessário do discurso nesse âmbito. Isso significa que o discurso no âmbito dos direitos fundamentais, como o discurso jurídico em geral, compartilha da insegurança quanto aos resultados, característica do discurso prático geral. Por isso, a abertura do sistema jurídico, provocada pelos direitos fundamentais, é inevitável. Mas ela é uma abertura qualificada. Ela diz respeito não a uma abertura no sen-

187. Com relação ao fato de o discurso no âmbito dos direitos fundamentais não ser apenas uma questão de jurisdição constitucional e de ciência do direito constitucional, cf. Peter Häberle, "Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten", JZ 30 (1975), pp. 279 e ss.

tido de arbitrariedade ou de mero decisionismo. A base aqui apresentada fornece à argumentação no âmbito dos direitos fundamentais uma certa estabilidade e, por meio das regras e formas da argumentação prática geral e da argumentação jurídica, a argumentação no âmbito dos direitos fundamentais que ocorre sobre essa base é racionalmente estruturada.¹⁸⁸

A insegurança quanto aos resultados do discurso no âmbito dos direitos fundamentais leva à necessidade de decisões dotadas de autoridade. Se a maioria parlamentar não deve controlar a si mesma, o que significaria ser juiz em causa própria,¹⁸⁹ sobra apenas a alternativa de alguma forma de jurisdição constitucional. O fato de um tribunal constitucional não apenas argumentar, mas também decidir, nada tem de irracional. De forma geral, vale a idéia de que a razão prática pode ser realizada apenas no âmbito de um sistema jurídico que vincule, de forma racional, argumentação e decisão.¹⁹⁰ À luz dessa reflexão, a institucionalização de uma jurisdição constitucional cujas decisões sejam passíveis e carentes de fundamentação e crítica em um discurso racional no âmbito dos direitos fundamentais é algo inteiramente racional.

188. Cf. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, pp. 345 e ss.

189. Cf. Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, pp. 142-143.

190. Cf. Martin Kriele, *Recht und praktische Vernunft*, pp. 40 e ss.

POSFÁCIO (2002)

A tese central deste livro é a de que os direitos fundamentais, independentemente de sua formulação mais ou menos precisa, têm a natureza de princípios e são mandamentos de otimização. Desde o seu surgimento, em 1985, a tese da otimização foi alvo de inúmeras críticas. Algumas delas dizem respeito a problemas gerais da teoria das normas.¹ A maioria, no entanto, gira em torno da questão sobre se a tese da otimização conduz a um modelo adequado dos direitos fundamentais. Essas críticas transitam entre dois pólos ou linhas.

I – INSUFICIÊNCIA E DEMASIA

A primeira linha crítica alega que o modelo de princípios baseado na tese da otimização retira força dos direitos fundamentais. Essa objeção foi formulada com toda agudeza por Habermas: “Se princípios estabelecem valores que devem ser realizados de forma ótima, e se a medida da satisfação desse mandamento de otimização não pode ser obtida a partir da própria norma, então, a aplicação desses princípios no âmbito do faticamente possível exige uma quantificação orientada por finalidades”.²

Essa “quantificação orientada por finalidades” implicaria a possibilidade de que “direitos individuais sejam, em alguns casos, sacrifi-

1. Cf., a esse respeito Robert Alexy, “Zur Struktur der Rechtsprinzipien”, in Bernd Schilcher/Peter Koller/Bernd-Christian Funk (orgs.), *Regeln, Prinzipien und Elemente im System des Rechts*, Wien: Verlag Österreich, 2000, pp. 31 e ss.

2. Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, 4ª ed., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994, p. 310.

cados em favor de finalidades coletivas”.³ Com isso, no entanto, os direitos fundamentais perderiam a sua solidez, que só pode ser garantida por meio de uma estrutura estritamente deontológica, ou seja, pela estrutura de regras. O caráter principiológico derrubaria um “muro protetor”: “Se, nos casos de colisão, *todas* as razões puderem adotar o caráter de argumentos definidores de finalidades, derruba-se então aquele muro protetor que uma compreensão deontológica das normas jurídicas introduz no discurso jurídico”.⁴

E o sopesamento de direitos fundamentais não ameaçaria apenas a sua força em geral. Ele implicaria também o risco de que os direitos fundamentais fossem vítimas de “juízos irracionais”,⁵ pois não haveria nenhum parâmetro racional para esse sopesamento: “como faltam parâmetros racionais para tanto, o sopesamento é realizado ou de forma arbitrária ou irrefletida, baseado em standards e hierarquias sedimentados”.⁶ Em resumo: em primeiro lugar, os direitos fundamentais são flexibilizados, ao serem transformados em mandamentos de otimização; depois, ficam ameaçados de desaparecer no turbilhão do sopesamento irracional.

É possível chamar a crítica de Habermas de alerta para o perigo de uma insuficiência de direitos fundamentais. O seu oposto, o perigo de um excesso desses direitos, é o cerne da crítica de Böckenförde. O ponto de partida de Böckenförde é a distinção entre direitos fundamentais como direitos clássicos de defesa do cidadão contra o Estado e direitos fundamentais como normas de princípios. Direitos fundamentais como normas de princípios – ou, como Böckenförde as denomina, apoiando-se na terminologia do Tribunal Constitucional Federal, como “normas objetivas de princípios” – correspondem “exatamente àquilo” que na teoria dos princípios é denominado “mandamento de otimização”: “Normas-princípios são mandamentos de otimização, que podem ser satisfeitos em graus diversos, e cuja medida devida de satisfação não depende apenas das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. Elas têm uma tendência normativa à oti-

3. Jürgen Habermas, “Replik auf Beiträge zu einem Symposium der Cardozo Law School”, in Jürgen Habermas, *Die Einbeziehung des Anderen*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996, p. 368.

4. Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, p. 315.

5. Idem, p. 316.

6. Idem, pp. 315-316.

mização, sem se fixar, no entanto, em um conteúdo determinado; elas são – necessariamente – passíveis de serem sopesadas”.⁷

Böckenförde admite que esse caráter principiológico é “adequado para reproduzir o conceito dogmático básico dos direitos fundamentais, porque é capaz de abarcar todas as funções desses direitos de forma abrangente e, de maneira conversã, permite que todas essas funções se desenvolvam de forma variável a partir dele”.⁸

Mas isso teria amplas conseqüências que, no fim, seriam inaceitáveis. O papel dos direitos fundamentais no sistema jurídico seria alterado profundamente. Enquanto os direitos fundamentais clássicos estavam limitados a uma parte do sistema jurídico – a relação entre Estado e cidadão –, os direitos fundamentais enquanto princípios produziriam seus efeitos por todo o sistema jurídico. Haveria um efeito irradiador em todos os ramos do direito, o que necessariamente conduziria a uma produção de efeitos dos direitos fundamentais em face de terceiros (ou efeitos horizontais), bem como a conteúdos de direitos fundamentais como proteção, segurança social e organização e procedimento, os quais demandariam uma ação positiva do Estado e não se limitariam – como os direitos clássicos de liberdade – a uma exigência de abstenção estatal.⁹ Dessa forma, os direitos fundamentais transformar-se-iam em “princípios supremos da ordem jurídica como um todo”.¹⁰ Enquanto tais, eles já conteriam tudo em si mesmos. Necessária seria apenas uma concretização por meio de um sopesamento: “No nível das normas-princípios com tendência otimizadora, a ordem jurídica já está inteiramente contida na constituição. Ela apenas carece de uma concretização”.¹¹

Isso corresponderia exatamente àquilo que Forsthoff sarcasticamente chamou de “constituição como genoma jurídico (...) do qual tudo deriva, do Código Penal até a lei sobre a fabricação de termôme-

7. Ernst-Wolfgang Böckenförde, “Grundrechte als Grundsatznormen: Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik”, in Ernst-Wolfgang Böckenförde, *Staat, Verfassung, Demokratie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, p. 185.

8. Idem.

9. Idem, pp. 168 e ss.

10. Idem, p. 188.

11. Idem, p. 189.

tros para febre".¹² A compreensão dos direitos fundamentais como mandamentos de otimização conduziria, assim, a um modelo de constituição com conseqüências fatais. O legislador parlamentar perderia toda a sua autonomia. Sua atividade esgotar-se-ia na mera constatação daquilo que já foi decidido pela constituição. O processo político democrático perderia consideravelmente em importância,¹³ e não seria mais possível deter a "transição do Estado legislativo parlamentar para um Estado judiciário constitucional":¹⁴ "Se os direitos fundamentais expressam normas de princípios com tendência otimizadora, o tribunal constitucional é invocado para dotar de validade o seu conteúdo normativo".¹⁵

Por isso, segundo Böckenförde, há apenas duas possibilidades: decidir-se por direitos fundamentais como princípios e, com isso, por um Estado judiciário, ou decidir-se pela limitação dos direitos fundamentais à sua clássica função como direitos de defesa e, com isso, por um Estado legislativo parlamentar.¹⁶ Neste ponto, é necessário indagar se de fato existem apenas essas duas possibilidades.

II – MOLDURA E FUNDAMENTO

A alternativa entre Estado judiciário e Estado legislativo é um confronto entre duas espécies de repartição de competências. Böckenförde associa essa dicotomia – situada no nível das competências – a uma alternativa que se refere à estrutura e ao conteúdo das normas constitucionais e, nesse sentido, da constituição como um complexo normativo. Trata-se da contraposição entre ordem-moldura e ordem-fundamento. A alternativa entre moldura e fundamento tem um papel central na polêmica em torno da teoria dos princípios. Isso já é perceptível pelo fato de o conceito de moldura se ter transformado em uma bandeira comum para os adversários da idéia de otimização, adversários, esses, que, individualmente considerados, têm posições bas-

12. Ernst Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft*, 2ª ed., München: Beck, 1971, p. 144.

13. Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Grundrechte als Grundsatznormen", p. 197.

14. Idem, p. 190.

15. Idem, p. 196.

16. Idem, pp. 198 e ss.

tante distintas entre si. Nesse ponto, à teoria dos princípios é atribuído o conceito oposto, isto é, o conceito de ordem-fundamento. Segundo Böckenförde, uma constituição é uma “ordem jurídica fundamental de toda a comunidade” quando “todos os princípios jurídicos e possibilidades de harmonização para a conformação do ordenamento jurídico já estão *in nuce* contidos na própria constituição”.¹⁷ Isso equivale ao genoma jurídico de Forsthoff e espelha, de forma rudimentar, mas precisa, o inimigo comum de todos os defensores da constituição como moldura.

A partir dessa base, a teoria dos princípios é uma vítima fácil. Se ela necessariamente conduz a uma constituição na qual a totalidade da ordem jurídica já está contida, então, a teoria dos princípios condena o legislador – sob o controle do Judiciário – a apenas declarar aquilo que já foi decidido pela constituição. A “liberdade de conformação política do legislador” seria, assim, eliminada totalmente, por meio de uma “pressão otimizadora jurídico-constitucional”,¹⁸ o que seria incompatível com os princípios do parlamentarismo democrático e da separação de poderes. Esses princípios exigem que o Legislativo, legitimado democraticamente, tenha uma participação significativa – quantitativa e qualitativamente – na configuração da ordem jurídica.

Diante disso, o que se deve indagar é se a teoria dos princípios leva, de fato e necessariamente, a uma ordem-fundamento no sentido dado por Böckenförde, uma ordem que exclui toda e qualquer liberdade do legislador. A resposta a essa questão depende dos conceitos de moldura e de fundamento. No tópico seguinte será analisado o conceito de moldura.

1. O conceito de ordem-moldura

O conceito de moldura tem que ser distinguido dos critérios para a determinação de seu conteúdo. Para a determinação do conteúdo de ordem-moldura são propostos diversos critérios. Três exemplos serão examinados. O primeiro é o de Böckenförde. Para Böckenförde, a moldura surge por meio do abandono das novas dimensões dos direitos

17. Idem, p. 198.

18. Christian Starck, “Rezension: Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts”, *Der Staat* 32 (1993), pp. 475-476.

fundamentais, como os efeitos horizontais ou perante terceiros e os deveres de proteção, e com a volta a uma compreensão dos direitos fundamentais como os direitos clássicos de defesa contra o poder estatal.¹⁹ Isso pode ser chamado de redução liberal da constituição. Entre aqueles que não concordam com uma decisão substancial nesse sentido está Hain. Ele preserva todas as dimensões dos direitos fundamentais, para depois reduzi-las a um patamar mínimo.²⁰ Isso pode ser chamado de redução material geral da constituição. Mais radical é o modelo de redução metodológica da constituição, proposto por Jestaedt. De acordo com essa terceira variante, deve fazer parte da constituição apenas aquilo que se pode empiricamente estabelecer como a vontade histórica do legislador constituinte.²¹

Esses critérios para a determinação do conteúdo de uma constituição como moldura devem ser distinguidos do conceito de ordem-moldura em si mesmo, que permanece inalterado para todas as variantes baseadas na idéia de moldura e que, nesse sentido, é um conceito formal. Para facilitar as coisas, aqui será analisada apenas a relação entre Constituição e Legislativo, para a qual é possível diferenciar três constelações.

Na primeira constelação, a Constituição não contém nenhum dever ou proibição substancial que restrinja a competência do legislador. Desde que ele respeite as previsões constitucionais sobre competência, procedimento e forma, ao legislador é tudo permitido e ele está autorizado a tudo fazer. Esse é um modelo de constituição puramente procedimental.²² Por definição, nesse modelo não há nenhuma moldura substancial. As competências do legislador são substancialmente ilimitadas. Se chamarmos de "discricionariedade" a classe das decisões que são possíveis a um legislador, então, a afirmação de que não há nenhuma moldura substancial é equivalente à afirmação de que a discricionariedade do legislador é substancialmente ilimitada.

19. Cf. Ernst-Wolfgang Böckenförde, "Grundrechte als Grundsatznormen", pp. 194-195.

20. Cf. Karl-E. Hain, *Die Grundsätze des Grundgesetzes*, Baden-Baden: Nomos, 1999, pp. 32 e 188 e ss.

21. Cf. M. Jestaedt, *Grundrechtsentfaltung im Gesetz*, Tübingen: Mohr, 1999, pp. 337 e 361-362.

22. Cf. Capítulo 10, I.

O modelo puramente procedimental é incompatível com a vinculação jurídica do legislador aos direitos fundamentais, pois esse modelo é definido pela negação de toda e qualquer vinculação jurídica substancial. A partir do ponto de vista de um cético radical em relação ao sopesamento, a compreensão dos direitos fundamentais como princípios tem como consequência a negação de toda e qualquer vinculação jurídica substancial. O ceticismo radical em relação ao sopesamento é caracterizado pela aceitação de qualquer resultado de sopesamento como algo possível. Se os direitos fundamentais, como objeto de sopesamentos, não excluem nenhum resultado, então, eles não são aptos a vincular nada. Eles não têm condições de estabelecer limites ao legislador, e, por conseguinte, não podem constituir uma moldura. Do ponto de vista do ceticismo radical em relação ao sopesamento, a única coisa de que os direitos fundamentais são capazes é criar uma falsa impressão de que existe uma moldura. Um tribunal constitucional pode se utilizar disso para mascarar o caráter decisionista de seus julgamentos. Por essa perspectiva, o legislador não está vinculado à constituição, mas está à mercê do tribunal constitucional. Mas para essa situação de submissão não haveria razões legítimas.

Um ceticismo radical em relação ao sopesamento é raramente defendido de forma explícita e em toda sua extensão. Mas com frequência é possível percebê-lo nas entrelinhas. Esse é o caso da crítica de Habermas acerca da ausência de parâmetros racionais para o sopesamento, simbolizada pela imagem da queda do muro protetor dos direitos fundamentais.²³ Com isso, surge a primeira indagação em relação à teoria dos princípios feita pela perspectiva da ordem-moldura: a teoria dos princípios é capaz de estabelecer, de forma racional, uma moldura ao legislador?

O contraponto de um modelo puramente procedimental é um modelo puramente material. Nele, a constituição contém deveres ou uma proibição para toda e qualquer decisão legislativa imaginável. Essa é a constituição como um genoma, no sentido descrito por Forsthoff. Sob essa constituição não há nenhuma regulação legislativa que seja de decisão livre do legislador. Diante disso, toda e qualquer discricionariedade é eliminada. Não pode haver dúvidas de que uma tal inexistência de discricionariedade contradiria o princípio da competência

23. Cf. Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, pp. 315-316.

decisória do legislador democraticamente legitimado. Se a objeção de Böckenförde, segundo a qual a teoria dos princípios levaria a uma eliminação de toda competência decisória autônoma do legislador, fosse correta, então, a teoria dos princípios seria atingida no coração.

Quando do exame do modelo puramente formal foi formulada a questão acerca da capacidade da teoria dos princípios para proibir algo ao legislador, ou seja, para lhe impor uma moldura, no sentido de um limite. A essa pergunta soma-se uma segunda: se ela é capaz de fazê-lo sem lhe retirar toda e qualquer discricionariedade. Isso ocorreria se a teoria dos princípios fosse capaz de obrigá-lo a algumas coisas, proibir-lhe outras e, em relação ao resto, não estabelecer nem uma obrigação, nem uma proibição. Se algo não é nem obrigatório, nem proibido, então, é permitido fazê-lo ou se abster de fazê-lo. Se é permitido fazer algo ou se abster de fazê-lo, então, essa ação é facultada.²⁴ Assim, a discricionariedade do legislador é formada exatamente pelas alternativas que a ele são facultadas. Por isso, é possível denominar essa discricionariedade também como "âmbito facultado".

Na primeira constelação, ao legislador era tudo facultado, e isso corresponde ao modelo puramente procedimental de constituição. Na segunda constelação, nada era a ele facultado, e isso é a expressão de um modelo puramente material de constituição. A terceira constelação consiste na existência de coisas facultadas e coisas não-facultadas, ou seja, obrigatórias ou proibidas. Isso corresponde ao modelo material-procedimental.²⁵

A metáfora da moldura pode ser, então, definida da seguinte forma: o que é obrigatório ou proibido é a moldura; o que é facultado – ou seja, nem obrigatório, nem proibido – é aquilo que se encontra no interior da moldura. Nesse sentido, a discricionariedade do legislador é definida por aquilo que é facultado. Essa discricionariedade é de natureza estrutural.²⁶ Seria também possível falar em uma discricionariedade substancial decorrente da estrutura das normas constitucionais. O que é decisivo é que a sua extensão é determinada por aquilo que é juridicamente válido em virtude das normas constitucionais.

24. Cf. Capítulo 4, II.1.2.1.

25. Cf. Capítulo 10, I.

26. Cf. Capítulo 9, II.3.

Portanto, a discricionariedade estrutural decorre dos limites daquilo que a constituição definitivamente obriga ou proíbe.

Essa última definição distingue a discricionariedade estrutural da discricionariedade epistêmica ou cognitiva. Uma discricionariedade epistêmica decorre não dos limites daquilo que a constituição obriga ou proíbe, mas dos limites da possibilidade de se reconhecer o que a constituição, de um lado, obriga e proíbe e, de outro, nem obriga nem proíbe, ou seja, o que ela faculta. De uma forma exagerada, é possível afirmar que a discricionariedade epistêmica decorre dos limites da capacidade de se conhecer os limites da constituição. Os limites dessa capacidade podem ser tanto limites da cognição empírica quanto limites da cognição normativa. Saber se a constituição admite tais espécies de discricionariedade epistêmica é algo que depende do papel dos princípios formais, e isso será examinado no momento adequado. Aqui, interessa apenas a distinção entre as discricionariedades estrutural e epistêmica.

O modelo da moldura foi até agora descrito com o auxílio dos conceitos de dever, de proibição e de faculdade. Mas é possível fazê-lo também com o auxílio dos conceitos de necessidade, impossibilidade e possibilidade. Aquilo que a constituição obriga é constitucionalmente necessário; o que ela proíbe, constitucionalmente impossível; e o que ela faculta não é constitucionalmente nem necessário, nem impossível, mas meramente possível. Assim, o problema da moldura pode ser formulado como problema da existência de uma esfera composta por aquilo que é apenas constitucionalmente possível. Os adversários da teoria dos princípios sustentam que a existência de uma tal esfera é incompatível com a idéia de otimização.

2. O conceito de ordem-fundamento

Antes de abordar o problema da compatibilidade entre a idéia de moldura e a de otimização, é necessário esclarecer o segundo conceito do arsenal dos adversários da teoria dos princípios: o conceito de ordem-fundamento. Esse conceito pode ser compreendido de forma quantitativa ou de forma qualitativa. Em um sentido quantitativo, uma constituição é uma ordem-fundamento se ela nada faculta, ou seja, se para tudo ela tem ou um dever, ou uma proibição. Esse é o genoma

descrito por Forsthooff, que teria uma decisão até mesmo para os termômetros para febre. Esse conceito quantitativo de ordem-fundamento é um verdadeiro conceito contraposto ao conceito de ordem-moldura.²⁷ É impossível que uma constituição seja, ao mesmo tempo, uma ordem-fundamento em sentido quantitativo e uma ordem-moldura. Mas o caso do conceito de ordem-fundamento em sentido qualitativo é bem diferente. Uma constituição é uma ordem-fundamento em sentido qualitativo ou substancial se por meio dela são decididas questões que sejam fundamentais para a comunidade. Esse conceito de ordem-fundamento é compatível com o conceito de ordem-moldura. Uma constituição pode decidir questões fundamentais, e, nesse sentido, ser uma ordem-fundamento, e, mesmo assim, deixar muitas questões em aberto, e, nesse sentido, ser uma ordem-moldura. De acordo com a teoria dos princípios, uma boa constituição deve conciliar as duas coisas. Ela tem que ser tanto uma ordem-fundamento quanto uma ordem-moldura. Isso é possível se ela, em primeiro lugar, obriga e proíbe algumas coisas, ou seja, se ela estabelece uma moldura; em segundo, faculta outras coisas, ou seja, aceita discricionariedades; e, em terceiro, se por meio de seus deveres e proibições forem decididas aquelas questões fundamentais para a comunidade, que podem e devem ser decididas por uma constituição. A questão é saber se esse postulado pode ser satisfeito quando se pressupõe que os direitos fundamentais têm a estrutura de princípios.

III – DISCRICIONARIEDADE ESTRUTURAL E SOPESAMENTO

Aquilo que as normas de uma constituição nem obrigam nem proíbem é abarcado pela discricionariedade estrutural do legislador. A discricionariedade estrutural é muito menos problemática que a epistêmica. Não é necessário fundamentar que o legislador é livre se a constituição não o obriga a nada. Já não tão óbvio é fundamentar que ele é livre porque há dificuldades em se identificar se ele é livre. Isso já é suficiente para justificar a análise da discricionariedade estrutural antes da discricionariedade epistêmica.

27. Ao lado desse, há um segundo conceito verdadeiramente contraposto ao conceito de ordem-moldura. É o conceito de uma constituição que nada decide do ponto de vista substancial, ou seja, que corresponda ao modelo puramente procedimental.

Há três tipos de discricionariedade estrutural: a discricionariedade para definir objetivos, a discricionariedade para escolher meios e a discricionariedade para sopesar.

1. Discricionariedade para definir objetivos

Diante de um direito fundamental, o legislador tem uma discricionariedade para definir objetivos se esse direito contiver uma autorização de intervenção que ou deixe em aberto as razões para a intervenção ou, embora mencione essas razões, apenas permita, mas não obrigue, a intervenção se essas razões estiverem presentes. No primeiro caso o legislador pode decidir ele próprio se ele quer intervir no direito fundamental e em razão de que finalidades, objetivos ou princípios.²⁸ No segundo caso ao legislador cabe pelo menos a decisão sobre encampar os fins, objetivos e princípios elencados no dispositivo constitucional e sobre a própria oportunidade da intervenção.

A discricionariedade para definir objetivos tem sua maior extensão nos casos em que o legislador pode ele mesmo escolher os objetivos que irão justificar sua intervenção. Na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal é possível encontrar exemplos desses objetivos na “manutenção e promoção dos ofícios manuais”²⁹ e na participação do empregador nos custos que decorrem do seguro-desemprego quando antigos funcionários não encontram um novo trabalho em razão de uma proibição de concorrência acordada com esse empregador.³⁰ Um terceiro exemplo diz respeito à “manutenção de uma marinha mercante alemã”. O art. 27 da Constituição alemã prescreve que os navios mercantes alemães constituem uma marinha mercante única. Isso pode ser interpretado no sentido de que a manutenção de uma marinha mercante alemã tenha “a hierarquia de um bem constitucionalmente protegido”. Nesse caso, a perseguição dessa finalidade seria obrigatória ao legislador. Não haveria, então, nenhuma discricionariedade para definir objetivos. Mas o Tribunal Constitucional Federal deixa em aberto a definição do interesse coletivo na manutenção de uma marinha mercante alemã como objeto de um princípio constitucional, e se

28. Cf. Capítulo 3, II.3.1.

29. BVerfGE 13, 97 (110).

30. BVerfGE 99, 202 (212).

limita à constatação de que o legislador "pode"³¹ perseguir legitimamente esse fim. Com isso, a manutenção de uma marinha mercante alemã é tratada como uma finalidade que o legislador pode perseguir, porque está incluída em sua discricionariedade para definir objetivos.

Finalidades no âmbito da discricionariedade para definir objetivos são, em geral, interesses coletivos. Se um direito individual é suscitado como razão para a restrição de um direito fundamental, então, há princípios constitucionais em ambos os lados. Nesse caso, não há nenhuma discricionariedade para definir objetivos.

2. *Discricionariedade para escolher meios*

A segunda espécie de discricionariedade – a discricionariedade para escolher meios – entra em cena quando normas de direitos fundamentais não apenas proíbem intervenções, como também exigem ações positivas, como, por exemplo, a concessão de uma proteção.³² Essa discricionariedade decorre da estrutura dos deveres positivos. Se é obrigatório salvar alguém que se afoga, e se isso é possível tanto por meio de um salvamento direto a nado, quanto por meio do lançamento de uma bóia de salvamento, quanto com o auxílio de um bote, então, do dever de salvar não decorre a obrigação de se utilizar dessas três possibilidades. O dever é cumprido se o salvamento é alcançado por meio de um dos três caminhos. O caso dos deveres negativos é diferente. A proibição de matar inclui a proibição de toda e qualquer ação homicida.³³ A discricionariedade para escolher meios praticamente não suscita problemas se os diferentes meios forem aproximadamente adequados para realizar ou fomentar a finalidade e se não tiverem nenhum ou praticamente nenhum efeito negativo em outras finalidades ou princípios. Mas isso é diferente nos casos em que os diversos meios fomentarem a finalidade em graus distintos, ou se for incerto em que grau eles o fazem, ou se tiverem efeitos negativos em diferentes graus nas outras finalidades ou em outros princípios ou, ainda, se for incer-

31. *BVerfGE* 92, 26 (43).

32. Cf., por exemplo, *BVerfGE* 46, 160 (164-165).

33. Cf. Capítulo 9, II.3.

to em que grau isso ocorre.³⁴ Nesses casos, a decisão depende de sopesamentos e da possibilidade de identificar os respectivos graus de fomento e de prejuízo em relação a outras finalidades e princípios. Isso suscita novos problemas relacionados à discricionariedade. Em primeiro lugar, será analisada questão da discricionariedade estrutural para sopesar.

3. *Discricionariedade para sopesar*

Uma objeção frequentemente suscitada contra a teoria dos princípios inicia com a tese de que a idéia de otimização está associada à concepção de um ponto máximo, e avança na afirmação de que isso excluiria uma discricionariedade estrutural para sopesar. Lerche afirma que, se compreendidos como mandamentos de otimização, os princípios estão “vinculados ao máximo alcançável dadas as circunstâncias (jurídicas e fáticas)”, e, “nesse sentido, *in nuce*, a um ponto *ideal*”.³⁵ “Em face de seus conteúdos amplos e continuamente em movimento e *em colisão*”, isso significaria uma “sujeição intensa e fundamental do legislador ao ponto ‘máximo’ alcançável”. Para tanto faltaria uma “legitimação interna”.³⁶ Em sentido semelhante são as considerações de Scherzberg. Segundo ele, enquanto mandamentos de otimização, os direitos fundamentais permitiriam “apenas aquelas soluções de colisões que [implicassem] a máxima realização possível de todos os bens de direitos fundamentais envolvidos”. Afora algumas raras exceções, “do ponto de vista da estrutura das normas, isso excluiria uma discricionariedade decisória”.³⁷

A tese do ponto máximo implica a existência de uma única resposta correta no âmbito dos princípios. Se a isso se adiciona que o âmbito dos princípios de direitos fundamentais é ilimitado, em virtude da liberdade geral de ação, do enunciado geral de igualdade e de seu

34. Cf., a respeito, Martin Borowski, *Grundrechte als Prinzipien*, Baden-Baden: Nomos, 1998, pp. 140 e ss.

35. Peter Lerche, “Die Verfassung als Quelle von Optimierungsgeboten?”, in Joachim Burmeister (org.), *Verfassungsstaatlichkeit: Festschrift für Klaus Stern zum 65. Geburtstag*, München: Beck, 1997, p. 205.

36. Idem, pp. 205-206.

37. Arno Scherzberg, *Grundrechtsschutz und “Eingriffsintensität”*, Berlin: Duncker & Humblot, 1989, p. 174.

efeito irradiador por todo o sistema jurídico, então, fica claro que a objeção à idéia de ponto máximo nada mais é que uma variante especial, aplicada à otimização, da crítica baseada na idéia de genoma jurídico, feita por Forsthoff.

Saber se a objeção do ponto máximo é procedente é algo que depende do que se entende por “otimização” na teoria dos princípios. Esse conceito decorre da própria definição de princípios. Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Uma das teses centrais da “Teoria dos Direitos Fundamentais” é a de que essa definição implica a máxima da proporcionalidade, com suas três máximas parciais – as máximas da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito –, e que a recíproca também é válida, ou seja, que da máxima da proporcionalidade decorre logicamente o caráter principiológico dos direitos fundamentais.³⁸ Essa equivalência significa que as três máximas parciais da máxima da proporcionalidade definem aquilo que deve ser compreendido por “otimização” na teoria dos princípios. A questão acerca da incompatibilidade da otimização com a idéia de constituição como moldura é, portanto, equivalente à questão acerca dessa incompatibilidade em relação à máxima da proporcionalidade. Para responder a essa pergunta, é necessário antes um breve exame das máximas da adequação e da necessidade.

3.1 Adequação e necessidade

As máximas da adequação e da necessidade expressam a exigência – contida na definição de princípio – de uma máxima realização em relação às possibilidades fáticas. Isso tem pouco a ver com a idéia de “ponto máximo”, e que será ilustrado com o auxílio de dois casos. O primeiro deles diz respeito à adequação. Um cabeleireiro colocou, sem permissão, uma máquina de venda automática de cigarros em seu estabelecimento. Diante disso, as autoridades administrativas impuseram-lhe uma multa por descumprimento da lei sobre o comércio no varejo. Essa lei exigia uma permissão, que só seria concedida se o

38. Cf. Capítulo 3, I.8.

requerente demonstrasse “a necessária expertise”, a qual poderia ser obtida por meio de um curso profissionalizante como comerciante, de uma prática de muitos anos em um estabelecimento comercial ou de um exame especial, no qual seriam testados conhecimentos técnico-comerciais.³⁹ O cabeleireiro procurou a proteção dos tribunais. O Tribunal Superior Estadual de Saarbrücken, que se ocupou com o caso em segunda instância, considerou inconstitucional a exigência de uma demonstração de expertise comercial nos casos de instalação de simples máquinas automáticas e suscitou uma prejudicial de inconstitucionalidade perante o Tribunal Constitucional Federal. O Tribunal Constitucional Federal chegou à conclusão de que a exigência de uma prova de expertise para qualquer comércio de qualquer mercadoria – ou seja, também para a exploração de máquinas automáticas para vender cigarros – viola a liberdade profissional garantida pelo art. 12, § 1º, da Constituição alemã. Sua fundamentação baseia-se essencialmente no fato de que a exigência de uma prova de competência comercial no caso da exploração de uma máquina automática para vender cigarros não é adequada para proteger o consumidor contra prejuízos à sua saúde ou contra prejuízos econômicos.⁴⁰ Por essa razão, essa exigência seria proibida pela máxima da adequação e violaria o direito fundamental à liberdade profissional.

Essa argumentação é a expressão da idéia de otimização. Em jogo estavam dois princípios: o da liberdade profissional (P_1) e o da proteção ao consumidor (P_2). Por inexistência de adequação, a medida adotada (M) – a exigência de demonstração de competência comercial – não é capaz de fomentar P_2 , mas embaraça a realização de P_1 . Nessa situação, não há custos nem para P_1 , nem para P_2 , caso M não seja adotada, mas há custos para P_1 se M for adotada. P_1 e P_2 , se considerados em conjunto, são realizados em maior grau – relativamente às possibilidades fáticas – se se abrir mão de M . Por conseguinte, P_1 e P_2 , considerados conjuntamente, proíbem a adoção de M . Isso nada mais é que a expressão da idéia de eficiência de Pareto: uma posição pode ser melhorada sem que uma outra seja piorada.⁴¹

39. BVerfGE 19, 330 (332 e ss.)

40. BVerfGE 19, 330 (338-339).

41. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.

Esse exemplo simples demonstra que, se não se pretende abandonar a máxima da adequação, não é possível passar ao largo de algum tipo de otimização. Ele demonstra, além disso, que o aspecto da otimização presente na máxima da adequação não aponta para um ponto máximo. Essa máxima tem, na verdade, a natureza de um critério negativo. Ela elimina meios não adequados. Um tal critério negativo não determina tudo, mas exclui algumas coisas. Nesse sentido, ele ajusta-se à idéia de uma ordem-moldura. Como elemento de uma ordem como essa, ele exclui algumas coisas – a saber: aquilo que não é adequado – sem, com isso, determinar tudo.

Algo semelhante é válido para a máxima da necessidade. Ela exige que, dentre dois meios aproximadamente adequados, seja escolhido aquele que intervenha de modo menos intenso. Mais uma vez será usado um exemplo que diz respeito a uma colisão entre a liberdade profissional e a proteção do consumidor. Uma portaria do Ministério para a Juventude, Família e Saúde continha a proibição de comercialização de doces que, embora contivessem chocolate em pó, eram feitos sobretudo de flocos de arroz e não eram, portanto, produtos genuinamente de chocolate. O objetivo dessa portaria era proteger o consumidor contra compras equivocadas. O Tribunal Constitucional Federal observou que uma tal proibição de comercialização de mercadorias seria inteiramente adequada para proteger o consumidor. Se há uma proibição de que algo seja comercializado, o risco de que ele seja comprado por engano é pequeno. No entanto, a proibição de comercialização não seria necessária. Haveria uma medida igualmente adequada e, ao mesmo tempo, menos invasiva. Um dever de identificação no rótulo poderia combater o perigo de confusões e equívocos “de maneira igualmente eficaz, mas de forma menos invasiva”.⁴²

Também aqui a idéia de otimização é facilmente identificável. O princípio da proteção do consumidor (P_2) é satisfeito de forma similar pelo dever de identificação no rótulo (M_1) e pela proibição de comercialização (M_2). Assim, para P_2 é indiferente se se adota M_1 ou M_2 . Mas isso não é assim para o caso da liberdade profissional (P_1). M_2 intervém em P_1 de forma muito mais intensa que M_1 . Em face das possibilidades fáticas (M_1 ou M_2), P_1 é satisfeito em um grau maior com a escolha de M_1 que com a escolha de M_2 sem que, com isso,

42. BVerfGE 53, 135 (146).

surjam custos para P_2 . Por isso, a otimização de P_1 e P_2 veda a utilização de M_2 .

Nesse sentido, também a máxima da necessidade é expressão da idéia de eficiência de Pareto. Em razão da existência de um meio que intervém menos e é igualmente adequado, uma posição pode ser melhorada sem que isso ocorra às custas da outra posição. É claro que, ao contrário do que ocorre com o exame da adequação, aqui não ocorre uma simples eliminação de meios. Mas ao legislador também não é prescrita categoricamente a adoção do meio que intervém em menor intensidade. O que se diz é apenas que, se o legislador quiser perseguir o objetivo escolhido, ele pode adotar apenas o meio mais suave, ou um meio igualmente suave ou um meio ainda mais suave. Isso não é nenhuma otimização em direção a algum ponto máximo, mas apenas a vedação de sacrifícios desnecessários a direitos fundamentais.

É claro que os exames da adequação e da necessidade não são sempre assim tão simples como nos casos acima analisados. E isso por vários motivos. Dois deles merecem ser salientados. O primeiro é que os exames da adequação e da necessidade dizem respeito a uma relação meio-fim, cuja avaliação freqüentemente suscita difíceis problemas de prognósticos. Em 1994 o Tribunal Constitucional Federal tinha que decidir se a criminalização da fabricação, comercialização, disseminação e aquisição de produtos derivados de *cannabis* seria compatível com a liberdade geral de ação (art. 2º, § 1º, da Constituição alemã) e com a liberdade pessoal (art. 2º, § 2º, 2, também da Constituição alemã). Nesse contexto, era também necessário indagar se uma liberação da *cannabis*, como um meio menos gravoso em relação à liberdade, não poderia afastar os perigos associados a essa droga e a seu comércio ilegal de forma tão ou mais eficiente que uma criminalização geral. A resposta do tribunal baseou-se na tese de que não existem "conhecimentos fundados cientificamente que decidam indubitavelmente em favor de um ou de outro caminho".⁴³ Nessa situação, a decisão do legislador pela criminalização teria que ser aceita, "[p]ois o legislador tem uma prerrogativa de avaliação e decisão para a escolha entre diversos caminhos potencialmente adequados para alcançar um objetivo legal".⁴⁴

43. BVerfGE 90, 145 (182-183).

44. BVerfGE 90, 145 (183).

Isso demonstra o grande papel que pode ser atribuído à discricionariedade epistêmica no exame da adequação e da necessidade. O reconhecimento de uma competência legislativa para a avaliação de variáveis empíricas é, no que diz respeito ao seu resultado, equivalente ao reconhecimento de uma competência para restringir o direito fundamental.⁴⁵ Saber se e em que extensão são justificáveis essas discricionariedades para fazer estimativas é algo que diz respeito não às discricionariedades estruturais, mas às epistêmicas. Mas esse é um problema essencialmente ligado aos princípios formais.

O problema da discricionariedade epistêmica surge tanto no exame da adequação quanto no exame da necessidade. O segundo motivo para que a estrutura desses exames – que, em si, é simples – se torne complexa está ligado apenas ao exame da necessidade. Ele reside na possibilidade de situações nas quais não apenas dois princípios sejam relevantes. Frequentemente, em relação ao direito fundamental afetado, há meios mais suaves e que fomentam o objetivo perseguido pelo legislador de forma igualmente efetiva, mas que têm como desvantagem a afetação de um terceiro princípio. Um exemplo dessa situação é oferecido por decisão do Tribunal Constitucional Federal que dizia respeito à proibição de que empresários da construção civil utilizassem mão-de-obra de trabalhadores temporários. Essa prática gerava inúmeras violações contra prescrições de direito do trabalho, direito social, direito econômico e direito tributário. Mas havia agências intermediadoras que obedeciam a essas prescrições. Isso indicava que uma proibição total de sua atividade não seria necessária, já que o objetivo legislativo – o combate à prática ilegal – poderia ser alcançado por meio de uma medida mais suave. Necessário seria apenas um controle mais eficiente nos canteiros de obra. Dessa forma seria possível, ao mesmo tempo, proteger o direito fundamental à liberdade profissional e alcançar o objetivo do legislador. Se importantes fossem apenas a liberdade profissional (P_1) e o combate à prática ilegal (P_2), então – pressuposta uma similar eficiência entre o controle (M_1) e a proibição (M_2) –, esse argumento seria inafastável. Ou seja: a proibição (M_2) seria vedada. Mas o Tribunal Constitucional Federal suscita a existência de um terceiro princípio, o do uso racional dos recursos públicos (P_3). Os indivíduos não podem esperar que, para que sejam

45. Cf. Capítulo 9, II.3.

evitadas intervenções em direitos fundamentais, “os limitados recursos públicos sejam utilizados – para além da medida que a sociedade poderia razoavelmente esperar – na ampliação dos órgãos responsáveis pelo combate a essas irregularidades”.⁴⁶ Com isso, a constelação altera-se de maneira fundamental. Saber se se deve adotar M_1 no lugar de M_2 é algo que não pode mais ser decidido com base na relação entre P_1 e P_2 . Em relação à alternativa M_1 ou M_2 , P_2 é neutro e, com isso, não é relevante no que diz respeito à escolha entre essas duas possibilidades, pois ele apenas exige que seja adotada ou M_1 ou M_2 . A escolha é decidida exclusivamente entre P_1 e P_3 . No caso em questão a constituição admite uma intervenção relativamente intensa no direito fundamental (M_2), para que os recursos públicos sejam menos comprometidos, ou ela exige um maior comprometimento dos recursos públicos, para que se possa realizar a finalidade de combater a prática ilegal (P_2) com uma intervenção relativamente pequena no direito fundamental (M_1)? Com essa questão, abandona-se o âmbito da otimização em relação às possibilidades fáticas. Trata-se de uma realização mais ampla possível em relação às possibilidades jurídicas. O que se indaga é se P_2 e P_3 , *tomados em conjunto*, justificam a intervenção relativamente intensa em P_1 , presente na proibição (M_2). Essa é uma questão de sopesamento. Com ela, adentra-se a terceira etapa da máxima da proporcionalidade.

3.2 Proporcionalidade em sentido estrito

Como mandamentos de otimização, princípios exigem uma realização mais ampla possível em face não apenas das possibilidades fáticas, mas também em relação às possibilidades jurídicas. Essas últimas são determinadas sobretudo pelos princípios colidentes. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito – a terceira máxima parcial da máxima da proporcionalidade – expressa o que significa a otimização em relação aos princípios colidentes. Ela é idêntica à lei do sopesamento, que tem a seguinte redação:

Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro.⁴⁷

46. BVerfGE 77, 84 (110-111).

47. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.

Isso expressa que a otimização em relação aos princípios colidentes nada mais é que o sopesamento.

A lei do sopesamento mostra que ele pode ser dividido em três passos. No primeiro é avaliado o grau de não-satisfação ou afetação de um dos princípios. Depois, em um segundo passo, avalia-se a importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, em um terceiro passo, deve ser avaliado se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a afetação ou a não-satisfação do outro princípio.

A objeção de Habermas à teoria dos princípios seria em seu cerne justificada caso não fosse possível elaborar juízos racionais sobre intensidades de intervenções, sobre graus de importância e sobre o relacionamento entre ambos. Afora as eliminações levadas a cabo por meio das máximas da adequação e da necessidade, os direitos fundamentais compreendidos como princípios permitiriam qualquer solução. Não haveria nenhuma moldura, já que não existiria nenhum limite. De outro lado, a objeção de Böckenförde também seria em seu cerne justificada caso o sopesamento exigisse sempre apenas uma única decisão do legislador, ou seja, se não existisse nenhuma discricionariedade estrutural para sopesar. Visto que só faz sentido falar em moldura e discricionariedade se algum tipo de limite for possível, é necessário começar pelo problema descrito por Habermas. Se se toma literalmente sua tese de que faltam "parâmetros racionais" para o sopesamento,⁴⁸ então, essa tese sustenta que por meio de um sopesamento não é possível chegar a uma conclusão de forma racional em nenhum caso. Há duas teses contrárias a essa tese, uma radical e uma moderada. A tese radical sustenta que o sopesamento possibilita uma conclusão racional em todos os casos. A teoria dos princípios nunca sustentou essa tese e sempre salientou que o sopesamento não é um procedimento que conduza, em todo e qualquer caso, a um resultado único e inequívoco.⁴⁹ Diante disso, as atenções se voltam para a versão moderada. Ela sustenta que, embora o sopesamento nem sempre determine um resultado de forma racional, isso é em alguns casos possível, e o conjunto desses casos é interessante o suficiente para justificar o sopesamento como método.

48. Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, p. 315.

49. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2. Cf. também, no mesmo Capítulo, II.3.2, e Capítulo 10, II.2.2, III.1, III.2 e III.3.2.3.

É fácil encontrar exemplos nos quais sejam possíveis juízos racionais sobre intensidades de intervenções e graus de importância e, nesse sentido, nos quais se possa alcançar um resultado racional por meio de um sopesamento. Assim, o dever imposto aos fabricantes de produtos derivados de tabaco de imprimir em seus produtos informações sobre os riscos do fumo para a saúde é uma intervenção leve na liberdade profissional. Já uma proibição total contra produtos derivados do tabaco deveria ser classificada como séria. Entre esses casos leves e sérios há casos cuja intensidade da intervenção pode ser classificada como moderada. Um exemplo seria a proibição de máquinas automáticas de venda de cigarros em conjunto com uma restrição à venda de produtos derivados de tabaco em determinados estabelecimentos. Dessa forma é construída uma escala com as categorias “leve”, “moderado” e “sério”. Nosso exemplo demonstra que são possíveis atribuições válidas a essas categorias. Vamos supor que alguém classifique uma proibição total de todos os produtos derivados do tabaco como uma intervenção leve na liberdade profissional dos produtores, e o dever de imprimir avisos nas embalagens como uma intervenção séria. Não seria fácil levar esses juízos a sério.

A possibilidade de uma escala com três níveis também existe no âmbito das razões contrapostas. A razão para o dever de imprimir avisos nos produtos derivados de tabaco reside na proteção da população contra riscos à sua saúde. O Tribunal Constitucional Federal não exagera quando, em sua decisão sobre avisos nas embalagens de cigarro, sustenta que, “de acordo com o conhecimento médico atualmente estabelecido”, fumar causa câncer e doenças cardíacas e vasculares.⁵⁰ Portanto, o peso das razões que justificam a intervenção é grande. São razões fortes. Definidos, assim, a intensidade da intervenção como leve e o grau de importância da razão da intervenção como alto, então, o resultado é facilmente perceptível. A forte razão para intervenção justifica a leve intervenção. Por conseguinte, o dever de imprimir avisos nas embalagens de produtos derivados de tabaco não viola a liberdade profissional dos produtores, garantida pelo art. 12, § 1º, da Constituição alemã. Esse resultado do exame da proporcionalidade em sentido estrito não é apenas plausível; em face da pequena intensidade da intervenção e do grande peso da razão para essa interven-

50. BVerfGE 95, 173 (184).

ção, é possível, como fez o Tribunal Constitucional Federal, classificá-lo como “evidente”.⁵¹

Alguém poderia sustentar que o exemplo não diz muita coisa. De um lado, trata-se de uma atividade econômica, no âmbito da qual a possibilidade de se construir escalas é grande, porque a ela subjazem considerações sobre custos. De outro lado, porque diz respeito a uma questão de vida ou morte. Se é possível demonstrar, por meio de pesquisas empíricas, que o risco é relativamente alto, a decisão por uma classificação nos patamares mais altos de importância pode ser baseada em fatos quantificáveis. Mas isso não poderia ser transportado para outros âmbitos, nos quais fatores quantificáveis – como custos e probabilidades – têm pequeno ou nenhum papel.

Para refutar essa objeção será analisado um caso que diz respeito à clássica colisão entre liberdade de expressão e direito de personalidade. Um oficial da reserva tetraplégico que havia realizado com sucesso um exercício militar para o qual havia sido convocado foi chamado pela popular revista satírica *Titanic* de “assassino nato” e, em uma edição posterior, de “aleijado”. Diante de uma ação ajuizada pelo oficial da reserva, o Tribunal Superior Estadual em Düsseldorf condenou a revista a uma indenização no valor de 12.000 marcos alemães. A revista *Titanic* interpôs uma reclamação constitucional. O Tribunal Constitucional Federal realiza um “sopesamento com base nos elementos do caso”⁵² entre a liberdade de manifestação do pensamento dos envolvidos do lado da revista (art. 5º, § 1º, 1, da Constituição alemã) e o direito geral de personalidade do oficial da reserva (art. 2º, § 1º, c/c o art. 1º, § 1º, ambos também da Constituição alemã). Para tanto, as intensidades de afetação desses direitos foram determinadas e relacionadas. A condenação à indenização é classificada como “de alto impacto”, ou seja, como uma intervenção *séria* na liberdade de expressão, ainda que tenha sido o resultado de uma condenação no âmbito civil, e não no âmbito penal. Isso é fundamentado sobretudo por meio do fato de que a indenização poderia reduzir a futura disposição dos afetados em editar sua revista na forma como feito até então.⁵³ A alcunha “assassino nato” é, então, analisada no contexto do

51. BVerfGE 95, 173 (187).

52. BVerfGE 86, 1 (11).

53. BVerfGE 86, 1 (10).

artigo satírico em que estava inserida. Nele, várias pessoas têm alguma característica associada ao adjetivo “nato”, de uma forma “claramente não-séria, por meio de jogos de palavras que às vezes beiravam a tolice”. O então Presidente da República, Richard von Weizsäcker, é chamado, por exemplo, de “burguês nato”.⁵⁴ Esse contexto impede que se considere a alcunha uma “violação inadmissível, intensa e ilegal do direito de personalidade”.⁵⁵ Diante disso, a afetação ao direito de personalidade é avaliada, no máximo, como sendo de intensidade *moderada*, talvez até mesmo *leve*. A isso corresponde uma importância *média*, talvez apenas *pequena*, em proteger a personalidade do oficial da reserva por meio de uma indenização em dinheiro. Essas classificações encerram a primeira parte da decisão. Para justificar a condenação à indenização em dinheiro – uma intervenção séria no direito fundamental à liberdade de expressão – seria necessário que a afetação do direito de personalidade – a ser compensada mediante a indenização – fosse igualmente séria. Mas na avaliação do Tribunal Constitucional Federal não era esse o caso. Então, a intervenção na liberdade de expressão havia sido desproporcional, o que significa que a utilização da alcunha “assassino nato” para designar o oficial da reserva não poderia ser sancionada por meio de uma indenização em dinheiro.

Diferente é o caso da alcunha “aleijado”, que fere o oficial tetraplégico “*seriamente* em seu direito de personalidade”.⁵⁶ Portanto, é de grande importância a proteção do oficial da reserva por meio de uma indenização em dinheiro. Isso é fundamentado por meio do fato de que chamar de “aleijado” um portador de deficiência física grave é, hoje em dia, em geral “visto como uma humilhação” e expressão de um “desrespeito”. À séria intervenção na liberdade de expressão é, então, contraposta a grande importância da proteção do direito de personalidade. Nessa situação, o Tribunal Constitucional Federal chega à conclusão de que não é possível identificar “nenhuma ponderação equivocada contra a liberdade de expressão do pensamento”.⁵⁷ Assim, a reclamação constitucional da revista *Titanic* foi considerada justifi-

54. BVerfGE 86, 1 (11).

55. BVerfGE 86, 1 (12).

56. BVerfGE 86, 1 (13) – sem grifo no original.

57. Idem.

cada somente na parte que se refere à condenação a uma indenização em dinheiro em virtude da denominação "assassino nato". Na parte que diz respeito à denominação "aleijado" ela foi considerada sem fundamento.⁵⁸

É claro que é discutível se, de fato, a alcunha "assassino nato" é uma intervenção apenas moderada ou leve. Esse tipo de dúvidas será analisado quando do exame dos princípios formais. Aqui importa apenas o fato de que praticamente não há dúvidas de que tanto a imposição de uma indenização em dinheiro quanto a denominação "aleijado" afetam de forma intensa os princípios em jogo.

Naquilo que diz respeito ao portador de deficiência grave é possível fazer quantificações que vão além daquelas feitas pelo tribunal. O Tribunal Constitucional Federal constata corretamente que chamar um tetraplégico de "aleijado" é uma humilhação e um desrespeito. Essa humilhação e essa falta de respeito públicas atingem a dignidade do envolvido. Isso não é simplesmente uma afetação séria, mas uma afetação muito séria ou extraordinariamente séria. Com ela adentra-se o âmbito no qual afetações são praticamente injustificáveis por meio de um fortalecimento das razões para a intervenção. Isso corresponde à lei da taxa marginal decrescente de substituição.⁵⁹ Essa lei é o muro protetor que faz falta a Habermas na teoria dos princípios. Por isso, o caso *Titanic* é não apenas um exemplo da possibilidade de se fazer escalas que podem ser relacionadas entre si de forma razoável também nos casos que envolvam bens imateriais, como o direito de personalidade e a liberdade de expressão; mas também um exemplo da força inerente aos direitos fundamentais compreendidos como princípios. Por meio do sopesamento, essa força impõe limites que, ainda que não sejam identificáveis de forma rígida e independente de sopesamentos, não são, por isso, menos sólidos e claros.

As decisões sobre os produtos derivados do tabaco e sobre a revista *Titanic* demonstram que juízos racionais sobre graus de intensidade e importância são possíveis e que eles podem ser relacionados com vistas à fundamentação de uma decisão. É claro que esses juízos pressupõem parâmetros que não estão contidos na própria lei do sopesamento. Assim, na constatação de que a imposição de uma indeniza-

58. BVerfGE 86, 1 (14).

59. Cf. Capítulo 3, III.2.2.2.

ção em dinheiro contra a revista *Titanic* é uma séria intervenção na liberdade de expressão estão implícitas algumas suposições sobre o que constitui um risco à liberdade de expressão. Do outro lado, o juízo de que a designação “aleijado” é uma séria intervenção na personalidade implica suposições sobre o que significa ser pessoa e ter dignidade. Mas isso não significa, para usar as palavras de Habermas, que o sopesamento seja realizado “de forma arbitrária ou irrefletida, baseado em standards e hierarquias já sedimentados”.⁶⁰ As suposições que subjazem aos juízos sobre a intensidade de intervenção e o grau de importância não são arbitrárias. Para a sua fundamentação são apresentadas razões plausíveis. Também é duvidoso que as suposições do Tribunal Constitucional Federal sejam definidas “de forma irrefletida, baseadas em standards e hierarquias já sedimentados”. Os standards são sobretudo uma linha de precedentes. Falar, nesse ponto, de “standards já sedimentados” seria justificado somente se a decisão levasse em consideração apenas a existência dessa linha de precedentes, mas não a sua correção. Além disso, falar em uma aplicação “irrefletida” seria possível apenas se essa aplicação não ocorresse de forma argumentativa. Os argumentos são a expressão pública da reflexão. Não há, contudo, uma carência argumentativa. E isso tudo vale também para a decisão sobre produtos derivados do tabaco.

Ambas as decisões demonstram, portanto, que há casos em que, com o auxílio da lei do sopesamento, são impostos limites à atividade estatal de forma racional. Com isso, refuta-se a tese de que o sopesamento, no limite, tudo permitiria, em virtude da falta de parâmetros racionais. A lei do sopesamento sobrevive, assim, às objeções de Habermas. Agora é, então, necessário verificar se isso ocorre também em relação às objeções de Böckenförde. Para tanto, a lei do sopesamento tem que ser compatível com um grau suficiente de discricionariedade. Para responder à questão acerca da discricionariedade no âmbito de aplicação da lei do sopesamento, é necessário examinar o sistema que subjaz à construção das escalas vistas anteriormente. Todas as classificações ocorrem em um modelo em três níveis, ou triádico. Os três níveis podem ser identificado por meio dos termos “leve”, “moderado” e “sério”. Para facilitar, esses três níveis serão identificados pelas letras “l”, “m” e “s”. A letra l, aqui, não significa apenas “leve”, mas

60. Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, p. 315.

também “reduzido” ou “fraco”; e *s* substitui, além de “sério”, termos como “elevado” ou “forte”.

Nos termos da lei do sopesamento, aquilo que é avaliado como *l*, *m* ou *s* é o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio e a importância da satisfação do outro. Ao invés de se falar em “grau de não-satisfação ou de afetação”, é possível também falar em “intensidade da intervenção”. Se se utiliza “ P_i ” como variável para o princípio cuja violação está sendo examinada, então, é possível simbolizar a intensidade da intervenção em P_i por meio de “ IP_i ”. Intervenções são sempre intervenções concretas. A intensidade da intervenção é, por isso, uma grandeza concreta. Enquanto tal, ela se diferencia do peso abstrato de P_i . Por razões de clareza, é sempre importante deixar claro se se está falando de uma grandeza abstrata ou de uma grandeza concreta. No caso de IP_i isso não é necessário, porque intensidades de intervenções são sempre grandezas concretas. Mas não há prejuízo em se explicitar a concretude de “ IP_i ” por meio da aposição de “ C ”, que expressa as circunstâncias relevantes para a decisão do caso. Na lei do sopesamento⁶¹ “ C ” desempenha um papel central. Para deixar clara essa conexão, a intensidade da intervenção (*I*) em P_i no caso em questão (*C*) será simbolizada por “ IP_iC ”.

A segunda grandeza presente na lei do sopesamento é a importância da satisfação do outro princípio. Ao contrário do que ocorre com a intensidade da intervenção, o grau de importância não tem necessariamente que ser compreendido sempre como uma grandeza concreta. É possível construir um conceito de importância que seja a reunião de uma grandeza concreta e uma grandeza abstrata. Nesse sentido, a vida humana tem, em abstrato, um peso maior que a liberdade geral de se fazer ou deixar de fazer o que se queira. Portanto, a importância que a proteção da vida tem em uma determinada situação pode ser determinada, ao mesmo tempo, com base no peso abstrato da vida e na ameaça que ela sofre no caso concreto. Mas a possibilidade de um tal conceito integrado de importância não é um argumento contra a distinção entre seus elementos. E isso, em primeiro lugar, por razões analíticas. A essas razões soma-se também o fato de que, nos sopesamentos, os pesos abstratos têm um papel influente na decisão apenas se esses pesos forem diversos. Se eles foram iguais – o que é muito

61. Cf. Capítulo 3, I.3.2.1.

freqüente nas colisões entre direitos fundamentais –, tudo dependerá exclusivamente dos pesos concretos. Por isso, um conceito de importância concreta é algo imprescindível. Esse conceito pode ser formado se se utiliza “ W ” para a importância, “ P_j ” para o princípio e “ C ” para mostrar que se trata de importância no caso concreto. Assim, a importância concreta de P_j pode ser simbolizada por “ WP_jC ”.

É claro que isso ainda não responde à pergunta acerca do que seja a importância concreta de P_j . O que foi definido foi apenas que ela depende das circunstâncias do caso concreto. Os elementos do caso concreto essenciais para decisão são a medida questionada e os efeitos que sua adoção e sua não-adoção têm nos princípios envolvidos. A não-adoção faz parte da análise porque se trata de decidir se a medida é permitida ou proibida do ponto de vista dos direitos fundamentais, e a proibição corresponde à constelação na qual a medida não é adotada. O significado disso pode ser ilustrado com o auxílio do caso *Titanic*. Neste ponto interessa apenas a alcunha de “aleijado” dada ao oficial da reserva portador de grave deficiência física. Para determinar a intensidade da intervenção na liberdade de expressão é necessário apenas indagar o quão intensamente sua proibição, em conjunto com a imposição do pagamento de uma indenização em dinheiro, intervém na liberdade de expressão. Isso é o que a Constituição exigiria desse direito fundamental se ela tivesse que permitir a proibição dessa manifestação, definida na decisão do Tribunal Superior Estadual em Düsseldorf, em conjunto com a imposição do pagamento de uma indenização em dinheiro. Para determinar a importância da satisfação do princípio da proteção da personalidade é necessário, por sua vez, questionar o que a abstenção ou a não-realização da intervenção na liberdade de manifestação do pensamento – ou seja, a classificação da alcunha “aleijado” como permitida e, com isso, a não imposição de uma indenização – significaria para a proteção da personalidade. Isso diz respeito a nada mais que aos custos impostos à proteção da personalidade em razão de se poupar a liberdade de expressão. No caso *Titanic*, portanto, a importância do princípio da proteção da personalidade decorre do definição do quão intensamente a não-intervenção na liberdade de expressão da revista interviria no direito de personalidade do oficial da reserva. Isso pode ser generalizado e resumido na seguinte fórmula: a importância concreta de P_j é medida a partir da definição de quão intensamente a não-intervenção em P_i intervém em P_j .

Aqui seria possível questionar por que, diante dessa fórmula, é ainda necessário falar em "importância" concreta de P_j . Esse é um problema terminológico. Seria de fato possível, também no caso de P_j , falar apenas da intensidade de uma intervenção – nesse caso, da intensidade da intervenção por meio da não-intervenção em P_i . É, então, necessário indagar qual terminologia é mais apropriada. Análises jurídicas devem ir tão profundamente em seu objeto quanto for possível e não se intimidar diante das estruturas mais complexas. Mas, depois que o trabalho analítico já foi realizado, o jurista tem que voltar à superfície e divulgar seus conhecimentos com as palavras mais simples e confiáveis. Por esse aspecto, o conceito de importância concreta do princípio colidente parece ser adequado para compreender o conteúdo do conceito de intensidade da intervenção por meio de não-intervenção e para associá-lo a intuições bem fundamentadas e usuais. Por isso, a lei do sopesamento continuará a fazer menção à importância da satisfação do outro princípio. Com isso, o contraponto de " IP_iC " é " WP_jC ".

Os objetos que devem ser avaliados como l , m ou s estão definidos. Quando da apresentação da lei do sopesamento afirmou-se que ela dividia o sopesamento em três passos. Os primeiros dois passos podem ser agora realizados em nosso modelo triádico: a avaliação de IP_iC como l , m ou s , e a avaliação de WP_jC também como l , m ou s . Neste ponto é necessário indagar como o terceiro passo deve ser realizado para que ambas as avaliações sejam relacionadas entre si. Se se observam as constelações possíveis no modelo triádico, a resposta é fácil. Há três constelações nas quais P_i tem precedência:

- (1) $IP_iC: s/WP_jC: l$
- (2) $IP_iC: s/WP_jC: m$
- (3) $IP_iC: m/WP_jC: l$.

Nesses casos, e exatamente nos termos da lei de colisão, vale a relação de preferência ($P_i \succ P_j$) C .⁶² A esses três casos de precedência de P_i correspondem três outros casos de precedência de P_j .

- (4) $IP_iC: l/WP_jC: s$
- (5) $IP_iC: m/WP_jC: s$
- (6) $IP_iC: l/WP_jC: m$.

62. Cf. Capítulo 3, I.3.2.1.

Nesses casos, vale $(P_j \text{ P } P_i) C$. A esses seis casos, que podem ser decididos em razão do escalonamento triádico, somam-se três casos de impasse:

$$(7) IP_i C: l/WP_j C: l$$

$$(8) IP_i C: m/WP_j C: m$$

$$(9) IP_i C: s/WP_j C: s$$

Os três casos de impasse no sopesamento levam a uma discricionariedade estrutural para sopesar. Para demonstrar isso, o modelo triádico tem que ser analisado um pouco mais.

Os três níveis do modelo triádico constituem uma escala que procura sistematizar as classificações que são encontradas tanto na prática cotidiana quanto na argumentação jurídica. Um escalonamento triplo está longe de uma metrificação das intensidades de intervenção e dos graus de importância por meio de uma escala cardinal como, por exemplo, uma escala de 0 a 1. E isso tem que ser assim, porque as intensidades de intervenção e os graus de importância não são passíveis de serem metrifcados com o auxílio de uma escala desse tipo.⁶³ Com certa frequência a simples classificação como leve, mediano ou sério já cria problemas. Às vezes consegue-se, com certo esforço, distinguir entre leve e sério, e em alguns casos até mesmo isso parece ser impossível. Por isso, escalonamentos jurídicos só são possíveis com limiares relativamente rudimentares, e isso nem mesmo em todos os casos. Por conseguinte, ficam excluídas metrificações calculáveis com o auxílio de um *continuum* de pontos entre 0 e 1. O que é, no entanto, possível é uma ilustração numérica da estrutura que subjaz ao modelo triádico. A partir desse pano de fundo, é possível estabelecer uma fórmula que expresse o peso de um princípio sob as circunstâncias de um determinado caso, ou seja, que expresse o seu *peso concreto*. Ela tem o seguinte conteúdo:

$$GP_{i,j} C = \frac{IP_i C}{WP_j C}$$

63. Cf. Capítulo 3, III.2.2.1.

Essa fórmula complementa as leis de colisão e do sopesamento. Ela será chamada de "fórmula do peso".⁶⁴

O único símbolo que ainda não havia sido apresentado é "*G*". "*G*" simboliza o peso concreto de P_i , ou seja, o peso de P_i sob as circunstâncias do caso a ser decidido (*C*). A fórmula do peso salienta que o peso concreto de um princípio é um peso relativo, já que determina que esse peso concreto é o quociente entre a intensidade da intervenção nesse princípio e a importância do princípio colidente. Essa relatividade é expressa por meio de " $P_{i,j}$ ". O peso concreto de P_i é o peso concreto de P_i em relação a P_j . Mas só se pode fazer menção a um quociente se houver números à disposição. No caso do sopesamento isso não é possível em um sentido direto. Por isso, o peso concreto só pode ser definido verdadeiramente como um quociente em um modelo numérico que ilustre a estrutura do sopesamento. Na argumentação jurídica isso é possível apenas por analogia. Mas essa analogia é instrutiva.

64. A fórmula do peso contém apenas grandezas concretas. Nesse sentido, ela representa uma situação na qual apenas esse tipo de grandeza importa. Como já foi mencionado, isso é assim sempre que os pesos abstratos são iguais. Se os pesos abstratos forem distintos, então, eles devem ser acrescentados a essa fórmula. Para tanto, pode-se simbolizar o peso abstrato de P_i por " GP_iA " e o peso abstrato de P_j por " GP_jA ". Nesse caso, a fórmula do peso passa a ter a seguinte redação:

$$GP_{i,j}C = \frac{IP_iC \cdot GP_iA}{WP_jC \cdot GP_jA}$$

Essa fórmula faz com que fique claro por que os pesos abstratos são supérfluos quando são iguais: eles podem ser cancelados mutuamente. Por isso, a fórmula sem os pesos abstratos não é uma fórmula distinta daquela com esses pesos; ela é a mesma fórmula após a realização desse cancelamento.

Uma questão interessante é saber se é possível introduzir um efeito cumulativo na fórmula do peso. Essa é uma questão que surge, por exemplo, quando se pode recorrer a mais de um princípio em favor de uma intervenção em determinado direito fundamental. Seria, então, possível pensar na seguinte extensão da fórmula do peso:

$$GP_{i-n}C = \frac{IP_iC \cdot GP_iA}{WP_jC \cdot GP_jA + \dots WP_nC \cdot GP_nA}$$

A adequação dessa extensão depende de se saber se a importância das razões para restrições aumenta apenas de forma aditiva, à medida que essas razões se incrementam.

Há diferentes possibilidades para a atribuição de números aos três valores do modelo triádico. Relativamente simples e, ao mesmo tempo, bastante instrutiva é a utilização dos valores 2^0 , 2^1 e 2^2 , ou seja, 1, 2 e 4.⁶⁵ A partir daí, l tem o valor 1, m o valor 2, e s o valor 4. O peso concreto de $P_i - (GP_{i,j}C)$ – surge, então, por meio da atribuição, na fórmula do peso, dos valores 1, 2 e 4 a IP_iC e a WP_jC . Que número será atribuído é algo que é determinado por meio da valoração da intensidade da intervenção e do grau de importância como leve, mediano e alto. Nos casos em que P_i tenha precedência a atribuição dos números mencionados faz com que o peso concreto de $P_i - (GP_{i,j}C)$ – tenha os seguintes valores: $s/l = 4$, $s/m = 2$, $m/l = 2$. Isso corresponde à intuição de que um princípio tem um peso concreto especialmente alto (4) quando a ele se pretende impor uma intervenção profunda

65. Seria também possível pensar em representar a escala em três níveis por meio de três pontos em uma escala de 0 a 1. Uma possibilidade mais óbvia seria dividir essa escala em três partes e escolher, para l , m e s , exatamente o valor central de cada uma dessas partes. Assim, l teria o valor $1/6$, m , o valor $1/2$, e s , o valor $5/6$. Como as distâncias entre l e m , de um lado, e m e s , de outro, seriam iguais, isso criaria uma sequência aritmética. Mas, na definição de um *quociente*, esses valores conduziram a distorções inadmissíveis. Nos casos em que uma intervenção justificada em P_i , isso até despertaria uma impressão plausível. A cadeia de valores seria: $l/s = 1/5$, $l/m = 1/3$, $m/s = 3/5$. O fato de o valor de l/m – apesar da igual distância, de um lado, entre l e m , e, de outro lado, entre m e s – ser menor do que o valor de m/s , poderia ser interpretado como a expressão de que princípios são mais resistentes nos casos de intervenções moderadas do que nos casos de intervenções leves, ou seja, com o aumento da intensidade da intervenção eles ganhariam força. Mas o mesmo teria que ocorrer do lado oposto, nos casos em que P_i vence. No entanto, a cadeia de valores nesse caso é: $s/m = 5/3$, $m/l = 3$, $s/l = 5$. Nesses termos, P_i tem um peso concreto menor ($5/3$) no caso de uma intervenção séria diante de uma importância apenas mediana do princípio colidente do que no caso de uma intervenção mediana diante de uma importância pequena do princípio que com ele colide (3). Isso contradiz a intuição segundo a qual princípios ganhariam força com o aumento da intensidade da intervenção. Em sequências aritméticas, essas distorções podem ser evitadas somente os quocientes forem substituídos por diferenças. Com a sequência $1/6$, $1/2$ e $5/6$, seriam obtidas os seguintes valores diferenciais, nos casos de superação de P_i : $l/m = -1/3$, $m/s = -1/3$, $l/s = -2/3$. No caso de uma vitória de P_i , obter-se-ia a seguinte cadeia: $s/m = 1/3$, $m/l = 1/3$, $s/l = 2/3$. E nos casos de um impasse (l/l , m/m , s/s), a diferença é sempre 0. Essa forma de exposição tem a vantagem da simplicidade. Sua desvantagem é que ela não expressa, ao contrário do que ocorre com a uma sequência geométrica, como a adotada no texto, que princípios sempre ganham força com o aumento da intensidade da intervenção. Agradeço aqui a Virgílio Afonso da Silva, Matthias Klatt e Hermann König suas interessantes observações acerca dos problemas na atribuição de números a l , m e s .

(s) por um motivo relativamente pouco importante (l). Também neste ponto fica claro em que sentido o peso concreto é um peso relativo. O peso relativo diminui (2) quando a intervenção profunda (s) ocorre em virtude de uma importância mediana da satisfação do princípios colidente (m). O mesmo resultado (2) ocorre no caso de uma intervenção média (m) para a qual se apresenta uma razão de pouco importância (l).

Em todos os casos nos quais P_i tem precedência em relação a P_j , o valor de P_i é maior que 1. Se ele ficar abaixo de 1, isso significa que é P_j que tem precedência. Os três valores para o caso de uma superação de P_i por P_j são os seguintes: $l/s = 1/4$, $m/s = 1/2$, $l/m = 1/2$. Aqui vale o oposto daquilo que foi dito acerca dos valores nos casos em que P_i tem precedência.

Para a questão da discricionariedade estrutural os casos de impasse são de especial interesse. Neles o peso concreto de P_i é sempre igual. Isso expressa idéia de uma equivalência de valores para todos os casos de impasse. Essa equivalência do impasse no sopesamento é a razão para a discricionariedade estrutural. Isso será demonstrado por meio de um caso concreto.

Esse caso diz respeito a reportagens da revista *Stern*, de Hamburgo, dos anos de 1982 e 1983, sobre investigações da promotoria da cidade de Bonn em um caso envolvendo doações de empresas a um partido político (o caso "*Flick-Spendenaffäre*"). Nessas reportagens eram feitas citações textuais retiradas dos autos sobre a oitiva de testemunhas e sobre o interrogatório de um dos acusados, bem como de peças produzidas pelo advogado de defesa. Essas citações textuais ocorreram antes que os autos se tornassem públicos. Essa conduta é punível com pena privativa de liberdade de até um ano ou multa, nos termos do § 353, "d", 3, do Código Penal alemão. O juízo de primeira instância, em Hamburgo, perante o qual os redatores responsáveis foram denunciados, considerou esse dispositivo inconstitucional, por não ser suficientemente adequado para alcançar os objetivos por ele almejados. Por isso, foi apresentada uma prejudicial de inconstitucionalidade perante o Tribunal Constitucional Federal. O Tribunal Constitucional Federal identificou dois objetivos do § 353, "d", 3, do Código Penal alemão: o primeiro é a proteção dos envolvidos em um processo, obrigatória em face do art. 2º, § 1º, c/c o art. 1º, § 1º, da Constituição alemã e da presunção de inocência do art. 6º, § 2º, da Convenção Europeia de Direitos Humanos; o segundo é a proteção da imparcialidade dos

envolvidos do processo, exigida pelo princípio do juízo imparcial, expresso nos arts. 97 e 101 da Constituição alemã.⁶⁶ O problema mais importante dessa decisão era o fato de que somente a citação textual dos autos do procedimento era punível, mas não uma reportagem que fosse ainda mais sensacionalista mas que não utilizasse transcrições dos autos. O Tribunal Constitucional Federal chega à conclusão de que citações textuais, em razão de sua autenticidade, ameaçam em maior grau os dois objetivos mencionados que reportagens sem o recurso a essas transcrições.⁶⁷ Embora a proteção por meio de uma proibição de citações textuais seja “incompleta” e, por isso, “pequena”⁶⁸ e “menos eficaz”,⁶⁹ as liberdades de expressão e de imprensa, garantidas pelo art. 5º, § 1º, da Constituição alemã, são também “restringidas em reduzida medida”, pois à imprensa ainda resta a possibilidade de noticiar sem a transcrição literal de partes dos autos.⁷⁰ O Tribunal Constitucional Federal resume o resultado de seu exame da proporcionalidade em sentido estrito em um enunciado que pode ser lido como uma aplicação da fórmula do peso em relação aos valores *///*: “Nesse sentido, [*isto é: em face da reduzida intensidade da intervenção*] a restrição às liberdades do art. 5º, § 1º, da Constituição alemã não é desproporcional em relação ao que se pretende com ela alcançar: a proteção – certamente pouco eficaz – dos bens jurídicos do § 353, “d”, 3, do Código Penal alemão”.⁷¹

Nesse enunciado, o trecho “não é desproporcional” tem especial importância. O tribunal aceita uma intervenção na liberdade de imprensa como compatível com a Constituição não somente se a importância das razões para a intervenção forem maiores que a intensidade da intervenção, mas também quando há uma equivalência – aqui, um impasse *///*. A desproporcionalidade em sentido estrito surge apenas quando a importância concreta fica abaixo da intensidade da intervenção, ou seja, somente nas constelações *s/l*, *s/m* e *m/l*. Nesse caso de impasse (*///*) ao legislador é permitido não agir. Mas, ao mesmo tempo, diante dessa constelação, é a ele também permitido agir, e isso

66. BVerfGE 71, 206 (216-217, 219).

67. BVerfGE 71, 206 (216).

68. BVerfGE 71, 206 (219).

69. BVerfGE 71, 206 (221).

70. BVerfGE 71, 206 (220).

71. BVerfGE 71, 206 (221).

significa, em face da mencionada definição de discricionariedade como faculdade, que a ele é conferida uma discricionariedade. Visto que essa discricionariedade decorre daquilo que é válido em virtude dos direitos fundamentais, trata-se de uma discricionariedade estrutural.

Um segundo significado dessa decisão para a teoria da discricionariedade estrutural decorre de uma observação quase marginal por meio da qual o tribunal constata que cabe ao legislador decidir se ele deseja escolher outra forma de regulamentação que pudesse ser melhor ou mais justa.⁷² Uma solução que fosse melhor para a proteção da personalidade e para a integridade da administração da justiça somente poderia ocorrer às custas de uma intervenção mais intensa na liberdade de expressão. Para que essa intervenção de intensidade média pudesse ocorrer, seria necessário que o grau de importância da proteção também alcançasse o nível médio. Mesmo uma intervenção mais séria poderia ser justificada se a ela correspondesse um maior grau de importância da proteção. Isso significa que a discricionariedade estrutural percorre a linha dos impasses.

Esse último ponto demonstra que é necessário distinguir dois aspectos da discricionariedade estrutural para sopesar. O primeiro consiste no impasse enquanto tal. Se a razão para uma intervenção é tão forte quanto a razão contra ela, a intervenção não é desproporcional. A decisão no caso *Stern* é um exemplo disso. O mesmo vale para o oposto da intervenção: a não-garantia de proteção. Se as razões a favor de uma não-proteção são tão fortes quanto as razões para a proteção, a não-proteção não é desproporcional. Isso cria uma extensa discricionariedade no âmbito dos efeitos dos direitos fundamentais perante terceiros.⁷³ O segundo aspecto da discricionariedade estrutural para sopesar consiste no fato de que impasses são equivalentes em diferentes níveis da escala. Assim, a idéia de uma discricionariedade estrutural para sopesar é a conjunção de dois pensamentos: o da igualdade no impasse e o da igualdade entre os impasses. Ainda que isso não responda a todas as perguntas, fica claro o que a idéia da discricionariedade estrutural para sopesar significa.

72. BVerfGE 71, 206 (218).

73. Cf., a respeito, BVerfGE 96, 56 (66), decisão na qual o Tribunal Constitucional Federal fala, de forma terminologicamente precisa, em uma "discricionariedade para sopesar".

Um adversário da teoria dos princípios poderia alegar que falar em impasse no sopesamento é uma artimanha. Esse impasse só seria plausível no modelo triádico rudimentar. Isso mascararia o fato de que, na verdade, não existem ou existem muito poucos impasses. Alguma pequena diferença, por mais ínfima que seja, sempre existirá. O que se pode no máximo aceitar é que, se impasses existem, eles são extremamente raros ou são raramente perceptíveis.⁷⁴ A base dessa objeção é a possibilidade de classificações mais refinadas que aquela do modelo triádico. Essas classificações mais refinadas podem ser construídas ou com o auxílio de uma escala mais depurada, ou simplesmente de forma direta, por meio da indagação, no caso em questão, se IP_iC é maior que WP_iC , se o contrário é que ocorre, ou, ainda, se ambos são iguais. A segunda alternativa seria uma quantificação no caso concreto, por meio de uma renúncia a qualquer forma de escalonamento. Em primeiro lugar será analisada a possibilidade de uma escala mais refinada.

Com base no modelo triádico é muito simples construir uma escala mais refinada e plausível. Basta aplicar os três níveis a si mesmos. Dessa forma, obter-se-ia um modelo triádico duplo, com nove níveis, que pode ser representado da seguinte forma: (1) *ll*, (2) *lm*, (3) *ls*, (4) *ml*, (5) *mm*, (6) *ms*, (7) *sl*, (8) *sm*, (9) *ss*. Essa divisão expressa que não existem apenas intervenções leves (*l*), moderadas (*m*) e sérias (*s*), mas também intervenções seriíssimas (*ss*), moderadamente sérias (*sm*) e levemente sérias (*ss*); intervenções moderadas quase sérias (*ms*), moderadas propriamente ditas (*mm*) e moderadas tendendo para o leve (*ml*); e intervenções leves quase moderadas (*ls*), moderadamente leves (*lm*) e levíssimas (*ll*).⁷⁵ Há muitos casos nos quais um escalonamento desse tipo é plausível. No caso da revista *Titanic*, por exemplo, a importância da proteção do oficial da reserva diante da alcunha “aleijado” pode ser classificada como importantíssima (*ss*), à qual é

74. Cf. Arno Scherzberg, *Grundrechtsschutz und “Eingriffsintensität”*, p. 174.

75. Os 9 níveis do modelo triádico duplo podem ser representados por valores de 2º a 28. Nessa representação, o peso concreto de $P_i - (GP_iC)$ – aumenta e diminui de forma considerável nos casos de grandes intervalos. No caso de uma intervenção seriíssima (*ss*), que seja justificada por uma razão muito pouco importante (*ll*), o peso concreto de P_i é de 256. Do lado oposto, no caso de uma intervenção levíssima (*ll*), justificada por uma razão importantíssima (*ss*), esse valor cai para 1/256. E os casos de impasse triplicam, chegando a 9.

contraposta uma intervenção moderadamente séria (*sm*) na liberdade de imprensa.

Contudo, esses refinamentos têm seus limites. Embora eles possam, em tese, ser expandidos sempre mais, com isso o sistema fica cada vez mais incompreensível. O que seria possível compreender por "moderado levemente sério"? De resto, os nove níveis freqüentemente só seriam aplicáveis com muita dificuldade. Já não é fácil, no âmbito do modelo triádico simples, responder à questão sobre se uma intervenção é leve, moderada ou séria. Assim, e como demonstra o caso *Titanic*, embora um refinamento da escala possa solucionar alguns casos de impasse, ele não é capaz de eliminá-los por completo, visto que cada aumento na sofisticação do escalonamento também traz consigo maiores problemas de aplicação.

Resta a questão acerca da possibilidade de uma eliminação radical dos casos de impasse por meio de uma quantificação no caso concreto, com a renúncia a qualquer forma de escalonamento. Se, nesse caso, forem admitidas tanto as relações de precedência – incluindo as suas relações conversas, as relações de superação – quanto as relações de equivalência, surge, então, um modelo que reduz as nove constelações do modelo triádico básico a apenas três: aquela na qual o IP_iC é maior que o WP_jC ; aquela na qual o WP_jC é maior que o IP_iC ; e aquela na qual ambos são iguais. Mas esse último caso é a mesma coisa que um impasse. Para excluir a possibilidade de impasses seria necessário, de antemão, classificar a relação de equivalência como impossível, ou sustentar que não há nenhum caso na qual ela ocorra. A primeira alternativa é uma simples eliminação daquilo que não se quer ter. Isso é inaceitável. A segunda exige que se indague se os princípios de direitos fundamentais e as formas de argumentação ligadas à sua aplicação têm uma estrutura tão precisa que pudesse fazer com que quase sempre houvesse uma diferença de grau que excluísse um impasse; ou seja, um impasse seria tão improvável que essa categoria poderia ser eliminada. Isso seria assim se as intensidades de intervenção, os graus de importância e os pesos abstratos estivessem de fato em condição de serem representados por meio de uma escala com infinitos níveis. Uma representação desse tipo seria, então, não apenas um modelo idealizado,⁷⁶ mas uma representação de uma estrutura de fato existen-

76. Cf., a esse respeito, Nils Jansen, "Die Abwägung von Grundrechten", *Der Staat* 36 (1997), pp. 29 e ss.

te. Mas há poucos indícios de que uma tal estrutura de fato exista. Aqui vale – como vale em geral no âmbito prático – a observação de Aristóteles segundo a qual nós não podemos “buscar a mesma exatidão em relação a todo e qualquer objeto, mas, em cada caso, apenas aquilo que é compatível com o material dado”.⁷⁷ Os direitos fundamentais não são um objeto passível de ser dividido de uma forma tão refinada que exclua impasses estruturais – ou seja, impasses reais no sopesamento –, de forma a torná-los praticamente sem importância. Nesse caso, então, de fato existe uma discricionariedade para sopesar, uma discricionariedade estrutural tanto do Legislativo quanto do Judiciário.⁷⁸

Mas por trás dessa constatação há um problema latente. Como é possível diferenciar, nos sopesamentos, entre os impasses que decorrem da estrutura normativa dos direitos fundamentais e os impasses que somente surgem porque as possibilidades cognitivas são limitadas? Apenas os primeiros fundamentam uma discricionariedade estrutural. Os últimos podem ser, quando muito, objeto de uma discricionariedade epistêmica. A simples possibilidade de questionar acerca da distinção entre impasses estruturais e epistêmicos – e a ausência de critérios facilmente disponíveis para responder a essa questão – indica que a distinção entre as discricionariedades estrutural e epistêmica pode ser algo difícil. Mas essa dificuldade não significa que a distinção não exista. E, se ela existe, então, surge a pergunta acerca da admissibilidade de discricionariedades epistêmicas. Em sua essência, isso é algo que diz respeito aos princípios formais.

IV – PRINCÍPIOS FORMAIS

A relação entre princípios materiais e princípios formais é uma das questões mais polêmicas da teoria dos princípios. A preparação para uma resposta a algumas objeções de alguns críticos exige, em primeiro lugar, que se deixe clara a posição da teoria dos princípios. Essa posição pode ser resumida na tese segundo a qual o problema da discricionariedade epistêmica ou cognitiva deve ser solucionado por meio de sopesamentos entre princípios formais e princípios materiais.⁷⁹

77. Aristóteles, *Nikomachische Ethik*, 1098a.

78. A esse respeito, cf. *BVerfGE* 96, 56 (63 e ss.).

79. Uma pesquisa exaustiva e instrutiva sobre esse tema pode ser encontrada em Marius Raabe, *Grundrechte und Erkenntnis*, Baden-Baden: Nomos, 1998.

1. *A discricionariedade epistêmica como resultado de sopesamentos*

A questão acerca da existência de uma discricionariedade epistêmica surge quando é incerta a cognição daquilo que é obrigatório, proibido ou facultado em virtude dos direitos fundamentais. A insegurança pode ter suas causas na insegurança das premissas empíricas ou normativas. Insegurança empírica pode se tornar um problema em qualquer fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais. Ela tem um papel especial nos exames da adequação e da necessidade. A decisão sobre produtos derivados de *cannabis* oferece um exemplo. Saber se o legislador pode proibir produtos derivados de *cannabis* é algo que depende essencialmente de se saber se a intervenção na liberdade constitucionalmente protegida, resultado dessa proibição, é adequada e necessária para diminuir os riscos associados a essa droga. Se a proibição penal não for adequada ou não for necessária para tanto, ela seria definitivamente proibida pela perspectiva do direito fundamental. Seria possível pensar, então, que o Tribunal Constitucional Federal só poderia admitir a intervenção no direito fundamental se a veracidade das suposições empíricas – das quais a adequação e a necessidade dependem – fosse sólida. Mas o Tribunal procede de outra forma. Ele não constata a veracidade das premissas empíricas pressupostas pelo legislador, mas apenas a sua incerteza: “Não estão presentes conhecimentos fundados cientificamente que decidam indubitavelmente em favor de um ou de outro caminho”.⁸⁰

Mesmo assim ele admite a intervenção no direito fundamental. Isso ocorre por meio do reconhecimento ao legislador de uma discricionariedade em relação à cognição dos fatos relevantes – ou seja, uma discricionariedade epistêmica de tipo empírico – e da inclusão, nessa discricionariedade cognitiva, das suposições empíricas que fundamentam a proibição de produtos derivados de *cannabis*.

Já uma discricionariedade epistêmica de tipo normativo, ou uma discricionariedade epistêmica normativa, está relacionada à incerteza acerca da melhor quantificação dos direitos fundamentais em jogo e ao reconhecimento em favor do legislador de uma área no interior da qual ele pode tomar decisões com base em suas próprias valorações.

80. BVerfGE 90, 145 (182-183).

Um exemplo é oferecido pela decisão do Tribunal Constitucional Federal sobre a proteção contra demissões, de 1998. Essa decisão tratou da possibilidade de isentar empresas com menos de cinco empregados do cumprimento das previsões jurídico-trabalhistas relativamente rígidas sobre proteção contra demissões e garantir a seus empregados apenas a proteção geral relativamente flexível do direito privado. Aqui, a liberdade profissional do empregador, enquanto um direito de defesa, garantida pelo art. 12, § 1º, da Constituição alemã, colide com o dever de proteção estatal em favor dos trabalhadores, também decorrente do art. 12, § 1º. O Tribunal Constitucional Federal exige uma otimização: “As posições de direitos fundamentais colidentes devem ser compreendidas em seu efeito recíproco e devem ser limitadas para que sejam eficazes ao máximo para todos os envolvidos”.⁸¹

Mas, neste ponto, o Tribunal reconhece ao legislador uma “ampla margem de conformação”, que engloba não apenas prognósticos empíricos, mas também “a avaliação do complexo de interesses, ou seja, a quantificação dos interesses contrapostos e a determinação da necessidade de sua proteção”.⁸²

Isso significa que a violação do dever de proteção aos trabalhadores só ocorre se os limites dessa discricionariedade forem extrapolados. O Tribunal nega a existência dessa extrapolação ao observar que “a proteção mínima exigida constitucionalmente” pode ser garantida ao trabalhador por meio das prescrições gerais do direito civil.⁸³ Para resolver uma colisão entre direitos fundamentais é possível ou garantir aquilo que é minimamente exigido pela constituição ou garantir mais que isso. Se a nenhuma das partes é garantido menos que o mínimo, então, a constituição não foi violada. No caso em questão, a garantia mínima da proteção não é fundamentada apenas por meio da oposição de um direito do empresário – “merecedor de proteção em grande medida” – em face do “importante interesse” do trabalhador,⁸⁴ o que apontaria na direção de um impasse estrutural, mas também por meio do fato de que os interesses do empresário foram con-

81. *BVerfGE* 97, 169 (176).

82. *Idem*.

83. *BVerfGE* 97, 169 (178).

84. *BVerfGE* 97, 169 (177).

siderados “*pelo legislador como especialmente dignos de proteção*”.⁸⁵ Essa referência à classificação feita pelo legislador indica uma discricionariedade cognitiva normativa.⁸⁶ Essa discricionariedade poderia também ser utilizada de forma contrária. Isso ocorreria se o legislador considerasse os interesses dos trabalhadores como dignos de proteção especial e incluísse as pequenas empresas na rígida proteção contra demissões. Se há uma discricionariedade, então, isso não seria inconstitucional, desde que a proteção à posição do empresário ficasse abaixo do mínimo. Isso define a outra face da discricionariedade.

Em razão de sua proximidade com a discricionariedade estrutural – perceptível na decisão que acaba de ser mencionada –, a discricionariedade epistêmica para o sopesamento suscita problemas especiais. Nesse aspecto, a discricionariedade epistêmica de tipo empírico tem uma estrutura mais simples. Ela será analisada em primeiro lugar.

A decisão sobre produtos derivados de *cannabis* faz com que fique claro, com toda agudeza, o principal problema de todo tipo de discricionariedade epistêmica. Se ao legislador é permitido fundamentar uma intervenção em um direito fundamental a partir de uma premissa que seja incerta, então, é possível que a esse direito não seja garantida a proteção devida – e ele seja, por isso, violado – nos casos em que a premissa que fundamenta a intervenção seja equivocada. Diante disso, pode-se afirmar que os direitos fundamentais ofereciam mais proteção se fosse negada uma discricionariedade cognitiva ao legislador.

A teoria dos princípios pode se alinhar quase que automaticamente a essas considerações gerais sobre a estrutura da discricionariedade cognitiva. Direitos fundamentais, compreendidos como princípios, exi-

85. BVerfGE 97, 169 (180) – sem grifos no original.

86. Seria possível ver nessa manifestação também uma indicação de uma discricionariedade para definir objetivos. A reserva de regulação do art. 12, § 1º, 2, da Constituição alemã não indica razões para intervenções. Com isso, e como demonstrado acima, ela permite também intervenções baseadas em objetivos cuja persecução não seja prescrita pela constituição. Entre eles estão também objetivos político-econômicos. A discricionariedade para definir objetivos não é, contudo, ilimitada. A decisão sobre seus limites é tomada por meio de sopesamentos. Neles, aparecem os problemas das discricionariedades estruturais e epistêmicas. Nesse sentido, é inevitável o contato entre a discricionariedade para definir objetivos e a discricionariedade epistêmica para sopesar. E a distinção entre ambas pode ser também difícil. Mas, como sempre, isso não é uma objeção contra essa distinção.

gem uma realização máxima diante das condições fáticas e jurídicas presentes. Reconhecer ao legislador uma discricionariedade cognitiva de tipo empírico significa a possibilidade de se admitir que, diante das possibilidades fáticas presentes, esses direitos não sejam realizados na extensão do que seria possível. Diante disso, o princípio de direito fundamental afetado negativamente exige, enquanto mandamento de otimização, que não seja reconhecida nenhuma discricionariedade cognitiva. Se esse fosse o único fator relevante, um direito fundamental só poderia ser restringido em virtude de premissas empíricas cuja veracidade fosse certa. Se essa veracidade não puder ser comprovada, seria autorizado partir apenas das premissas empíricas que forem mais vantajosas ao direito fundamental, que são aquelas sobre cuja base a intervenção ou a não-garantia de proteção não tem como ser justificada.⁸⁷

É exatamente esse o ponto no qual entra em jogo o princípio formal da competência decisória do legislador democraticamente legitimado.⁸⁸ Esse princípio é um princípio formal, porque ele não determina nenhum conteúdo, mas apenas diz quem deve definir conteúdos. Por isso, seria possível também denominá-lo “princípio procedimental”. Enquanto princípio procedimental, ele exige que as decisões relevantes para a sociedade devam ser tomadas pelo legislador democraticamente legitimado.⁸⁹ Decisões como a proibição ou a permissão de produtos derivados de *cannabis* são relevantes para a comunidade. Se a decisão sobre essa questão depende de avaliações empíricas, a competência decisória do legislador, exigida *prima facie* pelo princípio formal, inclui a competência para decidir sobre ela também nos casos de incerteza. Nesses termos, o princípio formal colide com o princípio material de direito fundamental. Este último exclui *prima facie* a competência do legislador para fundamentar decisões desvantajosas para o direito fundamental em premissas empíricas incertas; o primeiro requer *prima facie* exatamente essa competência.

Há duas soluções extremas para essa colisão, por trás das quais está, na verdade, a velha relação de tensão entre direitos fundamentais

87. Marius Raabe (*Grundrechte und Erkenntnis*, p. 228) fala, com precisão, de uma “exigência de caráter epistêmico no âmbito dos direitos fundamentais”. Seria possível também utilizar o conceito de otimização epistêmica.

88. Cf. Capítulo 9, II.3. Cf. também Capítulo 6, I.3.2.

89. Cf. Capítulo 3, II.3.1.

e democracia.⁹⁰ A primeira consiste em uma precedência absoluta do princípio material de direito fundamental em face do princípio formal nos casos de incerteza empírica. A consequência disso seria que o legislador, sempre que interviesse de alguma forma em um direito fundamental, somente poderia basear-se em premissas empíricas cuja veracidade fosse comprovada. Se existe um direito fundamental à liberdade geral de ação, quase todas as decisões do legislador intervêm em direitos fundamentais. Mas mesmo decisões que não se refiram a esse direito têm que ser avaliadas a partir dos direitos fundamentais. Assim, é muito difícil imaginar uma medida de direito econômico, do trabalho ou ambiental que não intervenha na liberdade profissional ou no direito de propriedade de alguém. Uma precedência absoluta do princípio material de direito fundamental teria, então, como consequência o fato de que o legislador poderia perseguir seus objetivos apenas com base em premissas empíricas comprovadamente verdadeiras. Mas conhecimentos empíricos dessa qualidade não estão praticamente nunca à disposição nos casos minimamente complexos. Diante disso, a precedência absoluta do princípio material de direito fundamental geraria uma total ou quase total incapacidade de ação do legislador em uma extensa área de sua competência. Essa não pode ser a intenção de uma constituição que, em primeiro lugar, cria um Poder Legislativo e, em segundo, que pretenda que ele seja legitimado democraticamente de forma direta. Precisa é, portanto, a formulação do Tribunal Constitucional Federal: "A incerteza sobre os efeitos de uma lei em um futuro incerto não pode excluir a competência do legislador para aprová-la, mesmo que ela tenha um alto impacto".⁹¹

Portanto, uma precedência absoluta do princípio material de direito fundamental em face do princípio da competência decisória do legislador deve ser refutada. Ela não seria compatível nem com o princípio da separação de poderes, nem com o princípio democrático.⁹²

A outra solução extrema também não é possível. Ela implicaria uma permissão para que o legislador baseie em prognósticos extrema-

90. Cf. Capítulo 9, I.5. Cf. também Robert Alexy, "Basic rights and democracy in Jürgen Habermas's procedural paradigm of the law", *Ratio Juris* 7 (1994), pp. 227 e ss.

91. *BVerfGE* 50, 290 (332).

92. Cf. *BVerfGE* 56, 54 (81).

mente incertos até mesmo intervenções muito intensas em direitos fundamentais. Enquanto no caso de precedência absoluta do princípio de direito fundamental a condição de veracidade comprovada reduziria o poder de ação do legislador a um mínimo, no caso de uma precedência absoluta do princípio formal o limite da incorreção comprovada ampliaria esse poder de ação ao máximo. Essa não pode ser a intenção de uma constituição que protege os direitos fundamentais. Também aqui é necessário concordar com o Tribunal Constitucional Federal: "De outro lado, a incerteza não pode ser suficiente, enquanto tal, para fundamentar uma discricionariedade para prognósticos por parte do legislador que seja infensa ao controle por parte da jurisdição constitucional".⁹³

Excluídos os extremos, somente as soluções intermediárias podem ser levadas em consideração. Estas podem ou exigir o mesmo grau de certeza para todas as intervenções em direitos fundamentais, ou diferentes graus de certeza, dependentes das diferentes intervenções. Apenas essa última alternativa é compatível com os direitos fundamentais enquanto princípios. Enquanto princípios, eles exigem que a certeza das premissas empíricas que fundamentam a intervenção seja tão maior quanto mais intensa for a intervenção. Isso conduz a uma segunda lei do sopesamento, com o seguinte conteúdo:

Quanto mais pesada for a intervenção em um direito fundamental, tanto maior terá que ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia.

Diferentemente do que ocorre com a primeira lei, essa segunda lei do sopesamento não está associada à importância material das razões que sustentam a intervenção, mas à sua qualidade epistêmica. Nesse sentido, a primeira lei do sopesamento pode ser chamada de "lei material do sopesamento", e a segunda, de "lei epistêmica do sopesamento".

É facilmente perceptível que os antecedentes de ambos os enunciados do tipo "quanto mais/tanto mais", presentes nas leis do sopesamento, são, em essência, iguais. É bem verdade que a lei material do sopesamento, na formulação mencionada anteriormente,⁹⁴ faz referência apenas à intensidade da intervenção (grau de não-satisfação ou de

93. *BVerfGE* 50, 290 (332).

94. Cf., neste "Posfácio", III.3.2.

afetação), enquanto a lei epistêmica do sopesamento, que acaba de ser formulada, faz menção ao peso da intervenção. Mas essas variações na formulação podem ser clarificadas e compreendidas com o auxílio da fórmula do peso. O conceito de peso de uma intervenção, até agora não analisado de forma sistemática, é composto por dois elementos da fórmula do peso: a intensidade da intervenção (IP_iC) e o peso abstrato do princípio envolvido (WP_A). Ele pode ser definido por meio do produto desses dois valores. Quando da análise da fórmula do peso foi demonstrado que os pesos abstratos podem ser cancelados quando forem iguais.⁹⁵ Sob essas condições, a parte relativa ao peso abstrato também pode ser retirada da formulação da lei epistêmica do sopesamento. O mesmo vale quando se pretende focar apenas a relação entre a intensidade da intervenção e a certeza das premissas que a sustentam. Nesse caso, a lei epistêmica do sopesamento tem o seguinte conteúdo:

Quanto mais intensa for a intervenção em um direito fundamental, tanto maior terá que ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia.

Tudo isso são apenas variações da mesma fórmula, as quais, sob diferentes circunstâncias, podem ser mais ou menos apropriadas, mas em nada alteram a identidade dos antecedentes nos enunciados.

A identidade entre os antecedentes dos enunciados tem grande importância sistemática. Ela expressa o fato de que os princípios materiais de direitos fundamentais envolvidos constituem um ponto de Arquimedes. Esse ponto de referência comum torna possível combinar elementos materiais e epistêmicos no âmbito das razões para a intervenção. Essa combinação ocorre com base na regra segundo a qual a importância concreta da satisfação do princípio colidente (WP_jC) por meio de uma medida legislativa M pode justificar cada vez menos a intensidade da intervenção em P_i , levada a cabo por M , à medida que diminui a certeza de que M de fato alcança a satisfação de P_j . Portanto, o peso concreto de um princípio ($GP_{i,j}C$) cresce na medida em que o grau de incerteza empírica no âmbito da realização do princípio colidente também cresce.

95. Idem.

Mas tudo isso pressupõe que faça sentido e seja procedente falar em graus de segurança ou certeza e graus de insegurança e incerteza das premissas empíricas do legislador. Com essa indagação surge o problema do uso de escalas também na parte epistêmica da lei do sopesamento.

Na decisão sobre co-gestão o Tribunal Constitucional Federal procurou diferenciar três níveis de intensidade de controle: um “controle intensificado de conteúdo”, um “controle de plausibilidade” e um “controle por evidência”.⁹⁶ Isso constitui um modelo triádico que apresenta grandes semelhanças formais com o modelo triádico material apresentado anteriormente, e que pode ser incorporado à fórmula do peso sem grandes problemas.⁹⁷ Esse modelo compartilha a grande plausibilidade intuitiva do escalonamento material em três níveis. Assim, dificilmente se pode duvidar de que no caso de uma intervenção de intensidade alta deve ser exigida uma grande certeza das premissas empíricas que a sustentam. A isso corresponde o “controle intensificado de conteúdo”, que o Tribunal Constitucional Federal realiza, por exemplo, no caso da pena de prisão perpétua.⁹⁸ Se tanto a intensidade da intervenção quanto o grau de importância alcançam o nível mais alto, então, uma certeza apenas mediana do lado do princípio colidente nunca será suficiente para justificar uma perda certa do lado do objeto da intervenção. Está-se diante de uma certeza média quando as premissas são plausíveis ou defensáveis. Quando, na decisão sobre *cannabis*, o

96. BVerfGE 50, 290 (333).

97. Para tanto, deve-se introduzir “S” como símbolo para a segurança das suposições empíricas que dizem respeito àquilo que as medidas em exame significam para a não-realização de P_i e para a realização de P_j no caso concreto. Isso pode ser simbolizado por “ SP_iC ” e “ SP_jC ”. Diante disso, a fórmula do peso pode ser expandida da seguinte forma:

$$GP_{i,j}C = \frac{IP_iC \cdot GP_iA \cdot SP_iC}{WP_jC \cdot GP_jA \cdot SP_jC}$$

Aos três níveis epistêmicos – certo ou garantido (g), sustentável ou plausível (p) e não evidentemente falso (e) – podem ser atribuídos 2⁰, 2¹ e 2² como valores de $\frac{SP_iC}{1}$ e $\frac{SP_jC}{1}$. É claro que aqui também é possível um refinamento da tríade.

98. BVerfGE 45, 187 (238).

Tribunal Constitucional Federal aceita como suficiente que as suposições empíricas do legislador sejam "plausíveis",⁹⁹ ele dá a entender, com isso, que, na sua concepção, a intervenção não tem uma intensidade máxima. O mesmo vale quando é suficiente que não seja evidente que as premissas empíricas sejam falsas. No modelo triádico simples esse é o menor nível de certeza.

Dessa forma, nos casos de discricionariedade epistêmica de tipo empírico é relativamente fácil de ser determinada a relação entre os princípios formais e materiais. As coisas são um pouco mais complicadas nos casos de discricionariedade epistêmica de tipo normativo. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com o conceito de discricionariedade normativa e está, em segundo lugar, associado à dificuldade na determinação da relação entre a discricionariedade para sopesar de tipo estrutural e a discricionariedade para sopesar de tipo epistêmico. Todas as formas de discricionariedade têm em comum o fato de que na área discricionária localiza-se aquilo que é facultado ao legislador e que o limite da discricionariedade é definido exatamente por aquilo que ao legislador é proibido ou obrigatório. Mas uma discricionariedade cognitiva é uma discricionariedade que decorre da incerteza na cognição daquilo que é obrigatório, proibido ou facultado em virtude dos direitos fundamentais. Reconhecer uma discricionariedade cognitiva ao legislador significa, portanto, conceder a ele a competência, em certa extensão – que é exatamente a extensão da discricionariedade cognitiva –, para determinar aquilo que a ele é obrigatório, proibido ou facultado em virtude dos direitos fundamentais. No caso da discricionariedade cognitiva empírica havia motivos plausíveis para tanto. Mas será que isso ocorre também no caso da discricionariedade cognitiva normativa?

Em um primeiro momento parece que uma discricionariedade cognitiva normativa para o legislador seria algo a ser rejeitado, porque ela diluiria os limites da discricionariedade estrutural e, com isso, a vinculação do legislador aos direitos fundamentais. Se em todos os casos fosse facultado ao legislador decidir, como juiz em causa própria, aquilo que os direitos fundamentais obrigam, proíbem ou facultam em relação a si mesmo, não seria mais possível falar em uma vinculação real – ou seja, controlável – aos direitos fundamentais. Os

99. BVerfGE 90, 145 (182).

direitos fundamentais não teriam nenhuma normatividade jurídica que pudesse ser levada a sério. Uma faculdade assim extensa, que equivaleria a uma discricionariedade cognitiva normativa ilimitada, está fora de discussão. Uma discricionariedade cognitiva só deve ser levada em consideração em casos de incerteza. Visto que existem, como já foi demonstrado, inúmeros casos nos quais é certo ou suficientemente certo como deve ser realizado o sopesamento, então, há inúmeros casos nos quais está excluída uma discricionariedade cognitiva.

Uma discricionariedade cognitiva normativa só pode existir – se é que pode – nos casos de incerteza normativa. Os casos mais importantes de incerteza normativa no âmbito dos direitos fundamentais são os casos de incerteza quanto ao sopesamento. Nesses casos, a questão decisiva é saber como deve ser definida a relação entre as discricionariedades estrutural e epistêmica para sopesar.

Como exemplo será usada mais uma vez a decisão do Tribunal Constitucional Federal sobre a proteção contra demissão. O fato de o Tribunal Constitucional Federal falar em uma “ampla margem de conformação” do legislador na “valoração do complexo de interesses” não significa necessariamente que se trata de uma discricionariedade normativa para sopesar. Isso vale também quando ele iguala a valoração do complexo de interesses à “quantificação dos interesses contrapostos” e à “determinação da necessidade de proteção”.¹⁰⁰ Isso tudo pode ser facilmente interpretado no sentido de um impasse estrutural no sopesamento. É necessário apenas que os interesses do empresário e do trabalhador sejam classificados como sendo de importância similar para se chegar à conclusão de que tanto a isenção de obediência das pequenas empresas às regras mais rígidas de proteção contra demissões quanto sua inclusão nessas regras estão inseridas na discricionariedade estrutural, ou seja, ambas são facultadas ao legislador. Isso pressupõe somente a aceitação de que, nesse caso, os direitos fundamentais admitem um escalonamento apenas rudimentar, de forma a criar um considerável impasse no sopesamento, ao qual corresponde uma discricionariedade estrutural equivalentemente ampla, que abarca tanto as medidas legislativas quanto uma abstenção em relação a elas. A “valoração do complexo de interesses” por meio do legislador

100. *BVerfGE* 97, 169 (176).

— incluindo-se aí a “quantificação” por ele realizada — não é, *per definitionem*, uma valoração e uma quantificação jurídicas no âmbito da discricionariedade estrutural, mas uma valoração e uma quantificação políticas. Seu resultado é juridicamente facultativo. Os princípios de direitos fundamentais podem constituir objetos de sopesamento na discricionariedade estrutural, mas, em razão do impasse estrutural, eles não podem determinar o sopesamento. A competência de controle do Tribunal Constitucional é, então, limitada, sem que seja necessária uma discricionariedade cognitiva do legislador, pois as competências do Tribunal terminam nos limites daquilo que é definitivamente devido.¹⁰¹

É de suma importância que o mesmo resultado também possa ser construído com o auxílio de uma discricionariedade para sopesar de tipo epistêmico-normativo. Os limites da discricionariedade estrutural para sopesar são, nesse caso, idênticos aos limites da discricionariedade para sopesar de tipo epistêmico-normativo. A diferença está somente na não-eliminação do elemento jurídico. Pelo contrário, a discricionariedade é formada justamente pelas diversas possibilidades jurídicas. De um lado, considera-se fundamentável e, portanto, possível que os direitos fundamentais tanto permitam — ou até mesmo obriguem — quanto proibam a extensão da proteção rígida contra demissões às pequenas empresas; de outro lado, considera-se impossível reconhecer qual dessas possibilidades pode ser mais bem fundamentada. Nessa situação, visto que há direitos fundamentais envolvidos em ambos os lados, há entre esses direitos um impasse epistêmico. É certo que cada um dos direitos fundamentais exige a solução mais vantajosa para si, mas nenhum deles têm, em razão do impasse, força para decidir a contenda. A situação substancial dos direitos fundamentais é, portanto, neutra. Nessa situação, os princípios materiais de direitos fundamentais não têm força para evitar que do princípio da competência decisória do legislador democraticamente legitimado decorra uma discricionariedade epistêmica para sopesar. Qualquer outra solução seria insustentável, em face da relação fundamental de tensão entre direitos fundamentais e democracia. Nesse sentido, é possível falar da existência de uma discricionariedade cognitiva também de tipo normativo.

101. Cf. Capítulo 9, IV.3.

2. A *discretionariedade epistêmica* e a *vinculação à constituição*

Se uma decisão pode ser tomada porque ela é abrangida por uma *discretionariedade epistêmica*, então, não se pode excluir a eventualidade de que essa decisão, embora possível, seja incorreta. As análises empíricas até então não realizadas ou os argumentos até então não levados em consideração podem tornar claro esse equívoco. Portanto, uma *discretionariedade epistêmica* está necessariamente associada ao problema da divergência entre aquilo que é de fato obrigado, proibido e facultado pelos direitos fundamentais e aquilo que por meio deles pode ser demonstrado como sendo obrigatório, proibido ou facultado.¹⁰² Com essa divergência entre aquilo que é, ou seja, o *ôntico*, e aquilo que pode ser constatado, ou seja, o *epistêmico*, a *discretionariedade cognitiva* parece conduzir a violações a direitos fundamentais não-constatáveis. A competência do legislador para, por meio de lei e em virtude de uma *discretionariedade epistêmica*, proibir algo que não pode ser proibido em razão dos direitos fundamentais parece corresponder não apenas a não-competência do Tribunal Constitucional para invalidar a proibição inconstitucional, mas também uma proibição constitucional para fazê-lo. Isso suscita a possibilidade de proibições de direitos fundamentais infensas a controles. A fundamentação de uma *discretionariedade epistêmica* com o auxílio de princípios formais parece conduzir inafastavelmente a uma divergência entre normas de ação – ou seja, normas que dizem o que é proibido, obrigatório e facultado ao legislador – e normas de controle – ou seja, normas nos termos das quais o Tribunal Constitucional controla o legislador.¹⁰³

A principal objeção aos princípios formais dirige-se contra essa divergência. Ela sustenta que a *discretionariedade epistêmica* criada pelos princípios formais é inconciliável com a vinculação do legislador aos direitos fundamentais, exigida pelo art. 1º, § 3º, da Constituição alemã,¹⁰⁴ e, de resto, com a vinculação do Legislativo à Constituição,

102. A esse respeito, cf. Marius Raabe, *Grundrechte und Erkenntnis*, pp. 147 e ss.

103. Cf. Matthias Jestaedt, *Grundrechtsentfaltung im Gesetz*, p. 259.

104. Arno Scherzberg, *Grundrechtsschutz und "Eingriffsintensität"*, pp. 175-176, e Martin Gellermann, *Grundrechte in einfachgesetzlichem Gewande*, Tübingen: Mohr, 2000, p. 71.

exigida pelo art. 20, § 3º.¹⁰⁵ A hierarquia jurídica seria relativizada por essa divergência.¹⁰⁶ A “espinha dorsal do ordenamento jurídico” seria submetida a um “processo de osteomalacia normativa”.¹⁰⁷ Em resumo: tudo seria tragado por um turbilhão incontrolável.

Para enfrentar essas objeções, é recomendável distinguir duas indagações. A primeira refere-se ao quanto de divergência os princípios formais criam. E a segunda, se essa divergência é, de fato, uma divergência real. A primeira indagação será analisada antes. Princípios formais teriam uma força máxima para a criação de divergências se, em primeiro lugar, eles fossem capazes de afastar direitos fundamentais e, em segundo lugar, se eles pudessem fazê-lo por completo. Scherzberg chega perto dessa idéia quando alega que o princípio formal da competência decisória do legislador criaria uma situação na qual “se abriria uma exceção à estrutura normativa fundamental que se postula” para os princípios em favor do próprio legislador. A natureza principiológica dos direitos fundamentais – “sua natureza de mandamentos de otimização” – seria transformada, “*ela mesma em ‘princípio’*”.¹⁰⁸ Scherzberg parece, com isso, querer dizer que, no caso de uma colisão, os princípios formais não apenas superariam os princípios materiais, como também lhes retirariam seu caráter de mandamento de otimização. Com isso, não restaria praticamente nada na esfera material.

Esse ponto de vista ignora que o princípio formal da competência decisória do legislador, considerado em si mesmo, não é suficiente para superar um princípio material de direito fundamental. Se isso não fosse assim, então, não seria impossível afirmar algo como: “A intervenção no direito fundamental é muito intensa, e não há a menor razão substancial que a justifique. Mesmo assim, ela é admissível, porque o legislador democraticamente legitimado tem um campo decisório mais amplo se ele puder decidir acerca dessa intervenção”. Se é sabido que uma intervenção muito intensa em um direito fundamental não é justificada por nenhuma razão substancial, então, nos termos da fórmula do peso, essa intervenção viola claramente o direito fundamental. Se generalizado, o enunciado mencionado anteriormente desembocaria

105. Cf. Matthias Jestaedt, *Grundrechtsentfaltung im Gesetz*, pp. 223 e ss.

106. Cf. Karl-E. Hain, *Die Grundsätze des Grundgesetzes*, p. 137.

107. Cf. Matthias Jestaedt, *Grundrechtsentfaltung im Gesetz*, p. 246.

108. Arno Scherzberg, *Grundrechtsschutz und “Eingriffsintensität”*, p. 175.

nesse outro enunciado: "Violações a direitos fundamentais são admissíveis porque o campo decisório do legislador é mais amplo se essas violações forem admissíveis". Esse enunciado tem um quê de absurdo. Isso decorre do fato de que ao princípio material de direito fundamental é contraposto apenas o princípio formal da competência decisória do legislador. Princípios formais procedimentais só podem superar princípios materiais de direitos fundamentais se conectados a outros princípios materiais. Isso pode ser chamado de "lei da conexão". A lei da conexão faz com que fique claro por que é fácil levar os princípios formais *ad absurdum* quando eles são contrapostos de forma isolada aos princípios materiais.

As coisas são bem diferentes no caso da incerteza cognitiva. A questão acerca de uma discricionariedade cognitiva normativa somente surge se os pesos dos princípios em colisão são incertos. Uma discricionariedade cognitiva empírica só está em discussão se as premissas empíricas que sustentam a intervenção não são seguras. Em ambos os casos os princípios formais têm apenas o papel de participar da repartição das competências decisórias nos casos de incertezas presentes na relação entre os princípios materiais. Assim que a incerteza desaparece, eles também saem de cena. Isso exclui a possibilidade de que, diante de uma violação a um direito fundamental, um tribunal constitucional sustente que a concepção jurídica concorrente do legislador deva ser respeitada por razões formais.¹⁰⁹

A admissibilidade de uma discricionariedade cognitiva empírica dificilmente pode ser contestada. Aquele que clama por sua completa eliminação praticamente exige a eliminação da capacidade de ação do legislador. É por essa razão que os críticos dos princípios formais quase não dão atenção a essa discricionariedade. Mas ela é um importante exemplo do papel central desses princípios. A discricionariedade cognitiva empírica demonstra que os princípios formais ameaçam os direitos fundamentais tão pouco quanto os princípios materiais colidentes. Da mesma que esses últimos são englobados pela lei material do sopesamento, os primeiros são englobados pela variante epistêmica dessa lei.

109. A esse respeito, cf. Jan-R. Sieckmann, *Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems*, Baden-Baden: Nomos, 1990, p. 163.

Semelhante é o caso da discricionariedade cognitiva normativa. É claro que um cético radical em relação ao sopesamento pode aqui afirmar que o âmbito da incerteza no sopesamento é idêntico ao âmbito do sopesamento em si, e que, por isso, se se concede ao legislador uma discricionariedade para sopesar nos casos de incerteza, nunca será possível lhe impor limites com base em um sopesamento. Isso restringiria ao extremo a força vinculante dos direitos fundamentais enquanto princípios. Mas contra essa idéia já se afirmou que avaliações racionais sobre intensidades de intervenções e graus de importância são possíveis, e, nesse sentido, que são possíveis também cognições racionais no âmbito do sopesamento.¹¹⁰ A isso é necessário apenas acrescentar que, à medida que aumenta a intensidade de uma intervenção em um direito fundamental, cresce também não só o seu poder de resistência substancial, mas também a possibilidade de cognição de diferenças graduais. À lei material da taxa marginal decrescente de substituição corresponde algo como uma lei epistêmica da taxa marginal crescente de discriminação. Nas coisas cotidianas muitas vezes não se sabe o quão intensa é uma intervenção. Mas quando se vai em direção ao núcleo aumenta a capacidade de diferenciação.

Portanto, o grau de divergência nos casos de admissibilidade de uma discricionariedade cognitiva é, em geral, limitado e controlável. Mas resta perguntar se a divergência é, enquanto tal, sustentável. Será que não seria sempre exigível uma convergência entre aquilo que é válido em virtude dos direitos fundamentais e aquilo que pode ser identificado como válido? Essa exigência não expressa nada mais que o postulado segundo o qual só se deve agir com base em uma situação ideal de cognição. Mas aquele que defende esse postulado no âmbito da ação tem que pagar um alto preço. No direito constitucional esse preço é a uma considerável incapacidade de ação do legislador. Constituições que garantem direitos fundamentais são tentativas de, ao mesmo tempo, organizar ações coletivas e assegurar direitos individuais. No caso dos direitos fundamentais esse duplo caráter pode ser percebido por meio da possibilidade de sua restrição por parte do legislador. Essa possibilidade de restrição dos direitos fundamentais positivados é parte de sua essência. À restrição material as discricionariedades cog-

110. Cf., neste "Posfácio", III.3.2.

nitivas acrescentam um limite epistêmico. Esse limite é requerido pela constituição como um todo, ou seja, por um argumento sistemático-constitucional. Isso faz com que, da perspectiva daquilo que a constituição como um todo exige, a divergência desapareça. A discricionariedade cognitiva integra-se ao direito fundamental. Ela é internalizada. Embora a divergência permaneça no princípio material de direito fundamental como um espinho,¹¹¹ esse espinho é um tributo que o ideal dos direitos fundamentais tem necessariamente que pagar em razão do ganho dificilmente superestimável decorrente de sua institucionalização no mundo tal como ele é.

111. Cf. Marius Raabe, *Grundrechte und Erkenntnis*, p. 171.